



التقرير السنوي لمحكمة التعقيب 2020

الكتاب	التقرير السنوي لمحكمة التعقيب 2020
ر.د.م.ك:	978-9938-20-00000000-3
	الطبعة الأولى
© حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لمجمع الأطرش للكتاب المختص  مجمع الأطرش النشر والتوزيع المختص LATRACH EDITION	

العنوان	95 شارع لندرة 1000 تونس
الهاتف	00216.71.241.123
البريد الإلكتروني	latrachsale@gmail.com
الموقع	www.latrach-edition.com



عملاً بأحكام الفصل 115 من الدستور أعدت
محكمة التعقيب تقريرها السنوي الثالث.

والله ولي التوفيق

وكيل الدولة العام

الرئيس الأول

فتحي عروم

المنصف الكسو

في التعريف بمحكمة التعقيب



الرئيس الأول السيد المنصف الكسور



وكيل الدولة العام السيد فتحي عروم

العنوان	شارع 9 أفريل 1019 تونس
الهاتف	71561970
الفاكس	71571178
موقع واب محكمة التعقيب:	www.cassation.tn
محكمة التعقيب: @	courdecassation@justice.tn
الرئيس الأول @	courdecassation.1president@justice.tn
وكيل الدولة العام @	courdecassation.procureurgeneral@justice.tn
كتابة المحكمة: @	courdecassation.greffe@justice.tn

لجنة إعداد التقرير السنوي 2020

- * السيد المنصف الكشو، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
- * السيد فتحي عروم، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب

الأعضاء

- مكتب الرئيس الأول،
- * السيد حاتم بن جماعة ، مستشار بمحكمة التعقيب
- * السيد بديع بن عباس، مستشار بمحكمة التعقيب

الفهرس

الكتاب الأول الكلمات الافتتاحية

- كلمة الرئيس الأول 29
- كلمة وكيل الدولة العام 35

الكتاب الثاني قرار في ذاكرة فقه قضاء 2019

- قرار في ذاكرة فقه قضاء 2019 39

الكتاب الثالث فقه القضاء

- I - فقه القضاء 79
- أ- قرارات الدوائر المجتمعة 79
- ب- قرارات الدوائر المجتمعة في المادة المدنية 79
- مرافعات مدنية وتجارية 79

- 79 مراقبة صحة التبليغ
- 82 الإقرار بأولوية المقر المختار على المقر الأصلي مسألة اجتهادية بحتة
- 83 مشاركة القاضي في الحكم الابتدائي ثم في القرار التعقيبي كمدّع عام
- 86 عدم التفطن إلى المؤيّدات الدّالة على توفّر الصّفة في الطّاعنة
- 88 عدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ المتعلقة بتبليغ مستندات الطعن
- 89 عدم التنصيص على رقم بطاقة تعريف متلقي التبليغ
- 91 عدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ المتعلقة بتبليغ مستندات الطعن
- التعريف بالهويّة لا يعني التنصيص بالمحضر على عدد بطاقة التعريف
- 94 الوطنيّة
- 95 الآراء القانونية ولو كانت تمثل آراء انفرادية لا تُعدّ من قبيل الخطأ البين
- عدم تبليغ مستندات الطعن إلى خلفاء المعقب ضده المتوفّي بعد تقديم
- 97 مطلب التعقيب
- ورود هويّة غير هوية الطاعن الصحيحة في طالع مستندات الطعن يُعدّ خطأ
- 100 ماديا
- 102 نيابة المحامي تنتهي بالطور الذي ناب فيه
- 104 تبليغ مستندات التعقيب بمكتب المحامي
- 105 تأويل القانون يخرج عن دائرة الغلط الواضح
- 106 تبليغ مستندات الطعن إلى محل مخابرة ثبت انقطاع العمل به
- 108 شروط تعهّد الدّوائر المجتمعة
- 115 مفهوم العذر الشرعي
- قرار إصلاح حجة الوفاة لا يقبل إلا دعوى الإبطال أمام المحكمة
- 118 الابتدائيّة

- مدني عام 122
- وكيل الشركة لا يعد قد عقد لنفسه إذا كانت الذات المعنوية ممثلة تمثيلاً
- صحيحاً بغيره 122
- وعد البيع المرتبط بخلاص باقي الثمن فيه على الحصول على قرض
- بنكي 127
- السبب الصحيح الذي ينفي عن الموعد له صفة المماطلة 130
- عيني 135
- صحة البيع الذي صدر فيه حكم لفائدة المتسوغ بحق الأولوية في الشراء 135
- مفهوم حسن النية في الرسوم العقارية 141
- تجاري 145
- مفهوم الأعمال التجارية التبعية - طبيعة اختصاص الدائرة التجارية 145
- تأمين 153
- طريقة احتساب التعويض عن الضرر المهني 153
- تمتع مالك العربة بالتعويض عندما يكون مرافقاً لسائقها 157
- التعويض عن مصاريف العلاج يكون حسب ما تمّ بذله فعلاً أم باعتماد
- التعريفات الإطارية؟ 160
- اجتماعي 165
- لا يجوز الاتفاق على قواعد مرجع النظر الترابي الواردة بمجلة الشغل .. 165
- قرارات الدوائر المجتمعة في المادة الجزائية 168
- إجراءات جزائية 168
- قبول الخطأ البين في المادة الجزائية - لا يتم تبليغ المستندات إلا لمن
- شملة الطعن 168

- الغفلة عن المقر الأصلي 170
- قبول الخطأ البين في المادة الجزائية - التبليغ على معنى الفقرة 2 من الفصل 8 من م.م.م. ت. لا يوجب الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ 174
- قبول الخطأ البين في المادة الجزائية - تحديد مناط الطعن من حيث الأطراف يُعدّ إجراء أساسيا 178
- علاقة الطعن المرفوع من المحامي بالطعن المرفوع من المتهم شخصا 181
- خلّو الملف من مستندات التعقيب لعدم إضافتها من كتابة المحكمة 183
- قبول الخطأ البين في المادة الجزائية - يوم العدّ لا يُعدّ 184
- سبق النّظر في الموضوع 187
- سبق النظر في الموضوع 190
- التنصيب المنسوب لممثل النيابة العمومية على ظهر الملف إشارة إلى تعقيب الحكم لا يُمثّل طعنا قانونيا صادرا عنه في ظلّ عدم تلقيه من كاتب المحكمة 198
- قبول الطعن بالخطأ البين في القرارات الجزائية - رفض التعقيب شكلا استنادا على وصل تسليم تضمّن خطأ ماديا 200
- بداية احتساب أجل تقديم مستندات الطعن والأثر المترتب عن عدم احترامه 203
- يجب أن يبلغ الاستدعاء بتسلم نسخة الحكم بصورة فعلية 205
- النيابة العمومية غير مُلزّمة بتبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده 207
- قبول الخطأ البين في المادة الجزائية - لا يتم تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلا لمن شملته عريضة الطعن 209
- مطلب القيام بالحق الشخصي المقدم في الطور الاستقرائي لا يتواصل إلى

-الطور الحكمي - جواز تقديم كل من المطلب والطلبات في تقرير	
موحد للمحكمة	211
-المانع المادي المعلق لمدة التقادم	214
-إثبات مخالفات الاتصالات - مدى وجوب إحالة جميع المحاضر	
المتعلقة بجرائم الاتصالات دون استثناء على الوزير المكلف بالاتصالات	217
ب-قرارات الدوائر	221
1 - شخصي	221
1 - 1 - مصاريف الولادة هي من المصاريف الضرورية التي تدخل في	
مفهوم النفقة	221
1 - 2 - ارتباط فرع النفقة حكما وترابيا بقضية الطلاق ينتهي بصدر حكم	
بات في شأنها	223
1 - 3 - واجب المساكنة - أفراد الزوجة بمحل مستقل	225
1 - 4 - حالة مدنية	226
1 - 4 - 1 - إصلاح رسم ولادة بموجب إذن على عريضة	226
1 - 4 - 2 - إجراءات الاعتراض على حجة الوفاة وإبطالها	227
2 - اجتماعي	229
2 - 1 - تمادي العامل على تقديم خدماته بعد انقضاء أجل العقد ينقلب به	
العقد إلى مدة غير محددة	229
2 - 2 - النزاعات المتعلقة بعقد التدريب تخضع لاختصاص دائرة الشغل	230
2 - 3 - مدى تمتع العامل المنتدب على حساب الحضائر بالتغطية	
الاجتماعية - تكليف محكمة الموضوع الصندوق الوطني للتقاعد	

والحيطة الاجتماعية باحتساب قيمة المساهمات الواجب دفعها.....	231
2- 4- عدم وجوبية المرور بمرحلة التسوية الصلحية في حوادث الشغل	233
2- 5- سقوط الدعوى في الضمان الاجتماعي.....	234
2- 5- 1- سقوط الدعوى في حوادث الشغل بعامين من تاريخ البرء	
النهائي.....	234
2- 5- 2- سقوط حق المطالبة بالمساهمات الاجتماعية.....	235
3- مدني عام.....	236
3- 1- في العقود.....	236
3- 1- 1- تكييف العقود.....	236
3- 1- 2- تدخل القاضي لوضع حد لعقد قبل حلول أجله.....	237
3- 2- البيع.....	239
3- 2- 1- بيع ملك الغير - حجية الجزائي على المدني.....	239
3- 2- 2- البائع المدلس - حجية الجزائي على المدني.....	240
3- 2- 3- عدم توفر الصفات التي التزم بها البائع عند البيع.....	241
3- 2- 4- استحالة التزام الواعد بإبرام عقد البيع النهائي بسبب استحقاق	
العقار منه.....	242
3- 2- 5- الرضا في عقد البيع - غياب إمضاء المشتري لا يبطل العقد ..	244
3- 3- الفسخ.....	245
3- 3- 1- تغيير العدد الرتبي لصانع العربة من العيوب الخفية الموجبة	
للفسخ.....	245
3- 4- البطلان المطلق.....	247
3- 4- 1- سقوط دعوى البطلان المطلق.....	247

248	3-4-2 - قطع أمد تقادم دعوى الإبطال المطلق
250	3-5-المسؤولية التعاقدية
250	3-5-1 - أجل سقوط المسؤولية التعاقدية
252	3-5-2 -مسؤولية المحامي المحال على عدم المباشرة
256	3-6 - سماع البيئة غير ضروري لإثبات مرض الموت
	3-7 - واجب التسليم في عقد الكراء يتعلق بتنفيذ الالتزام وليس بصحته
257	بما يُرتَّب فسخه وليس بطلانه
258	3-8 - تبني القانون التونسي للمعيار النفسي في تقدير أثر الإكراه
	3-9 - طبيعة عقد الكراء الرابط بين القباضة المالية وشخص من
260	أشخاص القانون الخاص
261	3-10- شروط الإثبات الإلكتروني -القوة الثبوتية للرسائل الإلكترونية .
262	3-11-الغلط الحسي
264	3-12 - القوة القاهرة وتأثيرها في تنفيذ الالتزام
264	3-12-1- أحداث الثورة ليست قوة القاهرة
266	3-12-2- فعل الأمير عاملا في إنهاء عقود مناوله بسبب قرار وزاري ..
268	3-12-3 -انقطاع التيار الكهربائي قوة القاهرة
268	3-13 - الدعوى البليانية
	3-13-1- شروط الدعوى البليانية - الأحكام الكاشفة والأحكام
268	المنشئة
	3-13-2 - الدعوى البوليانية - الدين مستحق الأداء وسابق في الوجود
272	على التصرف المطعون فيه

274	3-13-3- شروط الدعوى الوليانية
275	4 - قانون عقاري وتهيئة عمرانية
275	4- 1 - التجاوز عن حسن نية إلى جزء يسير بأرض ملاصقة
276	4- 2 - التعويض لمن تضررت حقوقه من حكم في التسجيل أو الترسيم
276	4- 2- 1 - شروط التعويض عن الضرر
278	4- 2- 2 - مفهوم الخطأ في دعوى التعويض عن تسجيل العقار
	4- 3 - دعوى كف الشغب على عقار مُسجل تهدف لحماية الانتفاع
279	وليس الحيازة
280	4- 4 - الدعاوى المتعلقة بالرّسوم العقارية
	4- 4- 1 - اختصاص النظر في دعاوى التشطيب والإبطال وإصلاح أخطاء
280	الرسوم العقارية والبحث في شرعيتها
288	4- 4- 2 - مفهوم حسن النية في مجلة الحقوق العينية
291	4- 5 - رفع مضرّة
	4- 5- 1 - إزالة هوائيات الإرسال والالتقاط بعقار - اختصاص حتمي
291	للقضاء العدلي
	4- 5- 2 - اختصاص القضاء الإداري للبت في مسؤولية الشركة
294	التونسية للكهرباء والغاز عن إنشاء أشغال بأرض الغير
296	4- 5- 3 - رفع مضرّة - ضرر مستقبلي على أرض بيضاء
298	4- 5- 4 - التناسب في إزالة المضرّة
298	4- 6 - تعريف الوكيل العقاري - استحقاق الأجرة والاتفاق حولها
301	5 - تجاري
301	5- 1 - ديون تجارية

- 5- 1- 1 - مفهوم العمل التجاري - الأعمال التجارية بالتبعية - انعقاد
 اختصاص الدائرة التجارية 301
- 5- 1- 2 - دعوى الرجوع على الملتزمين بالكميالة 303
- 5- 1- 3 - حرية الإثبات في المادة التجارية 304
- 5- 1- 4 - إثبات وجود النشاط التجاري 305
- 5- 2 - كراء تجاري 307
- 5- 2- 1 - مرجع نظر دعوى إبطال التنبيه بالخروج - توجيه التنبيه في بحر
 السنة التسويغية الثانية 307
- 5- 2- 2 - الأشغال التحسينية بالمكرى التجاري 309
- 5- 2- 3 - حق الانتفاع بحق تجديد الكراء ينتفع به التاجر وصاحب
 الصناعة وكذلك صاحب الحرفة على حدّ سواء - اكتساب الحلاق
 للأصل التجاري بقطع النظر عن بيعه للعطورات ومواد التجميل 310
- 5- 2- 4 - ممارسة حق العدول في الأجل يُعني من دفع غرامة الحرمان 312
- 5- 2- 5 - استرجاع المكري لإنجاز أشغال 313
- 5- 2- 6 - بطلان عقد كراء أصل تجاري 315
- 5- 2- 7 - انتفاع الحرفي بقانون 1977 شرط استغلاله لأصل تجاري ... 316
- 5- 2- 8 - المطالبة بغرم إضافي مقابل الزيادة قيمة المكري في المدة الفاصلة
 بين تاريخ الحكم بغرامة الحرمان وتاريخ عرضها 317
- 5- 2- 9 - إجراءات وآجال تعديل معين الكراء التجاري 318
- 5- 2- 10 - الزيادة الاتفاقية في الأكرية التجارية 320
- 5- 2- 11 - شهادة التقايد (الفصل 242 من م ت) تهم النظام العام وتتعلق
 بكل دعوى تتعلق بإنهاء الكراء 321

324	5-3- شركات تجارية.....
324	5-3-1- تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة الباطلة إلى شركة
324	مفاوضة فعلية
324	5-3-2- بطلان إحالة الشريك للحصص دون إعلام الشركاء في الشركة
326	ذات المسؤولية المحدودة ولو كان له صفة وكيل
327	5-3-3- شروط سحب الفلسة - أساس دعوى سحب الفلسة
329	5-3-4- مسؤولية الشركة عن الديون التي يُمضيها وكيلها
329	5-3-5- تطبيق القانون التجاري على المؤسسات التي تملك الدولة جزءا
330	من رأسمالها
331	5-3-6- مسؤولية مُسَيّر الشركة عند التملص من دفع دين عمومي
331	5-3-7- لا يمكن القيام ضد الوكيل شخصا في الدعاوى الموجهة
333	ضد الشركة
335	5-4- تجارة بحرية.....
335	5-4-1- التضامن بين ناقلي البضائع
335	5-4-2- تعريف وثيقة الشحن - عقد النقل البحري - مشاركة الإيجار -
337	الفوارق بينها والآثار.
340	5-5- ملكية صناعية
340	5-5-1- معايير تقدير تقليد علامة الصنع والتجارة والخدمات
340	-العلامة المشهورة.....
345	5-5-2- حماية العلامة الصناعية الأجنبية
348	5-5-3- حماية الرسوم والنماذج الصنّاعية
352	5-6- إجراءات جماعية

5-6-1 - الأحكام الوقتية في مادة الإنقاذ قابلة للاستئناف ولا يمكن تعقيها	352
5-6-2 - الحط من الدين في غياب موافقة الدائن - مبدأ المساواة بين الدائنين	354
5-6-3 - الطبيعة القانونية الخاصة بإجراءات التسوية القضائية	356
5-6-4 - ترسيم وترتيب الديون في التسوية القضائية	358
5-6-5 - إبطال برنامج إنقاذ	360
5-6-6 - التناسب بين الوضعية الاقتصادية للمؤسسة وحلول الإنقاذ المقترحة	361
5-7-7 - بنكي	362
5-7-1 - تكرر عمليات السحب المشبوهة يُرتّب مسؤولية البنك عن عدم أخذه الاحتياطات لحماية الحريف	362
6 - المسؤولية المدنية والتأمين	364
6-1 - المسؤولية المدنية	364
6-1-1 - أركان المسؤولية الشئئية	364
6-2 - التأمين	366
6-2-1 - ضرورة التنصيب بالعقد على جزاء سقوط الحق في الضمان في صورة عدم احترام أجل الإعلام بالحادث	366
6-2-2 - شرط سقوط الحق يجب أن يبرز بشكل ظاهر جدا	367
6-2-3 - الحكم مباشرة على المكلف العام بنزاعات الدولة - إجراء التسوية الصلحية وخيار المتضرر	368

- 6-2-4 - سائق العربة المجرورة بحيوان يُنزل منزلة المترجل 369
- 6-2-5 - مفهوم الخطأ الفادح 370
- 6-2-6 - استحقاق الفوائد بداية من تحقق الخطر المؤمن عليه 371
- 6-2-7 - انفصال نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور عن التداعي الجزائي 372
- 6-2-8 - سحب رخصة السياقة لا يعني أن السائق غير متحصل على الشهادات الصالحة لسياقة العربات 373
- 6-2-9 - تدخّل الصندوق في حالة عدم التأمين المطلق 374
- 6-2-10 - الخطر طبق الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين 377
- 7- إجراءات مدنية وتجارية 378
- 7-1 - الاعتراض على الأحكام في المادة المدنية 378
- 7-1-1 - شروط الاعتراض على الأحكام في المادة المدنية 378
- 7-1-2 - الاعتراض على حقوق الأطراف في النزاعات غير القابلة للقسمة 381
- 7-2 - سبق النظر في الموضوع 383
- 7-2-1 - سبق النظر في الموضوع يهم النظام العام 383
- 7-2-2 - سبق النظر يمسّ بالإجراءات الأساسية 384
- 7-2-3 - سبق النظر لا يتعلق إلا بالأحكام ولا يمتدّ إلى الأذن على المطالب 384
- 7-2-4 - سبق التعهد بقضية استعجالية لا يُعدّ سبق نظر في الموضوع .. 388
- 7-2-5 - مشاركة القاضي المراقب في المفاوضة وإبداء رأيه في برنامج الإنقاذ لا يُعدّ سبق نظر في الموضوع 389

- 7-3- أنواع المقر - تبليغ المؤيدات إلى المدعى عليه. 392
- 7-4- الإجراءات في دعوى كف الشغب 395
- 7-4-1- التجريح في الخبر يختلف عن القدح في اختصاصه - دعوى كف الشغب المرفوعة من الشريك 395
- 7-4-2- القيام بدعوى الاستحقاق يشترط الإذعان لحكم الحوز 398
- 7-5- الإجراءات أمام محكمة الاستئناف 399
- 7-5-1- إجراءات التبليغ - الخطأ في ذكر اليوم لا يبطل عريضة الاستدعاء 399
- 7-5-2- إجراءات وآجال الاستئناف 402
- 7-5-2-1- الأجل المستوجب لاستدعاء المستأنف ضده 402
- 7-5-2-2- استدعاء محامي المستأنف للحضور بالجلسة المعينة لها القضية بواسطة عدل تنفيذ 405
- 7-5-3- الإدخال في الطور الاستئنافي عند الطعن في حكم غير قابل للتجزئة 408
- 7-5-4- الدفع الشكلي على معنى الفصل 149 من م.م. ت. أمام محكمة الاستئناف 409
- 7-6- الصفة والأهلية في القيام 410
- 7-6-1- بطلان القيام ضد ميت - تعذر تصحيح الإجراء بإدخال الورثة 410
- 7-6-2- التمسك بالصفة في القيام بالطور التعقيبي إخلال بالنزاهة في التقاضي 414
- 7-7- إصلاح الأخطاء المادية 415
- 7-7-1- الخطأ المتسرب لهوية المستأنف بالحكم هو من الأخطاء

415	المادية القابلة للإصلاح
415	7-7-2 - شروط إصلاح الخطأ المادي
417	7-7-3 - الطعن في قرارات الشرح وتفسير الأحكام
	7-8 - إنذار المدين بالخلاص هو إجراء وجوبي سابق لاستصدار الأمر
419	بالدفع
420	7-9 - مفهوم نسخة الحكم المطعون فيه
421	7-10 - الاختصاص الحكمي والترابي
	7-10-1 - مقدار الكراء السنوي كمعيار لتحديد مرجع النظر الحكمي
	- الكراء لا نزاع فيه - على محكمة الموضوع واجب التحقق من
421	جدية المنازعة
422	7-10-2 - الاختصاص الحكمي في قضايا الكراء
424	7-10-3 - الاختصاص الحكمي للدوائر التجارية
424	7-11 - إثارة الدفوعات
	7-11-1 - لا تثار أمام محكمة التعقيب أوجه دفع جديدة إلا ما كان منها
424	ماسا بالنظام العام
425	7-11-2 - إثارة قرينة اتصال القضاء
426	7-12 - الاختصاص الحكمي في نزاعات المنشآت العمومية
	7-13 - الأهلية - الترشد ببلوغ سن الرشد - الطعن في حكم قابل للتجزئة
427	وفي حكم غير قابل للتجزئة
	7-14 - قرار النقض والإحالة الصادر عن الدوائر المجتمعة ملزم
429	لمحكمة الإحالة - زور مدني

- 7- 15 - مدى جواز التمسك أمام محكمة الإحالة بدفع من متعلقات النظام العام والإجراءات الأساسية خارج عن أسباب النقض. 431
- 7- 16 - عرض الملف على النيابة 433
- 7- 16 - 1 - وجوبية إجراء العرض على النيابة العمومية بالطور الأصلي. 433
- 7- 16 - 2 - تجاوز إجراء عرض الملف على النيابة طالما لم يترتب عنه ضرر 434
- 7- 17 - إثارة المحكمة لنص قانوني من تلقاء نفسها لا يخرق مبدأ الحياد 435
- 7- 18 - سلطة المحكمة في تقدير توجيه اليمين الحاسمة 436
- 7- 19 - التنفيذ 436
- 7- 19 - 1 - حجية محاضر عدول التنفيذ 436
- 7- 19 - 2 - أعمال التنفيذ تتصل بالنظام العام - التنفيذ لا يكون إلا بطلب من له حق التنفيذ 437
- 8 - العقل 441
- 8 - 1 - العقل العقارية 441
- 8 - 1 - 1 - بيع العقار بواسطة عدل تنفيذ لا يمكن فيه للمدين أن يقوم بدعوى معارضة 441
- 8 - 1 - 2 - دعوى إبطال حكم التثبيت مخوِّلة لمن تضرر من حكم التثبيت لأسباب لاحقة له 443
- 8 - 1 - 3 - الاختصاص الترابي في دعوى إبطال البتة 445
- 8 - 1 - 4 - عدم قابلية حكم التثبيت للطعن بالتعقيب 447
- 8 - 2 - العقلة التوقيفية 448
- 8 - 2 - 1 - مفهوم العذر الشرعي 448

- 8-2-2 - عدم تقديم تصريح يوجب اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر
ولا أقل 449
- 8-2-3 - عقلة توقيفية مؤسسة على فاتورة - البت في ثبوت الدين 450
- 8-2-4 - عدم أحقية المعقول تحت يده طرح دينه عند التصريح 452
- 9 - استعجالي 454
- 9-1 - التثبت من مدى قيام علاقة تسويقية فيه مساس بالأصل 454
- 9-2 - الأحكام الاستعجالية وقتية ولا تحوز قوة الأمر المقضي به 455
- 9-3 - سلطة القاضي في تقدير شروط التقاضي الاستعجالي 456
- 10 - تحكيم 458
- 10-1 - بداية احتساب أجل البت في الخصومة التحكيمية 458
- 10-2 - امتداد الشرط التحكيمي 459
- 10-2-1 - امتداد الشرط التحكيمي إلى الغير - التكييف - تدويل التحكيم 459
- 10-2-2 - امتداد الشرط التحكيمي في تجمّع الشركات - الاعتراف
بالحكم التحكيمي - نطاق الإكساء بالصبغة التنفيذية - الإجراءات الأساسية
في التحكيم 465
- 10-2-3 - تجمع الشركات وتحملها لدين موضوع قرار تحكيمي 475
- 10-3 - الأثر السلبي للشرط التحكيمي 479
- 10-3-1 - الأثر السلبي للشرط التحكيمي المضمّن بوثيقة الشحن سند عقد
النقل البحري - حجية وثيقة الشحن 479
- 10-3-2 - الأثر السلبي للشرط التحكيمي - إخراج النزاع عن أنظار
القضاء الرسمي - البت في الاختصاص مسألة أولية 481
- 11 - قانون دولي خاص 483

11-1 - محكمة الضرورة في صورة استحالة ممارسة الحق في	
التقاضي	483
11-2 - دعاوى أداء الديون ليست من الدعاوى المُتعلّقة بالتركة في	
مفهوم القانون الدولي الخاص	486
11-3 - طبيعة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية -الاختصاص	
الممكن في القانون الدولي الخاص -الاختصاص الدولي في عقود التوزيع	489
12 - قانون جزائي وإجراءات جزائية	494
1-12 - قانون جزائي	494
21-1-1 - إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة	494
12-1-2 - الجريمة المثارة - أعمال الوساطة في جرائم المخدرات هي	
المشاركة طبق المجلة الجزائية	495
12-1-3 - القصد الجنائي الخاص في جريمة القتل	498
12-1-4 - يجب أن يكون الحكم مكثفيا بذاته ولا يضطر من يطّلع عليه	
إلى الاعتماد على أية وثيقة أخرى خارجة عنه لفهم النزاع ووجه الفصل	
فيه	500
12-1-5 - الأمر الطارئ الذي ينفي الركن القصدي للجريمة	501
12-1-6 - الزوج قبل فكّ عصمة الزواج السابق	502
12-1-7 - التحريض على التكفير أو الدعوة إليه	503
12-2 - إجراءات جزائية	504
12-2-1 - محكمة الإحالة غير مُقيّدة بمناط النقض إذا تعلق بمسائل	
واقعية	504

12-2-2- تأخذ الأحكام وصفها الصحيح من الواقع والقانون وليس من وصف المحكمة.. 506

21-2-3- طبيعة قرارات الحفظ الصادرة عن أعضاء النيابة العمومية.. 507

12-2-4- استبعاده الصّح مع الإدارة دون السعي في الوقوف على حقيقته -

رفض الاعتراض شكلا لسقوط العقاب بمرور الزمن..... 509

12-2-5- القيام على المسؤولية الخاصة - اتصال القضاء بالوصف

القانوني للأفعال 511

12-2-6- عدم إمضاء النيابة العمومية أمام كاتب المحكمة على مطلب

استئنافه يجعل طعنه مرفوضا شكلا ولا يصحّحه إمضاؤه على ظهر ملف

القضية أو بطرة محضر الجلسة 512

12-2-7- عدم جواز قبول القيام بالحق الشخصي عند تعهد قلم التحقيق

بموجب الفصل 31 من م.إ.ج..... 514

12-2-8- تعويض قاضي التحقيق المتعهد بغيره من القضاة في حالة الضرورة

أو الغياب أو التعذر يجب أن يكون بقرار من رئيس المحكمة..... 516

12-2-9- ضم العقاب لا يشترط التعليل 518

II - مختارات من طلبات الادعاء العام..... 519

- طلبات الإدعاء العام في القضية عدد 42979 - إجراءات مدنية

الإختصاص الحكمي في قضايا إبطال العقود 519

- طلبات الإدعاء العام في القضية عدد 42913 - مدني

حجية الجزائي على المدني 525

- طلبات الإدعاء العام في القضية عدد 55210 - مرور

المرافق وتعدد الوسائل المشاركة في الحادث 529

- طلبات الإدعاء العام في القضية عدد 425 - عقاري	
تعقيب حكم عقاري	533
- طلبات الإدعاء العام في القضية عدد 94564 - 94861 - 94887 - 94898 -	
قانون جزائي	
تدليس عملة أجنبية	535
- طلبات الإدعاء العام في القضية عدد 01201 - تعديل بين الحكام	
تحديد الاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية	537
- طلبات الإدعاء العام في القضية عدد 424 - خطأ بين	
التبليغ بمقر المحامي	540
- طلبات الإدعاء العام في القضية 92431 92569 92713 92785 -	
قانون جزائي مفهوم العصابة	542

الكتاب الرابع

معطيات إحصائية

- النشاط العام لمحكمة التعقيب حسب السنوات من 2013 إلى	
2019	546
- تطور النشاط القضائي الوارد على محكمة التعقيب والمفصول حسب	
المواد	579



الكتاب الأول

الكلمات الافتتاحية

كلمة الرئيس الأول

منصف الكشور

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

كلمة وكيل الدولة العام

الحمد لله وحده

بسم الله الرحمن الرحيم

فتحي غروم

وكيل الدولة العام لدى محكمة العقيب



الكتاب الثاني

قرار في ذاكرة فقه قضاء 2020

قرار في ذاكرة فقه قضاء 2020

مدني

الجمهورية التونسية

وزارة العدل

محكمة التعقيب

ع 56171.2017 عدد القضية

تاريخه : 12 فيفري 2020

أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 / 10 / 2017 من الأستاذة «فا. الش.» المحامية لدى التعقيب

نيابة عن :

«ف. رو. ان. قو.» «F. Ro. An. Go.» بوصفه مولى على تركة المرحوم «جا. ب. ما. ري.» Legataire Universel والمعين محل مخابراته بمكتب محاميته الأستاذة «فا. الش.» الكائن

ضد :

1 - «ك. الق.» المعين محل مخابراته بمكتب محاميته الأستاذة «ح. بن ح.» الكائن ب..... بموجب محضر تعيين محل مخابرة عدد 9351 المؤرخ في 05 / 08 / 2010 تنوبه لدى هذا الطور .

2 - «س. الق.» القاطن ب..... ينوبه الأستاذان «الح. الو.» و«و. بو.» .

3 - «ص. الق.»، القاطن ب.... تنوبه الأستاذة «ح. بن ح.» .

4 - «يا. الق.» القاطن ب..... تنوبه الأستاذة «س. كا. ر.» .

5 - «الن. الع.» لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مقره ب.....

6 - «ب. الد. العي.» بوصفه مصفيا قضائيا لتركة المرحومة «ز. الق.» مقره

طعناني القرار الاستئنافي المدني عدد 86401 الصادر بتاريخ 29 / 3 / 2017 عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي بقبول الاستئناف الاصيلي والاستئنافات العرضية شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالقضاء بعدم سماع الدعوى وبتخطية الطاعن بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وتغريمه لفائدة المستأنف ضدهما «ك.» و«ص. الق.» بأربعمائة دينار (400,000د) سوية بينهما لفائدة المستأنف ضده «س. الق.» بنفس المبلغ لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة معدلة.

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهم وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى بقية الوثائق الواجب تقديمها حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م.

وبعد الاطلاع على مذكري الرد على تلك المستندات المقدمة من الأستاذة «بن ح.» نيابة عن المعقب ضدهما «ك.» و«ص. ق.» ومن الأستاذ «الو.» نيابة عن المعقب ضده «س. الق.» والراميتين إلى طلب رفض مطلب التعقيب أصلا. وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية إلى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:
من حيث الشكل :

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا جميع أوضاعه وصيغته القانونية مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية .

من حيث الأصل :

حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الأصل «ج.ب. ما. ري.» لدى المحكمة الابتدائية بتونس عارضا بواسطة نائبه ان زوجته «ز. الق.» ولدت بتونس في 24 جوان 1918 .

وتم التصريح بولادتها لدى ضابط الحالة المدنية بتونس كيفما يتأكد ذلك من مضمون ولادتها التونسي واستقرت منذ زواجها الاول بالمدعي الفرنسي الجنسية بفرنسا ولم تكن تأت إلى تونس الا لقضاء عطلتها وانه واثناء قضائها لعطلة آخر سنة 2009 بتونس اصيبت بجلطة توفيت على اثرها في 13 / 01 / 2010 كما

يتأكد من مضمون وفاتها عدد 287/2010 وانه وبمناسبة تصفية مكاسبها بتونس وخلاص معالم نقلها طلبت ادارة الجباية من المدعي اقامة حجة وفاة تونسية للمرحومة «ز. الق.» «ظنا من انها تونسية الجنسية وقد تولى المدعي خطأ اقامة حجة وفاة تونسية لزوجته بتاريخ 04 ماي 2010 لدى قاضي ناحية تونس والحال ان حجة الوفاة التونسية لا يمكن اقامتها الا لحاملي الجنسية التونسية نظر الخضوع الاجانب من حيث احوالهم الشخصية وميراثهم لقانون الدولة التي يحملون جنسيتها وان المرحومة «ز. الق.» بالرغم من ولادتها ووفاتها بالبلاد التونسية فإنها لم تكن حاملة للجنسية التونسية بل كانت فرنسية الجنسية كما سيأتي بيانه :

1 - في ثبوت اكتساب المرحومة «ز. الق.» الجنسية الفرنسية بموجب المفعول الجماعي لأمر التجنس بالجنسية الفرنسية الصادر لفائدة والدها من قبل سلطة الحماية الفرنسية :

قولا انه بموجب امر صادر عن سلطة الحماية الفرنسية في 21 ديسمبر 1922 تجنس والد المرحومة «ز. الق.» بالجنسية الفرنسية وتم سحب الجنسية الفرنسية على ابنته القاصرة المرحومة «ز. الق.» المولودة في 24 جوان 1924 بموجب المفعول الجماعي لأمر التجنس بالجنسية الفرنسية Effet collectif du Décret de naturalisation الصادر لفائدة والدها من قبل سلطة الحماية الفرنسية كما يتأكد ذلك من شهادة الجنسية المسلمة لها من القاضي الفرنسي في 29 افريل 1986 .

وبناء على هذا الأمر تم ترسيم ولادة المرحومة «ز. الق.» بدفتر الحالة المدنية الفرنسي واقامة رسم ولادة فرنسي لها كما يتأكد ذلك من مضمون ولادتها الفرنسي .

ولم تتقدم المرحومة «ز. الق.» عند بلوغها سن الرشد بمطلب قصد اعفائها من الجنسية الفرنسية كما يتأكد ذلك من شهادة الجنسية المسلمة لها من القاضي الفرنسي والمشار إليها أعلاه بل واصلت طيلة حياتها التعامل والتمسك بجنسيتها الفرنسية كما يتأكد ذلك من عقدي زواجهما وبطاقة تعريفها وجوازات سفرها وتصاريحها الجبائية .

ولا وجود في الأوراق الشخصية للمرحومة «ز. الق.» ما يفيد انها كانت حاملة للجنسية التونسية أيضا.

وان ثبوت حملها للجنسية الفرنسية دون الجنسية التونسية بالرغم من ولادتها ووفاتها بتونس يتعزز بالرجوع إلى أحكام مجلة الجنسية التونسية المنطبقة في تاريخ استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي.

2 - في ثبوت فقدان المرحومة «ز. الق.» الجنسية التونسية بمفعول القانون بعد صدور مجلة الجنسية التونسية الحديثة:

فقد جاء بالفصل 1 فقرة 2 من مجلة الجنسية التونسية الصادرة في 26 جانفي 1957 أي ابان استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي ان «الجنسية.... تفقد بمفعول القانون أو بموجب قرار من السلط العمومية يتخذ حسب الشروط المعينة بالقانون.»

ونص الفصل 30 من هذه المجلة انه «يفقد التونسي الرشد جنسيته التونسية اذا ما تحصل بمحض اختياره على جنسية اجنبية...»

وتكون زوجة المدعي المرحومة «ز. الق.» التي خيرت الابقاء على جنسيتها الفرنسية بعد دخول قانون الجنسية التونسي الحديث حيز التنفيذ قد فقدت جنسيتها التونسية بمفعول دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وطالما لم تقم زوجة المدعي بتصريح كتابي في تاريخ دخول قانون الجنسية التونسي حيز التنفيذ للتخلي عن جنسيتها الفرنسية التي اكتسبتها بموجب المفعول الجماعي لأمر تجنس والدها واختارت الابقاء عليها تكون قد فقدت جنسيتها التونسية بمفعول القانون.

وان الفصل 30 جديد من مجلة الجنسية الصادر بموجب القانون المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 والذي نص انه «لا يمكن للتونسي ان يفقد الجنسية التونسية الا بأمر» لا يمكن ان ينطبق على زوجة المدعي المرحومة «ز. الق.» التي لم تكن في تاريخ صدوره تونسية وانما فرنسية.

وتكون زوجة المدعي والحالة ما ذكر قد فقدت جنسيتها التونسية بمفعول دخول مجلة الجنسية التونسية الصادر ابان استقلال البلاد حيز التنفيذ بما لا يمكن معه اعتبارها تونسية .

3 - بطلان حجة المرحومة «ز. الق.» التي اقامها قاضي ناحية تونس بتاريخ 14 ماي 2010 :

فقد نص الفصل 39 من مجلة القانون الدولي الخاص «ان الاحوال الشخصية للمعني بالأمر تخضع لقانونه الشخصي» وبالتالي فان كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية لزوجة المدعي المرحومة «ز. الق.» من حيث صحة زواجها بهذا الاخير ونظام الاموال بينها وبين المدعي والهبات والموارث والوصايا وغير ذلك من التصرفات بموجب الوفاة فانه يخضع لقانون البلد الذي تحمل جنسيته في تاريخ وفاتها وهو القانون الفرنسي.

وانه عند اقامة حجة الوفاة يتولى قاضي الناحية تطبيق قانون الارث التونسي مما لا يمكن اقامة حجة وفاة تونسية في خصوص اجنبي لمخالفة ذلك الاجراء الفصل 39 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي اخضع الاجانب لقانونهم الوطني وكذلك الفصل 54 من نفس المجلة الذي اخضع «الميراث لقانون الدولة التي يحمل المتوفي جنسيتها عند وفاته أو لقانون آخر مقرر له...»

وطلب تأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام الفصل 30 من القانون الدولي الخاص اعتبار زوجة المدعي في الأصل المرحومة «ز. الق.» حاملة للجنسية الفرنسية دون غيرها ما لفقدانها الجنسية التونسية بمفعول القانون وعلى هذا الأساس الحكم ببطلان حجة وفاتها التونسية التي اقامها السيد قاضي ناحية تونس بتاريخ 11 ماي 2010 لمخالفتها الفصلين 39 و54 من مجلة القانون الدولي الخاص.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 36158 بتاريخ 04 ماي 2015 والقاضي ابتدائيا برفض الدعوى الاصلية وقبول الدعوى المعارضة شكلا وفي الأصل بتغريم المدعي لفائدة المدعى عليهم بمبلغ (250,000د) لقاء اتعاب التقاضي واجور الدفاع وحمل المصاريف القانونية على المدعي .

فاستأنفه المدعي في الأصل .

وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها المطعون فيه المضمن نصه أعلاه والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالقضاء بعدم

سماع الدعوى بناء على ثبوت حمل مورثة المستأنف ضدهم للجنسية المزدوجة الفرنسية والتونسية وعدم توصل المستأنف لإثبات فقدان المورثة المذكورة لجنسيتها التونسية.

فتعقبه الطاعن بوصفه مولى على تركة المدعي في الأصل بواسطة نائبه الذي طلب صلب مستندات طعنه نقضه بناء على ما يلي :

المطعن الاول المستمد من خرق أحكام الأمر المؤرخ في 27/01/1883 المتعلق بتحديد ابتداء العمل بالقوانين :

قولا بان محكمة القرار المنتقد اعتبرت ان القوانين اللاحقة المنظمة للجنسية لا يمكن ان يكون لها تأثير على جنسية الشخص الاصلية الا انه وخلافا لذلك فان جنسية الشخص لا يمكن ان يكون حقا مكتسبا طيلة حياته بل هي خاضعة للقوانين المتتالية المنظمة للجنسية التونسية والتي تطبق على الاشخاص الحاملين لها بصورة الية بمجرد صدورهما وهي قوانين لم تحدد تاريخ ابتداء العمل بها مما يستوجب حسب منشور كاتب الدولة للعدل المؤرخ في 16 ماي 1963 تطبيق قواعد القانون العام الواردة بأمر 27 جانفي 1883 المنقح بأمر 13 سبتمبر 1956 والقاضية بان القوانين الجديدة تدخل حيز التطبيق بتونس بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للبلاد التونسية .» ويستخلص من هذه القاعدة العامة :

-إن قوانين الجنسية لها مفعولا حينيا - Effet immédiat de la loi sur la nationalité مما يؤكد ان الجنسية تحدد بالرجوع إلى قانون الجنسية المنطبق في ذلك التاريخ.

-ان قوانين الجنسية لا تطبق بصورة رجعية La non rétroactivité de la loi sur la nationalité وعملا بمبدأ المفعول الحيني للقوانين :

فان جنسية المرحومة «ز. الق.» تحدد بالرجوع إلى قانون الجنسية المنطبق في تاريخ ولادتها وفقدانها أو عدم فقدانها لجنسيتها الاصلية أي الجنسية تحدد بالرجوع للقانون المنظم للجنسية في تاريخ حصول الواقعة التي سيكون لها تأثير على جنسيتها الاصلية وهي واقعة اكتسابها للجنسية الفرنسية عن محض ارادتها أي في تاريخ بلوغها سن الرشد والموافق لسنة 1939 وذلك بعدم اعراضها في

ذلك التاريخ عن الجنسية الفرنسية والحال ان الأمر المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 المنظم للجنسية التونسية في تاريخ بلوغها سن الرشد كان يمنع الجمع بين الجنسية التونسية والجنسية الفرنسية.

وعملا بمبدأ عدم رجعية القوانين :

فانه لا يمكن اعتبار التونسي المتجنس بالجنسية الفرنسية قد فقد جنسيته الاصلية الا من تاريخ ثبوت اكتسابه أو احتفاظه بالجنسية الفرنسية عن محض ارادته أي بالنسبة للمرحومة «ز. الق.» من تاريخ بلوغها سن الرشد أو اعراضها في ذلك التاريخ عن جنسيتها الفرنسية.

كما لا يمكن ان تعيد القوانين اللاحقة المنظمة للجنسية التونسية والتي تجيز ازدواجية الجنسية للشخص الذي فقد جنسيته التونسية الاصلية بموجب قوانين سابقة..

وانه ولما اعتبرت محكمة القرار المعقب ان القوانين اللاحقة المنظمة للجنسية لا يمكن ان يكون لها تأثير على جنسية الشخص الاصلية تكون قد اسست قرارها على خرق لقاعدتين أساسيتين لتطبيق القوانين وهي مبدأ المفعول الحيني للقوانين ومبدأ عدم رجعية القوانين اللذان كرسهما الأمر المؤرخ في 27 جانفي 1883 المتعلق بتحديد ابتداء العمل بالقوانين مما يتجه نقض القرار المعقب من هذا الأساس .

المطعن الثاني في سوء تطبيق القرار المعقب للقوانين المتوالية المنظمة للجنسية التونسية والتي تحجر الجمع بين الجنسية التونسية والجنسية الفرنسية:

قولا وان كانت المرحومة «ز. الق.» قد اكتسبت الجنسية الفرنسية دون ارادتها عندما كانت قاصرة وذلك بموجب المفعول الجماعي لأمر تجنس والديها الصادر في 21 ديسمبر 1922 فان عدم اعراضها عن هذه الجنسية عند بلوغها سن الرشد والمحافظة على هذه الجنسية طيلة حياتها يصبح معه احتفاظها بالجنسية الفرنسية مبني على ارادة شخصية مما يجعل تمسك القرار المعقب بان بقاء المرحومة «ز. الق.» على جنسيتها الفرنسية لم يكن عن ارادة شخصية وانما نتيجة المفعول الجماعي لأمر تجنس والديها لا يستقيم واقعا ولا قانونا.

وانه ومنذ ان بلغت المرحومة «ز. الق.» سن الرشد وقررت عدم التخلي عن جنسيتها الفرنسية عن محض ارادتها فإنها اصبحت خاضعة للتحجير الذي سنته القوانين المنظمة للجنسية التونسية في تلك الفترة والمتعلق بعدم الجمع بين الجنسية التونسية والفرنسية وهي على التوالي :

-الأمر العلي المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 :

+نص هذا الأمر ان «كل شخص ولد بتراب مملكتنا وكان احد ابويه مولودا به فهو تونسي الا الفرنسيون...» ومعنى ذلك ان كل شخص مولود بتونس من ابوين يكون واحدا منهما مولود بتونس يعتبر تونسيا الا من كان حاملا للجنسية الفرنسية كجنسية اصلية أو بموجب التجنس وبالتالي يتأكد من هذا الفصل ان في تاريخ اكتساب المرحومة «ز. الق.» الجنسية الفرنسية عن محض ارادتها أي عند بلوغها سن الرشد خلال سنة 1939 كان القانون التونسي يجيز للتونسيين الجمع بين الجنسية التونسية وكل الجنسيات الاخرى ما عدى الجنسية الفرنسية التي باكتسابها يفقد المتجنس بموجب القانون أي اليا جنسيته التونسية .

+ان الأمر المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 المنظم للجنسية التونسية في تاريخ بلوغ المرحومة «ز. الق.» سن الرشد أي في تاريخ اكتسابها للجنسية الفرنسية عن محض ارادتها قد حجر على التونسيين الجمع بين الجنسية التونسية والفرنسية فلا يعتبر هذا الأمر التونسيون المولودين بتونس والذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية باقين على جنسيتهم التونسية باعتبار ان فقدان الجنسية يمكن ان يكون اليا بموجب دخول القانون الذي يمنع ازدواجية الجنسية حيز التنفيذ.

+ان الأمر العلي المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 لم يستوجب اتخاذ أي اجراء من قبل الادارة التونسية لتحرير التونسي المتجنس بالجنسية الفرنسية عن محض ارادته من تابعيته للدولة التونسية وهو الشأن بالنسبة للتونسيين اللذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية عندما كانوا قاصرين ولم يعرضوا عنها عند بلوغهم سن الرشد والدليل على ذلك انه يصبح بموجب امر تجنسه بالجنسية الفرنسية تابع للمحاكم العدلية الفرنسية وخاضعا للقوانين الفرنسية في خصوص احواله الشخصية وحالته المدنية ويخرج عن سلطة المحاكم الشرعية التابعة للدولة التونسية بل يمنع حتى من الدفن بالمقابر التونسية.

وحيث وعملا بأحكام الفصل المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 تكون زوجة مورث المعقب المرحومة «ز. الق.» قد فقدت جنسيتها التونسية بعدم اعراضها عن الجنسية الفرنسية عند بلوغها سن الرشد وذلك دون حاجة إلى الادلاء بوسائل اثبات أخرى لم ينطق بها هذا القانون مما يؤكد ان القرار المعقب قد انبنى على مخالفة صريحة لمقتضيات هذا الأمر وسوء تطبيق له مما يتجه نقضه من هذه الناحية.

-الأمر الفرنسي المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 الذي تم اشهاره بالرائد الرسمي التونسي :

وانه وفي نفس التاريخ الذي صدر فيه الأمر العلي المشار إليه أعلاه عن الحكومة التونسية صدر كذلك امرا عن الحكومة الفرنسية تم اشهاره بالرائد الرسمي التونسي يتعلق بالجنسية الفرنسية وهو ما يؤكد تطبيقه بالبلاد التونسية جاء فيه «يعتبر فرنسي كل شخص ولد بالبلاد التونسية من ابوين خاضعين للقضاء الفرنسي.....»

«Est français tout individu né dans la Régence de Tunis de parents dont l'un est justiciable au titre étranger des tribunaux français.... Pourvu que sa filiation soit établi...avant l'âge de 21 ans...celui-ci peut, entre sa 21 et sa 22 année, déclarer qu'il renonce à sa qualité de français ».

هذا ان المرحومة «ز. الق.» لم تعرض عن جنسيتها الفرنسية عند بلوغها سن الرشد كما يتأكد من شهادة جنسيتها الفرنسية المضافة بملف القضية وهو ما تكون معه عملا بهذين الامرين التونسي والفرنسي الصادرين في 8 نوفمبر 1921 بالرائد الرسمي التونسي قد فقدت جنسيتها التونسية.

ويتبين مما تقدم ان ما ذهب إليه القرار المعقب من ان اكتساب المرحومة «ز. الق.» للجنسية الفرنسية لم يكن عن محض ارادتها وانه لا شيء بملف القضية يفيد تخليها عن الجنسية التونسية أو فقدانها لها مبنى على سوء فهم وتطبيق لأحكام هذين الامرين مما يتجه نقض القرار المعقب من هذه الناحية.

-الاتفاقية الثنائية التونسية الفرنسية المتعلقة بوضعية الاشخاص المؤرخة في 3 جوان 1955 والمنشورة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 6 سبتمبر 1955 :

وانه ولفض النزاعات التي قد تنشأ بعد استقلال تونس حول تحديد وضعية الاشخاص التونسيين اللذين اكتسبوا أو قرروا الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية عن محض ارادتهم تم امضاء اتفاقية بين الدولتين في 3 جوان 1955 تضمن الباب الثاني منها قواعد لفض تنازع قوانين الدولتين في خصوص مسألة الجنسية. وقد التزمت الحكومة التونسية في الفصل 8 فقرة ب منها، بعدم اعتبار من مواطنيها التونسيون اللذين اكتسبوا أو سيكتسبون الجنسية الفرنسية بمحض ارادتهم.»

Article 8 B: (Le Gouvernement tunisien) s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux tunisiens qui ont acquis ou acquerront la nationalité française par naturalisation individuelle.»

وان المرحومة «ز. الق.» وان كانت قد اكتسبت الجنسية الفرنسية بموجب المفعول الجماعي لأمر تجنس والديها الا ان عدم اعراضها عن هذه الجنسية عند بلوغها سن الرشد أي خلال سنة 1939 يجعل احتفاظها بالجنسية الفرنسية ناتج عن ارادة فردية وهو ما يجعل أحكام الفصل 8 فقرة ب تنطبق عليها كذلك فتكون الحكومة التونسية ملزمة بموجبه بعدم اعتبار المرحومة «ز. الق.» من مواطنيها نظرا لثبوت اكتسابها للجنسية الفرنسية بمحض ارادتها بعدم اعراضها عن الجنسية الفرنسية عند بلوغها سن الرشد أو عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

وان الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية هي اعلى مرتبة من القوانين الداخلية عملا بأحكام الدستور القديم والجديد وهو ما يجعل التمسك بعدم فقدان المرحومة «ز. الق.» للجنسية التونسية مخالفا لأحكام هذه الاتفاقية وفيه خرق لأحكام الفصل 20 من الدستور مما يتجه نقضه من هذه الناحية أيضا.

- الفصل 30 قديم من مجلة الجنسية الصادرة بموجب المرسوم عدد 6 المؤرخ في 28 فيفري 1963 :

فقد اقتضى الفصل 30 قديم من مجلة الجنسية بانه «يفقد الجنسية التونسية التونسي الذي اكتسب بمحض اختياره جنسية اجنبية» وهو ما يؤكد بصورة واضحة لا شك فيها ان فقدان الجنسية التونسية لمن يكتسب بمحض ارادته الجنسية الفرنسية يكون اليا بموجب تطبيق هذا القانون .

وانه بالنسبة للمرحومة «ز. الق.» فانه وان كان اكتسابها للجنسية الفرنسية لم يكن عن محض اختيارها باعتبارها كانت في ذلك التاريخ قاصرا الا ان ابقائها على جنسيتها الفرنسية بعد بلوغها سن الرشد والحال انه كان بإمكانها الاعراض عنها يكون ناتج عن محض اختيارها وعلى هذا الأساس تعتبر ابتداء من تاريخ بلوغها سن الرشد وكأنها اكتسبت الجنسية الفرنسية عن محض ارادتها فتصبح بذلك خاضعة للفقدان الالي للجنسية التونسية الذي نص عليه الفصل 30 قديم من مجلة الجنسية.

وانه ولئن تم تنقيح هذا الفصل بموجب القانون عدد 49 الصادر في 14 نوفمبر 1975 ليصبح فقدان الجنسية التونسية خاضع لصدور امر الا ان الفصل 30 جديد ليس له اثر رجعي فتكون المرحومة «ز. الق.» بموجب المفعول الحيني للفصل 30 قديم من مجلة الجنسية فقدت اليا جنسيتها التونسية كل هذا على فرض انها لم تفقدها بموجب الامرين المؤرخين في 8 نوفمبر 1921 أو بموجب الفصل 8 فقرة ب من الاتفاقية التونسية الفرنسية المتعلقة بحالة الاشخاص المبرمة بباريس في 3 جوان 1955 والمصادق عليها بموجب الأمر عدد 1179 المؤرخ في 03 سبتمبر 1955 مما لا يمكنها بالتالي اعادة اكتساب الجنسية التونسية الا باتباع اجراءات التجنس المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية .

ويتبين والحالة ما سبق شرحه بان التعليل الذي تبناه القرار المعقب والذي مفاده ان القوانين المنظمة للجنسية التونسية والمشار إليها أعلاه والتي صدرت لاحقا لتاريخ ميلادها لا تأثير لها على جنسية المرحومة «ز. الق.» التونسية ولا يمكن ان تفقدها جنسيتها التونسية التي اكتسبتها عند الولادة بتعلة ان ذلك فيه نيل من حقوقها المكتسبة وبان الأمر المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 لم يتضمن صراحة تحجير ازدواجية الجنسية كما ان امر تجنسها بالجنسية الفرنسية لم ينص صراحة

على اسقاط الجنسية التونسية هو تعليل مبني على سوء فهم وتطبيق لهذه الاحكام مما يتجه نقضه كذلك من هذا الأساس .

المطعن الثالث في خرق القرار المعقب للقواعد العامة المنصوص عليها بالفصلين 536 و 546 م ا ع :

قولا ان المشرع وضع قواعد عامة يستوجب اعتمادها لتفسير وفهم القانون الا ان القرار المعقب لم يأخذها بعين الاعتبار عند مناقشته للقوانين المنظمة للجنسية ضمن قضية الحال.

وانه بالرجوع إلى مختلف القوانين التي نظمت الجنسية التونسية ابتداء من تاريخ بلوغ المرحومة «ز. الق.» سن الرشد خلال سنة 1939 إلى تاريخ تنقيح الفصل 30 قديم من مجلة الجنسية بموجب القانون عدد 49 الصادر في 14 نوفمبر 1975 نتبين انها كلها اقرت مبدا التحجير على التونسيين الجمع بين جنسيتهم التونسية وجنسية اجنبية وخصوصا في فترة الاستعمار بين الجنسية التونسية والجنسية الفرنسية بل والكل يعلم ان من تحدى هذا التحجير نعت بالكافر ومنع من المثول امام المحاكم التونسية أو حتى الدفن بمقابر المسلمين وهو ما يؤكد ان الجمع بين الجنسيتين كان محجرا تحجيرا مطلقا بموجب القوانين المنظمة للجنسية في تلك الفترة وحتى بعد الاستقلال والى حين صدور القانون عدد 49 المؤرخ في 4 نوفمبر 1975 الذي وضع حد للفقدان الالي للجنسية التونسية بموجب التجنس بجنسية اجنبية.

وبالرغم من ذلك فان القرار المعقب لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التحجير المطلق واعتبر انه فيه نيل من حقوق المرحومة «ز. الق.» المكتسبة ورفض التسليم بمبدأ الفقدان الالي للجنسية التونسية في صورة اكتساب الجنسية الفرنسية عن محض ارادة خارقا بذلك القواعد العامة التي وضعها المشرع لفهم وتفسير القانون ومن ذلك :

الفصل 536 م ا ع الذي اقتضى انه :«ما حكم به القانون لسبب معين جرى العمل به كلما وجد السبب المذكور» وهو ما يجب معه تطبيق مبدا الفقدان الالي للجنسية التونسية كلما تبين ان تونسيا اكتسب الجنسية الفرنسية عن محض ارادته أو قرر عدم الاعراض عن جنسيته الفرنسية التي اكتسبها بموجب المفعول الجماعي لأمر تجنس والديه عند بلوغه سن الرشد.

الفصل 546 م ا ع الذي اكد انه :« اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع» وهو ما يقتضي معه ترجيح تطبيق المانع المتمثل في عدم الجمع بين الجنسية التونسية والجنسية الفرنسية على المقتضي الذي تمثل في عدم النيل من الحقوق المكتسبة خلافا لما ذهب إليه القرار المعقب .

ويتبين مما تقدم ان التفسير الذي تبناه القرار المعقب في مناقشته للقوانين المنظمة للجنسية ابتداء من تاريخ بلوغ المرحومة «ز. الق.» سن الرشد إلى تاريخ صدور القانون عدد 49 لسنة 1975 المشار إليه أعلاه كانت فيها خرقا للقواعد العامة لتفسير القانون التي وضعها المشرع بالفصلين 536 و 546 م ا ع مما يتجه نقضه من هذا الأساس أيضا.

المطعن الرابع؛ في سوء تطبيق الحكم المستأنف لأحكام الفصل 59 م ج :

قولا بان المعقب تمسك امام محكمة القرار المعقب ان المرحومة «ز. الق.» قد فقدت جنسيتها بمفعول القانون المنظم للجنسية في تاريخ بلوغها سن الرشد وعدم اعراضها عن الجنسية الفرنسية أي الأمر المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 ودون حاجة للقيام باي اجراء اخر لم يأتي به هذا القانون طالما ثبت انها لم تعرض عن هذه الجنسية طيلة حياتها من خلال شهادة جنسيتها الفرنسية المسلمة من السلط الفرنسية كما اثبت من خلال المؤيدات التي قدمها ان الجنسية الفرنسية هي الجنسية التي كانت تعتمد عليها المرحومة «ز. الق.» فعليا في معاملتها طيلة حياتها .

وقد اقتضى الفصل 59 من مجلة الجنسية انه «في مادة الجنسية عبء الاثبات على من يدعي انه تونسي سواء بطريق القيام بدعوى اصلية أو بطريق الدفع اثناء نشر القضية» وهو ما يجعل في هذه القضية عبء الاثبات محمول على من يدعي انها ما تزال حاملة للجنسية التونسية وذلك بالإدلاء بما يفيد اعادة اكتسابها لهذه الجنسية بموجب امر التجنس ذلك ان الغاء الأمر المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 أو الاتفاقية الثنائية التونسية الفرنسية المتعلقة بوضعية الاشخاص المؤرخة في 3 جوان 1955 وتنقيح الفصل 30 قديم من مجلة الجنسية لا يمكن ان يعيد المرحومة «ز. الق.» جنسيتها التونسية التي فقدتها بموجب هذه القوانين علما وان شهادة الجنسية التونسية المدلى بها من المعقب ضدهم لا يمكن اعتمادها كحجة قاطعة في الدعوى للأسباب التي سبق شرحها .

ويكون القرار المعقب الذي طالب المعقب بالإدلاء بما يفيد اعراض المرحومة «ز. الق.» عن جنسيتها التونسية بالرغم من تمسك المعقب بالقوانين المنطبقة في فترة اكتسابها للجنسية الفرنسية والتي تؤكد ارساء مبدأ فقدان الالي للجنسية التونسية في صورة اكتساب جنسية اجنبية وبالأخصصوص الجنسية الفرنسية عن محض اختبار فيه خرق لأحكام الفصل 59 من مجلة الجنسية مما يتجه نقض القرار المعقب من هذا الأساس .

المطعن الخامس؛ في ضعف التعليل وتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع:
قولاً بان محكمة القرار المعقب تمسكت بثبوت عدم فقدان المرحومة «ز. الق.» لجنسيتها التونسية قائلة :

«ان نائبة الطاعن لم تفلح في اثبات فقدان مورثة المستأنف ضدهم لجنسيتها التونسية وان هذه الاخيرة كانت حاملة للجنسية المزدوجة الفرنسية والتونسية وهو ما اقر به موكل المتداخلين نفسه بالتنصيص على ذلك صراحة ضمن كتب الاتفاق المحرر من طرفه بتاريخ 15 جوان 2010 أو من خلال سعيه لاستخراج حجة وفاة الهالكة المطعون فيها راهنا والمقامة بطلب منه وهو ما يجعل قيامه من قبيل السعي في نقض ما تم من جهته فضلاً عن تجرد دعواه من كل سند قانوني أو واقعي يدعمها»

ويتبين مما تقدم ان محكمة القرار المعقب اعتمدت على قرائن اعتبرتها حجة على عدم فقدان المرحومة «ز. الق.» لجنسيتها التونسية وعلى تمتعها بكلي الجنسيتين التونسية والفرنسية طيلة حياتها وهذه القرائن هي :

- + ما عبرت عنه بـ«اقرار المعقب ضمن كتب الاتفاق الذي حرره شخصيا في 15 جوان 2010 بجنسية المرحومة «ز. الق.» التونسية.
- + حمل المرحومة «ز. الق.» لبطاقة تعريف وطنية.
- + ترسيم ولادتها ووفاتها بدفاتر الحالة المدنية التونسية.
- + تسليمها وزارة العدل شهادة في الجنسية التونسية مؤرخة في 19 نوفمبر 2013.

الا انه وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فان بعض من هذه القرائن لا تستقيم واقعا ولا قانونا اما البقية فإنها لا ترتقي إلى مرتبة الحجة القاطعة بدليل امكانية من يدعي خلافها اثبات ذلك حسب أحكام الفصل 64 من مجلة الجنسية: فالإقرار لا يمكن اعتباره دليل اثبات في النزاعات المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص بصفة عامة وبالجنسية بصفة خاصة فهو بينة مقبولة قانونا في مادة الالتزامات «لإثبات تعمير الذمة وبراءتها» وفق ما جاء بأحكام الفصول 427 وما بعده من ماع وفي المادة الجزائية وفق ما تضمنه الفصل 152 م ا ج وبالتالي يكون الحكم الذي اعتبر الاقرار وسيلة اثبات في مادة الجنسية قد اساء تطبيق أحكام الفصل 64 م ج.

اما القرائن الاخرى التي تمسك بها الحكم المطعون فيه والمتمثلة في رسوم الحالة المدنية المسلمة للمرحومة «ز. الق.» (مضمون وفاتها التونسي وبطاقة تعريفها التونسية وكذلك شهادة الجنسية المسلمة من وزارة العدل).

فالملاحظ ان الادارة عادة ما تتعامل مع الاشخاص حسب ظاهر الامور ولا تتحرى عند تسليم رسوم الحالة المدنية لأصحابها فيكفي ان يثبت من مضمون الولادة ان صاحبه ولد بتونس من والدين تونسيين وعدم وجود ما يفيد لدى وزارة العدل لتصريح يفيد اعراض المعني عن الجنسية التونسية ليحمل من قبل الادارة على كونه تونسي يحق له الحصول على بطاقة ولادة تونسية وشهادة جنسية تونسية ومضمون وفاة تونسي .

وانه من الثابت ان الادارة التونسية كانت تجهل امر تجنس المرحومة «ز. الق.» بالجنسية الفرنسية في الفترة التي لم تكن مجلة الجنسية التونسية تسمح فيها بازدواجية الجنسية (الفصل 30 قديم) خصوصا انها تجنست بالجنسية الفرنسية ايام الحماية الفرنسية وتحت طائل قانون جنسية لم ينص على وجوب القيام بإجراءات التصريح بالأعراض عن الجنسية التونسية وهو الأمر المؤرخ في 08 نوفمبر 1921 نظرا وان اجراءات التصريح جاءت بها مجلة الجنسية الجديدة كما ان مورثة المعقب تقيم بالخارج ولا تأتي إلى تونس الا لقضاء عطلة مما لا وجود لما يثبت ان الادارة التونسية كانت على علم بأمر تجنسها بالجنسية الفرنسية في فترة الحماية وهو ما يؤكد ان الادارة التونسية لما سلمت رسوم الحالة المدنية

لزوجة المعقب كانت تجهل تماما حقيقة حالتها المدنية وتعاملت معها استنادا إلى ما بدا لها ظاهرا من خلال مضمون ولادتها أي انها ولدت بتونس من ابوين تونسيين.

علما وان مضمون ولادة المرحومة «ز.الق.» اقيم عند ولادتها في تاريخ كان والديها تونسيين ولم يحين طيلة حياتها بالتنصيص على زواجها الاول والثاني كما ان البيانات المضمنة به تتناقض مع الواقع كتجنس والديها بالجنسية الفرنسية في فترة الحماية الفرنسية وفقدانها على أساس ذلك الجنسية التونسية وتجنسها بدورها بهذه الجنسية عملا بالمفعول الجماعي لأمر تجنس والديها وعدم اعراضها عن هذه الجنسية عند بلوغها سن الرشد وهي بيانات بقيت مجهولة من الادارة التونسية لعدم التصريح بها من قبل المرحومة «ز.الق.» لدى ضابط الحالة المدنية بتونس ولعدم اجراء الادارة التحريات اللازمة للتعرف على حالتها المدنية الحقيقية حتى يمكنها استخلاص النتائج القانونية منها قبل تسليمها بطاقة تعريف وطنية أو شهادة في الجنسية التونسية .

وقد تبين ان وزارة العدل اعتمدت في شهادة الجنسية التونسية للمرحومة «ز.الق.» التي سلمتها للخصوم على مضمون ولادتها ومضمون وفاتها وعلى القانون المنظم للجنسية التونسية في تاريخ ولادتها أي الأمر المؤرخ في 19 جوان 1914 مما يؤكد انها اعتمدت على ما تم التنصيص عليه بمضمون ولادتها في تاريخ ولادتها أي انها ولدت بتونس من ابوين تونسيين دون الاخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت لاحقا على وضعيتها والتي كانت الادارة تجهلها تماما.

وطالما لا وجود لما يفيد ان المعقب ضدهم سلموا وزارة العدل صحة مطلبهم.

ما يفيد تجنس المرحومة «ز.الق.» بالجنسية الفرنسية وعدم اعراضها عنها طيلة حياتها وخصوصا عند بلوغها سن الرشد .

-او ما يفيد اعراضها عن الجنسية الفرنسية بدخول الفصل 30 قديم من مجلة الجنسية التونسية حيز التنفيذ والذي اقر بان كل تونسي تجنس بجنسية اجنبية بمحض اختياره يفقد الجنسية التونسية اليا.

او ما يثبت ان المرحومة «ز. الق.» بعد تنقيح الفصل 30 من مجلة الجنسية خلال سنة 1975 لغاية تمكين التونسيين من حق اكتساب جنسية ثانية قامت بما يقتضيه القانون أي القيام بإجراءات التجنس بالجنسية التونسية التي فقدتها بعد دخول الفصل 30 قديم حيز التنفيذ.

فان الشهادة المدلى بها من المعقب ضدهم لا يمكن ان تعبر عن موقف الوزارة الحقيقي من دعوى الحال وبالتالي لا يمكن ان يكون لهذه الشهادة تأثير على وجه الفصل في دعوى الحال .

علما وان ما تضمنه مضمون وفاة المرحومة «ز. الق.» من تنصيصات هو مجرد نقل حرفي لما جاء بمضمون ولادتها مما لا يمكن للأسباب التي سبق بيانها اعتماد هذه البيانات لاستخلاص نتائج قانونية منها فيما يخص حقيقة جنسية زوجة المعقب المرحومة «ز. الق.».

ويتبين مما تقدم ان ما اعتبرته محكمة القرار المطعون فيه قرائن تؤكد ان زوجة المدعي في الأصل كانت تتمتع بالجنسية التونسية إلى جانب الجنسية الفرنسية في قائم حياتها هو في الحقيقة والواقع ناتج :

من ناحية ثانية عن جهل الادارة التونسية للتغيرات التي طرأت على الحالة المدنية للمرحومة «ز. الق.» في قائم حياتها مما حال دون ان تستخلص النتائج القانونية الحقيقية من تلك التغيرات فكانت تسلم رسوم الحالة المدنية استنادا على ما ثبت لديها من ظاهر البيانات المضمنة في مضمون ولادتها ومضمون وفاتها ولا شيء فيما تم تقديمه من وثائق تتعلق بالحالة المدنية للمرحومة «ز. الق.» (مضمون ولادة، بطاقة تعريف، مضمون وفاة، شهادة جنسية) يؤكد ان الادارة التونسية كانت عالمة بأمر تجنس المرحومة «ز. الق.» بالجنسية الفرنسية في فترة لم يكن القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية مما لا يمكن اعتماد هذه الوثائق للجزم بان المرحومة «ز. الق.» لم تفقد جنسيتها التونسية.

وقد كان المعقب قد تمسك بهذا الدفع الجوهري وهو جهل الادارة التونسية لأمر تجنس المرحومة «ز. الق.» بالجنسية الفرنسية في فترة حصر فيها ازدواجية الجنسية لبيان سبب حصول المرحومة «ز. الق.» على أوراق حالة مدنية تونسية الا ان القرار المعقب تجاهلها ولم يعتمد عليها بالرغم ان العديد من المناشير الادارية

جاءت لتؤكد الاخطاء العديدة التي وقعت فيها الادارة في تسليم أوراق الحالة المدنية للأشخاص المعنية وهي أخطاء ناجمة عن جهل الادارة لحقيقة التغيرات التي تطرا على الحالة المدنية للأشخاص اثناء فترة حياتهم والتي يخفونها على الادارة اما عن جهل أو متعمدين .

ويكون القرار المعقب والحالة تلك مبني على تحريف للوقائع وسوء تطبيق للقانون وهضم لحقوق الدفاع مما يتجه الحكم بنقضه من هذه الناحية كذلك .

المطعن السادس؛ في هضم حقوق الدفاع:

قولا بان المعقب ادلى بالعديد من القرائن التي تؤكد ان المرحومة «ز. الق.» تمسكت طيلة حياتها بجنسيتها الفرنسية واعراضها الفعلي عن جنسيتها التونسية وتتمثل هذه القرائن في :

-عدم قيامها بتحيين مضمون ولادتها التونسي طيلة حياتها الذي لم تتضمن التنصيص الا على زواجها الاول ولا على زواجها الثاني بينما تضمن مضمون ولادتها الفرنسي كل البيانات المتعلقة بالتغيرات الحاصلة على حالتها المدنية .
-استقرارها بفرنسا منذ بلوغها سن الرشد فلم تكن تأتي إلى تونس الا لقضاء عطلها السنوية لو لتفقد مصالحها .

-تزوجها في مناسبة اولى وثانية بأزواج من ذوي الجنسية الفرنسية .

-استعمالها المستمر لوثائق هويتها الفرنسية سوى في الخارج أو في تونس كجواز سفرها الفرنسي وبطاقة تعريفها الفرنسية وبطاقة القنصلية الفرنسية المسلمة لها من القنصلية الفرنسية بتونس والتي كانت تؤكد انها كانت تعتبر نفسها فرنسية حتى في تونس .

-ابرام عقد زواجها الاول على يد القنصل الفرنسي بتونس وعقد زواجها الثاني على يد عدلي اشهاد فرنسيين واخضاع نظام زواجها المالي للقانون الفرنسي .

-التنصيص على جنسيتها الفرنسية دون التونسية في جميع العقود التي ابرمتها ومن ذلك عقود زواجها .

-خلاص ادائها الجبائية بفرنسا .

- حصولها على عدة اوسمة من الدولة الفرنسية تقديرا للخدمات التي قدمتها للثقافة الفرنسية .

وان دلت كل هذه القرائن على شيء فهي تدل على ان الجنسية الفعلية Nationalité Fonctionnelle للمرحومة «ز. الق.» لم تكن سوى الجنسية الفرنسية التي اختارتها في كل معاملاتها .

وقد عبرت زوجة المدعي في الأصل طيلة حياتها من خلال تزوجها في مناسبتين بفرنسيين واستعمالها لوثائق هوية فرنسية واستقرارها بفرنسا عن تعلقها بجنسيتها الفرنسية وعن اذعانها للدولة الفرنسية من خلال حرصها على تحيين وثائق حالتها المدنية الفرنسية وخلاص معاليمها الجبائية بفرنسا واخضاع نظامها المالي للزوجية للقانون الفرنسي مما يؤكد انها اختارت الجنسية الفرنسية في معاملتها واعرضت فعليا عن جنسيتها التونسية .

ويكون القرار المعقب الذي تجاهل مناقشة كل هذه القرائن التي قدمها له المعقب والتي تؤكد تخلي المرحومة «ز. الق.» الفعلي عن جنسيتها التونسية والذي تمسك بعدم فقدان هذه الاخيرة لجنسيتها التونسية وطالب المعقب بالإدلاء بوسائل اثبات لم ينطبق بها قانون الجنسية التونسية المنطبق في تاريخ ابقائها على الجنسية الفرنسية عند بلوغها سن الرشد مبني على هضم لحقوق الدفاع مما يتجه نقضه من هذه الناحية أيضا.

وحيث وردا على ذلك لاحظت الأستاذة «بن ح.» نائبة المعقب ضدهما «ك.» و«ص. ق.» صلب مذكرتها الكتابية ان موقف المعقب متناقض ومخالف لمبدأ عدم رجعية القوانين ولمبدأ الاستقرار والحقوق المكتسبة اذ من جهة يقر بان قوانين الجنسية لها مفعول حيني اذ انها تحدد بالرجوع إلى قانون الجنسية المنطبق في ذلك التاريخ الا انه يعتبر من جهة اخرى وان جنسية مورثة المعقب ضدهما تتغير كلما صدر قانون جديد يتعلق بتغيير أحكام الجنسية وان محكمة القرار المطعون فيه قد احسنت تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين حينما اعتبرت ان جنسية الشخص تحدد بمقتضى التشريع النافذ زمن ولادته ولا يمكن ان تتأثر بقوانين لاحقة بصورة رجعية لما في ذلك من نيل من الحقوق المكتسبة وان اعتبار المعقب ان والدي مورثة المعقب ضدهما اكتسبا الجنسية الفرنسية

بمفعول التجنس الصادر بتاريخ 21/12/1922 وطبق الأمر العلي المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 أصبحوا فرنسيون وان مورثة المعقب ضدهما وحينما لم تعرض عن الجنسية الفرنسية عند بلوغها سن الرشد تكون قد فقدت الجنسية التونسية طبقا للأمر العلي المذكور هو دفع لا سند له من القانون ضرورة انه لا وجود لاي نص قانوني يوجب على التونسي الذي اكتسب دون ارادته الجنسية الاجنبية ان يتخلى عنها حتى لا يفقد جنسيته التونسية وان القانون المنطبق على وضعية مورثة المعقب ضدهما هو الأمر العلي الصادر في 19 جوان 1914 وذلك احتراماً لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو ما انتهت إليه محكمة القرار المطعون فيه عن صواب مضيفا ان مورثة المعقب ضدهما لم تكتسب الجنسية الفرنسية بمحض ارادتها وعليه فان احتجاج المعقب بالاتفاقية الثنائية بين البلاد التونسية والبلاد الفرنسية في غير طريقه باعتبار ان هذه الاتفاقية تنص على ان الدولة التونسية لن تتمسك بمواطنيها الذين بمحض ارادتهم اكتسبوا أو سيكتسبون الجنسية الفرنسية كما ان تعلل المعقب بأحكام الفصل 30 قديم من مجلة الجنسية لسنة 1963 المتعلق بفقدان الجنسية التونسية في غير طريقه باعتبار ان اكتساب مورثة المعقب ضدهما للجنسية الفرنسية كان قبل صدور المجلة ودخولها حيز التنفيذ بتاريخ 7 مارس 1963 ولا يمكن ان يكون للقانون مفعول رجعي الا اذا نص على ذلك صراحة مؤكدا على ان مورثة المعقب ضدهما قد اكتسبت الجنسية التونسية نظرا لكونها مولودة بتونس ومن اب وام تونسيين وان امر التجنس جاء اثر ولادتها ولم تكتسب الجنسية الفرنسية بمحض ارادتها بل في اطار التجنس الجماعي عندما كانت قاصرا وان ذلك الأمر لا يفقدها جنسيتها التونسية التي تمتعت بها طيلة حياتها إلى حين صدور مجلة الجنسية ولا وجود لأمر أو غيره يثبت فقدانها للجنسية التونسية وعليه فان استنتاجات المعقب وان المورثة قد فقدت جنسيتها التونسية بصفة الية هي استنتاجات مخالفة لجميع القوانين الصادرة في مادة الجنسية وانه وخلافا لما يدعيه المعقب فان الفصل 59 من مجلة الجنسية نص في فقرته الثانية على ان كل شخص ينازع شخص في جنسيته التونسية عليه اثبات ذلك وعليه فان المعقب الذي نازع في مسألة جنسية مورث المعقب ضدهما يكون هو المطالب بإثبات وانها فقدت الجنسية التونسية باعتبار ان عبء الاثبات محمول على القائم بالدعوى وقد قدم المعقب ضدهما جميع المؤيدات التي تثبت ان جنسية

مورثتهما تونسية وفي غياب الطعن في صحة التصريحات الموجودة بهذه الوثائق لا يمكن القول بعدم اعتمادها والاعتداد بها ما لم يوجد ما يخالفها وعليه فان اعتماد محكمة القرار المطعون فيه عليها كان في طريقه وغير مخالف للقانون.

منتها إلى ان ما اسست عليه المحكمة قضاءها يتمشى وما له أصل ثابت بأوراق الملف فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا مستساغا يتمشى واحكام الفصل 123 من م م م ت ولم تأت مستندات الطعن بما يوهنه بما يتعين معه ردها جميعا ورفض مطلب التعقيب أصلا.

وحيث تمسك الأستاذ «الو.» نائب المعقب ضده «س. الق.» صلب مذكرته الكتابية بالردود التالية:

من حيث الشكل :

فان مطلب التعقيب مرفوض شكلا لان الطاعن لا يعتبر وارثا للمدعو «جا. ب. ما. ري.» وتبعا لذلك فان تداخله في القضية الاستثنائية مخالف للقانون ولا صفة له في الطعن بالتعقيب .
بصفة عرضية من حيث الأصل :

بخصوص المطعن الاول المتعلق بادعاء خرق الأمر المؤرخ في 27 / 01 / 1883 :
فان الأمر المؤرخ في 27 / 1 / 1883 المنسوب لمحكمة القرار المنتقد لم يبق موجودا ضمن المنظومة القانونية التونسية وقد تم الغاء العمل به بموجب الأمر المؤرخ في 08 / 09 / 1955 ولا يمكن بالتالي ان ينسب للحكم المنتقد مخالفة نص قانوني لم يبق موجودا وحتى لو افترضنا جدلا ان الأمر المؤرخ في 27 / 1 / 1883 لا زال نافذا فهو ينص على دخول النصوص القانونية حيز النفاذ بعد يوم من نشرها بالرائد الرسمي ومن الواضح ان محكمة القرار المنتقد لم تخالف مطلقا هذه القاعدة اذ انها لم تعتبر ان الأمر المؤرخ في 08 / 11 / 1921 لم يدخل حيز النفاذ بل اكدت انه لم يأت بجديد مقارنة بالأمر المؤرخ في 19 / 06 / 1914 بخصوص وضعية المرحومة «ز. الق.» ويتضح من ذلك ان الحكم المنتقد لم يخالف مطلقا أحكام الأمر المؤرخ في 27 / 01 / 1883 بما يجعل هذا المطعن في غير طريقه ومن المتجه رده.

بخصوص المطعن الثاني المتعلق بادعاء سوء تطبيق النصوص المتعلقة بالجنسية:

فانه وخلافا لما ادعاه الطاعن فان الأمر المؤرخ في 08/11/1921 لا يتضمن تحجير ازدواجية الجنسية ولا يوجب مطلقا على من اكتسب جنسية اجنبية بعد صدوره ان يتخلى عنها مؤكدا ان اسناد وفقدان الجنسية التونسية يحددها المشرع التونسي وليس التشاريع الاجنبية وعليه فلا يجوز للطاعن ان يتمسك بأحكام الأمر الفرنسي المؤرخ في 08/11/1921 المتعلق بشروط اسناد الجنسية الفرنسية لكي يستخلص منه فقدان المرحومة «ز. الق.» للجنسية التونسية كما ان تمسك الطاعن بمضمون الاتفاقيات التونسية الفرنسية المؤرخة في 03/06/1955 مردود عليه وفاقد لكل جدية باعتبار ان تلك الاتفاقيات لم تطبق مطلقا والغيث بموجب معاهدة 20/03/1956 المتعلقة بالاستقلال التام للبلاد التونسية كما ان تمسك الطاعن بأحكام الفصل 30 قديم من مجلة الجنسية التونسية والمطالبة بتطبيقه مردود عليه لأنه ليس لهذا النص مفعول رجعي وهو يتطبق فقط على من اكتسب جنسية اجنبية بمحض ارادته بعد ادراج مجلة الجنسية التونسية سنة 1963 بما يجعل هذا النص لا ينطبق مطلقا على وضعية مورثة الطرفين التي اكتسبت الجنسية الفرنسية منذ سنة 1922 أي قبل 41 عاما من صدور المجلة ومن جهة اخرى فان الفصل 30 المشار إليه يتعلق بمن اكتسب جنسية اجنبية بمحض ارادته وليست هذه وضعية المرحومة زينب القبائلي بما يجعل هذا المطعن متعين الرد .

بخصوص بقية المطاعن :

فهي تتعلق بجدل موضوعي يهدف لمناقشة محكمة الأصل في تقديرها لمضمون الشهادات والوثائق الادارية التي ادلى بها المعقب ضده وباقي المدعى عليهم في الأصل لإثبات تمتع مورثة الطرفين بجنسيتها التونسية كالنعي عليها عدم اخذها بالقرائن التي استدلت بها المعقب لإثبات تمسك مورثة الطرفين بجنسيتها الفرنسية طيلة حياتها والحال ان ذلك راجع لاجتهادها المطلق دون معقب عليها هذا وقد ثبت ان كل الوثائق التي ادلى بها المعقب ضدهم صادرة عن الجهات الرسمية المختصة بما يتجه معه اعتبارها صحيحة ومنتجة لكل اثارها القانونية عملا بأحكام الفصل 559 من م ا ع وهو ما انتهت إليه محكمة القرار

المطعون فيه عن صواب التي احسنت تعليل قرارها المطعون فيه بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون اهمال منها لاي دفع من الدفوعات المثارة لديها وكانت بذلك مستندات الطعن حرية بالرد وهو ما يتعين معه بصفة عرضية رفض مطلب التعقيب أصلا .

وحيث ولئن قدمت الأستاذة سهام كافي رزيق تقريرا في الرد على مستندات التعقيب نيابة عن المعقب ضده «يا. الق.» الا ان التقرير المذكور قد تم تقديمه بتاريخ 20/12/2017 أي خارج الاجل المنصوص عليه بالفصل 186 من م م ت وهو ثلاثون يوما من تاريخ محضر اعلامه بعريضة أسباب الطعن والموافق ليوم 09/11/2017 بما يتعين معه الالتفات عن التقرير المذكور .

المحكمة

من حيث الشكل :

حيث وخلافا لما دفع به الأستاذ «الح. الو.» نائب المعقب ضده «س. الق.» فان الصفة في التداخل والطعن بالتعقيب متوفرة في جانب الطاعن «ف. رو. ان. قو.» باعتبار انه ثبت من مطروحات الملف ان القائم بالدعوى الاصلية «جا. ب. ما. ري.» توفي بتاريخ 16/1/2016 اثناء نشر القضية الاستئنافية وحل محله الطاعن الان بوصفه مولى على تركه Legataire universel بموجب وصية خطية تركها المتوفي مؤرخة في 16/9/2010 وقام بتعديلها في 28/3/2014 معرف عليها بالإمضاء من عدلي الاشهاد بباريس (فرنسا) «دو. بو.» وجليسه بتاريخ 14/6/2014 ومصادق عليها من القنصلية العامة لتونس بباريس (فرنسا) في 09/01/2016 ومسجلة بالقباضة المالية بتونس في 01/09/2016 وهو بذلك يتمتع بصفة الوريث للقائم بالدعوى الحالية والمخول له للحلول محل مورثه في ما يتعلق بتصفية مخلفه.

وحيث يكون والحالة تلك مطلب التعقيب صادر ممن له الصفة والمصلحة وفي الآجال القانونية بما يتعين معه قبوله من الناحية الشكلية.

من حيث الأصل :

عن كافة المطاعن لترابطها ووحدة القول فيها :

حيث من المسلم به قانونا ان الجنسية هي علاقة الولاء التي تربط الفرد بالدولة وينتج عنها حقوق وواجبات متبادلة فهي لذلك تعرف بانها الانتماء القانوني للشخص لمجموعة ما تكون دولة ويعرفها بعض الفقهاء كذلك بانها رابطة قانونية وسياسية تفيد اندماج الفرد في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة فهي بذلك تكتسي اهمية بالغة بالنسبة للفرد فهي الارتباط الانساني الذي يأتي في قيمته الادبية والمعنوية بالنسبة للصغير مباشرة بعد الارتباط الاسري ويتقدم جميع الارتباطات أيا كان نوعها بالنسبة للبالغ فهذا الارتباط احد اهم مكونات الشخصية القانونية للفرد لأنه يمثل احد اهم عناصر هويته وبفضلها يمكنه التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وحيث ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الجنسية سواء بالنسبة للفرد أو الدولة فقد حرصت مختلف الدول على تنظيم قواعد اكتسابها ووقع التمييز بين الجنسية الاصلية وبين الجنسية المكتسبة حيث يمكن للفرد ان يتحصل على جنسية دولة ما في مرحلة من مراحل حياته حسب قوانين الدولة المانحة لها وهو ما يختلف عن الجنسية الاصلية التي تمنح وتثبت للفرد منذ الميلاد ولا دخل لإرادته فيها وهو ما جعل بعض الفقهاء يصفها بالجنسية المفروضة. ويعتبر القانون التونسي المنظم للجنسية من القوانين التي شهدت تطورا هاما فبعد اعلان عهد الامان سنة 1857 ودستور عهد الامان لسنة 1861 اللذين كرسا مفهوم الانتماء الابدي للبلاد التونسية تلتهما كل من أحكام الأمر العلي المؤرخ في 19/6/1914 وأحكام الأمر العلي المؤرخ في 8 نوفمبر 1921 لتصدر في مرحلة اولى مجلة الجنسية المؤرخة في 26 جانفي 1956 تفعيلا للاتفاقيات التونسية الفرنسية للاستقلال المؤرخة في 3 جوان 1955 والتي اقرت الجنسية التونسية بمفهومها الحديث وابتقت على بعض الامتيازات للمتمتعين بالجنسية الفرنسية إلى حدود الاستقلال التام ثم وفي مرحلة ثانية صدرت مجلة الجنسية التونسية بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 وهي مجلة قنت أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية التونسية أو اسقاطها أو سحبها .

وحيث ان الاشكال القانوني المطروح يتعلق بمعرفة ان كان اكتساب التونسي أو التونسية للجنسية الفرنسية قبل صدور مجلة الجنسية التونسية وبموجب المفعول الجماعي لأمر التجنس بالجنسية الفرنسية Effet collectif du décret

de naturalisation الصادر عن سلطة الحماية الفرنسية بتاريخ 1922 / 12 / 21 يفقده أو يفقدها الجنسية التونسية الاصلية ؟

وحيث لا جدال كيفما هي الوضعية في قضية الحال ان مورثة المعقب والمعقب ضدهم «ز. الق.» قد ولدت بتونس في 24 جوان 1918 من اب وام تونسيين مولودين بدورهما بتونس وهو ما اكسبها بصورة الية للجنسية التونسية . كما لا جدال في كونه قد تم سحب الجنسية الفرنسية عليها قبل بلوغها سن الرشد بموجب المفعول الجماعي لأمر التجنس الصادر لفائدة والدها من قبل سلطة الحماية الفرنسية في 1922 / 12 / 21 وان البحث عن مدى فقدان المورثة المذكورة لجنسيتها التونسية من عدمه بعد تجنسها بالجنسية الفرنسية ومدى تمكنها من الجمع بين الجنسيين التونسية والفرنسية في ان واحد يقتضي تحديد التشريع المنطبق على وضعيتها وتفصيل ما وردت به من أحكام في هذا الشأن .

وحيث اعتبرت محكمة القرار المطعون فيه ان جنسية الشخص تتحدد بمقتضى التشريع النافذ زمن ولادته ولا يمكن للقوانين اللاحقة ان تنطبق عليه بصورة رجعية لما في ذلك من نيل من الحقوق المكتسبة وينطبق بالتالي على وضعية مورثة الطرفين أحكام الأمر العلي المؤرخ في 1914 / 6 / 19 الذي اكتسبت بمقتضاه الجنسية التونسية بصورة الية وان تجنسها بالجنسية الفرنسية بمقتضى الأمر الجماعي الصادر بتاريخ 1922 / 12 / 21 لا يفقدها الجنسية التونسية باعتبار انه لا وجود لاي نص قانوني يفرض على التونسي الذي اكتسب بدون ارادته جنسية اجنبية ان يتخلى عنها حتى لا يفقد الجنسية التونسية كما لا يمكن ان يكون فقدان الجنسية التونسية بصورة ضمنية وهو ما يصح معه اعتبار مورثة الطرفين من ذوي الجنسية المزدوجة في غياب تحجير قانوني صريح في ذلك.

وحيث دفع الطاعن في المقابل ان المورثة «ز. الق.» ولئن اكتسبت الجنسية الفرنسية دون ارادتها عندما كانت قاصرة وذلك بموجب المفعول الجماعي لأمر التجنس الصادر في 1922 / 12 / 21 الا ان عدم اعراضها عن هذه الجنسية عند بلوغها سن الرشد والمحافظة على هذه الجنسية طيلة حياتها يصبح معه احتفاظها بالجنسية الفرنسية مبني على ارادة شخصية وتفقد بمقتضى ذلك جنسيتها التونسية

لكونها أصبحت خاضعة للتحجير الذي سنته القوانين المنظمة للجنسية التونسية في تلك الفترة والمتعلقة بعدم الجمع بين الجنسية التونسية والفرنسية ويكون بذلك القرار المطعون فيه حينما قضى بخلاف ذلك قد خرق أحكام الأمر المؤرخ في 27 جانفي 1883 المتعلق بتحديد ابتداء العمل بالقوانين واساء تطبيق القوانين المتوالية المنظمة للجنسية التونسية ومنها الأمر العلي المؤرخ في 8/11/1921 والأمر الفرنسي المؤرخ في 8/11/1921 والاتفاقية الثنائية الفرنسية المؤرخة في 3/6/1955 والفصل 30 قديم من مجلة الجنسية والتي تحجر الجمع بين الجنسية التونسية والجنسية الفرنسية كما خرق القواعد العامة المنصوص عليها بالفصلين 536 و546 من ماع واساء تطبيق أحكام الفصل 59 من مجلة الجنسية وأورث قضاءه ضعفا في التعليل وتحريفا للوقائع وهضمنا لحقوق الدفاع .

وحيث وبخصوص الدفع المتعلق بمخالفة الأمر المؤرخ في 27/1/1883 المتعلق بتحديد ابتداء العمل بالقوانين فقد تمسك الطاعن بان جنسية الشخص لا يمكن ان تكون حقا مكتسبا طيلة حياته بل هي خاضعة للقوانين المتتالية المنظمة للجنسية التونسية والتي تطبق على الاشخاص الحاملين لها بصورة الية بمجرد صدورهما والا لما وضع المشرع احكاما منظمة لفقدانها .

وحيث وخلافا لذلك فان محكمة القرار المطعون فيه قد نزلت موضوع الدعوى في اطارها التشريعي السليم من حيث تكريس أحكام القانون النافذ زمن ولادة مورثة طرفي النزاع وان القول بان قوانين الجنسية التي عرفت البلاد التونسية لم تحدد تاريخ ابتداء العمل بها هو قول مخالف لمبدأ حينية القوانين وعدم رجعيتهما ونفاذاها بمجرد صدورهما ذلك ان وضع الاشخاص واستقرارهم لا يمكن ان يتأثر بمجموعة قوانين تصدر بصفة متتالية ما لم ينص القانون صراحة على تطبيقها بصفة رجعية وتكون بذلك محكمة القرار المطعون فيه قد احسنت تطبيق القواعد الأساسية لتطبيق القوانين هذا وان الطاعن لم يبين في هذا الخصوص وجه مخالفة القرار المطعون فيه للأمر المؤرخ في 27/1/1883 ذلك ان هذا الأمر فضلا عن كونه قد تم الغاء العمل به بموجب الأمر المؤرخ في 13/9/1955 فهو ينص على دخول النصوص القانونية حيز التنفيذ بعد يوم من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي وهو الأمر الذي استند إليه منشور كاتب الدولة للعدل عند تحديده لتاريخ ابتداء العمل بمجلة الجنسية الجديدة لسنة 1963 .

واتجه لذلك رد هذا الدفع المثار لعدم جديته .

وحيث لا جدال ان القوانين المنظمة للجنسية التونسية قبل صدور مجلة الجنسية سنة 1963 هي الاوامر الصادرة عن الباى والمتمثلة في الأمر العلي المؤرخ في 19/6/1914 والامر العلي المؤرخ في 8/11/1921 .

وحيث كرس الأمر العلي المؤرخ في 19/6/1914 في فصله الوحيد الجنسية التي تنشأ بموجب حق الدم *Jus sanguinis* « ودون تمييز على أساس الانتماء الديني اذ اعتبر ان التونسي» هو كل شخص ولد بالايالة التونسية أو خارجها من اب تونسي أو عند عدم معرفة الاب من ام تونسية وانه وبتنزيل أحكام الأمر المشار إليه النافذ المفعول في تاريخ ولادة مورثة الطرفين تكون هذه الاخيرة قد اكتسبت بصورة الية للجنسية التونسية كجنسية اصلية بحكم ولادتها بتونس من اب وام تونسيين مولودين بدورهما بتونس .

وحيث جاء الأمر العلي المؤرخ في 8/11/1921 والنافذ المفعول في تاريخ اكتساب مورثة الطرفين للجنسية الفرنسية ليلبور بصفة أدق مفهوم الجنسية أضاف عنصر رابطة الأرض أو الإقليم *Jus soli* « أي اكتساب الجنسية بمقتضى «ثنائية الولادة بتونس» كما اكد مفهوم الانتماء إلى الدولة اذ جاء بفصله الوحيد ان «كل شخص ولد بتراب مملكتنا وكان احد ابويه مولود به فهو تونسي الا الفرنسيين أو التابعين للدولة العظمى الحامية من غير رعايانا وذلك مع مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الرابطة بدولتنا التونسية قبل وبعد اجراء العمل بهذا الأمر وهو ساكن بها أو خارجها».

وحيث وطالما ان القوانين المنظمة للجنسية هي قوانين تهتم النظام فانه لا يجوز التوسع في تأويلها هذا وقد تبين من استعراض التشريع المتعلق بالجنسية التونسية والنافذ المفعول في تاريخ اكتساب مورثة الطرفين للجنسية الفرنسية سنة 1922 انه تضمن التأكيد على ان الجنسية تقوم على مبدأ الولاء التام للايالة التونسية ولم يقع التنقيص صلبه مطلقا سواء بصفة ضمنية أو صريحة على أي تحجير أو منع لازدواجية الجنسية أو على فقدان التونسي لجنسيته التونسية الاصلية بصفة الية بعد اكتسابه للجنسية الفرنسية وعدم اعراضه عنها عند بلوغه سن الرشد كيفما دفع به الطاعن عن غير صواب وعليه فان اكتساب مورثة الطرفين للجنسية الفرنسية

بمقتضى المفعول الجماعي لأمر التجنس لسنة 1922 لا يمكن ان ينزع عنها جنسيتها التونسية الاصلية لعدم وجود أي نص قانوني ساري المفعول عندئذ يقتضي ذلك خاصة وان اكتسابها للجنسية الفرنسية كان بدون ارادتها وهو ما يصح معه اعتبارها من ذوي الجنسية المزدوجة لان الأصل في الأمر هو الجواز والمطابقة للقانون وهو ما انتهت إليه محكمة القرار المطعون فيه عن صواب التي احسنت تعليل قرارها في هذا الشأن.

وحيث ان احتجاج الطاعن من جهة اخرى بأحكام الأمر المؤرخ في 8/11/1921 الصادر عن الحكومة الفرنسية هو احتجاج في غير محله باعتبار ان الأمر المذكور لا يجد له انطباقا على وضعية مورثة الطرفين فهو يتعلق بشروط اسناد الجنسية الفرنسية قبل صدور امر التجنس لسنة 1922 وهو امر قد تم نسخه بموجب الأمر الفرنسي الصادر بتاريخ 20/12/1923 كما ان تمسك الطاعن بمضمون الاتفاقيات التونسية الفرنسية المؤرخة في 03/06/1955 مردود عليه لكون الاتفاقية المذكورة تخص مواطني الدولة التونسية الذين بمحض ارادتهم اكتسبوا أو سيكتسبون الجنسية الفرنسية وهو غير صورة الحال باعتبار ان اكتساب مورثة الطرفين للجنسية الفرنسية لم يكن بمحض ارادتها واختيارها وانما بموجب امر التجنس الجماعي المشار إليه أعلاه فضلا على كون الاتفاقية الثنائية المذكورة لم تطبق مطلقا وتم الغاؤها بموجب ابرام بروتوكول الاستقلال التام بين الدولتين في 20 مارس 1956 وهو ما انتهت إليه محكمة القرار المطعون فيه عن صواب.

وحيث ان تعلل الطاعن فضلا عن ذلك بفقدان مورثة الطرفين للجنسية التونسية عملا بالفصل 30 قديم من مجلة الجنسية لسنة 1963 طالما انها ابقت على جنسيتها الفرنسية بعد بلوغها سن الرشد ولم تعرض عنها بما يجعلها قد اكتسبتها بمحض ارادتها هو دفع مردود عليه لان الفصل 30 قديم ليس له مفعول رجعي فهو ينطبق فقط على من اكتسب جنسية اجنبية بمحض ارادته عند صدور مجلة الجنسية سنة 1963 وهو غير وضعية المورثة المذكورة التي اكتسبت الجنسية الفرنسية منذ سنة 1922 بموجب المفعول الجماعي لأمر التجنس وبدون ارادتها فضلا على كون الفصل المذكور أوجب صدور امر في الغرض يقضي بسحب الجنسية التونسية كما انه نص قد تم تنقيحه بموجب القانون عدد

79 لسنة 1975 الذي اصبح في صيغته الجديدة يجيز ازدواج الجنسية بما يجعل الاحتجاج بالفصل المذكور في غير طريقه واتجه الالتفات عنه .

وحيث ان ثبوت الجنسية أو نفيها لا يكون الا بطلب الشخص نفسه هذا وقد ثبت ان مورثة الطرفين التونسية الجنسية تطبيقا للأمر العلي المؤرخ في 19/6/1914 وانها حافظت على جنسيتها المذكورة عند اجراء العمل بالأمر العلي المؤرخ في 8/11/1921 وتمتعت بها طيلة حياتها وإلى تاريخ وفاتها سنة 2010 بدليل انها تمسك شهادة جنسية تونسية صادرة عن وزارة العدل وبطاقة تعريف تونسية ولم يثبت وجود أي تصريح بوزارة العدل أو امر أو أي عمل اداري يثبت بصفة قاطعة فقدان هذه الاخيرة للجنسية التونسية ولا يمكن لاي كان القيام بعد وفاتها بطلب افقائها جنسيتها التونسية باعتباره حقا مكتسبا غير قابل للمساس به بإرادة أي كان. كما ان اقامة مورثة الطرفين بفرنسا وحملها لوثائق فرنسية وخلاصها للاداءات الجبائية بفرنسا وزواجها من فرنسين لا يمكن ان يؤدي ذلك إلى اعتبارها متخيلة عن جنسيتها التونسية الثابتة بموجب وثائق رسمية صادرة عن الدولة التونسية تعد صحيحة مضمونا ومعتمدة قانونا طالما لم يقع الطعن فيها طبق القانون وهو ما استخلصته محكمة القرار المطعون فيه عن صواب التي احسنت تعليل موقفها في هذا الشأن وعليه فقد اضحى احتجاج الطاعن بأحكام الفصل 59 من مجلة الجنسية التونسية احتجاج في غير موضعه باعتبار ان ادعاءه فقدان مورثة الطرفين الجنسية التونسية محمول عليه وحده اثباته بصفته القائم بالدعوى وهو ما لم يتوصل إليه كيفما وقع بسطه أعلاه.

وحيث وتأسيسا على ما تقدم فان محكمة القرار المطعون فيه وحينما انتهت إلى ثبوت محافظة مورثة الطرفين «ز. الق.» على جنسيتها التونسية إلى جانب الجنسية الفرنسية في غياب نص قانوني صريح يحجر الجمع بين الجنسيين المذكورتين في تاريخ اكتسابها للجنسية الفرنسية تكون قد احسنت تطبيق القانون بعد ان كانت اجابت عن مختلف الدفوعات الجوهرية المثارة لديها معللة بذلك قضاءها تعليلًا قانونيًا سليمًا مستمدا بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف منها للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع وهو ما يجعل قرارها بمنأى عن النقض واتجه لذلك رد جميع المطاعن المثارة لعدم وجاهتها ورفض مطلب التعقيب أصلا .

ولهذه الاسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الأربعاء 12 فيفري 2020 عن الدائرة المدنية الرابعة المتألّفة من رئيسها السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجلاء المصمودي والسيد محمد معز العروسي بمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

قرار في ذاكرة فقه قضاء 2020

جزائي

الجمهورية التونسية

وزارة العدل

محكمة التعقيب

عدد القرار: 11964

تاريخه: 2020 / 06 / 02

الحمد لله وحده

قرار تعقيبي جزائي

أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية من طرف الأساتذة (ب.ف) و(م.س) و(ن.ف) و(ن.ع) و(ل.ن) بتاريخ 03 فيفري 2020 في حق المظنون فيه (أ.س).

طعنا في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الصادر تحت عدد 151 بتاريخ 30 جانفي 2020 والقاضي بقبول استئناف النيابة العمومية شكلا وفي الأصل بتأييد قرار قاضي التحقيق وإبقاء المظنون فيه (أ.س) تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده كرفض مطلب الإفراج المقدم في حقه من طرف نائبه الأستاذ (ب.ف) وإرجاع الملف إلى السيد قاضي التحقيق المتعهد.

وبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتثبت من كافة الإجراءات في القضية.

وبعد الإطلاع على ملحوظات الإدعاء العام لدى هذه المحكمة والاستماع إلى شرحها في الجلسة والرامية إلى طلب إحالة الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قصد دعوة الدوائر المجتمعة إلى الاجتماع وتوحيد الرأي

في المسألة القانونية المطروحة على مستوى الشكل وإرجاء تقديم الطلبات في الأصل إلى وقت لاحق.

وبعد الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع والرامية إلى التمسك بما ورد بمستندات التعقيب. وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:

من حيث الشكل:

حيث تمسك الادعاء العام بطلب إحالة الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قصد دعوة الدوائر المجتمعة إلى الاجتماع وتوحيد الرأي في المسألة القانونية المطروحة بخصوص مسألة قبول الطعن بالتعقيب شكلا وفي القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام في مادة الإيقاف التحفظي.

وحيث تمسك لسان الدفاع بقابلية الطعن بالتعقيب شكلا في القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام في مادة الإيقاف التحفظي وذلك استنادا إلى المبررات التالية:

أولاً- استقرار فقه قضاء محكمة التعقيب منذ صدور قرار الدوائر المجتمعة سنة 1966 على وجوب مراقبة احترام القواعد القانونية المنظمة للإيقاف التحفظي.

ثانياً- العديد من القرارات التعقيبية تعتبر أن الإيقاف التحفظي هو مساس بحق الحرية وهي مسألة أصلية تدخل في نطاق الطعن بالتعقيب طبق مقتضيات الفصل 258 من م.ج.

ثالثاً- يستنتج من القراءة المتناغمة للفصول 120 و 258 و 259 و 260 و 323 و 326 و 328 من م.ج والمقاربة بينها أن المبدأ هو قبول الطعن بالتعقيب في كل قرارات دائرة الاتهام عدا الصور الاستثنائية التي منع فيها المشرع هذا الطعن. وأن شروط الفصل 258 من م.ج لا تعني القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام لأن هذا الفصل يمنح الطعن بالتعقيب للمحكوم عليه ولم يشر إطلاقاً على المتهم أو المظنون فيه.

وأن المشرع حصر صور منع تعقيب قرارات دائرة الاتهام بصورة دقيقة بما يدل على أنه عدا هذه الموانع المضبوطة نصاً فإن المبدأ يبقى جواز الطعن بالتعقيب.

رابعاً- عدم ورود منع التعقيب في قرارات الإيقاف التحفظي بالفصول المنظمة لدائرة الاتهام ضرورة أن المشرع لم يتعرض ضمن الفصول من 112 إلى 120 من م ا ج إلى عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات الدائرة الصادرة في مادة الإفراج المؤقت أو البطاقات القضائية مهما كان نوعها وأن عدم ورود مثل هذا المنع يدل على عدم اتجاه الإرادة المشرع إلى منع الطعن بالتعقيب في قرارات رفض مطالب الإفراج الصادرة عن دائرة الاتهام.

خامساً- عدم ورود منع التعقيب في قرارات الإيقاف التحفظي ضمن الأحكام الخاصة بالإفراج المؤقت ضرورة أن الفصل 87 من م ا ج أشار إلى إمكانية تقديم المظنون فيه مباشرة إلى دائرة الاتهام مطلباً في الإفراج المؤقت وسكتت عن منع تعقيب قرار رفض مطلب الإفراج الصادر عن دائرة الاتهام، وبالتالي فإن هذا السكوت لا يستشف منه المنع بقدر ما يجب أن يستشف منه إجازة ضمنية وضرورية لمبدأ تعقيب القرارات الراضية لمطلب الإفراج المؤقت.

سادساً- عدم ورود منع التعقيب في قرارات الإيقاف التحفظي ضمن الأحكام الخاصة بالإيقاف التحفظي ضرورة أن الفصلين 84 و 85 من م ا ج لم يتضمنا ما يدل على منع جواز تعقيب القرارات المتعلقة بالإفراج المؤقت كما لم يتعرض الفصل 83 من ذات المجلة إلى أي منع لتعقيب قرارات دائرة الاتهام ذات الصلة بالبطاقات القضائية.

وانتهى لسان الدفاع بعد استعراض تلك المبررات إلى طلب قبول مطلب التعقيب شكلاً.

المحكمة

حيث تسلط الطعن بالتعقيب على قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس عدد 151 المؤرخ في 30 جانفي 2020 والقاضي بإبقاء المظنون فيه (أ.س) تحت مفعول بطاقة الإيداع ورفض مطلب الإفراج المقدم من طرف نائبه. ✓ في خصوص طلب الادعاء العام الرامي إلى الالتماس من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب دعوة الدوائر المجتمعة للانعقاد قصد توحيد الآراء القانونية عملاً بمقتضيات الفصل 275 من م ا ج.

حيث اقتضى الفصل 274 ممن م ا ج أن الدوائر المجتمعة تلتزم بإذن من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سواء تعلق الأمر بتوحيد الآراء القانونية بين مختلف الدوائر أو تطبيقا لمقتضيات الفصل 273 من م ا ج في فقرته الثانية لحسم الخلاف بين محكمة التعقيب ومحكمة الإحالة إذا كان قرارها مخالفا لقرار محكمة التعقيب القاضي بالنقض مع الإحالة ووقع الطعن بالتعقيب من جديد ولنفس المطاعن الأولى.

وحيث أنّ موضوع القضية المعروضة على أنظار هذه الدائرة لا يدخل ضمن مقتضيات الفصل 273 من م ا ج، كما أن دعوة الدوائر المجتمعة للانعقاد كلما كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين مختلف الدوائر، تدخل في مجال الاختصاص الحصري للرئيس الأول لمحكمة التعقيب عملا بالفصلين 274 و275 من م ا ج ودون توقف عن وجود قضية منشورة في الموضوع، وبالتالي ليس لهذه الدائرة أن ترجع القضية إلى الرئيس الأول للنظر في إمكانية إحالتها على الدوائر المجتمعة طالما سبق له أن اتخذ قرارا بإحالة القضية على هذه الدائرة واتجه تبعا لذلك تجاوز طلب الإدعاء العام.

✓ في خصوص مبررات لسان الدفاع بشأن إمكانية تعقيب قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت:

1 - في الحجة المستمدة من فقه قضاء محكمة التعقيب وتحديد القرار عدد 5088 الصادر عن الدوائر المجتمعة في 3 ديسمبر 1966 وحجة تعدد القرارات التعقيبية في هذه المسالة لوحدة القول فيهما:

حيث تمسك لسان الدفاع بجواز الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي وأنّ فقه قضاء محكمة التعقيب إستقر على هذا المبدأ منذ صدور القرار عدد 5088 عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 3 ديسمبر 1966 والذي اعتبر قرارات حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام في مادة الإفراج خاضعة لرقابة محكمة التعقيب.

وحيث علاوة على أن القرار المستشهد به صدر قبل إصدار مجلة الإجراءات الجزائية بموجب القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ولم يقع تبنيه تشريعا بمقتضى القوانين العديدة المنقحة أو المتممة لها، فإنه لم

يؤسس لإستقرار فقه قضاء محكمة التعقيب بخصوص هذه المسألة بدليل صدور عدة قرارات تعقيبية جزائية أكدت على عدم قابلية الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام في مادة الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت من بينها القرار التعقيبي الجزائي ع49170-د المؤرخ في 7 أفريل 2017 والذي ورد بحيثياته صراحة أنّه: «من المتعارف عليه كمبدأ قانوني عام أن القواعد الإجرائية في المادة الجزائية تفسر وتؤول تأويلا ضيقا وأن الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية حصر المشرع صورها وحدد شروطها ضمن الفصل 258 من م ا ج وأن الشرط الأساسي لجواز الطعن بالتعقيب في حكم أو قرار قضائي ولو كان صادرا عن دائرة الاتهام هو أن يكون صادرا في الأصل ونهائيا ... ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن الطعن بالتعقيب لا يُقبل إلا ضد الأحكام والقرارات المنهية للإجراءات وللتتبع والمتضمنة خوضا في تفاصيل الوقائع والباتة في أصل التهمة والتتبع». ولا يمكن بالتالي اعتبار فقه قضاء محكمة التعقيب المستند إليه من لسان الدفاع حجة تؤيد قبول مطالب التعقيب في مادة الإيقاف التحفظي واتجه صرف النظر عن هذا المبرر لتعارضه مع القانون.

2 - في الحجة المستمدة من قراءة الفصول 120 و 258 و 259 و 260 و 323 و 326 و 328 من م ا ج:

حيث اقتضى الفصل 120 من م ا ج أنه: «يقع الإعلام بقرارات دائرة الاتهام طبق أحكام الفصل 109 ويمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من هذا القانون».

وحيث اقتضى الفصل 258 من م ا ج أنه: «يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه:

- (1) المحكوم عليه،
- (2) المسؤول مدنيا،
- (3) القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية،
- (4) وكيل الجمهورية،

- 5) الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الاستئناف،
6) ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على الأمر الصادر له ممن
كاتب الدولة للعدل».

وحيث حدد الفصل 258 من م ا ج نطاق الطعن بالتعقيب وشروطه وذلك بأن
يكون القرار الطعون فيه صادرا نهائيا وبت في الأصل وأن يكون قائما على إفراط
في السلطة أو عدم الاختصاص أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.

وحيث أن المقصود بالقرارات الصادرة في الأصل هي القرارات التي تصدرها
دائرة الاتهام في أصل التهمة في إطار ممارسة سلطتها التقديرية للأفعال المنسوبة
للمظنون فيه والجريمة التي تتألف منها عند الاقتضاء والنصوص القانونية المنطبقة
عليها والتثبت من مدى تطابق الأعمال الاستقرائية مع الأحكام الإجرائية المحددة
قانونا وترجيح الأدلة والفرائن نفيًا وإثباتًا وإسنادًا، وتقرر الدائرة تبعًا لذلك إما
إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة أو أن تقرر الحفظ لسبب من الأسباب
التي حددها القانون، وأن القول بعدم وجود قرارات تصدر في الأصل عن دائرة
الاتهام لا يستقيم منطقيًا وقانونيًا لا سيما أن الفقرة الثانية من الفصل 119 من م
ا ج نصت على ضرورة أن يتضمن قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام عرضًا
مفصلاً للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني وإلا كان باطلا ما يؤكد أن
البت في أصل الوقائع والتهم يدخل في صميم صلاحيات دائرة الاتهام.

وحيث وجب التمييز بين صنفين من القرارات التي تصدرها دائرة الاتهام
يشمل أولهما القرارات الوقتية التي يسوغ الرجوع فيها أو تعديلها قبل صدور
قرار في الأصل أو بصورة متزامنة معه من بينها التدابير الاحترازية أو التحفظية
على غرار تحجير السفر أو التجميد الأموال أو حجز وسائل الإثبات وعائدات
الجريمة أو الإيقاف التحفظي أو الإفراج المؤقت، ويجوز اتخاذها خلال مرحلة
التحقيق بدرجتيه ويمكن الرجوع فيها حسب الحالات من قبل قاضي التحقيق
أو دائرة الاتهام، وكذلك القرارات التمهيدية أو التحضيرية التي تصدرها دائرة
الاتهام لغاية تهيئة القضية للفصل من حيث الأصل والقاضي بإرجاء النظر في
الأصل لاستكمال الاستقراءات أو تصحيح الإجراءات سواء مباشرة لديها أو
بواسطة قاضي التحقيق. ويتعلق الصنف الثاني بالقرارات النهائية الصادرة في

أصل التهمة إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو بالحفظ وهي القرارات القابلة للطعن بالتعقيب طبق مقتضيات الفصلين 120 و 258 من م ا ج.

وحيث اقتضى الفصل 532 من م ا ج أن «نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون». وحيث أن العبارات الواردة بالفصلين 120 و 258 من م ج والمتعلقة بالأحكام والقرارات القابلة للتعقيب وهي التي تكون صادرة نهائيا في الأصل جاءت صريحة ومعناها في ظاهر لفظها، لذا فإنها لا تحتاج إلى تأويل أو بيان وتعين إنفاذها دون زيادة أو نقصان، وإن القول بكون القرارات التي تتعلق بحرية المتهم تعد من المسائل الأصلية وهي المقصودة من عبارة في الأصل هو تأويل واسع يتعارض مع أحكام الفصل 532 من م ا ج.

وحيث خلافا لما تمسك به لسان لدفاع من كون المشرع قنّ منع تعقيب قرارات دائرة الاتهام صراحة ضمن الفصلين 259 و 260 والفصول المتعلقة بالتسليم وتحديد الفصول 323 و 326 و 328 من م ا ج وأنه لو انصرفت نيته إلى منع تعقيب القرارات المتصلة بالإيقاف التحفظي لنصّ على ذلك صراحة، وأنه طالما لم يكن المنع صريحا فإن المبدأ يظل الجواز، فإن هذا التبرير المأخوذ من القاعدة الأصولية الفقهية القائلة بأن «الأصل في الأشياء والأفعال والأقوال الإباحة ولا حكم (لا منع) لأفعال العقلاء قبل ورود النص» يخص شرعية الجرائم والعقوبات إذ لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، وهو مبدأ نص عليه الدستور وأقره الفصل الأول من المجلة الجزائية. أما مبدأ الشرعية في مادة الإجراءات الجزائية ومفاده أن لا إجراء دون نص صريح، فإن الأصل هو منع كل إجراء غير وارد بالقانون، وهو مبدأ وثيق الارتباط بشرعية الجرائم والعقوبات وبمبدأ التأويل الضيق في المادة الجزائية وجميع تلك المبادئ تدخل في إطار ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرها الدستور وأحاطها القانون بأحكام إجرائية وجوبية تضبط مسار الدعوى العمومية خلال كل الأطوار، ورتب البطالان جزء لكل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية وفقا لمقتضيات الفصل 199 من م ا ج.

وحيث أنّ التمسك بأنّ المشرع منع صراحة الطعن في ما يصدر عن دائرة الاتهام في مادة تسليم المجرمين الأجانب حسب الفصل 323 من م ا ج بما يفهم منه أنّ منع الطعن في القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام في مادة الإيقاف التحفظي يجب أن يتم التنصيب عليه صراحة في غير طريقه طالما أن ما يصدر عن دائرة الاتهام في تلك المادة هو رأي وليس قرار أو حكم وفقا لمقتضيات الفصلين 323 و 324 من م ا ج ولا يكتسي مقومات القرار القضائي القابل للطعن بالتعقيب، ورغم وجوبية تعليل رأي دائرة الاتهام القاضي بقبول التسليم، فإن القرار النهائي تتخذه الحكومة بمنح التسليم أو رفضه، وإذا قررت الحكومة منح التسليم، يعرض وزير العدل أمرا في الغرض على إمضاء رئيس الجمهورية. وبالتالي لا وجه للمقارنة بين قرار الإيقاف التحفظي والرأي الصادر في مادة تسليم المجرمين الأجانب لاختلاف طبيعة كل منهما من حيث المبادئ والمفاهيم والإجراءات والآثار القانونية، واتجه ترتيبا على ذلك صرف النظر عن هذا المبرر.

3 - في الحجة المستمدة من عدم ورود منع تعقيب قرارات الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت ضمن الفصلين 85 و 87 من م ا ج:

حيث بالرجوع إلى الفصلين 85 و 87 من م ا ج، يتضح أنّ المشرع نص صراحة على قابلية الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق سواء في الإيقاف التحفظي أو الإفراج المؤقت أو رفضه دون التنصيب على قابليتها للطعن بالتعقيب. إذ لو انصرفت نيته إلى جواز الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت وبقية القرارات المؤقتة لنص على ذلك صراحة على غرار الفصلين 29 و 30 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذين أجازا صراحة الطعن بتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مطلقا دون استثناء. كما تضمنت بعض القوانين المقارنة التنصيب صراحة على إمكانية الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة في مادة الإيقاف التحفظي كالقانون الفرنسي (الفصل 567 مطة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية) والقانون البلجيكي (الفصل 31 1 جوبلية 1990 المتعلق بالإيقاف التحفظي)، وأضحى هذا المبرر في غير طريقه وتعين الالتفات عنه.

4 - في الحجة المستمدة من اعتبار عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات الإيقاف التحفظي مساسا بمبدأ الحرية:

حيث لا جدال في أن حرية المتهم تعد من المبادئ التي كفلها الدستور وأن السلطة القضائية في جميع أطوار التقاضي تسهر على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك وهو المبدأ الذي كرسه دستور الجمهورية التونسية في فصله 102 الذي جاء فيه أن: «القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات...» غير أن اعتبار الحرية هي الأصل المقصود بالفصل 258 من م ا ج الأمر الذي يجوز معه الطعن في القرارات المتعلقة بإصدار البطاقات القضائية بما هي استثناء بمبدأ الحرية يتجافى ومفهوم الأصل المقصود بالفصل 258 المذكور وهو جوهر القضية ووقائعها والمعبر عنه باللغة الفرنسية fond في حين أن المقصود بعبارة الحرية في المادة الجزائية هو أن الحرية هي المبدأ أو القاعدة وأن الإيقاف التحفظي هو استثناء بصريح عبارة الفصل 84 من م ا ج الذي ينص على أن الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية. وتبقى هذه المحكمة مختصة بمراقبة حسن تطبيق القانون واحترام القواعد القانونية التي حددها المشرع في مادة الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت بشرط تعهدها بالنظر في القرار الصادر نهائيا في الأصل، واتجه ترتيبا على ذلك رد هذا المبرر لعدم وجاهته.

5 - في الحجة المستمدة من عدم ورود منع التعقيب في قرارات الإيقاف التحفظي ضمن الفصول المنظمة لدائرة الاتهام وضمن الفصول الخاصة بالإفراج المؤقت:

حيث اعتبر نواب الطاعن أن أحكام الفصول من 112 إلى 120 من م ا ج التي تنظم عمل دائرة الاتهام لا تشير صراحة أو ضمنا إلى عدم قابلية القرارات المتعلقة بإصدار بطاقات الإيداع للطعن بالتعقيب وهو قول يتعارض مع مبدأ الشرعية في مادة الإجراءات الجزائية، وإن عدم التنصيص على المنع لا يعني مطلقا الجواز في المسائل الإجرائية بقدر ما يعني المنع إذ لا إجراء دون نص صريح، ومن ثم فإن عدم وجود نص قانوني صريح يجيز الطعن بالتعقيب في قرارات الإيقاف التحفظي أو الإفراج المؤقت كما هو الشأن في القانون المقارن

على غرار القانون الفرنسي والبلجيكي تصبح معه إمكانية الطعن بالتعقيب في تلك القرارات غير ذات سند قانوني.

وحيث أن القرار المطعون فيه وإن كان صادرا عن دائرة الاتهام بصفتها درجة ثانية من التحقيق إلا أنه لم ينظر في أصل التهم المنسوبة للمظنون فيه وطالما تسلط الطعن على قرار تحفظي لا يستجيب للشروط التي حددها الفصل 258 من م ا ج، فإن الطعن فيه بالتعقيب يصبح فاقدًا للسند القانون وتعين رفضه شكلا. وحيث أن رفض مطلب التعقيب شكلا يغني عن النظر في بقية المطاعن من حيث الأصل.

وحيث خاب الطاعن في طعنه مما يتعين معه حجز معلوم الخطية.

لذا ولهذه الأسباب:

قررت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا والحجز

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 02 جوان 2020 عن الدائرة الخامسة والعشرون المتركة من رئيسها السيد محمد العسكري وعضوية المستشارين السيد إبراهيم الغرياني والسيدة نجوى الشريف وبحضور المدعي العمومي السيد نور الدين الزياتي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد علي العمراوي.

وحرر في تاريخه



الكتاب الثالث

نشاط محكمة التعقيب

وحيث وتأسيسا على ما سلف النظر إليه فان مطلب تصحيح الخطأ البين لا يكون مقبولا الا اذا قدم خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار المنتقد.

وحيث ان منطلق الاحتساب يكون من اليوم الموالي لصدور القرار، ذلك ان القاعدة تقتضي ان يوم العد لا يعد عملا باحكام الفصل 140 من ماع الذي نص على ان يوم ابتداء عد مدة الاجل لا يكون معدودا منه وان قدر بالايام فانه يتم عند تمام اليوم الاخير منه.

وحيث كان صدر القرار المنتقد يوم 09 / 08 / 2019 فتكون بداية الاحتساب من يوم 10 / 08 / 2019.

وحيث اقتضى الفصل 141 من ماع انه اذا قدر الاجل بالاسابيع أو الاشهر أو السنين اعتبر الاسبوع سبعة ايام كاملة والشهر ثلاثون يوما كاملة والسنة ثلاثمائة وخمس وستين يوما كاملة.

وحيث قدم مطلب تصحيح الخطأ البين يوم 08 / 11 / 2019 أي في اليوم الواحد والتسعين من تاريخ صدور القرار وهو ما يعد معه قد ورد خارج الاجل القانوني .

وحيث ان اجال الطعن تعد من صميم الاجراءات الأساسية وهي من المسقطات التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت وعليه فانه وجب تقديم مطلب تصحيح الخطأ البين في غضون تسعين يوما ولا ينبغي حصول التقصير في جانب من تولى تقديمه ذلك ان الاجل محدد بداية من صدور القرار التعقيبي المنتقد والذي يمتد إلى نهاية التسعين يوما باعتماد تاريخ تقديم المطلب دون غيره.

وحيث ان مطالب الخطأ البين لا تحتمل التقصير البين ومن ذلك مسألة الاجال التي تعد من الاجراءات الاستثنائية والتي احاطها المشرع بكثير من الدقة والصرامة.

وحيث وعلى نحو ما سلف فيه من البيان فان مطلب تصحيح الخطأ البين يكون قد سقط لوروده خارج الاجال القانونية.

وحيث ان اجراءات مطالب تصحيح الخطا البين تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وهو الأمر الذي يتجه معه رفض مطلب تصحيح الخطا البين شكلا جزاءا باحكام الفصل 193 من م.م.ت.

حيث اخفقت الطاعنة في طعنها واتجه حجز معلوم الخطية المؤمن».

- قرار صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 458 بتاريخ 1 أكتوبر 2020

«من حيث الشكل:

حيث نص الفصل 192 من م.م.ت أنه :

«تنظر الدوائر المجتمعة أيضا :

(1) إذا كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين الدوائر.

(2) عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر في أول الفقرة ويعتبر الخطأ بينا:

(1) إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.

(2) إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق.

(3) متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.»

وحيث نص الفصل 193 من م.م.ت على أنه:

«تتركب الدوائر المجتمعة من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة على أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة عن الثلاثين من كل صنف وتعد جلساتها بمحضر وكيل الدولة العام وبمساعدة كاتب المحكمة وتجتمع بدعوة من الرئيس الأول ويكون رأيه مرجحا عند تعادل الآراء.

وله دعوتها بطلب من أحد الخصوم للنظر في تصحيح خطأ بين حاصل في قرار إحدى الدوائر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وبعد أخذ رأي وكيل الدولة العام في الموضوع.

وفي هذه الصورة تبت الدوائر المجتمعة طبق أحكام الفصل 176-177-178 و197».

وحيث ومنذ صدور القرار التعقيبي الجزائي عدد 297 بتاريخ 29/12/2011 أوضحت الإمكانية متاحة للنظر في مطالب تصحيح الخطأ البين في المادة الجزائية

بالنظر لوحدة الأخطاء سواء في المادة المدنية أو الجزائية وعلى هذا الأساس وقع الاستنجد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية لملئ الفراغ المسجل بمجلة الإجراءات الجزائية.

وحيث استقر فقه قضاء محكمة التعقيب منذ صدور القرار التعقيبي عدد 42 بتاريخ 10/12/1991 على اعتبار الأجل الوارد بالفصل 193 من م.م.م ت من المسقطات ضرورة أن المشرع عند ضبطه لمواعيد الطعن قد جعل هذه الأخيرة من قبيل الحق المؤقت ذلك أن القانون يحدد فترة زمنية معينة لقيامه فإذا لم يرفع في ميعاده سقط الحق فيه .

وحيث أن أجال الطعن تعد من صميم الإجراءات الأساسية وهي من المسقطات التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من م.م.م ت وعليه فانه وجب تقديم مطلب تصحيح الخطأ البين في غضون تسعين يوماً ولا ينبغي حصول التقصير في جانب من تولى تقديمه ذلك أن الأجل محدد بداية من صدور القرار التعقيبي المنتقد والذي يمتد إلى نهاية التسعين يوماً باعتماد تاريخ تقديم المطلب دون غيره .

وحيث ثبت بالإطلاع على مظروفات الملف أن مطلب تصحيح الخطأ البين قدم لكتابة محكمة التعقيب بتاريخ 15 نوفمبر 2019 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه وفق أحكام الفصل 193 من م.م.م.ت المذكور.

وحيث أن الأجال المتعلقة بالطعون تهم النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لتعلقها بالإجراءات الأساسية ما يتجه معه رفض مطلب تصحيح الخطأ البين شكلاً والحجز عملاً بأحكام الفصلين 13 و 193 من م.م.م.ت.

قرارات الدوائر

1- شخصي

1-1 استقرار الزوجة بعيدا عن زوجها في إطار نقلة عملها لا يعتبر إخلالا منها بواجب المساكنة.

قرار تعقيبي عدد 80441.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثامنة برئاسة السيدة مفيدة الشوالي وعضوية المستشارتين السيدتين بسمة بودن وهاجر الشريف وبحضور المدعي العام السيد محمد الزواوي ومساعدة كاتب المحكمة السيد توفيق المناصري.

حيث أن التحقيق في الضرر يعدّ من مشمولات محكمة الموضوع لما لذلك من علاقة وارتباط مع ملاسبات النزاع ومعطياته ولا رقابة لهذه المحكمة على ما خلصت إليه كلما بررت وجهة نظرها بتعليل سليم وقراءة صحيحة للوقائع.

وحيث أن المساكنة تعدّ من أبرز مكونات الزواج وغاياته وهي تقتضي مساكنة الزوجة لزوجها بمحلّ الزوجية تحقيقا لتلك الغاية والإخلال بذلك يترتب عنه مبدئيا ضرر يلحق بالزوج إلاّ أن إنعدام المساكنة لا يمكن النظر فيه بمعزل عن الظروف والملاسبات المحيطة به على غرار ما تفرضه بعض الوضعيات من عمل الزوجة أو الزوج بعيدا عن محلّ الزوجية لذلك وجب النظر إلى ذلك الواجب في إطار ظروف الزوجين وهو ما تطرحه الوقائع الماثلة التي ولئن ثبت منها استقرار الزوجة بجهة المرسى بعيدا عن زوجها القاطن بسليمان إلاّ أنّ ذلك كان في إطار نقلة عملها التي وبقطع النظر عن سببها فإن المحكمة قد تعاملت مع ذلك المعطى الواقعي واستنتجت منه ثبوت المبرر لعدم المساكنة خاصة في ظل موقف الزوجة الثابت والمعبر عن إرادتها وتمسكها بالحياة الزوجية وهو ما ينفي عنها نية مغادرة محلّ الزوجية رفضا للمساكنة كسبب أساسي يسند دعوى المعقب ضده القائمة على أساس الضرر وهو الأمر الذي تناولته محكمة الحكم المطعون فيه في إطار ملاسبات النزاع المطروحة أمامها وانتهت إلى إنتفاء الضرر بتعليل سليم لا تملك هذه المحكمة سلطة الرقابة عليه وعلى ما آل إليه اجتهادها الذي كان معللا تعليلا

سليما لا يشوبه ضعف أو هضم لحق الدفاع أو خرق للقانون وتعين لذلك رد المطعنين لعدم سدادهما».

1- 2 ربط الزوجة لعلاقة غرامية مع شخص غير زوجها عبر شبكة التواصل الاجتماعي يمثل ضررا محققا.

قرار تعقيبي عدد 82073.2019 بتاريخ 26 فيفري 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثامنة برئاسة السيدة مفيدة الشوالي وعضوية المستشارتين السيدتين بسمة بودن وهاجر الشريف وبحضور المدعي العام السيد محمد الزواوي ومساعدة كاتب المحكمة السيد توفيق المناصري.

«عن المطعنين معا لارتباط القول فيهما:

حيث إن الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية يشمل جميع أوجه الضرر سواء كان حسيا أو ماديا وهو ما يخلص من إطلاق المشرع لعبارة الضرر الواردة بالفصل 31 من م.أ.ش وفي هذا الصدد فإن المحكمة المتعدهة بالبحث في الضرر لا تعد مقيدة بالنتيجة الجزائية إلا في حدود ما بت فيه القاضي الجزائي من ماديات ووقائع وذلك بالنظر لمفهوم الدعوى العامة وآثارها التي تكون نافذة في حق الكافة بما في ذلك القاضي المدني إلا أنّ ذلك لا يمكن أن يشكل حائلا أمام المحكمة المتعدهة بالطلاق للضرر في البحث في وجه آخر في الضرر حتى ولئن كانت النتيجة الجزائية من مؤيدات الدعوى وذلك في إطار مفهوم الزواج القائم على التزامات متبادلة والواجبات المحمولة على الطرفين بموجب الفصل 23 من م.أ.ش لذلك فإنّ إنتفاء التهمة الجزائية عن طرف لا يمنع المحكمة من البحث في الضرر وفي الالتزامات المحمولة على الطرفين بحسن المعاشرة وتجنب إلحاق الأذى بالقرين وهي من الأمور الراجعة أيضا لمطلق اجتهادها فلا يمكن مؤاخذتها على الأخذ بحجة أو ترك أخرى حدودها في ذلك التعليل السليم المبني على قراءة صحيحة للوقائع دون هضم لحق الدفاع .

وحيث إن إلحاق الأذى بالقرين يشكل ضررا موجبا للطلاق ولا شك أنّ الأذى كما يأخذ شكلا ماديا قد يأخذ مظهرا معنويا على غرار ما تطرحه الوقائع الماثلة التي استبان منها ربط الطاعنة لعلاقة غرامية مع شخص غير زوجها عبر شبكة التواصل الاجتماعي ولا يمكن الدفع بشأنها بأنّها من قبيل اللقاءات العفوية

التي لا تكتسي معنى الضرر المحقق بالنظر إلى خصوصية عقد الزواج الذي ينفرد طرفاه بتحديد مدى التصرف المؤذي والمؤثر على استمرار العلاقة والذي يكتسي طابعا ذاتيا يكون فيه الطرف المتظلم هو القادر لوحده على تحديد مصير العلاقة الزوجية بتجاوز ما صدر عن الطرف الآخر عند الاقتضاء من فعل مخل بواجب حسن المعاشرة ومؤثرا في العلاقة معنويا فيقتصر دور المحكمة في هذا الصدد في البحث من الناحية القانونية حول ثبوت التصرف المؤذي من عدمه في إطار خصوصية عقد الزواج وهو أيضا الأمر الذي حققت فيه محكمة الحكم المطعون فيه في إطار مشمولاتها في تقديم الأدلة ولم تقتصر على معاينة الإرساليات من طرف عدل التنفيذ بل أيضا على ما ثبت من محضر البحث الجزائي من ماديات تؤكد وجود علاقة بين الطاعنة وبين شخص غير زوجها .

وحيث إن ما استخلصته محكمة القرار المنتقد من ثبوت إضرار الزوجة بزوجها بانتهاكها واجب الإخلاص وواجب تجنب إلحاق الأذى بالزوج كان مبنيًا على قراءة صحيحة للوقائع وللأدلة المعروضة عليها ولم تثبت المعقبة خلفها أو ما تدّعيه من احتمال اختراق لحسابها على شبكة التواصل الاجتماعي كما عللت المحكمة النتيجة المنتهية إليها تعليلا سليما ضافيا لا يشوبه ضعف أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع وأضحى الطعن يمثل جدلا موضوعيا يهدف إلى مناقشة محكمة الأصل في اجتهادها المعلن وإلى إعادة عرض الوقائع من جديد على محكمة القانون وتعين لذلك رده».

1-3 تأويل عبارة «في ظل الحياة الزوجية» الواردة بالفصل 31 م أ ش في تقدير التعويض عن الطلاق

قرار تعقيبي عدد 2020.20113 بتاريخ 10 أوت 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة بسمة العيساوي وعضوية المستشارين السيد مكرم الخذري والسيد يوسف رمضان وبحضور ممثلة الادعاء العام السيد شاكر التواتي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيد احمد عبيد .

«عن جميع المطاعن لاتحادها وترابطها:

«تحريف الوقائع وضعف التعليل المتعلق بالضرر المعنوي والمادي:

قولا بأن المحكمة أقرت بضرر المعقبة لكنها تغافلت عن طلبها في الترفع في الغرم المعنوي والمادي بناء على قصر مدة الحياة الزوجية وعدم وجود أبناء ولم تأخذ المحكمة في تعليلها بعين الاعتبار سن المعقبة الذي ناهز 43 سنة ما يجعل فرصتها في الزواج ثانية وإنجاب أبناء شبه مستحيلة خلافا لما استندت إليه المحكمة كما أنّ المحكمة استندت إلى قصر مدة الزواج لتحديد الغرم المعنوي والحال أنّ المدة من إبرام عقد الزواج إلى صدور حكم بات في الطلاق وهو ما أقرته محكمة البداية لما اعتبرت مدة الزواج سنتين اثنتين كما إنّ طول نشر النزاع قد اثر سلبا على وضعية المعقبة بان تقدمت عن السن وأصبحت حظوظها في إنجاب أطفال مستحيلة كما تجاهلت المحكمة ما قدمته من حجج تفيد تأثير الطلاق على وضعيتها الصحية وما يثبت كذلك دخلها المادي المحدود رغم عملها كمحامية وهو مما يجعل من القرار المطعون فيه ضعيف التعليل ومحرفا للوقائع وموجبا للنقض.

وحيث اقتضى الفصل 123 من م.م.م.ت أنّه «يجب أن يضمن بكل حكم المستندات الواقعية والقانونية.

وحيث نص الفصل 31 من م.الأحوال الشخصية أنّه: «ويقضي لمن تغرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق وبالنسبة إلى المرأة يعوض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات.»

وحيث وخلافا لما تمسكت به المعقبة فان محكمة القرار المتتقد استندت إلى شروط أحكام الفصل 31 من م.الأحوال الشخصية السالف بسطه واعتبرت أنّ المدة الفعلية للحياة الزوجية هي مدة قصيرة وهو تفسير يتماشى مع مفهوم «في ظل الحياة الزوجية» الذي استعمله المشرع أي المدة الفعلية التي استمرت عليها الحياة الزوجية وتواجد الزوجين مع بعضهما بمحل الزوجية دون احتساب مدة نشر قضية الطلاق لدى المحكمة وهو تفسير يتطابق مع الشروط المنصوص عليها بالفصل 31 من م.س هذا فضلا على أنّ محكمة القرار المطعون فيه اعتبرت إنّ

سن المعقبة وعدم وجود أبناء تمنح المعقبة فرصة في بناء حياة جديدة وهو تعليل يتمشى مع الواقع الاجتماعي باعتبار تأخر سن الزواج لدى الإناث والذكور وإمكانية إعادة تزوج المعقبة باعتبارها لم تنجب ابناً ونظراً لمكانتها الاجتماعية وإن الدفع المتعلق لعدم القدرة على الإنجاب وتأثير الطلاق على وضعيتها الصحية فظلت دفعات مجردة عما يؤيدها ولم تقدم المعقبة ما يثبت العلاقة السببية المباشرة بين الأضرار المشخصة بالشهادات الطبية واتجه رد المطعن.

وحيث أسست محكمة القرار المطعون فيها قرارها في خصوص التعويض عن الضرر المادي على أساس قانونية سليمة وعللت رأيها تعليلاً قانونياً مستساغاً بما له أصل ثابت بملف القضية ودون خرق لأحكام الفصل 31 من م.أ.ش. وبينت الأسس الواقعية والقانونية التي أسست عليها قضاؤها ولم يشوبه أي ضعف في التعليل باعتبار انتفاء شرط الاعتياد على مستوى العيش المنصوص عليه بالفصل 31 من م.أ.ش. وذلك نظراً لقصر المدة الزمنية للحياة الزوجية الفعلية وهي أربعة أشهر (04) فضلاً على اعتماد محكمة القرار المطعون فيه على عنصر المستوى المادي للزوج وهو عنصر الثراء والمستوى المادي للزوجة المعقبة بوصفها تعمل كمحامية مع الأخذ بعين الاعتبار التصاريح الجبائية المقدمة المضافة لملف القضية والمعتمدة من المحكمة كعنصر تقدير أولي وانتهت إلى الحط من المبلغ اعتباراً لشططه وهو تقدير إنبنى على عناصر واقعية وقانونية سليمة راعت الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة والمستوى المادي لكل منهما بما له أصل ثابت من مؤيدات مطروفة بملف القضية وأضحى من الدفع غير مؤسس قانوناً واتجه رده لعدم وجاهته.

وحيث لم تأت أسانيد الطعن بما من شأنه أن يوهن مستندات القرار المطعون فيه والتي تأسست على عناصر قانونية وواقعية سليمة واتجه معه رفض مطلب التعقيب أصلاً».

1-4 نفي النسب بناء على التحليل الجيني-الحجية القاطعة للتحليل الجيني
قرار تعقيبي عدد 23704 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثالثة برئاسة السيدة نعيمة رحيم وعضوية المستشارتين السيدة عبير الخلفي

والسيدة نورة نوري وبمحضر ممثل الادعاء العمومي السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوي.

«عن المطعنين المتعلقين بمخالفة القانون وتجاوز السلطة وتحريف الوقائع لترابطهما ووحدة القول فيهما

حيث انحصرت دفوع الطاعنة حول المنازعة في نتيجة التحليل الجيني سند قضية الطلاق للضرر ومعارضتها لنتيجته وان إهمال المحكمة لتلك المنازعة يعد تحريفا للوقائع وتجاوزا للسلطة

وحيث إنّ معارضة نتيجة اختبار علمي على غرار التحليل الجيني حتى تكون منازعة جدية وحرية بالاهتمام لا تستوجب الاكتفاء بالإنكار وطلب إعادة التحليل وإنّما تفترض تقديم نتيجة علمية تدحض تلك النتيجة وتقلل من مصداقيتها فمجرد الإنكار والمعارضة لنتيجة اختبار علمي دقيق دون تقديم حجة علمية موازية له تدحض النتيجة التي انتهى إليها يغني المحكمة عن الالتفات لتلك المنازعة ضرورة ان للمحكمة سلطة تقديرية لا في تقدير حجية المؤيدات فقط وإنّما أيضا في تقدير مدى جدية الطلبات المعروضة عليها من الخصوم.

وحيث إنّ محكمة القرار المطعون فيه لما التفتت عن معارضة المعقبة لنتيجة التحليل الجيني وطلبها إعادته دون تقديم حجة مضاهية للقيمة العلمية للتحليل الجيني إنّما تكون قد أحسنت تقييم جدية طلبها الغير معزز بما يبرر الاستجابة إليه ولا تثريب عليها فيما انتهت إليه ضرورة أنّ ملف القضية معزز بنتيجة تحليل جيني منجز في فرنسا أكد نفس النتيجة الواردة بالتحليل الجيني المأذون به من المحكمة.

وحيث أنّ استناد محكمة الأصل على قرار استئنافي نهائي في نفي النسب بناء على التحليل الجيني الذي اقر بنفي نسب الطفلة «م.» عن المعقب ضده لا يحتاج إلى صيرورته باتا حتى يعتد به كحجة على اعتبار وان حجية قيمة التحليل الجيني تعد قرينة قاطعة قائمة الذات دون ضرورة انتظار صيرورة القرار باتا سيما وان ملف القضية خلو مما يدحض حجية ذلك الاختبار وأضحت دفوع الطاعنة في غير طريقها واتجه رفض مطلب التعقيب أصلا».

1-5 التمييز بين مؤسستي الحضانة والتقديم على القاصر

قرار تعقيبي عدد 75417 بتاريخ 29 جوان 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيد البشير المطوي وعضوية المستشارين السيدين مريم البكوش وعربية الطويهرى وبمحضر المدعي العام السيد رفيق الحداد وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوي.

«حيث اقتضى الفصل 191 م.م.م.ت أن «القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض وإذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى وحكمت هذه بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولاً فإن محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة وإذا رأت النقض فإنها تبت في الموضوع إن كان مهياً للفصل.

وإذا رأت إرجاع القضية فإن قرارها يكون واجب الإلتباع من طرف محكمة الإحالة.»

وحيث انتهت محكمة التعقيب بقرارها الصادر في القضية عدد 22925.2015 بتاريخ 23/12/2015 إلى أن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 جاءت محددة وبصورة دقيقة وواضحة في قضايا التقديم التي ينظر فيها حاكم التقادير وهي حالة العجز للقاصر الذي لا ولي له وهي غير صورة الحال سيما أن تواجد والد البنيتين على قيد الحياة وصفته كولي شرعي يغني المحكمة من الخوض في الطلب فالنص 7 المذكور يتعلق بالاختصاص الحكمي لقاضي التقادير ولا مجال للتوسع في مفهومه وإن القول بأن الموضوع يهم صور التقديم وشروطه وليس مسألة الاختصاص هو قول مردود على محكمة الحكم المنتقد ويتعارض مع صريح عبارات الفقرة الثانية من الفصل 7 من الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 وتبعاً لذلك فإن محكمة الأصل لما قضت لصالح الدعوى تكون قد خلطت بين أحكام مؤسسة التقديم ومؤسسة الحضانة التي تخضع للمصلحة الفضلى للمحضون بينما تخضع مؤسسة الولاية التي تثبت

ولاية الأب وتتدخل المحكمة عبر حاكم التقاديم لسد الفراغ أو الشغور بوفاته أو فقدانه لأهليته.

وحيث خالفت محكمة الإحالة - المطعون في حكمها الآن - ما انتهت إليه محكمة التعقيب بالقرار المشار إليه أعلاه واعتبرت أن «لا شيء بالفصل 7 المذكور ما يفيد صراحة أو دلالة أن الصور الواردة به للتعهد جاءت على سبيل الحصر لا الذكر في غير صورة الصغير الذي لا ولي له»... وإنه ولئن كانت مؤسسة التقديم مستقلة عن مؤسسة الحضانة ، فإن الحضانة تمنح الحاضن جزء من صلاحيات الولاية على النفس فيما تمنح مؤسسة التقديم جزء من صلاحيات الولاية على المال... وإنه في إطار نظر قاضي الأسرة في مسألة حضانة البنّتين القاصرتين س.و.ع. اسند الحضانة للمستأنفة حالياً بناء على العلاقة الحميمة التي تربط الجدة المستأنفة والحفيدتين اللتين كانتا ضمن حضانتها الفعلية منذ قائم حياة والدتهما والتي تم إسنادها لاحقاً قضائياً لما للحضانة من أهمية وخطورة... وإن إسناد الحضانة وهي ضرب من ضروب الولاية على النفس وما تتسم به من خطورة بتوفير الرعاية والتنشئة والسهر على حسن التربية فانه من باب أولى وأحرى أن تقدم المستأنفة على أموال المحضونتين ..»

وحيث عقب المسوّغ القرار الإستئنافي المذكور ناعياً عليه أن محكمة الأصل لم تناقش ما تم التمسك به بخصوص انه لا يلجئ إلى التقديم على القاصر إلاّ عند وفاة الأبوين ولم يكن للقاصر وصي أو ولي وأهملت المحكمة المذكورة تطبيق أحكام الفصل 154 والفصل 8 م.أ.ش حال أن المشرع قد ضبط في إطارهما الإطار العام للولاية على القاصر ونظام تداولها بين الأب والأم والوصي ولا يلجئ إلى التقديم إلاّ عند وفاة الأبوين كما أساءت تأويل وتطبيق أحكام الأمر المؤرخ في 18/7/1957 المتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم ذلك أن التقديم المطلوب ليس من ضمن حالات الفصل 7 المذكور والذي لم ينصّ على إمكانية تسمية مقدم على الصغير الذي له ولي شرعي وان المحكمة قد سعت إلى تحميل النص القانوني ما لا يتحمّله صريح لفظه ، كما أساءت المحكمة فهم مؤسسة الحضانة ذلك أن إسنادها للجدة لا ينفي ولاية الأب وحيث أضحى الخلاف بين محكمة التعقيب ومحكمة الإحالة منحصر في تأويل أحكام الأمر المؤرخ في 18/07/1957 المتعلق بترتيب تسمية المقدمين

ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم ولا سيما الفصل 7 منه ومن ثمة مدى اعتبار قاضي التقادير مخولاً للاستجابة لطلب التقديم المقدم من حاضنة القاصر في قائم حياة وليه وما يفرضه البت في كل ذلك من ضرورة التمييز بين مؤسستي الحضانة والتقديم، وهو ما تتوفر معه شروط تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة للنظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من محكمة الإحالة عملاً بالفصل 191 م.م.ت.م.

2 - اجتماعي

1-2 شغلي

1-1-2 اختلاف الاضراب غير الشرعي عن الاحتجاج والصدّ عن العمل.
قرار تعقيبي 74361/2020 بتاريخ 7 فيفري 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة التاسعة عشر برئاسة السيدة حياة البصلي وعضوية المستشارين السيد الأنور الكعلي والسيدة هاجر الخالدي وبمحضر المدعي العام السيد لطفي بن سليمان ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«عن جملة المطاعن بالمطلب ع-74361 دد لترباطها ولاتحاد القول فيها.
حيث دفعت المعقبة بتحريف محكمة الحكم المطعون فيه للوقائع حين عللت قضاءها بنقض حكم البداية قولاً بأنه تأسس على الأحكام الجزائية دون البحث في غيرها من المؤيدات

كما دفعت بان ما اعتمدته المحكمة المطعون في حكمها من مؤيدات سبق وان تناولته محكمة البداية وتجاوزت الأخذ به لعدم قانونيته.

وحيث عللت محكمة القرار المنتقد حكمها قولاً بان محكمة البداية قد استندت في قضائها إلى الأحكام الجزائية القاضية بعدم سماع الدعوى دون الإلتفات إلى بقية المؤيدات في حين ثبت من أوراق الملف وخاصة من حكم البداية إنّ المحكمة التي أصدرته لم تؤسس قضاءها بانتفاء الخطأ على أي حكم جزائي قضى بعدم سماع دعوى تهمة الإضراب غير الشرعي فضلاً عن أنّه من الثابت أنّ التداعي الجزائي في خصوص التهمة المذكورة صدرت بشأنه أحكام

لاحقة عن صدور حكم البداية فكان ما انتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من تقدير فيه تحريف للوقائع.

وحيث وفضلا عن ذلك فانه ولئن كان من المقرر أنّ للقاضي الشغلي مطلق الاختصاص في تقدير وقائع الدعوى وتفحص الحجاج والأدلة بما من شأنه أن يثبت الادعاء أو ينفيه دون التقيد بما يصدر من أحكام جزائية على اعتبار أنّ الخطأ المهني يبقى مستقلا عن الخطأ الجزائي فان ذلك يبقى مشروطا أيضا بسلامة تناوله لهذه الحجاج ومناقشتها وبيان سنده في اعتمادها من عدمه وان ذلك عنصر أساسي في تسببه للحكم الأمر الذي أساءت تقديره محكمة الحكم المطعون فيه بما ثبت من كونها استندت إلى قائمة اسمية من العملة لم تكن جزءا من محضر معاينة عدل التنفيذ لواقعة الإضراب المدعى به من المؤجرة وإنّما تسلمها من الممثل القانوني للمؤجرة وقد ذيل عدل التنفيذ القائمة بملاحظته التي أكد من خلالها أنّ الأسماء الواردة بالقائمة هي بذكر من ممثل الشركة وبالتالي ليست نتيجة معاينته للواقعة.

ما تكون معه محكمة القرار المنتقد لما استندت في إثباتها للواقعة المدعى بها من المؤجرة على قائمة اسمية للعملة المدعى بمشاركتهم في الإضراب على اعتبار أنّها جزء من محضر معاينة عدل التنفيذ للواقعة والحال أنّ القائمة تم إعدادها من الممثل القانوني للشركة المؤجرة تكون قد أساءت تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها إلى حد تحريفها وأسست قضاءها على مؤيدات لا ترقى إلى مرتبة الحجة القانونية وكان ما انتهت إليه من نتيجة قد إنبنى على تحريف للوقائع وخرق للقانون ما يجعله موجبا للنقض من هذا الجانب.

وحيث وفضلا عن ذلك فقد أجمعت المحكمة في الموازنة بين الأدلة حين تجاوزت عن محضر المعاينة والعرض على العمل المحرر بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ «ع.الج». بتاريخ 10/6/2014 تحت عدد 17576 والذي تبين منه العرض على العمل من جهة الإجراء ومن ضمنهم المعقبة الآن ورفض الممثل القانوني للمؤجرة قبولهم لأنه قدر بأنهم في إضراب غير شرعي منذ الأمس وان الملف لدى كل من النيابة العمومية وتفقدية الشغل ولم تعلل المحكمة ما حملها

على تجاوز المحضر المذكور وعدم اعتماده أو حتى مناقشته وبيان سندها في رده.

وحيث وفضلا عن ذلك أيضا فقد عللت محكمة القرار المنتقد قضاءها بثبوت الخطأ في جانب المعقبة قولاً بأن «محاضر المعاينة بتاريخ 9 و 10 جوان 2014 وشهادة زملائها في العمل أكدت في مجملها وقوع الخطأ الفادح المنسوب إلى المدعية في الأصل» فكان تعليلها لذلك لا يرقى إلى التعليل السليم والمستساغ فلا هي دقت في المقصود منها بمحاضر المعاينة بتاريخ 9 و 10 جوان 2014 ببيان مصدرها ولا بينت مضمونها وما دلت عليه هذا المضمون حتى يحملها على الأخذ به كما لم تبين هويات الشهود المستند إلى شهاداتهم ولا مضامين هذه الشهادات ولا أيضا السند المادي المضمنة به هذه الشهادات، وبالتالي مدى حجيتها على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 92 من م.م.م.ت، حتى يبقى من حق الأطراف مناقشة مضمون هذه الشهادات كمناقشة سند تلقيها وهي مسألة مبدئية يكون إغفالها من المحكمة مرتباً لنقض حكمها لما في ذلك من هضم لحق الدفاع وخرق للقانون ما يجعل الحكم قاصراً عن التسبيب وضعيفاً في التعليل.

وحيث وفضلا عن ذلك فقد تسلطت دفوع المعقب ضدها أمام محكمة الموضوع بطوريها على اعتبار أن قطع العلاقة الشغلية كان من جانب المعقبة لمشاركتها في إضراب غير شرعي وعليه فإن العلاقة الشغلية بين الطرفين تكون قد انقطعت آلياً على معنى أحكام الفصل 387 من م.ش. في حين تمسكت المعقبة بنفي ادعاء المعقب ضدها في خصوص تعمدتها المشاركة في إضراب غير شرعي.

وحيث من المقرر فقها وقضاء أن طرح الوقائع ولئن كانت مسألة يختص بها صاحب الادعاء فإن تكييفها وصبغ الطبيعة القانونية الصحيحة عليها يبقى من مطلق اختصاص محكمة الموضوع وذلك بعد التأكد من ثبوت تحققها كالتأكد من ثبوت نسبتها للمدعى عليه سواء كان طالبا أو مطلوباً في الدعوى.

وحيث وفضلا عن أن ما انتهت إليه المحكمة في خصوص ثبوت الأفعال في جانب المعقبة كان فاقداً للتعليل السليم وذلك بمثل ما سلف بسطه فانه من الثابت من الحكم المنتقد أن المحكمة التي أصدرته لم تتمحص من الأفعال التي اعتبرت أنها ثابتة في جانب المعقبة ولم تكييفها التكييف القانوني الذي هو

من مطلق اختصاصها بل سلّمت بأنّها مكونة لواقعة الإضراب غير الشرعي دون بيان السند المادي والقانوني المعتمد منها للقطع بالنتيجة التي توصلت إليها كما اعتبرت أنّ الإضراب غير الشرعي هو من قبيل الخطأ الفادح كل ذلك بعد أن حققت أنّ الحكم الجزائي القاضي بالبراءة من تهمة الإضراب غير الشرعي لا يقيد قاضي الشغل المخول له قانونا تقدير وموازنة الخطأ المهني وثبوته.

وحيث لا خلاف في أنّ المشرع التونسي لم يعط تعريفا مدققا للإضراب بل إقتصر على تنظيمه وتحديد شروط ممارسته في الباب الثالث عشر من مجلة الشغل تحت عنوان «تسوية نزاعات الشغل الجماعية» في الفصول 376 جديد وما بعده.

وعرفته الدوائر المجتمعة لهذه المحكمة بأنّه «توقف مجموعة من العملة معا قصد تحقيق طلبات مهنية وهو يقوم خلافا للعقد ويستمد شرعيته من القانون الذي خوله للأجراء وفق شروط معينة وإجراءات محددة باعتباره وسيلة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والحصول على تعديل في شروط العمل وفي مجابهة ما يتمتع به المؤجر من وسائل تنظيمية واقتصادية تجعل من الأجير تابعا له».

الأمر الذي يخلص منه أنّ تحقق محكمة الموضوع من واقعة الإضراب يجب أن تطرح عندما يتضح من ظروف الواقعة أنّ أساس الخلاف بين الطرفين مرده النزاع الجماعي على معنى أحكام الفصل 376 وما بعده من م ش ذلك أنّ الإضراب هو توقف جماعي واتفاقي مؤقت عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية مشتركة، ويمارس هذا الحق من طرف الهيكل النقابي الممثل للعملة وطبقا لما اقتضاه التشريع الجاري به العمل وقد نظم المشرع ضمن الباب الثالث عشر المذكور السبل الواجب إتباعها لممارسة هذا الحق كما اعتبر أنّ الإضراب الواقع في مخالفة لهذه السبل هو إضراب غير قانوني.

وحيث وبناء على ما سلف بسطه فإنّ إثبات الإضراب غير القانوني يفترض بالضرورة أن يكون المدعى عليه بارتكابه قد خالف جملة من الشروط الإجرائية لتنفيذ إضراب قانوني وهي مسالة فنية بالأساس ولا يمكن معاينتها إلّا من أهل الاختصاص لذلك خص المشرع ضمن أحكام الفصل 174 من م ش أعوان تفقدية الشغل بهذه المهام لما لهم من المعرفة والدراية بقوانين الشغل وتشاريعه

بما يخول لهم الوقوف على الأفعال حال قيامها ومعاينتها والتدقيق في ظروف وملابسات قيامها ما يخول لهم التحقق، في مرحلة أولى، ما إذا كانت تدخل في خانة الإضراب فإن صح ذلك يتأكد العون، في مرحلة ثانية، ما إذا كان الإضراب قانونيا أو غير قانوني.

وحيث وفضلا عن ذلك فإن المشرع لما خص أعوان تفقدية الشغل بمعاينة الإضراب فهو قصر ذلك على الجانب الفني للفعل دون واجب التحقق من هويات المشاركين في الإضراب لذا فهو لم يمنع عن المحكمة اعتماد بقية الحجج والأدلة والتي منها معاينة عدول التنفيذ وبقية أعوان الضابطة العدلية حيث تكون لمحاضرهم حجية في إثبات وجود الأجير ومشاركته في الإضراب فيكون بذلك على قاضي الشغل، وبعد ان يتبين له من ملابسات الوقائع وظروف حصولها أنها تنزلت في إطار نزاع جماعي بين الطرفين وان الهيكل النقابي للطرف العمالي هو من دفع بالإضراب، أن يتمحص من مدى احترام شروط الإضراب ومتى لم تراعى هذه الشروط، بحسب ما يتوفر لديه من حجج تؤكد ذلك، يكتف الواقعة على أنها من قبيل الإضراب غير الشرعي ويعلل ما انتهى إليه من نتيجة بما له سند ثابت بالملف واستنادا إلى النص القانوني الصحيح الأمر الذي أغفلته محكمة القرار المنتقد في حكمها.

وحيث وفضلا عن ذلك فإن الإضراب غير القانوني وعلى اعتباره من قبيل الخطأ فقد أفرد المشرع بطبيعة خاصة لان الفعل المكون له لا يتج إلا خطأ واحدا وهو الإضراب غير القانوني ومع انه خطأ واحد إلا أن المشرع رتب عليه وبصريح الفصلين 387 و388 من م ش جزاءين مختلفين الأول مدني أو مهني بالأساس والثاني جزائي فيكون بالتالي البحث في توفر أركان الخطأ هو واحد سواء تعهد قاضي الشغل بالدعوى الشغلية أو تعهد القاضي الجزائي بالدعوى الجزائية

غير انه وحتى مع سبق تعهد القاضي الجزائي بالمسالة والبت فيها فان ذلك لا يمنع قاضي الشغل من البحث والتمحص من الوقائع حين تعهده بالدعوى وذلك اعتبارا للسببين:

أو لهما إنَّ الحكم الجزائي يبقى مؤيدا من مؤيدات الدعوى ولا تقوم حجته على الدعوى المدنية إلا متى تبين للمحكمة المتعده انه بحث في مدى توفر شروط الإضراب غير القانوني بمثل ما اقتضته أحكام الفصول 376 وما بعده من م ش وانتهى في صريح حكمه إلى أنَّ أركان الإضراب غير القانوني قد توفرت أو إلى أنَّها لم تتوفر أمَّا الحكم القاضي بانتفاء جريمة الإضراب غير القانوني لعدم كفاية الحجة أو لتجرد الادعاء فهو قضاء إنبنى على تقدير الأدلة والقرائن المعتمدة في نسبة الفعل للمتهم وليس على القطع بان الأفعال المدعى بها لا تكون جريمة الإضراب غير القانوني على معنى الأحكام التي نظمته وبالتالي فلا اتصال للقضاء بالموضوع

والسبب الثاني هو انه حتى مع بت الحكم الجزائي في انتفاء صفة الإضراب غير القانوني في الأفعال المنسوبة للمتهم وحتى مع ضرورة تقيد القاضي الشغلي بذلك فانه يتوجب عليه البحث والتمحيص في الأفعال المذكورة والتي يمكن أن تؤسس لأخطاء مهنية أخرى غير الإضراب غير القانوني كالوقوفات الاحتجاجية غير القانونية أو الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بالعمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة وهي من الأخطاء التي يمكن أن يكتفيها القاضي من قبيل الهفوة الفادحة المبررة للطرد وبالتالي فانتهاء الإضراب غير القانوني ولئن كان ينفي خطأ الإضراب غير القانوني كخطأ مهني فانه لا ينتفي معه الخطأ المهني في المطلق ويبقى من دور القاضي تبين ما إذا كان ذلك من قبيل الخطأ الفادح المبرر للطرد أم لا فضلا عن أنَّ الهفوة الفادحة وبخلاف الإضراب غير القانوني فهي تستوجب المؤاخذه التأديبية من المؤجر.

وحيث وتبعاً لما سلف بسطه وخلافا لما دفعت به المعقبة فان القضاء الجزائي عند قضائه بعدم سماع الدعوى لم يبت في مسألة التكييف القانوني للأفعال وما إذا كانت تشكل إضراباً غير قانوني من عدمه وإنَّما أسس قضاءه على تجرد الادعاء بارتكاب الفعل في حد ذاته وبالنتيجة لذلك فلا وجود لاتصال القضاء بمسألة انتفاء صفة الإضراب غير القانوني عن الأفعال المنسوبة للمعقبة.

وحيث وتبعاً لما سلف بسطه وخلافا لما دفعت به المعقبة فانه يبقى من السلطة المطلقة لقاضي الشغل أن يبحث من جديد في الأفعال المنسوبة للمعقبة ويكيفها التكييف القانوني الصحيح ما يتجه رد هذا المطعن.

وحيث وفضلا عن ذلك وخلافا لما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد فان أحكام الفصل 387 من م.ش نصّت صراحة على أنّ «علاقات الشغل تقطع بمفعول الطرف المسؤول عن عدم مراعاة أحكام هذا الباب» وبذلك يكون المشرع قد خص الخطأ المتمثل في الإضراب غير القانوني بجزاء مهني خاص وهو القطع الآلي لعلاقة العمل بين الطرفين وان هذا القطع الآلي هو بسبب من الأجير على معنى الفصل المذكور ما يعفي المؤجر حتما من أي مؤاخذه تأديبية فضلا عن انه يعفيه من التحمل بغرامات الطرد.

وبالنتيجة لذلك فلا يعد الإضراب غير الشرعي من قبيل الهفوة الفادحة وإلاّ لكان أدرجه المشرع بالفصل 14 رابعا من بين الأخطاء الفادحة وانه لا شيء كان يمنع المشرع من إدراجه من بينها خاصة وانه من الحالات الشائعة الحصول في العلاقة بين الأجير ومؤجره

كما انه طالما كان الإضراب غير الشرعي ثابتا في جانب الأجير فهو يرتب القطع الآلي للعلاقة الشغلية على معنى الفصل 387 من م ش كما لا يعد أي احتجاج أو توقف عن العمل لمجموعة من العملة هو من قبيل الإضراب طالما لم يتبين من وقائع الدعوى وخاصة أدلتها، بمثل ما سلف بسطه (معينة أعوان تفقدية الشغل على معنى أحكام الفصل 174 من م ش)، أنّ الاحتجاج أو التوقف عن العمل كان في إطار نزاع جماعي تفاوضي بين الطرفين وان الهيكل النقابي قد دفع إليه فضلا عن أنّ الاحتجاج أو الوقفة الاحتجاجية يمكن أن تعد من قبيل الهفوة الموجبة للمؤاخذه التأديبية وانه يكون من دور القاضي مراقبة مدى فداحة هذه الهفوة بما يتوفر لديه من ملاسبات الدعوى كمراقبة مدى احترام المؤجر للإجراءات القانونية المتعلقة بتتبع العامل تأديبيا.

وحيث وتبعاً لكل ما سلف بسطه فان ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد كان مؤسسا على تحريف للوقائع فضلا عن الإساءة في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها والإساءة في فهم القانون وخرقه ما جعل الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل وهو لكل ذلك موجب للنقض.

عن المطاعن بالمطلب عد78215دد:

عن المطعنين الأول والثاني لاتحاد القول فيهما:

حيث أنّ نزاعات الشغل الجماعية هي تلك التي تنشأ بين مؤجر ومجموعة عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاعاً شغلياً جماعياً وعادة ما يكون موضوعها مصالح أو حقوق مشتركة بين سائر أولئك الإجراء والتي منها الإضراب الجماعي أو الصد أو الدفاع عن حق نقابي أو المطالبة بالزيادة في الأجور وأما إذا ما كان النزاع بين المؤجر واحد وعملته وكان موضوعه لا يتعلق إلا بمصلحة أو حق هذا العامل فهو نزاع فردي ومن اختصاص الدوائر الشغلية ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الأجراء وحتى مع تعلق طلبهم بنفس الموضوع طالما تعلق ذلك باجر مستحق عن العمل الذي قدمه اذ العبرة في نزاعات الشغل الجماعية اتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع وليس تعدد الأجراء ما دام كل واحد منهم يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه.

وحيث تبين بالرجوع إلى أوراق الملف ان موضوع الدعوى تعلق بطلب المستحقات المهنية والغرامات نتيجة الطرد التعسفي المدعى به من المعقب ضده ودفعت المؤجرة بان العلاقة الشغلية قد انقطعت مع العامل بحكم القانون نتيجة إضرابه غير الشرعي وإعمالاً لأحكام الفصل 387 من م ش.

وحيث وتبعاً لما سلف بسطه وخلافاً لما تمسكت به الطاعنة فان قيام المعقب ضده كان بعد انقطاع العلاقة الشغلية ما ينتفي معه العنصر المحدد للنزاع الجماعي القائل بان مبنى الخلاف هو تنفيذ عقد الشغل بين طرفي التداعي فكان بذلك التداعي الحالي منحصراً في مسألة قطع العلاقة الشغلية بين الطرفين وما ترتب عنها من طلب مستحقات وغرامات تخص المعقب ضدها وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بصعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي وبغاية حماية مصالح مشتركة لكافة العملة ما يخرج النزاع عن صبغته الجماعية وما يكون معه الدفع بعدم اختصاص قاضي الشغل بالنظر حكماً هو دفع غير جدي لانعدام الالتباس حول ما إذا كانت للنزاع الصبغة الجماعية من عدمه طالما انه وبتاريخ القيام كانت العلاقة الشغلية قد انقطعت بين الطرفين وما يعني المحكمة من عرض الملف على النيابة العمومية على معنى أحكام الفصل 251 من م م م ت.

فكان ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد مؤسسا واقعا وقانونا واتجه والحالة تلك رد المطاعن الماثرة في هذا الجانب.

عن المطعن الثالث:

حيث وخلافا لما دفعت به المعقبة فان قول محكمة القرار المنتقد بتصادق الأطراف على ثبوت العلاقة الشغلية لا ينطوي على أي تحريف للوقائع ذلك ان مقصدها في ذلك هو تصادق الأطراف على قيام العلاقة الشغلية بين الطرفين وهي مسألة لم تنكرها المعقبة فضلا عن ان المحكمة لم تجزم بتصادقهما على تواصل العلاقة بل أشارت إلى أنّ النزاع انحصر في مسألة تواصلها وهي مسألة ناقشتها المحكمة وردت عليها واستخلصت مما عرض عليها من أدلة تواصل هذه العلاقة واسترسالها إلى تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين وكان ما استخلصته من نتيجة متوافقا وأوراق الملف ودون تحريف للوقائع والأدلة التي اعتمدها والمتمثلة في كشف التصريح بالأجور والبيئة المتلقاة أمام محكمة البداية فكان ما انتهت إليه من نتيجة قانونية في هذا الجانب مؤسسا واقعا وقانونا دون تحريف للوقائع وعللت حكمها تعليلا مستساغا وبما له سند ثابت بالملف واتجه لذلك رد هذا المطعن.

عن المطعن الرابع:

حيث استخلصت محكمة القرار المنتقد من وقائع الدعوى ارتكاب المعقب ضدها لواقعة الإضراب غير الشرعي واعتبرت ذلك من قبيل الهفوة الفادحة التي ولئن كانت سببا جديا مبررا للطرد فانه كان متوجبا على المؤجرة اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها قبل اتخاذ قرار الطرد والمتمثلة في الإحالة على مجلس التأديب وانه طالما لم تفعل يكون الطرد الصادر عنها تعسفيا لعدم احترام الإجراءات القانونية.

وحيث من المقرر أنّ الإضراب غير الشرعي هو غير الهفوة الفادحة التي تستوجب بالضرورة المؤاخظة التأديبية وان التمييز بين الحالتين اقره المشرع صراحة ضمن أحكام مجلة الشغل من ذلك أنّ الفصل 14 رابعا من م ش ولئن أورد جملة من الأمثلة عن الأخطاء الفادحة المبررة للطرد إلاّ أنّه لم ينصص على الإضراب غير الشرعي من بين الأخطاء التي أوردها وانه لا شيء كان يمنع المشرع من إدراجه من بينها خاصة وانه من الحالات الشائعة الحصول في العلاقة بين الأجير ومؤجره وان التساؤل عن سبب عدم إدراجه من بين حالات الهفوة الفادحة

يجد الجواب عنه ضمن مقتضيات الفصل 387 من م ش التي خصت الإضراب غير الشرعي بنظام قانوني منفرد خاصة فيما يتعلق بالجزاء المترتب عنه متى ثبت ارتكابه من العامل وإن هذا الجزاء يتمثل في الإنهاء الآلي لعقد الشغل وهو ما يستخلص من الفقرة الأخيرة من الفصل 387 المتقدم والتي ورد بها ان «علاقات الشغل تقطع بمفعول الطرف المسؤول عن عدم مراعاة أحكام هذا الباب»

فكانت النتيجة القانونية التي انتهت إليها محكمة الحكم المطعون فيه متضاربة العناصر طالما أنّ الإضراب غير الشرعي يخرج عن الهفوة الفادحة التي اقتضتها أحكام الفصل 14 رابعا من م ش والتي تستوجب المؤاخذة التأديبية وإن القاطع بثبوت من المحكمة يمنع من المطالبة بأية غرامات تعويضية عن الطرد ما يتجه معه نقض القرار المطعون فيه في هذا الجانب».

2-1-2 النزاعات الشغلية الفردية والنزاعات الشغلية الجماعية

قرار تعقيبي 78309 / 2020 بتاريخ 7 فيفري 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة التاسعة عشر برئاسة السيدة حياة البصلي وعضوية المستشارين السيد الأنور الكعلي والسيدة هاجر الخالدي وبمحضر المدعي العام السيد لطفي بن سليمان ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني .

«حيث أنّ نزاعات الشغل الجماعية هي تلك التي تنشأ بين مؤجر ومجموعة عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها ان تثير نزاعا شغليا جماعيا وعادة ما يكون موضوعها مصالح أو حقوق مشتركة بين سائر أولئك الإجراء والتي منها الإضراب الجماعي أو الصد أو الدفاع عن حق نقابي أو المطالبة بالزيادة في الأجور وأما إذا ما كان النزاع بين المؤجر واحد عملته وكان موضوعه لا يتعلق إلا بمصلحة أو حق هذا العامل فهو نزاع فردي ومن اختصاص الدوائر الشغلية ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الأجراء وحتى مع تعلق طلبهم بنفس الموضوع طالما تعلق ذلك باجر مستحق عن العمل الذي قدمه إذ العبرة في نزاعات الشغل الجماعية اتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع وليس تعدد الأجراء ما دام كل واحد منهم يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه .

وحيث تبين بالرجوع إلى أوراق الملف أنّ موضوع الدعوى تعلق بطلب المستحقات المهنية والغرامات نتيجة الطرد التعسفي المدعى به من المعقب

ضده ودفعت المؤجرة بان العلاقة الشغلية قد انقطعت مع العامل بحكم القانون نتيجة إضرابه غير الشرعي وإعمالاً لأحكام الفصل 387 من م.ش.

وحيث وتبعاً لما سلف بسطه وخلافاً لما تمسكت به الطاعنة فإن قيام المعقب ضده كان بعد انقطاع العلاقة الشغلية ما ينتفي معه العنصر المحدد للنزاع الجماعي القائل بان مبنى الخلاف هو تنفيذ عقد الشغل بين طرفي التداعي فكان بذلك التداعي الحالي منحصراً في مسألة قطع العلاقة الشغلية بين الطرفين وما ترتب عنها من طلب مستحقات وغرامات تخص المعقب ضدها وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بصعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي وبغاية حماية مصالح مشتركة لكافة العملة ما يخرج النزاع عن صبغته الجماعية وما يكون معه الدفع بعدم اختصاص قاضي الشغل بالنظر حكماً هو دفع غير جدي لانعدام الالتباس حول ما إذا كانت للنزاع الصبغة الجماعية من عدمه طالما انه وبتاريخ القيام كانت العلاقة الشغلية قد انقطعت بين الطرفين وما يعفي المحكمة من عرض الملف على النيابة العمومية على معنى أحكام الفصل 251 من م.م.م.ت.

فكان ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد مؤسسا واقعا وقانونا واتجه والحالة تلك رد المطاعن المثارة في هذا الجانب.

عن المطعن الثالث:

حيث وخلافاً لما دفعت به المعقبة فإن قول محكمة القرار المنتقد بتصادق الأطراف على ثبوت العلاقة الشغلية لا ينطوي على أي تحريف للوقائع ذلك أنّ مقصدها في ذلك هو تصديق الأطراف على قيام العلاقة الشغلية بين الطرفين وهي مسألة لم تنكرها المعقبة فضلاً عن أنّ المحكمة لم تجزم بتصادقهما على تواصل العلاقة بل أشارت إلى أنّ النزاع انحصر في مسألة تواصلها وهي مسألة ناقشتها المحكمة وردت عليها واستخلصت مما عرض عليها من أدلة تواصل هذه العلاقة واسترسالها إلى تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين وكان ما استخلصته من نتيجة متوافقة وأوراق الملف ودون تحريف للوقائع والأدلة التي اعتمدتها والمتمثلة في كشف التصريح بالأجور والبيئة المتلقاة أمام محكمة البداية فكان ما انتهت إليه من نتيجة قانونية في هذا الجانب مؤسسا واقعا وقانونا دون تحريف

للقائع وعللت حكماها تعلللا مستساغا وبما له سند ثابت بالملف واتجه لذلك رد هذا المطعن.

عن المطعن الرابع:

حيث استخلصت محكمة القرار المنتقد من وقائع الدعوى ارتكاب المعقب ضدها لواقعة الإضراب غير الشرعي واعتبرت ذلك من قبيل الهفوة الفادحة التي ولئن كانت سببا جديا مبررا للطرد فانه كان متوجبا على المؤجرة اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها قبل اتخاذ قرار الطرد والمتمثلة في الإحالة على مجلس التأديب وانه طالما لم تفعل يكون الطرد الصادر عنها تعسفيا لعدم احترام الإجراءات القانونية.

وحيث من المقرر أنّ الإضراب غير الشرعي هو غير الهفوة الفادحة التي تستوجب بالضرورة المؤاخذه التأديبية وأنّ التمييز بين الحالتين أقرّه المشرع صراحة ضمن أحكام مجلة الشغل من ذلك أنّ الفصل 14 رابعا من م ش ولئن أورد جملة من الأمثلة عن الأخطاء الفادحة المبررة للطرد إلاّ انه لم ينصص على الإضراب غير الشرعي من بين الأخطاء التي أوردتها وأنّه لا شيء كان يمنع المشرع من إدراجه من بينها خاصة وانه من الحالات الشائعة الحصول في العلاقة بين الأجير ومؤجره وأنّ التساؤل عن سبب عدم إدراجه من بين حالات الهفوة الفادحة يجد الجواب عنه ضمن مقتضيات الفصل 387 من م ش التي خصّت الإضراب غير الشرعي بنظام قانوني منفرد خاصة فيما يتعلق بالجزاء المترتب عنه متى ثبت ارتكابه من العامل وأنّ هذا الجزاء يتمثل في الإنهاء الآلي لعقد الشغل وهو ما يستخلص من الفقرة الأخيرة من الفصل 387 المتقدم والتي ورد بها أنّ «علاقات الشغل تقطع بمفعول الطرف المسؤول عن عدم مراعاة أحكام هذا الباب»

فكانت النتيجة القانونية التي انتهت إليها محكمة الحكم المطعون فيه متضاربة العناصر طالما أنّ الإضراب غير الشرعي يخرج عن الهفوة الفادحة التي اقتضتها أحكام الفصل 14 رابعا من م ش والتي تستوجب المؤاخذه التأديبية وان القطع بثبوته من المحكمة يمنع من المطالبة بأية غرامات تعويضية عن الطرد ما يتجه معه نقض القرار المطعون فيه في هذا الجانب».

2-1-3 تكييف العلاقات الشغلية الرابطة مع المنشآت العمومية

قرار تعقيبي 82214/2020 بتاريخ 14 فيفري 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة التاسعة عشر برئاسة السيدة حياة البصلي وعضوية المستشارين السيد الأنور الكعلي والسيدة هاجر الخالدي وبمحضر المدعي العام السيد لطفي بن سليمان ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«عن جملة المطاعن لاتحاد القول فيها:

حيث تمسكت المعقبة باستبعاد انطباق أحكام مجلة الشغل وتحديد الفصل 4-2 منها على وقائع الحال وان العلاقات الشغلية للمعقبة وباعتبارها منشأة عمومية تضبطها أحكام القانون ع78 دد لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985 والتي نظمت بصفة حصرية طرق انتداب العملة القارين لديها.

وحيث ولئن كان من المقرر أنّ المعقبة هي منشأة عمومية كما أنّه من المقرر أيضا أنّ المشرع أرسى قانونا خاصا لتطبيقه على الأعوان المستخدمين لدى المنشآت العمومية فانه يكون من المتوجب البحث في مدى إلزامية التقيد بالقانون الخاص عند النظر في مختلف العلاقات الشغلية الرابطة بين المنشأة العمومية وبين العمال المستخدمين لديها أو الرجوع إلى القانون العام وتحديدًا مجلة الشغل والذي يبقى انطباقه واردا إذا ما أحال القانون الخاص عليه صراحة أو تبين انه كان قاصرا عن ضبط مجمل هذه العلاقات.

وحيث إنّ الفصل في المسالة يستوجب قبل كل شيء تحديد مجال انطباق القانون الخاص باعتباره المقدم في التطبيق.

وحيث اقتضى الفصل الأول من القانون ع78 دد لسنة 1985 أنّه « ينطبق هذا النظام الأساسي العام على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات والمنشآت التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكيّا والشركات ذات المساهمات العمومية التي تطبق على أعوانها نظاما أساسيا خاصا في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.»

وحيث يستخلص من أحكام الفصل المذكور أن قانون 85-78 يضبط بالأساس العلاقات الشغلية الرابطة بين العامل المستخدم بصفة دائمة والمؤسسة

العمومية المؤجرة له وان المقصود بالعامل المستخدم بصفة دائمة هو العامل الواقع انتدابه كعون قار على معنى أحكام الفصل 19 من نفس القانون وان انطباق القانون على الأعوان المذكورين إنما يتعلق أساسا بسبل انتدابهم وتدرجهم في الوظائف وترقياتهم وتأديبهم.

وحيث اقتضى الفصل 19 من نفس القانون أن « المناظرة هي الطريقة الأساسية لانتداب أعوان المؤسسات المعنية بالأمر. »

وحيث يستخلص من الفصل المذكور وخاصة من عبارة « الطريقة الأساسية » إن المناظرة ولئن كانت الطريقة الأساسية لانتداب الأعوان القارين إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة في الانتداب ما يتأكد معه أن قانون 85-78 لم يمنع عن المؤسسة المؤجرة غيرها من أشكال الانتداب ومنها الانتداب الوقي للأعوان ما يجعل هذه الطريقة الأخيرة وباعتبارها الطريقة غير العادية في الانتداب رجوعا إلى قانون 85-78 فإنها تنشئ وضعية غير عادية في العلاقة الشغلية الرابطة بين المؤسسة المؤجرة والعامل وهي بالضرورة تخرج عن مجال انطباق قانون 85-78 الذي نص صراحة في فصله الأول إن مجال انطباقه يتعلق بالعملة المستخدمين بصفة دائمة ما يطرح التساؤل حول مدى إلزامية تطبيق أحكام مجلة الشغل في مثل هذه الحال.

وحيث طالما ثبت من أوراق الملف أن العلاقة الشغلية الرابطة بين المعقبة والمعقب ضده إنبتت بالأساس على الانتداب الوقي للعامل ما يخرج عن صفة العامل القار أو الدائم على معنى أحكام الفصل الأول من قانون 85-78 ما يخرج هذه العلاقة عن مجال انطباق القانون المذكور وانه طالما ثبت أيضا أن العلاقة الشغلية قد تواصلت بصفة مستمرة ما يتضح معه أن الانتداب ولئن اخذ في ظاهره الصبغة الوقية إلا أنه تجاوز المدة القانونية التي تخرجه عن صبغته الوقية ليندرج ضمن صنف العامل القار كل ذلك على معنى أحكام الفصل 6-4-2 من م ش ما يكون معه الاستنجد بأحكام القانون العام والتي تصبح مستوجبة الانطباق لخروج العلاقة الشغلية عن مجال انطباق قانون 85-78 بمثل ما سلف بسطه من جهة ولإلزامية إنطباق أحكام مجلة الشغل باعتبارها القواعد العامة المنطبقة في غياب النص الخاص ولصبغتها الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي من جهة ثانية وهو أمر يتدعم أيضا رجوعا إلى أحكام مجلة الشغل.

وحيث نص الفصل الأول من م ش انه « تنطبق أحكام هذا القانون على محلات الصناعة والتجارة والفلاحة وعلى توابعها، مهما كان نوعها العامة أو الخاصة. »
كما نص الفصل 2 من نفس المجلة في فقرته الثالثة انه « تعتبر بالخصوص محلات صناعية المحلات الآتية:

3- المؤسسات المعدة لنقل الأشخاص والبضائع برا وبحرا وجوا بما في ذلك عمليات مباشرة البضاعة في مختلف المستودعات البرية والبحرية والجوية »

كما نص الفصل 5 من نفس المجلة انه « تنطبق أحكام هذا القانون أيضا على أنواع العملة الآتي ذكرهم: 1 -الأشخاص الذين كلفوا في نطاق المؤسسة الصناعية أو التجارية من طرف رئيس المؤسسة أو بموافقته بأن يكونوا على ذمة الحرفاء طيلة إقامة هؤلاء في محلات المؤسسة أو في توابعها ليحافظوا على ما لهم من الثياب والأمتعة أو ليقدموا لهم ما يحتاجون من الخدمات مهما كان نوعها».

وحيث يستخلص من الفصول المتقدم ذكرها أنّ المشرع أرسى مبدأ عاما ضمن أحكام مجلة الشغل مفاده أنّ العلاقات الشغلية أيا كانت طبيعتها وأيا كان الأطراف المرتبطين بها بما في ذلك المؤسسات العمومية والتي من ضمنها المعقبة الآن يمكن أن تخضع بصفة مبدئية لأحكام مجلة الشغل ما لم يتعارض ذلك مع النصوص الخاصة التي تنظم هذه المؤسسات.

وحيث دفعت المعقبة بان المنشور الصادر عن وزير النقل بتاريخ 10/7/1997 أوجب استبعاد أحكام الفصل 6 من م ش وهو دفع لا يستقيم باعتبار أنّ المنشور يبقى متصلا بذات القانون لشرحه وتفسيره ولا يمكن ان يؤسس لقاعدة قانونية مستقلة بذاتها فضلا عن أنّ قانون 85-78 نفسه لم يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل حيث ورد في فصله الثالث انه « تنطبق أحكام مجلة الشغل على الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه ما لم تكن مخالفة لهذا القانون.»

وفضلا أيضا عن أنّ المشرع أضفى على مجلة الشغل صبغة الشمولية في الانطباق وذلك في حال قصور النص الخاص عن ذلك أو في حال غيابه.

وحيث وبالنتيجة لذلك وتبعاً لما سلف بسطه فإنّ ما اتجهت إليه محكمة القرار المنتقد باستنادها إلى أحكام الفصل 6-4-2 من م ش في تكييف العلاقة الشغلية الرابطة بين المعقبة والمعقب ضده فيه حسن تطبيق للقانون وإن ما انتهت إليه من نتيجة قانونية تطبيقاً للفصل المذكور كان متوافقاً وأوراق الملف وكان حكمها معللاً تعليلاً سليماً المبني واقعاً وقانوناً واتجه والحالة تلك رد المطاعن المثارة.

2-1-4 تكييف العلاقة الشغلية- عقد الشغل محدد المدة- الفصل 6-4 من مجلة الشغل- عدم تجاوز الأربع سنوات

قرار تعقيبي 77387/2020 بتاريخ 31 جانفي 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة التاسعة عشر برئاسة السيدة حياة البصلي وعضوية المستشارين السيد الأنور الكعلي والسيدة هاجر الخالدي وبمحضر المدعي العام السيد لطفي بن سليمان ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«حيث لا خلاف في أنّ تقدير وقائع القضية من إطلاقات محكمة الموضوع شرط استقراء هذه الوقائع بما له أصل ثابت بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية.

وحيث انتهت محكمة البداية وأيدها في ذلك محكمة الحكم المطعون فيه إلى أنّ العلاقة الشغلية قامت بين الطرفين في حدود المدة المتراوحة بين سنة 2011 و2016 وعللت ذلك بما ثبت لديها من بطاقات الخلاص وكشف الحياة المهنية.

وحيث وبالرجوع إلى أوراق الملف يتضح من بطاقات الخلاص وكشف الحياة المهنية المدلى بها من المعقب ضده نفسه والمعتمدة من محكمة الموضوع بطوريها أنّها دلت على أنّ بداية العلاقة الشغلية بين الطرفين انطلقت بداية من شهر جويلية من سنة 2012 ذلك أنّ أول بطاقة خلاص تعلقت بشهر جويلية من سنة 2012 كما أنّ أول تصريح بأجور العامل من طرف المعقبة تعلق بالثلاثية الثالثة من سنة 2012 فضلاً عن أنّ المعقب ضده قد سبق وأن أدلى بعقود شغل بينه والمعقبة تبين منها أنّ منطلق العلاقة الشغلية كان بموجب عقد محدد المدة عن الفترة الممتدة من 4/7/2012 إلى غاية 3/8/2012 ما تكون معه الحجج

المقدمة من الأجير قد دلت على خلاف ما ادعاه من كون منطلق العلاقة الشغلية كان منذ سنة 2011 فكان بذلك ما انتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من نتيجة فيه إساءة في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها إلى حد تحريفها ما أورث حكمها ضعفا في التعليل وهو لذلك موجب للنقض من هذا الجانب.

عن المطعن الثاني:

حيث دفعت المعقبة بان المحكمة قضت لفائدة المعقب ضده بالتعويض عن الطرد التعسفي وتكون بذلك قد خرقت أحكام الفصل 6-4 الفقرة الثانية من م ش حال أن الأجير لم يكتسب صفة العامل القار وأنّ إنهاء العلاقة الشغلية كان بانتهاء مدة آخر عقد بينهما.

وحيث اقتضى الفصل 6-4 من م ش انه »

1. يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في الحالات التالية :

- القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة،
- القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل،
- التعويض الوقي لعامل قار متغيب أو توقّف تنفيذ عقد شغله،
- القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو تصليح خلل بمعدّات أو تجهيزات أو ببناءات المؤسسة،
- القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معيّنة.

2. كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معيّنة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤجر والعامل على أن لا تتجاوز مدة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديده. وكلّ انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدة يقع على أساس الاستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة. وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلم الآخر إلى العامل.»

وحيث يخلص من الفقرة الثانية من الفصل المتقدم أنّ الانتداب الواقع لمدة معينة وفي غير صور الفقرة الأولى من نفس الفصل ينقلب بقوة القانون إلى الاستخدام القار في حال استمرت العلاقة الشغلية لمدة تجاوزت الأربع سنوات

فيكتسب العامل نتيجة لذلك صفة العامل القار ويكون بذلك على محكمة الموضوع أن تبحث في مدى سلامة تحقق شرط المدة في خصوص تواصل العلاقة الشغلية إلى ما يتجاوز الأربع سنوات حتى تقطع بانطباق أحكام الفصل 2-4-6 على وقائع الدعوى.

وحيث ثبت من أوراق الملف وخاصة من المؤيدات المدلى بها من المعقب ضده نفسه ان العلاقة الشغلية قامت بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة بدايته من 2012/7/4 إلى غاية 2012/8/3 وان العلاقة تجددت بموجب عقود لاحقة ومحددة المدة أيضا إلى غاية آخر عقد بينهما تنتهي مدته بتاريخ 2016/2/29 وهو التاريخ الذي توافق وقطع العلاقة الشغلية بين الطرفين ما يتضح معه أنّ العلاقة الشغلية، واستنادا إلى العقود المحتج بها من العامل وما أضافته المعقبة من بقية العقود، قد إنبت بالأساس على عقود محددة المدة وانه ولئن تواصلت هذه العلاقة واستمرت ما يمكن ان يوحى بنية الاستخدام القار من المؤجر إلا أنّ هذه العلاقة لم تتجاوز الأربع سنوات ما يمنع من تطبيق أحكام الفصل 2-4-6 من م ش وما يمنع أيضا من تطبيق الفصل 6-2 من م ش طالما لا شيء من أوراق الملف ثبت منه أنّ إرادة الطرفين اتجهت صراحة نحو الاستخدام القار منذ انطلاق العلاقة الشغلية.

فكان بذلك ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد، قولا بان أدلة الملف تثبت أنّ العامل مستقر في العمل لدى المؤجرة لمدة غير محددة وان قطع العلاقة الشغلية يكتسي صبغة تعسفية، فيه إساءة في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها وخرق لأحكام الفصلين 6-2 و 2-4-6 من م ش ما يجعل حكمها موجبا للنقض من هذا الجانب أيضا».

2-1-5 إنتقال عقد الشغل عملا بالفصل 15 من م ش.

قرار تعقيبي 2020.2023 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة الواحد والعشرين برئاسة السيدة آية بن ملوكة وعضوية المستشارتين السيدتين نادرة بن سالم وسلوى سلامة وبحضور المدعي العام السيد مصطفى العجمي وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«حيث ولئن كان من المسلم به أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل الدفوعات التي تثار لديها إلا أنها تظل محمولة وجوبا على الرد على ما كان منها جوهريا ومؤثرا على وجه الفصل أو ماسا بالنظام العام وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

وحيث ثبت رجوعا إلى مطروحات الملف أن المعقب الآن كان دفع أمام محكمة الأصل بالمطاعن المقدم الآن أمام محكمة القانون والمتصل أساسا بعدم تجاوز سن المعقب ضدها سنة 1991 الثالثة عشر من العمر بما يفند صحة ادعاءها بالعمل لدى المعقب منذ 1991 وقد تولت محكمة القرار المطعون فيه استعراض الدفع المثار من الطاعن والتحري في جديته لتبرير قضائها بإقرار الحكم الابتدائي حيث اعتبرت أن بداية العلاقة الشغلية بين طرفي النزاع كانت بداية من تاريخ 1991 إلى غاية 2010 استنادا للقرار الاستئنافي عدد 2900 الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف بتاريخ 04-01-2016 والذي أقر المعقب عند التحرير عليه بكونه أصبح باتا بموجب رفض تعقيبهِ أصلا وقد كان جليا أن قرارها كان مستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم ولم يثبت أنها قد قصرت في ذلك أو حادت عن أعمال صحيح القانون طالما أن بداية العلاقة الشغلية بداية من 1991 أصبح ثابتا بموجب حكم بات أحرز على قوة الأمر المقضي به وإنه من هذه المثابة فإنه طالما ثبتت للمحكمة العلاقة الشغلية بداية ونهاية وقضت تبعا لذلك بإقرار الحكم الابتدائي فإن موقفها ينطوي على جواب ضمنى لهذا الدفع مفاده أن الدفع بسن المعقب ضدها كان غير وجيه ولا تأثير له على وجه الفصل وهو موقف متماهي مع القانون .

عن المطعن المتعلق بخرق القانون:

حيث لا جدال أن دور قاضي الموضوع ينحصر في فحص ما يقدمه طرفا التداعي من حجج وتقديرها ثم البت على ضوئها ويكفيه أن يبين في حكمه أسباب ما قضى له وأسباب عدم أخذه بالدفوعات المتمسك بها وهو غير ملزم بالاستجابة لكل الطلبات المرفوعة إليه متى كانت الوسائل المطلوبة غير مجدية.

وحيث ولئن إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها ويكفي أن تبين أسباب حكمها الحقيقية التي اقتنعت

بها والتي لها أصل ثابت بأوراق الملف وليس عليها الاستجابة إلى كل طلب أو حجة تقدم إليها مادام قيام الحقيقة التي اقتصعت بها وأوردت دليلها بالمستندات فيه الرد الضمني المسقط لتلك الطلبات والتي من ضمنها الدفع المتعلق بتاريخ بداية نشاط المعقب الذي يرجع لسنة 1997 حسب عقد الوكالة الحرة المدلى به ضرورة أن ذلك ليس من شأنه دحض ما أثبتته الحكم الاستئنافي عدد 2900 المشار إليه ولا يمكن لذلك العقد أن يكون حجة على عدم عمل المعقب ضدها بالمشرع قبل تاريخ تسويغه للمعقب ذلك أنه من المسلم به قانونا وعملا بالفصل 15 م ش أن عقد الشغل يبقى قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية ومن الثابت أن المشرع كان في تصرف والد المعقب قبل انتقاله إليه بالكرام ما يجعله متحملا بكامل مستحقات الأجير منذ انطلاق العلاقة الشغلية.

وحيث تكون لذلك الطعون غير مبررة واقعا وقانونا وكان القرار المنتقد معللا تعليلا سليما وبصفة يتجلى منها حسن تطبيق القانون وتعين لذلك رد الطعون لعدم وجاهتها».

2-2-2- ضمان اجتماعي

2-2-2-1 جواز إنتقال حق وصيغ التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية لورثة الأجراء- القانون عدد 24 المؤرخ في 27 فيفري 2002

قرار تعقيبي 70271/2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة الواحد والعشرين برئاسة السيدة آية بن ملوكة وعضوية المستشارتين السيدتين نادرة بن سالم وسلوى سلامة وبحضور المدعي العام السيد مصطفى العجيمي وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«عن المطعن الوحيد المؤسس على خرق القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للأجراء:

حيث بالرجوع إلى المستندات القانونية للقرار المطعون ثبت أن المحكمة إنتهت في مجارة لموقف محكمة البداية إلى توفر شروط تكفل الصندوق الوطني

لضمان الاجتماعي المعقب بالمنح والمستحقات القانونية الناجمة عن المغادرة لأسباب إقتصادية في جانب المعقب ضدهم بصفتهم ورثة العاملة «س. ال.». وحيث أن غاية المشرع من سن القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 هو ضبط إجراءات الإحاطة الاجتماعية لفائدة العمال المفصولين عن العمل حسب المبادئ المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بضمان تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمنح الراجعة للعمال والمستحقات القانونية المقررة لفائدتهم في صورة ثبوت عدم تمكنهم من إستخلاص المبالغ المستحقة لهم بسبب توقف المؤسسة عن الدفع وذلك عند فصلهم عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنية أو عند الغلق النهائي الفجئي للمؤسسة دون إحترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل ويشترط للإنتفاع بإجراءات التكفل إثبات حالة من حالات الطرد المشار إليها بمقتضى حكم أحرز على قوة إتصال القضاء وثبوت عدم تمكن الأجير من إستخلاص المنح والمستحقات الخاضعة لمبدأ التكفل.

وحيث ولئن لم ينازع الطاعن في ثبوت عملية الطرد لمورثة المعقب ضدهم لأسباب إقتصادية لصدور الحكم الشغلي عدد 41728 بتاريخ 16 فيفري 2012 القاضي باعتبار غلق المؤسسة من قبيل الطرد التعسفي وإلزام المؤجرة بأن تؤدي لها جملة من الغرامات والمنح القانونية الواقع الإعلام به طبق القانون في 07 سبتمبر 2012 حسب رقيم عدل التنفيذ فهمي الهمامي عدد 442 والذي أضحى بات لعدم الطعن فيه وفقا لشهادة عدم إستئنافه المسلمة من محكمة الإستئناف ببزرت بتاريخ 28 ماي 2015 وإنحصرت منازعته في مدى جواز إنتقال حق وصيغ التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية لورثة الأجراء من عدم ذلك. وحيث بالرجوع إلى القانون عدد 24 لسنة 2002 المشار إليها الضابط لصيغ التكفل ولئن نص فصله الأول على أن تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار آلية التكفل ممنوح لفائدة العمال المفصولين إلا أنه لم يقصي صراحة ولا ضمناً ورثة الأجراء من الإنتفاع بتلك الآلية ليبقى بالتالي مبدأ

إنسحاب حق التكفل على ورثة الأجراء جائز وممكن عملا بالقاعدة الأصولية القائلة بأن الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه.

وحيث أن المستحقات والمنح الشغلية المحكوم بها لفائدة الأجير هي دين وإلتزام شخصي في ذمة المؤسسة المؤجرة ملزمة بأدائه للأجير شخصيا ومتى توفي هذا الأخير قبل التنفيذ الكلي إنتقل حق إستخلاصه الكلي أو الجزئي للورثة تفعيلا للقاعدة المدنية مناط الفصل 241 من م إ ع بأن « الإلتزامات لا تجري أحكامها على المتعاقدين فقط بل تجري أيضا على ورثتهم وعلى من ترتب له حق منهم ما لم يصرح بخلاف ذلك أو ينتج من طبيعة الإلتزام بمقتضى العقد والقانون لكن لا يلزم الورثة إلا بقدر إرثهم وعلى نسبة مناباتهم » والتي لا تتناقض موجباتها مع القواعد الخاصة في المادة الشغلية.

وحيث طالما ثبت تعذر إستخلاص الأجير ومن بعده ورثته للمستحقات الشغلية المحكوم بها قضائيا وطالما ضبط المشرع إجراءات التكفل بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن تلك الإجراءات تنسحب على الورثة وفقا لصيغها المضبوطة بالقانون الخاص المذكور أعلاه والقول خلاف ذلك في غياب نص صريح بحصر صيغ التكفل في الأجير دون جواز إنتقالها للورثة لا سند صحيح له في القانون.

وحيث خلافا لمستندات الطعن فإن محكمة القرار المنتقد ومن قبلها محكمة البداية تولت إحتساب المنح والمستحقات القابلة للتكفل من قبل المعقب وقضت في حدود المبلغ الغير خالص كل ذلك بعد طرح ما تم إستخلاصه من المعقب ضدهم من طرف مصفي الشركة مؤجرة مورثتهم وما تحصلت عليه هذه الأخيرة في قائم حياتها من المعقب في إطار إعانات إجتماعية.

وحيث وترتبا على ما سبق فإن محكمة القرار المطعون فيه طبقت القانون تطبيقا سليما ينم عن فهم صحيح لأحكامه فجاء قرارها سليم المبنى قانونا ومعللا تعليلا مستساغا ولم تأت مستندات المطعن بما من شأنه الخدش فيه فتعين رفض الطعن أصلا».

2-2-2 استحقاق المنح الاجتماعية طبق الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بإحداث منحة تحفيز لأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات

قرار تعقيبي 2020/20164 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة الواحد والعشرين برئاسة السيدة كوثر السعدي وعضوية مستشارتيها السيدتين امال المالكي ولطيفة الحضيري وبحضور المدعي العام السيد محمد مهدي مزيو وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة راضية الهمادي.

«حيث انحصر الخلاف بين الطرفين حول طبيعة المنحة التي يطالب المعقب ضده المدعي في الأصل باعتمادها وكيفية احتسابها في تعديل جريته.

وحيث نص الفصل الأول من الأمر عدد 2941 المؤرخ في 07 أوت 2014 والمتعلق بإحداث منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية انه تسند منحة شهرية تسمى «منحة التنسيق والمتابعة لمالية العمومية» للأعوان المباشرين فعليا بالإدارات المركزية والمدرسة الوطنية للمالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية باستثناء الأعوان المتفيعين بأحكام الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بإحداث منحة تحفيز لأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات.

وحيث أضاف الفصل الثالث من نفس الأمر أن تحديد المبلغ الفعلي للمنحة الراجعة لكل عون على أساس عدد من النقاط يسندها الرئيس المباشر أقصاها 100 نقطة وفقا لمقاييس الانضباط والحضور ومجهود العون ونجاعته.

وحيث يستخلص من الفصلين المذكورين أن الفصل الأول حدد الأعوان المتمتعين بالمنحة المحدثة وهم الأعوان المباشرين في تاريخ صدوره بينما ضبط الفصل الثالث معايير ومقاييس احتساب تلك المنحة وهي جميعها مقاييس مرتبطة بالممارسة الفعلية لنشاط العون المعني بها كما تدل عليها تسميتها كما أنها من الناحية العملية تتغير وتتراوح من عون لآخر حسب النقاط المسندة إليه من رئيسه المباشر تبعا لنشاطه المهني ومواظبته عليه وهو ما لا يمكن أن ينطبق على العون المتقاعد وبذلك الصفة فهي لا تعد من العناصر القارة للمرتب حتى يقع إدماجها في احتساب جرایة التقاعد على معنى الفصل 37 من القانون عدد 12

لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25/06/2007 وبالتالي فإن عدم استحقاقها من قبل الأعوان المحالين على التقاعد لا يمثل خرقاً لأحكام الفصل 37 المشار إليه.

وحيث يكون القرار المنتقد لما اقر بسحب المنحة محل النزاع على الأعوان المتقاعدين قد قصر في فهم وتطبيق القانون وفي تفسير فصول النص الواحد بعضها ببعض ولم يتعرض بالدرس للنصوص القانونية المنظمة للنزاع ولم تبت بصفة واضحة ومعللة في الإشكال القانوني المطروح عليها وهو مدى استحقاق العون المتقاعد لمنحة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها بالأمر عدد 2941 لسنة 2014 وبالتالي غير مؤسس كما يجب قانوناً باعتبار أن كل من الفصلين الأول والثالث من الأمر المحتج به اشترطا لاستحقاق تلك المنحة أن يكون العون مباشراً لعمله وطالما ثبت أن المعقب ضده قد أحيل على التقاعد قبل تاريخ صدور هذا الأمر فإن طلب انتفاعه بها يكون عديم السند الأمر الذي يعرض قضاءها للنقض».

2-2-3 سقوط المطالبة بمساهمات الصندوق بعد مضي أجل عام من انتهاء عقد الشغل على معنى الفصل 111 مكرر من القانون عدد 38 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي-أجل تقادم.

قرار تعقيبي عدد 22037 بتاريخ 31 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثالثة برئاسة السيدة نعيمة رحيم وعضوية المستشارتين السيدة عبير الخليفة والسيدة نورة نوري وبمحضر ممثل الادعاء العمومي السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوي.

«عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصل 111 مكرر من القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6/5/1988 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.

حيث تمحور هذا الفرع من الطعن حول سقوط حق المعقب ضدها الأولى في مطالبة مؤجرها بدفع مساهمات الصندوق بعد مضي أجل عام من إنهاء عقد الشغل على معنى الفصل 111 مكرر من القانون عدد 38 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.

وحيث أنّ مسألة الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن شرعت كوجه من أوجه الدفاع لرد الطلب وهي على حالتها تلك تتعلق بمصالح الخصوم ولا تعد قاعدة إجرائية تهم النظام العام ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

وحيث لئن سبق للطاعن وان عرض مسألة سقوط حق الطالبة في طلب دفع المساهمات على محكمة القانون فإنها سلطت رقابتها على مطاعن أخرى دون ذلك المطعن وهو ما يغني محكمة الإحالة من التعرض إليها على اعتبار وان الفصل 191 من م.م.م.ت يحدد تعهدها ونظرها فيما تسلط عليه الطعن مما يجعل من مسألة سقوط الحق مسألة اتصل بها القضاء ولا مجال لإعادة إثارتها وتكون محكمة الإحالة لما التفتت عنها قد احترمت الإجراءات القانونية وحدود ما تعهدت به مما يتجه معه رد هذا المطعن.

بخصوص المطعن المتعلق بهضم حقوق الدفاع لعدم التقيد بطلبات الدعوى
وحيث لئن كان قاضي الأصل مقيد بحدود الطلبات المحررة ضمن عريضة الدعوى فان له سلطة تقديرها وفهمها واتخاذ الوسائل والأعمال التحضيرية اللازمة لحصرها وضبطها .

وحيث تولت محكمة الإحالة التحرير على القائمة بالدعوى بخصوص المساهمات الغير مدفوعة وبينت أنّ طلبها الأصلي تعلق بكامل مدة العمل وهو ما يعد منها تحريرا للدعوى وضبطا لطلباتها إذ وخلافا لما ذكر الطاعن فان محكمة الأصل لها من الصلاحيات ما يخولها السعي لحصر حدود الطلبات وضبطها سيما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي الذي لا تكون فيه إنابة المحامي وجوبية خلال الطور الابتدائي وأن إجراءات التعهد فيه بسيطة ولا تثريب بالتالي على المحكمة لما سعت إلى التحرير على القائمة بالدعوى لضبط حدود طلبها وهو ما لا يشكل تجاوز لحدود الطلبات ولا هزما لحقوق الدفاع وتعين رد هذا المطعن ورفض مطلب التعقيب أصلا».

2-2-4 سقوط حق المطالبة بالأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لا يقبل التعليق ولا القطع ما لم يتمسك بالصيغة الشغلية للحدث أو المهنية للضرر.

قرار تعقيبي عدد 2019 / 75902 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجلاء المصمودي والسيدة نجوى الغربي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر .

«عن المطعن الوحيد المأخوذ من خرق الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة

1994

حيث ينصّ الفصل 28 من القانون من القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بجبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أنه يسقط الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامات المستحقة طبقاً لهذا القانون بمرور سنتين مع مراعاة أحكام الفصل 392 م ا ع بالنسبة للقصر وبتدئ تاريخ سقوط الحق بالنسبة للمنح الوقتية انطلاقاً من يوم وقوع الحادث أو المعاينة الطبية للمرض بالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التثام الجرح أو البرء الظاهر أو وفاة العامل وحيث انحصر الخلاف في نزاع الحال فيما إذا كان الأجل الوارد بالفصل 28 المذكور أعلاه قابلاً للقطع والتعليق من عدمه فالطاعن يدفع بأن الأجل المحدد بسنتين من تاريخ البرء هو أجل سقوط لا يقبل القطع ولا التعليق ويدفع المعقب ضده بانطباق آجال القطع والتعليق وسائرته في ذلك محكمة القرار المتخذة عن غير صواب منها لأن الأجل لا يقبل القطع ولا التعليق ما لم يوجد نزاع في الصبغة الشغلية للحادث أو الصبغة المهنية للضرر أو تاريخ البرء النهائي إلا في حالة واحدة صريحة بموجب الفصل 28 المذكور آنفاً وهي التي يشمل فيها التعويض قاصراً إذ يستعمل المشرع عبارة مع مراعاة أحكام الفصل 392 من م ا ع بالنسبة للقصر وبما أن الفصل 392 المذكور يتعلق بتوقف سقوط الدعوى بمرور الزمن في حق القاصرين الغير مأذونين بالتصرف وبذلك فإن الأجل يمضي في حق من عداهم ولا يتوقف احتسابه وهي حالة وردت بنص خاص تقدم على القواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود حول القطع والتعليق لآجال سقوط الدعوى كل ذلك ما لم يوجه لزام في الصبغة الشغلية أو صبغة المرض أو في تاريخ أبرء النهائي ويسقط بالتالي حق المطالبة بمضي سنتين بشأن المستحقات المستمرة من تاريخ البرء على غير القصر وهو جزاء اقره الفصل 28 لكل من يتقاعس عن المطالبة بالتعويض .

وحيث أخطأت محكمة الحكم المطعون فيه في تأويل القانون لما اعتبرت
اجل الستين بالفصل 28 قابل للقطع خلافا لما ذكر أعلاه وأسأت تطبيقه حين
اعتبرت القيام واقعا خلال الأجل القانوني وعرضت قضائها للنقض».

3 - مدني عام

3 - 1 في العقود

3-1-1 مبادئ التعاقد

3-1-1-3 مبدأ الأمانة في التعاقد

قرار تعقيبي عدد 75785.2020 بتاريخ 27 جانفي 2020 صادر عن الدائرة
المدنية الثانية برئاسة السيد محمد العسكري وعضوية المستشارين السيدين مكرم
الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة
كاتبة الجلسة السيدة راضية همادي.

«حيث كانت المطاعن صلب مستندات التعقيب في تحريف المحكمة
الأصلية طلب المعقبة وخرقها للقانون خاصة حجية الحكم الجزائي الصادر
ضد المعقب ضدها ذلك أن الدعوى تأسست على فسخ عقد كراء ممضى بين
الأطراف عدلته المعقب ضدها وافتعلته مما جعلها موضوع إدانة جزائية.

حيث ثبت أن محكمة الحكم المطعون فيه قد عاينت بعد التحرير على المعقبة
الآن قبولها بممارسة المعقب ضدها لنشاط الخياطة وبيع الملابس الجاهزة لتقدر
من خلال التحريرات أن للمعقب ضدها الحق في البقاء على معنى الفصول 1 و2
من قانون 1977.

حيث إن لمحكمة الأصل بسط رقابتها على العلاقة التعاقدية كما انه من
المستوجب قانونا التقصي والتحقق من مدى توفر شروط الاستغلال التجاري
بعد مضي مدة الكراء المحددة بالقانون وبعد توفر التجديد وشروطه وأن الثابت
في النزاع أن المعقبة تمسكت بأن العقد سند الاستغلال من قبل المعقبة تم تغييره
وثبت بعد التشكي الجزائي افتعال العقد وتغييره بعد إمضائه من الطرفين مما أدى
إلى المساس بإرادة الطرفين .

وحيث ثبت من المؤيدات المتعلقة بالحكم الجزائي أن العقد على حالته موضوع افتعال وأنه لا يمكن اعتباره أصلا قابلا للتنفيذ ولا يمكنه أن يسند حقوقا للمعقب ضدها سواء كانت تستغله للنشاط المتفق عليه عقدا وقبل إفتعاله أو بعد ذلك.

حيث أن العقد الرابط بين الطرفين هو الشريعة والفيصل بينهما وان تنفيذ العقود وتطبيقها يكون مع تمام الأمانة وفق الفصل 243 ماع وأن زيادة المعقب ضدها لعبارات العقد بعد إمضائه من شأنه تغيير نوع التعاقد وطبيعته وفيه مساس بمبدأ الأمانة في العقود كما أن المعقبة أدلت بحكم جزائي بات له حجية في المادة المدنية بخصوص افتعال العقد وإضافة عبارات بخصوص نوع الاستغلال المحور من حرفي إلى تجاري . وكان على المحكمة التحقق من سند الطلب وهو الحكم الجزائي المثبت لافتعال بنود العقد وكان على المحكمة التثبت من تلك العناصر القانونية والرد بخصوصها وكان الحكم ضعيف التعليل خارقا للقانون ومغيرا لأسانيد الطلب المؤسس على الفسخ المؤسس على حكم جزائي بالإدانة، وتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بين عروس للنظر في القضية بهيئة أخرى».

3-1-2 تعريف العقد- أركان التعاقد- التوافق والتقاء ارادتين في تكوين العقد
قرار تعقيبي عدد 2018 / 70947 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن المطعن الوحيد المأخوذ من ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون .
حيث أسست المعقبة طعنها على أن عقد التأمين وبوصفه عقدا رضائيا قد أبرم بين الطرفين لأن المعقب ضدها ضمنت موافقتها صلب العرض المقدم لها بما يخول للطاعة المطالبة بأقساط التأمين .

وحيث ان المسألة الخلافية في نزاع الحال تتمثل في معرفة ما ان كان عقد التأمين قد أبرم بين الطرفين من عدمه والحسم فيها يقتضي الرجوع لمفهوم العقد وشروطه للوقوف على مدى توفر تلك الشروط في نزاع الحال .

وحيث أن العقد هو التقاء إرادتين أو أكثر لإنشاء التزام قانوني من خلال بالتصريح بالرضا الذي يبنني عليه العقد تصريحاً معتبراً وفق ما ينصّ عليه الفصل 2 من م ا ع ويتم الرضا بصدور قبول موافق للإيجاب والذي يميز عن مجرد الدعوة للتعاقد فهو تعبير بات عن إرادة حرة وحقيقية جدية وواعية ويتضمن عرضاً للتعاقد حسب شروط معينة فيكون باتاً لا لبس فيه معبراً عن إرادة صريحة للتعاقد في ظروف وبشروط مضبوطة ويقتضي الأمر أن يكون القبول متطابقاً مع الإيجاب حتى ينبرم العقد على أنه يمكن أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً أما إذا اقترن بقيد أو شرط فإنه لا يعد قبولاً لعدم تطابقه مع الإيجاب .

وحيث وإن كان العرض المقدم من المعقبة معبراً عن إرادتها الصريحة في التعاقد بشروط مبيّنة بالعرض من تحديد للضمانات التي يشملها التأمين وسقف التغطية ومعلوم الاشتراك بما يعد إيجاباً منها فإن ما دونته المعقبة ضدها على العرض المقدم لها من الطاعة والتمثل في عبارة Bon pour établissement du contrat ليس فيها ما يدل على تكوين العقد الأصلي ولا يحمل معنى التوافق والتقاء إرادتين في تكوين العقد بل هو اتفاق على مبدأ إبرام العقد وهو مجرد مرحلة من أجل الوصول إلى العقد النهائي واتفاق على إبرام العقد وليس على أركان العقد بما لا يصح معه القول بإبرام عقد التأمين ولا ينشأ عنه أي التزام قانوني ولا يخول للطاعة تبعاً لذلك المطالبة بأقساط التأمين طبق ما إنتهجه عن صواب محكمة الحكم المطعون فيه التي أحسنت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلاً سليماً ومؤسساً على ما له أصل ثابت بالملف وتعين لذلك رد المطعن».

3-2-2 إلتزام الأمي

3-2-2-1 تحرير محضر تلاوة على معنى الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية قرار تعقيبي مدني عدد 71369 بتاريخ 26 ماي 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثانية والثلاثين برئاسة السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية المنتصر ونفيسة العلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الحلواني .

«عن المطعنين لتدخلهما ووحدت قول المحكمة فيهما:

حيث نسبت المعقبة للقرار الاستثنائي المطعون فيه مخالفته للقانون وتحريف الوقائع وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بمقولة أن إمضاءها المذيل أسفل كتب التنازل المراد إبطاله ورد في شكل علامة لا تمت للواقع بشيء الأمر الذي يؤكد أميتها فضلا عن أن الكتب المذكور لم يكن مرفوقا بمحضر تلاوة ليكون صحيحا ويجوز الأخذ به عملا بالفصل 378 م ح ع ناعية من جهة أخرى على محكمة الحكم المنتقد عدم سعيها لإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة لإثبات الأمية في جانبها .

وحيث اقتضى الفصل 454 م إ ع أن « التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة لا يمضي حتى يتلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك ».

وحيث أن الأمي الذي قصده المشرع صلب الفصل 454 المذكور هو الشخص الذي لا يحسن الكتابة وبالتبعية القراءة على الإطلاق بقطع النظر عن الطريقة التي يمضي بها على الكتائب الصادرة عنه لذلك وحماية لحقوقه وإرادته ورضاه نزعت عن الكتب المتضمن لالتزام الأمي كل قيمة قانونية وحجية في صورة عدم تحريره بحجة رسمية لدى عدول إشهاد أو لدى المأمور العمومي المختص .

وحيث لا جدال أن مجرد التعريف بالإمضاء لا يمكن قانونا أن يضيفي على الكتب صفة الحجة الرسمية .

وحيث عرف فقه القضاء التونسي الأمي بكونه الشخص الذي يمضي على الكتائب التي يعقدها إما بوضع علامة إبهامه أو بوضع قاطع ومقطوع أو علامة صليب أو غيرها من العلامات التي لا تمت إلى الواقع بشيء .

وحيث بالاطلاع على إمضاء المعقبة الآن المضمن أسفل كتب التنازل المطعون فيه بالإبطال يتبين أنها ولئن لم تضع علامة إبهامها كما أن إمضاءها لم يرد في شكل علامة قاطع ومقطوع فانه يتضح جليا أنها لا تحسن الإمضاء باعتبار أنه لم يكن إمضاء عاديا يدل على صدوره عن شخص يحسن الكتابة مما يضيفي الجدية على دفع الطاعنة بأميتها .

وحيث عرف المشرع التونسي الإمضاء صلب الفقرة الأخيرة من الفصل 453 م إ ع بكونه يتمثل في « وضع إسم أو علامة خاصة بخط يد العاقد نفسه مدمجة بالكتب المرسوم بها... ».

وحيث ورغم ثبوت أن الإمضاء المنسوب للطاعنة تمثل في مجرد خط مبهم في حين اشترطت الفقرة المذكورة أن يكون الإمضاء متمثلاً في وضع اسم أو علامة خاصة بخط يد العاقد نفسه مدمجة بالكتب المرسوم بها فإن محكمة الحكم المطعون فيه أغفلت كل ذلك دون أي تعليل أو تبرير واقعي أو قانوني.

وحيث أن لفت محكمة الموضوع نظرها عن الصيغة التي جاء على منوالها الإمضاء وإحجامها عن التثبت في ما إذا كان هذا الإمضاء له دلالة من عدمه ينضوي على خرق واضح لأحكام الفصلين 453 و 454 م إ ع وضعف في التعليل.

وحيث اقتضت محكمة الحكم المنتقد في أسانيد قرارها على القول بأن الاكتفاء بتصريح المعقبة بكونها أمية في غير طريقه ومخالف للفصل 420 م إ ع وأغفلت عدة معطيات واقعية ثابتة بالملف كما أنها لم تستفرغ جهدها في تمحيص الدفوعات المقدمة إليها والتعمق فيها لما لها من الأهمية على وجه الفصل بمزيد التحري والتثبت في ثبوت الأمية من عدمها سيما قد ثبت أن الطاعنة ومنذ تقديم عريضتها الافتتاحية كانت تمسكت بطلب سماع بينتها في خصوص ما تقدم.

وحيث ومن جهة أخرى فإن أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 378 م ح ع المحتج بها من طرف الطاعنة والتي اقتضت أنه «إذا كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه تجب تلاوة الكتب عليهم لدى إحدى السلطات المذكورة بالفقرة الأولى من ذات الفصل بمحضر شاهد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد وتشهد السلطة المتعاهدة بأنها تعرف الأطراف أو أن هويتهم ثبتت لديها طبق التشريع الجاري به العمل كما تشهد بأن هؤلاء الأطراف قد صرحوا بأنهم استوعبوا مضمون الكتب وقبلوا شروطه ثم تمضي محضر تلاوة مع الشاهد كما يضع الأطراف الحاضرون علامة إبهامهم ما لم تثبت كما يجب استحالة ذلك » تتعلق بالكتائب الخطية التي يكون موضوعها حقوق عقارية خاضعة للتسجيل سيما أن الفصل 378 م ح ع جاء تحت عنوان ترسيم الحقوق العينية العقارية وهو نص خاص يتعلق بالعقود الخطية التي تشترط محضر تلاوة إذا كان أحد أطرافها

أمّا وهي العقود التي يكون موضوعها حقا عينيا عقاريا ومحضر التلاوة هنا هو شرط للتعريف بالإمضاء صلب هذا العقد حتى يقبل الترسيم بالسجل العقاري ولم يثبت من أوراق الملف أن المناوبات المشاعة موضوع كتب التنازل المراد إبطاله تتعلق بعقار مسجل.

وحيث بناء على ما تقدم بسطه وطالما ثبت أن المعقبة وخلال كامل أطوار القضية تمسكت بأمتها على معنى الفصل 454 م إع استنادا إلى العلامة المبهمة التي وضعتها أسفل كتب التنازل المحرر بخط اليد فانه كان على المحكمة الوقوف على هذه المسألة والتحري في طبيعة هذا الإمضاء استنادا إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 453 م إع وعند الاقتضاء إجراء كل الأعمال الاستقرائية من ذلك التحرير على الطرفين وسماع بيئتهما وترتيب ما يستوجب من آثار قانونية على ذلك سعيًا إلى الوقوف على مدى ثبوت الأمية من عدمها.

وحيث أضحى موقف محكمة القرار المنتقد متسما بخرق للقانون وضعف في التعليل وقصور في التسيب يوهن حكمها ويعرضه للنقض وتعين القضاء به مع الإحالة لإعادة النظر من جديد فيما تسلط عليه النقض».

3-2-2-2-3 غياب شرط التلاوة سببا لإبطال العقد الممضى من الأمي

قرار تعقيبي عدد 68551 بتاريخ 13 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والثلاثين برئاسة السيد وجدي الهذيلي وعضوية المستشارين السيدين رجاء بوسمة ومحمد الورهاني وبحضور المدعي العام السيدة رجاء الخضراوي، وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«عن المطعن الوحيد المتعلق بخرق القانون وضعف التعليل:

حيث يعد البحث في أمية المعقب ضدها والوقوف على مدى صحة ادعائها بشأن ذلك من عدمه من المسائل الواقعية التي ترجع بالنظر والاجتهاد إلى محاكم الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون ما لم يكن قضاؤها مشوبا بخرق للقانون أو ضعف في التعليل أو مخالفا لما له أصل ثابت بالملف.

وحيث تبين بالاطلاع على مستندات القرار المنتقد وعلى بقية مظروفات الملف أن المحكمة لم تكتف بمعاينة إمضاء المعقب ضدها بوضع علامة قاطع ومقطوع لاستنتاج جهلها للقراءة والكتابة وإقرار حقها في الحماية التي خصها

بها المشرع بموجب الفصل 454 من م ا ع وإنما تولت بوصفها محكمة إحالة مسaire ما أقرته محكمة التعقيب من وجوب إجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن في إطار صلاحياتها المتعلقة بتهيئة القضية للفصل فحررت على طرفي النزاع وسمعت بينة المعقب ضدها التي أجمعت على الشهادة بأمرتها منتهية إلى إبطال عقد المقاسمة لعدم استجابته لشروط الفصل 454 المذكور من حيث تحريره من طرف مأمور عمومي مع وجوب تلاوة محتواه على الطرف الأمي وإثبات ذلك بمحضر تلاوة.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الفصل 458 من م ا ع نص عام ينطبق على المتعاقد الذي وضع إمضاءه ولم ينكره بوجه صريح ليعتبر مقبولا لديه ويكون نافذا في حقه ولا يسري على الأمي الذي لا يحسن الإمضاء ولم ينكر وضعه لعلامة قاطع ومقطوع أو غير ذلك من العلامات المبهمة التي تفيد مشاركته في العقد دون علمه بفحواه.

وحيث ولئن كانت مسألة العلم بفحوى العقد من الأمور الخاصة التي تندرج في إطار سرائر النفوس والتي يصعب مبدئيا الوقوف على حقيقتها وإرساء قناعة جازمة بشأنها، فإن المشرع ترك اختيار وسائل البحث الاستقراء الملائمة لاجتهاد وتقدير محاكم الأصل بما لا مجال معه لحصر صلاحياتها في هذا الشأن في توجيه يمين الاستيفاء على معنى أحكام الفصل 508 من م ا ع والحال أن المشرع خص الأمي بحماية شكلية تغني عن البحث في هذه المسائل الباطنية تتمثل في إرفاق العقد الذي هو طرف فيه والواقع تلقيه بواسطة مأمور عمومي بمحضر تلاوة يقيم الدليل على إعلامه بفحواه بحيث لا يثبت العلم بذلك المحتوى إلا بذلك المحضر فيما يعد غيابه حجة على عدم العلم بموضوع العقد.

وحيث تبعا لما تقدم فإن محكمة القرار المنتقد تكون قد أصابت المرمى حين حصرت أبحاثها في مسألة الأمية من عدمها لاعتماد غياب شرط التلاوة سببا لإبطال العقد أمام ثبوت أمية المعقب ضدها واكتمال قناعتها بذلك ولم يرد قضاؤها مشوبا بأي ضعف في العليل أو خرق للقانون من هذه الناحية بما اتجه معه رد مطعن المعقب في هذا الشأن.

وحيث لم تتضمن مستندات الطعن ما من شأنه أن يوهن القرار المتخذ بما اتجه معه رفض مطلب التعقيب أصلاً».

3-1-3 الحط من حجة رسمية إلى حجة غير رسمية الكتب المحرر والممضى من عدل إشهاد واحد دون جليس

قرار تعقيبي مدني عدد 70752 بتاريخ 19 ماي 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثانية والثلاثين برئاسة السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية المنتصر ونفيسة العلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الحلواني.

«عن جملة المطاعن لاتحاد وجه القول فيها:

حيث تناول نائب المعقبة عند صياغته لجملة المطاعن المضمنة بمستندات تعقيبه مسائل أربعة اتصلت الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 12 من قانون 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد و539 م ا ع بمقولة أن اعتماد حجة محررة من قبل عدل واحد يعد باطلا قانونا واستندت الثانية إلى القول بأن اشتراط حضور عدلين اثنين عند تحرير العقود ليس مجرد إجراء شكلي وإنما هو شرط يهم النظام العام ويدخل ضمن أحكام الإجراءات الأساسية أما الثالثة فتعلقت بخرق أحكام الفصلين 448 و329 م ا ع على أساس أن تحرير الحجة من طرف عدل واحد دون تلاوتها على المتعاقدين نتج عنه عدم اطلاع المعقبة على حقيقة التزامها وتعلق المطعن الرابع بما اعتبره تحريفا للوقائع وخرقا للفصل 481 م ا ع بمقولة اختلاف موضوع وسبب الدعوى الجزائية عن موضوع قضية الحال عند البحث في المسألة المتعلقة بمدى حصول تغيير في إرادة المتعاقدين من عدمه.

وحيث تعلقت المسألة الخلافية مناط قضية الحال بمدى إمكانية اعتبار الحجة الكتابية المحررة من طرف عدل إشهاد واحد حجة باطلة ولا عمل عليها قانونا باعتبار أن الصبغة الرسمية قد نزعَت منها أم أنه يمكن الحط من حجيتها الإثباتية لتتحول إلى كتب غير رسمي عند توفر شروطها القانونية.

وحيث لا نزاع في أن الكتابة بوصفها دليلا للإثبات تنقسم إلى نوعين رسمية وغير رسمية ولقد عرف المشرع التونسي الحجة الرسمية صلب الفصل 442 م

إع بأنها «هي التي يتلقاها المأمورون المنتصبون لذلك قانونا في محل تحريرها على الصورة التي يقتضيها القانون» وانطلاقا من هذا التعريف يتبين أن تحرير الكتب الرسمي يتوقف على وجود شخص هام في دائرة التعاقد وهو المأمور فالكتب الرسمي يستمد قوته من شخص المأمور العمومي المحمول على الصدق والنزاهة والحياد باعتبار أن الحجة الرسمية لا تمثل وسيلة إثبات فحسب بل هي شرط صحة لتحرير بعض العقود ضرورة أن العقود التي تتطلب توفر الحجة الرسمية لصحتها هي عقود شكلية لا يكفي التراضي بين الطرفين لانعقادها إنما يجب إلى جانب التراضي احترام شكل خاص أي تحريرها بحجة رسمية وذلك على خلاف الحجة غير الرسمية والتي ولئن لم يعرفها المشرع التونسي فقد استقر الفقه على تعريفها بأنها «الوثيقة المحررة من غير المأمورين المختصين في ذلك والتي يشترط أن تكون موقعة من أطرافها».

وحيث وفي هذا السياق اقتضى الفصل 448 م 1 أنه «إذا كان الكتب لا يعتبر رسميا لكون تحريره من وظيفة غير الذي حرره أو لعدم أهلية أو لنقص في الصورة اعتبر كتبا غير رسمي إن كان به إمضاء المتعاقدين الواجب رضاهما لصحة العقد»، وبالتالي ومن خلال هذا النص القانوني يتبين أن التوقيع يعتبر الشرط الأساسي لصحة الكتب الخطي الذي يختلف عن الكتب الرسمي في كونه لا يتطلب لتحريره وجود طرف ثالث -المأمور العمومي- بل يقتصر على وجود طرفي العقد .

وحيث أن الكتب الرسمي وباعتباره يستمد رسميته من شخص المأمور العمومي لذلك فإن حجيته تكون أقوى من حجية الكتب الخطي فهو يمثل حجة مطلقة تجاه الطرفين وتجاه الغير بينما حجية الكتب الخطي تقتصر على شخصي المتعاقدين فحسب.

وحيث وبالرجوع إلى مظروفات الملف وتحديدًا الحجة المحررة من طرف عدل الإشهاد الهادي المشري يوم 18-9-1998 المراد بإبطالها تبين أن موضوعها تعلق بتولي المعقبة الآن التفويت بالبيع للمعقب ضدهما أنصافا بينهما على الشياخ وبثمن قدره ألفان وأربعون دينار في جميع المناب المعقول على محمد بن عبد القادر النوالي من كامل الغرس زيتون الكائن بمنطقة سيدي

«عبد الجبار» عمادة الطليارية والذي انجر لها بموجب حكم التثبيت عدد 864 الصادر عن دائرة البيوعات العقارية للمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 20-11-1997 .

وحيث يتبين مما تقدم أن البيع موضوع النزاع يتعلق بعقار غير مسجل وبالتالي فهو لا يخضع لمبدأ التحرير الوجوبي من قبل عدول الإشهاد أو غيرهم من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 377 مكرر م ح ع.

وحيث ثبت من جهة أخرى أنه صدر عن محكمة الاستئناف بالمنستير بتاريخ 28-11-2006 حكم تحت عدد 1724 قضى نهائيا حضوريا بثبوت إدانة عدلي الإشهاد الهادي المشري وعبد المجيد المكني من أجل جريمة اقامة صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية طبق أحكام الفصل 199 من المجلة الجزائية تأسيسا على القول بأن عدل الإشهاد الهادي المشري عند تحريره للصك ولئن ثبت انه لم يغير إرادة الطرفين المصرح بها لديه ولم يلحق بهما مضرة واضحة خاصة أو عامة الا انه تعمد التنصيص بالحجة المذكورة على أمور غير حقيقية مادية والمتمثلة في حضور جليسه العدل عبد المجيد المكني عند تلقي تصريحات المتعاقدين في حين انه ثبت مادية باعترافهما أن هذا الأخير لم يكن حاضرا بمجلس العقد وأمضى بالكتب لاحقا وهو ما يوجب مؤاخذتهما جزائيا .

وحيث استقر فقه القضاء على اعتبار انه « لا يجوز للقاضي المدني أن يتجاهل ما أثبتته القاضي الجزائي بحكمه من حيث مرتكبي الفعل الضار وحصول الضرر منه للمجني عليه إلا أنه يبقى حرا في تقدير درجة الخطأ وتوزيع المسؤولية».

وحيث خلافا لما ورد بمستندات التعقيب فإن محكمة القرار المنتقد تكون قد أصابت في تعليل قضاءها وطبقت القانون تطبيقا سليما لما وقفت على ما انتهى إليه القاضي الجزائي عند نظره في الدعوى العمومية ذلك ان حكمه هو مبنى القيام بطلب الإبطال لدى محكمة الأصل وعليه فإنها لما اعتبرت استنادا إلى ما أثبتته الحكم الجزائي انتفاء كل تحيل أو تزوير أو تحريف لإرادة الطرفين المتعاقدين الذين امضيا على العقد بكامل إرادتهما وان العيب لم يطل الا مسالة حضور عدل الإشهاد الجليس لم تحرف الوقائع ولم تخرق مقتضيات الفصل 481 م ا ع بل أنها طبقت القانون تطبيقا صحيحا حين أخذت بعين الاعتبار لما

أثبتته تتبع الجزائي ورتبت على ذلك الآثار القانونية السليمة عملاً بمبدأ حجية الجزائي على المدني .

وحيث وبالرجوع إلى أحكام الفصل 448 م ا ع المشار إليه أعلاه يتضح أن المشرع استعمل عبارات دالة على ضرورة نزع الصيغة الرسمية عن الحجة الرسمية الباطلة وتنزيلها منزلة الكتب غير الرسمي عند وجود إخلال بشروط تحريرها من ذلك عبارة «إذا كان الكتب لا يعتبر رسمياً» وعبارة «أعتبر كتباً غير رسمي» التي تفيد حتما تحولا في طبيعة الكتب ذاته من كتب رسمي إلى آخر غير رسمي .

وحيث علاوة على ما تقدم فإن التوقيع هو الشرط الجوهرى الوحيد لصحة الحجة غير الرسمية وان الكتب غير الرسمي يستمد قوته من توقيع الأطراف باعتبار أن الإمضاء هو تصديق على ما ذكر بالكتب وهو دلالة على انصراف إرادة المتعاقد إلى قبول التصرف القانوني .

وحيث يستنتج مما سلف بسطه وخلافا لما ورد بمستندات التعقيب أنه ولئن ثبت من خلال الحكم الجزائي المظروف بالملف اختلال شرط حضور عدل الإشهاد الجليس عند تحرير الحجة المؤرخة يوم 18-9-1998 فإنه وطالما ثبت لمحكمة الحكم المطعون فيه تولي جميع أطراف الكتب الإمضاء عليه ولم يثبت من خلال الحكم الجزائي حصول أي تغيير في إرادة الطرفين المصرح بها فضلا عن أن الصبغة الرسمية لم تكن مشترطة لصحة التصرف موضوع الكتب المطعون فيه بالإبطال الآن فإن كل ذلك ينزع عن الحجة الرسمية الصادرة عن عدل الإشهاد الذي حررها الصبغة الرسمية لترد في عداد الكتائب الخطية رغم ثبوت تولي الجليس إمضاء الكتب بصفة لاحقة ويبقى احتجاج الطاعة الآن مثلما ذهبت إليه محكمة الحكم المعقب بعدم معرفتها لما ضمن بالعقد على وجه اليقين نتيجة عدم التلاوة مردود عليها باعتبار أن الكتب الخطي يكتسب حجية مطلقة بين المتعاقدين بمجرد إمضائه .

وحيث وتأسيسا على ما سلف بسطه أضحى الخدش في الحكم المنتقد على أساس مخالفته القانون فضلا عن تحريفه الوقائع غير مبرر واقعا وقانونا وكان

القرار المنتقد معللاً سليماً وبصفة يتجلى منها حسن تطبيق القانون وتعين لذلك رد جملة المطاعن المثارة لعدم وجاهتها ورفض التعقيب أصلاً.

وحيث أخفقت المعقبة في طلبها واتجه حيز معلوم الخطية المؤمن من طرفها عملاً بأحكام الفصل 184 من م م م ت».

3 - 3 البيع

3-3-1 الفرق بين انتقال الملكية وتسليم المبيع - ضمان الاستحقاق الجزئي

قرار تعقيبي مدني عدد 70752 بتاريخ 19 ماي 2020 صادر عن الدائرة المدنية السادسة عشر برئاسة السيدة وسيلة التليلي وعضوية المستشارتين السيدتين آسيا العياري وعربية الطويهري وبحضور المدعي العام السيدة لطيفة العرفاوي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلي الرياحي.

«عن المطعن الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق الفصلين 402 و 629 م إ ع:

حيث أن الدعوى تأسست ابتداء على مقتضيات الفصول المتعلقة بضمان الاستحقاق وهو ما يقتضي بدهاء استبعاد الفصل 629 م إ ع الوارد في الفرع المتعلق بتسليم المبيع بما يجعل القواعد العامة المتعلقة بالتقادم المنصوص عليها بالفصول 384 م إ ع وما بعده هي المنطبقة.

وحيث أن استبعاد محكمة الحكم المنتقد لقاعدة الفصل 629 م إ ع كان في طريقه وتعين لذلك ردّ المطعن.

عن بقية المطاعن لارتباطها ووحدة القول في شأنها:

حيث أن تعليل الأحكام لا يكون قانونياً وكفيلاً بتحقيق المقصود منه إلا متى إنبنى على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لأجوبة المحكمة عما أثير من دفع بصورة تقنع المطلع عليها بوجاهتها فإن خلا من ذلك كان مستهدفاً للنقض لخلوه من التسبب الكافي والتفاته عن وجهة الرد عما أثير من دفع جوهرية.

وحيث اكتفت محكمة الحكم المنتقد بالقول أنه «ثبت فيما يخص الجزء موضوع الرسم العقاري عدد 13050 صفاقس أن المستأنف ضدها المعقبة الآن باع ما لا تملك وأن الاستحقاق المحمول على البائع لا ينحصر في تسليم المبيع للمشتري وعدم التشويش عليه أو التعرض له بل يتمثل بالأساس

في نقل لملكية المحل موضوع التعاقد» دون استعراض مبررات حكمها بفسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع ودون الرد على دفع المستأنف ضدها المعقبة الآن بأسلوب يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحكمها فضلا على إسقاط جملة من المفاهيم القانونية رغم اختلاف أنظمتها القانونية والخلط بين مفهوم انتقال الملكية الذي يحدث بمجرد الاتفاق على أركان العقد بصفة آلية وذهنية وبين التسليم كعملية مادية حصلت فعلا بموجب تخلي البائعة عن المبيع كيفما هو ثابت بالعقد المطلوب فسخه من أنها «سلّمت له المبيع فتسلمه منها وقبله وحازه عنها حوزا ناجزا معترفين بالرؤية والتقليب والرضا» وبين ضمان الاستحقاق كال التزام محمول على البائعة كان على المحكمة بيان شروط ضمانه طبق ما يقتضيه الفصل 631 وما بعده من م إ ع والنظر في مدى تفعيل موجبات الفصل 640 م إ ع الذي دفعت به المستأنفة المعقبة الآن وذلك بالبحث فيما إذا كان الجزء المستحق موضوع الرسم العقاري عدد 13050 صفافس والماسح لـ 230،5 م م له أهمية من عدم ذلك مقارنة بكامل مساحة المبيع أخرى وأنه إذا لم يكن للجزء المستحق أهمية توجب عينا فليس للمشتري الفسخ وإنما له طلب حطّ القيمة بقدر ما استحق لا غير.

وحيث جاء الحكم المتقدم قاصر التسيب والتعليل ولم تبرر فيه المحكمة ما يبرّر الاستجابة لطلب فسخ العقد الأمر الذي حال دون مراقبة هذه المحكمة لتطبيق القانون واتجه لذلك نقضه».

3-3-2 التفويت في ذات المبيع عن سوء النية يفتح التعويض على أساس الفصل 631 من م. إ. ع.

قرار تعقيبي عدد 76651 بتاريخ 14 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجلاء المصمودي والسيدة نجوى الغربي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن جملة المطاعن لترباطها واتحاد القول فيها

حيث أسس المعقب طعنه على أن القطعة موضوع مشتراه هي ذاتها موضوع التداعي الحاملة عدد 1252 وعلى توفر عنصر سوء النية في جانب البائع مورث المعقب ضدهم لقيامه بالتفويت في ذات المبيع.

وحيث تبين من أسانيد القرار المنتقد أنه تضمن تحريفا وضعفا في التعليل فالمدعي في الأصل يملك بموجب الشراء في سنة 1971 وأنه تم حرمانه من مشتراه من البائع له بعد أن أعاد التفويت في العقار لابنه في سنة 1991 وهو البيع الذي تم إخفائه من البائع له ومن المعقب ضده الذي اعترض على حكم القسمة بين المدعي - الطاعن - والبائع له مورث المعقب ضدهم ولم تقع إثارة ملكية المعقب ضده إلا بعد القسمة وإخفاء متعمد للعقد المبرم بين هذا الأخير ووالده وهو ما يبرز سوء النية ويفتح الحق للطاعن في الاستناد للفصل 631 من ماع لطلب التعويض وكان على محكمة الموضوع الوقوف على تلك العناصر للتحقق من توفر ركن سوء النية في جانب البائع مورث المعقب ضدهم الذي استغل عدم إدراج الطاعن لمشتراه بالرسم العقاري للتفويت فيه لابنه المعقب ضده كقيامه بالتفويت في القطعة عدد 673 لابنته المعقب ضدها بما لا يترك للطاعن أي إمكانية لتسلم مشتراه وهي مسألة غفلت محكمة الحكم المطعون فيه عن تمحيصها وترتيب النتائج القانونية عليها بتعويض الطاعن عن قيمة المبيع غير أن التقدير لا يمكن أن يكون في تاريخ القيام بالدعوى في سنة 2010 وإنما في تاريخ التحقق من الطاعن أنه لم يعد بإمكانه الرجوع على العقار وذلك في سنة 1998 تاريخ صدور القرار الاستئنافي الاعتراضي القاضي بإلغاء مفعول حكم القسمة المعارض عليه الذي كان اعتبر مبيع الطاعن الآن يتمثل في القطعة عدد 1252 ولأن نفي استحقاق الطاعن للقطعة موضوع التداعي كان بموجب القرار الاستئنافي الاعتراضي وهو التاريخ المعتبر في تقدير القيمة المستحقة في التعويض وقد جانبت محكمة القرار المنتقد الصواب في ما انتهجته وأساءت تعليل قضائها بما يوجب النقض.

وحيث رد المعقب ضده الأول على تلك المستندات بواسطة نائبه بأن شراء المعقب لا يتعلق بالقطعة موضوع التداعي بما يجعل شرط دعوى الضمان مناط الفصل 631 من ماع غير متوفر وأن عنصر سوء النية غير ثابت والقيام على الورثة في غير طريقه لرفضهم التركة وطلب رفض التعقيب أصلا .

و حيث ردت المعقب ضدها الثانية على تلك المستندات بواسطة نائبها بعدم
تعلق شراء المعقب بالقطعة موضوع النزاع كعدم توفر شروط الفصل 631 من م
اع وغياب عنصر سوء النية كما أن القيام على الورثة في غير طريقه لكونهم تولوا
التصريح برفضها وطلب رفض التعقيب أصلاً».

3 - 4 هبة

3-4-1 ابطال عقد هبة لأسبقية الدين طبق الفصل 306 من م.إ.ع.

قرار تعقيبي عدد 68902 بتاريخ 20 جانفي 2020 برئاسة السيدة مريم البكوش
وعضوية المستشارين السيد وليد بن جديدية والسيدة عربية الطويهي وبحضور
المدعي العام السيد سفيان العرابي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة
الغزواني.

«عن المطعنين لوحدة القول فيهما:

حيث ان هذين المطعنين إنما يريان إلى إعادة طرح ما سبق الدفع به لدى
محكمة الموضوع بخصوص تعلق كتب الاتفاق المعرف عليه بالإمضاء في
29/12/2010 وكتب إجراء الحساب المعرف بالإمضاء في 10/11/2011
بمديونية جديدة غير التي تعلق بها الأمر بالدفع عدد 376 الصادر في
16/09/2009 ما يجعل الحكم بالإبطال المؤسس على ما تم القضاء به
بموجب الأمر بالدفع المذكور في غير طريقه ، وهو نقاش موضوعي محض مكانه
التداعي الموضوعي لتعلق الأمر بتقدير للأدلة تستقل محكمة الأصل بنظره ولا
معقب عليها في ذلك من لدن هذه المحكمة بشرط التعليل الصحيح ، وقد أبانت
مستندات القرار المطعون فيه ان المحكمة اعتبرت انه بالاطلاع على الكتبين
المذكورين يتضح انه قد تمت عنونتهما بكتب اتفاق وإجراء حساب مما يستشف
منه وجود دين محل اتفاق إعادة جدولة وان بنود الكتبين تضمنت أن موضوع
الجدولة يتعلق بباقي أصل الدين موضوع الأمر بالدفع عدد 376 وأضافت
المحكمة أن الأمر بالدفع والإجراءات التي تبعت محاولة استخلاصه والتي
انتهت بعقلة تنفيذية تم رفعها بنفس تاريخ إمضاء كتب الاتفاق وإجراء الحساب
وبنفس التوقيت مما يدل على أن رفع العقلة كان بناء على كتب اتفاق الذي لا

يعتبر دينا جديدا في غياب ما يفيد خلاص كامل الدين والإبراء منه منتهية إلى أن عقد الهبة المحرر بتاريخ 02/01/2011 تتوفر لإبطاله شروط الفصل 306 ماع حيث اقتضى الفصل 242 ماع ان ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين الطرفين

وحيث أن التعليل المنتهج من محكمة القرار المطعون فيه تأسس على الثابت من بنود كتيبي الاتفاق وإجراء الحساب التي تثبت على نحو صريح وثابت تعلقهما بإعادة جدولة باقي الدين المحكوم به بموجب الأمر بالدفع عدد 376 وكان الدفع بكون الدين الذي صدر به الأمر بالدفع المذكور قد تم خلاصه كليا غير ثابت ولم يأت المعقبان بما يقطع به

وحيث ومن جهة أخرى نعى نائب المعقبين على محكمة القرار المطعون فيه التفاتها عن الطلب المقدم من قبله والرامي إلى التحرير على الطرفين شخصا للوقوف على أن انقضاء الالتزام الناشئ على أساس الأمر بالدفع عدد 376 وعلى نشأة مديونية جديدة غير مرتبطة به

وحيث ومع التسليم ابتداء أن قاضي الموضوع هو الذي يسير ويراقب إجراءات تحقيق الدعوى وله ترجع سلطة الإذن بإجراء الأبحاث التي تحتّمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها ومن ضمن الأعمال الاستقرائية الإذن بإجراء تحريرات على الأطراف ، فانه يمكن لمحكمة الأصل الإذن بذلك أو الالتفات عن الطلب المقدم في الغرض بحسب ما تراه لازما لبناء حكمه ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما لم يثبت أنها أخلّت بموجبات التعليل السليم وكانت مناقشتها في ذلك من قبيل الجدل الموضوعي بما لا يسع معه إلا رد هذا الفرع

وحيث أن ما انتهى إليه قضاء محكمة القرار المطعون فيه بخصوص تعلق الكتيبن المبرمين بين طرفي التداعي بإعادة جدولة خلاص باقي الدين موضوع الأمر بالدفع عدد 376 ومن ثمة أن عقد الهبة المبرم بين المعقبين لاحق للدين وان شروط الفصل 306 ماع قد توفرت لإبطاله ، إنما كان تطبيقا لصحيح القانون على الثابت من الوقائع وهو ما يجعل القرار المذكور قد استوفى موجبات التعليل السليم وتعين لذلك رفض الطعن أصلا».

3-4-2 الهبة في مرض الموت

قرار تعقيبي عدد 68902 بتاريخ 20 جانفي 2020 برئاسة السيدة مريم البكوش وعضوية المستشارين السيد وليد بن جديدي والسيدة عربية الطويهري وبحضور المدعي العام السيد سفيان العرابي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني.

«عن المطعنين لوحدة القول فيهما:

حيث يقتضي النظر في وجهة هذا الطعن تأطير الأمر بمساره الصحيح على نحو مؤداه أنّ نظر محكمة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة محكوم بالضرورة وعملا بالفصل 191 م.م.م.ت - بنطاق ما تم تعهدها به من قبل محكمة التعقيب بموجب قرارها عدد 24965 بتاريخ 10/12/2015 الذي بنى نقضه على أساس أنّ محكمة الموضوع جانبت الصواب في تكييفها لمرض الواهبة كما تخلت عن سلطتها عن غير صواب وحرفت الوقائع ضرورة أنّ الحكيم شخص الحالة وعائنها ووصفها وبين ما نتج عنها من قعود الواهبة عن قضاء شؤونها وحاجتها لمن يساعدها كما ان المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ تحرير العقد والوفاة له أهميّة على توصيف المرض ولا معنى لتعليل المحكمة بان العدول عاينوا حالة الوعي التي كانت عليها الواهبة فالعدول لا يمكنهم ان يقوموا بدور الطبيب.

وحيث لا خلاف في أنّ المرض هو أمر واقعي تجتهد محكمة الموضوع في تقديره رجوعا إلى المؤيدات المدلى بها - بعد الترجيح بينها وهذا كله يخرج عن رقابة محكمة التعقيب - أمّا تكييف ذلك المرض بأنه مرض موت وتحديد تأثيره على صحة ما أتاه المريض من تصرفات قانونية ، فهذه مسألة قانونية تختص محكمة الأصل بتقديرها - وتكون بصبغتها تلك - خاضعة لرقابة محكمة القانون، على تقدير أنّ محكمة الموضوع وفي سبيل تكييفها أنّ المرض يمثل مرض موت أنما تستحضر مفهومها قانونيا تطبقه على الوقائع الثابتة لديها ، حتى إذا ما سلمنا بذلك ورجعنا إلى القرار المطعون فيه يتضح أنّ محكمة الإحالة ، وبعد أن إستعرضت شروط مرض الموت ومحصت وقائع الدعوى وخصوصا فحوى التقرير الطبي المشخص لحالة الواهبة والمدة التي فصلت بين الكتب المطعون

فيه والوفاة ، انتهت في نطاق سلطتها التقديرية إلى تقرير أنّ شروط مرض الموت قائمة لثبوت ان إصابة الواهبة بمرض السرطان جعل حالتها الصحية ميؤوس من شفائها وهي في تدني متزايد وحالة الوعي لديها غير مستقرة وان العقد المطعون فيه قد ابرم قبل اقل من شهرين من وفاتها.

وحيث إنّ ما عللت به محكمة القرار المنتقد إبنى على الثابت من الوقائع ورتبت عليه نتيجة قانونية صحيحة في غير تحريف وفي كنف الالتزام بأسباب النقض التي صدر بها القرار التعقيبي سند تعهدها.

وحيث أنّ ما تمت إثارته بالمطعن الأول من كون العقار الموهوب لم تزد قيمته عن ثلث مخلف الواهبة وان ملف القضية خال تماما مما يفيد أنّ العقار الموهوب هو كل مخلف الواهبة وان ملف القضية خال تماما مما يفيد أنّ العقار الموهوب هو كل مخلف الواهبة أو أنّه أكثر من ثلث مخلفها ، كان خارجا عن أسباب والنقض والإحالة وعليه فان تطبيق صحيح القانون عليه يقتضي الالتفات عن النظر فيه عملا بالفصلين 176 و 191 م م م ت.

و حيث أنّ تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية طالما كان ذلك متوجا بتعليل سليم واقعا وقانونا متماهي مع ما حواه الملف من معطيات دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون وهو ما اجتمع في قضاء محكمة القرار المطعون فيه واتجه رد هذا الطعن أصلا.

وحيث أخفق المعقبان في طلبهما واتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرفهما عملا بأحكام الفصل 184 من م.م.م.ت.».

3-5 الوصية

3-5-1 إبطال وصية

قرار تعقيبي عدد 69259 بتاريخ 19 فيفري 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثالثة برئاسة السيدة نعيمة رحيم وعضوية المستشارتين السيدة عبير الخليفي والسيدة نورة نوري وبمحضر ممثل الادعاء العمومي السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عبير الحلواني.

«حيث اقتضت أحكام الفصل 185 من م ا ش انه « إذا هلك الموصى به المعين أو استحق فلا شيء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق اخذ الموصى له ما بقي منه» كما نص الفصل 186 أنَّ الموصى به يجب أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إذا كان معيناً بالذات».

و حيث أوجب الفصلين المذكورين ضرورة تملك الموصي بموضوع الوصية كما تعرضا لصورة الهلاك الكلي أو الجزئي لها والحقوق المترتبة للموصى له .
و حيث انه لا يجوز تحميل عبارات النص بأكثر مما دلت عليه مقاصده وطالما لم يشترط المشرع صلب الفصلين المذكورين تعيين الموصى به وتفصيله فلا موجب لاعتمادهما للتأسيس لدعوى إبطال الوصية التي تسلطت على جميع ممتلكات الموصي.

و حيث ولئن تسلطت الوصية على كامل ممتلكات الموصى فان حسن تطبيق القانون يوجب على المحكمة التحقق من وجود العين موضوع الوصية وبقائها على ذمة الموصي قبل وفاته أو عدم هلاكها باعتبار أنَّها تمثل محل العقد التي باختلالها ينعدم كتب الوصية.

و حيث أن تعليل الأحكام شرط لصحتها وذلك بأن تبين المحكمة اقتناعها بما قضت به وجعلته نتيجة في حكمها والاتجاه التي أطمأنت إليه فيشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي أنبنى عليها الحكم ولقد أوجب القانون تعليل الأحكام بتضمينها الإدعاءات ودفع الخصوم وفهم ما أحاطت بها من مسائل قانونية لتتمكن محكمة التعقيب من مراقبة أحكام المحاكم حتى تشرف على تطبيق القانون هذا فضلا على أن القضاء المعلل يضمن الاطمئنان على نفوس المتقاضين. وحتى تصدر الأحكام ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون يلزم أن يضمن القاضي صلب الحكم ملخصا لمقالات الخصوم وما اشتملت عليها من دفع وإثارات وما قدموه من أدلة وحجج ومناقشتها وتمحيصها والرد على ما كان جوهرها منها وله تأثير وجه الفصل في النزاع المعروض على المحكمة وبيين في أسباب الحكم ما استخلص ثبوته من الوقائع دون تحريف وطريقة الثبوت وما طبقه من قواعد.

و حيث تبين بالاطلاع على القرار محل الطعن ان المحكمة اعتمدت في قضائها على القرارين الاستثنائيين الصادرين عن المحكمة العقارية بتاريخ 03/02/2014 تحت عدد 901 و 902 وأهملت القرار الاستثنائي عدد 903 الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 03/12/2014 الذي رفض طلب ترسيم الوصية على العقار موضوع الرسم عدد 526787 لتفويت الموصي في جزء كبير من المنابات كما أهملت الحكم الابتدائي عدد 53496 المؤرخ في 29/06/2015 الذي رفض ترسيم الوصية بالرسم العقارية عدد 590993 وعدد 370888 وعدد 597087 ولم تنتظر ماله ولم تبين موقفها منها حال أنّها كانت محل دفع من الطاعنين وهو ما يعد هضمًا لحق الدفاع يستوجب تداركه بإرجاع القضية لمحكمة الأصل لإعادة النظر فيها.

و حيث انه ولئن تم ترسيم الوصية موضوع الطلب بالرسم العقاري عدد 590912 و عدد 597339 بموجب القرارين عدد 901 و عدد 902 فان ذلك لا يؤسس لما اعتمدته محكمة القرار المنتقد من أنّ مسالة ترسيم الوصية قد حازت على قوة الأمر المقضي به طالما أنّ الترسيم كان جزئيا على بعض الرسوم دون غيرها التي صدرت فيها أحكام بالرفض كيفما سبق بيانه أعلاه وهو ما يعد تحريفا للواقع يوجب نقض قرارها.

و حيث انه طالما لم تعتمد محكمة القرار المنتقد جميع مؤيدات الملف وأغفلت عن دراسة بعضها كما إنّها حرفت الوقائع في خصوص ترسيم كتب الوصية من المحكمة العقارية فانه تعين نقض قرارها».

3-6 المقاصة

3-6-1 تعريف المقاصة وعلاقتها بالمماثلة

قرار تعقيبي عدد 2019 / 83111 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجلاء المصمودي والسيدة نجوى الغربي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن الفرع الأول من المطعن الأول المأخوذ من مخالفة الفصل 374 من م ا ع :

حيث أسست المعقبة طعنها على توفر شروط المقاصة بين الدينين .

وحيث انه من الثابت أن المقاصة طريقة من طرق انقضاء الالتزامات حين يصبح المدين دائئا لدائنه فينقضي الدينين في نفس الوقت ولا تصح المقاصة إلا بتوفر شروط في الدينين فلا بد أن يكونا ثابتين ومعلومي المقدار وحل أجل خلاصهما أمّا إذا كان أحدهما أو كلاهما غير ثابت أو متنازعا في شأنه فانه لا يتسنى إجراء المقاصة وهو ما جرى عليه نزاع الحال فما أدلت به الطاعنة من فواتورات ظلت قاصرة عن إثبات المديونية في جانب دائئتها (المعقب ضدها) لكونها غير محلاة بصيغة القبول بما ينزع عن دينها المحتج به صفة الثبوتية ويحول دون القضاء بالمقاصة لعدم توفر شروط الفصلين 368 و 374 من م ا ع طبق ما انتهجته عن صواب محكمة القرار المتقد التي أحسنت تطبيق القانون بما يتجه معه رد المطعن لخلوه من كل سند صحيح .

عن باقي المطاعن لاتحاد القول فيها:

حيث تأسست المطاعن على اختلاف مبلغ الدين المطلوب بين ما تضمنه محضر الإنذار بالدفع وما يوجد بالفواتورات وما قضت به محكمة الأصل بما ينفي المماطلة عن المدينة ويجعل الدعوى غير محررة.

وحيث وخلافا لما ورد بالمطاعن فان المماطلة تثبت في جانب المدين بعد انذاره بوجه صريح بدفع ما عليه وتأخره رغم ذلك عن الوفاء دون سبب صحيح مثلما جرى علي نزاع الحال فالمعقب ضدها وجهت إنذارا بالدفع للطاعنة وطالبتها بوجه صريح بالأداء وأرفقت الإنذار بالفواتورات سند الدين وهو إجراء كفيل بإثبات المماطلة في جانب المعقبة التي تخلفت عن الأداء وأن الخلل في مقدار الدين المضمن بالإنذار لا تأثير له على جوهر الوفاء بالالتزام في ظل ثبوت الدين ولا ينزع عنها المماطلة لتوصلها بسند الدين المطلوب والذي يستند إليه في تحديد المبلغ المستحق وهي مسائل ترجع بالأساس لمطلق صلاحيات محكمة الموضوع لما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترتيب الأثر القانوني السليم وهو ما انتهجته عن صواب محكمة القرار المتقد فأحسنت تطبيق القانون بتعليل مستساغ ويتعين تبعا لذلك رد المطاعن لعدم وجاهتها .

قرار تعقيبي عدد 69381 بتاريخ 19 فيفري 2020 صادر الدائرة المدنية السابعة والثلاثين المتركة من رئيسها السيدة نازك كادة وعضوية المستشارتين السيدتين هنده العلاقي ورجاء الجزيري وبحضور المدعي العام السيد لطفي البدوي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة البرقاوي.

«حيث من المسلم به قانونا وفقها وقضاء أنّ التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام، لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي أو امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وعليه كانت ممارسته منظمة بجملة من القواعد والضوابط ولا سيما تلك المتعلقة بالمطاعن الجائر تقديمها بهذا الطور فلا يطرح أمام محكمة التعقيب إلاّ المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتشكل بذلك حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175 م م م ت كل ذلك دون الخوض في مسألة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة .

وحيث دفعت الطاعنة بمخالفة محكمة القرار المنتقد لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة بعدم تفعيل واجب الخصم من المورد على معينات التسويغ المستحقة ، كخرقها أحكام الفصلين 420 و 779 من م ا ع بإهمالها لواجب إثبات مدة استغلال المكري المدعى بها والمحمول على المعقب ضدها . كما عابت عليها الخطأ في تقدير معين كراء تلك المدة لعدم التجائها لأهل الخبرة والتفتاتها عن طلب إجراء المقاصة بين طرفي النزاع .

وحيث من الثابت أنّ جملة المطاعن المشار إليها إنما ترمي إلى إعادة طرح ما سبق الدفع به لدى محكمة الأصل ، وهو نقاش موضوعي محض مكانه التداعي الموضوعي لتعلق الأمر بتقدير للوقائع تستقل محكمة الأصل بنظره ولا معقب عليها في ذلك من لدن هذه المحكمة بشرط التعليل الصحيح، وهو ما استوفاه القرار المطعون فيه الذي أبانت مستنداته على أنّ المحكمة استعرضت وقائع النزاع وانتهت إلى أنّ تفعيل مقتضيات الفصل 52 من مجلة الضريبة يوجب على الطاعنة الإدلاء بشهادة قانونية في الخصم من المورد وهو ما لم يتوفر بملف القضية. كما رأت في خصوص النزاع المتعلق بمدة استغلال المكري أنّ محكمة

البداية قد أحسنت تأسيس قضائها على ما ثبت لديها من مصادقة الطاعنة على كشف استهلاك الماء والكهرباء بعنوان شهر أكتوبر وقد تأيد ذلك بإقرار هذه الأخيرة أمام محكمة القرار المنتقد بتقديمها وجبات أكل لفائدة المستأنف ضدها خلال شهر أكتوبر . كما أحسنت محكمة القرار المنتقد التعليل لما ردت الدفع المتعلق بمخالفة الفصل 779 من م ا ع بكون الحكم بمعين استغلال مماثل لمعين الكراء المعمول به بين الطرفين لا يتعارض مع أحكام الفصل 779 السالف الذكر الذي لا يكتسي أي صبغة أمر.

كما ردت طلب الطاعنة إجراء المقاصة باعتبارها جاءت مخالفة لأحكام الفصل 374 من م ا ع الذي اشترط ان يكون الدينين حاليين ومعلومي المقدار وهو ما لم يتوفر في قضية الحال.

وحيث يخلص من كل ذلك أنّ محكمة الحكم المطعون فيه قد أجابت عن المطاعن المثارة أمامها بصفة مستساغة واستوفى قضاؤها الموجبات القانونية والواقعية في التعليل فباتت مناقشتها فيما ذكر من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح طرحه على محكمة القانون واتجه رفض الطعن أصلاً».

3 - 7 البطلان المطلق

3-7-1 البطلان المطلق للعقد لغياب المحل

قرار تعقيبي عدد 69381 بتاريخ 19 فيفري 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثالثة برئاسة السيدة نعيمة رحيم وعضوية المستشارتين السيدة عبير الخلفي والسيدة نورة نوري وبمحضر ممثل الادعاء العمومي السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عبير الحلواني.

«حيث انه من المقرر قانونا على مقتضى الفصلين 176 و 191 من م.م.م.ت أنّ سلطة محكمة الإحالة مقيدة بنطاق ما أفصحت عنه محكمة التعقيب في منطوق حكمها صراحة من نقض كلي أو جزئي وهو مسالة تعد مطروحة إليها ولو لم يتعرض لها أي من الطرفين لتعلقها بمجال تعهدا وحدوده.

وحيث انه وإعمالا لما تقدم وبالرجوع إلى القرار التعقيبي عدد 32948 يتبين أنّ النقض الذي صدر به تأسس على سوء تطبيق الفصل 143 من القانون عدد 33

لسنة 1975 المنقح بالقانون عدد 43 لسنة 1985 الصادر في 25/04/1985 و المنقح بدوره بالقانون عدد 48 لسنة 2006 الصادر في 17/07/2006 في خصوص تطبيق الأجل المذكور به وكان لزاما على محكمة الأصل أن تتقيد بما ذكر. أما وقد نحت منحى مغايرا لما سبق إيراده بعدم الخوض مطلقا فيما عهدتها به محكمة النقض وعدم بيان موقفها من النص القانوني المنطبق لاحتساب السقوط فإنّها تكون قد أساءت تطبيق النصوص القانونية السالف الإلماع إليها فاستوجب حكمها النقض من هاته الناحية.

و حيث أوجب الفصل 123 من م م م ت لصحّة الأحكام تعليلها من الوجهتين الواقعية والقانونية وذلك يقتضي سرد الوقائع الكاملة المكونة للدعوى واستخلاص الصحيح منها وتقديره وإرساء التكييف القانوني السليم توصلا لإرساء القاعدة القانونية الملائمة وترتيب آثارها وذلك دون إغفال مؤيدات الدعوى وما تضمنته طلبات الخصوم فإن أهملت المحكمة كل أو بعض هذه المؤيدات والدفع كان حكمها معيبا ومستوجبا للنقض.

و حيث اتضح بالاطلاع على أوراق الملف أنّ المدعي في الأصل أسس لدعوى إبطال العقد الرابط بين المعقب ضده خميس والمعقب ضدها الثانية بانعدام المحل باعتبار أنّ إنجرار ملكية المعقب ضده للمبيع كانت بالشراء من شقيقه «الع». «بموجب عقد بيع تم إبطاله بموجب أحكام بate.

و حيث أنّ محكمة القرار المنتقد عوض أن تتناول مدى تعلق المبيع الرابط بين المعقب ضدهما بموضوع البيع الذي صدرت فيه أحكام نهائية بالبطلان وتبدي فيه رأيها القانوني حادت بالدعوى عن مسارها وطفقت تبحث في ملكية البلدية لمحل النزاع وفي انعدام صفتها كمدينة.

وحيث وترتبا على ذلك وطالما لم تتولى محكمة الإحالة بيان موقفها مما عهدتها به محكمة التعقيب وأهملت موضوع القضية الرامي إلى طلب الإبطال لانعدام المحل وأغفلت ما تضمنه عقد البيع موضوع طلب الإبطال في باب العرض التمهيدي من تنقيصات تعلقت بانجرار ملكية المبيع والإشارة صراحة إلى أنّ المعقب ضده الأول اشترى المقسم موضوع البيع من شقيقه «الع». حسب ما هو مضمن بالحجة العادلة المؤرخة في 08/01/1997 التي تمّ

إبطالها بالقرار الاستثنائي عدد 12518 المؤرخ في 23 / 01 / 2003 كما أهملت مضمون الرسم العقاري عدد 3508 من انه غير خاضع لمبدأ المفعول المنشأ وما يترتب عليه من آثار قانونية بخصوص العقود الغير مرسمة فإنها تكون قد أساءت تطبيق القانون وفهم الواقع وهضمت حق الدفاع بما يتعين معه نقض قرارها».

3 - 8 المسؤولية

3-8-1 المسؤولية التقصيرية

3-8-1-1 تعريف المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ

قرار تعقيبي عدد 2020 / 24195 بتاريخ 7 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن المطعنين الأول والثاني لترابطهما واتحاد القول فيهما:

حيث أسست المعقبة طعنها على انتفاء عناصر المسؤولية التقصيرية في جانبها ناعية على محكمة الحكم المطعون فيه الالتفات عن دفعاتها الجوهرية.

وحيث أنّ تأسيس القيام بطلب التعويض على أحكام المسؤولية التقصيرية مناط الفصل 83 من م ا ع يستوجب إثبات توفر عناصرها ويقضي من محكمة الموضوع التحقق من توفر تلك العناصر مجتمعة والمتمثلة في الضرر موضوع طلب التعويض والخطأ المنسوب للمقام عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومعنى ذلك أن تتولى محكمة الأصل الوقوف على كل عنصر لأن غياب أحدها تنتفي به المسؤولية ويحول دون القضاء بالتعويض وهو ما غفلت عنه محكمة الحكم المطعون فيه فقد اكتفت بثبوت الأضرار موضوع المطالبة بالتعويض استناداً منها إلى تقرير الخبير المنتدب ورتبت عليه نتائج قانونية دون أن تبحث أولاً في الخطأ أساس المسؤولية المنسوب للمطلوبة في الأصل (المعقبة) وثانياً في العلاقة السببية بينه وبين الضرر فحصول أضرار بأرض المدعين في الأصل (المعقبة ضدهم) لا يكفي بذاته لإلزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار ما لم يقيم الدليل على ارتكابها الخطأ فقيامها بأشغال بناء الطريق السيارة في مكان

مجاور ومحيط بأرض المعقب ضدهم لا يشكل خطأ مفترضا موجبا لقيام المسؤولية بل وجب بيان ماهية الخطأ الذي يقوم على مفهوم التعدي والانحراف بالسلوك وإقامة الدليل على إتيانها لأمر محظور أو امتناعها عن القيام بما وجب فعله على معنى الفصل 83 من م ا ع كإثبات العلاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون الخطأ المنسوب للطاعة في نزاع الحال هو السبب المنتج والمباشر في حصول الأضرار بأرض المعقب ضدهم دون غيره من الأسباب.

وحيث تبين من أسانيد القرار المنتقد أن محكمة الحكم المطعون لم تتناول عناصر المسؤولية التقصيرية على معنى الفصل 83 من م ا ع سند القيام سيما أمام منازعة المستأنفة لديها (المعقبة) في ارتكابها للخطأ وفي قيام العلاقة السببية وإثارته لدفعات جوهرية أهملت محكمة الموضوع مناقشتها وتمحيصها والرد عليها حال أنه من سلامة الأحكام وشروط صحتها وفق الفصل 123 من م م م ت أن تشمل كافة عناصر القضية ولا يكون التعليل قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا متى إنبنى على أسباب واضحة ومستساغة وشاملة لأجوبة المحكمة عما أثير لديها من دفعات فان خلا من ذلك كان مستهدفا للنقض لخلوه من التسبب الكافي والتفاته عن الرد عما أثير من دفعات جوهرية وقد خالفت محكمة الموضوع قاعدة التعليل السليم بعدم تناول ما أثير لديها من دفعات تعلق بانتفاء عناصر الفصل 83 من م ا ع سند القيام وفي أعمال الاختبار وما انتهى إليه في نتيجة أعماله وأورثت قضائها خرقا للقانون وضعفا في التعليل بما يوجب النقض».

3-8-1-2 أركان المسؤولية التقصيرية

قرار تعقيبي عدد 74684.2020 بتاريخ 7 جويلية 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«حيث كان المطعن صلب مستندات التعقيب في إهمال محكمة الحكم المطعون فيه لمؤيدات المعقب واختيارها للبعض منها لتجعلها حجة ضده وكان حكمها غير معلل وموجبا للنقض في توفر شروط المسؤولية الموجبة للتعويض وفق الطلب».

حيث لا خلاف تصديقا لقول المعقب أن محكمة الحكم المطعون فيه قد اطلعت على أوراق الملف واستنتجت ما تضمنه حكمها وأقر نائب المعقب أن إثبات الوقائع والمسائل المادية تبقى لاجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة محكمة القانون بشرط التعليل.

حيث أن القول أن الحكم يجب أن يضمن به الرد على الدفوعات وإن يتم فيه الاطلاع على مؤيدات الأطراف قول سليم وإن التوصل إلى استنتاج من المحكمة يجب أن يقترن بالتعليل ليتمكن فهم تلك النتيجة وتحديد أوجه الطعن فيها لدى محكمة القانون.

حيث أعاب المعقب على المحكمة استبعاد محاضر سماع الشهود لدى القاضي الجزائي في الشكاية الجامعة للأطراف كما لم تعتمد المحكمة أقوال الشهود والأجوار في المعاينة المحررة من قبل عدلي الإشهاد السيدين «م.ه» وجليسه والذين صرحوا بقيام المعقب ضده بإزالة الحواجز لفتح الطريق مما تسبب في الضرر الحاصل لمحطة البنزين التي على ملك المعقب ، كما بين المعقب أن الدعوى لم تستند إلى ملكيته للطريق العام المفتوح على الطريق السريعة عدد 22 إنما تضرر من حفر الطريق الفرعي من المعقب ضده وهو الطريق الذي انفق عليه مالا لتعبيده وتهيئته كما تمسك بمضمون تقرير الاختبار المأذون به والذي حقق قيام المعقب ضده بإزالة الحائط الحامي لمخرج المحطة وجرف التربة مما أضر بالطريق وهو مهين كـمخرج للمحطة مع تقدير الاختبار قيمة الضرر وما فات المعقب من ربح من نقص الحرفاء.

حيث وخلافا للطرح المضمن بمستندات التعقيب فإن المحكمة عرضت الإشكال القانوني الذي لم يطر لدى محكمة القانون واعتبرت ان النزاع في قيام المسؤولية في جانب المعقب ضده الآن وأنّ البت فيها يقتضي النظر في توفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

حيث خلصت المحكمة في ترتيب سليم لما توفر من مؤيدات دون فرز أو إقصاء إلى نتيجة أولى وهي ان التبع الجزائي في المسألة في علاقة بالمعقب ضده تعلق بشكاية قدمها المعقب ضد خصمه صدر فيها القرار الاستئنافي عدد 3652 في 20/1/2006 والذي تأسس على محضر بحث صادر عن مركز

الأمن الوطني بالمروج الأول الذي تعلق بالإحالة من أجل السب والعنف الشديد وتعطيل العمل وان مؤيدات النزاع الجزائي لم تخضع أو تتعلق بوقائع قضية الحال فيما تعلق أساسا بإضرار المعقب ضده بالملك العام الذي هو في انتفاع المعقب أو المساس بالمخرج الخاص بمحطة البنزين التي على ملك الدولة العمومي وفي تصرفه طبق موجبات القانون والرخص المعتمدة في النظام القانوني الخاص بها على مستوى استغلال الطريق العام.

حيث ثبت من استنتاجات المحكمة أن التتبع الجزائي بما فيه من محاضر وسماع شهود لا علاقة له بالضرر موضوع الدعوى الحالية كما طالبت المحكمة بالمحضر عدد 162 ولم يقع الإدلاء به للتحقق من مدى الوقوف على الضرر الواقع ادعائه سواء على مستوى عدم القدرة على استغلال الطريق أو الخسارة الناجمة عن ذلك.

حيث جاء في حيثيات المحكمة أن المعائنات المقدمة قاصرة عن إثبات الضرر والخطأ وان قول المعقب أن في استبعادها بها ضعف في التعليل قول مردود ذلك أن المحكمة لم تعتمد محضر سماع الشهود لمخالفته للفصل 82 م.م.ت وفي ذلك تعليل قانوني لسبب ردها لم يأت المعقب بما يخالفه.

حيث أن المعقب تمسك على امتداد التقاضي بثبوت الضرر المتمثل في حفر الطريق والإضرار به من المعقب ضده ووضع آلة تراكس المضمن وضعها في محضر البحث عدد 1178 إلا أنه لم يثبت من تقرير الاختبار ولا من المعائنات أو سماع الشهود أن سائق «التراكس» تلقى الأمر بالحفر أو غيرها من الأشغال من المعقب ضده وان التصريحات على اختلافها كانت إما في إطار الافتراض أو في تلقي شهادات غير معروضة على القدر طبق القانون، وكان قول المحكمة أن محاضر المعينة لم تتضمن تولي المعقب ضده القيام بالأشغال المضرة وأنها محاضر عاينت الوقائع ولم تعين الخطأ أو الفعل في حق المطلوب قول سليم كما كان قولها من خلال التدقيق في المحاضر والمؤيدات أن لا وجود لركن الإسناد قول سليم ومعلل ولم يأت المعقب بما يخالف ذلك قانونا وواقعا.

حيث ان قول المعقب أن الخبير المعين بطلب منه بموجب إذن على عريضة قد حقق في الاختبار أن المعقب ضده هو من قام بإزالة الحائط الحامي لمخرج

المحطة التي على ملك المعقب وهو من وضع الأتربة في الطريق قول مردود لعدم استناد الاختبار إلى مرجع قانوني سوى أقوال المعقب للإقرار بتوفر عنصر الإسناد وتعين رد ما تضمن من معطيات ليس من شأنها المساس بجوهر الحكم ومضمونه فضلاً عن تحديد الاختبار للمضرة وتقييمها دون أن يكون للخبير اختصاص التقدير كما أنه لا سند للنقص في رقم المعاملات والحرفاء مما يجعل التقرير غير ذي موضوع.

حيث لم تأت المستندات بما يوهن الحكم المطعون فيه على مستوى إسناد الخطأ وإحداث الضرر للمعقب ضده مما ينفي قانوناً توفر المسؤولية التقصيرية ويحول دون الاستجابة للدعوى كما حررت ووفق مؤيداتها وكان الحكم معللاً وتعين رفض التعقيب أصلاً».

3-8-2 المسؤولية التعاقدية

3-8-2-1 المسؤولية التعاقدية للناقل الجوي

قرار تعقيبي عدد 2020.68400 بتاريخ 28 جانفي 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«عن المطاعن المأخوذة من خرق وسوء تأويل وتطبيق الفصل 17 من اتفاقية فرسوفيا المتعلقة بالنقل الجوي:

قولا من المعقبة أنّ المحكمة خالفت في حكمها الفصل 17 من اتفاقية فرسوفيا الخاصة بالنقل الجوي من حيث فهمه وتطبيقه على النزاع مشددة بواسطة نائبها على ضرورة التفرقة بين قرينة المسؤولية وقرينة الخطأ وحق الناقل في الانتفاع بشروط الإعفاء من المسؤولية عند إحسان ربط الفصل 17 بالفصول 20 و21 و23 من ذات الاتفاقية.

وحيث اعتبرت المحكمة الاستئنافية أنّ الحادثة لم تكن بسبب المعقب ضدها كما ان السقوط الحاصل لا يعزى إليها معتبرة أنه بغض النظر عن سبب السقوط فإن الحادث حصل أثناء مراحل السفرة في مكان في عهدة الناقل الجوي.

حيث وخلافا لما جاء بمستندات التعقيب فإن محكمة الحكم المطعون فيه أحسنت تطبيق الفصل 17 من اتفاقية فرسوفيا باعتبارها الإطار القانوني الدولي والمصادق عليها من الجمهورية التونسية ذلك أنّ الفصل كرس مسؤولية الناقل الجوي عند تعرض المسافر إلى حادث على متن الطائرة أو أثناء عملية الرحيل أو النزول من الطائرة وبالقياس عند الصعود إليها والتأهب لذلك كما في صورة قضية الحال.

وحيث أنّ قول المعقبة أنّ الحادث لا يمكن أن يكون كل واقعة أو حدث أيا كان وإن غاية المشرع في الفصل أن يكون كل فعل خارج بطبيعته عن إرادة المسافر أو أن يكون غير متوقع أو غير المألوف ويتسبب في إلحاق الضرر به قول يتوافق مع طبيعة الحادث الحاصل للمعقبة ذلك أنّها لم تكن متسببة فيه ولم تتعمد وقوعه فضلا عن انطباق المكان والزمان على ميعاد الرحلة الجوية المغطاة من المعقب ضدها.

وحيث أنّ نسبة الحادث الحاصل للمعقب ضدها لسقوطها وحدها وبنفسها لا يغير من الواقعة التي تمت عند الاستعداد للصعود للطائرة وإن المعقبة لم تشر إلى مسؤولية الغير من المتدخلين في الحادث على أنّ دحض القرينة القائمة على مسؤولية الناقل لا يكون بإسناد ركن المسؤولية للمسافر دون إثبات التعمد المفضي إلى الرغبة في تثقيب كاهل الناقل بالتعويض وفق منهجية الطرح المعروض دون أدلة معتمدة واقعا وقانونا مما تعين رد التأويل للفصل المذكور. وحيث اعتبرت المعقبة أن اتفاقية فرسوفيا اتخذت حلا توفيقيا بإرسائها لقرينة الخطأ دون قرينة المسؤولية وذلك لتمكين الناقل الجوي من وسائل الإعفاء من الخطأ بإثباته اتخاذ جميع الوسائل لتفادي وقوع الضرر مع تحميله عبء إثبات ذلك.

حيث أنّ هذا التمشي فيه تضيق لما تم تشريعه بموجب الفصل 17 من الاتفاقية التي أرسى قرينة المسؤولية في جانب الناقل باعتباره الضامن والمسؤول عن الحادث مطلقا ومكنته من إثبات اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومن إثبات تسبب من لحقه الضرر فيه وفق موجبات الإعفاء الحصرية في الفصل 20 من الاتفاقية والتي لا تقبل التوسع على أنّ المعقبة لم تثبت تسبب المتضررة المعقب ضدها

في الحادث ولم تأت على وسائل الحيلة المفترضة لحماية المعقب ضدها من فرضية وقوع الحادث وان شروط الإعفاء المحددة بالنص لم تتوفر وتبقى المسؤولية قائمة على معنى الفصل 17 في غياب وسائل دحضها المحدودة باعتبار قيام المسؤولية هو المبدأ باعتبار روح التشريع الدولي وسبل الإعفاء محصورة ومشروطة فضلا عن ان المعقبة لم تثبت الخطأ في جانب المعقب ضدها أو الغير مما يصير دفعها بسوء تطبيق وتأويل الفصل 17 من الاتفاقية في غير محله وتعين رده.

عن المطعن المأخوذ من خرق الفصل 22 من اتفاقية فرسوفيا:

حيث عرضت المعقبة انه على فرض الإقرار بمسؤولية الناقل الجوي عن الحادث فإن الفصل 22 فقرة أولى جعل التعويض محددًا بمبلغ يقدر بوحدة الفرنك الذهبي DTS وفي حدود 125 ألف فرنك ذهبي ناعيا على الحكم التعويض باعتماد مبلغ جزافي غير مقرر بالاتفاقية.

وحيث وخلافا للمطعن المتعلق بحدود التعويض فإن محكمة البداية لم تقدر التعويض جزافيا بل استندت إلى عرض المتضررة على الفحص الطبي وقدرت التعويضات المادية والمعنوية على ضوء تقرير اختبار ونسبة سقوط نهائية وفق التشريع الداخلي المنطبق والذي لا يتعارض فنيا مع التشريعات الدولية على أن الخوض في الدفع من الأساس لا فائدة ترجى منه لا اعتبار أن مسألة التعويض ومن ورائها التقدير مسألة موضوعية كان على الطاعنة إثارتها لدى محاكم الأصل غير أن إثارة عدم تطبيق الفصل 22 بخصوص التعويض عن الضرر كانت لأول مرة لدى محكمة القانون وان المطعن له علاقة بمسألة موضوعية لا يصح إثارتها لأول مرة لدى هذه المحكمة على أن كل ما له علاقة بالتقدير والوقائع من مشمولات محكمة الأصل وكان الدفع في غير محله وتعين رده والقضاء برفض التعقيب أصلا لعدم توصل المعقبة إلى المساس بوحدة القرار المطعون فيه وسلامة التقدير والتعليل فيه».

3-8-2-2 المسؤولية التعاقدية المكرسة بمجلة الموانئ البحرية

قرار تعقيبي مدني عدد 80700 بتاريخ 29 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثانية والثلاثين برئاسة السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين

السيدتين راضية المنتصر ونفيسة العلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الحلواني .

«-عن المطعن الأول:

حيث نسبت المعقبة للقرار الاستثنائي المطعون فيه سوء تطبيق القانون بمقولة أن المحكمة خالفت مقتضيات الفصل 242 م ا ع لما ألزمتها بالتعاقد مع المعقب ضده والحال أن ركن الرضا منعدم فضلا عن مخالفتها أحكام مجلة الموانئ البحرية التي تقتضي المساواة أمام المرفق العام.

وحيث خلافا لما ورد بهذا المطعن فقد ثبت من مطروفات الملف أن المعقب ضده حين تعاقد مع المعقبة بوصفها باعثا عقاريا واقتنى منها منزلا بالميناء الترفيهي الذي تولت تشييده على خليج قمرة اتفقا صلب المراسلة الصادرة عنها والموجهة للمعقب ضده بتاريخ 14 ماي 2009 على موافقتها على تمكينه من الحصول على حلقة إرساء بالميناء الترفيهي طولها 16 م كما أكدت له صلب الشهادة الصادرة عنها بتاريخ 24 جويلية 2013 أنها وضعت على ذمته بميناء خليج قمرة عدد 2 مرافئ لإرساء مركبه الأول طوله 18 م والثاني طوله 16 م وذلك باعتبار أنه مالك لمسكنين بمارينا قمرة .

وحيث ومثلما أكدته محكمتي الموضوع يتبين مما تقدم أن حق المدعي في إرساء سفينته في احد الأماكن المخصصة لذلك بالميناء الترفيهي مارينا قمرة هو حق استمدته من العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين المعقبة وهو أيضا مخول له بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 08-07-2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية الذي كرس مبدأ المساواة بين كل مستعملي الملك العمومي للموانئ البحرية والاستمرارية في تقديم الخدمات .

وحيث يكون لذلك هذا المطعن المثار من قبل المعقبة غير مبرر واقعا وقانونا وكان القرار المنتقد معطلا سليما وبصفة يتجلى منها حسن تطبيق القانون وتعين لذلك رده لعدم وجاهته .

-عن المطعن الثاني:

حيث لا جدال في أنه ومثلما هو ثابت من أوراق الملف فان المعقبة هي من تستغل الميناء الترفيهي مارينا قمرة وترجع لها سلطة تسييره والإشراف عليه

اثر حصولها على لزمة لتسيير الملك العمومي للموانئ البحرية عملا بمقتضيات القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 08-07-2009 المشار إليه أعلاه وعليه فقد أضحى هذا المطعم المؤسس على الدفع بانتفاء الصفة في جانبها للتعاقد مع الغير فاقدًا لأي وجهة وهو ما أكدته محكمة الحكم المعقب عن صواب حين اعتبرت ان مواصلة المعقبة إدارة الميناء والإشراف عليه وتسييره ثابت بدليل انتفاء أي عنصر قانوني على رفض أو معارضة وزارة الإشراف على بقائها بالمكان اثر نهاية عقد التسويغ المجدد .

وحيث تفريعا عما سلف الإلماع إليه أضحى الحكم المطعون فيه معللاً على أساس وفهم صحيح للقانون والواقع الأمر الذي يتعين معه رد هذا المطعم أيضا لعدم قيامه على ما يشهد له بالاعتبار ورفض التعقيب أصلاً».

3-8-2-2 المسؤولية التعاقدية للبائع عن التأخير في التسليم وعيوب الصنع

قرار تعقيبي عدد 68021-2020 بتاريخ 11 فيفري 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي .

«حيث كانت المطاعن صلب مستندات التعقيب مؤسسة على عنصري الدعوى وهما مسألة المطالبة بتقدير العيوب المطالب بتحديدتها بموجب اختبار مأذون به من المحكمة فيما يتعلق بالعيوب للتسليم ومسألة القضاء بتمكين المعقب ضده من خطايا تأخير دون حصول التأخير أصلاً.

وحيث وبخصوص المطعم المتعلق بخلط المحكمة بين موعد التسليم وظهور العيوب بالعقار موضوع التداعي فإن المحكمة نقضت الحكم الابتدائي الذي قضى بتغريم المعقبة الآن بوصفها مشرفة على أعمال المقاول لبناء وتهيئة ستسلم إلى المعقب ضده موضوع عقد ممضى من الطرفين لتقديم المعقبة عقد صلح تم بموجبه إقرار المعقبة الآن بوجود عيوب بالبنية والتصريح بمعاينة عيوب بعد التسليم والاتفاق على ان تعوض المعقبة الآن عيوب قيمتها 12248.000 د وذلك لفائدة للمعقب ضده وفي المقابل يتنازل على كل الدعاوى المتعلقة بالعيوب Malfaçons.

وحيث ان محكمة الحكم المنتقد لم تربط بين واقعة التأخير والعيوب ذلك أنّها
إعتبرت أنّ الاتفاق على التنازل على التقاضي لقاء التعويض عن ما تمت معاينته
وتحديده من عيوب يرفع الطلب بخصوص الطلب في الأصل في مطالبة المعقبة
بالتعويض عن الأضرار والعيوب التي تعلقت بالفيلا وكان النقص بخصوص
ذلك العنصر من الدعوى مطابقا لما تضمنه الاتفاق اللاحق لتاريخ التسليم وذلك
من خلال التعريف عليه بالإمضاء في 11/06/2010.

وحيث وخلافا للطعن الموجه لمضمون عقد الصلح فإن العقد كان صريحا
وواضحا من حيث ينه الثاني الذي ألزم الشركة المعقبة المقاول على تعويض
المعقب ضده المشتري المبالغ المتفق عليها في دياجة الاتفاق على أن يتخلى
المشتري عن أي دعوى تتعلق بالعيوب وان الاتفاق لم يشمل تعويضات أخرى
وكان محددا ومنحصرا في العيوب وأنه خلافا للمطعن فإن الاتفاق غير قابل
للتأويل وليس في حاجة للبحث عن المقاصد والدلالات منه لصراحة وثبات
الالتزامات به وكان القول بضرورة تطبيق الفصل 514 فقرة ثانية من ماع غير
ذي موضوع وتعين رد المطعن المتعلق بمضمون الاتفاق لقيام المحكمة بتطبيق
محتواه طبق القانون ووفق إرادة الطرفين مناط الفصل 242 ماع وكان الحكم
معللا من هذه الناحية .

وحيث وبخصوص المطعن المتعلق بتغريم المعقبة بخطايا تأخير ترتيبا على
التأخير في تسليم الفيلا فإنه ثبت أن المحكمة قد أقرت الحكم الابتدائي الذي
قضى بتوفر ما يفيد التأخير في إنهاء الأشغال المتفق عليها بالعقد.

وحيث ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عاينت التأخير الملزم
للتعويض من مضمون الفصل 6 من وعد البيع كما بينت أن الالتزام بتنفيذ العقد
بعد التمديد ينتهي أمده في 20 جوان 2008 واعتمدت على محضر موجه من
المعقب ضده إلى المعقبة يطالبها فيها بتاريخ 24/10/2008 بإستكمال
الأشغال التي من شأنها أن تجعل الفيلا جاهزة للتسليم لتستتج ان التسليم لم يتم
إلى ذلك التاريخ مقرة الحكم بخطايا التأخير .

وحيث لا خلاف بخصوص اجتهاد محكمة الأصل وعدم رقابة محكمة
القانون لذلك الاجتهاد ما لم يقع تحريف للوقائع أو تقصير من المحكمة في

تعليل حكمها واعتماد مؤيدات الخصوم عند عملية التقدير والاستنتاج وترتيب النتائج القانونية .

وحيث ان الاستدلال من المحكمة بمحضر كحجة من المعقب ضده لمعانة التأخير كان بمقارنة بسيطة من المحكمة بين تاريخ التسليم والمحضر والحال أنّ المعقبة كانت تقدمت للمحكمة بوثيقة ممضاة من زوجة المعقب ضده لم يقع الدحض فيها وهي تثبت إمضاءها لوصل تسليم في 7 / 5 / 2008 كما قدمت المعقبة كبدية حجة رسالة الكترونية تعلمه فيها بإمكانية التسليم وقبل الموعد وهي حجج لم تتعرض إليها المحكمة ولم تتحقق منها والحال أنّها لها التقصي بخصوصها وتعليل قبولها أو رفضها وهو التعليل المفترض من محكمة الأصل وفق موجبات الفصل 123 م.م.ت.

وحيث ثبت من مؤيدات الملف أن المعقبة وجهت مكتوبا للمعقب ضده قبل تاريخ انتهاء مدة التسليم بالعقد تعرض عليه التسليم وتذكره بضرورة خلاص آخر قسط غير مدفوع.

وحيث ثبت من وعد عقد البيع في الفصل الثامن التنصيص على انه لا تتم الحيابة إلاّ بعد الخلاص الكامل للثمن النهائي .. موضوع وعد البيع والشراء ... وحيث أنّ الشرط التعاقدي المشترط من الشروط المألوفة في القطاع باعتبار أنّ دفع آخر قسط يساهم في إتمام الأشغال لضمان التسليم في الآجال وأنّ التأخر في الخلاص من شأنه ماديا التأخير في الانتهاء من الأشغال وبالتالي التسليم وتبعا لذلك فإنّ مسألة تحميل مسؤولية التأخير إن صحّت باعتبار تمسك المعقبة بأنّها سلّمت الفيلا في الآجال فإنّ مساهمة المعقب ضده في التأخير تكون مفترضة ما دام خلاص باقي الثمن كان لاحقا لتاريخ انتهاء الأشغال في العقد.

وحيث تمسّكت المعقبة باستعانة المعقب ضده بشركة أخرى تتعامل معها وتكليف المعقب ضده لها للقيام بأشغال بالفيلا وأنّ المحكمة لم تتحقق من تداخل أطراف أخرى في النزاع ولم تبحث في عنصر واقعي ومادي ثابت وهو تدخل المعقب ضده في عملية البناء ورفع العيوب بواسطة الغير من ذلك خلاصه لعاملين من غير فريق المعقبة بالمسكن وان تلك المعطيات الواقعية والقانونية لم تكن موضوع بحث أو قراءة أو ردّ من المحكمة مما يصير ما توصلت إليه من

استنتاج بخصوص ثبوت التأخير في التسليم من المعقبة غير ثابت من حيث الواقع والقانون فضلا عن أنّ كل الاتفاقات والأشغال الحاصلة كانت بعد التسليم وان المحكمة لم تتحقق من مسؤولية المعقبة عند تقدير التأخير وتحديد الخطايا ولم تبين المحكمة أمدها طريقة احتسابها وكان الحكم منقوصا بخصوص التحقق من توفر واقعة التأخير ومن حصولها من عدمه.

وحيث تعين للأسباب السلف ذكرها القضاء بنقض القرار وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى».

4 - قانون عقاري وتهيئة عمرانية

4-1 تقدير غرامة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية

قرار تعقيبي عدد 67975 بتاريخ 13 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والثلاثين برئاسة السيد وجدي الهذيلي وعضوية المستشارين السيدين رجاء بوسمة ومحمد الورهاني وبحضور المدعي العام السيدة رجاء الخضراوي، وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«عن المطعنين معا لارتباطهما واتحاد القول فيهما:

حيث عملا بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية كيفما نقحه القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 فإن غرامة الانتزاع تحدد بحسب قيمة العقار مع مراعاة طبيعته والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع وبالتنظير بين تلك الغرامة والأسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة للعقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها.

وحيث يعد التنظير على معنى أحكام الفصل 4 المذكور من المسائل الواقعية التي تؤسس على معطيات موضوعية يعتمد عليها أهل الخبرة وتراقبها المحكمة دون أن يشترط فيها شكل معين كالاستناد إلى عقود أو غيرها من الحجج وإنما يخضع الوقوف على مدى جديتها إلى اجتهاد المحكمة طالما عللت حكمها كما يجب ولم تنطو مستنداتها على ما ناقض ما احتواه الملف من مؤيدات.

وحيث ولئن تبين بالرجوع إلى تقرير الاختبار المعتمد من محكمة البداية ومن بعدها محكمة القرار المنتقد أن الخبراء المتنديين أشاروا إلى اعتمادهم الأسعار المتداولة في تاريخ صدور أمر الانتزاع دون بيان سندهم في ذلك، فقد استكملت محكمة البداية أعمالهم بالتحريز عليهم في خصوص المصدر الذي رجعوا إليه لتحديد تلك القيمة فبينوا أنه تم الاسترشاد من الأجوار ومن أصحاب العقارات المجاورة أمام تعذر حصولهم على كتائب وعقود تنظير مع الاستناد إلى خبرتهم في التقدير بالرجوع إلى موقع العقار والصبغة السقوية للتربة ونوعيتها واستغلاله في النشاط الفلاحي مؤكدين انعدام الفرق بين التقدير بالمتري المربع أم بالهكتار باعتبارها تعادل 6د. للمتر المربع الواحد أو 60000د. للهكتار الواحد على حد سواء.

وحيث تبعا لما تقدم وطالما أجرت محكمة البداية ومن بعدها محكمة القرار المنتقد رقابتها على أعمال أهل الخبرة طبق ما يخوله لها القانون وفي نطاق سلطتها الاجتهادية في تقدير الوقائع بصفتها محكمة موضوع ولم يقدم المعقب ما من شأنه أن يدحض ما انتهت إليه ويقيم الدليل على خلافه فقد بات أخذها بنتيجة الاختبار والتفتاتها عن دفعها لمجرد مندرجا في إطار اطمئنانها لما توصل إليه الخبراء الذين اختارتهم للقيام بالمأمورية استنادا لما ارتأته فيهم من كفاءة ونزاهة وقدرة على التقدير ولو لم يكن رأيهم مؤيدا بعقود تنظير كتابية تدعمه وهو ما لا رقابة معه في ذلك من هذه المحكمة طالما كان حكمها معللا تعليلا سليما ومستندا إلى معطيات واقعية جديّة من هذه الناحية.

وحيث وعلاوة على ما سبق بيانه فقد أجابت محكمة القرار المنتقد عن المطعن المتعلق بمخالفة أحكام الفصل 7 من قانون الانتزاع والذي يقتضي أخذ ما زاد في قيمة الجزء غير المنتزع نتيجة الأشغال المزمع القيام بها والمصاريف التي تتطلبها تهيئته بعين الاعتبار في تقدير غرامة الانتزاع، مستنتجة بعد وقوفها على صحة ما جاء بالاختبار أن الانتزاع تسبب في الحط من قيمة ذلك الجزء لا الزيادة فيه بسبب الجسر المزمع إنجازه في الطريق السيارة وحرمان تلك القطعة من واجهة الطريق.

وحيث بناء على ما سلف بسطه وطالما اعتبرت محكمة القرار المنتقد أن تقرير الاختبار استوفى مقوماته الفنية ورأت فيه وفي باقي مؤيدات الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها بعدل القيمة المقدرة من الخبراء المتدبين من قبلها واستيفائه لعناصر التقدير المقررة قانونا وخاصة محضر التحريات المكتبية المجرة مع الخبراء والذي يمثل محتواه جزءا لا يتجزأ من رأيهم، فقد بات قضاؤها على نحو ما ذكر استنادا إلى عدم إثبات الطاعن للشطط المدعى به في طريقه ولم ينطو على أي خرق للقانون بما اتجه معه رفض مطلب التعقيب أصلا».

4-2 مفهوم الغير حسن النية في المادة العقارية-التشطيب على الترسيم لا تأثير له على ابطال عقد البيع

قرار تعقيبي عدد 67975 بتاريخ 13 جانفي 2020 صادر عن الدائرة الثمانية عشر برئاسة السيدة هاجر المحرزي وعضوية المستشارين السيدين رؤوف الملكي وماجدة الرياحي وبحضور ممثل الادعاء العام السيد رؤوف الملكي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد.

«عن جميع المطاعن لتداخلها ووحدة القول فيها:

حيث يتبين بتفحص أسانيد القرار المطعون فيه أن المحكمة قد ركزت قضاءها في الاستجابة لدعوى إبطال عقد شراء الطاعن لأن على ما ثبت لديها من الأوراق ووفقا لاجتهادها أن المعقب لا يعد غيرا حسن النية على معنى الفصل 305 من م ح ع وبالتالي فهو غير جدير بالحماية القانونية المتولدة عن النص القانوني المذكور الذي شرع لحماية المشتري الذي يجهل العيوب أو الأسباب المؤدية إلى إبطال الترسيم الذي اعتمد عليه في اكتساب حقه على العقار الشيء المفقود في قضية الحال إذ ثبت من مؤيدات الدعوى أن الطاعن كان على علم بالنزاع الحاصل بين المعقب ضدهم والبائع له بمعية ورثة المالك الأصلي لعقار التداعي بخصوص العقار المذكور موضوع الرسوم العقارية من عدد 533428 نابل إلى عدد 533435 نابل والذي هو موضوع الشراء السابق الحاصل للمعقب ضدهم من مورث البائع للطاعن ص.ش..

وحيث عللت محكمة القرار المنتقد قضاءها بالقول أن كتب شراء المعقب ضدهم المذكور آفا مازال ساري المفعول طالما لم يقع إبطاله أو فسخه ذلك

أن التشطيب على ترسيم ذلك البيع إنما تسلط على عملية الترسيم لا غير وهو لا يمس من صحة العقد وهو تعليل سليم قانونا الشيء الذي لا يخول لمورث المالك الأصلي البائع للمعقب التفويت في موضوع ذلك البيع بعد أن صدر من مورثه بيع سابق لمورث المعقب ضدهم بما لا يجعل الطاعن بصوفه مشتري لوارث المبيع والحال أنه قد أثبت علمه المسبق بالبيع المشار إليه في مؤمن من دعوى الإبطال المرفوعة من المشتريين السابقين لعقار التداعي.

وحيث خلافا لما ورث بالمطعن، فإن حكم القسمة عدد 96955 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 05/06/1992 لا تأثير له على قضية الحال ولا على حقوق المعقب ضدهم على العقار موضوع التداعي عملا بمبدأ المفعول النسبي للأحكام من جهة ولعدم شمول القسمة جميع المستحقين في الرسم العقاري موضوع التداعي وعليه فإن الاحتجاج بأحكام الفصول 480 و481 و485 من م.إ.ع غير موفق من الطاعن وهي تفتقر للسند الصحيح وتعين الالتفات لهذا المطعن وبالتالي ردّه.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن عدم ثبوت اتصال القضاء بالحكم الجزائي الصادر ضد الطاعن بمعية البائع له بالإدانة من أجل بيع ما سبق بيعه لا يشوب القرار المطعون فيه اعتبارا وأنه لم يكن الأساس الوحيد لصدوره بل كان من ضمن بقية الأسانيد القانونية والواقعية التي أسست عليها المحكمة قضاءها كما سبق التعرض إليه بما يكون الاستناد إلى هذا المطعن غير صائب وإثارة الفصل 7 من م.إ.ع يتعين ردّه.

وحيث بناء على ما تقدم فإن القرار المنتقد كان صحيح المبنى وأحسنّت المحكمة فيه تطبيق القانون وجاء معللا تعلّلا سائغا من حيث الواقع والقانون لا شائبة تشويه، وكانت جميع المطاعن قاصرة عن خدشه يتعين ردّها والقضاء تبعا لذلك برفض مطلب التعقيب أصلا».

4 - 3 الترسيم بالسجل العقاري يكرس حماية قانونية للمالكين من كل عمل يمس بحقوقهم

قرار تعقيبي عدد 81189 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجلاء

المصمودي والسيدة نجوى الغربي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن المطعن الأول المأخوذ من خرق الفصل 307 من م.ح.ع.

حيث أسس المعقبين طعنهما على أن محل النزاع مسجل ولا يمكن لأحد التمسك في شأنه بالحوز.

وحيث تبين من أسانيد القرار المنتقد أن محكمة الموضوع ردت دفع المستأنفين لديها (المعقبين الآن) بأن دعوى كف الشغب تهدف لحماية الحوز بصرف النظر عن الملكية وهو تعليل يخالف ما اقتضته أحكام الفصل 307 من م.ح.ع الذي ينص على أنه ليس لأحد أن يتمسك بالحوز في العقارات المسجلة مهما طالت مدته فلا يمكن الحديث عن حوز وحياسة في العقار المسجل مهما كان نوعه ومهما طالت مدته لأن الترسيم بالسجل العقاري يكرس حماية قانونية للمالكين من كل عمل يمس بحقوقهم وهو ما خالفته محكمة الحكم المطعون فيه وجاء قرارها خارقا للقانون موجبا للنقض.

عن المطعنين الثاني والثالث لاتحاد القول فيهما:

حيث ينسب المعقبين لمحكمة الحكم المطعون فيه هضم حق الدفاع لعدم تفحص المؤيدات ورفض طلب تكليف خبير لتطبيق الرسم العقاري وحيث تبين من أسانيد القرار المنتقد أن محكمة الحكم المطعون فيه التفتت عن مؤيدات المستأنفين لديها (المعقبين الآن) المتمثلة أساسا في الرسم العقاري لمحل النزاع بناء على عدم الإدلاء بها لدى محكمة الدرجة الأولى وهو تعليل يتناقض مع المفعول الانتقالي للاستئناف فمحكمة الدرجة الثانية تتعهد بالنظر في جميع ما تسلط عليه الاستئناف وتتولى البت في النزاع على ضوء ما توفر لديها من حجج قدمها الأطراف ولا يمكن اعتبار إضافة تلك المؤيدات بالطور الاستئنافي من قبيل الاحتجاج بوسائل جديدة اعتبارا إلى أن محكمة الدرجة الثانية محكمة أصل وتتعهد بالدعوى المستأنفة على ضوء أسانيد الاستئناف وتفحص مؤيدات الطرفين وتجري الأبحاث والاستقراءات اللازمة وطالما تمسك المعقبين بمستندات الاستئناف بطلب إعادة الاختبار لتطبيق الرسم العقاري المحتج به على محل النزاع فإن المحكمة مدعوة لاستنفاد ولايتها في النزاع بإجراء الأبحاث

الكاشفة للحقيقة سيما وأن الطلب المذكور له تأثير على وجه الفصل في النزاع وكان مبررا وأنّ إعراض محكمة القرار المنتقد عن تفحص مؤيدات المعقّبين وعن إجراء الاختبارات اللازمة يشكل خرقاً للقانون وهضمًا لحقوق الدفاع موجبا للنقض».

4-4 قرار تعقيبي عدد 67984 بتاريخ 13 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والثلاثين برئاسة السيد وجدي الهذيلي وعضوية المستشارين السيدين رجاء بوسمة ومحمد الورهاني وبحضور المدعي العام السيدة رجاء الخضراوي، وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«عن المطعن الوحيد المتعلق بمخالفة أحكام الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 والفصل 19 من م م م ت:

حيث وفي خصوص الفرع الأول من المطعن، ولئن اقتضت أحكام الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 والمتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري أن النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول في منطقة مسح عقاري تصبح بعد نشر القرار القاضي بفتح عمليات المسح من أنظار لجنة المسح ويقع التخلي عنها لفائدة اللجنة المذكورة ولو كانت على بساط النشر أمام محاكم الحق العام، فقد ثبت صدور قرار المسح الإجباري بعد صدور الحكم الابتدائي وبالتالي عدم مباشرة أعمال المسح حال نشر الدعوى الابتدائية بما لا يقوم معه صدور قرار المسح بصفة لاحقة سببا موهنا لحكم البداية ومؤسسا للطعن فيه من هذه الناحية.

وحيث وفضلا عما تقدم فإن الدفع بواجب التخلي لفائدة لجنة المسح يقتضي إثبات وجود نزاع حوزي أو استحقاق وتواصله أمام محكمة الدرجة الثانية حال مباشرة أعمال المسح، الأمر الذي لم يتوفر في صورة الحال ولم تقف عليه محكمة القرار المنتقد ضرورة أن الطاعن لم يناقش مسائل الحوز ولم ينازع في وضع اليد المطلوب حمايته من خصومه في هذا الشأن وإنما اقتصر على إنكار واقعة الشغب المنسوبة إليه بما يخرج عن إطار النزاع الحوزي على معنى أحكام الفصل 13 من المرسوم المذكور واتجه رفض هذا الفرع من المطعن لعدم وجاهته.

وحيث وفي خصوص الفرع الثاني من المطعن والمتعلق بمخالفة أحكام الفصل 19 من م م م ت، فقد ثبتت لدى محكمتنا الأصل الأفعال المنسوبة إلى المعقب وبالتالي صفته في القيام ضده ولم يفلح من جهته في إثبات خلاف ذلك وكان قضاء محكمة القرار المنتقد من هذه الناحية معطلا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما اتجه معه رد مطعنه في هذا الشأن أيضا.

وحيث تبعا لما سلف بسطه لم يرد بمستندات الطعن ما من شأنه أن يوهن القرار المنتقد بما اتجه معه رفض مطلب التعقيب أصلا».

4-5 آجال سقوط دعوى الشفعة

قرار تعقيبي مدني عدد 67984 بتاريخ 17 فيفري 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيدة نازك كادة وعضوية المستشارين السيد يوسف رمضان والسيدة رجاء الجزيري وبمحضر المدعي العام السيد لطفي البدوي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة البرقاوي.

«حيث انحصر الخلاف في دعوى الحال حول القانون المنطبق على عقد البيع موضوع الشفعة والالجال الواجب احترامها من طرف الشفيع لممارسة حقه في الشفعة.

وحيث تمسك المعقب صلب مستندات تعقيبه بان المعقب ضده الأول قد اخل بواجب الإعلام المحمول عليه قانونا طبق ما نصت عله الفقرة الأولى من الفصل 115 جديد من م ح ع وانه طالما لم يثبت حالة تعذر الإعلام فان اجل القيام يبقى مفتوحا وينطبق عليه الأجل العام للقيام المقدر بخمسة عشر عاما طبق ما استقر عليه رأي محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة .

وحيث لا جدال ان عقد البيع موضوع دعوى الشفعة يخضع من حيث آجال سقوطها لأحكام الفصل 115 من م ح ع الواقع تنقيحه بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/05/2006 بناء على أن حق الشفيع ينشأ بنشأة العقد الذي فوت بمقتضاه هذا الأخير في منابه الشائع.

وحيث اقتضى الفصل 115 جديد من م ح ع على انه يجب على المشتري إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف . ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر إعلامه . وفي صورة تعذر

الإعلام فإن القيام بدعوى الشفعة يسقط بمضي ستة أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم ومن يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم أو العقارات غير المسجلة.

وحيث تبين بالاطلاع على الرسم العقاري الذي ورد عليه عقد البيع موضوع دعوى الشفعة انه يخضع من حيث أجال سقوط حق القيام بدعوى الشفعة لأحكام الفصل 115 المذكور سلفا من مجلة الحقوق العينية باعتباره هو المنطبق ضرورة أن الرسم أقيم قبل سنة 1998.

وحيث ان الرسوم العقارية غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم تخضع من حيث أجال ممارسة حق الشفعة على عقود البيع المتعلقة بها وذلك من تاريخ تسجيل عقد البيع بالقباضة المالية كلما ثبت للمحكمة حصول تعذر الإعلام بالشراء.

وحيث ولئن وفقت المحكمة في الوصول إلى تحديد النص المنطبق واعتمدت في قضائها على الفصل 115 جديد من مجلة الحقوق العينية إلا أنّها أساءت تأويله ضرورة ان المشرع التونسي ومن خلال ما ورد بتقرير لجنة التشريع العام المتعلق بأحكام الفصل 115 من م ح ع قد اعتبر ان التنقيح جاء يهدف إلى وضع حد لمحاولات بعض المشترين بالتستر على شراء اتهم بغاية حرمان الشريك أو من بقي من الشركاء من الحلول محله في التملك بمبيع الشريك وان المشرع ارسى المبدأ وهو الإعلام بالشراء وهو ما عناه المشرع بان حرص على ضرورة احترام المشتري لواجب الإعلام دون أن يغفل على وضع الاستثناء له من خلال إمكانية عدم الإعلام مع شرط إثبات صورة التعذر التي حالت دون قيام المشتري بمثل ذلك الواجب بإعلام من بقي من الشركاء بالعقار.

وحيث درج فقه القضاء على أنّ إثبات حالة تعذر الإعلام بالشراء تقع على المشتري ويعد التعذر واقعة قانونية تخضع لاجتهاد المحكمة ذلك انه بالرجوع إلى تقرير لجنة التشريع العام المذكور قد راعى في التنقيح المدخل على الفصل 115 من م ح ع ورود عديد الوضعيات الواقعية التي يتعذر فيها على المشتري

إتمام واجب الإعلام ومن ذلك كثرة المستحقين بالعقار أو إذا ما أصبح الشريك مجهول المقر وتعذر التبليغ اليه.

وحيث أنّ محكمة الحكم المطعون فيه لم تبحث في الموجب من وراء عدم قيام المشتري بالإعلام ولم تقف عند أسباب تعذر ذلك خاصة وإن فقه قضاء الدوائر المجتمعة من خلال القرار التعقيبي عدد 24634 بتاريخ 2018/03/08 قد ذهب إلى ضرورة التحقيق في أسباب التعذر التي أعاقَت المشتري عن إتمام الإعلام بالمشتري والتي يعود ترجيحها من عدم ذلك إلى اجتهاد المحكمة بشرط التعليل وانه في صورة انعدام حالة التعذر أو ما إذا كانت الأسباب التي يقدمها المشتري لا تقتنع بها المحكمة ولا تعتبرها من حالات التعذر التي قصها المشرع فإنّ الأجل المعتمد للقيام بدعوى الشفعة يكون الأجل العام المنصوص عليه بالفصل 402 من م.ع.

وحيث أنّ محكمة الحكم المطعون فيه لم تبحث في أسباب تعذر الإعلام وكان عليها أن تخوض فيها ولا يمكنها أن ترتب حكمها على ضوء أحكام الفصل 115 من م.ع وتعتمد أجل الستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية لمعالجة الغير به قبل أن تبت في أسباب التعذر التي حالت دون إتمام المشتري وإعلام من بقي من الشركاء.

وحيث وطالما أغفلت المحكمة عن بسط ولايتها الموضوعية على الخوض في أسباب التعذر تكون قد أخطأت في تأويل أحكام الفصل 115 قديم من م.ع ويكون حكمها موسوماً بضعف التعليل مما يوجب نقضه.

وحيث وباعتبار أنّ مسألة الخوض في أسباب التعذر تعد من الوسائل الواقعية وتخضع لاجتهاد قضاء الأصل فانه اتجه إرجاع القضية لمحكمة الحكم المطعون فيه للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى.

4-6 دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تمنع القيام بدعوى الخروج لعدم الصفة

قرار تعقيبي 21059.2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة الواحد والعشرين برئاسة السيدة آية بن ملوكة وعضوية المستشارتين

السيدتين نادرة بن سالم وسلوى سلامة وبحضور المدعي العام السيد مصطفى العجيمي وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«حيث تعين وضع الأمور في نصابها بما مؤداه أن الأساس القانوني الذي يحدده المدعي في الأصل هو حق مشروع يضبطه وفق المصلحة التي يروم حمايتها في إطار ما يخوله له القانون.

وحيث لا جدال أن انعقاد نظر القاضي الاستعجالي متوقف على شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل وأنه بتوفر هذين الشرطين يمكن لكل شخص الالتجاء له لطلب الحماية العاجلة دون التعرض لصميم الحق ولا الفصل في النزاع الموضوعي.

وحيث إن إمكانية القيام بدعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع وإن كانت جائزة قانوناً في مثل صورة قضية الحال إلا أن ذلك لا يمنع الطالب اختيار دعوى الخروج لانعدام الصفة طالما توفرت شروط القيام بها ولم تخالف هذه الدعوى ما أتاحه القانون ودون أن يشكل ذلك خرقاً لقواعد الاختصاص الحكمي ذلك أن أحكام الفصل 307 م ح ع لم تلغ مؤسسة الخروج لعدم الصفة وإنما قصرت دعوى كف الشغب عن العقار المسجل على محكمة الناحية وإن في اختيار المعقب ضده لدعوى الخروج لانعدام الصفة لا يعني نفياً لدعوى كف الشغب وإنما ركوباً لمطية أبلغ للوصول لمقصده ما يجعل الدفع بعدم الاختصاص الحكمي غير قائم على أساس من القانون وتعين رد هذه المطعن.

وحيث إن ما انتهت إليه محكمة القرار المطعون فيه من إقرار لحكم البداية لا ينطوي على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه على نحو ما جاء بمطاعن المعقب، ضرورة أنها أسست حكمها على ما ثبت لها من معطيات تثبت في ظاهرها ملكية المعقب ضده للعقار موضوع النزاع وعليه فقد أضحت منازعتها في ذلك في منأى عن رقابة محكمة التعقيب واتجه رد هذا المطعن ورفض التعقيب أصلاً».

4-7 قسمة المهياة لا ترقى سبباً لمنع الورثة من ممارسة الحق في القسمة القضائية أو تسمية مصفي

قرار تعقيبى عدد 23793.2020 بتاريخ 27 جانفي 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثانية برئاسة السيد محمد العسكري وعضوية المستشارين السيدين مكرم

الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة راضية همادي.

«عن المطاعن المأخوذة من خرق الفصل 420 م إ ع ومن طبيعة الطلب إن كان يتعلق بحالة شيوع أو تصفية تركة:

حيث كانت المطاعن صلب مستندات التعقيب في عدم تحقق محكمة الحكم المطعون فيه إن كان الأمر يتعلق بحالة شيوع تتخذ سبل قانونية للخروج منها أن وضعية طلب تسمية مصفي على تركة معتبرا أن المعقب ضدها لم تثبت ما ادعته عملا بالفصل 420 م إ ع والحال أن الرسوم العقارية موضوع طلب تسمية مصفي تضمنت أسماء المعقبين والمعقب ضدها ولا وجود لما يفيد تعلق الأمر بتركة تستوجب وضع مصف عليها.

حيث إن شهادات الملكية المضافة بالملف والتي تم فيها إدراج هوية وعنوان كل صاحب مناب في الرسم العقاري لا ترقى وسيلة لإثبات مصدر الملكية إن كانت متأتية من إرث أو بيع أو غيرها من وسائل التملك في الرسم العقاري وأن التحقق من ذلك لا يكون إلا بتقديم السجل العقاري كاملا خاصة أن التسجيل الحاصل للعقار تم سنة 1980 أي في قائم حياة المورث وأن الملف خال مما يثبت خلافا لموقف الطاعن لملكية الشركاء في الرسم العقاري بالشراء أو غيرها من سبل التملك دون الإرث وكان القول بأن لا وجود لتركة لتسمية مصفي باعتباره المكلف قانونا وفق قانون 1997 بحصر وإدارة التركة قول غير معلل وغير مثبت في مستندات الطعن وتعين رده.

حيث وبخصوص القول بأن الوضع يتعلق بحالة شيوع في عقارات مسجلة بين الأطراف المتنازعة وليس بطلب تعيين مصفي قول مردود باعتبار انبثاق الاشتراك في الملك عن تركة مورث الأطراف في ملك الهالك بل. الب. وذلك لعدم دفع المعارضين بأن الملك جاء بوجه كسب دون الإرث وهو ما ذهبت إليه المحكمة لتعلل صحة طلب تعيين مصفي وأن الدفع من جديد ولأول مرة بأن الأمر لا يتعلق بتركة يقتضي الإثبات من الطاعنين وبقي الدفع المثار لدى هذه المحكمة غير مثبت واتجه رده وفق ما سبق ذكره بخصوص قصور شهادات الملكية المقدمة عن نفي التركة أو إثبات الملكية المباشرة فضلا عن أن الاستجواب المتمسك به

من نائب الطاعنين عن إحدى الورثة لإثبات وجود قسمة مهيأة بين الأطراف تم الإقرار فيه لدى عدل الإشهاد وجليسه بانجرار ملكية العقارات عن والد الطاعنين مما يثبت توفر أسباب تعيين مصفي وفق الاذن موضوع طلب الرجوع.

حيث عارض الطاعنون في طلب تسمية مصف على الأملاك المشتركة لوجود قسمة مهيأة منذ سنة 1991 وبعد وفاة مورثهم وذلك وفق الفصل 67 م ح ع الذي اقتضى الاتفاق على الاتفاق على الانتفاع بين الشركاء على قسمة مهيأة ولكل شريك التصرف بعوض أو بدونه في حقه الخاص والذي يتنفع به طيلة المدة المعينة له ...

حيث جاء الفصل 67 م ح ع في باب الشيوخ في المجلة وان ذلك الاتفاق وإن لم يشترط فيه المشرع العقد فإن المعقبين لم يثبتوا الاتفاق على التصرف لكل طرف في عقار أو جزء منه للتمسك بإفراد المعقب ضدها بعقار دون آخر فضلا عن ان تلك القسمة لا تحرم الوارث من ممارسة حقه في طلب تعيين مصفي أو القيام بقسمة قضائية بقطع النظر عن التصرف في التركة من عدمه عند تعدد الفصول أو حرمانه من جزء منها أو انتهاء الانتفاع المتفق عليه وأن الاستشهاد بأقوال أحد الورثة أو الأجوار أمام عدم إثبات الاستغلال والقبول من المعقب ضدها بقسمة المهيأة إن تمت لا يرقى سببا لمنع الورثة من ممارسة الحق في القسمة القضائية أو تسمية مصفي وتعين رد المطعن.

عن المطعن المأخوذ من ضعف التعليل:

حيث تمسك نائب المعقبين بأن القرار المنتقد جاء ضعيف التعليل لما اعتبر قيام المعقب ضدها كان وفق الفصل 135 م ح ع لطول المدة بين وفاة المورث والقيام ولوجود اتفاق على تمييز المعقب ضدها بالعقار ذو الرسم العقاري عدد 37102 منذ سنة 2007.

حيث فضلا عن عدم وجود قسمة مهيأة أو قسمة رضائية مكتوبة بحجة تعتمد قانونا أو قسمة قضائية فإن حق الطالبة في القيام بطلب تسمية مصفي على التركة يبقى قائما كما أن الطلب لا يتعارض مع طلب قسمة العقارات وغيرها من القضايا الهادفة للخروج من حالة الشيعاء والمقدمة من المعقب ضدها ولا وجود لتاريخ

أو لسقوط في أجل «تقادم» لهذه الطلبات ما دام قد تم إثبات الشيوع وعدم الاستغلال من كل الورثة «انتفاع مطلق أو استبداد بالملك».

حيث إن القول بأن الدعوى في قسمة عقار لإنهاء حالة الشيوع وليس في تسمية مصفي قول لا يمكن أن تبت فيه محكمة القانون التي ليس لها تعديل أو تكيف طلبات الخصوم ما دام القانون يسمح بذلك على أن الدعوى في الرجوع في إذن لدى الدائرة الاستعجالية وليس في قسمة عقار وتعين اعتبار المحكمة على صواب في تطبيق الفصل 135 م ح ع وكان تحليلها تعليلاً مستساغاً وتعين رفض التعقيب أصلاً».

4-8 شروط ثبوت حالة الإشتراك في المال المراد نصب الائتمان عليه وضرورة شمول الدعوى كافة المستحقين

قرار تعقيبي 2020.21699 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة الواحد والعشرين برئاسة السيدة آية بن ملوكة وعضوية المستشارتين السيدتين نادرة بن سالم وسلوى سلامة وبحضور المدعي العام السيد مصطفى العجيمي وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«عن المطعن الأول المؤسس على سوء تطبيق القانون:

حيث تأسس المطعن على أن الفصل 15 من القانون عدد 71 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفيين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين أجاز طلب الائتمان من المحكمة المختصة من طرف أحد المستحقين وإن عدم شموله جميع المستحقين لا يخل به من ناحية الشكل.

وحيث إقتضى الفصل 15 من القانون عدد 71 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفيين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين أنه « يتولى رئيس المحكمة المختص بالنظر والمتعهد من أحد المستحقين تعيين مؤتمن عدلي يختاره ضمن المؤتمنين العدليين المبينين بالقائمة كما يكلف قاضياً تعهد له مهمة رقابة عملية الائتمان».

وحيث أن مقتضيات الفصل المشار إليها تتعلق بضبط من له حق القيام بدعوى الائتمان وقد مكن القانون التونسي لكل مستحق في عقار مشترك طلب تعيين

مؤتمن على المشترك الذي يملك فيه بغاية حفظ حقوقه من إستبداد باقي الشركاء أو بعضهم إلى حين فض الخلاف بالتراضي أو بالتقاضي.

وحيث أن الفصل 15 المشار إليه لم يشر مطلقاً إلى أن دعوى تنصيب مؤتمن لا يشترط فيها شمولها كافة المستحقين في المشترك ولا يمكن تحميل عبارات الفصل أكثر من المعنى الذي تقتضيه عملاً بالقاعدة الأصولية مناط الفصل 532 من م.إ.ع.

وحيث أن تسلط الائتمان على العقارات المشتركة يتعين معه أن يكون كافة الشركاء مشمولين بالمطلب سواء طالبين أو مطلوبين حتى يدلوا بما لهم من مؤيدات وحجج تؤيد الائتمان وتؤكد الحاجة له أو تنفي شروط نصبه فهي بالتالي مسألة أولية يتعين على المحكمة التحقق من توفرها قبل الخوض في وجهة طلب الائتمان لأن القبول بخلاف ذلك يؤدي إلى تسليط الائتمان على منابات شركاء ليسوا طرفاً في النزاع ترفع بموجبه أياديه عن إستغلال مناباتهم ويحل محلهم في ذلك مؤتمن عدلي تم تنصيبه في إطار إجراءات تمت في مغيبهم ولم يكونوا على علم بها في مخالفة صارخة لحق الدفاع ومبدأ المواجهة.

وحيث أن حق الغير الذي لم يسبق استدعاؤه أو إدخاله أو تداخله في نازلة في الإعتراض عليه طبق لموجبات الفصل 168 وما بعده من م.م.ت لا يمكن أن يكون مبرراً لعدم إستدعاء أحد الشركاء في العقار لدعوى تعيين مؤتمن لا سيما إن كان شريكاً معلوماً منصوباً على هويته بشهادة الملكية أو سندها.

وحيث أن العقار موضوع طلب الائتمان الراهن هو عقار مسجل حسب ما هو ثابت من شهادة الإشتراك بالملكية وإن عدم إستدعاء الشريكين صدام بن عمارة والسيدة بنت مصباح الحفناوي المضمنين تحت عدد 4 و 13 بشهادة الملكية يعيب طلب الائتمان وإن تعلل المعقبين بأن الأول لا يتصرف في العقار المشترك لأنه بصدد مزاولته تعليمه وبأن الثانية توفيت وتم إستدعاء ورثتها لا يصحح ذلك الخلل ضرورة أن عدم تصرف أحد المستحقين في المشترك على فرض صحته لا يبرر عدم شمول الدعوى له طالما أنها تتسلط على العقار الذي يملك فيه منابات والمفروض قانوناً أن يكون طرفاً في كل دعوى تتعلق به سواء مباشرة أو بواسطة وليه أو مقدمه إن كان قاصراً أو حجوراً عليه أو وكيله إذا ما عين وكيله.

وحيث بالنسبة للمستحقة السيدة فقد ثبت بتفحص أوراق الملف خلوه من حجة وفاتها بما يصير إستدعاء كل من راضية والأزهر والحساني ومنية على أنهم ورثتها مجرد من كل دليل ومن قبيل شمول الدعوى لغير ذي صفة.

وحيث أن ما إنتهت إليه محكمة القرار المنتقد من وجود عيب شكلي شاب القيام لعدم شموله لجميع المستحقين في العقار في طريقه واقعا وقانونا ولا مخالفة فيه لموجبات الفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 1997 بل يتماشى ويتوافق مع الغاية المرجوة من الائتمان وهو حفظ حقوق جميع الشركاء وعدم تغييبهم في مسألة تتعلق بالمشارك.

وحيث أضحى المطعن المثار في غير طريقه وتعين التصريح برده.

عن المطعن الثاني المؤسس على ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع:

حيث أن محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع المعروضة عليها ولها أن تستخلص منها من الوجهتين الواقعية والقانونية النتيجة القانونية بشرط التعليل المستوفي والمستمد من أوراق الملف ويجب أن يكون ذلك التعليل مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية وأن يتولى مناقشة تصريحات الأطراف وفحصها والرد عليها بدلالات ثابتة ومعززة مما حوته مظروفات القضية دون تحريف.

وحيث إستقر فقه القضاء على اعتبار الائتمان العدلي إجراء وقتي وتحفظي يلتجأ إليه في حالات التأكد القصوى وأن من شروطه ثبوت حالة الإشتراك في المال المراد نصب الائتمان عليه من جهة وإستبداد شق من الشركاء بالتصرف في المشترك أو إستثمارهم به دون وجه حق بما يجعل حقوق بقية الشركاء مهددة بالتلف والضياع من جهة أخرى وأنه يفضي إلى رفع يد كافة الشركاء عن إستغلال المشترك وتخويل المؤتمن المنصب القيام بأعمال إدارته وتسييره وإتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بحفظه نيابة عنهم إنتهاء إلى توزيع مداخيله عليهم كل حسب نصيبه في المشترك بعد طرح أعباء ومصاريف الإدارة والتسيير.

وحيث إنتهت محكمة القرار المطعون فيه على صواب إلى عدم ثبوت ركن الإستبداد ضرورة أن مضمون محاضر المعاينة المدلى بها تأييدا لشرط الإستبداد قاصرة على إثباته باعتبارها تضمنت معاينة لبعض الشركاء في العقار يتولون جني صابة الزيتون وخلت تلك المحاضر من أي معاينات لأعمال منع أو عنف تنسب

للمعقب ضدهم بل تضمنت تصريحاً للقائمين بالجني بأن الجني في حدود ما لهم من مناب بالمشارك ، كما أن الشكاية الجزائية المحتج به من المعقبين ضد بعض المعقب ضدهم في الإستلاء على مشترك قبل القسمة إنتهت برفض الدعوى العمومية فيه حسب شهادة في مضمون حكم جزائي وإن الطعن فيه بالإستئناف لا يوهن الحجية الراهنة لذلك الحكم عملاً بأحكام الفصل 443 من م إ ع فضلاً على أن كائب الشهادة المتلقاة خلافاً للصيغ المنصوص عليها بالفصل 92 وما بعده من م م ت لا يمكن أن تمثل وسيلة إثبات قانونية لركن الإستبداد.

وحيث والحالة ما ذكر تكون محكمة القرار المنتقد قد عللت حكمها تعليلاً مستساغاً مؤسساً على ما ثبت من مؤيدات الملف لا ضعف شابه ولا هضم فيه لحقوق الدفاع بما يتجه معه التصريح برفض هذا المطعن».

4-9 أسباب اكتساب ملكية العقار- الفصل 22 من م. ح. ع.

قرار تعقيبي عدد 21196 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثالثة برئاسة السيدة نعيمة رحيم وعضوية المستشارتين السيدة عبير الخلفي والسيدة نورة نوري وبمحضر ممثل الادعاء العمومي السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوي.

«عن المطعنين المتعلقين بسوء تطبيق القانون وهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل لترابطهم ووحدة القول فيهما:

حيث تمحورت دفوع الطاعنين حول مدى توفيق المحكمة في المراوحة بين حالات اكتساب الملكية المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلة الحقوق العينية وما إن كان تعدد حالات اكتساب الملكية في دعوى واحدة لطلب الاستحقاق مخالف للفصل المذكور ومدى توفيقها في تطبيق شروط التقادم المكسب للملكية.

وحيث اعتبر المشرع صلب الفصل 22 من م ح ع أن الملكية «تكتسب بالعقد والميراث والتقادم والالتصاق ومفعول القانون وفي المنقول بالاستيلاء أيضاً».

وحيث أن تعدد أوجه اكتساب الملكية كما تم التنصيص عليها بالفصل 22 المشار إليه إنما هو تعدد تنظيري الغاية منه ذكر مختلف الحالات ولا يعد تعدداً حصرياً يفرض ضرورة اعتماد حالة دون الأخرى في اكتساب الملكية فمن

اكتسب ملكا بموجب الميراث يجوز له أيضا أن يكتسب ملكا في ذات العقار بموجب العقد أو بموجب التقادم المكسب وكذلك بموجب الالتصاق بما يفيد قولاً أن الجمع بين أكثر من حالة من حالات اكتساب الملكية جائز ولم يمنعه المشرع لا في الفصل 22 المشار إليه ولا في الفصول اللاحقة المحددة لشروط كل حالة على حدى وان عبارة القانون متى وردت مطلقة جرت على إطلاقها.

وحيث أن محكمة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن طلب الطاعنين سماع البينة لإثبات أنهم المتصرفون في العقار موضوع دعوى الاستحقاق بموجب الإرث وبموجب عقود المعاوضة يخالف الفصل 22 المشار إليه لعدم جواز الجمع بين حالات اكتساب الملكية في دعوى واحدة إنما تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لما حملت الفصل 22 من م ح ع مقاصد ومفاهيم لم ترد به ولم تتجه إرادة المشرع إليها وان خطئها في تطبيق القانون شمل الفصل 22 من م ح ع من جهة وشمل أيضا الفصل 45 من نفس المجلة والمحدد لآثار وشروط الحوز المكسب للملكية مناط طلب المدعين في الأصل.

وحيث أن طلبات المدعين تعلقت بالحكم لهم باستحقاق القطعة موضوع النزاع لتصرفهم فيها بموجب الحوز وعقد المعاوضة المظروف بملف القضية وقد نص الفصل 45 من م ح ع أن « من حاز عقارا أو حقا عينيا على عقار مدة خمسة عشر عاما بصفة مالك حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس كانت له ملكية العقار أو الحق العيني بموجب التقادم والحوز المعيب لا تأثير له إلا من وقت زوال العيب ».

وحيث أن طلب الحكم للمعقب ضدهم باستحقاق العقار بموجب التقادم يستلزم ضرورة توفر شروط الفصل 45 المشار إليه وذلك بان يتصرفوا مدة خمسة عشر عاما في القطعة موضوع النزاع مدة خمسة عشر عاما بصفة مالكين حوزا هادئ دون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس وهي شروط تتأكد منها المحكمة بموجب إجراء بحث استحقاقى على عين العقار بغاية سماع بينة وشهود الطرفين على اعتبار وان صفة المالك والتصرف الهادئ دون شغب أو منازعة وبصفة مستمرة تتأكد في وجدان المحكمة أو تنفى بموجب البينة ولا بمجرد تصريحات طرفي الدعوى فالبينة بالشهادة هي حجر الزاوية في دعوى

الاستحقاق لان صفة المالك وكذا الاستمرار في التصرف دون انقطاع ولا شغب وبصفة هادئة تنشأ في ذهن العموم من المجاورين للقائم بالدعوى والذين اعتادوا على مشاهدة تصرفه في العقار دون لبس أو غموض أو مشاغبة ثم تتأيد بعد ذلك بموجب ما للخصوم من عقود ومؤيدات التي تأذن المحكمة بتطبيقها.

وحيث أنّ محكمة القرار المطعون فيه قضت باستحقاق المعقب ضدهم للقطعة موضوع النزاع بالاعتماد على بحث استحقاقى اكتفت محكمة البداية بسماع طرفي الدعوى فيه فقط دون سماع الشهود الذين يحقنون الصفات المشار إليها آنفا لدى المدعين وهو ما يجعل مستنداتها غير تامة وليس فيها ما يحقق توفر الصفات المشتركة في التقادم لدى المدعين وان الاكتفاء بتطبيق العقد على عين العقار من قبل الاختبار لا يحسم مسألة المتصرف بصفة مالك حوزا هادئ ومستمر وقد طلب الطاعنين من المحكمة سماع بيئتهم إلا أنّها التفتت عن طلبهم المذكور وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون وهضما لحقوق الدفاع في ذات الوقت اعتبارا لأهمية البيئة في تحديد معالم وشروط الحوز المكسب للملكية وأضحى القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع مما يتعين معه نقضه».

4-10 رفع مضرّة

4-10-1 التطور التشريعي في معالجة مضار الجوار- ثبوت الكشف ولو بفواصل ممر عام لا ينفي المضرّة

قرار تعقيبي مدني عدد 23093 بتاريخ 4 جويلية 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثانية والثلاثين برئاسة السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية المنتصر ونفيسة العلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الحلواني.

«حيث نعى المعقب على محكمة الحكم المتقد خرق أحكام الفصل 99 م 1 ع والفصول من 172 إلى 175 م ح ع بمقولة أن أحكام الفصل 99 م 1 ع لا تنطبق على قضية الحال باعتبار أنّ المشرع خص مسألة المضار الناجمة عن البناء بقواعد قانونية خاصة واردة بمجلة الحقوق العينية أما المضار المقصودة بالفصل 99 م 1 ع فتتخصر في المضار العادية الناجمة عن الأماكن المضرة بالصحة أو المكدرّة

للراحة ولا يمكن اعتبار مضار الكشف وحجب الشمس والهواء مشمولة بالمضار التي قصدتها المشرع بالفصل المذكور كما يوجب الكشف على ملك الجار أن يكون هذا الأخير صاحب العقار المجاور مباشرة ولا يمكن ان يشمل العقارات التي يفصل بينها طريق عام.

وحيث إنّ الإشكال القانوني المطروح الآن يفترض أساسا الجواب على التساؤل الآتي:

هل يمكن الحديث عن مضار الجوار وتحديدًا مضرة الكشف اذا كان يفصل بين العقارين المتجاورين طريق عام أم أنه بمجرد ثبوت وجود هذا الطريق تنعدم المضرة تماما؟

وحيث بالرجوع إلى عريضة الدعوى الافتتاحية منطلق قضية الحال يتبين ان المدعي في الأصل المعقب ضده الآن قد أسس دعواه على مقتضيات الفصل 99 م ا ع وقانون 28 نوفمبر 1994 المصدر لمجلة التهيئة الترابية والتعمير.

وحيث لا جدال في أن المشرع التونسي كغيره من التشريعات الأخرى تدخل لضمان حد أدنى من عدم الإضرار بالجار وتعتبر مجلة الالتزامات والعقود المرجع الأول والإطار القانوني الأشمل الذي نظم حق الجوار فكّر المشرع صراحة نظرية مضار الجوار بالفصلين 99 و 100 م ا ع التي وضعت على كاهل الجار واجبا عاما بتحمل الأضرار المألوفة وتمكينه من حق دفع ما تجاوز ذلك الحد من الأضرار الماسة بالصحة والراحة.

وحيث يعود أساس العناية بالأجوار في القانون التونسي إلى أحكام الفقه والشرعة الإسلامية التي تعد مصدرا للفصلين 99 و 100 م ا ع ضرورة أن الفصل 99 هو تقريبا نقل حرفي للفصل 110 من مشروع صانتيلا المأخوذ عن المادة 1200 من المجلة العثمانية التي أقرت أن: «الضرر الفاحش يدفع بأي وجه كان». وهذا الحل أقرته القواعد العامة في الشريعة الإسلامية عملا بقول الرسول الكريم ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».

وحيث مكن الفصل 99 م ا ع المتضرر من الحصول على جبر ضرره (بإزالة ما أحدثه جاره) الذي يجب أن يتجاوز الحد الإعتيادي بقطع النظر عن ثبوت الخطأ مما يتبين معه أن نظرية مضار الجوار تستقل من حيث الشروط والآثار

عن قواعد المسؤولية التقصيرية فخاصية مضار الجوار أن الجار يسأل حتى لو لم يرتكب خطأ لأنه حمل جاره ضرراً يتجاوز الحد المألوف بقطع النظر عن كونه أخطأ أو اتخذ الحيطة اللازمة فلا يهتم إن مارس نشاطه ضمن القانون أو خارجه.

وحيث إن ما كرسه المشرع بالفصل 99 م.أ.ع حين جعل الجار مسؤولاً عن كل الأضرار غير المألوفة دون ضرورة صدور خطأ منه يتعارض مع قواعد المسؤولية العامة التي تخول تعويض كل الأضرار مهما نقصت بشرط إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

وحيث يستنتج مما تقدم ومن خلال الفصلين 99 و 100 م.أ.ع أن ركني قيام المسؤولية في نطاق مضار الجوار هما وجوب إثبات العلاقة الجوارية والعلاقة السببية بينها وبين الفعل الضار غير المألوف المراد رفعه.

وحيث وبصدور مجلة الحقوق العينية اهتم المشرع بحماية الملكية العقارية وبالتالي حماية الجار من أي اعتداء عليه من طرف مجاوريه كحماية الحياة الخاصة وما يتطلبه ذلك من منع للكشف وتحديد المسافات بين البناءات... حتى يضمن حداً من رفاهة الفرد داخل محل سكناه فأصبح حق الملكية مقيداً بحق الملكية المجاورة.

وحيث تطورت نظرة المشرع التونسي إلى النظرية العامة للجوار تدريجياً بحرصه على تحقيق رفاهة الحياة الخاصة للأجوار كتحقيق التوازن بين ما تتطلبه التنمية وما يفرضه حق الجار في محيط سليم فأصدر مجلة التهيئة الترابية والتعمير بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 التي أضافت قيوداً لضمان رفاهة العيش وفرضت تناسق النسيج العمراني.

وحيث بالاطلاع على القرار المنتقد يتبين أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت أنه من المتعين أعمال أحكام الفصل 99 م.أ.ع على وقائع قضية الحال والتي جاءت مطلقة بأن جعلت المسؤولية عن مضار الجوار لا تقوم فقط عند مخالفة القانون وإنما تقوم أيضاً كلما ثبت تعسف الجار في استعمال ما خوله له القانون من حق الاستعمال والانتفاع بالعقار الذي في تصرفه بشكل يسبب ضرراً غير مألوف وغير محتمل.

وحيث أسست محكمة الحكم المعقب قضاءها على ما أثبتته تقرير الخبراء المتدبين من طرفها الذين أكدوا ثبوت المضرّة المتظلم منها والمتمثلة في الكشف المحقق والثابت والمكدر لراحة المعقب ضده لتقرر بأن الفصلين 99 م.أ.ع و 174 م.ح ع غير متعارضين بل متكاملين فضرر الكشف طبق الفصلين 174 و 175 م.ح ع مفترض بمخالفة الفعل الممنوع ويعفي الجار من إثبات المضرّة أما الفصل 99 م.أ.ع فهو غير مفترض لأنه غير مؤسس على مخالفة القانون بل على العكس على التعسف في استعمال الحق المخول لصاحب الملك بموجب القانون.

وحيث أن المحكمة بقضائها لصالح دعوى رفع المضرّة وذلك بنقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى تكون قد تحرت في جدية الضرر الحاصل ولم تحد عن ما قصده المشرع عند تكريسه لنظرية مضار الجوار.

وحيث خلافا لما ورد بمستندات الطعن فإن الفصل 99 م.أ.ع يبقى النص العام المنطبق على المضار الناشئة عن علاقة الجوار والذي يتجه استنادا إليه القضاء برفع مضرّة الجوار في صورة ثبوتها ولو تبين وجود طريق عام يفصل بين العقارين ضرورة أن العبرة في رفع المضرّة هي بثبوت وجود هذه المضرّة.

وحيث من المسلم به أن تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

وحيث أجابت محكمة القرار المنتقد عن الدفوع المثارة وعللت أسانيدها بصفة مستفيضة وكانت استنتاجاتها مبنية على ما له أصل ثابت بالملف ولا تثريب عليها في ذلك.

وحيث طالما تبين أنّ ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد كان مؤسسا على معطيات صحيحة وثابتة وكان قرارها مستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم، فإنّها تكون في منأى عن رقابة هذه المحكمة واتجه لذلك رد المطعنين المثارين ورفض التعقيب أصلا.

وحيث أخفق المعقب في طلبه واتجه بحجز معلوم الخطية المؤمن من طرفه عملا بأحكام الفصل 184 من م.م.م.ت.».

5 - تجاري

5-1 ديون تجارية

5-1-1 حق الدائن في تتبع الكفيل الشخصي المتضامن دون التوقف على ضرورة تتبع مكاسب المدين الأصلي

قرار تعقيبي عدد 2088 بتاريخ 6 جويلية 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيد البشير المطوي وعضوية المستشارين السيدين مريم البكوش وعربية الطويهي وبمحضر المدعي العام السيد رفيق الحداد وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوي.

«وحيث ومن جهة أخرى فقد ثبت بالرجوع إلى كتب القرض المبرم بين الأطراف المتداعية ان المعقب الأول اسند كفالة شخصية تضامنية لفائدة المعقبة الثانية وقد نص بفصله 8 على ان الكفيل المذكور ضامن شخصيا وبالتضامن في كل المبالغ المتخلدة أو التي يمكن ان تتخلد بذمة المعقبة لفائدة البنك المقرض المعقب ضده الآن وذلك بعنوان القرض المذكور.

وحيث اقتضى الفصل 242 م ا ع أن ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين الطرفين.

وحيث أسست محكمة الحكم المطعون فيه قضاءها على مقتضيات عقد القرض منتهية عن صواب إلى أن تحميل المعقب الأول بالأداء في حدود قيمة ضمانه وذلك بالتضامن مع المعقبة الثانية وعليه فان القول بضرورة تتبع المدينة الأصلية أولا لا سند له من القانون نظرا لطبيعة الكفالة التضامنية وما اقتضته أحكام الفصل 1499 م ا ع في هذا الشأن من انه ليس للكفيل ان يحيل الدائن على تتبع مكاسب المدين إذا كان التزامه بالخيار مع المدين الأصلي.

وحيث أضحى قيام الدائن المعقب ضده الآن على الكفيل الشخصي المتضامن لاستخلاص دينه دون التوقف على ضرورة ثبوت تتبع مكاسب المدين الأصلي سليم قانونا وهو ما أكدته محكمة القرار المطعون فيه وكان رأيها ذاك على هدي من صحيح القانون.

وحيث وبخصوص النعي على محكمة الأصل إغفالها لتكليف خبير فانه تتجه الإشارة إلى أنّ الاختبارات من الوسائل الاستقرائية لتحقيق الدعاوى وهي وسيلة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهي مع ما حواه الملف من معطيات ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون ، وهو ما كان شان القرار المطعون فيه الآن بما لا يسع معه إلاّ رد المطعنين.

عن المطعنين الثالث والرابع لوحدة القول فيهما:

حيث من المسلم به أنّ بسط محكمة القانون لرقابتها الدنيا على القرار الصادر عن محكمة الأصل يقتضي بالضرورة أن تكون المطاعن والدفع المطروحة أمامها محررة على نحو يمكن المحكمة من التحري في مكامن الوهن والخلل التي تشوب القرار المطعون فيه أمامها.

وحيث جاء بتفصيل المطعنين المذكورين ان نائب المعقنين تمسك بمخالفة القرار الاستئنافي للقاعدة الأصولية القائلة بان الطاعن لا يضار بطعنه لتجاوز المحكمة ما انصب عليه الاستئناف كمخالفته للقاعدة التي تمنع على المحكمة تكوين حجج الأطراف والانعياز لأحد أطراف النزاع بمراجعة المحكمة لنص الحكم والترفع في المبلغ المطالب به.

وحيث كان المطعنان المذكوران متسمين بالاجمال وتعوزهما الدقة لا سيما وانه لم يتبين رجوعا إلى ما تم القضاء به ان المحكمة قد خالفت القواعد المذكورة لا سيما وانه لم يقع الترفع من المبلغ المحكوم به بل انه قد تم الحط من المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 509334.075 دينار إلى 470774.181 دينار بما لا يسع معه إلاّ اعتبار أنّ تطبيق صحيح القانون على هذين المطعنين يقتضي بالضرورة ردهما».

..... 5-2 كراء تجاري

5-2-1 امتداد دعوى الخروج ان لم يدفع للمكرى التجاري دون الحاجة لتنبيه تجاري على معنى الفصل 23 من قانون 1977

قرار تعقيبي عدد 2020.20140 بتاريخ 23 جوان 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«عن المطعن المأخوذ من مخالفة القانون وبالتحديد الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 / 05 / 1977 :

حيث كان الطعن الجوهري صلب مستندات التعقيب في اعتماد محكمة الحكم المطعون فيه الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 / 05 / 1977 وإساءة تطبيقه ذلك أنها صادرت الحق الذي خوله المشرع للمسوغ المتعلق برفع الطلب إستعجاليا في خروج المتسوغ من المكروى لعدم خلاص معينات الكراء رغم الصبغة الاستعجالية للطلب وفرضت أن يكون القيام بدعوى الخروج لعدم الدفع مسبقا بتوجيه تنبيه تجاري من المسوغ للمتسوغ وفق الفصل المذكور.

وحيث لا شك أن للمالك أو المتصرف بأي وجه قانوني في عقار معد للسكنى أو للإدارة أو الخدمة أو التجارة قانونا القيام بدعوى في المطالبة بمعينات الكراء من المتسوغ وأن هذا الحق مكفول بقواعد القانون العام وأن المشرع أسند هذا الحق للمسوغ في المجلة المدنية في الفصول المتعلقة بالكراء سواء كان الكراء بعقد كتابي أو شفاهي .

وحيث دأب فقه القضاء بدرجات المحاكم الأصلية ومحكمة القانون على النظر في دعاوى إلزام المتسوغ بخلاص معينات الكراء في إطار دعوى الخروج لعدم الدفع وهي الدعوى الأكثر تداولا ونشرا في المحاكم على مستوى الدوائر الاستعجالية المعينة بالمحاكم الابتدائية والتي تنظر في تلك الدعاوى استنادا إلى الفصل المرجعي 201 م م م ت . وهو النص المؤسس للطلب الاستعجالي الذي يشترط فيه وفق منطوقه أن يكون الطلب مؤكدا ومستعجلا وأن يكون بغاية حفظ حق ظاهر أو رد المساس به وتهديده بشرط عدم المساس بالأصل .

وحيث يتجه فقهاء البحث عن الحق الذي يحميه المشرع في الفصل 201 مرافعات في إطار العلاقة الكرائية بين المسوغ والمتسوغ ذلك أنه الحق الذي يعرض بصيغة شبه متطابقة في دعوى الخروج إن لم يدفع كما اصطلح على

تسميتها والممنوح للمسوغ الذي يسلم أو يمكن المتسوغ من محله مهما اختلفت أوجه ملكيته أو تصرفه أو وكالته ليستغله أو ينتفع به ويجني مقابل ذلك مالا أو ما يعادله عينا اصطلاح على تسميته كراء أو غلة كراء.

وحيث إن حق المسوغ في جني الكراء حق ثابت وله صبغة معيشية وأخرى اقتصادية ويمكن أن يرقى إلى حق ذا دور في تطوير وتنشيط الحركة التجارية والعقارية في الاقتصاد عامة.

وحيث إن هذا الحق المسند للمسوغ صنف فقها حقاً ظاهراً وحريراً بالحماية وأن المطالبة به تنصهر في جوهر وكيونة تركيبة ومقصد الفصل 201 م م م ت الذي شرع لحماية الحق الظاهر والمؤكد والذي تتوفر فيه شروط العجلة النابعة من فكرة أساسية وهو أن وضع محل أو عقار على ذمة المتسوغ يثبت انتفاعه به يوجب قانوناً تمكينه من معينات الكراء وفق الاتفاق وأن الإخلال بذلك الاتفاق فيه ضرر ومساس بحق تعاقدى اتفاقي حري بالحماية المؤكدة ، وفي غياب ذلك تهدر الحقوق ويقع المساس بمبدأ استقرار المعاملات والوضعية القانونية القارة ومن هذا المنطلق القانوني والاقتصادي تبنى فقه القضاء حماية حق المسوغ وأجاز النظر في دعوى الخروج إن لم يدفع إستعجالاً لانطباق الفصل 201 المرجعي عليها سندا ومرجعاً وهادفاً.

وحيث إنه وفي مقابل الحق المكفول للمسوغ فإن المشرع أكد على حق المتسوغ المتمثل أساساً في تمكينه من المكرب وحفظ حقه في استغلاله ورد إمكانات حرمانه من ذلك الحق بسبب المسوغ أو بسبب من له علاقة به وهي الحقوق المكفولة بنص الفصل 739 م ا ع «الذي يلزم المكرب «المسوغ» بتسليم العين المكتراة وبضمان انتفاعه بها».

وحيث انقسم الباحثون في المادة في جدوى وإمكانية رفع دعوى الخروج إن لم يدفع إن كانت الدعوى خاصة بالكراء السكني أو المدني كما سمي في بعض الكتابات ، أو أنه يمكن أن يمتد إلى كل أنواع الكراء سواء المخصص فيه المكرب للإدارة أو الخدمات أو ذلك المكرب التجاري وبالتحديد المستغل به أصل تجاري مكتسب أو محدث بالطرق القانونية لتكوين الأصول التجارية.

وحيث يندرج الملف الحالي الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه في السياق المذكور آنفاً في هذا الإطار ذلك أن المعقب طلب لدى محكمة الدرجة الأولى إلزام المعقب ضده «المطلوب» بالخروج من المكري لعدم خلاص معينات الكراء وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبد رأياً قانونياً ثم تولت محكمة الحكم المطعون فيه طرح سند جديد والمتمثل في مدى توفر شروط القيام بالدعوى المؤسسة على الفصل 201 م م م ت في النزاع واعتبرت أن ذلك القيام مختل لأن طبيعة الكراء الحالي ذو الصبغة التجارية يقتضي إتباع إجراءات قانونية أمرة من ذلك ضرورة توجيه تنبيه تجاري للمتسوغ على معنى الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977، وذلك للمطالبة بمعينات الكراء غير الخالصة وانتظار الأجل المحدد به وفق الفصل.

وحيث إن محكمة القانون وبعد أخذ ورد بخصوص تطبيق الفصل 23 من قانون 1977 ومدى صحة القيام بدعوى الخروج إن لم يدفع مباشرة في الدعوى التي يكون فيها طلب معينات الكراء وفق الفصل 201 م م م ت ودون توجيه تنبيه تجاري قد استقرت على مبدأ عام في عدة أحكام صادرة مستقرة ومتواترة سنوات 2018 و2019 على جواز القيام من المتسوغ بدعوى الخروج إن لم يدفع ضد المتسوغ وإن كان الكراء تجارياً ومهما كان نوع التجارة وطبيعتها.

وحيث وخلافاً لموقف محكمة الحكم المطعون فيه فإن لا فرق بين الكراء السكني أو المدني من جهة والكراء التجاري من جهة أخرى عند قيام حق المتسوغ في المطالبة بمعينات الكراء غير المدفوعة ، وأن سند هذا التمشي الذي له أصل قانوناً وواقعاً أن الدعوى لا توجه ضد المتسوغ بغاية فسخ العلاقة الكرائية ولا بغرض معاينة انفساخ عقد الكراء على اختلاف شكلياته وشروطه بل تهدف إلى إلزامه بالخلاص. كما أن ما يترتب عن دعوى الخروج إن لم يدفع من آثار ثابتة في صورة عدم الإذعان للحكم من تقدير وتقرير إخراج المتسوغ من المكري لا يفسخ العلاقة الاتفاقية ولا يمس بجوهر العقد ، على أن الخروج وإن كان بتقصير من المتسوغ إلا أن حصوله يكون مؤقتاً أو بصفة أولية ذلك أن طبيعة الدعوى تفترض تمكين المتسوغ طيلة فترات التقاضي من الخلاص حتى بعد صدور الحكم بالخروج وإرجاع المتسوغ للمكري بمجرد الخلاص في إطار موجبات إرجاع الحالة المقررة بالنص.

وحيث إن الحكم بالخروج من المكري لعدم الدفع لا يترتب عنه قانونا فسخ العلاقة الكرائية بين المتعاقدين ذلك ان الغاية من الدعوى ليس حرمان مالك الأصل التجاري من ملكه بل حثه على خلاص الكراء المجسم لحق المتسوغ الظاهر الحري بالحماية في الدعوى.

وحيث إن دعوى الخروج إن لم يدفع لا تحتاج لتقوم أركانها إلى تنبيه تجاري على معنى الفصل 23 من قانون 1977 ولا وجه لربط القيام بتوفر التنبيه لسبب بسيط ووجهه أن التنبيه يحزر ويوجه في إطار دعاوى الفسخ وأن التنبيه إن كان حام لحق المتسوغ ضمن موجبات قانون أمر وهو قانون 1977 إلا أنه يوجه ويعتمد عند توجه نية الطالب إلى دفع المتسوغ على الخلاص وتحقيق نتيجة حتمية بنص الفصل 23 من قانون 1977 من توجيهه وهي فسخ العقد الرابط بين الطرفين.

وحيث إن منطوق الفصل 23 من قانون 1977 وطبيعة الحماية التي كرسها لصاحب الأصل التجاري تنحصر قانونا عند القيام بالفسخ والذي ينجر عنه اضمحلال الأصل الذي من آثاره الضرر لمالكه كالضرر المفترض للدائنين المرتهنيين إن وجدوا كل ذلك في إطار المساس بالعقد وبكينونته مما فرض تطبيق الفصل 23 الأمر بحكم طبيعة القانون الذي أنشأه في حماية مسندة لصاحب الأصل إزاء مالك الجدران الذي عادة ما يسعى إلى استرداد المحل عقارا وأصلا.

وحيث إن الهدف من تكريس وإعمال الفصل 23 من ذلك توجيه التنبيه للمتسوغ وانتظار أمد الثلاثة أشهر بالنسبة للأكرية التجارية هو المحافظة على تلك العلاقات ذلك أن المتسوغ يكون عالما بحتمية انفساخ العقد الذي يملك به ويمارس به حقوقه على الأصل بمجرد انقضاء أجل التنبيه لحتمية الفسخ بعد فواته ، وذلك حافز للخلاص لكن الامتناع يترتب انتهاء العلاقة وفسخ العقد الذي لا يملك قاضي العجلة ذو السلطة المطلقة إلا معينته والتصريح به ، وتلك وضعية قانونية لا تتعلق بدعوى الحال التي لا ترمي من خلالها الطالبة «المعقبة» فسخ العقد بينها وبين معاقدها وفق العقد المضاف بالملف ليقع إلزامها بتوجيه تنبيه تجاري للمطلوب «المعقب ضده» على معنى الفصل 23 من قانون 1977 بل أنه كان يهدف لطلب إلزامه بدفع معينات الكراء وأن الدفع المحقق للأداء وتنفيذ الالتزام التعاقدي ينتج حتما محافظة المعقب ضده على الأصل ولا وجه

للتمسك بعدم انطباق الفصل 201 م م م ت لضرورة رد التفرقة في القيام بين أنواع عقود الكراء ذلك أن كل عقد حامل لحق ظاهر ومؤكد لمالك المحل مهما كان الاستغلال المجسم فيه وهو حري بالحماية المستعجلة ووفق دعوى مبسطة وهي دعوى الخروج إن لم يدفع مناط الفصل 201 المذكور وكان الحكم القاضي برد الطلب لعدم احترام موجبات الفصل 23 من قانون 1977 لملكية المتسوغ لأصل بالمحل غير ذي موضوع ، ومخالف لاتجاه فقهي وقضائي مستقر وسائد مؤسس على قراءة سليمة للقانون لا بد من توخيها من محاكم الأصل لغاية فضلى وهي استقرار الوضعيات القانونية والتعاقدية والحرص على المساواة بين المتقاضين لرد إمكانات عدم توحيد آراء المحاكم في المادة الذي ينجر عنه ظفر بعض القائمين بالحق في القيام إستعجالينا وفق الفصل 201 م م م ت بمجرد دعوى مبسطة وبين اشتراط تنبيه الفصل 23 وانتظار آجاله وكأن سند القيام فسخ عقد كراء والحال أن الطالب لا يروم ذلك ولا يهدف إلى تغيير العقد أو فسخه كما أن القيام محكوم بقواعد القانون العام عملاً بأحكام الفصل 534 م ا ع .

وحيث تعين لما سبق ذكره وتحليله قبول مطعن المعقبة والقضاء بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجدداً بهيئة أخرى».

5-2-2 اكتساب الحلاق لحق الملكية التجارية بصفته حرفي بقطع النظر عن ممارسته لنشاط تجاري إضافي بالمكرى

قرار تعقيبي عدد 75590 بتاريخ 6 جويلية 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجلاء المصمودي والسيدة نجوى الغربي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر .

«عن كافة المطاعن لترابطها ووحدتها القول فيها:

حيث انحصر الإشكال القانوني المطروح في معرفة مدى انطباق القانون ع37د لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية على نشاط الحلاقة الممارس بالمكرى ومدى اعتبار ذلك النشاط وإن كان حرفياً يكسب المتسوغ الملكية التجارية بقطع النظر عن تخليه عن ممارسته لنشاط

تجاري كبيع العطورات والمستحضرات التجميلية ومدى بطلان محضر التنبيه الموجه له تبعا لذلك على معنى أحكام القانون العام.

وحيث اعتبرت محكمة القرار المطعون فيه أن النشاط الحرفي المتمثل في الحلاقة لا يكسب لوحده الملكية التجارية ويجعل العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين منضوية تحت طائلة أحكام القانون العام وليس قانون 1997 المتعلق بالأكرية التجارية.

وحيث لا جدال أن قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 لا يقتصر مجال انطباقه على النشاط التجاري والصناعي فقط بل هو يمتد إلى النشاط الحرفي بصريح أحكام الفصل الأول منه الذي ينصّ على أنه «تنطبق أحكام هذا القانون على عقود تسويغ العقارات والمحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل سواء أكان على ملك تاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة».

وحيث يستشف من ذلك أن نشاط الحلاقة وبوصفه نشاطا حرفيا بامتياز تنطبق عليه مقتضيات قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 ويكسب صاحبه الملكية التجارية متى توفرت الشروط القانونية في حقه بخصوص مدة الاستغلال وتكوين أصل تجاري تتوفر فيه العناصر المنصوص عليها بالفصل 189 من المجلة التجارية بقطع النظر عن ممارسته لنشاط تجاري إضافي كبيع العطورات والمستحضرات التجميلية وهو الاتجاه الذي كرسته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة التي تبنت صلب قرارها المبدئي عدد 42233 المؤرخ في 13/04/1995 مبدأ اكتساب الحلاقة للأصل التجاري بقطع النظر عن بيعها للعطورات ومواد التجميل وعليه فإن ما انتهت إليه محكمة القرار المطعون فيه من اعتبار النشاط المتمثل في الحلاقة لا يكسب لوحده الملكية التجارية ولا يخضع بالتالي علاقة الطرفين لأحكام قانون 1977 هو موقف مخالف لصريح الفصل الأول من قانون 1977 ولما استقر عليه فقه القضاء هذا من ناحية.

وحيث ومن جهة أخرى فمن الثابت بالرجوع إلى أوراق الملف أن العلاقة الكرائية المتنازع فيها قد انعقدت بين طرفيها منذ غرة أفريل 1997 بموجب عقد كراء أول تضمن منطلقا أن النشاط المتعاطى بالمكرى هو بيع العطورات والحلاقة ليقع لاحقا إبرام عقد كراء ثاني بتاريخ 11 أكتوبر 2004 تعلق بنفس

المحل موضوع التسويغ في العقد الأول تضمن تنصيحا على أن الكراء قد انعقد لمدة سنة واحدة وذلك بغرض الحلاقة فيكون العقد المبرم خلال سنة 2004 قد أبرم بعد حصول المعقب الآن على الأقدمية في استغلال المكري واكتسابه تبعا لذلك للملكية التجارية بما يجعله عقدا مخالفا للفصل 32 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 الذي حجر أي شرط أو اتفاق أو عمل من شأنه أن يمس حق المتسوغ في التجديد إذ جاء به أن «البنود والشروط والاتفاقات التي من شأنها النيل من حق التجديد المحدث بهذا القانون أو من أحكام الفصلين 23 و26 من هذا القانون تكون لاغية ولا عمل بها مهما كان شكلها» وعليه فإن العقد الآنف ذكره والذي من وراء إبرامه تستهدف مالكة الجدران (المعقب ضدها الآن) حرمان المعقب من حق التجديد بعد أن كون أصلا تجاريا بالمكري لا يعتد به ويكون لاغيا ولا عمل عليه انفاذا لأحكام الفصل 32 المذكور أعلاه.

وحيث أن محكمة القرار المطعون فيه وحينما أخذت بعين الاعتبار العقد الثاني لسنة 2004 والتفتت عن العقد الأول لسنة 1997 لتستنتج من ذلك أن العلاقة التسويغية تنضوي تحت طائلة أحكام القانون العام وليس قانون 1977 المتعلق بالأكرية التجارية اعتبارا منها لطبيعة النشاط الممارس (حرفة الحلاقة) فضلا عن عدم اكتساب المعقب للأقدمية المستوجبة بموجب العقد الثاني وعدم إثارتها لأحكام الفصل 32 المذكور أعلاه والحال أنه يتعلق بالنظام العام تكون قد أورثت قضاءها خرقا للقانون وضعفا في التعليل وكان بذلك قرارها المطعون فيه مستهدفا للنقض واتجه التصريح بذلك».

5-3 شركات تجارية

5-3-1 فقدان الذات المعنوية لكل وجود مادي فهي مجرد افتراض قانوني

قرار تعقيبي عدد 2088 بتاريخ 6 جويلية 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيد البشير المطوي وعضوية المستشارين السيدين مريم البكوش وعربية الطوبهري وبمحضر المدعي العام السيد رفيق الحداد وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوي.

«عن المطعنين الأول والثاني لوحدة القول فيهما:

حيث من المسلم به قانونا وفقها وقضاء أنّ الطعن بالتعقيب منظم بجملة من القواعد والضوابط ولا سيما تلك المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا الطور فلا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم النهائي المنتقد وقد تبين بمراجعة المطعنين المذكورين انه قد تمت الإشارة في جانب منها إلى مناقشة صريحة للحكم الابتدائي وإعادة طرح لذات الدفوع المثارة أمام محكمة الأصل وهو ما لا يجوز بسطه بهذا الطور ذلك أنّ القاعدة العامة تقتضي أنّ مراقبة محكمة التعقيب لا تتسلط إلا على ما انتهى إليه القرار المطعون فيه أمامها.

وحيث انه وبقطع النظر على ما تقدم وتأكيدا لسلامة ما انتهت إليه محكمة القرار المطعون فيه من اتجاه ، فانه من المتعين الإشارة إلى ان الذوات المعنوية تعتبر فاقدة لكل وجود مادي وإرادة مستقلة باعتبارها ذاتا افتراضية لا تكتسب وجودها إلا من خلال الاستنباط التشريعي « Fiction Juridique » ، فكونها مجرد افتراض قانوني اقتضته الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة يجعلها بالضرورة لا تُرى ولا تُعرف إلا من خلال ممثلها باعتباره التجسيد المادي لها وعليه فإنّ الإعلانات وكل الإجراءات الموجهة لها أو المتخذة ضدها هي - بالضرورة - موجهة لمن يمثلها قانونا من الذوات المادية وان عدم ذكر ذلك ليس من شأنه أن ينفي هذه الحقيقة وبالتالي فان عدم ذكر عبارة «في شخص ممثلها القانوني» عند تبليغ عريضة دعوى أو غيرها من الإجراءات ليس من شأنه أن يورث إجراءات القيام خللا شكليا وهو ما أكدته -عن صواب - محكمة القرار المطعون فيه تماهيا مع انتهت إليه محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة بقرارها عدد 38899.2009 بتاريخ 26/04/2012 والذي جاء به «وإن كانت الذات المعنوية منزلة الصغير على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 5 م إع ووجب تبعا لذلك مقاضاتها في شخص ممثلها القانوني فقد استقر فقه القضاء على اعتبار أن غياب عبارة في شخص «ممثلها القانوني» لا يترتب عنه البطلان» .

5-3-2 تقنيات خصخصة المؤسسات والمساهمات العمومية التي يمكن للسلطة العمومية إتباعها إذا ما رغبت في إعادة هيكلة المؤسسة.

قرار تعقيبي عدد 75590 بتاريخ 6 جويلية 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن جملة المطاعن لترابطها ووحدة القول فيها:

وحيث عدد القانون المنظم لعمليات خصخصة المؤسسات والمساهمات العمومية التقنيات التي يمكن للسلطة العمومية إتباعها إذا ما رغبت في إعادة هيكلة المؤسسة ما وتنقسم تلك التقنيات في ثلاثة أقسام أساسية (بيع سندات مساهمة) أو بيع أصول (Cession d'actifs) أو هيكلة بالمعنى الدقيق للكلمة (اندماج شركة في أخرى Fusion أو انقسام شركة scission) وان السلطات العمومية تختار احد التقنيات دون الأخرى أو المزج بينها وان الحرية التي تتمتع السلطة العمومية في ذلك لا تقيدها سوى ضرورات السوق ووضعية المؤسسة موضوع عملية إعادة الهيكلة كصيغة الإحالة كما هو في دعوى الحال.

وحيث اطر المشرع عملية الإحالة بإجراءات شكلية تقتضي أن تتولى «لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها» إبداء رأيها في برنامج التطهير وإعادة هيكلتها «إبداء رأيها في برنامج التطهير وإعادة الهيكلة وشروط تنفيذ (الفصل 24) وبعد تحوير قانون 1989 بموجب القانون عد102-د لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 أضيف الفصل رابعا الذي تضمن انه «يمكن بيع كتلة أسهم عن طريق طلب عروض وفق كراس شروط لفائدة شخص مادي أو معنوي أو مجموعة أشخاص ماديين أو معنويين ومنه فإن كراس هو الذي يحدد العناصر الأساسية للعقد المزمع إبرامه ويقتصر الراغب في الشراء على الانضمام إليه وتحديد الثمن الذي يقبل به الشراء، وقد عاينت محكمة الاستئناف، دون تحريف منها للوقائع، إن كراس الشروط كان يتضمن تنصيحا صريحا بعدم ضمان بقوله «إن تقدير العارض لقيمة العادلة للأسهم موضوع طلب العروض

هو شأن خاص به، ولا يمكنه في أي حال أن يرجع على المحيل متعللاً بأنه تمت الزيادة في قيمة الأصول إن تم التنقيص في قيمة الخصوم».

وحيث تمت فتح عرض الإحالة على مقتضى مضمون كراس الشروط الذي من أهم ما تضمنه بالفقرة الأخيرة: «إنّ تقدير العارض للقيمة العادلة للأسهم موضوع طلب العروض هو شأن خاص به ولا يمكنه في أي حال أن يرجع على المحيل متعللاً بأنه تمت الزيادة في قيمة الأصل إن التنقيص في قيمة الخصوم».

وحيث تكون على هذا الأساس عروض الشراء بدون ضمان وعلى أساس نفس الشروط المدرجة في كراس الشروط ويحرر كل راغب في الشراء عرضه المالي حسب صيغة موحدة مضبوطة سلفاً من طرف البائع بحيث يكون التزام المشتري نافذاً غير معلق على شرط وغير متضمن لأي احتراز فيصرح فيه العارض بصريح العبارة بالتنقيص التالي «ان العارض اطلع على الوثائق الاجتماعية وقدر من وجهة نظره وتحت مسؤوليته الوضعية المادية للمؤسسة» كما تضمن كتب العرض تصريحاً «بان العارض يخضع ويلتزم باحترام كراس الشروط بدون أي استثناء».

وحيث ان شرط «الضمان» المدرج بكتب البيع (كتب الإحالة) الذي تم توقيعه لاحقاً هو مجرد شكلية تضاف لتبادل الرضا لغاية معارضة الغير بالبيع وخاصة للقيام بإجراءات الإيداع بالمحكمة والتسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس (الفصل 71 من قانون 14 نوفمبر 1994)، ولا يفتح المجال لإعادة التفاوض في شروط البيع وعلى وجه الخصوص لإدراج شرط مخالف لما ورد في كراس الشروط يقتضي ضمان المحيلين لقيمة الأصول أو لقيمة الخصوم وان وجد فهو مخالف للفصل 33 رابعاً من القانون عدد المؤرخ في أول فيفري 1989 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 ولإجراءات البيع عن طريق كراس الشروط ولا يمكن العمل به فالعرض والقبول تم وفق كراس الشروط وان زيادة ضمانات إضافية بكتب الإحالة لم تسمح بها كراس الشروط يعد خرقاً لمبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الراغبين في الشراء وبما يحمي المال العام فلا يجوز تغيير موضوع التعاقد دون احترام مبادئ الدعوة للمنافسة والشفافية وعليه فإنه لا يمكن أن تدرج في عقد الإحالة

شروطا مخالفة لما ورد في كراس الشروط ومنها الشرط الذي يقتضي ضمان المحيلين لقيمة الأصول أو لقيمة الخصوم لما في ذلك من مخالفة الإجراءات البيع عن طريق كراس الشروط وتبعا لأحكام قانون غرة فيفري 1989 (تناول المجلس الدستوري الفرنسي نفس المسألة التي نحن بصددتها في قرار مؤرخ في يومي 25-26 جوان 1986 فصرح (الصفحة 4 من القرار) *que le choix des acquiers ne devra procéder d'aucun privilège* العمومي يخضع لقيود خاصة عندما يقوم ببيع مساهمته ويفقد حريته في تحديد شروط العقد النهائي بصورة خارجية مضمون كراس الشروط).

وحيث لا تخفي أيضا الصبغة الآمرة للفصل 33 رابعا من قانون 1989 ذلك أنّ أحكام قانون إعادة هيكليّة المؤسسات العمومية لها صبغة أمرّة بالنظر إلى اتصالها بحماية المال العام من جهة وبحماية المساواة بين العارضين والشفافية من جهة أخرى وإن مخالفتها تؤدي إلى الإضرار بالمؤسسة التي تساهم فيها الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إلى تحقيق منفعة للغير على حسابها.

وحيث سايرت محكمة الحكم المطعون القرار التعقيبي السابق في القضية عد 2016-37050 الذي تضمن انه «وحيث فضلا عن ذلك فإن قراءة المحكمة لأحكام الفصل 6-6 و 6-7 من كتب الإحالة على أنّها تكريس لضمان الطاعنة يجعل من كتب الإحالة متناقضا مع كراس الشروط ومن ثمة مع نفسه باعتبار أنّ كراس الشروط يمثل جزءا منه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قراءة المحكمة تجعل كتب الإحالة مخالفا لمبادئ المنافسة والشفافية التي جاء بها القانون عد 9-د لسنة 1989-ة ذلك أنّ عملية خوصصة مصنع الخزف التونسي تمت في نطاق دعوة للمنافسة حسب كراس الشروط ضمانا للشفافية في بيع الملك العام وضمانا للمساواة بين الراغبين في الشراء وعليه فإنه طالما تضمن كراس الشروط الذي على أساسه قدمت المطعون فيه ضدها عرضا بالشراء تضمنا تنصيبا صريحا على عدم الضمان وعدم مسؤولية الباعين عن صحة القوائم المالية فإنّ إرادة المشتريّة تكون قد اتجهت لشراء الأسهم دون ضمان... وعلى هذا الأساس تمت المصادقة على عرضها من طرف اللجنة المعنية وسلطة الإشراف وفق ما هو ثابت من أوراق وان في تعسف المحكمة في قراءة هذا الفصل 6 جزمها بأنّه منح ضمان للمعقب ضدها والحال انه تم رفض

هذا الضمان لباقي الراغبين في الشراء الذين قدموا عروضهم على أساس كراس الشروط يجعل عقد الإحالة مخالفا لقانون إعادة هيكلة المؤسسات الذي أرسى إجراءات شكلية صارمة للتعاقد تكفل الشفافية والمساواة بين جميع الراغبين في الشراء». وحيث أحسنت محكمة القرار المتقدم تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وأضحت المطاعن غير وجيهة وتعين ردها».

5-4 تجارة بحرية

5-4-1 الخطأ غير المغتفر لربان السفينة في المجال البحري

قرار تعقيبي مدني عدد 71328 بتاريخ 02 جوان 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثانية والثلاثين برئاسة السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية المنتصر ونفيسة العلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الحلواني.

«حيث عابت الطاعنة على محكمة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 12 من مجلة التأمين لما لم تتحرى في طريقة تحرير شروط إعفاء الضمان من الناحية الشكلية.

وحيث لا جدال في أن دعوى الحال تتعلق بتعويض أضرار بدنية ناتجة عن حادث اصطدام بين باخرتين وبالتالي تندرج في إطار مسؤولية الناقل البحري الخاضعة لأحكام مجلة التجارة البحرية.

وحيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 297 من مجلة التجارة البحرية على أن «الأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين البري لا تنطبق على التأمين البحري» مما يجعل احتجاج المعقبة الآن بمقتضيات الفصل 12 من مجلة التأمين في غير طريقه ومخالف أيضا لما اقتضته الشروط الخاصة لعقد التأمين المبرم بين طرفي النزاع.

وحيث بات بذلك هذا المطعن غير قائم على أسانيد قانونية سليمة وأضحى بذلك من المتعين رده.

عن بقية المطاعن لاتحاد وجه القول فيها:

حيث تسلطت جملة المطاعن المثارة على الدفع بكون محكمة القرار المطعون فيه لم تهتد إلى الوصف السليم للخطأ المزعوم المنسوب للناقل والمؤدي إلى

استثناء الضمان لا سيما أنّ العلاقة السببية بين خطأ الربان والضرر مفقودة كما نسبت المعقبة للحكم المنتقد تحريفه بنود عقد التامين وخرقه مبدأ القوة الملزمة للعقد الواردة بالفصل 242 ماع عندما اعتبر ان عقد التامين لا يغطي الخطر الذي تحقق.

وحيث تعلق الإشكال القانوني مناط قضية الحال بضرورة تحديد مدى توصل محكمة الحكم المنتقد إلى تكييف طبيعة الخطأ المنسوب لرباني الباخرتين التابعتين للمعقبة وبالتالي مدى تحقق شرط الاستثناء من الضمان المنصوص عليه بالفصل 3 من الشروط العامة لعقد التامين.

وحيث أنّ الإجابة عن هذا السؤال تفرض التعرض إلى مفهوم الخطأ عموماً وفي المجال البحري خصوصاً كضبط أصنافه وتحديد طبيعته القانونية ومعياريه .

وحيث لم يعرف المشرع التونسي الخطأ مكتفياً باستعمال عبارات عامة للدلالة عليه في المجلة الجزائية كعبارة «القصور» و« الإهمال» و«التغافل» و«عدم الإحتياط» أو «عدم مراعاة القوانين» أما في القانون المدني فقد خير المشرع تصنيف الخطأ صلب الفصل 83 ماع إلى خطأ بالفعل وخطأ بالتترك.

وحيث أجمع فقهاء القانون على تعريف الخطأ بأنه إخلال بالتزام معلوم بصفة مسبقة سواء كان مصدر هذا الالتزام القانون أو العقد.

وحيث أنّ الخطأ في المجال البحري لا يخرج عن هذا الإطار لكنّه يتميّز بخصائص لها صلة وطيدة بالقواعد الأساسية المنظمة لهذا المجال والأصول الفنية الثابتة المتعلقة به والتي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف.

وحيث لا جدال في أنّ تقدير مدى جسامته الخطأ المرتكب خاضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي عليه اعتماد معيار محدّد عند تحديد مسؤولية الطرف المخطئ لمعرفة ما إذا كان هذا الأخير قد بذل العناية اللازمة أو أنّه قصّر عند القيام بواجبه أو خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون الأصول الفنية الثابتة والقواعد الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف.

وحيث يركز معيار تقدير الخطأ من طرف محكمة الموضوع على ثلاثة أسس أولها تقدير سلوك الشخص المنسوب له الخطأ على ضوء سلوك شخص آخر من نفس الاختصاص والمستوى وثانيها الأخذ بعين الاعتبار للظروف الخارجية التي

أحاطت بالفعل الضار ومدى علم المتسبب في الضرر بها بصفة مسبقة من عدمه أمّا ثالثها فيتعلق بتحديد مدى مخالفة الفعل الضار المرتكب نتيجة الخطأ لتقاليد المهنة المعمول بها والأصول العلمية الثابتة.

وحيث بالاطلاع على أسانيد الحكم المطعون فيه يتبين أنّ المحكمة انطلقت عندبتها في النزاع القائم بين الطرفين من التساؤل حول طبيعة الخطأ الذي أدى إلى حصول حادث الاصطدام بين الباخرتين والذي انجر عنه الضرر الذي لحق المدعي في الأصل والمراد التعويض عنه الآن وما إذا كان مجرد خطأ عادي في الملاحاة أم انه خطأ غير مغتفر يبرر تمسك المعقب ضدها شركة التأمين كומר باستثناء الضمان.

وحيث عرفت محكمة الحكم المطعون فيه الخطأ الغير مغتفر بكونه خطأ الذي يبلغ حدا من الجسامة غير عادي وينجم عن فعل أو ترك إرادي بكيفية كان من المفروض أن يخامر الفاعل الخطر فيه وذلك مع انعدام أية دواع تبرر هذا الخطأ الذي تنعدم فيه نية الإضرار بما يميزه عن الخطأ العمدي.

وحيث وانطلاقاً من هذا التعريف تولت محكمة الدرجة الثانية تكييف الأفعال المنسوبة لرباني الباخرتين انطلاقاً مما حواه الملف من مؤيدات واختبارات ومعاينات مجرة من طرف باحث البداية ومضمنة بمحضر البحث الجزائي وما أفضت إليه التحريات المكتبية المجرة في الغرض متوصلة بعد استعراض جملة من المعطيات الواقعية والقرائن القوية والمتظافرة إلى ثبوت تعدد الأخطاء التي ارتكبتها رباني السفينتين المتصادمتين والتي من شأنها أن ترتقي إلى مرتبة الأخطاء الغير مغتفرة في مجال نقل البضائع والأشخاص بحراً والتي تسببت في حصول الضرر المراد التعويض عنه.

وحيث خلافاً لما ورد بمستندات الطعن فإن المنحى الذي انتهجته محكمة الحكم المطعون فيه كان قائماً على أساس صحيح واقعا وقانونا ضرورة أن التزام الناقل يندرج في إطار الالتزام بتحقيق نتيجة والذي يعرف بكونه الالتزام الذي يوجب على من التزم بتنفيذه تحقيق النتيجة محلّ الالتزام على خلاف الالتزام ببذل عناية الذي تكون فيه النتيجة المرجوة من الاتفاق المبرم غير محققة الوقوع ويكون تحقيقها مجرد احتمال.

وحيث لا جدال في أنّ المعقبة الآن ملزمة بضمان سلامة المسافرين على متن الباخرة التابعة لها أثناء السفرة البحرية بعدم تعريضهم إلى أيّ أذى وعدم إهمالها اتخاذ الاحتياطات التي يملئها الحذر العادي وضرورة مراعاة الحيلة والحذر اللازمين عند قيادة الباخرة الأمر الذي تؤكد لمحكمة الموضوع من خلال جملة القرائن الثابتة بالملف مخالفته من قبل المعقبة.

وحيث أنّ الخطأ الغير مغتفر هو الخطأ الذي يبلغ من الجسامة حداً غير عادي ويتنفي فيه عنصر العمد وينتج عن فعل أو ترك إرادي أي عن معرفة مسبقة بإمكانية حصول الخطر ورغم ذلك يتعمد مرتكب الضرر المجازفة غير عابئ بعواقبها دون وجود أي سبب يبرر تصرفه ذاك الأمر الذي ومثلما أقرّته محكمة الحكم المنتقد ينطبق تمام الانطباق على وقائع قضية الحال باعتبار أنّ ربان الباخرة التي كان يمتطيها المدعي في الأصل تعمد الإبحار في ظروف مناخية سيئة كان يعلمها بصفة مسبقة كما كان يعلم أنّ الإبحار لا يتماشى مع خاصيات الباخرة التي يقودها والتي لا يمكنها تحمل رياح تفوق قوتها 6 درجات فضلاً عن اتخاذ رباني الباخرتين قرارهما بالدخول إلى القنال في نفس الوقت ودون التنسيق بينهما مثلما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل ودون الاتصال لاسلكياً بديوان الموانئ البحرية رغم علمهما بالظروف المناخية غير الملائمة والتي زامت كامل السفرة البحرية.

وحيث وبناء على ما سلف بسطه وعلى خلاف ما ورد بمستندات الطعن فقد سلم القرار الاستئنافي من المآخذ المنسوبة إليه وكان قضاء محكمة الموضوع متوجهاً بتعليق سليم قانوناً ومبرراً واقعاً ولا تثريب عليها في ذلك مما يتجه معه رفض التعقيب أصلاً».

5-5 ملكية صناعية

5-5-1 جواز استعمال التسمية الجغرافية كصفة تمييزية لعلامة تجارية أو علامة صناعية أو علامة خدمة

قرار تعقيبي عدد 20750.2020 بتاريخ 10 نوفمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة

سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي .

«عن المطعن المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه:

من حيث القول بخرق المحكمة لأحكام الفصلين 11 و 32 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001:

حيث بين نائب الطاعنة صلب مستندات التعقيب أن الإشكال القانوني المطروح في القضية يتمثل أساسا في مدى قابلية إيداع عبارة «مرناق» **Mornag** كعلامة تجارية أو جزء من العلامة من قبل المعقب ضدها كمدى صحة قيام المعقب ضدها بمنع غيرها من منتجي الأغراب بما في ذلك المعقبة في نفس المنطقة الجغرافية من إستعمال هذه العبارة كدلالة على المنشأ؟

وحيث لا بد من التذكير تصديقا لقول نائب الطاعنة أن البت في صحة العلامة وفي صبغتها الوصفية أو التمييزية أو النظر في قابليتها لكي تكون علامة مكتملة الشروط والمواصفات أو أنها علامة مضللة كما أصطلح على تسميتها كذلك عند تعريف العلامة التجارية في القسم 1 من القانون النموذجي للدول النامية للعلامات والأسماء التجارية وقوانين المنافسة غير العادلة الصادر سنة 1967 وقد عرف توجيه المفوضية الأوروبية الصادر عام 1998 حول العلامات التجارية العلامة التجارية على أنها «العلامة التي يقصد بها توصيف المنتجات أو الخدمات بإحدى المشروعات من غيره من المشروعات الأخرى».

وحيث وبالرجوع لموقف المحكمة القائل بأن البت في صحة العلامة وفي مدى توفر الخاصيات المكونة لجوهرها غير راجع لمحاكم الأصل وأن المعقبة فوتت على نفسها الإعتراض على العلامة قول مردود باعتبار أن المعقبة ومنذ الطور الأول قامت بالرد على الدعوى في التقليد التي تختلف عن دعوى إبطال العلامة ، كما أن المعقبة لم تطلب إبطال علامة المعقب ضدها بل طلبت رد دعوى التقليد لعدم حيابة المعقب ضدها لعلامة تجارية لخلوها كما وقع شرحه من الطاعنة من التميز لدلالاتها على المصدر الجغرافي وللتصحيح لاعتبارها علامة عامة لا يمكن الإستثمار بها واعتبارها ملكا محفوظا مانعا لإستخدامها من الغير وكان تخلي المحكمة عن النظر في الدفوعات المقدمة من الطاعنة الآن

غير سليم من حيث التسبب لكنه غير مخالف للفصل 11 من قانون 2001 ذلك أن الفصل 11 وكذلك الفصل 32 من القانون والمتمسك به من الطاعنة تعرض إلى دعوى البطلان التي تقام رأساً أمام المحكمة المختصة كما أنه أشترط للقيام بدعوى البطلان من صاحب الصفة والمصلحة أن يكون القيام عند عدم مطابقة التسجيل للفصول 2 و 3 و 4 و 5 من القانون ذلك أن المشرع يخص الدعوى بمن تولى الإعتراض على العلامة وواصل في إجراءات التقاضي بعد فشل التوافق وفق الفصل 12 من القانون لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وهو الوضع القانوني الذي كرسه الفصل 32 من قانون 2001 ولا يمكن إعتداد آليات البطلان لرد دعوى التقليد خلافاً للطلب والأصل في الأمور أن المحكمة لا يمكنها إحالة البت في صحة العلامة أو بطلانها للمعهد المكلف بالتسجيل والنشر وغيرها من الإجراءات الإدارية لكنها لا يمكنها البت في دعوى البطلان التي من اختصاصها وفق الفصل 32 من القانون في إطار دعوى أصلية في التقليد تطبيقاً للقانون والأعمال التحضيرية لمشروع القانون ولطبيعة النزاعات المثارة لدى المحاكم المنضوية تحت إتفاقية باريس المصادق عليها من الجمهورية التونسية وكان المطعن غير ذي موضوع.

من حيث القول بخرق محكمة الحكم المطعون فيه للقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999:

حيث تمسك نائب المعقبة بمخالفة المحكمة للقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 في فصليه الأول والثاني، ذلك أن هذا القانون السابق في الصدور لقانون العلامات التجارية لسنة 2001 قد كرس التسميات المثبتة للأصل « إسم البلد أو الجهة الطبيعية أو بعض أجزائها والتي يتأتى منها المنتج ويستمد قيمته وخاصياته منها بالنظر إلى محيطها الجغرافي المتكون من عناصر طبيعية وعناصر بشرية... » وذلك بهدف حماية خصوصيات ومميزات المنتجات الفلاحية وتأمينها بإسنادها تسمية مثبتة لأصلها وبيان مصدرها... كما تمسك بأن الفصل 20 من ذات القانون أقر الحماية والحق المشترك لكل من يتولون تصنيع وتعبئة منتج في الجهة التي يشملها نظام التسمية المنشأة للأصل كما نص على عدم إسناد هيئات المواصفات أي علامة صنع أو إتجار تتطابق

مع تسمية مثبتة للأصل أو لبيان المصدر إذا صدر طلب العلامة بعد الإعلان عن تحديد التسمية...

وحيث تم التمسك من حيث تطبيق قانون سنة 1999 سابق الذكر أن الشركة المعقبة لها منتوجات تنتمي للمنطقة المثبتة للأصل وفق تقسيم المناطق الفلاحية والمقرر من وزارة الإشراف «وزارة الفلاحة» وأن المعقب ضدها لا تنتمي للمنطقة المصنفة تحت تسمية «مرناق» بحكم التقسيم الجغرافي والواقعي كما تم التمسك بالصبغة الأمرة لقانون 1999 فضلا عن مفعوله الرجعي الذي ألزم كل من قام بإستعمال تسمية مثبتة للأصل كعلامة ولم تكن منتجاته خاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات الناشئة عنه بأن يتخلى عن إستعمال العلامة أو يمثل للتسويق بشروط التسمية المستعملة مع التشديد على أن الإستعمال يبقى مشتركا لكل المستغلين الفلاحين في المنطقة.

وحيث وإن لم تقدم المعقبة ما يثبت أنها وعلى فرض التسليم بإنتمائها جغرافيا لمنطقة تسمية المنشأ أو الأصل «مرناق» من خلال رخصة أو ملصقة من وزارة الإشراف قد إحتزمت كل إجراءات الحصول على التسمية وفق كراس الشروط وغيرها من الإجراءات المحددة بقانون 1999 والمدرجة بعده بأوامر وقرارات وزارة الفلاحة فإنها تمسكت برجعية القانون من حيث إستعمال التسمية سابقا من المعقب ضدها والمقررة لتسمية مثبتة للأصل بعد كسب المعقب ضدها علامتها الناشئة والمستعملة منذ سنوات الخمسينات وفق ما أضيف بالملف فإن التسمية مهما كان مصدرها تقوم قانونا حقا مشتركا لكل المستغلين الفلاحين في المنطقة أو التقسيم الجغرافي وأن تلك التسمية تم إعتماها قانونا في قانون 1999 في الإستغلال الفلاحي الذي يشمل نشاط الطرفين في جانب الإنتاج أو الزراعة والذي أتخذ صبغته الصناعية والتجارية في أهم مظاهرها ذلك أن التسمية الفلاحية هي مصدر الحماية والعناية في قانون 1999 وفق نصوصه والقرارات الصادرة عن وزير الفلاحة المضافة بالملف والتي وإن كانت سابقة في الزمن للقانون المنظم لتسميات المنشأ إلا أن القرارات الوزارية لا يمكن أن تكون لها إلزامية القانون فضلا عن أنها تشمل التصنيف لمنطقة التسمية للمنشأ من المنظور والتقنين الخاص بالمنتوج الفلاحي.

وحيث لا خلاف بخصوص القول أن القانون عدد 57 لسنة 1999 قانون يهتم النظام العام وتبعاً لذلك ترتقي أحكامه للأمر والنفاذ كما لا خلاف بخصوص طابعه الجماعي كما لا جدال أيضاً بخصوص أن تسمية المنشأ ترقى إلى العلامة في المجال المخول لكل المنتجين في المنطقة المعنية للدلالة على المنشأ وأن منطقة مرنانق تسمية منشأ فلاحية في تنظيم قانوني ثابت لها طابع جماعي وأن محاكم فرنسية إعتبرت في عدة أحكام أن الاسم أو التسمية حرية بالحماية إلا أن فقه القضاء الفرنسي حمى العلامة المصنعة والتجارية على غرار حماية منطقة تصنيع وتسويق النبيذ في منطقة «شامبانيا» بقطع النظر عن التسمية الفلاحية ومن هذا المنطلق القضائي المستشهد به يطرح السؤال الجوهرى في القانون: وهو مدى صحة تطبيق القانون عدد 57 لسنة 1999 في نشأة قانون العلامات التجارية وعلامات الصنع والخدمة بموجب القانون عدد 36 لسنة 2001؟

حيث إن الرد على السؤال المطروح له الجواب المستفيض في أحكام القانون عدد 36 لسنة 2001 الصادر في 17/04/2001 وهو قانون خاص بالعلامات التجارية دون التسميات الأخرى سواء فلاحية أو غيرها كما أنه قانون حذف أحكام الأمر العلي المنظم للمادة ما عدا ما تعلق بكسب مدة التسجيل المضمنة به ووفق آجاله تكريسا للحقوق المكتسبة.

وحيث جاء بالفصل 68 من القانون عدد 36 لسنة 2001: «أنه تلغى بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة الأمر المؤرخ في 3 جوان 1889 المتعلق بعلامات الفبريكات وعلامات المحلات التجارية والنصوص المتممة والمنقحة له».

وحيث تنفيذا وتطبيقاً لنص الفصل 68 فإن أحكام قانون عدد 57 لسنة 1999 تلغى فيما تعلق بعلامات التجارة باعتبار إتجاه المشرع الثابت نحو إلغاء أي قانون سابق لقانون 2001 يتعلق بالعلامات التجارية وعلامات الصنع والخدمة.

وحيث إن ما جاء صريحاً في الفصل 20 من قانون سنة 1999 من أنه: «لا يمكن لهيئات المواصفات إسناد أي علامة صنع أو إتجار تتطابق مع تسمية مثبتة للأصل أو بيان للمصدر إذا صدر طلب العلامة بعد الإعلان عن تحديد التسمية أو البيان طبقاً للإجراءات المشار إليها بالفصل 15 من هذا القانون.» يصبح

بمفعول مباشر لصدور القانون عدد 36 لسنة 2001 في الفصل 68 منه لاغيا ولا عمل عليه وذلك بقطع النظر عن إن كانت التسمية إستعملت لمدة دنيا أو قصوى وعن سابقة ملكيتها قبل صدور قانون 2001 كما أن العبرة بصدور قانون 2001 وثبوت إتمام المعقب ضدها لموجبات التسجيل الحامي لعلامتها «أو مرناق» الحاصل سنة 2003 وفق شهادة التسجيل القانونية المضافة بالملف.

وحيث إنه وكنتيجة حتمية للتحليل السابق فإن القانون عدد 57 لسنة 1999 والمعتمد كسند ثابت في مطعن مستقل لحجب الحق عن المعقب ضدها في إستعمال علامة بها عبارة أو تسمية مرناق لعمومية العبارة من حيث التسمية والإنتماء ومن حيث حق كل المستغلين الفلاحيين المتوجهين نحو التصنيع والتسويق بمفهوم الإتجار لمنتجات تسمية المنشأ في إستعمال العبارة ما دامت مشتركة بين جميع المنتجين والتجار على حد السواء لا عمل عليه وذلك لمعطى قانوني ثابت وهو أن القانون عدد 36 لسنة 2001 كان قد ألغى القانون عدد 57 لسنة 1999 فيما تعلق بالعلامات التجارية لرغبة ثابتة من المشرع من خلال إصدار قانون العلامات في أفرادها بقانون خاص وإلغاء كل القوانين التي أشارت إلى العلامة التجارية سواء كان القانون متعلقا بالنظام العام من عدمه ولم يبق إلا على عنصر إكتساب تسجيل العلامات المسجلة في ظل القانون القديم لحفظ الحقوق لا غير مما تعين معه إستبعاد كل الأحكام الواردة بقانون سنة 1999 لمخالفته قانون العلامات التجارية شكلا وجوهرا.

من حيث القول بخرق القرار المطعون فيه لأحكام الفصول 2 و3 و4 و36 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 / 04 / 2001 والمتعلق بعلامات الصنع والتجارة والخدمة:

حيث تأسس طلب النقض للقرار المطعون فيه القاضي بتقليد المعقبة لعلامة خصيمتها على عدم إستثثار وتفرد المعقب ضدها بعلامة «مرناق» وأن العلامة التجارية المسجلة من المعقب ضدها في 27 فيفري 2003 لا يمكن أن تستمد ميزتها والأصح التمييز المفترض فيها من عبارة «مرناق» باعتبار ما سلف ذكره من أنها علامة مصدرها تسمية منشأ وهي حق مشترك لكل مصنعي الخمور وليست حكرا على المعقب ضدها كما تمسك بإمكانية إستعمال تسمية المنشأ عند توفر

شروط ذلك في حالة تكون العلامة مركبة وبشروط قانون 1999 مضيفاً أن المعقبة إتخذت علامة التسمية للمصدر المنتمية له وأضافت له عناصر تصويرية لتمييز بين تسمية المنشأ والعلامة وهو ما حققته المعقبة مبيناً أن الحكم مخالف للفصول 2، 3، 4 من قانون 2001 وتم من جهة أخرى التمسك قانوناً بأن كلمة «مرناق» لا يمكن أن تشملها أحكام قانون 2001 تفعيلاً لقانون 1999 المتعلق بتسميات المنشأ.

وحيث إنه وقبل الخوض في قراءة سليمة للفصول المعرفة للعلامة في قانون 2001 يبقى مثيراً للإستفسار عن ما تم تقريره من نائب المعقبة أن عبارة «مرناق» في حد ذاتها لا يشملها قانون 2001 ذلك أن التقدير ينتج حتماً أن العلامة المملوكة من المعقبة لا يشملها قانون 2001 وهي مجرد تسمية منشأ ويكون بذلك القول بملكية المعقبة لعلامة تجارية والبحث عن تواريخ التسجيل والإستعمال للعلامة لكلا الطرفين وصحة التصنيف لمنتج المعقب ضدها من حيث التصنيف القانوني بمعهد المواصفات والملكية الصناعية غير ذي موضوع في النزاع.

وحيث كان المطعن الجوهري في النزاع في قول المعقبة أن الفصل 2 من قانون 2001 قد عرف العلامة التجارية وأن الفصل 3 من ذات القانون بين أنه لا تشكل الشارات أو التسميات التي يمكن إستعمالها للدلالة على المصدر الجغرافي.... وقرر ذات النتيجة مع التفصيل في الفصل 4 من القانون.

وحيث وخلافاً لطرح المعقبة فإنه لم يذكر الفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2001 بأمانة ذلك أن الفصل عرف العلامة على أنها شارة ظاهرة تمكن من تمييز المنتجات ... التي يسديها الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي ... إلا أنه كان لزاماً نسخ كامل نص الفصل الثاني الذي جاء فيه تعريف العلامة ومكوناتها: مما تتكون العلامة «الشارة» خاصة من:

أ- التسميات بمختلف أشكالها مثل ... الكلمات ومجموع الكلمات والألقاب والأسماء المستعارة ... والأسماء الجغرافية.

حيث وفي قراءة للفصل الثاني نجد أن المشرع عرف العلامة كشارة ظاهرة ثم حدد مكوناتها ذلك يمكن أن تتشكل وتحدد من حروف أو تسميات من ذلك

التسميات الجغرافية وبعبارة أوضح فإن المشرع قرر أن المبدأ هو جواز استعمال التسمية الجغرافية كعلامة تجارية أو علامة صناعية أو علامة خدمة.

وحيث أن المعقب ضدها في النزاع تولت تسجيل علامة تجارية تضمنت تسمية جغرافية باعتبار أن كلمة «مرناق» هي منطقة جغرافية كائنة بولاية بن عروس من الجمهورية التونسية كما أنها تسمية مصدر بالنسبة لتصنيف التسميات الفلاحية ودون تطبيق قانون 1999 الذي تولينا إستبعاده لتمام إلغائه كما سلف ذكره ويكون بذلك تسجيل العلامة بالمكونات الموافقة قانونا لتعريف الفصل 2 من حيث المبدأ.

وحيث لا خلاف بخصوص تنقيص الفصل 3 من قانون 2001 على أن العلامة تقدر بالصفة التمييزية التي تحظى بها وأنه لا تشكل الشارة أو التسمية صفة مميزة : ب- الشارات أو التسميات التي يمكن استعمالها للدلالة على الميزة من ميزات المنتج ... وخاصة النوع والجودة والكمية والمصدر الجغرافي والفترة الزمنية التي تم فيها إنتاج السلع أو تقديم الخدمة.

كما جاء بذات الفصل أن كل الشارات وأن كانت لم تكتسب الصبغة التمييزية يمكن أن تكتسب الصفة بالإستعمال بإستثناء الشارات المذكورة بالنقطة ج.

وحيث أتى الفصل بالإستثناء الذي يمكن أن تكون معه تسمية جغرافية فاقدة لعنصر أساسي وهو التمييز وبالتالي لا تصح أن تكون العلامة التجارية سارية ومعتمدة في القانون إلا أن القول بفقدان تسمية «مرناق» الواردة كمكون وجزء من علامة المعقب ضدها عنصر التمييز لا سند له فضلا عن أنها لا يمكن أن تكون علامة وصفية لأنها تشمل التميز والتمييز من حيث عدم علاقتها بطبيعة المنتج ونوعه ومن حيث عدم وصفها له على أن المشرع حصر الإستثناء في الفصل الثالث من قانون 2001 من منطلق طبيعة الصفة التمييزية التي يمكن أن ترتفع في القيمة أو تتحدر بمعنى أن تقوى أو تضعف بعدة عوامل منها ما نص عليه الفصل 3 من أن التمييز يعلو أو يضعف.

وحيث وإن كان مكون علامة المعقب ضدها مصدرا جغرافيا لتسمية منشأ أو منطقة جغرافية ذات مدلول إلا أنه ثبت من مؤيدات الملف أن الاستعمال للعلامة من المعقب ضدها كان دائما ومسترسلا في الزمن والثابت من الملف أن التسمية

نشأت واقعا وقانونا قبل صدور قانون سنة 2001 وأنه بقطع النظر عن تسمية الشركة المالكة التي تغيرت بحكم تغيير نظامها وبقطع النظر عن مكان تعليق منتوج المعقب ضدها لو هن التمسك بمسائل لا سند قانوني لها ولا علاقة لها بمادة العلامات وبما يجب إثارته من حيث القانون فقد ثبت استعمال المعقب ضدها منذ الخمسينات للعلامة وبذات التسمية الجغرافية مما يجعل الصفة التمييزية قد اكتسبت وإرتفعت بحكم الفصل الثالث من القانون الذي خول اعتبار مكون الشارة حاصلا على عنصر التمييز من الاستعمال ما عدى حالات الفقرة «ج» والتي لا تشمل المكون أو المصدر الجغرافي للشارة.

وحيث إن العبرة بالتمييز في القوانين العالمية المصادق على أغلبها من الجمهورية التونسية هي ان تكون الشارة قادرة على تحديد المنتج وتميزه عن أي منتج آخر من صنفه وأن عبارة مرناق قادرة على تمييز المنتج «الخمور» عن أي منتج آخر ولا يمكن أن تكون شارة وصفية لعدم تدليلها على المنتج ومكوناته وأن المعقبة لم تثبت إستعمالها التسمية «العلامة» قبل المعقبة كما لم يثبت التسجيل إلا بعد تمام حصول تسجيل علامة المعقب ضدها بالنظام القديم وبقانون 2001 الذي حجب كل تسجيل سابق ما عدا الإستعمال الذي هو أمر واقعي وحق إعتماده بخصوص المعقب ضدها التي إستأثرت بالشارة كتسمية منذ عدة سنوات وهو ما يجعل التمييز في الشارة على معنى أحكام الفصل الثالث قائما باعتباره أورد الإستثناء في بداية النص والإستثناء فيما يخص جواز إكتساب التمييز بالإستعمال مما يعيدنا قانونا للمبدأ الأصلي وهو أنه يجوز إعتماد التسمية الجغرافية كعلامة ما دام توفر التمييز وهو ما ذهبت إليه عدة محاكم من الإتحاد الأوروبي ما لم تكن العلامة مضللة للمصدر من حيث التسمية والإستغلال.

وحيث وفي ذات السياق فإن الفصل 3 من قانون 2001 لا يقرأ فيما يخص المصدر الجغرافي للعلامة بمعزل عن الفصل 4 من قانون 2001 الذي تم التعرض إليه صلب المطاعن وتمت قراءته قراءة لا تتوافق مع مبدأ الإباحة في الفصل 2 من القانون وقد جاء بالفصل الرابع من قانون 2001 أنها لا تعتمد شارة كعلامة أو كعنصر من علامة إذا كانت (...د) من شأنها أن تغالط العموم خاصة فيما يتعلق بطبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي حيث وفي تحليل وتسلسل مقرر من المشرع وفي قراءة للفصل الرابع من قانون

2001 يتضح أن المشرع جعل المنشأ أو المصدر الجغرافي «الدال على مكان معين» مكونا للعلامة بموجب الفصل الثاني من القانون كما أن اتفاقية الترييس أشارت في المواد 22 و 24 على أنه يحصى في عداد الدلالات التجارية ما يسمى بالإشارات الجغرافية وعرفتها الاتفاقية على أنها بيانات تعرف سلعة بمصدرها في إقليم دولة عضو أو في منطقة أو محلها في ذلك الإقليم كما شملت الاتفاقية مفهوم «الإشارة للمصدر» و«تسميات المنشأ» الواردة في اتفاقية باريس وتأسيسا على ما جاء باتفاقية الترييس فإن المشرع التونسي إعتبر الإشارات الجغرافية علامات تجارية بشرط ان تكون مميزة من حيث الصفة التمييزية لاستبعاد التدليل على عناصر المنتج التكوينية كما جاء بالفصل 4 أن الشارة لا تعتمد عندما تكون عبارة دالة على مصدر جغرافي من شأن إستعماله كتسمية مغالطة المستهلك.

وحيث إنه بالرجوع إلى علامة المعقب ضدها فإنها ترمز حتما لمنطقة جغرافية مصنفة كم منطقة فلاحية مختصة في إنتاج الخمور وتغطي عدة مناطق وتبعاً لذلك يكون إختيار المعقبة للتسمية كعنصر وجزء من مكون تسميتها وبالتحديد علامتها «Haut Mornag» مادام الإختيار يتوافق من حيث التسمية مع منطقة جغرافية تختص بإنتاج الخمور وبزراعة الكروم وغيرها من المعطيات المثبتة قانونا بالعودة إلى تسميات المنشأ منطقة مختصة في الكروم زراعة وتصنيعا وتسويقا مع إمتداد التسمية لمناطق أخرى تشمل المعقبة كذلك على أن العبرة عند الحديث عن ملكية العلامة التجارية وفق قانون 2001 بالتسجيل القانوني وبأسبقية التسجيل في الزمن بقطع النظر عن القول بعدم إلتواء المعقب ضدها للمنطقة الجغرافية لا إعتبار أن الثابت في الملف أن المعقب ضدها حافظت على إستعمال ذات التسمية منذ نشأة العلامة تحت ظل القانون القديم ويكون للمعقب ضدها حق في التفرد قانونا بملكية علامتها وفق تركيبها لأنها إستعملت علامة دأبت على إستعمالها كما أن العلامة الدالة على مصدر جغرافي لا تحوي التضليل لوجودها في منطقة خاصة بالكروم وبقطع النظر عن التقسيم اللاحق للتسميات ذات المصدر في قانون 1999 وما تدعم من قرارات لا وجه لإعتقادها وخاصة الفصل 16 من القانون المذكور بعد صدور قانون 2001 المعتمد قانونا من حيث صحة إتخاذ شارة جغرافية كعلامة وصحة تسجيل العلامة من حيث زمن التسجيل وتجديده طبق القانون.

وحيث لا خلاف في تمسك المعقبة بأن علامة المعقب ضدها غالطت العموم على معنى الفصل 4 من قانون 2001 باعتبار توليها تصنيع منتوجها خارج منطقة مرناق حسب اللصيقة للمنتوج وأن تعبئة المنتوج تكون حسب اللصيقة في منطقة جبل الجلود مما يجعلها ممنوعة من استعمال عبارة مرناق.

وحيث إنه وردا على ما إعتبرته المعقبة تضليلا موجبا لسقوط علامة المعقب ضدها والسماح لها بإستعمالها بدلا عنها في طلب لنقض القرار المؤسس على التقليد فإن تحديد المصدر الجغرافي كمكون لعلامة المعقب ضدها ينطلق من مقارنة بين المنتوج والمنطقة المختارة من حيث الطبيعة والنوع وأن إختيار المعقب ضدها لمقر صناعي مغاير للمنطقة الجغرافية لا يعد تضليلا فالعبرة ليس بمقر الشركة أو بمكان التعبئة والتسويق بل بإنطباق المنتج على المنطقة الجغرافية من حيث الذاكرة الإنسانية وتاريخ الإستعمال وشهرة المنطقة تاريخيا وأنه لا يدخل في مكونات التضليل مناط الفصل 4 من قانون 2001 تغيير المقر الإجتماعي أو إختيار مكان تغليب في تحديد المنطقة الجغرافية على أن المعقبة لم تقدم ما يثبت قيامها بإجراءات الإنتماء للمنطقة الجغرافية مرناق وفق قانون 1999 الذي تمسكت به حتى تتمسك بسقوط علامة المعقب ضدها لخروجها عن المنطقة الجغرافية مرناق.

وحيث لا خلاف في أن محكمة القانون ووفق إتجاهها لا يسعها الرد على مخالفة المحكمة الأصلية للفصل 16 من القانون عدد 57 لسنة 1999 لتمام إلغائه وحلول قانون 2001 محله بالنص.

عن المطاعن المتعلقة بضعف التعليل وتحريف الوقائع:

حيث تمسكت المعقبة بمخالفة المحكمة للقانون كما نعت على القرار ضعف التعليل المستنتج من سوء التقدير من المحكمة من حيث تبني رأي الخبير المنتدب الذي قرر التشابه بين علامتي الطرفين وحقق الخلط في الأذهان بخصوص منتجات الطرفين ومرد ذلك سقوط عبارة مرناق غير المحمية بقانون 2001 وبقاء مسألة الشكل والمظهر الخارجي لقارورة النبيذ التي ليست حكرا على منتج دون آخر على أنه وردا على هذا المطعن فلا بد من التذكير بأن علامة المعقب ضدها والتي تقرأ كاملة دون تقسيم أو تجزئة «أو مرناق» علامة تجارية

تامة الشروط توفرت فيها شروط الفصل 2 و 3 من قانون 2001 ولا ينطبق عليها التضييل الوارد تعريفه في الفصل 4 من ذات القانون مع التأكيد أن التسجيل كان للعلامة وكان بموجب تسجيل قانوني لدى معهد المواصفات والملكية الصناعية في 27 فيفري 2003 وأن النص المنطبق على العلامة هو قانون 2001 الملغي لكل النصوص المتعلقة بالمادة والسابقة له كما أن المعقبة كذلك تخضع لذات القانون وأن الأصل أن ردها لدعوى التقليد وتقديم طلباتها من جديد أمام هذه المحكمة لسقوط العلامة المملوكة من المعقب ضدها كان تأسيسا على قانون سنة 2001 إلا أنه لا يصح طلب إعتداد القانون المنطبق عند إيجاد نصوص لصالح الطرف المتمسك به ثم طلب إستبعاده ما لم تتوافق بعض فصوله مع ذات الطلب.

وحيث إن ما تم معانيته من تشابه وتقليد من شأنه إيقاع المستهلك العادي في الخلط بين منتوجات الطرفين كان على مستوى العبارات المكونة للشارة وعلى مستوى إختيار الخط وطريقة النسخ وعلى مستوى القارورة من حيث الشكل على أن القول بأن كل القوارير تحمل ذات الشكل قول فيه بعض الجدية إلا أنه كان مثلا وعلى سبيل المثال بإمكان المعقبة إختيار شكل مربع أو مستطيل وليس شكلا بيضويا وإن كانت كل الاشكال متقاربة على ان البحث عن نقاط التشابه ووفق ما جاء بالإختبار تقرأ على إجمالها ودون تفصيل وإلا وقعنا في المحذور وهو البحث عن نقاط الإختلاف في العمل الفني المؤدي حتما لنفي التشابه أو التطابق وتقدير إنتفاء التقليد أساس دعوى الحال على أنه على كل حال فإن التمييز الثابت في عبارة مرناق لا يجعلها مسقطه في المجال العام لما سبق ذكره بخصوص التمييز والإستعمال وثبوت التقليد شكلا وجوهرا مما تعين معه رد المطعن المتعلق بضعف التعليل لسلامته بخصوص واقعة التقليد مطلقا.

وحيث وبخصوص القول بتحريف المحكمة للوقائع المتأني من حصول تغييرات على عملية التسجيل لعلامة المعقب ضدها خلال فترات التسجيل وتقدير الخبر تسجيلها منذ سنة 1979 لا يمكن أن يؤثر قانونا على صحة العلامة التي سجلت طبق القانون في 27 فيفري 2003 ووفق إجراءات قانون العلامات سنة 2001 وهو القانون المنطبق وإن سبق التسجيل ليس لإقرينة على سبق الإستعمال من المعقب ضدها للعلامة والأصل في الأمور الرجوع لتاريخ

التسجيل القانوني طبق قانون سنة 2001 ولا عبرة بالتسجيلات السابقة ولا أهمية لملاحظات الخبير إلا بخصوص العلاقة التي كانت ربطت الشركتين ببعض عندما كانت في مجمع واحد بقطع النظر عن التسميات والاندماج أو الإنحلال وكان المطعن واهيا وتعين رده.

عن المطعن المتعلق بهضم حقوق الدفاع:

حيث إن قول المعقبة أن المعقب ضدها لها علامتها وتتعامل في الأسواق وفق محضر معاينة أدلت به بعلامة أخرى قول مردود لاعتبار أن العلامة التجارية التي تلزم المعقب ضدها يمكن أن تعدل من حيث الألوان أو بعض الإشكال على أن لا تفقد العلامة صبغتها القانونية وتسميتها وأن هذا المعطى ليس جوهريا ولا يؤسس لسقوط العلامة ولا يمكن أن ينهض سببا وجيها لرد دعوى التقليد الثابتة في مقارنة العلامات على شكلها المسجل قانونا.

وحيث تمسكت المعقبة ببطان إيداع علامة المعقب ضدها تحت عدد TNT / 2003 / 0151 سند القيام بدعوى التقليد لتعلق العلامة بشركة «ك.ق.» والحال أن الشهادة المقدمة للخبير المنتدب ثبت فيها أن الشهادة كانت لفائدة (U.C.C.V). كما تم التمسك بالخطأ على مستوى التصنيف في قائمة المنتجات بالمعهد بين الشهادة والإشهار الحاصل في مجلة الإشهار التابعة للمعهد في عددها 224 ذلك أنه رسمت بأصل التسجيل في الصنف 33 وتم الاشهار في الصنف 32.

وحيث إن الثابت في الملف أن المعقبة كانت شركة منتمية للمجمع الذي كونه سابقا المعقب ضدها وأن الشركة المعقب ضدها طرأ على نظامها القانوني عدة تغييرات وأنه من الطبيعي أن تكون التسجيلات السابقة لسنة 2003 لعدة مؤسسات حسب إختلاف أشكال المؤسسات التي تغيرت أنظمتها القانونية متغيرة بحكم الشكل الذي تتخذه قانونا كما أن المعقب ضدها لها نظام شركة تعاونية أساسية للخدمات الفلاحية وفق قانون 2005 / 10 / 18 وأن لها إسم تجاري «ك.ق.» على أن العبارة بالتسجيل القانون في 27 فيفري 2003 والذي تم من المعقبة وفق شهادة التسجيل المضافة بالملف.

وحيث إن مسألة التصنيف والوضع في صنف من الأصناف الخاصة بالمنتجات ووفق ترتيب وتحديد عالمي مصادق عليه من البلاد التونسية والمعمول به عند التسجيل في معهد المواصفات والملكية الصناعية تبقى مرجعيتها للمعهد وأنه على إفتراض وجود خطأ في الإشهار أو الإدراج فإنه يبقى قابلاً للتصحيح على أنه وبالرجوع لقانون 2001 فإن المشرع رتب حالات عدم إعتداد الشارة كعلامة للتعد على حقوق مكتسبة بالفصل الخامس منه ولم يتوفر بالفصل والقانون بند يسقط أو ينزع الصفة والتسمية عن العلامة لحصول خطأ في التصنيف بالمعهد كما أن سقوط العلامة الوارد بالقانون تطبيقاً لإتفاقية باريس في الفصل 19 منها وضع وشرع في حالة معينة وهي عدم إستخدام العلامة لمدة زمنية متواصلة ومحددة ولا تسقط العلامة لوجود خطأ مادي في التصنيف على فرض صحة القول بمقارنة التسجيل المدرج بالشهادة بالإشهار الذي لا تسهر عليه المعقب ضدها من الأساس.

وحيث كان القرار المطعون فيه معللاً من حيث تقدير وجود التقليد وتركيز عناصره وإقرار ما تضمن الإختبار من أعمال تقنية معتمدة وتعهدها بعد القول بصحة منهج المحكمة من حيث الجوهر ورد دعوى الإبطال المثارة من المعقبة لرد دعوى التقليد بالرد على الدفوعات القانونية المتعلقة بالتسمية الجغرافية والتميز مع القول ببلوغ محكمة الأصل الهدف المنشود من تقدير سليم لوجود التعد موضوع التقليد وتعين رد كل المطاعن ورفض التعقيب أصلاً».

5-5-2 الكف والمنع عن استعمال وإستغلال علامة تجارية- مدة إستغلال العلامة

قرار تعقيبي عدد 2020.20120 بتاريخ 16 جوان 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«عن المطعن المأخوذ من خرق الفصل 69 فقرة أولى من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001:

وحيث تضمنت مستندات التعقيب قراءة فقهية وقانونية لمسألة إجرائية وهي منهجية وطريقة تطبيق النصوص القانونية في توفر حقوق مكتسبة أو ناشئة في

ظل قانون قديم على وضعيات قانونية شملها قانون جديد وبالتحديد الخوض في مسائل تتعلق بالأثر المباشر للقانون وضرورة تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين.

وحيث لا خلاف بخصوص ثراء المادة المطروحة في مستندات التعقيب والتي تأسست في طرح مبدئي وأولي على إشكالية تطبيق القوانين في الزمان ذلك أن النزاع موضوع قضية الحال تعلق برفع المعقب ضدها المدعية في الأصل دعوى في الكف والمنع عن إستعمال وإستغلال علامة تجارية ترجع لها بالملكية ضد المعقبة فيما أستخدم على تسميته وفق القانون عدد 36 لسنة 2001 المتعلق بعلامات الصنع والتجارة والخدمات بقضايا التقليد.

وحيث دفعت المعقبة لدى محكمة الحكم المطعون فيه الذي قضى بتوفر أسباب الحكم وفق الطلب وذلك بتوفر التعد موضوع دعوى التقليد بدفع شكلي إجرائي وهو سقوط العلامة موضوع الحماية لبطلان تجديدها باعتبار أن الملكية في مادة «علامات الصنع والتجارة والفبريكات وفق القانون القديم» وكذلك القانون الجديد لسنة 2001 غير مطلقة وأن مالك العلامة الذي يوثق ملكيته بالتسجيل مطالب بالإيداع للعلامة ثم تجديد تسجيلها لحفظ حقه على أن هذا الإتجاه في التجديد الذي أيدته وشجعت عليه الإتفاقيات العالمية في مجال الملكية الفكرية ومنها إتفاقية باريس مرتبط بأجل. ذلك أن الغاية منه الحث على التطوير والتصنيع والخلق على اعتبار أن فرضية الكف عن إستعمال العلامة من مالكةا جائز وأنه في غياب شروط التجديد المحددة بأجل يمكن أن يتم الإستثمار بعلامات وإبتكارات عديدة يتوقف صاحبها عن إستغلالها أو تطويرها ويحرم القادر على إستغلالها من ذلك وهو مبدأ مكرس على مستوى العلامات وخاصة براءة الإختراع المنظمة بقانون سنة 2000 والتي أنتهج بخصوصها المشرع التونسي وأغلب البلدان الماسكة لتشريع في المجال لمدة إستغلال قصوى لفسح المجال للخلق والإبتكار للغير.

وحيث أعاب نائب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الفصل 69 فقرة أولى جملة أولى من قانون 2001 المتعلق بعلامات الصنع والتجارة والخدمات، ذلك أن المعقب ضدها كانت قد أدعت ملكيتها لعلامة تجارية تم تقليدها بذكرها بفعل المعقبة ووفق مؤيدات من ذلك محضر معاينة في الغرض ... وكان رد

المعقبة أن تلك العلامة لم تعد تتمتع بالحماية القانونية لعدم تجديد التسجيل في الأجل مما يصيرها وفق وصف من هذه المحكمة قد سقطت أو إنتهت فترة حمايتها المرتبطة بأجل أمر وبالتالي يكون رد دعوى التقليد معطلا.

وحيث وخلافا لموقف نائب المعقب ضدها ولرد محكمة الحكم المطعون فيه فإن الدفع ببطلان التسجيل أو عدم التجديد في الآجال وفق القانون من الدفوعات الجوهرية التي يمكن الاحتجاج بها لرد دعوى أصلية في التقليد ذلك أن العلامة تكتسب قانونا بالتسجيل الخاضع لشروط شكلية منها الإدارية ومنها خلاص الرسوم وموجبات إيداع العلامة وفق القانون، وأن إنتهاء أمد قيام قرينة التسجيل يرتب قانونا أثرا قانونيا وهو بقاء العلامة دون تسجيل ذلك أن الحماية ليست مطلقة ولا وجه قانونا للقيام بدعوى في رد التقليد إلا بعد التحقق من حصول التسجيل وامتداده في الزمن والالتزام بالتجديد وفق ما يشترطه القانون ولا حاجة إلى حكم قضائي بالبطلان باعتبار أن المحكمة المختصة وفق قانون 2001 هي ذات النظر وللمقام ضده الدفع بعدم توفر شروط الملك للعلامة لمخالفة الموجبات الضرورية لقيامها وإكتساب الحق منها.

وحيث إن الطرح المقدم من نائب الطاعنة كان قد تأسس على قراءة للفصل 69 من قانون 2001 «جملة أولى» والذي ورد بها «تبقى العلامات المسجلة طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 3 جوان 1889 والمتعلق بعلامات الفبريكات وعلامات المحلات التجارية والنصوص المتممة والمنقحة له سارية المفعول دون اعتبار لإلغائه».

وحيث كان التمشي من المعقبة سليما لما إعتبرت أن الفصل جعل العلامات التي أحرزت شروط صحتها في ظل القانون القديم صحيحة وهو ما تم التصريح به صلب الفصل وهو ما يتماشى مع مبدأ عدم رجعية القوانين ذلك أن من إكتسب حقا في ظل قانون قديم يبقى محافظا عليه ويتمتع بما ضمن به سواء كان ذلك لفائده أو دون ذلك إلا ما إستثناه المشرع صراحة من ذلك أن من النصوص ما يدخل منافع لم تكن موضوع طرح في القانون القديم وينص المشرع على تطبيقها على من نشأ لهم الحق في ظل قانون قديم لمصلحة يقدرها ولتحقيق جانب من العدل المرجو في توحيد حقوق المتفعين بالقانون من ذلك أن التخفيف الضريبي

أو الديواني في الضرائب والرسوم ذات الصبغة المالية عادة ما يضمن بنص إحداثه إمكانية تطبيقه على وضعيات واقعية وقانونية سابقة لصدوره، إلا أنه بالتمعن في الفصل 69 من قانون 2001 فإنه لا وجود لاستثناء بخصوص الحالات السابقة لصدوره كما أن المشرع نص صراحة دون الحاجة إلى الاستعانة بمدارس الشرح والتأويل الفقهية أن العلامات المسجلة طبقاً للأمر العلي الذي كان يحكم المادة في تونس تبقى سارية المفعول أي أنها تبقى حاملة لشروط صحتها وانعقادها وفق النظام القانوني الذي نشأت فيه.

وحيث إن القول أن الفصل 69 من قانون 2001 أرسى قاعدة قانونية لها مبنى يستحق التدقيق والشرح قول مردود ذلك أن الطاعنة تطرح بقدر من الصحة تقدير المشرع إبقاء العلامة سارية على منهج القانون القديم الذي نشأت فيه بصريح النص ثم تتراجع فتقدر أن نية المشرع إتجهت نحو التفرقة بين شروط صحة العلامة وآثار إكتسابها.

وحيث إن القول أن الحكم المطعون فيه قد وقع في الخطأ لما أعرض عن التمييز بين نشأة الحق والأثر الممتد في الزمن قول مردود ذلك أن المحكمة وبإقرار الطاعنة أصابت لما إعتبرت أن ملكية المعقب ضدها للعلامة كانت بمجرد تسجيلها لدى الإدارة الحكومية المختصة وفي ظل القانون القديم «الأمر العلي» الذي نسخ بقانون 2001 إلا أن قول نائب الطاعنة أن العلامة نشأت صحيحة ولكنها غير خاضعة للقانون القديم بخصوص مدة إكتسابها في غير طريقه ذلك أن العلامة في تقدير الطاعنة ترتب آثاراً في الزمن وتلك الآثار لا يمكن أن تخضع للقانون القديم وهو قول مردود ويتنافى مع النص والمغزى منه ويعد من قبيل التأويل المغير للنص والبالغ مرتبة محوه ذلك لسائل أن يتساءل كيف يشرع لبقاء العلامة على حالها في ظل القانون القديم ويقدر المشرع من ناحية أخرى أن القانون الجديد هو الذي ينطبق عليها بمقولة أنها مستمرة في الزمن، وكأن العلامة كحق من الحقوق مفترض فيها الجمود وأن تقتصر النشأة على تسجيل إداري يأتي القانون المعدل لمدته ليطبق وينفذ الأجل الجديد والشروط الإجرائية والإدارية عليه في نفي لمبدأ عدم رجعية القوانين، الذي لسنا في حاجة إلى الرجوع إلى شروطه وإلى اتخاذ مناهج التأويل والتعديل بما يتناسب مع المبدأ وما يكرسه من مساواة، وذلك لاعتبار بسيط ومتوفر في الفصل 69 الذي جعل العلامة الناشئة

في ظل القانون القديم سارية وقفه دون تفرقة بين النشأة أو الإيداع وبين شروط سريان العلامة في الزمن ذلك أن التفرقة المذكورة من إحداث الطاعنة وأن التأويل المعتمد منها لا وجه لقبوله لمخالفته لقواعد سريان القوانين ولمعارضة ذلك الطرح المبادئ الفقهية التي ضمنتها في مستنداتها ثم تنكرت لها.

وحيث إن التفرقة الحاصلة لحقوق ملكية محددة في الزمن وأخرى غير محددة قول مردود ذلك أن المشرع تحدث عن العلامة مطلقاً وهي حاملة لشروط صحتها ما دامت توفرت فيها عند النشأة ولا عبرة بالتأويل فيما هو ثابت نصاً.

وحيث أصاب الحكم موضوع الطعن لما إعتبر أن مطلب التسجيل المتعلق بعلامة المعقب ضدها كان مستوفياً لشروطه الشكلية والموضوعية كما أصاب لما حسم النزاع حول الدفع بالبطلان ليعتبر أن العلامة خاضعة للقانون المذكور «القديم» في خصوص مدة إكتسابها لنشأتها في ظله وتعتبر هذه المحكمة أن التعبير الأخير المقتبس عن المحكمة قد أحسن التفسير والتعليل ذلك أن العلامة تنشأ في ظل قانون وترتب آثارها في ظله وتكتسب مدتها أي قيامها وصيرورة بقائها منه وفي إطاره ولا يمكن الفصل بين عملية التسجيل وعملية التجديد لغاية إسقاط الصلوحية والإستمرار الزمني للعلامة.

وحيث إن القول أن العلامة المملوكة من المعقب ضدها نشأت في أحضان الأمر العلي لسنة 1889 وأنها مازالت منتجة لآثارها في ظل إصدار القانون الجديد عدد 36 لسنة 2001 قول مردود ذلك أن العبرة بنشأة الحق وإكتمال شروط تحقيق الملكية وأن لا ضرر ولا ضرار من صدور قانون جديد يحسن الوضع القانوني إن تحقق فيمنحه لصاحب الحق لكن بشرط التنقيص الصريح كما سبق القول أن ما تعلق بالآثار يخضع للقانون الجديد وبشرط عدم المساس بالحق كيفما إكتسب وأن طلب تطبيق حكم بقاء وسريان العلامة بالقانون الجديد أقل من حيث المدة من القانون القديم مما يصير تطبيقه على فرض التصريح بذلك نصاً غير عادل بالنسبة للوضعيات الجارية والمستقرة مما ينفي توفر شروط التنفيذ السليم لسريان القوانين المرغوب تطبيقه وفق موجبات الفقه والقانون.

وحيث لا خلاف بخصوص وضع القانون الجديد قيماً جديداً على الحماية المخولة للعلامة وعدل مدة الحماية من 15 سنة إلى 10 سنوات إلا أن ذلك الأثر

والتعديل لا يسري إلا على من سجل علامته بداية من دخول قانون 17 أبريل 2001 حيز النفاذ تطبيقاً للمفعول المباشر والإجرائي السليم لتطبيق القوانين وسريانها في الزمن وأن الحد أو القيد المتحدث عنه لا يعني إلا الوضعيات اللاحقة في الزمن لصدور القانون الجديد ولا عبرة في النزاع بسريان القانون الجديد لعدم توفر شروط ذلك فضلاً على أن إيداع العلامة وتسجيلها لا يدخل في خانة الوضعيات الممتدة في الزمن من صنف العقود وما شابهها ولا مناص من تطبيق الأثر الفوري لقانون 2001 لكن على الوضعيات التي نشأت في ظله في قراءة عكسية لمضمون ومجمل فقرات الفصل 69 من القانون المذكور.

وحيث وردا على قول الطاعنة أن الأثر المباشر للقانون الجديد حري بالإعتماد لتكريس القانون سقوط العلامة من أجل عدم الإستعمال فإن لا علاقة للسقوط لعدم الإستعمال وشروطه بإنتهاء الحق في الحماية لعدم التجديد أو إحترام أجل التجديد وفق النص المنطبق. ذلك أن المسألة تعلقت بحق التجديد الذي هو من حقوق المعقب ضدها على العلامة وصح قول المحكمة أن المعقب ضدها تنتفع بأجل القانون القديم لنشأة العلامة في ظله وأنه بعملية حسابية بسيطة فإن تسجيل العلامة المملوكة للمعقب ضدها وفق تضمينها كان سنة 1993 ويكون لها الأجل الممتد لإعادة التسجيل سنة 2008 وهي السنة التي تم فيها إعادة التسجيل أي على إمتداد خمسة عشر سنة في ظل القانون القديم وكان مطلب التجديد سليماً ومطابقاً للنص القديم ، كما كان الدفع ببطالان العلامة غير ذي موضوع ذلك أن المقارنة المضمنة في المستندات بين قانون 2001 و 2000 المتعلق ببراءة الاختراع لا تستقيم لإختلاف النصوص بخصوص سريان القانون الجديد ولخصوصية البراءة باعتبار أنها تسقط تماماً في الأجل المحدد بالقانون الجديد على أن القراءة الحاصلة للقانون لا تنم عن خرق لمبدأ عدم رجعية القانون وكانت الحماية للحقوق المكتسبة هي العنوان الظاهر على أن العبارة بمضمون الفصل 69 من قانون 2001 الذي تضمن في كل فقراته دون توخي منهجية الفصل بينها تكريس عدم رجعية القانون الجديد وعدم تطبيق أثره المباشر على الحالات السابقة له رغم إلغاء الأمر العلي مما يغني عن الخوض في أي قانون وطني أو مقارن لا يحمل مضمون الفصل 69 المذكور وتعين رد المطعن بعناصره.

عن المطاعن المأخوذة من خرق الفصول 335 ماع والفصول 144، 146، 147 م م ت لإتحاد القول فيها:

حيث تمسك نائب المعقبة بمخالفة المحكمة للفصل 335 ماع على اعتبار أن إجراءات إعادة تسجيل علامة مسجلة سابقا تستوجب الخضوع إلى شكليات يفترض فيها البت من جديد في مطلب التسجيل مما يتعين النظر فيها كما لو كانت علامة جديدة إلا أن المطعن كما حرر تضمن في طياته ردا مخالفا للطرح المقدم فقول المعقبة أن إتباع إجراءات التسجيل عند التجديد كأنه تسجيل لعلامة جديدة قول إفترضت فيه القياس مستندة إلى الإجراءات الشكلية التي تفرضها طبيعة العلامة الخاضعة لنظام قانوني شكلي وإداري وفق موجبات القانون الجديد وأن المشرع في الفصل 69 من قانون 2001 لم يعتبر أن تجديد العلامة من قبيل التسجيل الجديد ذلك أن كل علامة تحرز على شرعيتها من التسجيل الأول وأن إعادة التسجيل المحدد في الزمن لا يعدو أن يكون شكلية لحفظ الحق وتدعيم الحماية ورفعها على من يعرض عن مواصلة العمل بها أو طلب الحماية من جديد، ذلك أن لا تأثير لمسألة شكلية التجديد على النزاع الحالي باعتبار أنه ماض وفق الفصل ووفق مقتضيات القانون الذي نشأت فيه علامة المعقبة ضدها مما تعين معه رد المطعن.

وحيث وبخصوص الدفع المتعلق بخرق الفصول 144 م م ت وما بعدها فإن الدعوى كما تم تحريرها تم النظر فيها إستئنافيا من محكمة الحكم المطعون فيه بعد تمام التحقق من سلامة إجراءات الإستئناف وأن القول أن ليس لمحكمة الدرجة الثانية عند نقل الدعوى برمتها إليها الزيادة فيها أو النقصان قول سديد بحكم المفعول الانتقالي للإستئناف، إلا أن ذلك لا يحول دون تسليط المحكمة رقابتها على عمل المحكمة والبت في النزاع كما طرح في الطور الأول وتغيير الرأي القانوني ذلك أنه وإن تفادى نائب المعقبة الخوض في جوهر النزاع فإن المحكمة ومن خلال محضر المعاينة والمؤيدات المقدمة لها والمشكلة لوقائع التقليد أذنت بالاختبار للتحقق من حصول التقليد من عدمه من أهل الخبرة وأن في الاستقراء والبحث في الملف إجتهد محمود من المحكمة ولا يمكن اعتباره تغييرا لوقائع الملف أو تعديلا لطلبات الأطراف ذلك أن محكمة البداية التي تم الرجوع عن صواب عن حكمها بعدم سماع الدعوى قد ردت في حيشة ضعيفة المبني عن واقعة التقليد ودون العودة إلى محضر المعاينة ومؤيدات الملف

«نماذج وصور ورسوم» تحدد التشابه بين منتجات العلامتين أن العنصر أو الشارة التصويرية المميزة لعلامة المعقب ضدها الممثلة في شخصية «الأرنب» لا تعدو أن تكون شخصية من الصور المتحركة التي يتعلق بها الأطفال نافية التشابه بين العلامتين مستدلة في ذلك على نقاط الاختلاف بين الشارتين التصويرية والأصل أن التفرقة أو المقارنة تتم برصد نقاط التشابه، ذلك أنه فضلا عن تقدير الاختبار المأذون به التقليد وفق المقارنات المضمنة به فإن القاضي المختص في المادة يمكن له بمجرد الإطلاع على العنصر الجوهري للشارة التصويرية معاينة التشابه المحيل إلى التقليد وأن القول أن المحكمة تجاوزت ما أنيط بعهدتها من نظر وفصل في النزاع قول مردود ذلك أنها عاينت مبدئيا التشابه بين العلامتين وقررت إجراء الإختبار الذي حقق ذلك فقضت على ضوئه بتوفر التقليد والمنع والكف عن الإستعمال وآثاره وفق موجبات القانون الجديد في الفصول 22 و23 منه وفق الطلب، على أن الخوض في وسائل عمل الخبرة والإعتراض على إعتداد مضمون المحاضر والعينات المعتمدة كلها عناصر موضوعية تدخل في اجتهاد محكمة الأصل وأنه لم يثبت تحريف الإختبار للدعوى أو إعتداد مؤيدات مغايرة لما أضيف بالملف كما أن العبرة في التقدير عند توفر التقليد ليس بحجم ونوع اللعب والنماذج بقدر توفر شروط التقليد وحصول التعد الذي يمكن أن يستمر في الزمن ذلك أن المشرع أجاز المعاينات والإختبارات في المادة لمعاينة جنحة التقليد وذلك قبل القيام بدعاوى جزائية ومدنية أصلية وأخرى استعجالية في المجال وكانت المطاعن بخصوص الزيادة في الدعوى وتعديلها غير ذي موضوع وكان الحكم معللا سواء على مستوى الرد على مسألة الحماية لعلامة المعقب ضدها أو عند تقدير ثبوت التقليد وتدعيم ذلك برأي فني لم يقع دحضه علميا مما تعين معه رد المطاعن ورفض التعقيب أصلا.

5-6 إجراءات جماعية.

5-6-1 الطبيعة القانونية للتسوية-نفاذ القانون الجديد-التوقف عن الدفع- سحب الفلسة.

قرار تعقيبي عدد 2019.82663- بتاريخ 12 فيفري 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة

نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن المطعن المأخوذ من طبيعة الإجراءات الجماعية والقانون المنطبق على النزاع:

1/ بخصوص طبيعة الاجراءات الحمائية

حيث أنه من الثابت أن لقانون الإجراءات الجماعية صبغة خاصة من خلال تناوله للمؤسسة التي تمر بصعوبات إقتصادية ومن خلال الغاية والنهاية التي يرمي إليها فهي ليست فصل خصومة بقدر ما هي إجراءات إنقاذ أن توفرت شروطها . ويؤدي ذلك إلى القول بأن البت في مطالب التسوية لا يمثل خصومة قضائية بقدر ما هو إجراء يستهدف الإحاطة بالمؤسسة وإخراجها من الصعوبات التي تعيشها بمساعدة دائئيتها وحرفائها والعاملين بها وبالتالي فهو لا يعد منازعة بالمعنى التقليدي للكلمة « Il s'agit d'une procedure et non pas d'un procès » وتكون فيه وظيفة القاضي بذلك غير وظيفته التقليدية لأنه لا يصدر أحكاما في خصومة قضائية ويفصل فيها لهذا الطرف أو ذاك بل أنه يضع حلولاً إقتصادية ومالية ناجعة وقابلة للتطبيق تخرج المؤسسة من وضعها الإقتصادي المتأزم إلا إذا لم تتوفر في المؤسسة المعنية بالإنقاذ عناصر القوة ومعايير إستئناف نشاطها بصفة عادية فتكون في هذه الوضعية غير قابلة للإنقاذ ومنه يتم التصريح بتفليسها ولذلك خولت أحكام الإجراءات الجماعية التصريح بتفليس المؤسسة كلما تعذرت حلول وسبل إنقاذها فهو خيار متروك من المشرع للقاضي بحسب التشخيص المادي والمالي للمؤسسة ومدى قدرتها على تجاوز صعوباتها المالية والإقتصادية.

وحيث أن للقاضي مثلما أشير إليه دور مهم في تقرير مآل المؤسسة في سواء بوضع برنامج إنقاذها أو التصريح بتفليسها وأن الواجب المحمول عليه في السعي في الإنقاذ والنهوض بالمؤسسة لا يحول دون التصريح بعدم وجود أية إمكانية للإنقاذ ببرنامج الإنقاذ ليس فكرة فقط وإنما هو حلول قابلة للتحقيق أي أنها حلول واقعية ذات جدوى Efficaces et faisables وعلى هذا الأساس فإن ما تضمنته المطاعن من عدم وجود السعي في الإنقاذ ومخالفة طبيعة قانون

الإجراءات الجماعية غير وجيه. فالمفروض أن المدين يقدم من جهته الحلول الممكنة ولا يترك المسألة للقاضي والمتصرف وهو ما لم يبرزه الطاعن أمام محكمة الحكم المطعون فيه بل أنه صرح عند التحرير عليه بأنه متوقف عن النشاط ولا يمكنه احياء نشاط المؤسسة من جديد لما يتطلبه من مال لتنشيط الدورة الاقتصادية وإصلاح آلات ومعدات العمل.

وحيث تضمن المطعن أيضا بأن المحكمة أخطأت في تحديد القانون الواجب تطبيقه على ملف التسوية محل نظرها فهي طبقت القانون عدد 34 لسنة 1995 والحال أنه كان من الواجب تطبيق القانون عدجد 36 لسنة 2016 تطبيقا للفصل 15 من الأحكام الإنتقالية للقانون عدد 36 لسنة 2016.

2/ بخصوص القانون المنطبق على وضعية المؤمنة الطاعنة

حيث ينص الفصل 15 من الأحكام الإنتقالية للقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016 أنه « تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية غير أنه يتواصل العمل بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية على :

- المؤسسة التي إنطلقت بشأنها إجراءات التسوية الرضائية إلى حين إستكمالها على أن تخضع إجراءات التسوية القضائية أو التفليس عند الإقتضاء لأحكام هذا القانون .

- المؤسسة التي إفتتحت في شأنها لإجراءات التسوية القضائية إلى حين إستكمالها على أن تخضع إجراءات التفليس عند الإقتضاء لأحكام هذا القانون .

- المؤسسة التي أحييت على التفليس قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ » .

وحيث أن الفصل 15 المذكور هو من الأحكام الإنتقالية ويعالج وضعية تنازعية إجرائية ويسعى من خلاله المشرع إلى المحافظة على وحدة النزاع وهو ما يستدعي حل مشكل التنازع بتدخل من القضاء .

وحيث تضمن الفصل 15 أعلاه المبدأ في الأثر الفوري للقانون فنص على أنه تلغى الأحكام السابقة له بما يعني التطبيق الفوري للقانون الجديد ولكن المشرع

في نفس الفصل أقر للأثر الفوري إستثناء وهو بقاء القانون القديم نفاذا في الوضعية التي تخص المؤسسة التي إنطلقت بشأنها إجراءات التسوية الرضائية إلى حين إستكمالها والمؤسسة التي أفتتحت في شأنها إجراءات التسوية القضائية إلى حين إستكمالها والمؤسسة التي أحيلت على التفليس قبل دخول القانون الجديد (قانون 2016) حيز التنفيذ ويتضح من ذلك أن الإجراءات التي إنطلقت في ظل القانون القديم تظل خاضعة له وتتواصل وفقه إلى حين تمامها وهو ما عبر عنه المشرع بإستكمالها أي الفصل فيها واستنفاذ المحكمة ولايتها فيها .

وحيث أن المشرع لم يتوقف عند هذا الحد بالفصل 15 المذكور فهو زيادة عن ذلك يستدرك للعودة لتطبيق القانون الجديد ذلك أن الإجراءات التي انطلقت قبل القانون الجديد تظل خاضعة له إلى حين إستكمالها أي أنها تنتهي في نفس الإجراءات التي إنطلقت على ضوءها .

وأما إذا تم التحول إلى نظام آخر أي من التسوية الرضائية إلى التسوية القضائية أو التفليس أو من التسوية القضائية إلى التفليس فإنه يتم تطبيق القانون الجديد لأن المشرع خول الإبقاء على القانون القديم إلى حين إستكمال الإجراءات بما يعني تمامه وإستعمل الإستثناء بكلمة « على » وهو إستدراك منه في العودة إلى الأصل وهو التطبيق الفوري للقانون الجديد بما يعني أنه يتم تطبيق القانون الجديد إذا تم تغيير نظام الإجراءات وتغير الوضع القانوني وتم تحويل إلى نظام جديد في التسوية مغاير عن الذي إنطلقت على ضوءه وفي ذهنه يعتبر المشرع أن الإجراءات الجديدة يخضع للقانون الجديد لأنه أصلح ويكفل سيرا أفضل للقضاء .

وحيث أن محكمة البداية تعهدت بالنظر في مطلب التسوية القضائية في ظل القانون القديم ذلك أن المطلب قدم لها في 18 / 5 / 2010 وإعتبرت أن الوضعية ليست في نظام الإنقاذ وإنما هي في نظام التفليس بناء على الوضعية الميؤوس منها التي تعيشها المؤسسة وأصدرت حكمها في ذلك يوم 4 / 7 / 2017 أي في زمن قد دخل فيه القانون الجديد حيز التنفيذ وسايرتها في ذلك محكمة القرار المطعون فيه التي أستندت في حكمها على أحكام المجلة التجارية بالفصل 596 وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 والحال أنه توجد وضعية إجرائية تنازعية تقتضي على أساسها الفصل 15 من الأحكام الإنتقالية تطبيق القانون الجديد

لأنه حصل تحول في النظام فمن تسوية قضائية إلى تفليس بما يوجب تطبيق الإستدراك الذي تبناه المشرع بالفصل 15 المذكور وهو التطبيق الفوري للقانون الجديد. وتكون محكمة القرار المطعون فيه وحينما لم تفعل ذلك قد أساءت تحديد القانون الواجب تطبيقه على ملف التسوية محل نظرها مما يستوجب نقض قرارها من هذه الناحية.

*** عن المطعن الثاني المأخوذ من تطبيق الفصل 3 من قانون 17 افريل 1995 :**

حيث تضمن المطعن أن مطلب التسوية تم تقديمه في سنة 2010 وقد أتضح للمتصرف القضائي أن الشركة متوقفة عن الدفع منذ سنة 2002 وكان من المفروض أن يتم رفض الطلب بناء على توقف النشاط إلا لأنه خلافا لذلك فطبق نظام الإنقاذ يهدف إلى إسترجاع توازن النشاط الإقتصادي وأنه عندما يتضح أن النشاط متوقف كما هو في النزاع الحالي فإنه لا يتم التصريح برفض المطلب مثلما ورد بالمطعن لأن إجراءات الإنقاذ ليست خصومة قضائية بمعناها التقليدي بل هي إجراءات تتسم ببعض الخصائص التي تميزها عن الخصومات التقليدية ذلك أنها ليست دعوى تؤول إلى الرفض إذا لم تتوفر شروطها ولا تخضع لقواعد النزاع المدني العادي فمطلب التسوية ليس خصومة وليس دعوى ملك لأطرافها فلا يتحكم الأطراف في سير المطلب والفصل فيه فإن كان بإمكان المدين تقديم دعوى ملك لأطرافها فلا يتحكم الأطراف في سير المطلب والفصل فيه فإن كان بإمكان المدين تقديم طلبه إلى القضاء أن تعلق الأمر بتسوية قضائية أو بتسوية رضائية فإنه لا يحكم سيره بل تتداخل الأطراف القضائية والإدارية ومساعدتي القضاء للتداول سيره وتحديد مآله خلافا لما تقتضيه القواعد الإجرائية المدنية من أن الأطراف يملكون الخصومة المدنية وسيطرون على النزاع ولهم تحديد وجهته وتمتد صلاحيات القاضي في تقرير مآل المطلب بحسب وجود إمكانية للإنقاذ وإلا فالتصريح بالتفليس وهو مقتضى قانون الإجراءات الجماعية الذي يعطي للقاضي صلاحيات التصريح بالفلسة ما لم تتوفر صيغة الإنقاذ ولا يمكنه الوقوف على رفض المطلب فقط إذ لا بد من تقرير مآل للمطلب إما التسوية أو التفليس وليس في الفصل 3 من قانون 1995 ما يخالف محكمة الحكم المطعون فيه وقد أحسنت تطبيق القانون القديم لأن الطلب منذ منطلقه في التفليس وصرحت به بما يعني أنه لم يحصل تغيير في نظام الإنقاذ يوجب تطبيق القانون الجديد.

*عن المطعين الثالث والخامس المأخوذ من الخطأ في تطبيق الفصل 19
وخرق الفصل 18 من قانون 17 افريل 1995:

حيث ينسب الطاعنان للحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتحقق من تعذر
إستخلاص الدائن دينه طبق التبعات الفردية كما لم يتضمن القرار المطعون فيه
ما يفيد التوقف عن الدفع.

وحيث إن طلب الدائن فتح إجراءات التسوية القضائية ضد مدينه يتوقف
على إثبات عدم الخلاص والتوقف عن الدفع وأن إشتراط إثبات التوقف عن
الدفع، وتحديد تاريخه ، يظل أمرا صعبا بالنسبة للدائن. ولذلك يسرّ عليه المشرع
الإجراءات في طلب التسوية فلم يخضعه لموجبات الإدلاء بكل المعطيات
والمؤيدات المشروطة لقبول مطلب التسوية وهو مطالب بتقديم ما يفيد أنه تعذر
عليه إستخلاص دينه بالطرق الفردية وهو ما يوفر لديه الصفة في تقديم مطلب
التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة الابتدائية وهي مسألة منطقية لأن الدائن
يظل اجنبيا عن المؤسسة . ولذلك فهو لا يطالب الا بإثبات حلول دينه وتعذر
إستخلاصه بطرق التنفيذ الفردية مع بيان سبب ذلك ويمكنه أن يستند إلى جميع
وسائل الإثبات المتاحة لأن الأمر يتعلق بإثبات واقعة قانونية وعليه إذا أثبت
الدائن تعذر الإستخلاص يمكن اعفاؤه من إثبات التوقف عن الدفع بقلب عبء
الإثبات على المدين عليه إثبات أنه لم يتوقف عن الدفع ويمكنه أن يفني الدين
موضوع الطلب وليس على الدائن اثبات التوقف عن الدفع فهذا الاخير لا يطلب
إلا بعدم التوصل إلى التنفيذ وفق الطرق الفردية.

وحيث وعلى هذا الأساس فان المحكمة هي التي تحدد التوقف عن الدفع
وتحدد تاريخه وفي دعوى الحال فقد بينت المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع
والحالة المالية التي تم الوصول إليها فقد بينت المحكمة ان المؤسسة الطاعنة
لم تعد لها اية امكانية لمواصلة النشاط وغير قادرة على الخلاص بما يعني انها
في حالة توقف كلي عن الدفع وقد وصلت إلى الوضعية الميؤوس منها التي لا
ينطبق الفصل 18 من قانون الانقاذ لسنة 1995 في ان ما لديها من موجودات
ايجابية يمكن ان تسمح لها بخلاص الديون مقسطة وهي وضعية عدم القدرة على
الخلاص وفق نص الفصل 18 من قانون انقاذ المؤسسات الذي بين أنه « تعد

متوقفة عن الدفع على معنى هذا القانون على وجه الخصوص كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل اجلها بما هو موجود لديها من سيولة ومن موجودات قابلة للتصرف على المدى القصير». وهي وضعية الطاعنة وفق ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وان الدفع بخلاص البعض من الدين لا يفيد خلافا لما ورد بالمطعن عدم توقف عن الدفع لان الدين موضوع فتح التسوية هو من الديون القديمة أي السابقة لانطلاق اجراءات التسوية والتي يجب خلاصها دون الديون الجارية بعد التسوية أو الجديدة.

وحيث خلافا أيضا لما ورد بالمطاعن فالتوقف عن الدفع في اطار التسوية يختلف عن اطار التفليس فهو في اطار التسوية لا يعني سوى الصعوبة المالية الدائمة التي تتطلب علاجا ، وهي غير صورة الحال بينما يعني في اطار التفليس الوضع الميؤوس منه الذي لا يمكن علاجه ، ويؤول بالضرورة إلى اقضاء التاجر من الحياة الاقتصادية لان الصعوبات متقدمة ويصعب فيها الاستجابة لطلب التسوية وفق قانون انقاذ المؤسسات لانعدام امكانية الانقاذ واتجه لذلك رد المطاعن المثارة لعدم وجاهتها.

*** عن المطعنين الرابع والسادس المأخوذ من عدم القيام بالاشهارات القانونية وخرق أحكام الفصلين 25 و 22 من قانون الانقاذ عدد 34 لسنة 1995 :**

حيث خلافا لما تضمنه المطعنين فان الاشهارات القانونية قد تمت وقد استوفت أيضا فترة المراقبة اعمالها وان عدم احترام الاجل في كلتا الحالتين لا يترتب عنه بطلان اجراءات التسوية فهي آجال استنهازية ترمي إلى حث كل الاطراف المتداولة على الاسراع في اجراءات الانقاذ تفاديا لتزايد المفعول السلبي للزمن للمدين دور مهم في التقيّد بها عندما يتعامل ايجابيا مع مطلب التسوية ويساهم في اعداد برنامج الانقاذ ليتفادى التأثير السلبي لطول الاجراءات على وضعية المؤسسة.

وحيث لم يتضمن المطعنين في الحالتين مجال خرق القانون وموجبات اثارته على معنى الفصل 175 من م م م ت ويتجه بذلك ردهما.

*** عن المطعن السابع المأخوذ من خرق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 34 لسنة 1995 :**

حيث وخلافا لما جاء بهذا المطعن فان المتصرف القضائي كان عرض برنامج الانقاذ وتولى على ضوء ذلك القاضي المراقب اعداد تقرير مؤرخ في 28 نوفمبر 2016 انتهى فيه إلى ان وضعية الشركة لا تسمح بانقاذها مقترحا تفليسها وبالتالي فان الاجراءات قد كانت سليمة من هاته الوجهة ولا شائبة تشوبها فقد ظل هيكل بهامه المناطة به واتجه لذلك ردّ المطعن المثار لعدم وجاهته.

* عن المطاعن الماخوذة من خرق القواعد المتعلقة بالتفليس والفصلين 475 و478 من المجلة التجارية:

حيث تضمنت المطاعن ان محكمة الأصل لم تبرز استحالة الانقاذ وان الطاعنة في وضع ميؤوس منه ودون سماع ممثل النيابة العمومية الا انه خلافا لذلك فقد تضمن القرار المطعون فيه انه بالتحجير على ممثل الشركة الطاعن الثاني تبين ان الشركة المدينة (المعقبة الأولى) متوقفة عن النشاط منذ شهر مارس 2005 وان هناك استحالة مطلقة لاعادة ادماجها في الدورة الاقتصادية. كما بينت المحكمة انه تمت مكاتبة لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي ابدت رايها بوجاهة التصريح بتفليس المؤسسة لانعدام امكانية الانقاذ وقد كانت المحكمة على صواب في ذلك فبرنامج الانقاذ ليس تصورا ذهنيا وفكريا بل هو دراسة موضوعية وبرنامج واقعي وعملي فالقاضي على أساسه يضع الحلول التي تستقر معها وضعية المؤسسات ولم تبين الطاعنة انها عرضت برنامجا للتخلص من وضعية التوقف عن الدفع واستعادة نشاطها المتوقف أو انه تتوفر لديها المعايير الموضوعية التي يمكن على أساسها ان تسترجع توازنها المالي والاقتصادي بل انها في وضعية ميؤوس منها يستوجب الأمر التصريح بتفليسها.

وحيث خلافا أيضا لما ورد بالمطاعن فقد تم التحجير على ممثل الشركة المدينة وتمّ تلقّي جوابه عنها باعتباره يمثلها وقد كانت النيابة العمومية في الطور الاول الابتدائي حاضرة ضمن تركيبة المحكمة حسب يتضح من محضر الحكم المؤرخ في 2017/7/4 ومن لائحة الحكم أيضا وقد يتشكله قضائية مكتملة التفليس يتقرر من الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية. ولا يمكن ان نتحدث عن هذه التركيبة بالطور الاستئنافي لانه لا توجد دوائر تجارية لديها ولا يشترط أي تركيبة خاصة في مثل هذه القضايا بالاطور الاستئنافي.

وحيث بات الطعن غير وجيه ويتجه رده».

* عن المطعن المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بتطبيق نص قد تم نسخه وهو الفصل 596 من المجلة التجارية:

حيث لا جدال كيفما سبقت الإشارة إليه أعلاه ان قواعد التفليس المنطبقة في قضية الحال هي القواعد القانونية الجديدة المضمنة بالكتاب الرابع من المجلة التجارية عملاً بأحكام الفصل 15 من الأحكام الانتقالية من القانون عدد 36 لسنة 2016 وتكون بذلك محكمة الاستئناف حينما أكدت على تطبيق أحكام الفصل 596 قديم من المجلة التجارية والذي وقع الغاؤه صراحة بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2016 فيما يتعلق بسحب الفلسفة على المسيرّ واعرضت عن تطبيق أحكام الفصلين 589 و590 من م ت (الجديدين) تكون قد اخطأت في تطبيق القانون وذلك بتطبيق نصّ قانوني وقع نسخه.

وحيث اقتضى الفصل 590 من المجلة التجارية « اذا تمّ تفليس الشركة يمكن التصريح بان يكون التفليس مشتركاً بينها وبين كل شخص التجأ إلى التستر بها لاختفاء تصرفاته وقام لمنفعته الشخصية بأعمال تجارية وتصرف بالفعل في مكاسب الشركة كما لو كانت مكاسبه الخاصة.

وحيث يستشف من ذلك ان سحب الفلسفة على المسيرّ (سواء بالفصل 596 قديم الذي وقع الغاؤه أو بالفصلين 589 و590 جديدين من م ت بعد تنقيح المجلة بالقانون عدد 36 لسنة 2016) يتوقف على شروط إجرائية وأخرى موضوعية فلا يكون التفليس مشتركاً إلا إذا ثبت ان تصرف المسيرّ كان وفق منفعة الخاصة متخفياً بالذات المعنوية وان يكون تصرفه في مكاسب الشركة كما لو كانت مكاسبه الخاصة ومع وجوب التفريق بين التصريح بالفلسفة على المدين وسحبها على المسير وهو ما يعني أنه على القرار المطعون فيه بيان الأسباب أعلاه وهو ما لم تقم به محكمة القرار المطعون فيه ومن قبلها محكمة البداية فهي قد سحبت منذ الطور الأول الفلسفة على مسير الشركة المدينة ودون أن تتعرض في شروط الإشتراك في الفلسفة إذ لم تبين بصفة واضحة وجلية الأخطاء التي قام بها المسير والتي أدت إلى تفليس الشركة وهو ما يجعل قرارها مستهدفاً للنقض وإتجه التصريح بذلك».

5-6-2 جواز أن يكون ممثل الدائنين مراقبا للتنفيذ

قرار تعقيبي عدد 2019.82353 بتاريخ 10 جوان 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«حيث أسست المعقبة طعنها على عدم وجهة تكليف الدائن بنك الأمان بمهام مراقب التنفيذ.

وحيث يطرح المطعن السؤال التالي هل يجوز أن يكون أحد الدائنين مراقبا للتنفيذ؟

وحيث ينص الفصل 453 من المجلة التجارية على أنه «وتعتمد المحكمة برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو ببراء مشفوعا بإحالتها وإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير وتحدد مدة البرنامج وتعين مراقبا أو مراقبين لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين وغيرهما ولمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه».

وحيث يؤخذ من أحكام الفصل 453 م ت المذكور أعلاه أنه يمكن أن يكون أحد الدائنين مراقب تنفيذ إذا كانت له صفة ممثلا للدائنين ويعرض مالهم من ملاحظات على القاضي المراقب وليس مراقبا للتنفيذ باعتباره دائنا فقط حتى لا يتأثر بموقعه كدائن وحتى لا تتضارب المصالح، بالإضافة إلى ما تقتضيه التجربة في إدارة تنفيذ برنامج التسوية بالصورة الكافية التي تثير سبيل المحكمة وهي عناصر لم تبرزها محكمة القرار المنتقد وكان ردّها عن الدفع بعدم وجهة تكليف الدائن بنك الأمان بمهام مراقب التنفيذ عاما وغير مقنع لأن ضمان حسن تنفيذ برنامج الإنقاذ لا يتحقق بمجرد تكليف أحد الدائنين وإنما بتوفر التجربة والتخصص لديه في إدارة تنفيذ برنامج التسوية ولا يكفي أن يكون أكثر الدائنين مثما يدفع بذلك المعقب ضده بنك الأمان ما لم تتوفر فيه صفة ممثل الدائنين وفق مقتضيات الفصل 453 من المجلة التجارية المذكور أعلاه فالمشرع وإن منح الخيار للمحكمة في تكليف أحد الدائنين كمراقب تنفيذ يتوقف أو على

صفته كممثل للدائنين بما يعني أن هؤلاء قد منحوه صلاحيات التفاوض في حقهم وعرض ملازماتهم عند إعداد البرنامج أي خلال فترة المراقبة وهي الصفة التي تجعله على دراية بالبرنامج وأسسها بما ييسر عليه متابعة تنفيذه وهو ما يفسر الربط بين الصفتين كما يتوقف على تلاؤم ذلك مع وضعية المؤسسة وهي مسائل قد أغفلت محكمة القرار المنتقد البحث فيها واتجه نقضها قرارها في الفرع المذكور.

5-6-3 الطعن بالاستئناف في حكم التسوية-تاريخ التوقف عن الدفع-المنع من التسيير

قرار تعقيبي عدد 77190/75203/75195/75194/75193.2019_ بتاريخ 11 مارس 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«-1 في المطاعن المقدمة من المساهمين موضوع القضية عدد 75193:

حيث اقتضى الفصل 152 من م م م ت أنه لا يمكن رفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفائهم أو من ممثل النيابة العمومية في الأحوال التي عينها القانون كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المستلظ عليها الحكم المستأنف.

وحيث حدد المشرع من خلال الفصل المذكور الأطراف التي يحق لها الطعن بالاستئناف والأطراف الذي يمكن رفع الاستئناف ضدهم وهؤلاء الأشخاص هو من كانوا مشمولين بالحكم المستأنف مدعين كانوا أو مطلوبين أو دخلاء ومتدخلين أو النيابة العمومية في الأحوال التي بينها القانون ولا يمكن رفع الاستئناف ممن لم يكن طرفا في الحكم المستأنف .

وحيث وبالرجوع إلى ملف القضية يتضح أن الطاعنون لم يكونوا طرفا في القضية لدى الطور الابتدائي سواء كمدعين أو مطلوبين أو دخلاء ومجرد إنابتهم لمحام وتقديمه لتقارير في حقهم لا يجعل منهم أحد أطراف الخصومة إذ لا يمكن أن تشمل الدعوى على من حضر من تلقاء نفسه وقدم طلباته دون أن يكون دخيلا أو متدخلا .

وبالتالي أحسنت محكمة القرار المنتقد فعلا لما رفضت إستئناف الطاعنين شكلا طالما لم يتوفر لها من أوراق الملف ما يفيد أن المعقبين الان كانوا طرفا في الحكم الابتدائي .

عن المطعين الثاني والثالث لترابطهما وإتحاد القول فيهما:

حيث وبالرجوع إلى الفصل 564 من القانون عدد 36 لسنة 2016 يتبين ان من بين الأشخاص التي يمكنها الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية المدين أو الدائنين أو المحال له أو المكتري أو النيابة العمومية. وحيث يطرح السؤال أن كان الشريك في المؤسسة التي تمتعت بإجراءات التسوية القضائية وصدر حكم في الغرض إثر إنتهاء الإجراء المذكور والذي يدعي أنه دائن بالمساهمة مثلما هو حال الطاعنين يحق له الطعن بالإستئناف في الحكم الابتدائي.

وحيث أن الجواب على هذا السؤال يقتضي التمعن في الفصل 564 المشار إليه آنفا الذي جاء واضحا وفي صيغة الحصر عند تحديده للأشخاص والأطراف التي يمكنها الطعن بالإستئناف إذ جاءت عباراته حصرية ولا تدع مجالا للشك في أن الواقع تعدادهم هم الوحيدون المخول لهم الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية ولم يتعرض إلى الدائن المساهم وهو أمر منطقي بما أن المساهم جزء من الذات المعنوية المتمثل في المؤسسة التي تمر بصعوبات إقتصادية وتم تمتيعها بإجراءات التسوية القضائية وطلباته لا يمكن أن تتجزأ عن المؤسسة التي هو شريك فيها ويكون صحبة بقية الشركاء رأس مالها ومساهماتهم هي ضمان لدائني المؤسسة وليست دينا على الشركة متخلدا لفائدتهم وعليه فهو مرتبط تلك الذات المعنوية وطلباته يجب أن تنضوي في مطالبها المقدمة من وكيلها أو المؤتمن عليها إذ تبقى المؤسسة التي تقدمت بمطلب تسوية وحدة إقتصادية وقانونية غير مجزأة بين مساهميتها ومستقلة عنهم بل يمثل كيان واحد ولا يمكن لهؤلاء المساهمين أن يتقدموا بطلبات مستقلة عن المؤسسة وقد أحسنت محكمة القرار المنتقد تطبيق القانون لما نحت هذا المنحى وتعين رد هذين المطعين لعدم وجاهتهما.

2) بخصوص الطعن المقدم من الشركة السياحية طالبة التسوية المطلوب عدد : 75194

عن المطعن الاول المتعلق بمخالفة الفصل 19 من م م م ت :

حيث تضمن المطعن أن دين بنك تونس العربي الدولي قد تمت حالته منذ سنة 2008 بكتب ثابت التاريخ إلى الشركة الدولية العربية للإستخلاص الديون ووضحت هذه الأخيرة هي التي لها صفة الدائنة ولم تتول المحكمة الإذن بإدخالها في القضية لتثبيت الدين رغم الدفع لديها باعتبارها هي الدائنة وقد ردت المحكمة ذلك الطلب لأنه لم يقع إدخال شركة الإستخلاص وينسب لها الطعن في ذلك خرق الفصل 19 من م م م ت بخصوص صفة البنك وصفة شركة الإستخلاص.

وحيث أن إجراءات التسوية القضائية تشمل المدين الخاضع للتسوية ودائنيه للبحث عن برنامج إنقاذ يفي بخلاص الديون وهو ما يقتضي أن يتحدد البرنامج بين المدين والدائنين بصفة فعلية وقانونية ولا يمكن أن يشمل الطرف الذي أحال دينه فالمحال له هو الذي يعتبر دائنا بموجب عقد إحالة الدين وهي شركة الإستخلاص في دعوى الحال ومن الضروري أن يشملها البرنامج وأن محكمة الحكم المطعون فيه لما تفتنت لذلك وتم الدفع به أمامها كان من المتعين عليها أن تأذن بإدخال الدائن الحقيقي وتتلقى موقفه ومؤدياته وتبحث في تسوية دينه وأنه من غير الوجيه رفض اعتبارها دائنة والإبقاء على البنك كدائن حال أنه كان أحال الدين ومنه فقد صفته كدائن وصفته في التسوية القضائية.

وحيث تكون محكمة الحكم المطعون فيه قد خالفت الفصل 19 من م م م ت وفكرة قانون الانقاذ في أنه برنامج تسوية ديون بين المدين ودائنين فلا يجوز أن تقضي المحكمة في أي نزاع بصفة تخالف الوثائق والمؤيدات المضافة بما يتعين معه نقض قرارها من هذه الناحية.

عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصلين 18 و 32 من قانون الانقاذ :

حيث تضمن المطعن ان تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بتاريخ تقديم مطلب تسوية يعد خارقا للقانون فعدم الرجوع بتاريخ التوقف إلى فترة الريبة فيه إجحاف بحقوق المؤسسة والمسيرين اللذين ساهموا في إنقاذ المؤسسة وتسوية ديونها.

وحيث بخصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع ينص الفصل 38 من قانون الإنقاذ على أن المحكمة تحدد تاريخ التوقف عن الدفع ويتم ذلك بالرجوع إلى محاضر العجز عن التنفيذ مثلا أو بالرجوع إلى الموازنات المالية على مدى ثلاث سنوات ونظرا للصعوبة الواقعية التي قد تعترضها في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة دقيقة ولتجاوز ما ينجر عن ذلك من منازعات خاصة من طرف المدين أعطى المشرع حلا قانونيا عند عدم وضوح المعايير أو عدم التصريح به من طرف المدين عند إيداع مطلب التسوية القضائية فقد اعتبر أن تاريخ تقديم المطلب هو تاريخ التوقف إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 38 أنه «في صورة قبول المطلب تحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ ايداع مطلب التسوية» ويقوم ذلك قرينة على أن التوقف عن الدفع حصل عند تقديم المطلب.

ولكن يمكن للمحكمة بحسب الوقائع والملازمات ان تعتبر أن التوقف عن الدفع قد تم في تاريخ سابق عن تاريخ تقديم المطلب فتقر تقديمه إلى مدة سابقة على أن لا تتجاوز مبدئيا الثمانية عشر شهرا من تاريخ تعهيد المحكمة وإن لم يبين المشرع بالفصل 38 من قانون الإنقاذ الطرف الذي يمكنه أن يطلب تغيير تاريخ التوقف عن الدفع فإن المحكمة تجتهد في ضبطه بناء على المعطيات المتوفرة لديها بملف القضية أو التي تكتشف خلال الإجراءات أو بناء على طلب احد الدائنين أو المتصرف القضائي أو النيابة العمومية.

وحيث وإن كان من الجائز تقديم تاريخ التوقف عن الدفع إلى ما قبل تقديم مطلب التسوية فإنه لا يمكن تقديم تاريخه إلى أكثر من ثمانية عشر شهرا باعتبارها المدة القصوى لفترة الرية ويجد هذا الموقف سنداً له في الأحكام المنظمة للتفليس القابلة للتطبيق في إجراءات التسوية القضائية فقد نص الفصل 56 من القانون على انطباق الفصول 446 و448 و450 و451 و462 و463 من المجلة التجارية على التسوية القضائية وهي فصول تتناول بطلان التصرفات التي تبرم خلال فترة الرية.

وحيث أن إشتراط اثبات التوقف عن الدفع وتحديد تاريخه يخضع لموجبات الإدلاء بالمعطيات والمؤيدات المشروطة بالفصل 4 مكرر من القانون فيحتوي

مطلب التسوية بيان أسبابه كبيان ما للمؤسسة وما عليها من ديون والمؤيدات المثبتة لذلك وبيان أسماء الدائنين والمدنيين ومقراتهم وموازنات الثلاث السنوات الأخيرة وجدول الإستغلال المستقبلي وبرنامج الإنقاذ المقترح وتمثل هاته البيانات معطيات موضوعية يتم على ضوءها تحديد تاريخ التوقف عن الدفع مع وجوب التحقق من وجود المطالبة والتتبع القضائي لإستخلاص الديون وتعذر الخلاص بصفة واقعية بما يصير أعمال التنفيذ الجبري محققة الحصول ضد طالب التسوية.

وحيث أن المطعن نسب للمحكمة خرق الفصل 18 في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع ولكنه لم يبين وجه الخرق ولم يبين التاريخ الذي يمكن إعتماده وبات بالتالي توجه محكمة الحكم المطعون فيه في تحديد تاريخ التوقف عند انطلاق التسوية وجيها وسليما واقعا وقانونا بما يتجه معه رد هذا المطعن.

عن المطعن المتعلق بمخالفة الفصلين 26 و28 من قانون الانقاذ:

حيث يطرح المطعن مسألة إستمرار رفع يد المسير عن إدارة المؤسسة بعد المصادقة على برنامج انقاذها فهل أن المنع من التسيير يظل وقتيا إلى حين صدور الحكم أم يمكن إستمراره حتى بعد المصادقة قضائيا على برنامج الانقاذ؟

حيث أذنت محكمة البداية للمتصرف القضائي بمواصلة إدارة وتسيير المؤسسة مقررة بذلك قرارها المؤرخ في 23 سبتمبر 2013 القاضي برفع يد المسير ع. بن م. والمسيرة س. اد. والتحجير على المسير الفعلي م. اد. القيام بأي عمل إدارة وتسيير دون إذن مسبق من المحكمة وأيدتها محكمة الحكم المطعون فيه ويدفع الطاعن بأن الإبعاد عن التسيير وتحجيره لا يمكن أن يكون إلا وقتيا ينتهي بصدور الحكم في التسوية القضائية سيما وقد ثبت أن المسير الفعلي محمد أدريس هو الذي بذل المال لإعادة المؤسسة الفندقية إلى نشاطها وبذل المصاريف لإدخال الإصلاحات المستوجبة.

وحيث أن تعهيد المتصرف بإدارة المؤسسة بصفة كلية أو جزئية يكون إستثنائيا من المحكمة ويتحول المسير بذلك إلى مساعد وتنقلب الأدوار فيصبح المتصرف القضائي مسيرا ويصبح المسير مساعدا له أو بدون هاته الصفة إن رأت المحكمة مصلحة المؤسسة في ذلك كل ذلك إذا تبين أن المسير قد إرتكب عدة

مخالفات في التسيير وإستولى على أملاك المؤسسة أو جعل منها واجهة لتحقيق منافع شخصية فإنه وحفاظا على مصالح الشركة والشركاء يقع إبعاد المسير عن مهام التسيير إلى حين البت في مآل التسوية والمصادقة على برنامج إنقاذها من المحكمة حتى تستعيد المؤسسة موقعها وتمثيلتها القانونية أمام العموم لأن المتصرف القضائي لا يمتلك صفة الممثل القانوني وبصفته يمثل الإستثناء فإن الإبعاد ورفع اليد يخضع لنظام الإستثناءات عموما فما به قيد يكون محدودا زمانا ومكانا وفق الفصل 540 من ماع ولا يعني ذلك بالضرورة عودة المسير السابق الذي ألحق أضرارا بالمؤسسة وإنما لا بد من تسمية هياكل المؤسسة سواء برفع التحجير عن المسير القديم أو دعوة الجلسة العامة لتسمية من يتكفل بالإدارة والتسيير.

وحيث أن محكمة الحكم المطعون فيه لما أبتت على التحجير بعد المصادقة على البرنامج ولم تبت في مسألة التسيير لتنفيذ البرنامج يمثل قصورا منها في الحكم لأن مراقب التنفيذ المكلف ليست له صفة المسير ومنه يكون من الوجهة نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية.

3) بخصوص الطعن المقدم في المطلب عدد 75203:

حيث تضمن الطعن أن المحكمة خالفت أهداف قانون الإنقاذ لأنها لم تضع البرنامج الذي يقبل التطبيق فهي لم تقبل الإستئناف العرضي في إحالة المؤسسة إلى الغير.

وحيث من الجدير البيان أن المشرع يضع برنامج مواصلة المؤسسة لنشاطها بنفسها من البرامج ذات الأولوية إذ يعتبر حل إنقاذ المؤسسة بنفسها الحل الطبيعي الذي يعول عليه المدين بأعباءه يبحث عن إعادة توزانه المالي عبر قانون الإجراءات الجماعية ولا يمكن المرور إلى الحلول الأخرى للإنقاذ وخاصة إحالة المؤسسة إلى الغير إلا إذا تعذرت حلول الإنقاذ بمواصلة النشاط باعتبار أن الإنقاذ بإحالة المؤسسة على الغير يبقى حلا لاحقا وثنائيا لبرنامج مواصلة النشاط ولذلك يتم تسبيق الحل في الإنقاذ بمواصلة النشاط ذلك ان الاحالة كحل من حلول الإنقاذ تمثل حلا ثانويا من حلول الانقاذ لا يمكن الالتجاء إليه إلا في صورة تعذر الإنقاذ بمواصلة النشاط إذ الأولى أن تبقى المؤسسة بين أيدي

مالكها ومسيرها ولا يمكن ان يعهد بها إلى أياد جديدة إلا إذا تعذر إنقاذها بمواصلة النشاط بنفسه وهو ما يقتضيه صراحة الفصل 47 من قانون الإنقاذ الذي ورد به أنه « لا يمكن أن تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة للغير إلا إذا تعذر انقاذها طبقاً لأحكام الفصول من 41 إلى 46 من هذا القانون » ويشترط فقه القضاء (قرار تعقيبي مدني عدد 52422 مؤرخ في 27-04-2012 غير منشور) إتباع التدرج والمرحلية في إختيار برنامج الإنقاذ قولاً « حيث أن محكمة القرار المطعون فيه حين استبعدت الحل التدريجي الذي إعتمدته محكمة البداية لإنقاذ الشركة المعقبة وعدلته بأن أذنت بإحالتها للغير لم تبين في تحليلها توفر الشروط المتلازمة والتي أوجبها الفصل 47 المذكور وهي : أولاً تعذر إنقاذ المؤسسة ثانياً ضمان إستمرار نشاطها أو الإحتفاظ بكل أو ببعض مواطن الشغل فيها ثالثاً تطهير ديونها جعلت قضاءها مشوباً بضعف التعليل وخارقاً للقانون موجبا للنقض من هذه الناحية أيضاً».

5-6-4 جواز تعديل الفوائض المشطة للتوازن بين الإلتزامات المحمولة على المؤسسة المدنية الخاضعة للتسوية

قرار تعقيبي عدد 2019.82353 بتاريخ 10 جوان 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن المطعن الثاني المأخوذ من إهمال البت في طلب أساسي بما يورث مخالفة للقانون:

حيث تعلق المطعن منذ الطور الموضوعي بمناقشة الفائض القانوني الذي تم تقريره في خلاص الدين الراجع للقباضة المالية، فقد تمّ إحتسابه بنسبة 9٪ على خلاف النسب المعتمدة لباقي الدائنين.

وحيث يعدّ تكييف الفوائض مسألة قانونية مطروحة يمكن لمحكمة التعقيب تسليط رقابتها عليها وتعديل الفوائض تبعاً لذلك باعتبارها من الشروط التغريمية التي يجوز للقاضي تعديلها بما يتناسب مع الغاية من تكريسها وحتى لا تكون تلك النسب المعتمدة مكلفة على المدين سيما وأن تنفيذها مستمر في الزمن،

وأن تنفيذ تلك النسبة في الفترة التي تمر فيها المؤسسة بصعوبات لا يتناسب مع الخدمات التي وفرها الدائن للمدين سيما وأن توظيفها هو لحث المدين على الإيفاء بالتزاماته ولا يمنع محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية من إجراء ما لها من حق الرقابة على النسبة المفروضة بحسب أحوال كل قضية على معنى الفصلين 243 و 278 ماع على قاعدة وأن القراءة المتكاملة للفصلين 242 و 243 ماع تبين أن المشرع التونسي لم يقصّي تماماً إمكانية تدخل القاضي بمراجعة إلزام أحد طرفيه متى يثبت أنه كان مرهقا ومجحفا بحقوقه أو أنه لم يعد مواكبا ومتماشيا مع الظروف العامة ضرورة أن المبدأ يفترض إمكانية تدخل المحكمة لإيجاد توازن بين الإلتزامات المحمولة على المؤسسة المدنية الخاضعة للتسوية والتي تبحث عن مساعدة دائئنها وحتى لا يتم إرهابها بفوائض مشطة ولا يكون المجال لتعسف الدائن.

وحيث إن محكمة القرار المنتقد لم تمارس سلطتها التقديرية في مراجعة نسبة الفوائض المحددة بـ 9٪ ولم تناقشها أو تبدي رأيها فيها رغم الدفع بذلك بما أورث حكمها ضعفا في التسبب موجبا للنقض من هذه الناحية وتعين لذلك نقض القرار المطعون فيه فيما يتعلق بتسمية الدائن بنك الأمان كمرقب تنفيذ وفي ما تعلق بنسبة الفائض القانوني المرتب على دين القباضة المالية».

5-6-5 انطلاق أجل التقادم من صدور الحكم المصرح بالتسوية القضائية أو بالفلسة بقطع النظر على وقوع الطعن فيه من عدمه.

قرار تعقيبي عدد 83376 / 83495 بتاريخ 10 فيفري 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيدة مريم البكوش وعضوية المستشارين السيد وليد بن جديدية والسيدة عربية الطويهري وبحضور المدعي العام السيد سفيان العرابي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني .

«عن المظعن الأول المقدم بمطلي التعقيب موضوع القضيتين عدد 83376 و 83495 والمأخوذ من خرق أحكام الفصل 121 من م.ش.ت وتجاوز السلطة في خصوص سقوط الدعوى بمرور الزمن:

حيث اقتضى الفصل 121 من مجلة الشركات التجارية أنه» إذا أظهرت التسوية القضائية أو التفليس عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من

المتصرف القضائي أو أمين الفلسفة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كلياً أو جزئياً الوكيل أو الوكلاء أو كل مسير فعلي وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها أن تحجر على المحكوم عليه مباشرة تسيير الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم. ولا يعفى الوكيل القانوني أو الفعلي من المسؤولية إلا إذا أثبتا أنها بذلا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حكم التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس».

وحيث أحتدم الخلاف بين طرفي التداعي بخصوص التاريخ المعتمد لإنطلاق إحتساب أجل التقادم المنصوص عليه بالفصل متقدم الذكر والذي اعتبرته محكمة القرار المطعون فيه ينطلق من تاريخ صيرورة الحكم بالتفليس نهائياً تأسيساً على ما لإستئناف ذلك الحكم من مفعول تعليلي وإنتقالي يقتضي إنتظار صدور قرار نهائي بالتفليس لإنطلاق إحتساب أجل دعوى سد العجز المؤسسة عليه.

وحيث ان النظر في هذا المطعن وفي مدى سلامة التعليل المعتمد من قبل محكمة القرار المطعون فيه للقول بوقوع القيام في كنف الآجال القانونية رداً للدفع بالتقادم ، يقتضي الوقوف على ما اذا كان تنصيب المشرع صلب الفصل 121 المذكور على أن أجل التقادم يُحتسب من تاريخ حكم التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس يؤول بالضرورة - عملاً بالمفعول الانتقالي والتعليلي للإستئناف - إلى وجوب إنتظار مآل الطعن أو أنه من المتعين الوقوف عند حرفية النص عملاً بما اقتضته القواعد العامة من أن نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته.

وحيث يقتضي الأمر إبتداء الإشارة إلى أن المشرع وفي مواضع مختلفة نص صراحة على ضرورة الإعتماد على تاريخ صدور الحكم النهائي وحائز على قوة إتصال القضاء كمنطلق لنشأة حق أو للقيام بإجراء من ذلك ما اقتضاه 106 م ش ت بخصوص دعوى المسؤولية المقامة ضد الوكلاء المتسببين في البطلان حيث أقتضى أنه « يكون الوكلاء والشركاء المتسببون في البطلان مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وباقي الشركاء عن الضرر الناشئ عن هذا البطلان. وتقرض دعوى

المسؤولية بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ إحراز الحكم القاضي بالبطلان على قوة اتصال القضاء.» وعليه وإنطلاقاً من أن المسلم به أن أعمال المشرع تبني على الدقة وتضان عن العبث فإنه ما من مجال للتزيد فيما إقتضاه المشرع من حل تشريعي لإحتساب أجل القيام أو التقادم بكل دعوى لا سيما وأن نصوص مجلة الشركات التجارية أبانت على أن المشرع إذا ما إتجهت أرادته إلى ضرورة إعتتماد حكم نهائي - لسريان أجل أو القيام بإجراء - نص على ذلك بصفة صريحة دون لبس أو موارد.

وحيث ومن جهة أخرى فإنه مع التأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة التي يكون على أساسها العمل بالنصوص القانونية ولا عبرة بأساليب اللغة الفرنسية - سواء تمت لها ترجمة النص العربي أو نقل عنها النص للعربية - إلا أنه إذا كان القصد من الإستدلال بالنص المصاغ باللغة الفرنسية هو الترجيح بين معنيين ممكنين لدلالة النص العربي أو رفع غموض شابها، فإنه من المستساغ الرجوع لصياغة النص باللغة الفرنسية باعتبار ذلك من القرائن التي يمكن إعتمادها لإستجلاء نية المشرع أو حقيقة مقصده ، وعليه وترتباً على ما تقدم فإنه بالرجوع إلى نص الفصل 121 م ش ت كيفما صيغ باللغة الفرنسية يتبين أن العبرة في إنطلاق أجل التقادم إنما هي من صدور الحكم المصرح بالتسوية القضائية أو بالفلسفة بقطع النظر على وقوع الطعن فيه من عدمه على اعتبار أنه نص ما يلي:

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite

وحيث وفضلاً على كل ما تقدم فإنه من المتعين الإشارة إلى أن إستئناف حكم التفليس لا يرتب بالضرورة إثراً توقيفياً فإستئنافه لا يوقف تنفيذه - إلا إذا ما تم الطعن من قبل النيابة العمومية - فيكون قابلاً للتنفيذ رغم الطعن فيه ويترتب عنه رفع يد المدين عن إدارة مكاسبه والتصرف فيه من تاريخه وهو ما يمكن اعتباره سنداً للقول بأن المشرع إعتبر أن من تاريخ حكم الفلسفة ينتج أثره ولا سيما بخصوص الدعاوى المخولة لأمين الفلسفة أو الدائنين ومنها الدعاوى مناط الفصل 121 م ش ت.

وحيث أضحى قول محكمة القرار المطعون فيه «بأن إستئناف أحكام الفلسفة لها مفعول تعليلي في إنتظار صدور القرار الإستئنافي وصيرورته نهائياً» يتجافى

وما أقره المشرع من خاصية للأحكام الصادرة في مادة التسوية من جهة عدم إخضاعها للمفعول التعليقي للإستئناف ما لم يتم الإذن بإيقاف تنفيذها بموجب قرار قضائي ووفق الشروط المقررة للغرض.

وحيث يؤخذ من كل ما تقدم أضحى ما انتهت إليه محكمة القرار المطعون فيه من قول بضرورة إحساب أجل التقادم مناط الفصل 121 م ش ت من تاريخ صيرورة القرار الصادر في شأن دعوى التفليس نهائيا تأسيسا على مقتضيات الأثر الإنتقالي والتعليقي للطعن بالإستئناف ينطوي على ضعف في التعليل وخرق للقانون فضلا عن هضمها لحقوق الدفاع لعدم تناولها كل أوجه الدفاع الجدية التي أثارها نائب المستأنفين وهو ما يجعل هذا المطعن ذي سداد واتجه قبوله.

عن بقية المطاعن:

حيث لما كان الدفع بالتقادم من الدفع بعدم القبول لكونه يرمي إلى المنازعة في أحقية رفع الدعوى في تاريخها ومنع المحكمة من النظر في أصل الطلب المرفوع لوقوعه خارج الأجل، فإن قبول المطعن المؤسس على خرق المحكمة لأحكام التقادم يفضي بالضرورة إلى الإلتفات عن النظر في بقية المطاعن على اعتبار أن تحقق شروط تقادم الدعوى يغني عن النظر في توفر أركان المسؤولية سواء ما كان منها ذاتيا متصلا بصفة المسير المعني بهذه الدعوى أو موضوعيا مرتكزا على عناصر المسؤولية وأثار قيامها».

5-6-6 إبطال برنامج الإنقاذ يفتح إمكانية إحالة المؤسسة للغير

قرار تعقيبي عدد 20759. 2020 بتاريخ 05 ماي 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«عن المطعن المأخوذ من خرق الفصل 46 من القانون الصادر في 17 أفريل 1995 والخطأ في تطبيقه وتأويله:

حيث كان العرض المقدم من نائب الطاعنة صلب مستندات التعقيب في بيان وضع المؤسسة التي خضعت للتسوية القضائية على معنى قانون إنقاذ المؤسسات

لسنة 1995 وتأسس الطعن أساسا على خرق المحكمة المصدرة للحكم موضوع الطعن للفصل 46 من قانون 17/04/1995 بقولها أن المشرع أقصى إمكانية الرجوع إلى طور المراقبة أو البحث عن برنامج إنقاذ للرجوع في قرار الإبطال طالما أن إعادة فتح التسوية القضائية مقترنة قانونا ووفق الفصل بالإحالة على الغير وأن تعذر الاستكمال بالتفليس أو التصفية.

حيث ثبت من قراءة للملف أن برنامج الإنقاذ الواقع إقراره للمؤسسة والمضي في تنفيذه تحت رقابة الخبير جلال الحداد تضمن إعداد كراس شروط كراء النزل وتمكين النزل من الإصلاحات والتحسينات والدعوى لجلسة عامة خارقة للعادة للترفيه في رأس المال إلى ثلاثة مليون دينار وفق تقدير محدد وأن الجلسة العامة الأولى لم تنعقد وأن الجلسة العامة الثانية المحددة لذات الغرض تم الحكم بخصوصها إستعجاليا في 29/09/2012 بإيقاف مداولاتها وذلك إلى حين البت في القضية الإعتراضية.

حيث لا خلاف في اعتماد المحكمة الأصلية على أحكام الفصل 46 من قانون 1995 وذلك بالمصادقة على إتخاذ محكمة الدرجة الأولى في حكمها عدد 182 قرارا بعد العرض على النيابة العمومية بإبطال برنامج الإنقاذ القاضي بتمكين المؤسسة من مواصلة النشاط ثم إعادة إفتتاح إجراءات التسوية القضائية وتعيين المعقب ضده مراقب التنفيذ بإعداد تقرير حول مآل المؤسسة كما قررت في نهاية الحكم إحالة الشركة بصفة كلية وصبرة واحدة للغير طبقا لإجراءات الفصل 47 من قانون 1995.

حيث لا خلاف تصديقا لموقف المعقب ضدهم أن العرض على النيابة العمومية وإتخاذ المحكمة المشرفة على التسوية قرارا في الإحالة على الغير بعد إعادة إفتتاح التسوية وفق إجراءات الفصل 47 من قانون 1995 بالنسبة للمؤسسة يحيل قانونا إلى توقف برنامج الانقاذ بعد ثبوت عدم إمكانية المؤسسة لمواصلة النشاط.

حيث ان الفصل 46 من قانون 17/04/1995 نص إجرائي واضح قرر حق القاضي والمحكمة المكلفة بالنظر في التسوية إتخاذ قرار إبطال برنامج الإنقاذ وثبت إحترام كل إجراءات الأبطال الشكلية وأن المرحلة الموالية بصريح النص إعادة افتتاح التسوية لغاية وحيدة ومنفردة وهي إحالة المؤسسة.

حيث أن المشرع وفق الفصل 46 من قانون 1995 قرن إجرائيا فشل برنامج الإنقاذ المكرس لمواصلة النشاط مع إتخاذ إجراءات التخفيف على المؤسسة من ذلك تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ بشروط محددة بالقانون بقرار تتخذه المحكمة بإبطال البرنامج والمرتبط بإنعدام طرق الانقاذ وأسبابه وتعيين مراقب تنفيذ وهو ما تم إقراره بالحكم موضوع الطعن الآن ثم تولت المحكمة تنفيذا للفصل اتخاذ قرار إحالة المؤسسة للغير.

حيث أن ما قرره المشرع من إجراءات متتالية ومنتظمة في التقدير والأجل لا ينظر إليها بمعزل عن الوضع المالي والإقتصادي والمادي للمؤسسة ولا يعتمد دون البحث عن أسباب إبطال البرنامج الأول ومدى حرص المشرفين على أعمال التسوية وهي جهات عديدة ومتداخلة على تمكين المؤسسة من الإنقاذ ودون تدخل المؤسسة ذاتها في ذلك لا اعتبارها تحت إشراف ورقابة المحكمة.

حيث أن المسؤولية المدنية والجزائية قائمة في حق المتصرف الذي تعهد ببرنامج الإنقاذ من خلال خلاصه للدائنين دون موجب كما أن السند والأساس المتعلق بعملية الترفيع في رأس المال وفي نطاق البرنامج المقرر تم إيقافه بحكم استعجالي في إيقاف الجلسة العامة الخارقة للعادة وأن البنك المساهم إنتصب دائما مفضلا وتولى التصدي لبرنامج الإنقاذ دون توخي المحكمة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التنفيذ بموجب الإجراءات المخولة قانونا للرئيس المحكمة الابتدائية ودون تتبع البنك وإستئناف الحكم الحائل دون عملية الترفيع وهي كلها معطيات تثبت أن عدم التوفيق في برنامج الإنقاذ كان بسبب المساهم الرئيسي والمتصرف القضائي دون اتخاذ التدابير اللازمة، ودون وجود محاولات لاحقة للتسوية وتفادي توقف برنامج الإنقاذ بعد إستخلاص المساهم كامل الدين وإنعدام السيوالة لتنفيذ البرنامج الذي هو جوهر ومناط التسوية حسب توجه المشرع الذي وضع القانون أساسا لضمان مواصلة المؤسسة للنشاط وليس للإحالة كحل نهائي وفق الفصل 46 وذلك بعد إستنفاد كل شروط الإنقاذ الإقتصادية والقانونية وأن المحكمة الأصلية طبقت ظاهر الفصل في سير إجراءاته وذلك دون التثبت من المتسبب في الضرر الحاصل للمؤسسة عند إفتتاح إجراءات التسوية الأولى وبعد التكليف بالبرنامج المعتمد والذي تمت مخالفته بسبب خارج عن المؤسسة وعن الطاعنة طالبة التسوية وكان الخرق في طريقة تطبيق الفصل 46 من قانون 1995

وليس في المفاهيم السليمة الواردة فيه مما يجعل التوصل من المحكمة إلى قرار الإحالة قابل للمراجعة وإعادة النظر من المحكمة مما يجعل الطعن في تطبيقها وإعتمادها معطلا وتعين قبوله.

عن المطعن المأخوذ من ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع :

حيث تمسكت المعقبة بخرق المحكمة للفصل 46 من قانون 1995 وأن المحكمة لم تحسن الرد على ذلك المطعن .

حيث أن كان لقاضي الأصل الحرية في إتخاذ القرار المنطبق وتطبيق القانون وفق قراءة عامة له إلا أنه يتعين الرد على كل دفع وتسبيب الرفض أو الإلتفات عن المطاعن خاصة إذا كانت جوهرية وأن الإكتفاء بتأويل الفصول 46 و 47 من قانون 1995 دون الرد على المطاعن الأصلية المثارة والتي لها علاقة بتطبيق الفصول وتحديد شروط تطبيقها الواقعية والقانونية يكون قد ورث حكمه الضعف في التعليل وتعين تبعا لما سبق ذكره نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بنابل لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى».

5 - 7 بنكي

7-5-1 تأويل وتكييف شروط انقضاء الضمان البنكي يخرج النزاع عن أنظار القاضي الاستعجالي

قرار تعقيبي عدد 2020.20140 بتاريخ 23 جوان 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«عن المطعن الوحيد المأخوذ من خرق ومخالفة القانون وتحريف الوقائع وإنعدام التعليل :

حيث تأسست المطاعن صلب مستندات التعقيب على مخالفة محكمة الحكم المطعون فيه لموجبات الفصل 242 و 243 م ا ع باعتبار أن للمعقب خلافا لموقف الحكم المطعون فيه حق المطالبة بإلغاء الضمانين البنكيين تأسيسا على العقد الذي نص في فصله الرابع على تلك الإمكانية وحدد شروطها بمجرد الوفاء

بالإلتزامات تجاه صاحب المشروع ومضي 4 أشهر كاملة على التسليم النهائي للأشغال الموثق نصا كما تأسست على إنعدام التعليل وتحريف وقائع الدعوى.

حيث تمسك الطاعن بأن البنك المعقب ضده أسند له بتاريخ 26 مارس 2018 ضمانين بنكيين الأول تحت عدد 1808269495 والثاني تحت عدد 1808218231 وأن الفصل الرابع من الضمان نص على أنه يسقط الضمان أي ينتهي مفعوله بمجرد تنفيذ الطاعن للإلتزاماته تجاه صاحب المشروع وهي الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه «مؤسسة إدارية تدير مرفق عام» وأنه تأييدا لإستحقاق إسقاط الضمانين تولى الطاعن تقديم ما يفيد التسليم النهائي للمشاريع المنجزة وذلك في 2017/09/12 و 2017/10/03 مع تمكين المعقب ضده من تعهد بعدم التحفظ من صاحب المشروع وقد واجهه المعقب ضده بالرفض دون سند ، مجددا طلب إنهاء مفعول الضمانين وفق منهج محكمة البداية طالبا نقض الحكم المطعون فيه لضعف ما تضمن من تعليل وتحريفه للوقائع مؤكدا على إنعقاد إختصاص قاضي العجلة في النزاع.

حيث ودون الخوض في مناقشة الإختيار اللغوي لعبارات الحكم لاعتبار أن العبرة بالمضمون وبنتيجته بعد التعليل فقد ثبت أن الحكم المطعون فيه قد أسس نقض حكم البداية على سند جوهري مضمن بالفصل 201 م م م م مرجع تعهد قاضي العجلة وتم الخوض في ولاية القاضي على أن له ولاية عامة للنظر في جميع القضايا المؤكدة عدا ما خرج عنها بنص كما أن تلك الولاية لا تؤخذ على إطلاقها وإعتبرت المحكمة عند النظر في حكم البداية أن المنازعة المثارة بخصوص شروط إلغاء مفعول الضمان ومدى استيعاب الفصل 111 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/03/13 للفصل الرابع من عقد الضمان موضوع الطلب والحاجة إلى تغيير الفصل الرابع من كتب الضمان من موجبات رفض الطلب.

حيث ثبت من رد المعقب ضده في أطوار النزاع أن سقوط الضمان لا يتوقف خلافا للطلب على تقديم محاضر تسليم المشاريع وعلى عدم التحفظ من المعاهد المنتفع من الضمان بل أن نوع العملية يستوجب قانونا تقديم المعقب ما يفيد الحصول على كتب في رفع اليد صادر عن المستفيد من الضمانين أو ما يفيد

أن مدة الضمان الاتفاقية قد إنتهت وأن ذمة المعقب لم تعد عامرة لفائدة الشركة صاحبة الصفقة بعنوان الضمان.

حيث أنحصر النزاع في تأويل الفصل الرابع من عقد الضمانين فإعتبر المعقب أن مجرد التسليم النهائي للمشاريع يرفع الضمان وقدّر الطرف المقابل أن الرفع مشروط برفع يد يسند للمقاولة الممثلة في المعقب لتعد موفية بالتزاماتها وفق الفصل موضوع النزاع.

حيث إن طرح النزاع بخصوص الوضع التعاقدي الحالي على اعتبار أنه محفوف بالتأكد وطلب الحكم في إطار ولاية قاضي العجلة برفع الضمان لا يستقيم لثبوت إثارة المطلوب تأويلا للوضعية العقدية تستحق القراءة والتقصي والتأويل وفق ذكر المحكمة وتكون من موجبات رفع يد قاضي العجلة على أن فقه القضاء إشتراط جدية المنازعة المحيلة إلى وجود مساس بالأصل أو الإحالة على إختصاص قاضي الأصل.

حيث بين المعقب ضده أن المعقب تقدم بمطلب في تمكينه من ضمانين بنكيين وذلك لتعويض الخصم بعنوان الضمان وذلك في 19 مارس 2018 وكان المطلب لاحقا بما يعادل خمسة أشهر من محضر القبول النهائي للمشاريع وأن الضمان قدم بعد القبول النهائي وبالتحديد في 26/03/2018 ونفى المعقب ضده علاقة القبول النهائي للأشغال بمدة الضمان ومدى انقضائه وهو نزاع جدي فيه قراءة مغايرة للفصل 4 من العقد يستوجب تكييف العقد وطريقة رفع اليد على الضمان لوقف طرح العمولة على حساب المعقب. كما أن المعقب ضده أكد أن الضمانين تعلقا بضمان العيوب اللاحقة للصفقة وأن هذا التأويل كان سببا من أسباب رد اختصاص قاضي العجلة وفق منهج المحكمة ذلك أن المطالب المضافة بالملف تضمنت طلب المعقب رفع يد معاقده على الضمان على الحجز وأن الخلاف حول ماهية الضمان ونوعه وطريقة رفعه أو إنهاء مفعوله كلها مسائل أصلية تستوجب التحري والتأويل وقد أصابت محكمة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت أن النزاع كما طرح يخرج عن ولايتها وكان قرارها حائزا على موجبات التعليل السليم ولا أثر لتحريف لوقائع الطلب الموجه للحكم كما حررت أسانيده.

حيث لا شك في وجوب الإلتزام بمقتضيات الفصل 242 م إ ع الذي أرسى قاعدة علوية الإتفاقات بين الأطراف بأن جعل العقد شريعة الطرفين ويقوم بينهما مقام القانون كما أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بالوفاء بإلتزاماتها مع تمام الأمانة وأنه يلزم ما صرح به في الإلتزام وما يترتب عنه من حيث القانون والعرف والإنصاف وفق القاعدة الأصولية الواردة بالفصل 243 م إ ع وهي مبادئ عامة وجوهرية تحكم المعاملات العقدية ومضامين الإلتزامات المتفق عليها فقها وتطبيقا.

حيث إن محكمة الحكم المنتقد لم تتعد ما أوجبه الفصلان 242 و 243 م 1 ع ولم تشر إلى ثبوت الإلتزام موضوع الضمان ولا إنقضائه أو زواله بل أعرضت عن الفصل في النزاع لحاجة النزاع كما طرح وكما أثير فيه من دفعات جوهرية إلى التأويل ، وإقتصر دور المحكمة على التصريح بعدم ولايتها على النزاع بحكم موجبات الفصل 201 م م م ت ولم تخض في مضمون الإلتزامات كما أن تعرضها لحجة كل طرف كانت لتقرير إنعقاد نظرها من عدمه لا غير ذلك أن البحث في تغيير الضمان وثبوت تكوينه على الصيغة الجديدة بعد التسليم النهائي يجعل الحسم في طبيعته مسألة مفترضة قانونا ولا يمكن الحكم بسقوط الضمان دون التحقق من انطباق نص الفصل 4 من العقد عليه وكذلك الفصل عدد 111 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13/03/2014 في توفر معطى واقعي وقانوني أن الضمان صدر أو أسند بعد التسليم وليس قبله وأن الفصل 4 من العقد ينص على إنهاء الضمان بعد التسليم وكان موقف محكمة الحكم المنتقد معللا ومنسجما مع عدم توفر عناصر الوضوح والجلء المفترضة في الحق الظاهر المراد استرداده أو حفظه وتعين لما سبق ذكره رد جملة المطاعن ورفض التعقيب أصلا».

5-8 أوراق تجارية

5-8-1 لا يقوم الانذار بالدفع مقام الاحتجاج ولا يمكن الاستعاضة عنه بالانذار-النفاذ العاجل في الكمبيالات 317- و 320 م ت-سوء النية لدى حامل الكمبيالة 279- و 280 من م. ت.

قرار تعقيبي عدد 2020.2027 بتاريخ 21 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن المطعن الأول المأخوذ من ضعف التعليل والإفراط في السلطة ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويل الفصلين 59 و 60 من م م ت والفصلين 317 و 320 المجلة التجارية:

حيث دفعت الطاعنة بأن محكمة الحكم المطعون فيه وقعت في الخلط بين إقامة الإنذار بالدفع على معنى الفصل 59 من م م ت ووجوب تحرير محضر الإحتجاج لعدم الدفع وهو سوء فهم منها وسوء تطبيق للفصل 320 من م م ت وإن الإنذار لا يمكن أن يقوم مقام الإحتجاج ولا يمكن الإستعاضة عنه بالإنذار.

وحيث أحاط المشرع تنظيم الكمبيالة بأحكام خاصة بالمجلة التجارية وبالفصل 59 من م م ت ومكن وفق نظام الفصل الأخير جبر المدين على الوفاء بقيمتها بإجراءات ميسرة تتمثل في إستصدار أمر بالدفع بعد إنذار المدين كما مكن الحامل من إستصدار أمرا بالدفع ضد حاملها بعد تحرير إحتجاج فيها على معنى الفصل 317 من م م ت ويبرز من ذلك أن إستصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة التي بقيت دون خلاص يجد له سنداً في مجلة المرافعات وفي المجلة التجارية ودون أن تتحد الإجراءات فيها بينها إذ يجب التمييز بين القانون العام لإستصدار الأمر بالدفع وهو مقتضى الفصول 59 وما بعده من م م ت والقانون الخاص (الفصل 317 من المجلة التجارية) الذي يعطي للكمبيالة قيمة أكبر في وظيفتها الإقتصادية ودعم الثقة فيها كورقة تجارية من خلال تمتيعها بميزة التنفيذ المعجل وقرينة المؤونة وعدم الإحتجاج تجاه الحامل بالعلاقات الشخصية مع المسحوب عليه ولا يمكن لنظام منها أن يقوم مقام النظام الآخر ذلك أن الفصلين 59 و 60 من م م ت هما نصان عامان ينطبقان على كل الأوامر بالدفع بما فيها الصادرة عن إلزامات ناشئة عن كمبيالة وإن إحترام شروط الفصلين المذكورين يكفي لإستصدار الأمر بالدفع ويكون الطعن في ذلك في الأمر بالدفع يعطل تنفيذه وفقاً للفصل 146 من م م ت.

وأما فيما يخص الفصلين 317 و 320 من المجلة التجارية فيتعلقان بتمكين الدائن من إستصدار الأمر بالدفع وتنفيذه بعد أربعة وعشرين ساعة من الإعلام به دون أن يوقف الطعن فيه بالإستئناف تنفيذه إذا ما تم إحترام شرط تحرير محضر احتجاج بالإمتناع بالدفع طبق الفصل 317 من م ت وهي مسألة تتعلق بالتنفيذ المعجل للأمر بالدفع وليست شرطا من شروط إستصداره وعلى هذا الأساس فإن ما دفعت به الطاعنة من خرق للفصل 317 من م ت لا يعتد به لما ذكر وبذلك فإن إستصدار الأمر بالدفع لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج ويمكن إستصداره على معنى الفصل 59 من م م م ت وبمجرد الإنذار وفقا للفصل 60 من م م م ت. وحيث أن الإستناد ضمن الطعن إلى الفصل 320 من م ت في غير محله فهو يجعل للإحتجاج صيغة محددة وإجراء خاص لما له من أثر على التنفيذ ولا يمكن أن يقوم مقامه أي إجراء آخر وهي غير صورة الحال إذ لم يقع اعتبار الإنذار يوم مقام الإحتجاج وتم الإستناد إلى محضر إنذار لإستصدار الأمر بالدفع.

وحيث ولما سبق فإن محكمة الحكم المطعون فيه لم تخرق الفصول 317 و 320 من م ت وأحسن تطبيق الفصلين 59 و 60 من م م م ت بقولها أنه بصرف النظر عن الدفع بوقوع الإحتجاج خارج الأجل القانوني فإن مقتضيات الفصل 59 من م م م ت وما يليه توجب توجيه محضر إنذار بالدفع لا محضر احتجاج بالدفع وهو ما تم إحترامه من المستأنف ضدها التي نهت عليها بالخلاص بتاريخ 15/12/2017 واتجه لذلك رد هذا المطعن.

عن المطعن الثاني المأخوذ من القصور في التسيب وخرق أحكام الفصول 279 و 280 و 282 من م ت:

حيث تضمن المطعن أن المعقب ضدها سيئة النية فهي تعلم بأن الكميالة قد تم عرضها على الخلاص ورجعت بدونه لإنعدام المؤونة وبذلك فهي لا يمكن أن تتمسك بحماية الفصل 280 من م ت فذلك مخول للحامل حسن النية بما يجعل عملية التظهير مستراب في سلامتها وهي ترمي إلى الأضرار بالطاعنة.

وحيث يستدعي الأمر التعرض إلى مسألة حسن النية وعدمها لدى حامل الكميالة عامة وهي تكون لدى ماسك الكميالة الذي يثبت في التوصل بها بسلسلة من التظاهرات غير منقطعة على معنى الفصل 279 من م ت ولا يعد

الحامل سيء النية إلا إذا إكتسبها بدون تسلسل شرعي أي تبعا لحادث عن سوء نية أو بموجب خطأ فاحش.

وحيث أن سوء النية هي مسألة واقعية تستخلصها محكمة الحكم الموضوع من الوقائع المعروضة عليها وهي تخضع لتقديرها ولم تر محكمة الحكم المطعون فيه فيما تولته المعقب ضدها من إجراءات وأعمال لإستخلاص قيمة الكمبيالة سند الأمر بالدفع ما يبعث على الإعتقاد بسوء نيتها طالما وأنها تسلمتها قبل حلول أجل خلاصها وأنها هي التي تولت إسقاطها وهي التي حررت الإحتجاج والإنذار بالدفع وذلك خلافا لما ورد بالمطعن بخصوص العلم المسبق بأن الكمبيالة تم عرضها على الخلاص ورجعت بدونه.

وحيث يقتضي الفصل 280 من م ت أيضا توفر نية الأضرار لدى الحامل أي أن يثبت التواطئ بين الحامل والساحب ومنه يمكن القول بأن الحامل يكون عن سوء نية إذا تسلم الكمبيالة في عملية تداول لا علاقة لها بعملياته التجارية والإقتصادية التي تدخل في صميم عمله أو أنه تواطأ مع الساحب للإضرار بالمدين المسحوب عليه وهو ما يثبت لدى محكمة الحكم المطعون وبات بالتالي الدفع بسوء النية وقصد الإضرار لا سند له وفق ما إنتهت إليه عن صواب محكمة الحكم المطعون فيه وعلى ذلك لا حجية للنزاع المنشور بين الطاعنة والمسحوب عليها حول طلب إسترجاع الكمبيالات ولا يعتد به ولا تجابه به المعقب ضدها باعتباره يهم علاقة الطاعنة بالمسحوب عليها وباعتباره يتناقض مع الوظيفة الائتمانية والإقتصادية التي شرع من أجلها التعامل بالكمبيالة.

وحيث وعلى هذا الأساس فإن محكمة الحكم المطعون فيه لما أضفت على قرينة المؤونة القرينة المطلقة فيما بين المعقب ضدها والطاعنة تكون قد أحسنت الإستخلاص وتطبيق الفصل 275 من م ت فلا يمكن مجابهة الحامل الشرعي للكمبيالة بانعدام المؤونة طالما وأنه مثلما إنتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه حامل شرعي ويتنفع بما يقتضيه الفصل 280 من المجلة التجارية.

وحيث يتجه لما تقدم رد هذا المطعن.

عن المطعن الثالث المأخوذ من انتفاء صفة الحامل الشرعي للمظهر لها ومخالفة الفصل 282 من م ت والفصلين 205 و217 من م ا ع:

وحيث وبالنسبة لصفة الحامل الشرعي فإن هذا الفرع من المطعن سبق التطرق إليه في المطعن الثاني دفعا وردا وأما بخصوص مخالفة الفصلين 205 و 217 من م إ ع فهي مسائل جديدة لم تعرض على محكمة الحكم المطعون فيه ولا تقبل بهذا الطور لأن الطعن بالتعقيب ليس إمتدادا للخصومة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه بمعنى أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي حتى يتسنى للأطراف أن يثيروا لديها ما لهم من مطاعن بل أن نظرها مقصور على إجراء الرقابة على الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا يمكن إثارة مسائل أمام محكمة التعقيب لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام وتعين لذلك رد المطعن».

6 - المسؤولية المدنية والتأمين

6-1 المسؤولية المدنية

6-1-1 عناصر التعويض في المسؤولية المدنية

قرار تعقيبي عدد 80857/81140 بتاريخ 9 مارس 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيدة مريم البكوش وعضوية المستشارين السيد وليد بن جديدية والسيدة عربية الطوبيري وبحضور المدعي العام السيد سفيان العرابي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني.

«حيث من المسلم به أن تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها وإجتهادها في بناء حكمها في الدعوى هو من صميم إختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي إنتهت إليه وعللت ذلك تعليلا سليما بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

وحيث ومع التسليم إبتداء أن القاضي هو الذي يسير ويراقب إجراءات تحقيق الدعوى وله ترجع سلطة الإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها، ومن ثمة له الأخذ بنتيجة الإختبار كلا أو بعض أو الإستعاضة عنها

كلياً متى تبين له عدم وجهة ما أنتهى إليه الخير وذلك بناء على ما لها من سلطة تقدير أعمالاً للفصل 112 م م م ت.

وحيث إقتضى الفصل 107 م ا ع أن «الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها تشمل ما تلف حقيقة لطالبها وما صرف منه أو لا بد أن يصرفه لتدارك عواقب الفعل المضرب».

وحيث نازع المعقب في عناصر الضرر المعتمدة من محكمة القرار المطعون فيه قولاً أنه كان على المحكمة اعتبار عنصر تأثير الفعل الضار على النمو ومردودية القطعة.

وحيث أبانت مستندات القرار المطعون فيه أن المحكمة إعتبرت أن عناصر الخسارة الواجب اعتبارها عملاً بالفصل 107 متقدم الذكر تتمثل في النقص الحاصل في كمية الإنتاج والإنتاجية فقط على أساس أنه ضرر محقق فعلاً فضلاً على أن النقص الحاصل على مستوى نمو النبتة بطبيعته يؤدي حتماً وبالضرورة إلى حصول نقص في الإنتاج.

وحيث لا خلاف في أن تقدير التعويض عن المضرة يرجع لمحكمة الأصل شريطة التعليل السليم وهو ما أستوفاه القرار المطعون فيه حيث بررت المحكمة ردها للأخذ بعنصر النقص في نمو النبتة.

وحيث تكون بذلك محكمة القرار المطعون فيه قد ألزمت حدود سلطتها على الملف في غير إفراط وأتجه لذلك رد هذين المطعنين لا سيما وأنهما يمثلان مناقشة خالصة لإجتهادها في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به ولا معقب عليها من محكمة القانون في ذلك بشرط التعليل الصحيح وهو ما إلتزمت به محكمة الموضوع التي بينت وجه إعتمادها لعنصر النقص الحاصل في كمية الإنتاج والإنتاجية دون بقية العناصر التي اعتمدها الخير».

6-1-2 الصفة في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي في عقد الإيجار المالي قرار تعقيبي مدني عدد 73389.2019 بتاريخ 20 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثانية والثلاثين برئاسة السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية المنتصر ونفيسة العلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الحلواني.

«حيث دفعت الطاعنة بإنعدام الصفة في جانب المحكوم لفائدتها المعقب ضدها الأولى للمطالبة بالتعويض عن قيمة السيارة المتضررة بناء على ثبوت ملكية الشركة العربية الدولية للإيجار المالي لهذه السيارة.

وحيث عرف الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 الإيجار المالي بكونه «عملية إيجار تجهيزات أو معدات أو عقارات مقتناة أو منجرة لغرض الإيجار من قبل المؤجر الذي يبقى مالكا لها، معدة للاستعمال في الأنشطة المهنية أو التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو الصيد البحري أو في الخدمات ويتم الإيجار المالي بمقتضى عقد كتابي لمدة محددة ومقابل معلوم معين ويخول للمستأجر إقتناء تلك التجهيزات أو المعدات أو العقارات أو البعض منها في نهاية أمد الإيجار مقابل ثمن متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار على الأقل في جزء منه المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجار ويمكن للمستأجر إقتناء تلك التجهيزات أو المعدات أو العقارات أو البعض منها خلال مدة الإيجار باتفاق مع المؤجر».

وحيث إن ما يميز عقد الإيجار الموصوف بالفصل المذكور عن بقية العقود هو أنه عقد إيجار على منفعة الشيء المستأجر يمكن أن يؤول في نهاية مدة العقد وبعد إتباع.

المستأجر لإجراءات معينة إلى نقل ملكية الشيء المؤجر للمتسوغ واعتبار المبالغ المدفوعة بعنوان معينات إيجار ثمنا أو جزءا من الثمن.

وحيث تسلط المطعن الحالي على مدى إمكانية اعتبار الطالبة في الأصل المعقب ضدها الأولى الآن لها الصفة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالسيارة والحال أنها مستأجرة لها بموجب عقد إيجار مالي.

وحيث لا جدال أنه ومثلما سلفت الإشارة إليه أعلاه ونظرا للطبيعة الخاصة لعقد الإيجار المالي الذي يؤدي إلى تملك المستأجر بموضوع الكراء بعد خلاص الأقساط المتفق عليها فإن الصفة في القيام تعتبر متوفرة في جانب المدعية في الأصل وعليه فإن محكمة القرار المنتقد لما تجاوزت هذا الدفع وردته ضمينا تكون قد أحسنت تطبيق القانون وترتبيا على ذلك اتجه ردّ المطعن المثار ورفض التعقيب أصلا».

6-2-1 سقوط الدعوى بمرور الزمن للقيام خارج أجل العامين المنصوص عليه بالفصل 14 من مجلة التأمين

قرار تعقيبي عدد 2020 / 22013 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«...عن المطعن الرابع المأخوذ من مخالفة الفصل 14 من مجلة التأمين حيث تأسس المطعن على سقوط الدعوى بمرور الزمن للقيام خارج أجل العامين المنصوص عليه بالفصل 14 من مجلة التأمين

و حيث وخلافا لما ورد بالمطعن فان قيام المدعي في الأصل (المعقب ضده) في طلب مبلغ التأمين المدفوع بموجب العقد الواقع ابطاله تدرج في اطار ممارسة حقه في استرجاع ما دفعه لسبب موجود قد زال تطبيقا لأحكام الفصل 325 من ماع الذي يؤول إلى ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الالتزام الباطل ويسترجع تبعا لذلك ما تم دفعه بموجب العقد المذكور وقد تأسس القيام على حكم الابطال الذي تنطلق منه احتساب آجال القيام على معنى الفصل 14 من مجلة التأمين وطالما أن حكم الابطال لم يصبح باتا الا بموجب صدور القرار التعقيبي في 20/11/2017 فان القيام بالدعوى كان واقعا خلال الأجل القانوني طبق ما انتهت إليه عن صواب محكمة الحكم المطعون فيه وتعين رد المطعن».

6-2-2 التجديد الضمني لعقد التأمين

قرار تعقيبي عدد 80857/81140 بتاريخ 9 مارس 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيدة مريم البكوش وعضوية المستشارين السيد وليد بن جديدية والسيدة عربية الطويهري وبحضور المدعي العام السيد سفيان العراقي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني .

«حيث إنحصرت المسألة المتنازع حولها والتي أسست عليها الطاعنة مستندات تعقيبيها في مدى اعتبار عقد التأمين قد إنسخ من عدمه تبعا للمراسلة الصادرة عن ال«ش. الت. للت. وا. الت. س.» المعقب ضدها الثانية بتاريخ

20/10/2003 والمتضمنة إعلام المؤمن لها بفسخ عقد التأمين بداية من فيفري 2004 تطبيقا للفصل 8 من عقد التأمين والفصل 5 من كراس الشروط كل ذلك إزاء ما تمسكت به المؤمن لها «ش. ف. ق. «المعقبة الآن من كون عقد التأمين قد تجدد بين الطرفين بصفة ضمنية تبعا لدفعها قسط التأمين للثلاثية الأولى لسنة 2004 إستجابة لمراسلة ثانية صادرة عن مؤمنتها لمطالبتها بدفع معلوم التأمين عن الفترة من 01/01/2004 إلى 31/03/2004 وهي فترة لاحقة لموفى السنة التأمينية بما يعني ضمينا إلغاء العمل برسالة الإعلام بالفسخ .

وحيث تناولت محكمة القرار المنتقد دفوعات الطاعنة وجميع طلباتها وبينت أسباب عدم الأخذ بها بناء على ما تمت إضافته لأوراق الملف من مؤيدات تمثلت أساسا في المراسلة الصادرة عن المعقب ضدها الثانية «ش. الت. للت. وا. الت. س. «بتاريخ 20/10/2003 والمتضمنة إعلام الطاعنة الآن برغبتها في فسخ عقد التأمين ومحضر التذكير بفسخ عقد التأمين عدد 19593 المؤرخ في 07-05-2007 والمتضمن تذكيرها بأن العلاقة التأمينية القائمة بينهما قد إنفسخت منذ شهر فيفري 2004 وهي كلها وثائق تثبت بما لا يدع مجالا للشك انقضاء العلاقة التعاقدية التأمينية التي كانت تربط بين الطرفين .

وحيث بالرغم من أنه ليس على المحكمة الجواب على كل دفوعات الخصوم وبإمكانها الالتفات عن الدفوعات التي تعتبرها غير جوهرية إلا أن محكمة القرار المنتقد وخلافا لما ورد على لسان نائب المعقبة قد تولت الإجابة على الدفع المتعلق بخلاص قسط التأمين المتعلق بالفترة الممتدة من 01/01/2004 إلى 31/03/2004 بقولها أن ملف الدعوى خال مما يفيد وجود أقساط خلاص للمدة اللاحقة للثلاثية الأولى لسنة 2004 ومما يؤكد تواصل العلاقة التأمينية بعد سنة 2004.

وحيث أن ما إنتهت إليه محكمة القرار المنتقد كان مؤسسا على معطيات صحيحة وثابتة وكان قرارها مستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم، وعليه فإنها تكون في منأى عن رقابة هذه المحكمة كما ثبت أن جملة الطعون المثارة كانت غير مبررة واقعا وقانونا باعتبار أن القرار المنتقد كان معللا بصفة سليمة يتجلى منها حسن تطبيق القانون وتعين لذلك رد هذه الطعون لعدم وجاهتها».

7 - إجراءات مدنية وتجارية

7-1 الإخلال بالنزاهة في إجراءات التقاضي عند التمسك بالصفة بالطور التعقيبي
قرار تعقيبي عدد 2020 / 24228 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة
المدينة الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة
نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن
بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.
«عن المظعن الأول المأخوذ من خرق الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية
والتجارية.»

حيث أسست المعقبة طعنها على إنتفاء الصفة في القيام في جانب المعقب
ضده لأن معاقبتها ذات معنوية فيما كان القيام من شخص طبيعي.
حيث أثارت المعقبة مسألة الصفة في القيام لأول مرة لدى هذه المحكمة وهو
ما يطرح تساؤلا إن كانت صفة القيام لها علاقة بالنظام العام؟

وحيث تبين من أسانيد القرار المنتقد والأوراق التي أنبنى عليها أن محكمة
الحكم المطعون فيه قد تعهدت بالنزاع بناء على الطعن المقدم من المعقبة
والتي أبدت دفعاتها بشأن النزاع ونازعت في إستحقاق المعقب ضده لمبلغ
الخصم من الضمان ناسبة له الإخلال بالتزاماته للتأخير في إنجاز الأشغال دون
إثارة مسألة الصفة التي دفعت بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب وأن إثارتها
بهذا الطور يناقض مبدأ النزاهة في التقاضي فليس لمن تقاضى مع خصمه ولم
ينكر عليه صفته في كامل مراحل التقاضي ليس له أن يثيره بهذا الطور للطعن
في القرار المطعون فيه وأن التصدي لهذا الدفع الغاية منه عدم حصول تحايل
في الإجراءات وتوظيفها حسب مشيئة مثيرها فالطرف الذي حضر وناقش ودافع
لا يمكنه أن يوظف المسائل الإجرائية للاضرار بغيره ذلك أن الحماية الإجرائية
شرعت لضبط مسألة التقاضي وتحقيق المواجهة الفعلية بين الأطراف ولذلك
ليس لمن توفرت في حقه هذه الضمانات ولم يدفع بالخلل الشكلي وتصدى
لأصل الدعوى أن يعود لاثارها أمام محكمة التعقيب ولأول مرة وتعين لذلك
رد المظعن.»

7-2 الاعتراض على الأحكام في المادة المدنية- شروط الاعتراض على الأحكام المدنية

قرار تعقيبي 2020.21294 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة عن الدائرة الواحد والعشرين برئاسة السيدة آية بن ملوكة وعضوية المستشارتين السيدتين نادرة بن سالم وسلوى سلامة وبحضور المدعي العام السيد مصطفى العجيمي وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«حيث نعي الطاعن على محكمة القرار المنتقد سوء تطبيقها للأحكام المنظمة للإعتراض مناط الفصل 168 وما بعده من م م م ت فهو كطريقة طعن غير عادية لا يشترط لقبوله أن يكون الحكم المعترض عليه باتا بل يفترض فقط أن يكون الحق المؤسس عليه لا يزال قائما ولم يضمحل.

وحيث ثبت بالرجوع إلى مستندات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته أسست قضائها على سابقة الطعن بالإعتراض لآوانه باعتبار أن القرار الإستئنافي المعترض عليه هو محل طعن بالتعقيب لا يزال على بساط النشر.

وحيث بقطع النظر عن مآل الطعن بالتعقيب في القرار الإستئنافي محل الاعتراض المدلى به من طرف نائب المعقب ضده كونه يعد من الحجج الجديدة التي لا يجوز تقديمها لدى هذه المحكمة التي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي والتي لا تسلط رقابتها إلا ما على تناولته محكمة القرار المطعون فيه بالمناقشة وما إستندت عليه من مؤيدات، فإن الفصل 169 من م م م ت أكد صراحة على قابلية كل حكم مهما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه للطعن فيه بالإعتراض ولم يشترط لا صراحة ولا ضمنا صيرورة الحكم المعترض عليه باتا.

وحيث أن الاعتراض على الأحكام مخول وفقا لمقتضيات الفصل 168 وما بعده من م م م ت لكل شخص لم يكن مشمولا في الخصومة الأصلية سواء بصفته طرفا أصليا أو متداخلا أو دخيلا ما دام الحق المؤسس عليه الحكم المعترض عليه لم يضمحل وما دام مضرا بحقوق من لم يكن طرفا فيه.

وحيث أن محكمة القرار المطعون فيه تكون قد أخطأت في فهم وتطبيق أحكام الفصول المنظمة للطعن بالإعتراض بأن إشتطت لقبوله موضوعا صيرورة الحكم المعترض عليه باتا وتكون بذلك قد أضافت شرطا لم تأت به النصوص القانونية

خاصة وأن الأمر يتعلق بمسألة إجرائية يمنع فيها تأويل قواعدها أو التضييق منها أو التوسع فيها».

7-3 التماس إعادة النظر - شروط الطعن بالتماس إعادة النظر

قرار تعقيبي مدني عدد 70655.2018 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثانية والثلاثين برئاسة السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية المنتصر ونفيسة العلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الحلواني.

« حيث نعى الطاعن على محكمة القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 189 و 191 م م م ت بمقولة ان القضاء قد إتصل بالفرع المتعلق بقبول مطلب التماس إعادة النظر شكلا إثر صدور القرار التعقيبي عدد 28136.

وحيث خلافا لما ورد بهذا المطعن فإن القرار التعقيبي عدد 28136 ذاته الصادر بتاريخ 12 أفريل 2016 والمحتج به من طرف الطاعن تأسس على القول بأنه يتعين على محكمة الإحالة إعادة النظر في القضية من الناحيتين الشكلية والأصلية لأن الحكم الاستئنافي عدد 10827 الصادر بتاريخ 12 مارس 2012 المنقوص من إمضاء أحد القضاة والواقع نقضه بموجب القرار التعقيبي عدد 76632 أصبح في حكم العدم وهو ما يتطلب النظر في القضية من جديد من جميع جوانبها مما يوجب بالضرورة على محكمة الحكم المعقب إعادة النظر في القضية من جهة الشكل والاصل معا.

وحيث بات هذا المطعن غير قائم على أسانيد قانونية سليمة واضحى بذلك من المتعين رده.

عن المطعن الثاني بجميع فروعه:

حيث تناول المعقب في صياغته لهذا المطعن مسألتين فرعيتين تعلقت الأولى بالدفع بتوليئه تأمين الخطية بمناسبة رفع الطعن بالتماس إعادة النظر لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية في إطار القضية عدد 10827 والثانية بعدم علمه بعقد التسويغ المحرر سنة 1965 والذي يخول له القيام بجميع الإصلاحات المستلزمة لتعمد المعقب ضدهم إخفاءه مما يجعل الخديعة ثابتة في جانبهم.

وحيث انه جدير بالإشارة إلى أنه قد ثبت بالإطلاع على مطلب التماس إعادة النظر المقدم من طرف الطاعن الآن بتاريخ 03 جوان 2011 انه كان مرفوقا بوصل خلاص الخطية التي أوجبها الفصل 160 م م ت.

وحيث لا جدال ومثلما اقتضته صراحة عبارات الفصل 160 م م ت أن الملتمس مطالب بتأمين معين الخطية التي يمكن تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه مرة واحدة عند تقديم المطلب ولا موجب لإعادة دفعها من جديد في صورة صدور قرار بالنقض من محكمة التعقيب وإعادة نشر القضية مجددا أمام محكمة الإحالة وعليه فإن محكمة الحكم المنتقد تكون قد أساءت تطبيق القانون وأخطأت في تأويل مقتضيات الفصل 160 لما إعتبرت أن الطاعن لم يدل بما يفيد تأمين الخطية المستوجبة قانونا مما أضحى معه الدفع الماثل صائبا وحرى بالقبول.

وحيث ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى أحكام الفصل 156 م م ت يتبين أن المشرع حدد بكل دقة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى الطعن بوسيلة الإلتماس بإعادة النظر فنص بالفقرة الثالثة من الفصل المذكور على أن الورقة القاطعة الممنوعة بفعل الخصم يمكن أن تفتح الباب أمام المحكوم ضده للطعن في ذلك الحكم على شرط أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا.

وحيث لا نزاع في أن غاية المشرع من سن هذه الوسيلة غير العادية للطعن هو التصدي إلى حالات الغش والخديعة التي قد يعتمد عليها أحد الخصوم ليدفع المحكمة إلى إصدار حكمها والذي كان سيتغير منطوقه لولا التغير الذي إعتمده.

وحيث وبناء عليه فانه يتحتم على الملتمس أن يثبت أن حجب الدليل القاطع عن المحكمة قد جعل من الوقائع المعروضة عليها منقوضة مما يشكل حجة على وجود نية الإحتيال لدى الطرف الذي منع الورقة حتى يحسم النزاع لفائدته ولا لفائدة خصمه كما يجب على الملتمس بإعادة النظر أن يثبت اكتشافه للورقة القاطعة بعد صدور الحكم الذي يروم الطعن فيه إذ لا مجال للطعن في صورة ما إذا كانت الورقة القاطعة ممنوعة لا بفعل الخصم بل بفعل الغير ودون أن يكون هناك تواطؤ بينهما.

وحيث وبتنزيل جملة الشروط المذكورة على وقائع قضية الحال ومستنداتها الواقعية والقانونية يتبين أن محكمة الحكم المنتقد لم تستفرغ جهدها في تمحيص الدفوعات المقدمة إليها والتعمق فيها لما لها من الأهمية على وجه الفصل بمزيد التحري والتثبت في مدى توفر الشروط القانونية الواردة بالفصل 156 من عدمه.

وحيث خلافا لما انتهجته محكمة القرار المنتقد في قضائها فإن الاستناد إلى عقد الكراء المؤرخ في غرة ماي 1965 في قضايا سابقة منشورة بين المعقب ضدهم الآن والمالك السابق للأصل التجاري المدعو (أ. د.) لا يعد قرينة قاطعة على علم الطاعن الآن بوجود هذا العقد خاصة في ظل وجود عقدين متتاليين في الزمن يتعلقان بنفس المكروى وبفس طرفي التسويغ فضلا عن ثبوت التنصيص فقط على عقد الكراء المؤرخ في 30 أبريل 1961 صلب عقد شراء الأصل التجاري من طرف المعقب دون العقد سند القيام بمطلب التماس إعادة النظر.

وحيث كان على محكمة الحكم المطعون فيه القيام بمزيد من الاستقراءات وتمحيص كافة الدفوعات التي أحتج بها طرفي النزاع للتحري في خصوص واقعة علم الطاعن الآن المسبق بوجود عقد التسويغ المؤرخ في غرة ماي 1965 قبل صدور حكم نهائي الدرجة في قضية الفسخ من عدمه.

وحيث وعلى الرغم من أهمية هذا الدفع وتأثيره على وجه الفصل في النزاع باعتبار أن عقد التسويغ المدلى به في إطار قضية الحال خول للمتسوغ إمكانية القيام بجملة من الأشغال بالمكروى من ماله الخاص ومنها إمكانية إحداث باب داخل المستودع على خلاف ما إنتهت إليه المحكمة الملتمس إعادة النظر في حكمها فإن محكمة القرار المطعون فيه لم تبذل قصارى جهدها للتحري فيه ولم تستجلي مدى وجاهته وبما أنها لم تفعل فإن تعليلها أضحى متسما بالقصور لعدم تركيزها قضاءها على معطيات ثابتة وقراءتها الأدلة المقدمة قراءة صحيحة تجعلها تنأى عن الإنحراف بها عن معناها وتُصيّرُها مبينة لوقائع غير صحيحة مما يوهن حكمها ويعرضه للنقض وتعين القضاء به مع الاحالة لإعادة النظر من جديد فيما تسلط عليه النقض».

7-4-1 إجراءات إعادة النشر والمراكز القانونية للأطراف

قرار تعقيبي عدد-2019 / 71919 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«عن المطعن الأول المأخوذ من خرق الفصل 191 من م م م ت.

حيث يدفع الطاعن بأن القرار المنتقد أدخل تغييرا على المراكز القانونية التي يشغلها الطرفين بما يشكل خرقا للفصل 191 من م م م ت.

حيث أنه من الثابت أن المعقب ضده - المدعي في الأصل - قد إستصدر حكما ابتدائيا في التعويض ضد الطاعنة - المدعى عليها في الأصل - التي تولت الطعن فيه بالإستئناف ثم بالتعقيب وتم نقض القرار المطعون فيه وقد أعيد مطلب النشر من جديد أمام محكمة الإحالة كمحكمة إستئناف بما يعني تناول الطعن وفق المراكز القانونية التي توافق الإستئناف المنقوض فالمستأنف في القرار المنقوض لا يمكن أن يتحوّل إلى مستأنف ضده ولا يتحول مركز المستأنف ضده إلى مستأنف أمام محكمة الإحالة التي تنتصب للقضاء بإحالة من محكمة التعقيب فهي تعوّض المحكمة التي سبقتها في النظر وتم نقض قرارها والتي ترفع يدها عن إعادة النظر وعليه فإنها لا تجري تغييرا على مراكز الأطراف عدى صورة الطعن من الطرفين فيكون كلاهما مستأنف ومستأنف ضده.

وحيث وفي النزاع الحالي فالثابت أن الطاعنة هي التي كانت مستأنفة في القرار المنقوض وأن إعادة النشر لا يخرجها عن تلك الصفة فتظل دوما مستأنفة ويضاف إليها صفتها تلك صفة «المعاد ضدها النشر» وهي صفة ترتبط فقط بمطلب إعادة النشر ولا تغير في مركزها كمستأنفة وقد إعتبرتها محكمة الإحالة «مستأنف ضدها» وجعلتها بالتالي في مركز يخالف مركزها الحقيقي ولكن مع التنصيص أيضا على كونها «معاد ضدها النشر» وهو المركز الذي يضيفه عليها مطلب إعادة النشر.

وحيث أن الخطأ في مركز الطاعنة (المستأنفة) لم يكن له تأثير عند نظر المحكمة في أصل النزاع فهو لم يغير من المعطيات والوقائع الثابتة في الملف ولم يكن له تأثير على فصل النزاع المعروض على محكمة الحكم المطعون فيه وفق ما تسلط عليه النقض وهو بذلك لا ينال من سلامة الحكم طالما أن النتيجة كانت صحيحة سيما وأن الأصل في الأمور هو أن مطلب إعادة النشر يرفع لمحكمة الإحالة من الطرف الأحرص على حقوقه وهو في صورة الحال المدعي في الأصل بما يعني أن مسالة إعادة النشر تتعلق بمصلحة شخصية وأن من يتمسك لذلك ببطالان الإجراء أن يثبت تضرره منه.

وحيث وتبعاً لما سبق فإنه لا موجب لنقض القرار المطعون فيه طالما وأنه كان صحيحاً في نتيجته وتعين لذلك رد المطعن».

7-4-2 إعادة النشر ونطاق تعهد محكمة الإحالة

قرار تعقيبي عدد 67362 بتاريخ 6 جانفي 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيدة مريم البكوش وعضوية المستشارين السيد وليد بن جديدية والسيدة عربية الطويهري وبحضور المدعي العام السيد سفيان العرابي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني .

«حيث يقتضي النظر في وجهة المطعنين المثارين تأطير الأمر بمساره الصحيح على نحو مؤداه ان نظر محكمة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة محكوم - بالضرورة وعملاً بالفصل 191 م م م ت - بنطاق ما تم تعهدها به من قبل محكمة التعقيب بموجب قرارها عدد 17295 بتاريخ 11/06/2015 الذي إقامته على فكرة جوهرية مفادها أن سند الدعوى الأصلية كان مؤسساً على عقد بناء مؤرخ في 25/09/2009 غير مسجل وهو ما يشكل خرقاً للفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.

وحيث أبانت مستندات القرار المطعون فيه أن المحكمة قدرت أن القرار التعقيبي سند تعهدها لم يبت في بقية المطاعن المتعلقة بأصل النزاع وهو ما يخول لها - كمحكمة إحالة - النظر فيه بعد أن تم تلافي الخلل الشكلي الذي من أجله قضت محكمة التعقيب بالنقض والإحالة.

وحيث من الأهمية بمكان التأكيد على أنه في غير الحالات التي يكون فيها النقص الصادر عن محكمة التعقيب كلياً أي أن يقع تعهيد محكمة الدرجة الثانية بإعادة النظر في الطعن برمته، فإن محكمة الإحالة تكون ملزمة قانوناً - في صورة النقص الجزئي - بالالتزام بأسباب النقص أو ما كان مترتباً عنها وجوباً وبالضرورة ومن ثمة عدم تناول ما خرج عن ذلك عملاً بالفصل 176 م م ت القاضي بأن محكمة التعقيب تقتصر على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر إبطال الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقص.

وحيث ثبت بمراجعة القرار التعقيبي عدد 17295 أن محكمة التعقيب قدرت أن اعتماد عقد غير مسجل يستوجب النقص» وذلك بصرف النظر عن باقي المطاعن «و مؤدى ذلك هو أنها لم تبت في تلك المطاعن مطلقاً.

وحيث ولئن كان وجيهاً ما أكدته محكمة الإحالة من أن المطاعن التي خرجت عن سبب النقص لم يتصل بها القضاء لعدم البت فيها وردّها من محكمة التعقيب، إلا أن ذلك لا يخول لها - كمحكمة إحالة - إعادة النظر فيها على تقدير أن النقص لم يتناول سوى مسألة تسجيل العقد وعليه كانت مراجعة محكمة الإحالة لأدلة الدعوى وإستبعادها للاختبار المجرى فيها ونظرها في مطاعن خارجة عن أسباب النقص غير مستندة لما يبررها قانوناً عملاً بالفصلين 176 و 191 م م ت.

وحيث ثبت عدم تعاطي محكمة الحكم المطعون فيه مع أسباب النقص سند تعهدها على النحو الأكمل فكان النعي عليها من قبل المعقب مخالفة القانون وضعف التعليل مبرراً وهو ما يؤسس لوجهة هذا الطعن أصلاً».

7-5 توزيع أموال - جميع الدائنين لهم حق التخاصص

قرار تعقيبي عدد 66270 بتاريخ 27 جانفي 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى المتركة من رئيسها السيد البشير المطوي وعضوية المستشارين السيدة مريم البكوش والسيد وليد بن جديدية وبحضور المدعي العام السيد سفيان العرابي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني.

«عن المطعن الوحيد المأخوذ من سوء تأويل الفصلين 464 و 468 م م ت:

حيث ان الإشكال القانوني المطروح في قضية الحال ينحصر أساسا في تحديد ما إذا كان الحق في طلب توزيع المال المؤمن مقتصر على الدائن العاقل أو المعارض أو أنه يحق لجميع دائني المدين مهما كان نوعهم المشاركة في توزيع ذلك المال.

وحيث خلافا لما دفع به المعقب فان الفصل 313 من م م ت لا يتعلق بتحديد شروط توزيع المال المؤمن ومن هم الدائنون المخول لهم الحق في المشاركة في التوزيع وإنما وضع قاعدة تتعلق بشروط العقلة فنص على أنه لا يمكن القيام بعقلة ثانية على شيء تمت عقلته سابقا وأنه اذا تولى دائن القيام بعقلة ثانية فإن هذه العقلة تعتبر إعتراضا كما أكد المشرع بالفصل 314 من نفس المجلة على أنه يحق للدائن المعارض المساهمة في توزيع الثمن المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا دون إقصاء بقية الدائنين ودون أن ينص على أن الحق في المشاركة في التوزيع مقتصر على المعارض فحسب.

وحيث ومن جهة أخرى نص الفصل 465 م م ت على أنه «لكل معني إذا تم تأمين المال أن يطلب توزيعه...».

وحيث وخلافا لما تمسك المعقب بأن الحق في طلب التوزيع مقتصر على الدائنين العاقلين أو المعارضين يتعارض مع عموم العبارة المستعملة بالفصل 465 إذ أن تنصيب المشرع على عبارة «لكل معني» يقصد بها أنه يحق لكل دائن المشاركة في التوزيع دون أي تمييز الأمر الذي يتماشى والقاعدة القانونية العامة المنصوص عليها بالفصل 533 م اع التي اقتضت أنه إذا كانت عبارة النص مطلقة فهي تجري على إطلاقها.

وحيث وفي ذات الاتجاه تتجه الإشارة إلى أنه لا يمكن تفسير إجراءات الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المشترطة في إطار عملية التوزيع إلا برغبة المشرع في دعوة كافة الدائنين سواء كانوا عاقلين أو غير عاقلين أو معترضين أو غير معترضين لطلب المحاصة وهو ما أكدته عبارات الفصل 468 م م ت التي إقتضت صراحة أنه «على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي بكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الإتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب

وحيث يتبين مما تقدم أن محكمة الحكم المنتقد إلتزمت في تسبب قضاائها - القائل بأن المشاركة في التوزيع على المتحصل من البيع لا تتوقف على شرط القيام بالإعراض - بمقتضيات الفصلين 465 و 468 م م م ت معتمدة في ذلك على تعليل صحيح دون خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع مما يتعين معه رد هذا الطعن».

قرار تعقيبي عدد 2020/80 بتاريخ صادر 21 فيفري 2020 عن الدائرة التاسعة عشر برئاسة السيدة حياة البصلي وعضوية المستشارين السيد الأنور الكعلي والسيدة هاجر الخالدي وبمحضر المدعي العام السيد لطفي بن سليمان ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

وحيث اقتضى الفصل 8 من م م م م ت في فقرته الأولى أنه « يسلم النظر إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال». كما إقتضى الفصل 7 من نفس المجلة أن «المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقراً أصلياً له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي».

255

كما لا خلاف في أن النص الإجرائي لا يحتمل التوسع في تأويل أحكامه لما في ذلك من الأثر على سلامة الإجراء.

وحيث عدّد الفصل 8 من م م م م ت في فقرته الأولى الطرق الواجب إتباعها في التبليغ أو الإعلام وأن هذه السبل جاءت بصفة حصريّة من ذلك أن الأصل في الإعلام هو أن يتم بين يدي الشخص المعني مباشرة وفي هذه الحالة فليس هناك أي اعتبار لمكان التبليغ طالما توصل المبلغ إليه بنفسه بالوثيقة موضوع التبليغ أو الإعلام وأنه وفي حال تعذر التبليغ أو الإعلام لذات الشخص فإنه يتعين إتمام ذلك بمقره الأصلي أو بمقره المختار وذلك بحسب الأحوال وأنه يفهم من عبارة «بحسب الأحوال» هو أن المشرع لم يوجب ضرورة أن يكون التبليغ أولاً بالمقر الأصلي ذلك أنه متى ثبت أن أحد الخصوم قد اختار صراحة مقراً بذاته في التبليغ فإن ذلك المقر يأخذ قانوناً صبغة المقر المختار ويكون بالضرورة المقر القانوني الواجب اعتماده عند التبليغ كل ذلك شرط أن يكون الطرف الذي تمسك بذلك قد اختار لنفسه مقراً ثابتاً ومعلوماً وحدد نطاق الخصومة المتصلة به والأهم من ذلك أنه اعلم به خصمه طبق ما يقتضيه القانون. الأمر الذي يستخلص منه أن ما خرج عن ذلك من صيغ التبليغ أو الإعلام هو تبليغ مخالف لمقتضيات الفصل 8 المتقدم وبالتالي ليس من قبيل الإعلام أو التبليغ الواقع طبق القانون.

وحيث وبالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن المدعية في الأصل، ومنذ رفعها لدعوى الحال، عينت محل مخابراتها بمكتب محاميتها الأستاذ «أ.الح.» وهو العنوان الذي اعتمدته المعقبة في التنبيه عليها، بموجب محضر التنبيه باختيار محل مخابرة محرر بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ «ن.أ.» بتاريخ 13 / 7 / 2016 تحت عدد 043621، بأنها اختارت مكتب محاميتها الأستاذ «الم.ب.» الكائن ... مقراً مختاراً لها فيما يتعلق بجميع المحاضر والإعلامات والتنبيه والاستدعاءات وغيرها وفي جميع النزاعات القائمة والتي سيقع رفعها ضدها. فكان من الثابت مما سبق أن التنبيه باختيار محل مخابرة قد وجه للمعقب ضدها في عنوانها القانوني والمختار منها وتم تبليغ محضر التنبيه طبق القانون ما يفترض وجوباً علمها بمضمون التنبيه كما أنه من الثابت أن التنبيه قد تضمن تنصيها صريحاً على أن المقر الذي اختارته المعقبة يتعلق بمنازعتها مع المعقب ضدها في التداعي الحالي سواء في طوره الابتدائي أو غيره من بقية الاطوار وحتى في غير التداعي

الحالي وهو ما يفهم من عبارات «وفي جميع النزاعات القائمة والتي سيقع رفعها ضدها». كما انه من الثابت ان التنبيه المذكور قد تم خلال نشر التداعي الابتدائي وبالتالي فهو سابق للطور الاستئنافي ولعريضة استئناف المعقب ضدها وان هذه الاخيرة وعلى الرغم من علمها المسبق بالعنوان المختار من المعقبة إلا أنها ضمّنت صلب عريضة إستئنافها عنوانا مغايرا للمقر المختار من المعقبة وأن هذا العنوان كان هو المعتمد من محكمة الإستئناف عند إستدعائها للمستأنف ضدها (المعقبة الآن) فكان بذلك إجراء الإستدعاء الإداري قد تأسس على معطى مغلوط في خصوص عنوان المستأنف ضدها والمضمن بعريضة الإستئناف المحررة من المستأنفة (المعقب ضدها الآن).

وحيث وخلافا لما دفعت به المعقب ضدها فإن إجراء تبليغ المستأنف ضده بموعد الجلسة ولئن كان محمولا على كتابة المحكمة على معنى أحكام الفصل 223 من م ش إلا أن سلامة التبليغ تبقى موقوفة على صحة العنوان المقدم من المستأنف ضمن عريضة طعنه الأمر الذي لم يتوفر في دعوى الحال وذلك بمثل ما سلف بسطه.

وحيث وفضلا عن ذلك فقد أحال الفصل 223 من م ش فيما يتعلق بسبل التبليغ على الفصل 202 من م ش وأن هذا الأخير نص في فقرته الأخيرة على أنه «بأذن رئيس دائرة الشغل بإستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الإستدعاء بصفة شخصية» وثبت من أوراق الملف أن المحكمة، وحين تعذر تبليغ المستأنف ضدها (المعقبة الآن) بالطريقة الإدارية أذنت تحضيريا بإستدعائها من طرف المستأنفة بواسطة عدل تنفيذ وأنه وتنفيذا لذلك تولت المعقب ضدها استدعاء المعقبة لجلسة الطور الاستئنافي بواسطة عدل التنفيذ وذلك في مقرها المضمن بعريضة الإستئناف وهو غير مقرها المختار وذلك على الرغم من أنه كان من الثابت من أوراق الملف من كون المستأنفة كانت على علم تام بالمقر القانوني للمستأنف ضدها وهو مقرها المختار وذلك رجوعا إلى محضر التنبيه بإختيار محل مخاطرة وخاصة بما تبين أيضا من كون المستأنفة قد تولت إعلام المستأنف ضدها بالحكم المطعون فيه بمقرها القانوني الصحيح وجاء في محضر الإعلام بالقرار المنتقد بأن محل مخاطرة المستأنف ضدها هو مكتب الأستاذ «م. ب.» وفي ذلك إقرار من المستأنفة (المعقب ضدها الآن) بأن المقر القانوني

للمستأنف ضدها هو مكتب نائبها الأستاذ «م. ب.» وليس ما ضمنتها بعريضة طعنها بالإستئناف.

وحيث لا خلاف في أن استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو اجراء جوهرى لصحة الحكم ذلك ان مبنى الخصومة هو مبدأ المواجهة بين الاطراف وان هذا المبدأ لا يمكن ان يتحقق ما لم يكن اجراء التبليغ المتعلق بنشر الدعوى امام المحكمة بمختلف اطوارها قد تم طبق ما يقتضيه القانون فتكون بذلك المحكمة المتعہدة بالنظر في القضية ملزمة بمراقبة الاستدعاء وفق الاجراءات القانونية للتأكد من سلامة اجراءات التبليغ خاصة في صورة عدم حضور المستدعى

وحيث طالما كان من الثابت مما سبق بسطه ان اجراءات تبليغ الاستدعاء الموجه للمستأنف ضدها لجلسة الطور الاستئنافي سواء بالطريقة الادارية أو بواسطة عدل التنفيذ قد تمت في غير العنوان القانوني وهو عنوان المقر المختار منها ما تعذر معه على المستأنف ضدها (المعقبة الآن) حضور الطور الاستئنافي والدفاع عن مصالحها. وطالما كانت القواعد المنظمة لاجراءات التبليغ عامة والتي لها صلة بالمقر خاصة تعتبر من القواعد التي تهتم النظام العام وهي قواعد اجرائية جوهرية يترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الاجرائي فان ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد قولاً بان المستأنف ضدها (المعقبة الآن) لم تحضر وانه بلغها الاستدعاء طبق القانون فيه هضم لحق الدفاع وخرق لاحكام الفصول 6 و 7 و 8 من م م م ت ما يتجه معه والحالة تلك نقض الحكم المطعون فيه في هذا الجانب وذلك دون الخوض في بقية المطاعن».

7-7 شروط استصدار الأمر بالدفع

قرار تعقيبي عدد 68585 بتاريخ 9 مارس 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى برئاسة السيدة مريم البكوش وعضوية المستشارين السيد وليد بن جديدية والسيدة عربية الطويهرى وبحضور المدعي العام السيد سفيان العرابي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني.

«عن المطعن الوحيد المأخوذ من خرق أحكام الفصل 59 م م م ت والخطا وتطبيقها والفصل 3 من العقد و242 م ا ع و705 م ت وضعف التعليل والاخلال بحق الدفاع:

حيث خص الفصل 59 م م م ت بعض الديون المحمولة على كونها ثابتة والناشئة عن سبب تعاقدى أو ورقة تجارية كالشيك والكمبيالة أو عن سند قرض عملاً بالقانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض بإجراء لا يقتضي المواجهة يؤول إلى استصدار سند قضائي في شأنها واستخلاصها وهو إجراء الأمر بالدفع، والطعن فيه بالاستئناف يفتح باب المواجهة بين أطرافه ويمنح الطاعن الحق في مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات المدلى بها.

وحيث ولئن استند الأمر بالدفع محل المنازعة على سند لأمر إلا أن الخلاف قد احتدم بين طرفي التداعي بخصوص مدى توفر شروط إجراءات الأمر بالدفع إزاء ما تم الدفع به من نائب المأمورين بالأداء المعقبين إلا - سواء أمام محكمة القرار المطعون أو أمام هذه المحكمة - من كون الدين محل نزاع جدي في أصله ومقداره باعتباره ليس هو أساس علاقة الطرفين باعتبار وإن استصداره كان بعنوان ضمان عند فتح الاعتمادات البنكية وبالعملة التي سيتم بها الصفقة، وأنه من المتعين الاستناد إلى الاعتمادات البنكية للتحقق من متخلد الدين الحقيقي وذلك باعتقاد اتفاق الطرفين حول تنزيل الاعتمادات وكيفية احتساب الفوائض باعتماد النسب المتفق عليها لاختلاف نسب الفوائض بالنسبة للتمويل بالدينار التونسي على نسبة الفوائض بالنسبة للتمويل بالعملة الأجنبية مستدلاً بأعمال الاختبار المنجز من قبل الخبير ر.إ. المنتدب بموجب إذن على العريضة.

وحيث ثبت رجوعاً إلى القرار المطعون فيه أن المحكمة أسست قضاءها بإقرار الأمر بالدفع المطعون فيه أمامها على أنه قد ثبت بالرجوع إلى الاختبار المنجز من الخبير «ر.إ.» أن المعاملة بين الطرفين تأتي في إطار عقد تجديد قرض اعتمادات مؤرخ في 29/10/2015 تولى بموجبه البنك تجديد منح المعقب إلا أن خط تمويل للتعهدات بالتوقيع بسقف قدره 500 ألف دينار كاعتمادات مرصودة لتمويل القروض الاستيرادية بالعملة الصعبة وأنه في هذا الإطار تم التمويل بالدينار في شكل مكشوف على الحساب وأنه قد تم التحقق من تنزيل المبلغ موضوع سند الأمر بحساب الطاعنة كما قدرت المحكمة عدم ثبوت تعمد البنك تغيير التواريخ للحصول على خلاص الدين مرتين أو مبادرته بقطع التمويل بصفة تعسفية.

وحيث ابانت مطروقات الملف وما تضمنته اقوال طرفي التداعي على قيام منازعة جدية بخصوص الدين ولا سيما نسبة الفوائض السارية على أصل الدين.

وحيث ان في قيام منازعة جدية في المديونية ما يتعارض وخصوصية الأمر بالدفع مناط الفصل 59 وما بعده من م م م م ت ضرورة ان طبيعته التي تتسم بالاستعجال تأبى ان تثار في اطار الطعن فيه مسائل تتعلق بأصل الحق وخاصة مسائل تستوجب البحث والتقصي اذ ان هذه المسائل يضيق مجال بسطها في حدود طور واحد من التقاضي اذ غني عن البيان ان استصدار الأمر بالدفع يكون من خلال اتباع اجراءات يغيب فيها عنصر المواجهة، فالطاعن في سند الأمر بالدفع يكون محروما من طرح منازعته على درجتين للتقاضي.

وحيث يؤخذ مما تقدم أن محكمة القرار المطعون فيه لم تصب المرمى بإقرارها الأمر بالدفع ما يتعين معه قبول الطعن أصلا».

7-8 بطلان القيام ضد ميت لفقدانه لأهلية التقاضي

قرار تعقيبي عدد 81803.2020 بتاريخ 3 مارس 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

« عن المطاعن المأخوذة من خرق ما استقر عليه فقه القضاء وتحريف الوقائع وضعف التعليل لاتحاد القول فيها:

حيث كان الطعن الشكلي موجها وفق انعقاد مرجع تعهد محكمة الاحالة «إعادة النشر» المصدرة للحكم المطعون فيه ان المحكمة تجاهلت قرار دوائر المجتمعمة المكرس لنظرية الظاهر عند القيام كعدم رد المحكمة على ما توفر بالملف من اعلامات موضوع التنايه والاستدعاءات التي رجعت للمعقب ضدهما بالمكرى مما ينفي فرضية عدم العلم.

حيث وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ثبت ان المحكمة اعتبرت ودون الخوض في عدد التنايه والاعلامات الموجهة للمعقب ضدهما بالمكرى موضوع التداعي ان الفصل 19 م م م ت:» اقتضى أن حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق ويجب

أن تكون للقائم مصلحة في القيام... ومن واجب المحكمة رفض الدعوى اذا تبين لها من أوراق القضية ان أهلية الطالب منعدمة».

وحيث اعتبرت محكمة الاحالة ان القيام على ميت قيام باطل وهو غير قابل للتصحيح وبينت أن القيام الحاصل على مورث المعقب ضدهما كان لاحقا لوفاته في 30/08/2013 وأكدت أن القيام لا يصحح مستشهادة بقرار تعقيبي لانعدام الاهلية في المقام ضده ولان التصحيح يحرم الورثة من درجة من درجات التقاضي.

وحيث ذهبت محكمة القانون في قرار صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 124 الصادر في نوفمبر 1999 ان رفع الطعن ضد ميت باطل لعدم أهلية الميت لرفع الطعن ضده ما لم يتضح أن الظروف السابقة عن الطعن تجعله جاهلا للوضعية القانونية الصحيحة...».

وحيث انه خلافا للمطعن فإن المبدأ انه لا جواز للقيام على ميت لفقدانه للأهلية وعدم صحة ذلك القيام من حيث ممارسة الدعوى والمساس بحق الورثة ان وجدوا بامكانية حرمانهم عند تصحيح القيام من درجات من التقاضي أو من حق التقاضي أصلا.

وحيث ان القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة على إلزاميته قرن قبول الطعن الحاصل ضد ميت بجهل الطاعن بالوضعية القانونية واعتبرت ان في ذلك تكريس لنظرية الأمر الظاهر الا ان مضروقات الملف من ذلك الاستدعاءات والتنابيه لم تكن حاصلة على قرينة العلم لكلا الطرفين كما ان التنابيه الموجهة للمعقب ضدهما والسابقة للقيام كانت موجهة من مالكي المكري الاصيلين وان المعقب ضدهما لم يتعمدا وفق المعطيات بالملف إخفاء الوضع المتعلق بواقعة الوفاة على ان الأمر الثابت ان الدعوى الحالية انطلقت من التنبيه بالتصريح بوضعية المتسوغ والذي صدر ضد ميت مما يصيره غير ماض ولا عمل عليه.

وحيث ان محكمة الاحالة وتدعيما لوقفها اعتبرت ان التبليغ لم يكن شخصا لحصوله على معنى الفصل 8 مرافعات بينما اعتبرت الطاعنة انها احترمت اجراءات النص وان العبرة بترك النظر وان كان موقف المحكمة من التبليغ غير متماش مع روح النص ومع تمام حصول الاجراء ذاته فإن المحكمة اعتمدت

ذلك التعليل بغاية القول ان التبليغ ليس شخصا ليعتبر العلم حاصل ويصبح القيام مصححا وفق مقتضيات نظرية الأمر الظاهر وقاعدة حلول الورثة محل موثهم وفق الفصل 241 م م م ت».

7-9 الاختصاص الحكمي - الاختصاص الحكمي في نزاعات الكتائب التكميلية يرتبط بقيمة الكتب الأصلي

قرار تعقيبي عدد 75784.2020 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«عن المطعن المأخوذ من خرق أحكام الفصلين 22 و 23 م م م ت:

حيث كان المطعن الاجرائي صلب مستندات التعقيب في عدم بسط محكمة الحكم المطعون فيه رقبتها على مدى اختصاص محكمة الحكم المطعون فيه لديها بالرجوع إلى نوع الدعوى ومدى تقديرها.

حيث اقتضى الفصل 21 م م م ت: «أن مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب».

حيث افترض نائب المعقب ان الدعوى المقامة من المعقب ضده غير مقدرة باعتبار أن الطلب لم يكن في مقدار مالي بل في إلزام منوبه بإبرام عقد تكميلي بعد سبق التعاقد على محل العقد منذ سنة 1985 واعتبر ان محكمة الناحية التي تعهدت بالدعوى غير مختصة حكما لأن الدعوى غير مقدرة وأن المحكمة الابتدائية هي المختصة حكما تطبيقا للفصل 22 م م م ت الذي منح الاختصاص للمحكمة المذكورة إذا كانت قيمة المتنازع فيه غير معينة أو غير قابلة للتعين .

حيث خلافا لموقف الطاعن فإن عقد البيع المؤرخ في 1985 والمراد إبرام عقد تكميلي لتصحيحه ماديا تضمن ثمن المبيع وهو مقدار أو قيمة قابلة للاعتماد والتقدير وقد استقر فقه قضاء محكمة القانون على ذلك تأصيلا لمبدأ تقدير قيمة الدعوى من قيمة العقود وذلك لتحديد مرجع النظر الحكمي تطبيقا للفصل 21 م م م ت.

حيث إن قول الطاعن أنه لا يمكن الاستناد إلى قيمة المبيع المضمنة بالعقد لتحديد الاختصاص لأن المشرع أجاز تلك القيمة بخصوص عقود التسويغ وقصرها عليها قول مردود لأن المشرع أطلق التقدير للمحكمة من العقود عامة ومن غيرها من إمكانيات التقدير وأن الثمن المحدد وجوباً في عقد البيع يمكن الاستناد إليه كميّار لتحديد قيمة الدعوى المالية لتحديد الاختصاص الحكمي. كما أن تخصيص المشرع الفصل 23 م م ت لتحديد مرجع النظر في عقود التسويغ من مقدارها العيني السنوي لا ينفي اعتماد القيمة بالنسبة لباقي العقود مادامت تضمنت مقدارا محدداً لقيمة مادية تمكن المحكمة من تحديد الاختصاص وهو اتجاه استقر عليه فقه القضاء وأقرته الدوائر المجتمعة في قرارها عدد 34428 الصادر في 1997/7/4 وتعين رد المطعن لانعقاد اختصاص محكمة الناحية باعتبار أن ثمن المبيع كان أقل من سبعة آلاف دينار وتعين رد المطعن الاجرائي لوهنه».

7-10 الاختصاص الترابي النوعي يهم النظام العام

قرار تعقيبي عدد 20567 بتاريخ 13 جويلية 2020 صادر عن الدائرة المدنية الأولى المتركة من رئيسها السيد بشير المطوي وعضوية المستشارين السيدة مريم البكوش والسيد وليد بن جديدية وبحضور المدعي العام السيد سفيان العرابي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني.

حيث تمسك المعقب بأن محكمة القرار المنتقد خرقت الفصلين 330 و343 من م م ت لما أقرت باختصاصها بالنظر في النزاع حال أن الموضوع يتعلق بتصحيح إجراءات عقلة توجب رفعه أمام المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين كما خالفت أحكام الفصل 672 من م م ت التي تمنع إمكانية تثقيل أحد الطرفين لذمته تجاه الآخر بمبالغ تتجاوز مقدار الوديعة وأفرطت في السلطة عندما قضت لصالح الدعوى حال أن الحساب مجمد وتم قفله بصفة ضمنية واستناداً إلى كتب غير مسجل فضلاً عن إغفالها عرض الملف على النيابة العمومية لحصول التمسك بخرق قواعد الاختصاص الترابي.

و حيث وبخصوص الدفع المتعلق بعدم الاختصاص فقد اقتضى الفصل 343 من م م ت أن «طلب تصحيح العقلة أو رفعها يقدم إلى المحكمة التي بدائلتها مقر المدين المعقول عنه» .

و حيث يستروح من أحكام الفصل المذكور أن الاختصاص بالنظر في دعاوى تصحيح العقل التوقيفية تحكمه قواعد خاصة نص عليها صراحة المشرع بالفصل 343 أعاد من خلالها التأكيد على وجوبية مقاضاة المدين أمام المحكمة الكائن بدائلتها مقره ، وهذه القاعدة لا يُعتقد الأطراف من واجب احترامها عند القيام ولا تُعفي المحكمة من الالتزام بها واثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ذلك ، انه -مع التسليم بتعلق الأمر باختصاص ترابي - الا انه يجب الا يغيب عن الازهان ان بعض قواعد الاختصاص الترابي وبحكم خصوصيتها والهدف الذي ينشده المشرع في توزيع الاختصاص تهم النظام العام وان احكامه ملزمة للأطراف والمحكمة وان الفقه وفقه القضاء على قول واحد في هذه المسألة وهذا الأمر يتحقق كلما خص المشرع محكمة بذاتها - بعد تحديدها تحديدا تريايا - بنظر صنف من الدعاوى معين بذاته هو الاخر ومن امثلة ذلك الطعن بالاعتراض الذي لا يصح ان يكون الا لدى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض عليه بدليل ما جاء بالفصل 170 م م ت وكذا الدعاوى المتعلقة بالاجراءات الجماعية والدعاوى المرتبة بها التي ترفع للمحكمة التي بدائلتها المقر الرئيسي للمدين عملا بالفصل 414 م م ت ودعاوى الضمان التي ترفع للمحكمة المنشورة لديها الدعوى الاصلية عملا بالفصل 37 م م ت وقضايا تبنت العقارات المعقولة التي ترفع لدى المحكمة التي بدائلتها العقار حتى اذا ما تعلق بأكثر من عقار موجود بدوائر محاكم مختلفة فان البتة تقع امام المحكمة التي بدائلتها اهم عقار رجوعا للفصل 424 م م ت ودعاوى الملك التجاري عملا بالفصل 28 م م ت والدعاوى الاستحقاقية التي ترفع أمام المحكمة الكائب بدائلتها العقار عملا بالفصل 38 م م ت .. والامثلة تتعدد وان الدعاوى المتعلقة بتصحيح اجراءات العقلة - على نحو التداعي المائل - لا تشذ على هذه القاعدة حيث خص المشرع بها المحكمة التي يقع بدائلتها مقر المدين حصرا عملا بالفصل 343 السالف الإشارة اليه .

و حيث من الثابت ان المشرع في تحديده للمحكمة المختصة تريايا في دعاوى تصحيح اجراءات العقلة التوقيفية وغيرها من الدعاوى - على نحو ما ضرب

مثل به أعلاه ذكرا لا حصرا - انما خرج عن القاعدة العامة في اعتبار القواعد التي تضبط مرجع النظر الترابي قواعد تهم مصالح الخصوم ويمكن استبعادها والاتفاق على مخالفتها لتعلق الأمر باستثناءات اقتضتها الضرورة التشريعية وحسن سير القضاء على نحو مؤداه انه اذا ما سلك المشرع مسلك الاستثناء في تحديد مرجع النظر الترابي أو التأكيد على انعقاد الاختصاص حصرا لجهة قضائية بعينها فان ذلك يحمل على معنى الوجوب والالزام والا لما اضحى لذلك معنى ذلك ان المشرع لا يمكن ان يُنسب له لغو أو عبث، وكما ان الخاص يقدم على العام فان الاستثناء أيضا يقدم على القاعدة وأن التأكيد على تعهيد جهة قضائية يجب أن يحمل على محمل الوجوب لا الخيار وهو ما أكدته محكمة التعقيب في قرارات تعددت فكوّنت فقه قضاء مستقر مفاده ان الاختصاص الترابي في دعاوى تصحيح اجراءات العقلة التوقيفية يعد من القواعد الامرة التي يتعين الامثال لمضمونها والتقيد بمنطوقها تحقيقا لغاية المشرع التي يرنو اليها.

وحيث يترتب على كل ما سبق انه لا يجوز الاتفاق على مخالفة قاعدة الاختصاص الترابي المبينة بالفصل 343 م م ت ومن ثمة لا يعتد بالشرط الاتفاقي المضمن بوثيقة فتح الحساب الجاري موضوع التداعي الذي اقصى الاخذ بهذه القاعدة وان محكمة الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة البداية باقرارها اختصاصها بالنظر في النزاع المعروض عليها لاتفاق الأطراف على مخالفة مقتضيات الفصل 343 م م ت تكون قد خرقت القانون وسلكت مسلكا يخالف ارادة المشرع في النأي بدعوى تصحيح اجراءات العقلة التوقيفية عن القواعد الاجرائية العادية في تحديد الاختصاص التي تجعل منها مجرد قواعد اجرائية تهم مصالح الخصوم ويمكن الاتفاق على ازاحتها وافرادها بنظام خاص يشذ عن تلك القواعد بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

7-11 ضم القضايا اجراء إداري خلافا للقانون الفرنسي

قرار تعقيبي مدني عدد 22294 بتاريخ 17 أوت 2020 صادر برئاسة السيدة بسمة العباسوي وعضوية المستشارين السيدين يوسف رمضان ومكرم الخذري وبحضور المدعي العام السيد نوفل البطي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد.

«حيث تبين انه قدم مطلبا التعقيب ضد نفس الحكم كما تبين انه يوجد ارتباط بينهما.

وحيث ولئن لم يتطرق المشرع التونسي إلى تحديد نظام لضم القضايا - على خلاف تشاريع مقارنة من ذلك المشرع الفرنسي بالفصل 367 من مجلة الإجراءات المدنية الفرنسية - إلا ان عمل المحاكم قد كرس هذه الالية باعتبارها عمل من اعمال ادارة القضاء الرامية إلى تسهيل تحقيق الدعاوى والفصل فيها عن طريق توحيد الاجراءات وسعيا إلى تلافي صدور أحكام متضاربة بشأن مسألة واحدة.

وحيث لا خلاف في ان الطعن المقدم في اطار قضية الحال عدد 22294 والطعن المقدم القضية عدد 21807 قد تسلطا على ذات الحكم الاستثنائي - يجعل من المتعين ضم مطلبي التعقيب المتصلين بنفس الحكم الاستثنائي توحيدا للإجراءات وتفايدا لصدور أحكام متعارضة في نفس المسألة المطروحة امام هذه المحكمة.

وحيث ومن هذا المنطلق يكون الطعنان موضوع قضية الحال والقضية عدد 21807 متصلين في محل المنازعة الأصلي بما لا يسع الا اعتبار انه من المتعين ضمهما واصدار قرار واحد في شأنهما.

قررت المحكمة ضم هذه القضية للقضية عدد 21807 للبت فيهما بقرار واحد».

7-12 إجراءات التنفيذ

7-12-1 صعوبة تنفيذية تنفيذ على الورثة-الخلف ليس غيرا على معنى قانون اجراءات الصعوبة التنفيذية ولا يجوز له إثارة الصعوبة التنفيذية

قرار تعقيبي عدد 22744.2020 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«عن المطاعن المأخوذة من خرق الفصل 19 م م م ت و 211 م م م ت و 241 م م م ت لارتباطهم واتحاد القول فيهم:

حيث كانت المطاعن المضمنة بمستندات التعقيب في عدم تطبيق محكمة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك بخرقها الفصلين 211 م م م ت و 19 م م م ت وقد أجاز الفصل الأول للمعقول عنه إثارة صعوبة تنفيذية بشروط وبين نائب المعقبة أن إثارة الصعوبة التنفيذية تقتضي توفر الصفة فيمن أثارها معارضا منهج محكمة الاستئناف التي لم تتحقق من صفة المعقب ضده الذي لا يحق له القيام لأنه ليس غيرا في علاقة بالحكم موضوع التنفيذ ومن تسلط عليه الحكم المورث «المدين».

وحيث لا خلاف بخصوص وجوب تحقق المحكمة الاصلية ومحكمة القانون وفي كل أنواع النوازل من صفة القائم والمقام ضده وفق الفصل 19 م م م ت وتطبيقا لما كرسه فقه قضاء هذه المحكمة.

وحيث ان تحديد الصفة يكون من منطلق علاقة القائم بالنزاع بخصومه ومدى توفر شروط التقاضي لوجود مساس بحقوقه أو ضرر ما مع توفر شروط الاهلية والمصلحة في الطرفين.

وحيث ان ما تضمنته الدراسة المقدمة من المعقبة والمعنونة «مدخل طرق التنفيذ» للأستاذ «خ. الخ.» من «أن الخلف ليس غيرا على معنى قانون اجراءات الصعوبة التنفيذية ولا يجوز له إثارة الصعوبة التنفيذية وان ليست له الصفة القانونية»، قول معتمد وسليم في غير صورة النزاع الحالي الذي تولى فيه المعقب ضده إثارة صعوبة تنفيذية لوقوع التنفيذ على سيارة خاصة على ملكه وليس على ملك المحكوم عليه والذي حق التنفيذ على ذمته المالية.

وحيث أنه لا نزاع حول صفة المعقب ضده المبدئية والأولية باعتبار تسلط عملية التنفيذ عليه شخصا وبالتحديد على ذمته المالية بثبوت مسكه لمؤيدات ملكية سيارة خاصة تسلط عليها العقلة المجرة لفائدة المعقبة في 11/04/2019 تنفيذاً للقرار الاستئنافي عدد 66278 الصادر في 3/3/2009.

وحيث ان حمل المعقب ضده لصفة الخلف العام باعتباره ابن كفيل المدين في القرار الاستئنافي عدد 66278 المذكور لا يحجب عنه مركزه القانوني كغير في عملية التنفيذ الحاصلة من منطلق واقعي وقانوني ثابت ان محل التنفيذ «السيارة» هي على ملك المعقب ضده وليس على ملك مورثه وهو أمر ثابت من شهادة

تسجيل السيارة ومحضر العقلة المضافة بالملف وأنه لا مجال للتمسك بصفته كخلف عام باعتبار ان التنفيذ لم يتسلط على المخلف وفق ما ثبت من مؤيدات الدعوى وتكون بذلك صفة المعقب ضده كمصلحته في القيام بإثارة الاشكال التنفيذي عند تنفيذ القرار الاستثنائي وموجبات العقلة التنفيذية بعنوانه قائمة على معنى الفصل 19 م م ت لثبوت استحقاق المعقب ضده للمعقول واستقلال ذمته المالية عن ذمة مورثه خاصة في غياب ما يثبت انجرار ملك السيارة من الخلف إلى السلف كما ان هذه الفرضية كذلك لا تجيز التنفيذ وتسند للمعقب ضده الصفة والحق في إثارة دعوى الحال وكان القرار المطعون فيه معللا لما قضى بتوفر الصفة والمصلحة في المعقب ضده.

وحيث وبخصوص خرق المحكمة للفصل 241 م ا ع فإن محكمة القرار المنتقد وتصديقا لمنهج المعقبة في تقديم طعونها لدى هذه المحكمة سنت قراءة تأصيلية للفصل 241 م ا ع تعتبر وفق تحليل محكمة القانون قراءة سليمة ومؤسسة لفهم منطقي متجانس مع مبادئ القانون العامة ومكرسة لقواعد الانصاف ذلك ان المحكمة فرقت بين شخصية الوارث والمورث الذي تنتقل إليه تركة مورثه وأن الضمان أوالتنفيذ الحاصل على السلف استنادا إلى ما تركه الخلف يكون في حدود التركة وأن هذه القراءة وخلافا لموقف الطاعنة لم تتجاوز روح وماهية الفصل 241 م ا ع ذلك أن المحكمة قدرت أن التركة تنتقل بعناصرها الايجابية والسلبية من المورث إلى الوارث كما اعتبرت أن شخصية المورث والوارث مستقلتين في حدود نوع النزاع الحالي الذي ثبت فيه حصول التنفيذ على ما هو ملك للوارث ودون أن يكون من فصول التركة وعللت المحكمة صحة القضاء بجدية الاشكال التنفيذي المثار من المعقب ضده من منطلق أن نقلة التركة من الخلف إلى السلف وهو انتقال آلي وقانوني وفق الفصل 241 م ا ع لا يجيز التنفيذ على الورثة إلا في ما تركه المورث . كما ان القول ان التبع يكون في حدود التركة قول سديد ولا حاجة إلى ذكره صلب الفصل 241 م ا ع الذي كرس انتقال التركة بين الوارث والمورث وليس اختلاط ذممهم المالية ولا تجاوز التركة وفصولها بدعوى الضمان المطلق ذلك ان ضمان المورث يكون في حدود ما خلف لا غير.

وحيث ان الخوض في تخلي الورثة في قضية الحال عن التركة وذلك من الطرفين لا جدوى منه باعتبار أن التخلي القانوني من استثناءات الفصل 241 م

اع وان التمسك بوجود التخلي وتوفر شروطه من عدمه لا علاقة له بالطرح في الدعوى والتي يقتصر النظر فيها على التحقق من مدى شمول التبع فصول وأعيان التركة أساسا وذلك قبل البحث في صحة التخلي عن التركة من عدمه وهو ما تحققت منه المحكمة بمجرد قراءة سليمة ومنطقية وواقعية للفصل 241 م اع في تحديد لعلاقة الوارث بالمخلف وتكريس المحكمة الاستثنائية مبدأ أصوليا: مفاده أن انتقال التركة ودون تطبيق اجال واجراءات التخلي المضمنة بالفقرة 2 من الفصل 241 م اع لعدم صحة التخلي المستند إليه من المعقب ضده يكون آليا من المورث إلى الورثة ، وأن تتبع التركة بين أيدي الورثة لا يكون إلا في حدود فصولها وقيمتها دون تتبع أملاك الورثة الشخصية وهو مبدأ أصولي مبدئي تقرر تبنيه من هذه المحكمة والتصديق عليه وأن تدعيم المحكمة قراءة الفصل 241 بأحكام الفصل 289 م م ت كان معللا وفيه تناسق في تطبيق القانون وتعين رد المطاعن لو هنها.

عن المطعن المأخوذ من ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع:

حيث تمسكت المعقبة بضعف تعليل القرار المطعون فيه ومساسه بحقوق الدفاع المتأني أساسا من نكران المحكمة لردود المعقبة وقيامها بسرد الوقائع دون التعرض لمستندات المعقبة عند تعليل حكمها.

وحيث ان تعليل الاحكام شرط أساسي لصحتها وأن التعليل يستوجب تقدير الوقائع وتكييفها قانونا واستخلاص نتائج قانونية مع شرط إيجاد حلول للنزاع لحفظ الحقوق موضوعه .

وحيث ثبت أن محكمة القرار المطعون فيه قد عرضت دفوعات المعقبة حاليا وردت بإطنا ب على سند القيام وهو الفصل 241 م اع كما أسست لفهم قانوني للنص وأشفعت القراءة بنصوص قانونية أخرى تدعيما لتعليلها المستفيض والمسترسل كما ان في تعليلها واستخلاص النتائج استحداث وتحليل قانوني لطريقة تتبع التركات وفصل الذمم المالية لضمان استقرار الوضعيات القانونية وان جوهر المطاعن تم الرد عليها وان المحكمة غير ملزمة بتطبيق نصوص قانونية أو فقهية تحرر بمستندات الاستئناف لا يمكن تطبيقها أو الرد عليها لتعارضها مع منهج المحكمة ، وكان الحكم معللا وسليم المنحى لما صحح مستندات القضاء

لصالح الطلب لعدم صحة اسانيد الحكم الايجابي الابتدائي في إشارة إلى إقراره مع اعتماد مستندات القرار الاستئنافي وتعين رد المطعن ورفض التعقيب أصلاً».

7-12-2 عوارض التنفيذ - تعارض الأحكام القضائية

قرار تعقيبي مدني عدد 24475.2020 بتاريخ 24 أوت 2020 صادر برئاسة السيدة بسمة العساوي وعضوية المستشارين السيدين يوسف رمضان ومكرم الخذري وبحضور المدعي العام السيد نوفل البطي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد.

«حيث تمسكت المعقبة بأن المحكمة قد خاضت من جديد في مسألة تنفيذ الحكم من خلال اعادة الجدل والنظر في طبيعته كما انها عمدت إلى رهن تنفيذ الحكم التجاري سند التتبع موضوع القضية عدد 35239 بمال القضية المتعلقة بتسليط الغرامة التهديدية التي لا تزال محل نظر من فضلا عن ابداء رايها في طرق التنفيذ وما يتلاءم وطبيعة الحكم المشار إليه حول ما اذا كان من الاحكام التقريرية كدعوتها للأطراف للصلح من خلال اجراء محاولة توفيقية بينها بالرغم عن عدم تسجيل مثل ذلك الأمر من الخصوم فضلا عن قرارها بتكليف خبير تعهد له مهمة معاينة تنفيذ الحكم صحة عدل تنفيذ وهي جملة المؤاخذات الموجهة على حكمها في هذا الخصوص .

وحيث تعلق النزاع الراهن موضوع قضية الحال بإشكال تنفيذي مثار من قبل المعقب ضده الأول قصد ايقاف أعمال تنفيذ الحكم التجاري عدد 35239 .

وحيث ومن باب التأصيل القانوني فان مؤسسة توقيف التنفيذ قد اقرها المشرع من خلال تمكين قاضي امور العجلة من البت في جملة المنازعات الرامية إلى تعطيل تنفيذ الاحكام ودعوته إلى النظر في عوارض التنفيذ بما يتلاءم وخصوصية مؤسسة قاضي العجلة دون خوض في الأصل ودون ابطاء اعتبارا بان المطالب الرامية إلى تعطيل تنفيذ الاحكام تعد من الاشكالات التنفيذية ويكون قضاء امور العجلة مدعوا إلى رفعها في حدود ما لا يمنع الحد من التنفيذ وما كان جديا كان يكون مبناها أسباب تتصل بالحق الحاصل التنفيذ عليه اقتضاء بحقوق الغير أو كادعاء المدين وفاء له أم كان مبناها اسبابا تتعلق بالإجراءات كقيام أسباب بطلان إجراءات التنفيذ والتي لا يخرج فيها نظره عنها في حدود

ما قيده به المشرع بشروط القضاء المستعجل مناط الفصل 201 من م م م ت اقتضاء بعدم الخوض في الأصل وشرط التأكد مع اعمال عنصر الزمن في فصل تلك العوارض الطارئة على مسار تنفيذ الاحكام بان يكون لزاما عليه البت فيها دون ابطاء وهو روح القضاء المستعجل في باب الاشكالات التنفيذية فلا يمكن لقاضي عوارض التنفيذ من ان يمد بصره إلى مواضيع ودفعات تعيقه عن اتمام مهمته التي اوكلها له المشرع في تخليص عملية التنفيذ من كل طارئ جدي يحول دون اتمامها كحفظ الحقوق المهددة والخشية من ضياعها وتلاشيها بسبب التنفيذ بالحد من آثارها على تلك الحقوق التي يخشى ضياعها ويستحيل الرجوع بالحالة إلى وضعها الاول من بعد التنفيذ فيقتصر دوره اذن على اتخاذ جميع الوسائل الوقائية الكفيلة بحماية الحق المهدد على أساس ظاهر المؤيدات المتوفرة لديه دون مساس بالأصل أو البت فيه.

وحيث ولئن لم يحدد المشرع شروطا موضوعية خاصة تمكن من الوصول إلى حل واضح بالنسبة لعوارض التنفيذ التي تطرا اثناء تنفيذ الحكم فقد فوض واوكل الأمر لإجتهد القاضي الاستعجالي والأمر لا يخرج عن فرضيتين لا ثالثة لهما فإذا أن يصدر قاضي عوارض التنفيذ قرارا ايجابيا ويقضي بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في النزاع المطروح من قبل محكمة الأصل أو سلبيا برفضه للمطلب ويأذن بذلك بالتمادي في أعمال التنفيذ فيكون مدعوا بموجب التكليف الذي ناله من المشرع إلى التحقق من جدية الإشكال المطروح ومن توفر شروط طلب التوقيف من عدمها ويقضي تبعا لذلك بأحد القرارين المذكورين دون وجود خيار ثالث لهما.

وحيث بتفحص أوراق الملف يتبين أن مشير الإشكال المعقب ضده الأول قد طلب إيقاف تنفيذ الحكم التجاري عدد 35239 والزام عدل التنفيذ المعقب ضده الثاني بالكف عن تفتيش وسائل النقل التابعة لها إلى حين بت محاكم الأصل في مسألة تنفيذه للحكم المذكور من عدمه معتبرا بوجود أحكام جارية في علاقة بالحكم التجاري سند التنفيذ موضوع الحكم القاضي بتسليط الغرامة التهديدية واستنادا إلى سبق تنفيذ الحكم التجاري الذي تضمن التزاما بإجراء عمل من خلال تنزيل المبلغ المحكوم به ضده بحساب المعقبة راهنا مدعما مطلبه بمحضر معاينة يقيم فعليا عملية التنزيل.

وحيث وبناء عليه فإن نظر محكمة القرار المطعون فيه يجب أن يقتصر على التأكد من جدية الإشكال المطروح دون الخوض في مسألة حصول التنفيذ فعليا من عدمه فذلك يقتضي التعمق في المؤيدات المعروضة وإجراء استقرارات وترجيح حجج على أخرى وهي كلها أعمال تتجافى ونظر قاضي العجلة وعليه وطالما خاضت محكمة الحكم المطعون فيه في مسائل لم يكلفها المشرع ببسط ولايتها عليها وكانت اشاحت بوجهها عن المسائل ذات العلاقة بعوارض التنفيذ من خلال تبين جدية الاشكال التنفيذي المثار في حدود ما قيده بها المشرع بالتحقق من توافر شروط وظروف الحق المهدد والمطلوب حمايته تكون قد تجاوزت حدود نظرها لتبت في أصل المنازعة المطروحة وتستنبط حلا مستهجنا متناقضا في شكله ومضمونه مع ما خوله المشرع بخصوص البت في الإشكالات التنفيذية عندما قضت بجدية الاشكال المثار لديها بالرجوع إلى فصلها في مسائل اصلية لم يكن من وليد اختصاصها القانوني وكانت اهمت البت في النزاع المطروح لديها من زاوية مدى توفر الجدية من عدمها اعمالا لنظرية الحقوق المهددة والمطلوب حمايتها من خلال الحرص على تفادي استحالة تدارك الوضع بعد التنفيذ فتكون المحكمة بذلك قد افرطت في ولايتها بوجهين اولهما سلبى بان احجمت عن تفعيل صلاحيتها المخولة لها قانونا في اطار الاختصاص المتعلق بالأشكال التنفيذي واخر ايجابى بان استعارت صلاحيات قاضي الأصل وهو محجور عليها ذلك .

وحيث أن محكمة القرار المنتقد بما أتته من بت في الأصل قد انتهجت منهج قضاء الأصل ولم تنحت في حكمها منهجا يتلاءم وفقه أحكام الفصلين 201 و 211 م م م ت وضوابطهما وتطرق إلى النزاع الأصلي فأورثت حكمها الوهن وخرق القانون مما يتعين معه نقضه.

عن جملة المطاعن الخامس والسادس والسابع المأخوذة جميعها من تناقض الحكم المطعون فيه مع القرارات الصادرة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب برفض مطلبى ايقاف التنفيذ والقرارات الاستعجالية الصادرة عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس برفض مطلب توقيف الحكم التجاري سند التبع والاحكام الاستعجالية الصادرة ابتداءيا برفض مطلب الاشكال التنفيذي

حيث اثارت هذه المطاعن اشكالا قانونيا تعلق بتحديد مفهوم التضارب بين الاحكام الموجب للطعن بالتعقيب طبق ما اوجبه الفقرة الخامسة من الفصل 175 من م م م ت . وحيث أن الأحكام المستند إليها من المعقبة والتي قضت جميعها برفض مطالب ايقاف تنفيذ الحكم عدد 35239 ورفض مطالب رفع العقلة المجرة من المعقبة ولئن تسلطت جميعها على عملية تنفيذ الحكم التجاري عدد 35239 فإنها تبقى أحكام سلبية لا يتصل بها القضاء ويمكن مخالفتها فضلا عن اختلاف سبب القيام الحالي عن أسباب القضايا المذكورة وعليه فلا وجود لأي ترابط بينها وبين القرار الحالي ولا مجال بالتالي للحديث عن تناقض القرار المطعون فيه مع الأحكام السابقة الصادرة برفض مطالب ايقاف تنفيذ الحكم التجاري عدد 35239 بناء على ان الاحكام السلبية لا ترتب حجية كما لا تعد من الاحكام التي اناطها القانون بقوة الشيء المقضي به عملا بالفصل 481 من م م ا ع ولا يقيد نظر المحكمة على مقتضاها طالما لم تتولد عنها حقيقة قضائية أو اتصال القضاء في مسألة معينة اتحد فيها النظر مع المحكمة الحكم المطعون فيه واتجه رد مجموع هذه المطاعن .

عن المطعنين الثاني والرابع المأخوذين من خرق أحكام الفصل 175 من م م م ت لتناقض الحكم المطعون فيه مع أحكام نهائية صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع ولنفس السبب كمخالفة القرار التعقيبي عدد 78144 الصادر في 02 / 12 / 2019 الذي يثبت عدم حصول التنفيذ بصورة باتة:

حيث انه من المسلم به فقها وقانونا ان فريضة القضاء من حيث انها سلطة تهدف إلى قول القانون كما تهدف إلى ايصال الحق سواء انشاء ام تصريحاً حيث يخول للقاضي من بسط ولايته على النزاع الا ان ذلك لا يكون بوجه مطلق حيث يمكن تقييد النظر لديه في مسائل كان سبق للقضاء قول كلمته الفصل فيها فلا يجوز اعادة النظر فيها أو الخوض فيها واطالة الجدل فيها طالما اصبحت موضوع حقيقة قضائية مطلقة اناطها القانون بقرينة قانونية وحجية تمنع على القاضي المبسوط عليه النزاع اعادة ابداء الراي فيها حيث تصبح من الحقائق القانونية المسلم بها عندما تنتهي فيها الخصومات بصدر أحكام باتة وتتصف بحجية الشيء المقضي به بفعل اتصال القضاء فيها بوجه بات .

وحيث ان العلة في تحجير اعادة الخوض في تلك المسائل التي اوضحت في حكم الحقيقة القضائية الباتة الخشية من صدور أحكام متناقضة والدعوة إلى حدوث فوضى قضائية يتزعزع فيها مفهوم الاحكام فحصول التضارب فيما بينها يؤول إلى تنازعها وتساقط بعضها وهو ليس من فريضة القضاء بلوغ الفوضى في الاحكام ضرورة ان القضاء عامل استقرار وطمأنينة وهو ما حدا بالمشرع إلى جواز الطعن بالتعقيب في احد مداخله وتحديدًا من باب تناقض الاحكام وتضاربها .

وحيث كان صدر القرار التعقيبي عدد 78144 الذي عرضت لديه الخصومة بشأن مدى حصول تنفيذ الحكم التجاري سند التبع وكان قال كلمته الفصل فيها دون لبس بعدم وقوع تنفيذ ذلك الحكم وفق ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي عدد 29508 الذي بين بان ما تولاه المعقب ضده الاول من تنزيل للمبلغ بالحساب دون تمكين المعقبة منه والاجراءات المتبعة في ذلك لا تؤسس للقول بوقوع التنفيذ وفق ما اقتضاه القانون من اجراءات.

وحيث أن ما انتهى إليه القرار التعقيبي المشار إليه يؤسس لحقيقة قضائية قاطعة وباتة من عدم حصول التنفيذ وما كان للمحكمة من اعادة تناوله بان انحرفت في قضائها عن تلك الحقيقة ولم يكن من دورها الخوض من جديد في مسألة تنفيذ الحكم التجاري لسبق الحسم في تلك المسألة بوجه بات وان حكمها اتسم بالتسبب في صدور أحكام متناقضة بعد ان كرس موقفا مخالفا للقرار التعقيبي الذي جاء ناطقا بحقيقة قانونية باتة .

وحيث أن الأحكام التي أحرزت قوة اتصال القضاء عملا بالفصل 481 من ماع تكون واجبة الاتباع من المحكمة ولا تملك سلطة اعادة النظر فيها من جديد هو الأمر الذي جعل حكمها يصدر بصورة مناقضة للقرار التعقيبي عدد 78144 وخالفت بحكمها تلك القرينة القانونية القاطعة وكان حكمها قد انتهى في قضائها إلى نتيجة منحرفة عن تلك القرينة وهو ما يورث حكمها خرقا واضحا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 175 من م م ت بما يتجه معه نقضه .

في شأن طلب التصدي للاصل والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه دون احالة

وحيث ومن باب التذكير فان محكمة التعقيب تكون محكمة أصل عندما يكون موضوع النزاع مهيا للفصل فيه وتكون محكمة الاحالة قد استفرغت جهدها واستنفذت كامل ولايتها الموضوعية على الملف.

وحيث انه بالرجوع إلى ما سلف الالماع إليه سلفا فان محكمة الحكم المنقوض قد انحرفت بصلاحياتها بوجه سلبي ولم تنظر في النزاع من زاوية فقه عوارض التنفيذ ولم تنقيد بأحكام الفصلين 201 و 211 من م م ت بان تلبست بصلاحيات قضاء الأصل وهو ليس من دورها بما جعل من قضاءها يحيد عن مبادئ قضاء امور العجلة كما لم تستنفذ ولايتها من زاوية اصول المحاكمات الخاصة بإشكالية التنفيذ وكان جوابها بعيدا عن مرماه ولم تعبر في قضائها عن موقفها من زاوية ما يمليه نظرها قيда بأحكام الفصلين 201 و 211 من م م ت وهو ما يسمح بالقول بان المحكمة فرطت في الحكم على معنى اصول فقه قضاء الاشكالات التنفيذية بما يتجه معه ضرورة بإحالة الملف عليها من جديد لإعادة صياغة موقف على معنى فقه عوارض التنفيذ مناط الفصلين 201 و 211 من م م ت».

8 - العقل

1-8 العقلة العقارية

1-1-8 1 امكانية تسجيل اعتراض من جديد في بثة جديدة بموجب النكول

قرار تعقيبي مدني عدد 69931 بتاريخ 9 جوان 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثانية والثلاثين برئاسة السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية المنتصر ونفيسة العلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الحلواني.

«... وحيث ومن جهة أخرى وفي خصوص الدفع بانعدام الصفة فانه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان المشرع ولئن قيّد الدعوى المعارضة بأجال معينة ومضبوطة بأن نص صلب الفصل 437 م م ت على أنه يجب تقديمها في اجل يتدئ من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة وينتهي قبل انعقاد جلسة التبتيت بعشرة أيام فانه لم يشترط ان يكون القائم بها طرفا في قضية التبتيت سيما

ان حق المعارضة هو حق مخول لكل من له مصلحة في الاعتراض على البتة وبات بذلك هذا الفرع من المطعن بدوره حريا بالرد .

عن الفرع الثالث من المطعن الثاني:

حيث يتأكد بالرجوع إلى الباب الثامن من الجزء الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن دعاوى البيوعات العقارية تختلف باختلاف الدعوى موضوعها فالدعاوى المعارضة السابقة لتبتيث العقار تختلف اختلافا كليا من حيث آجالها وشروطها وموضوعها عن الدعاوى المدنية الأصلية التي ترفع أمام محاكم الأصل والتي ترمي إلى طلب الحكم باستحقاق العقار المعقول أو التي ترفع طعنا في حكم البتة أو محضر التبتيت نفسه.

وحيث لا جدال ان الطعن في عقد بيع العقار موضوع التبتيت المبرم بين ب.ه. والشركة «الع. لب.» المؤرخ في 13-07-1982 والدفع بسقوطه بمرور الزمن هو طعن يخرج عن موضوع قضية الحال الرامية إلى الاعتراض على إجراءات إعادة البتة بموجب النكول وطلب الاذن بايقافها باعتبار ان الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن مناط الفصل 402 م ا ع يتعلق بالدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة وبالتالي لا علاقة له بالدعوى موضوع قضية الحال ولذلك يضحى هذا الفرع من الطعن غير وجيه ويتعين رده أصلا.

عن الفرع الرابع من المطعن الثاني:

حيث نص الفصل 446 م م ت على ان «إجراءات إعادة البتة بموجب النكول تتمثل في اشهار جديد وبتة جديدة وفقا للقواعد المقررة للتبتيت الأول...»

وحيث يتبين من خلال ما تقدم ان ما ورد بالفرع الرابع من المطعن الثاني كون قضية التبتيت بموجب النكول غير خاضعة للقيام بالدعوى المعارضة مخالف لما أورده المشرع صراحة بالفصل 446 المذكور الذي أحال لتطبيق القواعد المقررة للبتة عند تقديم قضية في إعادة البتة بموجب النكول والتي اعتبرها بمثابة بتة جديدة.

وحيث أضحى الخدش في الحكم المعقب على أساس مخالفته أحكام الفصل 433 وما بعده م م ت فضلا عن ضعف تعليله غير مبرر واقعا وقانونا وتعين لذلك رد هذا الفرع من المطعن لعدم وجاهته ورفض التعقيب أصلا.

وحيث أخفقت المعقبة في طلبها واتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرفها عملاً بأحكام الفصل 184 من م م م ت».

8-2 العقلة التوقيفية

8-2-1 اجراء العقلة التوقيفية بين يدي المستشفيات لدى المحتسب المكلف بالتصرف وإلا عُدَّت باطلة

قرار تعقيبي عدد 2019.76762 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الثالثة برئاسة السيدة نعيمة رحيم وعضوية المستشارتين السيدتين عير الخلفي نورة نوري وبمحضر ممثل الادعاء العمومي السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سنية عبداوي.

«حيث نعى الطاعن على محكمة القرار المنتقد خرقها للقانون وتحريفها للوقائع باعتبار وان استدعائه كان للحضور في القضية عدد 2397 والحال ان عدد القضية هو 1/23679 إضافة إلى عدم توجيه الاعلام بالعقلة إلى مكاتب المكلف العام بصفته الممثل القانوني للمؤسسات العمومية وتوجيه إلى المستشفى الجهوي بقفصة معتبرا ذلك خرقاً لأحكام الفصول 70 و71 من م م م ت والفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988.

وحيث ان تقدير واستخلاص النتائج منها هو من مشمولات محكمة الموضوع دون ان تكون لمحكمة التعقيب رقابة عليها في ذلك طالما كان رايها معللاً تعديلاً مؤسساً على ما له أصل ثابت بالملف وعلى تطبيق سليم للقانون .

وحيث تبين بالرجوع إلى مستندات القرار المنتقد والأوراق التي اعتمدها ان المحكمة تعرضت بكل تفصيل ودقة للمعطيات التي اعتمدها لاعتبار ان الاستدعاء كان للقضية الاستثنائية محل نظرها سيما وان ممثل المكلف العام حضر وأجاب عن الدعوى مما يرفع كل لبس تعلق بعدد القضية أو بتوجيه الاستدعاء للمستشفى الجهوي دون المكلف العام.

وحيث كان ثابتاً رجوعاً إلى أوراق الملف ان المعقب الان المكلف العام بنزاعات الدولة في شخص احد مقرريه كان حضر امام محكمة الحكم المطعون فيه وادلى بتقرير - بصفته ممثلاً للمعقول تحت يده - انتهى به إلى طلب تسجيل تقديمه لتصريح كتابي على معنى الفصل 341 من م م م ت وطلب الحكم وفق

مضمونه في فرع الدعوى المتعلق به وارفق جوابه بتصريح طبق مقتضيات الفصل 340 م م م ت.

وحيث يتضح مما ذكر ان محكمة القرار المنتقد قد عللت قضاءها تعليلا سليما منطقيا له أصل ثابت بالأوراق وبالتالي يعتبر مبنيا على اسس قانونية صحيحة ولا تثير عليها بخرقها لاحكام الفصول 70 و 71 من م م م ت والفصل الأول من قانون 1988.

عن المطعن الثاني المتعلق بمخالفة الفصل 348 من م م م ت:

حيث نظمت مجلة المرافعات المدنية والتجارية اجراءات ضرب العقلة التوقيفية من قبل الدائن على أموال مدينه بين يدي الغير المعقول تحت يده وألزمت كل طرف مشارك في العقلة باحترام الموجبات المحمولة عليه بمقتضى الفصول القانونية التي تعرضت للمسألة وفي هذا الاطار جاء الفصل 348 من م م م ت لينص في فقرته الثانية على ان «كل عقلة توقيفية وكل اعلام بإحالة يجب ان يقعا لدى المحتسب المكلف بالتصرف اذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي أو بذمة الجماعات المحلية» وادف في فقرته الأخيرة ان «العقل والاعلامات بالاحالة المذكورة لا عمل عليها اذا وقعت لدى غير الأشخاص المشار اليهم أعلاه».

وحيث لا جدال في ان المستشفى الجهوى بقفصة هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لسلطة وزارة الصحة ولتصرفها ولها استقلال مالي وهو ما يحتم وجوبا تطبيق مقتضيات الفصل 348 من م م م ت في خصوص العقل المضروبة تحت يده والتي يتعين ان تكون لدى المحتسب المكلف بالتصرف والا عدت باطلة

وحيث وتأسيسا على ذلك فإن محكمة القرار المنتقد تكون قد أساءت تطبيق الفصل 348 من م م م ت لما اغفلت ما تضمنه محضر العقلة سند الدعوى من علة بعدم اجرائه لدى المحتسب طبقا للقانون بما يجعل الطعن موقفا بخصوص هذا المطعن ويتجه بالتبعية التصريح بنقض القرار المنتقد».

9 - إستعجالي

9-1 خروج المطالبة بالزيادة الإتفاقية لمعينات الكراء عن إختصاص القاضي الإستعجالي

قرار تعقيبي عدد 22331 بتاريخ 26 ماي 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«عن المظعن المأخوذ من خرق القانون وتحريف الوقائع:

حيث تأسس الطعن صلب مستندات التعقيب على مخالفة المحكمة للفصل 201 مرافعات من ذلك أنه جاء فيها أن المحكمة أعتبرت أنها مؤهلة لإحتساب الزيادة الإتفاقية المقدرة في عقد تسويق محل معد للتجارة والحال أنه أثير نزاع حول مدى تفعيل هذه الزيادة وطريقة ومقدار أدائها.

حيث أنه لا خلاف في أن الفصل 201 مرافعات الفصل المرجعي في إنعقاد القضاء الإستعجالي قد ضبط شروط القيام لدى محكمة العجلة من ذلك أن يكون للقيام صبغة التأكد وأن يكون المرجو منه حماية حق أو رد خطر داهم كل ذلك دون المساس بالأصل.

حيث إن كانت المطالبة بأداء معينات الكراء غير الخالصة من الأمور المتأكدة باعتبار الحاجة لحماية حق المسوغ في الحصول عليها خاصة إذا ما كانت لها صبغة حياتية أو اقتصادية فإن نوع الطلب كذلك يندرج في الطلبات المستعجلة باعتبار توفر الحق الظاهر المؤسس على عقد تسويق ماض بين الأطراف فإن المشرع حجر أن ينظر القاضي المتعهد في ما يستوجب حين البت فيه اللجوء إلى التأويل والتفسير أو الحاجة إلى الإستقراء باعتبار أن في ذلك ما يحيل إلى المساس بالأصل.

حيث لم تكتف المعقب ضدها عند تحرير الطلب بمعينات الكراء الأصلية والتي كانت موضوع محضر عرض في الملف الابتدائي إلا أنها طالبت بمنحها زيادة إتفاقية وإن ثبت أنها زيادة أدرجت في العقد الذي بقي ملزما للمعقبين

باعتبارهما حلا محل مالك الأصل الذي ابتاعه لهما ، فإن المعقب ضدهما المالكون للأصل تمسكا بوجود إتفاق شفاهي مفاده حصول الإتفاق على جعل الزيادة السنوية في حدود 50 دينار عن كراء كل سنة وأن ذلك الإتفاق تم تفعيله وفق مبالغ الكراء المضمنة بالصكوك المتضمنة لمعينات الكراء.

حيث إن الأصل في الأمور تطبيق ما تضمنه العقد الكتابي الذي مازال ماضيا بين الأطراف إلا أنه توفر بالملف قرائن قانونية وفعلية على حصول المعقب ضدها بإسترسال على مبالغ كراء بزيادة قدرها 50 د أي ما يعادل مبلغا أدنى مما تضمنه العقد والزيادة المقدرة.

حيث إن الخوض في مدى تفعيل الزيادة من عدمها والتحقق من وجود إتفاق على زيادة مغايرة لما ضمن بالعقد كالتحقق المفترض من المحكمة الإستعجالية من صحة ما ضمن من مبالغ بالصكوك وهل أنها تتطابق مع الكراء الشهري أو هو كراء مجمع أو متأخر كلها معطيات تجعل النزاع في حاجة للاستقراء والتقضي وفي ذلك مساس بالأصل بحجب على قاضي العجلة وكان تقدير المحكمة إحتساب وإسناد المبالغ المطلوبة من أصل كراء وزيادة فيه مخالفة للفصل 201 مرافعات فضلا عن إختلاف ما حرر من طلبات مع ما احتسبته المحكمة مما تعين معه قبول المطعن.

عن المطعن المأخوذ من سوء التعليل :

حيث تمسك المعقبان بضعف تعليل الحكم المنتقد ذلك أن المحكمة قدرت وجوب إعتداد الزيادة الإتفاقية وإحتسبت المعينات مع الزيادة المقدرة وفق العقد ب 10 بالمائة وردت بخصوص قول المعقبين أن هناك اتفاق على زيادة قدرها 50 دينارا في كل سنة مالية بأن المعقب ضدها قبلت تلك المبالغ على وجه التسبقة وبحكم علاقة الجوار إلا أن ذلك المعطى لا صله له بما يقتضيه القانون ذلك أن تعليل التسليم من المعقب ضدها بمعين الكراء المدفوع من المتسوغ لوجود علاقة جوار لا يمكن أن يقوم أساسا وسندا لتعليل الأحكام كما أنه وخلافا لما تمسك به الطاعنان من توفر الإبراء على معنى الفصل 351 ماع لسكوت المعقب ضدها عن الزيادة فإن المطالبة بالزيادة التعاقدية حق للمتسوغ ولها المطالبة به إلا أن المطالبة به لدى قاضي العجلة دون توفر المطالبة به منذ قيام العلاقة وحاجة

التحديد لوجود تفعيل لها من المسائل الموضوعية الأصولية التي تحتاج إلى اعتماد شتى وسائل الإثبات التي لا تدخل في مرجع نظر قاضي العجلة مما صير الحكم بالمبالغ موضوع الزيادة وإحتسابها مع الأصل مخالفاً للفصل 201 م م ت على أنه كان بإمكان محكمة الحكم المنتقد الحكم بأصل الكراء لضمان حق المسوغ وترك الجزء المتعلق بالزيادة الإتفاقية من الدعوى لقاضي الأصل للتحري فيها مما تعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بنابل للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى».

9-2 المطالبة إستعجاليا بحق مرور يحول دون انطباق الفصل 13 من مرسوم 1964 المتعلق بإختصاص المحكمة العقارية لتعلقه بالنزاعات الأصلية دون الاستعجالية

قرار تعقيبي عدد 21073 بتاريخ 09 ماي 2020 صادر عن الدائرة المدنية برئاسة السيدة نجوى الملولي وعضوية المستشارين السيدين مكرم الخذري ومشكاة سلامة وبمحضر المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

«عن المطعن المأخوذ من خرق مقتضيات الفصل 177 م ح ع:

حيث كان المطعن صلب مستندات التعقيب في عدم إختصاص محكمة الحكم المطعون فيه للنظر في الطلب تطبيقاً لأحكام الفصل 177 م ح ع باعتبار أنه كان في تمكين المعقب ضدها من حق المرور والحال أن الحق منح لمالك العقار المحاط من كل جانب وليس لغيره متمسكين بإنعدام الصفة في المعقب ضدها للقيام.

حيث أن الصفة في القيام تؤطر قانوناً في القواعد الإجرائية المدنية العامة بالفصل 19 م م م ت الذي أسند القيام بطلب ممن له حق مع تمام المصلحة. وحيث إن القيام كان من المعقب ضدها مستندة إلى إذن على عريضة في إختبار شخص وعين وضع العقار الذي في تصرفها والذي تعذر عليها المرور إليه لحالة الإكتناف التي تعتريه.

وحيث إقتضى الفصل 177 م ح ع أنه: «لمالك العقار المحاط من كل جانب إذا لم يكن له منفذ إلى الطريق العام أو كان منفذه غير كاف لمصلحة عقاره أن يطلب ممرا في العقارات المجاورة مقابل دفعه تعويضا عادلا».

وحيث أن القول أن المتنفع والطالب لحق المرور يجب أن يكون مالكا قول سديد إلا أن الطالبة في الأصل كانت قد إستظهرت بشهادة حوز وتصرف للعقار موضوع التداعي وأن الملكية تثبت بكل الطرق وأن المعقيين لم يدلوا بما يفيد إنتفاء الملك على المالكة أو تحوز الغير بالعقار الذي في تصرف المعقب ضدها على أن القول أن الأرض ذات صبغة فلاحية وأنها موضوع مسح إجباري يجعل الملكية ظاهرة وناشئة بكل وسائل إكتسابها باعتبار أن العقار غير مسجل بإقرار من الأطراف المتداعية وأنه قانونا يكون العقار غير المسجل في ذمة حائزه وهو وجه من وجوه الملكية مما يصير المعقب ضدها مالكة وفق مقتضيات الفصل 177 م ح ع وتعين رد المطعن لمخالفته للقانون.

عن المطعن المأخوذ من خرق الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 لعدم الاختصاص الحكمي:

حيث كان الطلب في تمكين المعقب ضدها من حق المرور لاكتناف العقار الذي في تصرفها وفق إختبارين أصلي وتكميلي بموجب إذن على عريضة وعارض في إنعقاد إختصاص المحكمة العدلية باعتبار أن الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 نص على أن النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول بالمسح الإجباري تصبح من أنظار لجنة المسح وأن الطلب لا يمكن أن يكون من إختصاص المحكمة العدلية.

وحيث فضلا أن المطعن أثير للمرة الأولى لدى محكمة التعقيب إلا أنه من الثابت أن المشرع في الفصل 13 من مرسوم سنة 1964 تحدث عن النزاعات الأصلية والمتعلقة أساسا بالاستحقاق وأن الطلب كان إستعجاليا في تمكين الطالبة من ممر وقتي لتمكينها من التصرف وإلى حين إستقرار الوضعيات الإستحقاقية التي تنتظر فيها لجنة المسح المذكورة وتعين رد المطعن.

عن المطعن المتعلق بخرق الفصل 201 م م م ت:

حيث تمسك نائب المعقيين بمخالفة المحكمة للفصل 201 م م م ت لإنعدام شروط الفصل من تأكد وعدم مساس بالأصل على أساس أن للمعقب ضدها

ممر سابق ولأن الحكم بالتمكين من ممر لمجابهة حالة الإكتناف أعتمد على إختبارات مما يفيد خوض المحكمة في الأصل.

وحيث إن ما تم إثارته من مسك من المعقب ضدها لحكم جزائي يخول لها المرور قول مجرد وأن المحكمة تعهدت بحكم إختصاصها المطلق وفق الفصل 201 بالنظر في طلب مؤكد من حيث الحاجة للمرور من العقار وإليه للتصرف فيه وإستغلاله وأن للطلب صبغته العاجلة وأن التأكد ثابت من طبيعته المتمثلة في المرور للعقار لحالة الإكتناف وتوفر شروط الفصل 177 م ح ع.

وحيث إن القول أن المحكمة قد خاضت في الأصل قول مردود ذلك أن المحكمة تعهدت بمنح الحق الوقتي والعاجل وذو الصبغة المعاشية باعتبار انتفاع المعقب ضدها بالعقار المغروس وفق عريضة الطلب، وأنها لم تخض في مضمون الإختبارات ولا في صياغتها ولا في تفاصيل مضامينها بل أن نظرها إقتصر على تنفيذ مضمون إختبار جاهز حدد مسبقا الممر الذي قضت المحكمة بتمكين المعقب ضدها منه مؤقتا وإلى حدود إستقرار الوضعيات العقارية بما أن المعقبين أكدوا أن المنطقة مشمولة بالمسح الإجباري وأن القرار المتخذ كان من صميم إختصاص قاضي العجلة الذي من أهم أدواره الإستجابة للبحث عن حلول لوضعيات مؤكدة لمنح حق ثابت ودرء ضرر لاحق مما يجعل تعليل المحكمة قيما وقويما وتعين رفض التعقيب أصلا».

10 - تحكيم

10-1 عدم التصريح بالحياد والاستقلالية يؤسسان لطلب التجريح في المُحَكَّم
قرار تعقيبي عدد 74523 بتاريخ 1 جويلية 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجلاء المصمودي والسيدة نجوى الغربي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.
«عن المطعنين معا لتداخلهما ووحدة القول فيهما:

حيث تعلق الأمر في قضية الحال بالتجريح في محكم في نزاع تحكيمي داخلي تنظمه أحكام الفصلين 10 و 22 من مجلة التحكيم.

وحيث لا جدال أن الثقة في حسن تقدير المحكم وفي حسن عدالته هي في الأصل مبعث الاتفاق على التحكيم إذ أن المحكم هو شخص يتمتع بثقة الأطراف المتنازعة الذين اتجهت إرادتهم إلى منحة سلطة الفصل فيما شجر بينهم من خلاف ولأجل ذلك أوجب المشرع صلب الفصل 10 من مجلة التحكيم أن يكون المحكم رشيدا وكفئا ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية وبالاستقلالية والحياد إزاء الأطراف ولترسيخ هذا الاتجاه أوجب الفصل 22 من نفس المجلة على المحكم التصريح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده وإستقلاليته وإلزمته ومنذ تعيينه ومادامت إجراءات التحكيم سارية ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما به ويضرب لهم أجلا للرد مع إشعارهم بأنه لا يقبل المهمة أو يتمادى فيها إلا بعد موافقتهم الصريحة.

وحيث يستشف مما سبق بسطه أنه من الشروط الجوهرية لممارسة العمل القضائي عامة والتحكيم خاصة شرط الحياد والإستقلالية وهو شرط تكفل فقه القضاء بتحديد معناه فعرّف الإستقلالية بأن لا يكون للمحكم أية علاقة أو رابطة أو مصلحة مشتركة سواء كانت مادية أو أدبية بأحد أطراف الخصومة التحكيمية وأن كل رابطة من هذا القبيل تشكل خطرا على الطرف الآخر وتفقد المحكم إستقلاليته أما الحياد كسبب من أسباب التجريح فهو يعني لغة عدم الميل إلى أي طرف من أطراف الخصومة فهو بمعناه الأخلاقي عدم التحيز لأحد الأطراف على حساب الآخر فيقوم المحكم بوظيفته بعد إقصاء جميع الاعتبارات الخارجية عن موضوع القضية تحقيقا للعدل والإنصاف فالحياد مبدأ مستقل بذاته يرتبط من جهة أولى وثيق الارتباط بالعدل كقيمة بل هو جوهر العدالة نفسها أو عنصرها الأساسي ويمثل بذلك حجر الزاوية لمرفق القضاء الخاص والعدلي ودرة المبادئ الإجرائية كما يعد من جهة ثانية خاصية أساسية من خصائص حقوق الانسان المتمثلة في محاكمة عادلة وإلتزاما أخلاقيا محمول على المحكم كجهة قضائية.

وحيث أن الإشكالية المطروحة في النزاع الحالي تتعلق بمعرفة أن كان إمتناع المحكم عن تقديم التصريح بالحياد والإستقلالية يؤسس كطلب للتجريح فيه؟

وحيث لا جدال أن التجريح هو القدر في توفر المواصفات التي تجعل المحكم كفؤا وقادرا على القيام بدور القاضي ولو كان قاضيا متعاقدا خاصة من نزاهة وحياد وإستقلالية ومقدرة وهو كذلك الشك المبرر إذ وإنطلاقا من عبارة الفصل 22 من مجلة التحكيم «شكوكا لها ما يبررها» يعد التجريح مقبولا ومبررا فمطلب التجريح لا يتطلب فقط ثبوت انتفاء الإستقلالية والحياد بل يكفي أن يكون الشك مبررا ومؤثرا على ارتياح الأطراف للمحكم معملا بقاعدة الإطلاق على معنى الفصل 532 من ماع.

وحيث وبالنسبة للتصريح بالحياد فقد تناول فقه القضاء مسألة الإلتزام المحمول على المحكم بالتصريح «Obligation de divulgation» بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حياده وإستقلاليته رغم كون الأصل الصحة والسلامة فاعتبرت محكمة الإستئناف بتونس ضمن قرارها عدد 40438 الصادر بتاريخ 10-12-2013 أن الأصل في الأمور السلامة لكن لا يمنع ذلك من لزوم قيام المحكم بواجب التصريح المحمول عليه بقطع النظر عن مدى جدية سبب التجريح ومنه فإن مجرد إمتناع المحكم عن تقديمه التصريح رغم مطالبته بذلك كتابيا من طرف أحد أعضاء الهيئة التحكيمية وبقطع النظر عن مدى جدية سبب التجريح يعدّ مخالفة منه لأحكام الفصل 22 من مجلة التحكيم وهو ما من شأنه أن يؤكد الشكوك حول عدم إستقلاليته وحياده وهو ما ينطبق على وضعية الحال فالمحكم الأستاذة الهام بن عمار (المعقب ضدها الثانية) إمتنعت عن تقديم التصريح بالحياد والإستقلالية طبق ما تقتضيه أحكام الفصلين 10 و22 من مجلة التحكيم رغم مطالبتها بذلك والتنبيه عليها بواسطة عدل التنفيذ «ن. ب» حسب محضره عدد 559 بتاريخ 18-11-2015 وبعد أن سبق مطالبتها بذلك حسب التقارير المؤرخة في 07 و16 جويلية 2015 المقدمة للهيئة التحكيمية وطالما كان الأمر كذلك ولم تنقيد الأستاذة الهام بن عمار بإحكام الفصل 22 من م ت ولم تصرح بصفة تلقائية ورفضت تقديم التصريح في حيادها وإستقلاليته عند مطالبتها رسميا بذلك من قبل الطاعنة الآن وأن إصرارها على الرفض من شأنه أن

يثير الشكوك حول إستقلاليته وحيادها ويؤسس لطلب التجريح فيها ويجعله طلبا مقبولا بقطع النظر عن مدى جدية سبب التجريح.

وحيث أن محكمة القرار المطعون فيه وحينما لم تلتفت إلى مسألة إمتناع المحكم المجرح فيه الأستاذة الهام بن عمار ورفضها تقديم التصريح بإستقلاليته وحيادها رغم مطالبتها بذلك بصفة رسمية من الطاعنة الآن وإرتكازها في قضائها أساسا على مدى وجود علاقة تربط بين المحكم المخدوش فيه وأطراف النزاع التحكيمي قبل وأثناء نشر القضية التحكيمية والحال أن مجرد الإمتناع عن التصريح يؤسس لطلب التجريح لما يثيره من ريبة وشك حول الإستقلالية والحيادية تكون قد أورثت قضاءها خرقا لأحكام الفصلين 10 و 22 من مجلة التحكيم وهضما لحقوق الدفاع المقترن بضعف التعليل وهو ما يتعين معه قبول المطاعن المثارة ونقض قرارها المطعون فيه مع الإحالة».

10-2 التجريح في المُحكّم ينزع عنه كل ولاية إلى حين البت في مآل التجريح
قرار تعقيبي عدد 80379 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجلاء المصمودي والسيدة نجوى الغربي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

«حيث أسست المعقبة طعنها على أن القرار المنتقد أغفل مناقشة دفوعاتها بما يجعله مشوبا بضعف التعليل.

وحيث أنه من المتفق عليه أن تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا وكفيلا بتحقيق المقصود منه إلا متى أنبنى على أسباب واضحة وشاملة لأجوبة المحكمة عما أثير من دفعات بصورة تقنع المطلع عليها بوجاهتها فإن خلا من ذلك كان مستهدفا للنقض لخلوه من التسبيب الكافي والتفاتة عن الرد عما أثير من دفعات جوهرية وتبين من أسانيد القرار المنتقد أن المحكمة لم تجب عن مسألة مهمة تمت إثارتها وهي التجريح في أحد المحكمين ورغم ذكرها كأحد المسائل المطروحة فهي قد بيّنت أن طلب الإبطال أنبنى على مجموعة من الأسباب التي يندرج بعضها في إطار خرق قواعد الإجراءات الأساسيةية هيئة التحكيم لتتولى تبعا لذلك مناقشة مسألة تركيبة

هيئة التحكيم دون غيرها وأغفلت بذلك مناقشة الدفع المأخوذ من خرق قواعد الإجراءات الأساسية ولم تبدي رأيها بشأنها ولم ترددها سلباً أو إيجاباً ولم تتناولها بالدرس وهو ما يكسي القرار المطعون فيه ضعفاً في التعليل على معنى الفصل 123 من م م م ت وخرقاً للإجراءات الأساسية يستوجب نقضه.

عن المطعنين الثاني والثالث المأخوذ من تحريف الوقائع وهضم حق الدفاع حيث تدفع المعقبة بأن محكمة الحكم المطعون فيه أغفلت الدفع بالتجريح في شخص المحكم.

وحيث ثبت من اسانيد القرار المنتقد أن المعقبة كانت دفعت أمام محكمة الحكم المطعون فيه بوجود قضية في التجريح في شخص المحكم وأن الأمر يقتضي إنتظار مآلها وهي مسألة تكتسي أهمية لأن التجريح في المحكم يجسم إنعدام الثقة في شخصه بما يتعذر معه مباشرة أي عمل قانوني في إطار مأمورية التحكيم وينزع عنه كل ولاية إلى حين البت في مآل التجريح وهو دفع على أهميته لتعلقه بالإجراءات الأساسية في مادة التحكيم لم تتناوله المحكمة بالدرس والتحليل بما يعرض قضائها للنقض.

عن المطعن الرابع المأخوذ من خرق القانون:

حيث تدفع المعقبة بأن أحد أعضاء الهيئة المشاركة في الحكم لم يكن من ضمن القضاة الذين تلقوا المرافعة وهو دفع غير وجيه طالما ثبت من أوراق الملف أن أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي ذاتها التي تلقت المرافعة وفق ما تضمنه محضر جلسة الحكم وكانت لائحة الحكم مستوفية لشروطها القانونية وتعين رد المطعن لخلوه من كل سند صحيح».

10-3 التخلي عن الشرط التحكيمي للطبيعة الارادية للتحكيم

قرار تعقيبي عدد 2020 / 24228 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة المدنية الرابعة برئاسة السيد السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي والسيد محمد معز العروسي وبمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة اسكندر.

حيث دفعت الطاعنة بأنه تم مخالفة الإتفاق بوجوب المرور بإجراءات الصلح كمخالفة الشرط التحكيمي.

وأما بخصوص المطعن المتعلق بمخالفة الشرط التحكيمي فزيادة عن كونه دفع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المنتقد فهو غير وجيه تطبيقاً للفصل 19 من مجلة التحكيم لكونه من الثابت أن التحكيم يظل إرادياً يستند إلى إرادة الأطراف بما يبرر التنازل عن اللجوء إليه وعليه فإن عدم إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام القضاء بالشرط التحكيمي والقبول بالتقاضي بالخوض في النزاع يعد تنازلاً عن الشرط التحكيمي وهو ما ينطبق على الدفع بوجوب المرور بإجراءات الصلح ذلك أن الطرفان استمرا على التقاضي دون أية إثارة للفصل الخامس من الاتفاق وليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها باعتبار أن اللجوء إلى الصلح يهم الأطراف وأن من ترك الطور الصلحي وأستمر في التقاضي يعتبر متخلياً عن المسعى الصلحي وليس له أن يثيره أمام محكمة التعقيب كمطعن جديد بما يتعين معه رد المطاعن لعدم وجاهتها».

11 - قانون جزائي وإجراءات جزائية

1-11 قانون جزائي

1-1-11 كتب الاسقاط لا تأثير له على وجه الفصل في أصل القضية -استثناس المحكمة بكتب الاسقاط في تقدير العقاب

قرار تعقيبي عدد 82567 بتاريخ 12 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة الثانية والعشرون برئاسة السيد رضا العرعوري وعضوية المستشارين السيدين منير وردليتو وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العام السيد محمد القمودي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سنية العبادوي.

«وحيث انه خلافا لما ورد بمستندات الطعن، فانه تبين ان المتهم حضر لدى محكمة الحكم المطعون فيه واكتفى بانكار التهمة المنسوبة إليه دون تسجيله أي طلب من المحكمة بما في ذلك ان له كتب اسقاط أو أي مؤيد آخر يريد الادلاء به وبالتالي فان المحكمة وفرت له كل الضمانات القانونية للدفاع عن مصالحه دون هضم لحقوقه.

وحيث انه علاوة عما ذكر فان كتب الاسقاط المحتج به، ولو في حالة الادلاء به، لا تأثير له على وجه الفصل في أصل القضية، وانما للمحكمة الاستئناس به في تقدير العقاب علما وأن المحكمة غير مقيدة به لما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن .

وحيث يبرز وان تلك المحكمة أحسنت تطبيق القانون وأن حكمها كان معللا التعليل القانوني والمستساغ بما يتوافق واحكام الفصل 168 من م ا ج .
وحيث أن المطعن يرمي في حقيقة الأمر إلى مناقشة محكمة الحكم المنتقد فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي يدخل في نطاق اجتهادها المطلق لا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف .

وحيث لم تأت مستندات التعقيب بما يوهن الحكم المنتقد في شيء، وكان بذلك الحكم معللا كما يجب قانونا دون تحريف للوقائع ولا خرق للقانون بما يؤدي إلى رفض المطعن لخلوه من المستند الصحيح».

11-1-2 العنف كركن مشدد لجريمة السرقة

قرار تعقيبي عدد 97502 بتاريخ 11 نوفمبر صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي .

«حيث أن تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل سليما ومستساغا إلا إذا إستخلصت المحكمة النتائج القانونية السليمة من الوقائع المعروضة عليها .
وحيث نعى المعقب على القرار المطعون فيه قراءة للفصل 260 من م ج لم يتضمنها مطلقا بخصوص العنف كركن مشددا لجريمة السرقة .

وحيث أن العنف الذي إشرطه الفصل 260 من م ج في السرقة الموصوفة لا تتكون منه جريمة مستقلة بذاتها مهما كانت نتيجته وإنما هو أساسي لإعطاء القضية صبغتها الجنائية وعليه فهو ظرف تشديد يكسي السرقة صبغة جنائية بشرط أن يكون واقعا قبل فعل الإختلاس أو مقارنا له أو لاحقا لذلك الفعل بغرض الفوز بالمسروق .

وحيث وبناء على ذلك فإن الركن المشدد لجريمة السرقة موضوع قرار الإحالة هو كل عنف شديد أو تهديد به مسلط على المجني عليه بأي وسيلة كانت بقصد جبره على التخلي عن متاعه لفائدة الجاني سواء كان ذلك العنف أو التهديد به سابقا لفعل الإختلاس أو متلازما معه أو إثره لتسهيل إتمام السرقة أو الفوز بالمسروق.

وحيث وخلافا إلى ما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد فإنه ورجوعا لما له أصل ثابت بملف القضية يتبين وأن المتهم المعقب ضده قد تولى الإعتداء بالعنف الشديد على المتضرر حينما ضبطه وهو يخرج من مستودع منزله بعد أن تمكن ومن معه من إختلاس أكياس من الزيتون وآلة وزن من منزل الشاكي نقلوها بعيدا عن المكان الذي كان يحفظها فيه صاحبها وإن العنف المسلط منه على المتضرر لم يكن إلا بغاية التمكن من الفوز بالمسروق وحتى لا يحول المتضرر بينه وبين الفوز به وهو ما حققه الشاهد ر. ق. الذي أكد أنه عاين الشاكي يمسك بالمتهم وبينهما كيس به كمية من الزيتون.

وحيث أساءت محكمة القرار المطعون فيه إستخلاص النتيجة القانونية السليمة من الوقائع المعروضة عليها وأخطأت في تطبيق القانون فإستحق قرارها النقض مع الإحالة لهذا السبب».

11-1-3 عدم دفع مال النفقة - الفترة السابقة للإعلام يبقى دينا مدنيا - تعريف حالة العسر

قرار تعقيبي عدد 82586 بتاريخ 2 مارس 2020 صادر عن الدائرة الحادية عشرة برئاسة السيدة ماجدة بن غربية وعضوية المستشارين السيدين محمد العفيف الجعدي وعماد الدغاري وبمحضر المدعي العام السيدة فوزية قمري وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة أمال بن نصر.

« حيث نص المشرع التونسي صلب الفصل 53 مكرر من م.أ.ش على عقاب سالب للحرية وخطية لكل شخص قضى شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه وثبت تعمدته الإمتناع عن أداء مال النفقة أو جراية الطلاق، ولقيام الركن المادي للجريمة المذكورة ، يجب توفر عنصرين إثنيين، أولهما صدور فعل سلبي يتمثل في عدم الدفع وثانيهما إمتداده في الزمن، كما لا تتكون الجريمة إلا من تاريخ الإعلام

وبقاء المعني عمدا شهرا كاملا دون أداء ما حكم به أما ما سبق الإعلام فإنه يبقى دينا مدنيا غير موجب للتبعية وإنما للإستخلاص طبق قواعد القانون المدني.

وحيث فضلا ما سبق بيانه فإنه بقراءة الفصل 53 مكرر من م.أ.ش يتّضح أن المشرع لم يجعل من القصد عنصرا مفترضا الأمر الذي إستقر عليه فقه قضاء محكمة التعقيب منذ صدور النص الأول لجريمة عدم دفع النفقة وجراية الطلاق ضرورة أنها من الجرائم القصدية التي لا تقوم إلا بتوفر الركن القصدي وهو سوء النية والتعمّد في عدم الأداء ولذلك فإن تواجدها يبقى رهين ثبوت حالة العمد والإصرار على عدم الإنفاق تنكيلا بمستحق النفقة المحكوم بها وإمعانا في الإضرار به وإلحاحا في ضغط الحاجة عليه.

وحيث وفي هدي ما تقدم ذكره قد يتمسك المطالب بأداء مال النفقة لدفع التهمة الموجهة ضده بأنّ إمتناعه عن الأداء كان نتيجة أمر خارج عن إرادته أو أن بعض الظروف قد ألّمت بدمته المالية جعلته يعجز عن الخلاص وهي حالة العسر.

وحيث أنّ التمسك بحالة العسر عن الإنفاق من الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية وعلى محكمة الموضوع تفحص القرائن والأدلة المعروضة عليها في صورة التمسك به مثلما هو الحال في القضية موضوع النظر وتقديره موكلول لإجتهد قضاة الأصل بشرط التعليل وباعتبار حالة العسر واقعة قانونية يتم إثباتها بجميع وسائل الإثبات مع ضرورة التمييز بين حالة العوز الوقتي وحالة العسر التي تفترض عجزا كليا عن الأداء غير عارض ولا مؤقت ولم يتسبب فيه المدين بإرادته.

وحيث أنّ التمسك بحالة العسر في ظل وقائع قضية الحال ومؤيداتها يقتضي النظر إليه في مقارنة تأليفية وتمحيص لجميع القرائن والأدلة الناتجة عن الأعمال الإستقرائية المجرة بحثا وفي طور المحاكمة الأمر الذي أغفلت عنه محكمة الموضوع بالطور الابتدائي وتداركته محكمة الحكم المطعون فيه الآن وبينته بمستندات حكمها المؤسس على ما له أصل ثابت بوقائع الدعوى وأدلتها إستنادا إلى تصريحات الطرفين وما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي المنجز بتسخير من قاضي الناحية والمؤرخ في 15/11/2017 وتقرير البحث الإجتماعي المنجز

بواسطة الأخصائيين الاجتماعيين بوحدة النهوض الاجتماعي بغر الدماء المؤرخ في 11/12/2017 المضافة لملف القضية فضلا عما تضمنه محضر التحريات المنجز من قبل قاضي الناحية بتقريره المؤرخ في 06/11/2017 والتي تبين من خلالها نوعية الإعاقة التي لحقت بالمعقب ضده منذ سنة 2012 بتاريخ سابق للتشكي في قضية الحال ولتاريخ الحكم القاضي بالترفيغ في النفقة سند التتبع وطبيعة تلك الإعاقة ومظاهرها وآثارها وحالة العجز الكلّي عن التكبّس والعمل وثبت أن المعقب ضده لا يستطيع القيام بشؤونه الخاصة وعاجز عن الحركة وعن النطق ضرورة أن حضوره في مختلف أطوار سير الدعوى بحثا أو المحاكمة بمناسبة قضية الطلاق المنشورة بينه وبين الشاكية كان بمساعدة وبمرافقة شقيقته القائمة بشؤونه لعجزه حسب ما هو مضمن بالمحاضر المظروفة بملف القضية وتبين أن شقيقته هي من تتولى توفير مستلزماته ودفع معلوم النفقة المطالب بأدائه فضلا عن أن ثبوت الأداء لمقدار النفقة الأصلي المحكوم به للشاكية وإبنتها قبل الترفيع فيها بموجب الحكم سند التتبع في قضية الحال يتتفي معه ركن القصد وسوء النية تنكيلا بمستحق النفقة المحكوم بها أو إمعانا في الإضرار بها أو إلحاقا في ضغط الحاجة عليها وهو ما إنتهت إليه محكمة الحكم المنتقد.

وحيث يتضح مما سبق بيانه أن محكمة الحكم المطعون فيه قد وازنت بين جميع أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصر القضية دون إغفال أو خطأ وإستخلصت من كل ذلك ما إقتنع به وجدانها وإستقر عليه رأيها وبينته بمنطوق حكمها مستعرضة الأركان القانونية للجريمة ومبينة قرائن الإدانة والبراءة على حد سواء وقيمتها الحجية في الإثبات ورجحت بينهما بتعليل مستساغ واقعا ومنطقا وقانونا وأن ما إنتهت إليه محكمة الموضوع من هذه الناحية قائم على إستقراء سليم لماديات الواقعة وأدلتها وفهم صحيح لملاساتها وموازنة جدية بين أدلة الدعوى دون إغفال أو سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.

وحيث أضحت المطاعن المقدمة من هذه الناحية ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما إعتدته من العناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي داخل في إجتهادها المطلق وطالما تبين أن التأسيس لقاعدة الحكم محل الطعن كان مبناه الوقائع الصحيحة الثابتة والتطبيق السليم للقانون والموازنة بين مختلف أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون لبس أو خطأ أو ضعف في

التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع فإنه يتعين تبعا لذلك ردّ المطاعن لخلوها من المستند الصحيح.

وحيث ومن جهة أخرى فقد أحرز القرار المطعون فيه على جميع مقوماته القانونية ولم يلاحظ به أي خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام».

11-1-4 عدم الإمثال لما أمرت به القوانين الصادرة ممن له النظر

قرار تعقيبي عدد 84595 بتاريخ 02 جوان 2020 عن الدائرة الجزائية الثامنة والعشرون برئاسة السيد المنصف بلحاج وعضوية المستشارين السنيين صلاح الشياحي وريم دفدوف وبمحضر الادعاء العام السيد بديع الحكيم وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد.

« حيث اقتضى الفصل 315 من المجلة الجزائية أنه: «يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنائير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين لا يمثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر».

وحيث استقر فقه القضاء أنّ إضافة النيابة العمومية لنسخة من القرار الواقع مخالفته شرط أساسي وورقة رئيسية من أوراق الملف يتعذر على المحكمة البت فيه بدونها لما لها من تأثير على وجه الفصل في القضية ولكونها المحدد الرئيسي لحصول الجريمة من عدمها.

وحيث يستخلص مما سبق بسطه أنّ محكمة القرار المنتقد حينما قضت بثبوت إدانة المعقب من أجل جريمة مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر بدون المطالبة بإضافة القرار سند التتبع تكون قد خالفت القانون وعرضت قضاؤها للنقض».

11-1-5 جريمة تعطيل المرفق القضائي لا تقتضي أن يشير القاضي أي تتبع جزائي

قرار تعقيبي عدد 84902-84903 بتاريخ 02 جوان 2020 صادر عن الدائرة السادسة والعشرون برئاسة السيد منجي شلغوم وعضوية المستشارين السنيين عبد القادر غزال وحمادي الرحمان وبمحضر الادعاء العام السيد عبد الرحمان بين الحاج جلول وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

« [...] بخصوص جريمة تعطيل المرفق القضائي:

حيث أنّ تعليل الأحكام وتسببها هو من الأمور اللازمة لصحتها وأنّ التعليل ينبغي أيضا أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية منها والقانونية وأن يكون كذلك دالا على وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 ممن مجلة الإجراءات الجزائية.

وحيث عللت محكمة الحكم المطعون فيه قرارها القاضي ببراءة المتهم (ر) تعليلا غير سليم وغير مستساغ ذلك أنّ قيام تلك الجريمة لا يقتضي أن يثير القاضي أي تتبع جزائي بل يكفي أن يستنتج من خلال الوقائع الثابتة ما يفيد تحقق التشويش على سير المرفق القضائي وهو ما أكدته القضية المقررة ضمن تقريرها وتعزز بشهادة المدعو (ش.غ) وإقرار المتهم (ر) ذاته بحثا أنّه منع عملية قيس الأرض بما يجعل من أركان جريمة نص الإحالة بما فيها الركن القصدي قائمة في مواجهته ويورث الحكم المنتقد النقض دون المتهم الآخر (ع) التي تصادق الشاهدان بشأنه على كونه لم يكن حاضرا زمان الواقعة وكان الحكم المطعون فيه سليم بخصوصه».

11-1-6 لا يشترط في الجريمة السابقة عن جريمة غسل الأموال أن تثار بشأنها الدعوى العمومية أو أن يصدر بشأنها حكم بات بل يكفي للتدليل عليها وجود قرائن تدل بصفة واضحة على حصولها

قرارات تعقيبي عدد 84962 بتاريخ 2 جوان 2020 صادر عن الدائرة ... السيد (م.ع) وعضوية المستشارين السيدتين (ن.ع) و(ن.ش) وبمحضر المدعي العام السيد (ن.ز) وبمساعدة كاتب الجلسة السيد (ع.ع)

« [...] عن المطعن المأخوذ من خرق القانون لبطلان إجراءات التتبع:

حيث تأسس هذا المطعن على كون إجراءات التتبع في جريمة غسل الأموال مختلة لارتكازها على الجريمة القمرقية باعتبارها الجريمة المفترضة التي كانت مصدرا للأموال موضوع التبييض والتي كانت إجراءات التتبع في شأنها باطلة لعدم صدور إذن صريح أو تفويض من وزير المالية.

وحيث نصت أحكام الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10-12-2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل

الأموال أنه « يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأية وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من كل جنحة أو جناية ويعتبر أيضا غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويلها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو المساعدة في ذلك.

وحيث ولقيام جريمة غسل الأموال فقد اشترط المشرع توفر أركان ثلاث وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض المتمثل في الجريمة الأصلية السابقة عن جريمة غسل الأموال والتي كانت مصدرا للعائدات غير المشروعة المراد إخفائها، ولا يشترط بخصوص الجريمة المفترضة أن تتأثر بشأنها الدعوى العمومية أو أن يصدر بشأنها حكم بات بل يكفي للتدليل عليها وجود قرائن تدل بصفة واضحة على حصولها وهو ما يجعل إثارة التتبع بخصوص الجرائم القمرقية في إطار هذه القضية كاف لتوفر الجريمة المفترضة حتى وإن تبين فيما بعد أن إجراءات التتبع بشأنها باطلة».

11-1-7 كذب واعتداء على الأخلاق الحميدة

11-1-7-1 ركن العلنية في جرمي الكذب العلني والإعتداء على الأخلاق الحميدة يقوم بالجهر بعبارات نابية بمكان يسمعه غير المتخاطبين بنية الأذى والتشهير

قرار تعقيبي 86356 عدد بتاريخ 2 جوان 2020 عن الدائرة العشرية برئاسة السيد المنذر اللومي وعضوية المستشارين السيد عادل بوصفارة والسيدة هناء سحنون وبمحضر المدعي العام السيدة لمياء بن إسماعيل وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

«عن المطعن الوحيد المثار والمأخوذ من مخالفة القانون وضعف التعليل:

حيث نعى الطاعنين على محكمة القرار المطعون فيه اعتبارها أن الجريمة غير قائمة في حق المعقب ضده رغم توفر عديد القرائن التي تفيد ارتكابه للجرائم المنسوبة له.

وحيث تبين بالإطلاع على مستندات القرار المنتقد أن المحكمة إعتبرت أنه ولئن تضمن محضر المعاينة المحررة من طرف عدل تنفيذ عبارات قذف وأخرى منافية للأخلاق إلا أن ذلك لا يوفر في جانب المتهم جرائم القذف العلني والإعتداء على الأخلاق الحميدة لعدم توفر ركن العلنية.

وحيث إستقر فقه محكمة التعقيب أن جريمة القذف العلني والإعتداء على الأخلاق الحميدة تستوجب توفر ركن العلنية وأن هذا الركن يتوفر بمجرد الجهر بعبارات نابية وجارحة بمكان بحيث يسمعه أو يمكن أن يسمعه غير المتخاطبين أو المتخاصمين بنية الأذى والتشهير.

وحيث بالإطلاع على أوراق القضية وخاصة محضر المعاينة والصور التي وقع إلتقاطها يتبين أن المتهم المعقب ضده قام بسب وشتم الطاعن داخل عيادته الطبية وبحضور عدة مرضى بالعيادة واللذين طلب المعقب من المحكمة سماع شهادتهم.

وحيث تأسيسا على ذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه من عدم توفر ركن العلنية بشكل تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل يستدعي رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيقه الأمر الذي يتعين معه نقضه في خصوص جريمتي القذف العلني والإعتداء على الأخلاق الحميدة لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وحيث أنه وخلافا لما تمسك به الطاعنان فإن ما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد من أن جريمة التهديد بما يوجب عقاب جنائي غير متوفرة الأركان يكون في طريقه على اعتبار أن العبارات المذكورة من قبل المتهم المعقب ضده لا تؤسس الركن المادي لتلك الجريمة ولذا تعين رفض التعقيب في خصوص هاته الجريمة».

11-1-7-2 تفصيل العبارات التي تفوه بها المتهم لتقدير فحواها وتكييفها

قرار تعقيبي عدد 79769 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن عن الدائرة السادسة والعشرون برئاسة السيد منجي شلغوم وعضوية مستشاريها السيدين عبد القادر غزال وحمادي الرحماني وبمحضر المدعي العام السيد عبد الرحمان بن الحاج جلول وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

» [...] عن المطعنين المتعلقين بجريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة والكذب العلني:

حيث أنه لقيام الجريمتين لابد من وجود ذكر صريح للعبارات حتى يمكن للمحكمة تقدير حصول مساس بالأخلاق العامة من عدمه أو إسناد أمر معين لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار إنسان من عدمه.

وحيث بخلو الملف من تلك العبارات فإنه ليس للمتضررة أو الشاهدة إستنتاج أن تلك الكلمات تمثل جريمة دون ذكرها تفصيلاً بدعوى الإستحياء لأن ذلك يمنع المحكمة من بسط رقابتها وإعمال رأيها فيها بتقدير فحواها وتصنيفها وتكييفها وإعطائها الوصف الدقيق وطالما أن محكمة القرار المنتقد لم تبين تلك العبارات فإن تحليلها يكون غير سليم ومخالف للقانون وتعين نقض القرار بخصوص تلك الجريمة».

11-1-7-3 الإعتداء على الأخلاق الحميدة بلفت النظر علناً إلى وجود فرصة لارتكاب فجور بتسجيلات سمعية بصرية-مقطع الفيديو المخل بالحياء لم يخرج إلى العلن

قرار تعقيبي عدد 77212 بتاريخ 19 أكتوبر 2020 صادر عن عن الدائرة الجزائية الثانية والعشرون برئاسة السيد رضا العرعوري وعضوية المستشارين السيدين منير وردليتو وكمال بوكثير بمحضر المدعي العام السيد محمد القمودي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سنية العبادوي.

» حيث اعتبر الطاعن ان الملف به من الحجج والقرائن ما يكفي لقيام الجريمة وتوفر اركان الجريمة المنسوبة للمتهمين (المعقب ضدّهما)، وان الحكم المنتقد لما قضى بالبراءة هو ضعيف التعليل ومخالف للقانون.

وحيث رجوعاً إلى مظروفات الملف ثبت وأن محكمة الحكم المنتقد استعرضت جملة عناصر القضية مع توليها التدقيق فيها واستخلصت منها النتيجة القانونية التي مفادها وان الأركان القانونية للجريمة موضوع قرار الإحالة ومنها القصد الجنائي غير متوفرة ذلك وان نية المتهم صاحب الهاتف الجوال لم تتجه إلى نشر مقطع الفيديو المتضمن لمشاهد مخلة بالحياء ولم يصدر عنه أي فعل

يعبر عن اعتزامه القيام بذلك سيما وان الهاتف الجوال هو ملك خاص للمتهم ولم يكن في متناول العموم للاطلاع عما خزن بذاكرته .

وحيث أن قرارها انبنى على أسس قانونية سليمة ذلك وأن اركان جريمة الإحالة غير متوفرة طالما وان مقطع الفيديو المخل بالحياة لم يخرج إلى العلن ولا أحد كان بمقدوره الاطلاع عليه وان حفظ المتهم له بذاكرة هاتفه لا يعد جريمة، ذلك وانه لا جريمة بدون نص .

وحيث أن المطاعن ترمي في حقيقة الأمر إلى مناقشة محكمة الحكم المنتقد فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي يدخل في نطاق اجتهداها المطلق لا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف .

وحيث لم تأت مستندات التعقيب بما يوهن الحكم المنتقد في شيء ، وكان بذلك الحكم معللا كما يجب قانونا دون تحريف للوقائع ولا خرق للقانون بما يؤدي إلى رفض المطعن لخلوه من المستند الصحيح».

11-1-7-4 توارد جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة مع جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول

قرار تعقيبي عدد بتاريخ 8 جويلية 2020 صادر عن الدائرة الرابعة عشر برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية المستشارين السيدين العميد قاضي نورة الامام وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العام السيد عادل الغالي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سميرة بوشوشة.

« عن المطعنين المتعلقين بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع:

حيث رجوعا إلى الحكم المنتقد فان محكمة الأصل قد استخلصت وان جريمتي الاعتداء على الاخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه المنسوبة للمتهمين متواردتين على معنى أحكام الفصل 54 من المجلة الجزائية.

وحيث اقتضى الفصل 54 م ج المشار إليه أنه: «إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقرر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده».

وحيث انه بالنظر في أقوال المتهمين ثبت انها من الأفعال التي تكوّن في ذات الوقت الركن المادي لجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة أو لجريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه وبالتالي فان قاعدة أن الفعل الواحد تتكون منه عدة جرائم تنطبق على وقائع قضية الحال بما يجعل وأن قراءة محكمة الأصل لاحكام النص القانوني المذكور وفهمها له كانت سليمة .

وحيث ان المطاعن كانت ترمي في حقيقة الأمر إلى مناقشة تلك المحكمة في اجتهادها لاستخلاص النتيجة القانونية من عناصر القضية وهي التي كانت مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما ينزع عنها كل جدية ويجعلها مرفوضة .

وحيث لم تأت مستندات التعقيب بما يوهن الحكم المنتقد في شيء ، وكان بذلك الحكم معللا كما يجب قانونا دون تحريف للوقائع ولا خرق للقانون بما يؤدي إلى رفض المطعن لخلوه من المستند الصحيح» .

11-1-8 وسائل تعطيل حرية العمل محددة حصرا لا وجود فيها لوسيلة التهديد
المعنوي

قرار تعقيبي عدد 86882 بتاريخ 09 نوفمبر 2020 صادر عن الدائرة الثالثة عشرة برئاسة السيدة رجاء الفخفاخ وعضوية المستشارين السيد زهير الحسني والسيدة شفيقة الحجللاوي وبحضور ممثلة النيابة العمومية السيدة ليلي الشابي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني .

«حيث دفع الطاعن صلب مستندات الطعن بأن التهديد في واقعة قضية الحال هو تهديد معنوي لما فيه من إدخال للخوف والفرع في نفوس الموظفين بسبب كثرة عدد المحتجين وبأنه لا يستوجب أن يكون التهديد بالقول .

وحيث اقتضت أحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية أنه « يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.»

وحيث عللت محكمة القرار المنتقد قضاءها بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى بالقول بأنه: «ولئن ثبت من أوراق الملف أن المتهم ا.ع. ومن معه قد تسببوا في تعطيل حرية العمل بمحطة النقل البري بالفوار ومنعوا الحافلة

وسائقها من القيام بالسفرة المبرمجة ليوم الواقعة فإن ما صدر عن المتهم من تعطيل للعمل لم يكن باستعمال إحدى الوسائل المشار إليها بالفصل 136 م ج...»

وحيث إن هذا التعليل هو تعليل صحيح مستمد من قراءة سليمة للنص القانوني المذكور إذ لم يثبت لمحكمة القرار المنتقد أن تعطيل العمل كان باستعمال إحدى الوسائل المحددة حصرا صلب الفصل 136 م ج ضرورة أنه خلافا لما تمسك به المعقب فإنه لا وجود صلب الفصل الموماً إليه - ومثلما تمسك به المعقب - لتهديد معنوي كوسيلة من وسائل تعطيل العمل ، ليبقى المطعن المشار مندرجا صلب السلطة المطلقة للمحكمة في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها وهي بذلك جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهاد محكمة القرار المنتقد بصفتها محكمة موضوع وليس لهذه المحكمة أن تنقض الاجتهاد طالما كان معللا ومسببا.

وحيث تفريعا عليه تكون محكمة القرار المنتقد قد وفقت فيما ذهبت إليه فكان حكمها مؤسسا واقعا وقانونا ، مبنا على تقدير سليم للوقائع وتنزيل لصحيح القانون على ما عرض أمامها من معطيات وترتيب ما يستوجب من آثار قانونية على ذلك ولا تثريب عليها فيما انتهت إليه واتجه لذلك رد مطلب التعقيب أصلا».

11-1-9 إدخال عملة أجنبية صحيحة فقدت قيمتها الإبرائية

قرار تعقيبي عدد 14641 بتاريخ 16 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرون برئاسة السيد رياض الإمام وعضوية المستشارين السيد شكري كمون والسيدة سامية العابد بحضور المدعي العمومي السيد جلال الزواوي ومساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير .

« حيث يستخلص من أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية أن دائرة الاتهام تتمتع بسلطة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن المعروضة أمامها لتوجيه التهمة موضوع التتبع ولها سلطة مطلقة باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية في تناول الوقائع واضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، فتقرر تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو تقرر نقضه اذا ما تبين لها بأن لا وجه للتتبع لعدم كفاية الأدلة على المظنون فيه وذلك بالاستناد لما توفر لديها بأوراق الملف من

أدلة ومؤيدات مع وجوب بيان الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها في قرارها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.

وحيث لم تر محكمة القرار المنتقد فيما أسفرت عنه الابحاث ما يفيد قيام المطعون ضدهم بجريمة الفصل 187 من م ج المنسوبة اليهم، ذلك أن الفصل المذكور يقتضي مؤاخذه كل من يدلس أو يغير العملات الأجنبية أو يشارك في وضع أو عرض أو ادخال عملات أجنبية مدلسة أو مغيرة. وهو ما يفترض أن تكون العملة الأجنبية الواقع عرضها أو وضعها أو إدخالها مدلسة سلفا، في حين أنه قد ثبت من الاختبارات المجراة من قبل البنك المركزي أن الأوراق النقدية المحجوزة صحيحة الا انها فقدت قيمتها الابرائية بموجب سحبها من التداول.

وحيث لا خلاف أن الركن المادي لجريمة الفصل 187 يتمثل في وجود عملة مزيفة. أما وقد تبين أن العملة المحجوزة غير مدلسة، فان محكمة القرار المنتقد قد أحسنت فهم وتطبيق القانون حين اعتبرت أن الأفعال المنسوبة للمظنون فيهم تبقى خارجة عن مناه تطبيق أحكام الفصل 187 م ج لغياب الركن المادي للجريمة موضوعه. وأنه لا يمكن مؤاخذتهم على ذلك الأساس ولو كانت لديهم نية تدليسها لاحقا، ضرورة أن ركن التدليس يجب أن يكون ثابتا وسابقا عن عرض العملة وادخالها.

وحيث أن ما إنتهت إليه دائرة القرار المطعون فيه إنما كان في إطار سلطتها في تمحيص الوقائع واضفاء التكييف القانوني المناسب لها على ضوء ما توفر لديها من مؤيدات وقد عللت قرارها تعليلا سليما واقعا وقانونا لم تأت دفعات الطاعن بما يوهنه، بما يتجه معه التصريح برفض مطلب الطعن».

11-1-10 التجاهر بما ينافي الحياء يقوم على فعل مخل بالحياء بمكان عمومي أو مكان خصوصي يمكن للغير مشاهدة ما يقع فيه

قرار تعقيبي عدد 83446 بتاريخ 10 مارس صادر عن عن الدائرة السادسة والعشرون برئاسة السيد منجي شلغوم وعضوية مستشاريها السيدين عبد القادر غزال وحمادي الرحماني بمحضر المدعي العام السيد بعد الرحمان بن الحاج جلول وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

« حيث أن تعليل الأحكام وتسببها هو من الأمور اللازمة لصحتها وأن التعليل ينبغي أيضا أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية منها والقانونية وأن يكون كذلك دالا على وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وحيث أن جريمة التجاهر بما ينافي الحياء تقوم على جملة من الأركان منها الفعل المادي المخل بالحياء وحصول هذا الفعل بمكان عمومي أو مكان خصوصي لكن يمكن للغير مشاهدة ما يقع فيه.

وحيث عللت محكمة الحكم المطعون فيه قرارها القاضي بإدانة المتهم تعليلا سليما مستمدا عناصره مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومستساغا من الناحية القانونية والواقعية إستنادا إلى ما ثبت لديها بإقرار المتهم بكونه كان يعاقر الخمر بسيارته المركونة بالطريق العام وتأييد ذلك بضبطه من طرف باحث البداية داخل السيارة بصدد معاقرة الخمر وما تم حجزه عنه من علب جعة فضلا عن تعذر سماعه تاريخ الواقعة نظرا لحالة السكر التي كان عليها وهو ما يجعل من تلك الجريمة مستوفية الأركان.

وحيث فضلا عن ذلك فإن المطعن المثار كان يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها وليس لهذه المحكمة أن تنقض الاجتهاد طالما كان الحكم معللا ومسببا ».

11-1-11 عقد الشركة ليس من عقود الأمانة - انطباق مجلة الشركات التجارية قرار تعقيبي عدد بتاريخ 13 مارس 2020 صادر عن عن الدائرة السابعة عشر برئاسة السيدة روضة أويش ومستشاريها السيدتين مفيدة المداني ونائلة العباسي وبمحضر المدعي العام السيد عادل الدريسي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سميرة بوشوشة.

«عن جميع المطاعن لاتحاد القول فيها:

حيث لا جدال أن محكمة الأصل تنظر في الوقائع وتبحث عن قرائن البراءة وقرائن الإدانة على حد سواء وذلك سعيا منها لكشف الحقيقة ثم تخضعها

لنصوص القانونية المنطبقة في نطاق سلطتها في تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني المناسب.

وحيث تكون محكمة الحكم المنتقد لما طبقت الفصل 297 من م ج على وقائع قضية الحال والحال أن الأمر يتعلق بعقد شركة والذي ليس من عقود الأمانة الموجبة لقيام جريمة الخيانة والتالي فاعتبار المحكمة الوكالة على الشركة ظرفا مشددا لجريمة الخيانة فيه خرق واضح للقانون ولموجبات الفصل 297 من م ج.

وحيث ورجوعا للوقائع وأخذا بالتطبيق الضيق لمبدأ الشرعية وطالما ثبت أن المتهم المعقب هو وكيل الشركة الشاكية وبصفته تلك فإنه وحسب مجلة الشركات التجارية عند إرتكابه للجرائم المتعلقة بإدارة الشركة يكون تحت طائلة جريمة الاستبداد بأموال الشركة موضوع الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية وهو نص خاص يقدم على الفصل 297 من م ج الذي هو نص عام.

وحيث تكون محكمة الحكم المنتقد لما قضت على النحو الذي قضت به قد أورثت حكمها خرقا للقانون وضعفا في التعليل موجبان للنقض والإحالة».

11-1-12 جريمة القتل

11-1-12-1 قتل نفس بشرية عمدا مع سابقة القصد - القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

قرار تعقيبي عدد 87205 بتاريخ 13 مارس 2020 صادر عن عن الدائرة الخامسة عشر برئاسة السيد جلال الدين بوكثيف وعضوية المستشارين السيدين عدنان الهاني وأمال عاشور وبمحضر المدعي العام السيد أنيس ضيف الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة نجلاء الهمامي.

« [...] وحيث وبخصوص ضعف التعليل وتحريف الوقائع فإنه لا خلاف أن تعليل الأحكام هي من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها وهي من المسائل الهامة والجوهرية التي ترجع لإختصاص محكمة الموضوع وهو ما يجعل مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما إعتدته من العناصر لتبرير قضائها جدلا موضوعيا داخل في إجتهادها المطلق وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض هذا الإجتهاد ويبقى دور محكمة التعقيب منصبا على مراقبة مدى إحترام المحكمة

لمقتضيات القانون في إجتهادها ومدى تناولها ومناقشتها لكافة المستندات القانونية ولكافة الأركان القانونية التي إستندت عليها عند قضائها فضلا عن مدى موازنتها بين الأدلة والقرائن التي لها أصل ثابت بملف القضية.

وحيث أنه لا خلاف أيضا أنه من المبادئ الأساسية القضائية عند إصدار المحاكم لأحكامها التنصيص على الأركان القانونية للجريمة في ضوء وقائع القضية وما له أصل ثابت بالملف.

وحيث يتضح بالرجوع إلى حيثيات القرار المنتقد أن محكمة القرار أسست قرارها بثبوت إدانة المتهم على إقرارات المتهم التلقائية بالقتل فضلا عن المعاينات الميدانية بمسرح الواقعة فضلا عن شهادة الشهود إلا أنها لم توضح بصفة واضحة وجلية أركان الجريمة وسيما عنصر سابقة الإضمار الوارد بها الفصل 202 من المجلة الجنائية والذي يستلزم حتما سبق عزم الجاني على ارتكاب الجنائية بعد التفكير فيها وفي عواقبها وهو هادئ البال ذلك أنه لا يكفي بالنسبة لجرائم القتل عمدا مع سابقة الإضمار بيان توفر هذا الركن ووجود القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم القصدية وهو علم الجاني أن الأمر الذي يأتيه هو أمر محضور بل لا بد في جنائية القتل من توفر قصد جنائي خاص وهو إنصراف علم الجاني إلى عناصر الجريمة وإنصراف إرادته إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه أي عزمه بدون رجعة إلى إزهاق روح المجني عليه وبإحجام محكمة القرار المنتقد عن بيان ذلك بصفة واضحة وصريحة تمكن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق محكمة القرار المنتقد لذلك يكون قرارها ضعيف التعليل موجبا للنقض».

11-1-12-2 أركان القتل العمد مع سابقة القصد

قرار تعقيبي عدد 90332 بتاريخ 6 مارس 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرين برئاسة السيد رياض الامام وعضوية المستشارين السيد شكري كمون والسيدة سامية بحضور المدعي العام السيدة سميرة القرمانى وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

«عن جملة المطاعن لترابطها ووحدة القول فيها:

حيث تمسك نائبو الطاعن بأن ذهاب المتهم إلى بيت أصهاره لم يكن الا لزيارة أبنائه ولمحاولة مصالحة زوجته وارجاعها إلى محل الزوجية ولم يكن ابدا بنية الاعتداء أو القتل. واعتبروا أن الحكم المطعون فيه قد أساء فهم وتطبيق أحكام الفصلين 201 و202 من م ج على وقائع قضية الحال وكان تعليل المحكمة لقضائها مشوبا يتحريف الوقائع والقصور في التسبيب.

وحيث أن نية القتل على معنى أحكام الفصل 202 المذكور هي أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة والمظاهر الخارجية التي يأتياها الجاني وتنم عما يضمرة في نفسه. واستخلاص هذه النية موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وقد اعتبرت محكمة القرار المنتقد أن نية القتل قد توفرت في جانب الطاعن باستعماله ل سلاح ناري قاتل بطبيعته وتصويبه إلى أماكن قاتلة من جسد المجني عليهما وعلى مرمى قريب وإعادة الاطلاق عليهما بمواطن مختلفة من الصدر والبطن والأطراف حسبما جاء بتقرير الطب الشرعي ولم يتركهما الا وهما جثتان هامدتان. فقضت زوجته نجبتها حينها وبقيت والدتها تصارع الموت حتى توفيت بعد بضعة أيام. وتؤكد للمحكمة بذلك رغبة المتهم في التخلص من المجني عليهما والدافع إلى ذلك كان الخلافات المتواصلة وشك المتهم في سيرة وسمعة زوجته التي وصلت به إلى حد انكار نسب ابنته مثلما تحرر عليه وعلى باقي افراد عائلة الضحيتين.

وحيث أن ما أورده الحكم المنتقد كافيا وسائغا في التدليل على ثبوت نية القتل وتضمن بذاته الرد على ما أثاره الدفاع من أن الواقعة لا تعدو أن تكون سوى مشاجرة، ومحاولة الضحية افتكاك البندقية من الطاعن أفضت إلى استفرازه فأطلق النار دون أن تكون لديه نية القتل. هذا فضلا على نهأه لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل انما نشأت لدى الجاني نتيجة اثاره أو مشادة أو استفزاز أو غضب، ذلك أن نية القتل هي قصد احداث الموت المعاصر للفعل بخلاف سبق الإصرار وهي الفكرة المصمّم عليها قبل الفعل.

وحيث نفى دفاع الطاعن أيضا توفر عنصر سبق الاصرار لخلو التحقيقات مما يفيد التفكير الهادئ والتروي والتدبير للجريمة، ذلك أن الواقعة خالية من رسم خطة الجريمة وأن الحادث كان وليد مشاجرة واستفزاز الجاني الذي لم يكن

هادئ الباب وأنه اعتاد على حمل أداة الاعتداء لممارسة هواية الصيد ولم يفكر في حملها كي يستعملها في القتل.

وحيث أن سبق الإصرار هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل تنفيذها، فهو يعني أن فكرة الجريمة قد خطرت للجاني قبل أن ينفذها بوقت كاف أتيح له فيه أن يفكر بهدوء ثم ينتهي إلى التصميم على ارتكابها، فيرتب وسائله ويرسم خطته ثم يمضي إلى تنفيذها.

وحيث كان من المقرر أنه على محكمة الموضوع أن تستنتج توفر سبق الإصرار مما يحصل لديها من ظروف الواقعة وملابساتها. وعليها أن تبين في حكمها القرائن التي استندت إليها لاستظهار سبق الإصرار باعتباره حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة، وإنما تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توفره ما دام مدلول تلك الوقائع لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.

وحيث اعتبرت محكمة القرار المنتقد أن سبق الإصرار متوفر في جانب المتهم بالاستناد إلى تصريحات الشاهد إ. غ. الذي حقق أن المتهم أخبره أنه يعتزم الذهاب للافطار عند أحد أصدقائه ولا كما ادعى هو بأنه ذاهب للصيد ولمصالحة زوجته. كما أن إخفاء البندقية بمكان قريب من منزل عائلة زوجته قد رأت فيه المحكمة عنصرا من عناصر التخطيط للجريمة خاصة وأن منزل أصهار المتهم يبعد مسافة 1.5 كلم عن منزله وكان تبرير ذلك بأنه كان يخشى ان تحتجز منه البندقية لعدم الترخيص فيها غير منطقي، وكان من باب أولى أن يخفيها بمكان آمن بالقرب من مقر إقامته هو لا قرب مقر إقامة أصهاره. هذا فضلا على أنه وعلى فرض الأخذ بروايته، فإن التصرف العادي والطبيعي يقتضي منه أن يرجع البندقية إلى مكان إخفاءها قبل التوجه إلى منزل أصهاره خاصة وقد سبق منهم التشكي ضده في مسك سلاح ناري بدون رخصة. لا أن يدخل عليهم بذلك السلاح وهو مشحون بالخرطيش بالإضافة إلى تحوزه بخرطيش أخرى. وهي مظاهر لا تدل مطلقا على رغبته في الصلح ولا تنهض سوى حجة على نيته المبيتة في القتل.

وحيث اعتبرت محكمة الحكم المطعون فيه أن سبق الإصرار قائم في حق المتهم وقد أعد خطة للانفراد بالضحيتين فأخفى البندقية بمكان قريب من

مسكنهما ثم بقي يترصد المنزل وتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ خطته بعد أن تخمرت في ذهنه منذ مدة طويلة وذلك لطول الخلافات بينهم ورفض زوجته للصلح والتشكي به لعدم الانفاق على أبنائه بالإضافة إلى شكوكه حول سمعة زوجته ونسب ابنته مثلما صرح بذلك المتهم نفسه.

وحيث أضحى العمد وسبق الإصرار ثابت ومتوفر في حق المتهم مثلما بينت محكمة القرار المنتقد ولا تعدو مطاعن دفاعه أن تكون سوى منازعة موضوعية في مسألة يختص قاضي الموضوع بتقديرها ولا يجوز الجدل فيها أمام محكمة القانون طالما كان تعليلها مستساغا مستمدا مماله أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م.ج.

وحيث لم تأت مستندات الطعن بما يوهن الحكم المنتقد واتجه تبعاً لذلك رد جملة المطاعن لعدم وجاهتها» .

11-1-12-3 الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل والذي نتج عنه الموت-أركان قانونية

قرار تعقيبي عدد 13777 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة منيرة المانعي.

« حيث أن جريمة الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل والذي نتج عنه الموت مناط الفصل 208 من م.ج تقتضي قيامها توفر أركانها القانونية وهي:

1) فعل الجرح أو الضرب وهو يشمل كل فعل يقع على الجسم ويكون له تأثير ظاهري أو باطني

2) العمد أن يكون الجرح أو الضرب عمدا أي عن إرادة وعلم من الجاني بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته

3) النتيجة (الظرف المشدد) أن يترتب عن الجرح أو الضرب موت الضحية ولو بعد حين أو بعد زمن طال أو قصر حالة أن الجاني لم ينوي تحقيق تلك النتيجة (القصد الإجمالي) وإنما تعدى فعله غرضه إلى الموت الذي وقع فعلا ولم يكن مقصود له في الأصل.

(4) الرابطة السببية : وهي التي يتوقف عليها توفر الظرف المشدد من عدمه وعليه لا بد أن يكون الموت مرتبطا مع الجرح أو الضرب برابطة سببية أي أن يكون الضرب أو الجرح هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت وإن تنوعت على إحداث وفاة المجني عليه أخذا في هذا بالقصد الإجمالي للجاني لأنه كان من واجبه أن يتوقع كل النتائج الممكن حصولها جراء فعله ولذلك فلا مجال للخوض مثلا فيما إذا كان الجرح مميتا بطبيعته أو صار كذلك بسبب ضعف البنية الجسدية للضحية أو تدهور صحته أو أن تفادي تأخر الإسعافات الطبية عن وقتها المناسب كان يمكن أن يحول دون الوفاة كما لا مجال لقبول الاحتجاج بأن وفاة الضحية كان سببها إهماله معالجة نفسه ضرورة وأنه يجب أن يكون المتهم مسؤولا عن نتائج فعله لا أن يجعل المجني عليه الذي تعرض للضرب مطالبا بأن يعمل كل ما في وسعه وأن يحتاط لما عساه أن يحدث جراء ما تلقاه من ضرب طالما لم يعمل عملا إيجابيا ساءت به حالته فضلا على أن المتهم لم يقدم ما يقطع بأنه لو كان المجني عليه قد عولج بكيفية خاصة لكان قد شفي حتما ثم إن عدم الإعتناء وما شاكله لا يبيح فعل المتهم ولا يمحو السبب الأول المتمثل في الإصابة إذ المعول عليه هو الفعل الأصلي الذي لولاه لما حصل للمجني عليه كل ما أوجب وفاته ولا يقبل من المتهم القول بعدم توفر الرابطة السببية بين الضرب والوفاة طالما كان الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك للعوامل الأخرى المتنوعة (كضعف البنية الجسدية للضحية أو كتأخر العلاج مثلا) التي تعاونت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إحداث النتيجة النهائية وعليه فهو مسؤول عن كافة النتائج التي ترتبت عن فعله وهو مؤاخذ بقصده الإجمالي ولو لم يكن يتوقع هذه النتائج لأنه كان يجب عليه قانونا أن يتوقعها .

وحيث وخلافا لما تمسك به نائب المعقب فإن محكمة القرار المطعون فيه وقفت بالدلالة على توفر العلاقة السببية بين ما صدر عن المتهم من فعل تمثل في الضرب ووفاة الهالك حينما خلصت بأسانيد حكمها إلى أن ما قام به المتهم من فعل مادي إيجابي نتج عنه إزهاق روح الهالك واستندت في هذا خاصة إلى تقرير الطبيب الشرعي لتخلص إلى ما خلصت إليه وأضحى النعي على محكمة القرار المطعون فيه بعدم تعليلها بتوفر الرابطة السببية في غير طريقه واتجه الإلتفات عنه

طالما كان واضحاً من أسانيد القرار المطعون فيه وقوف المحكمة على ذلك الأمر ولو بصورة ضمنية.

وحيث كان الطعن والأمر على ماذكر خالياً من الوجهة فضلاً على أنه لم يتبين من الأوراق ما يوجب نقض القرار المطعون فيه لأمر يهم النظام العام واتجه تبعاً لكل ذلك التصريح برفض الطعن أصلاً».

11-1-12-4 الضرب الواقع عمداً دون قصد القتل والناجم عنه موت تنفيذاً لأوامر رئيس العمل

قرار تعقيبي عدد 12542 بتاريخ 7 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين ماهر كنوو توفيق السويدي بحضور المدعي العام السيد رياض الغربي ومساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير.

«حيث لا خلاف وان دائرة الاتهام لا تصدر احكاماً باتة ولا تقضي الا في شأن قيام الحجاج الكافية لتوجيه التهمة من عدم ذلك وهي بهذا المعنى صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع للاستخلاص اركان الجريمة منها وعليه فان الطعن بالتعقيب في قراراتها لا يتسلط الا على الخطا الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي اثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف اما تقدير الوقائع وادلتها فهو امر غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب أي ان هذه الأخيرة لا تملك سوى حق مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم اسباغه على الوقائع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة.

وحيث وخلافاً لما دفع به الطاعن فان دائرة القرار المطعون فيه قد استعرضت الوقائع مفصلة واثبتت على الأفعال المنسوبة للمظنون فيه دون تحريف ثم اسبغت الوصف القانوني السليم بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف على تلك الأفعال فجاء قرارها محترماً لمقتضيات الفصل 119 من م ج.

وحيث ان التمسك باحكام الفصل 42 من م ج في غير طريقه ضرورة وان المعقب لم يؤمر من قبل رؤسائه بدفع الهالك اسفل الوادي حتى يرتطم جسمه بالصخور ويلقى حتفه وانه وعلى فرض تلقي ذلك الأمر مجازاة لما ذهب إليه نائبه فان ذلك لا يعفيه من المؤاخذه عملاً باحكام الفصل 41 م ج الذي نص على

ان طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمه لمن يامر به بارتكاب جريمة لا تنجر له منها صفة الجبر .

وحيث ان ما انتهت إليه دائرة القرار المطعون فيه كان سليم المبنى الواقعي والقانوني ولم يتخلله أي خلل يوجب نقضه لفائدة النظام العام واتجه رد ما اثير ضده من طعن لعدم وجهته».

11-1-13 التمييز بين الجريمة المثارة والكمين

قرار تعقيبي عدد 98231 / 98235 بتاريخ عن الدائرة السادسة والثلاثون برئاسة السيدة زكية الماجري وعضوية مستشاريها السيدين عادل الأخضر وفيصل بن عامر بمحضر المدعي العام السيدة لطيفة العرفاوي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد علي العمراوي.

» [...] عن الدفع المتعلق بالجريمة المثارة:

حيث دفع نائب المعقب في حقه بكون الجريمة المنسوبة لمنوبه هي من نوع الجرائم المثارة التي ترتكب بدفع من الباحث.

وحيث لدفع هذا المطعن وجب التمييز بين الجريمة المثارة والكمين لتقاربهما من حيث الوقائع فالجريمة المثارة هي التي لم يكن لها وجود في ذهن الجاني ولم يخطر بباله إرتكابها ولم يعد لها الوسائل المادية لارتكابها فيتدخل الباحث لدفع الجاني على إتيان ركنها المادي الذي لم يكن ينوي إتيانه إلا أن الباحث جعل الجريمة تختمر في ذهنه وسهل له إرتكابها أما الكمين فهو الحالة التي تكون فيها الجريمة في ذهن الجاني وتولى دراستها وأعد لها ركنها لامادي تمهيدا لإرتكابها فيتدخل الباحث في هذه الحالة لإجبار الجاني على إخراج الجريمة للعلن حتى يضبط متلبسا بجرمها فالكمين إذا هو وسيلة لإثبات الجريمة على خلاف الجريمة المستثارة.

وحيث تضمنت ماديات قضية الحال أن الباحث علم بإندماج المتهم (س.ب) في مجال الإتجار في المواد المخدرة فسعى إلى نصب كمين له حتى يضبط متلبسا وللغرض أوهمه عون أمن أنه حريف ويريد إقتناء مخدر منه وضرب له موعدا للغرض وبالموعد المحدد حل المتهم (س.ب) رفقة المعقب في حقه مصحوبين بالبضاعة وتمكن الباحث من إلقاء القبض على المعقب في حقه دون

المتهم (س) الذي تمكن من الفرار فالجريمة في قضية الحال موجودة في ذهن المعقب في حقه ورفيقه الفار قبل تدخل الباحث بدليل تحوزهما بالمواد المخدرة قبل نصب الكمين لهما وتفاوض المتهم الفار مع عون الأمن حولها فقامت بذلك أركان الجريمة المنسوبة إليهما قبل تدخل الباحث الذي سعى إلى إثبات الجريمة فيحكما بنصب كمين لهما وبذلك فإن الدفع بكون الجريمة المنسوبة للمعقب في حقه في غير طريقه.

وحيث يتضح بالإطلاع على مستندات القرار المنتقد أن المحكمة قد اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها وتم إحترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو أي خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة الحق العام».

11-1-14 البت في المسألة الأولى

قرار تعقيبي عدد 83274 بتاريخ 9 مارس 2020 صادر عن الدائرة السادسة والثلاثين برئاسة السيدة زكية الماجري وعضوية المستشارين السيدين عادل الأخضر وفيصل بن عامر بمحضر المدعي العام السيدة لطيفة العرفاوي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد علي العمراوي.

«حيث أوجب الفصلان 166 و168 من مجلة الإجراءات الجزائية تحرير نسخة أصلية للحكم تتضمن المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الجزية اعتبارا أن تعليل الأحكام وتسبيبها أمر واجب لصحتها.

وحيث لا يكون ذلك التعليل قانونيا ومستساغا إلا متى كان شاملا لكامل عناصر القضية مجيبا على الدفوعات الجوهرية وترتبا عليه فإن كان لمحكمة الموضوع الاختصاص المطلق في تقدير الوقائع وإستخلاص النتائج القانونية منها إلا أن ذلك مرتبطا بحسن التعليل وسلامته بما لا يتجافى ومظروفات أوراق القضية وبما له أصل ثابت بالملف.

وحيث أنه بمناسبة نزاع جزائي تطرح مسألة أولية وجب على المحكمة البت في تلك المسألة كتأويل العقد أو بيان وضعية المظنون فيه مدنيا بالنسبة للشاكي وما ينسب له من أفعال مجرمة جزائيا ومركزه القانوني.

وحيث كان لزاما على قاضي الموضوع إذا ما أثّر أمامه دفع أولي أن يحكم طبق قواعد القانون المدني في تلك المسألة أثناء نشر قضية جزائية على أن لا تقبل تلك المسألة الأولية متى ظهر القصد منها مجرد المماثلة أو ليس لها تأثيرا مباشرا على التتبع.

وحيث تمسك الطاعن أمام محكمة الحكم المخدوش فيه بأن تطرح صفته كوكيل مؤسس أو وكيل حرا أو وكيل على معنى مجلة الالتزامات والعقود وأن المحكمة أغفلت عن البت في تلك المسألة الأولية حتى يتم بيان الأثر القانونية المتصلة بإمكانية تطبيق النص الجزائي على الطاعن.

وحيث لم تجب محكمة القرار المنتقد على البت في المسألة الأولية أورثت قضاءها ضعفا موجبا للنقض. وحيث وفي نفس السياق فإن أحكام الفصل 153 من مجلة الإجراءات الجزائية تنص أنه إذا كان وجود الجريمة يتوقف على وجود حق شخصي فإن الحاكم يعتمد وسائل الإثبات الخاصة بذلك الحق.

وحيث بالإطلاع على مستندات القرار المخدوش فيه وعلى مستندات الطعن التي كانت جدية ومن الوجهة بمكان إتجه معها قبولها فإن محكمة القرار المنتقد بوصفها محكمة إحالة بموجب القرار التعقيبي عدد 41231 القاضي بنقص القرار الاستئنافي يرجع القضية للحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض وذلك فيما قبل من المطاعن أي فيما تسلط على ذلك الطعن بالتعقيب. وحيث أن إعرض محكمة القرار المنتقد عن ذلك يجعل من قضائها ضعيفا للتعليل خارقا للقانون هذا فضلا على عدم بحثها في بيع الحصص للشاكية في الأصل أو جرد المخزون الذي غاب بصفة جازمة على الإختبار.

وحيث أن الإنتهاء إلى القضاء بإدانة المعقب من أجل الخيانة الموصوفة دون بيان صفته هذا فضلا على تمسكه بأن عقد الشركة إن وجد لا يدخل ضمن عقود الأمانة المنصوص عليه صلب الفصل 297 من المجلة الجزائية وعدم جواب المحكمة على ذلك وإغفالها على ما قام به المعقب إن كان يتمثل في سوء تصرف أو إستيلاء وتأثير عدم دفع الشاكية في الأصل لمساهمتها في رأس مال الشركة يجعل من قضائها ضعيف السند موجبا للنقض ومسيئا لتطبيق القانون.

وحيث أفلح الطاعن في طعنه وإتجه تبعا لذلك إعفاءه من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية».

11-1-15 المشاركة في وفاق بقصد التحضير للإعتداء على الأملاك

قرار تعقيبي عدد 91255 بتاريخ 7 فيفري 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرين برئاسة السيد رياض الامام وعضوية المستشارين السيدة سامية العابد والسيد سامي الداهش بحضور المدعي العام السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيد جلال العنتير.

« حيث كان من المقرر أن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها موكول لاجتهاد قضاة الأصل شريطة تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م.إ.ج .

حيث أن جريمة تكوين وفاق بقصد تحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص والاملاك تستوجب لقيامها توفر أركانها القانونية على معنى أحكام الفصول 131 و132 و133 من م.ج. وهي أن يكون هناك اتفاق على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك وأن يكون الغرض من ذلك الوفاق اقتراف جرائم متنوعة دون لزوم لضبط تلك الجرائم المتفق على ارتكابها مما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام وكذلك أن يكون الوفاق مبنيا على القصد الإجرامي أي العلم بأن تلك الأفعال مجرمة قانونا ومعاقب عليها.

وحيث أن السوابق العدلية للمتهم والقضايا التحقيقية المنشورة ضده لا تعتبر دليلا على ارتكابه لجريمة تكوين وفاق طالما لم يتضمن الملف ما يفيد توفر الأركان القانونية لتلك الجريمة المبينة أعلاه.

وحيث وعلاوة على ذلك فإن الوفاق يشترط وجود شخصين أو أكثر يقع التقارر بينهم لارتكاب اعتداءات وهو أمر مفقود في وقائع قضية الحال، ذلك أن الأشخاص الذين يشتبه في تقارره معهم ظلوا مجهولي الهوية واعتبرت محكمة القرار المنتقد تبعا لما تقدم عدم توفر أركان جريمة تكوين وفاق وغياب الدليل على ارتكاب المظنون فيه لتلك الجريمة.

وحيث أحسنت محكمة القرار المنتقد فهم الوقائع، وبينت أسباب وأسناد حكمها وعللت قضاءها تعليلاً مستساغاً بالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

وحيث وعلاوة على ذلك، فإن المظعن المثار يهدف في حقيقة الأمر إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها.

وحيث أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا يمكنها نقض اجتهاد قضاة الأصل طالما كان مؤسسا كما يجب واقعا وقانونا. واتجه تبعا لذلك رد المظعن لعدم وجاهته».

قرار تعقيبي عدد 10624 بتاريخ 28 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة الجزائية الثانية والعشرون برئاسة السيد رضا العرعوري وعضوية المستشارين السيدين منيرة حبيب وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العام السيد محمد القمودي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سنية العبدادي.

« حيث أن محكمة الأصل خلصت إلى اعتبار أن أركان الجريمة موضوع الإحالة قائمة في جانب المتهم وذلك بعد التدقيق في جملة عناصر القضية الواقعية والقانونية.

وحيث إن القراءة الصحيحة للفصل 131 م ج تفيد أن الجريمة موضوعه تقوم بتوفر اتفاق بين شخصين فما أكثر بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك وهو ما انطبق على المتهم المعقب ومن معه وإن احتجاج المعقب بأنه لم يحصل ارتكاب عملية سرقة ولا وجود لأي متضرر في قضية الحال لا يستقيم لأن جريمة الحال قامت بمجرد الاتفاق الحاصل بينهما على التحضير لارتكاب الاعتداء سواء على الأشخاص أو على الأملاك وهي القراءة نفسها التي عبرت عنها مستندات الحكم المنتقد وهو ما يعني أن ذلك الاتفاق لا يفترض حصول الجريمة المتفق عليها وإن المظعن المخالف لذلك يعد غير وجيه وتعين رده».

قرار تعقيبي عدد 99317 بتاريخ 9 مارس 2020 صادر عن عن الدائرة السادسة والثلاثين برئاسة السيدة زكية الماجري وعضوية مستشاريها السيدين عادل

الأخضر وسامي الهاني بمحضر المدعي العام السيدة لطيفة العرفاوي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد علي العمراوي.

11-1-16 التخفيف من العقوبة دون النزول بها درجة أو درجتين في سلم العقوبات لا يوجب بالتبرير

قرار تعقيبي عدد 16960 بتاريخ 6 نوفمبر 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرين برئاسة السيد رياض الامام وعضوية المستشارين السيد شكري كمون والسيدة سامية العابد بحضور المدعي العام السيد جلال الزواوي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

«عن المطعن الوحيد المتعلق بضعف التعليل:

حيث ان تقدير العقاب وان كان من مشمولات محكمة الموضوع وراجع لاجتهادها المطلق، إلا أنه لا يكون إلا في حدود القواعد الموضوعية والاجرائية التي حددها القانون.

وحيث اقتضى الفصل 53 في فقرته الأولى من م ج أنه: «إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي ضبطتها...».

وحيث ينص الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 المتعلق بالمخدرات على ما يلي: «يعاقب بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبخطية من ألف إلى 3 آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب».

وحيث نص الفصل 12 جديد من نفس القانون على أن أحكام الفصل 53 من م ج على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و 8 منه.

وحيث يتضح بالاطلاع على القرار المنتقد أن المحكمة قضت بتعديل حكم البداية وذلك بالخط من العقوبة المحكوم بها من 3 سنوات إلى عام واحد سجنًا ومن 3 آلاف دينار خطية إلى ألف دينار.

وحيث يتضح تبعًا لما تقدم وعملاً بأحكام الفصول أعلاه، أن محكمة القرار المنتقد ولئن خففت من العقوبة المحكوم بها على المتهم ابتداءً، إلا أنها لم تنزل بتلك العقوبة درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية، وهي الصورة التي تحتم على المحكمة تعليل حكمها بهذا الخصوص. أما صورة الحال وطالما أن المحكمة لم تنزل بالعقوبة المقررة للجريمة إلى درجة أقل، فإنه ليس عليها تبرير قضاءها بالخط من العقوبة المحكوم بها ابتداءً. واتجه رد المطعن لعدم وجاهته».

11-1-17 تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة

11-1-17-1 الحجز الفعلي يشمل البضاعة فقط دون وسيلة النقل

قرار تعقيبي عدد 10752 بتاريخ 9 جوان 2020 صادر عن بتاريخ 09/06/2020 عن الدائرة الثانية عشرة برئاسة السيدة منيرة النحالي وعضوية المستشارين السيدين سلوى التميمي ومحمد بن منصور بحضور المدعي العام السيد نبيل غرس الله وبمساعدة كاتب الجلسة السيد توفيق المناصري.

« حيث إستند الطعن لدى هذه المحكمة على خرق موجبات الفصل 5 من القانون المؤرخ في 18/02/1998 المتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل قولاً بعدم جواز تسليط الحجز على وسيلة النقل التي إرتكبت بها الجريمة.

وحيث إقتضى الفصل 5 المذكور أنه يتحتم الحجز الفعلي للبضاعة موضوع الجريمة المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون وإحالتها رفقة محضر تفصيلي على قابض المالية المختص مقابل وصل ينهى أصله مع المحضر...». وحيث لا خلاف أن الإجراءات المتبعة في الجرائم بصفة عامة والمضمنة بمجلة الإجراءات الجزائية أو بالقوانين الخاصة كقانون تعاطي تجارة المشروبات الكحولية موضوع قضية الحال لا تحتمل التأويل أو التفسير أو القياس.

وحيث أن الفصل 5 المذكور حدد نطاق الحجز الفعلي ليشمل البضاعة فقط لا غير أي كمية الخمر المحجوزة مستبعدا بذلك ما عداها من وسيلة النقل التي إرتكبت بها الجريمة وغيرها مما يتحتم معه الإلتزام بالنص الإجرائي وعدم التوسع فيه كالإلتزام بإرادة المشرع التي إنصبت على البضاعة فحسب وذلك بصفة صريحة وواضحة وهو دأب المشرع في سائر النصوص الخاصة كقانون المخدرات الذي نص صراحة على حجز وسيلة النقل التي إرتكبت بها الجريمة. وحيث أضحى المطلب تأسيسا على ما سبق مؤسسا على أسانيد قانونية صحيحة مما يتجه معه نقض الحكم المطعون فيه لخرقه أحكام الفصل 5 من القانون المؤرخ في 18 / 02 / 1998.

11-1-17-2 تعزيز قرينة الحجز

قرار تعقيبي عدد 89793 بتاريخ 12 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة الجزائية الثانية والعشرون برئاسة السيد رضا العرعوري وعضوية المستشارين السيدين منير وردليتو وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العام السيد محمد القمودي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سنية العبادوي.

«حيث اعتبر الطاعن ان ادانة المتهم ثابتة بالمحجوز ومعاينة باحث البداية، وان الحكم المنتقد لما قضى بالبراءة قد خالف القانون.

وحيث ان محكمة الحكم المنتقد استعرضت جملة عناصر القضية مع توليها التدقيق فيها واستخلصت منها النتيجة القانونية التي مفادها وان الأركان القانونية للجريمة موضوع قرار الإحالة غير متوفرة ، فان قرارها قد انبنى على أسس قانونية سليمة منها انه لم يتم ضبط المتهم ببيع المشروبات الكحولية سيما وأنه لا وجود لبينة تفيد الشراء منه وبالتالي لم تكن اركان الجريمة متوفرة .

وحيث ان واقعة الحجز لكمية من المشروبات الكحولية لا تكفي لوحدها لقيام جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية وانما كان لابد من تعزيزها بقرائن خارجية قوية وهو ما لم يثبت في صورة الحال.

وحيث أن المطاعن ترمي في حقيقة الأمر إلى مناقشة محكمة الحكم المنتقد فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي يدخل في نطاق

اجتهادها المطلق لا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف .

وحيث لم تأت مستندات التعقيب بما يوهن الحكم المنتقد في شيء ، وكان بذلك الحكم معللا كما يجب قانونا دون تحريف للوقائع ولا خرق للقانون بما يؤدي إلى رفض المطعن لخلوه من المستند الصحيح» .

11-1-18 جريمة الإدعاء بالباطل

قرار تعقيبي عدد 97964 بتاريخ 9 جوان 2020 صادر عن الدائرة الجزائية الخامسة والثلاثين برئاسة السيدة ليلي الذويبي وعضوية مستشاريها السيدتين كوثر الشريفي ونورة البكوش وبمحضر المدعي العام السيد سفيان بوزيد وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة أمال بن نصر .

«عن المطعنين معا لتدخلهما ووحدة القول فيهما:

حيث إقتضى الفصل 248 من المجلة الجزائية أنه «يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو عدة أشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية من نظرها تتبع هذه الوشاية أو رفعها للسلطة المختصة أو لدى رؤساء الموشى به أو مستأجره ويمكن للمحكمة أن تأذن علاوة على ما ذكر بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه

وإذا كانت الأفعال موضوع الوشاية موجبة لعقاب جزائي أو تأديبي فإنه يمكن إثارة التبعات بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو الإستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى وترك السبيل أو بعد قرار الحفظ الصادر عن محاكم التحقيق وإما بعد الوشاية من قبل القاضي أو الموظف أو السلطة المعنية أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير مآل الوشاية» .

وحيث يؤخذ من هذا النص أن جريمة الادعاء بالباطل لا تستقيم إلا إذا توفر في جانب المشتكي العلم المسبق بكذب وشايته ونية إلحاق الأذى بالمشتكى به عند التشكي فهو ما يفترض وجوبا علم المتهم اليقيني بان موضوع تشكيه باطل مطلقا ولا هدف من ورائه سوى إلحاق الضرر بالمشتكي بدافع التشفي .

وحيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن المحكمة أجابت بكل تفصيل على موضوع القضية وتلوت إبراز أركان جريمة نص الإحالة وتوفرها في جانب المعقبة إستنادا إلى سبق تقدمها بشكاية جزائية ضد المتهم (ع.د) تم حفظها من قبل النيابة العمومية لعدم كفاية الحجة بتاريخ 15 / 11 / 2015 وكذلك تقديمها لشكائتين ضدها إلى السيد مدير إقليم الأمن الوطني ببنزرت ووزير العدل في تواريخ قريبة من تاريخ الشكاية موضوع قضية الحال فهو دليل على إصرار المعقبة على التشكي بالمتضررة ورغبتها في التنكيل بها وهو ما يكون الركن القصدي لجريمة الادعاء بالبطل.

وحيث أن محكمة القرار المطعون فيه لما قضت بالصورة التي قضت بها تكون قد أحسنت تطبيق القانون وأسست قضاؤها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وإتجه رد هذا المطعن لعدم سداده».

11-1-19 جريمة الإستيلاء عن سوء قصد على شيء وصل إليه غلطا أو بالمصادفة - الفرق بينها وبين الإستيلاء على لقطة

قرار تعقيبي عدد 84742 بتاريخ 8 جوان 2020 صادر عن الدائرة الحادية عشرة برئاسة السيدة ماجدة بن غربية وعضوية المستشارين السيدين محمد العفيف الجعدي وعماد الدغاري وبمحضر المدعي العام السيدة فوزية قمري وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة أمال بن نصر.

«في جملة المطاعن لتداخلها ووحدة القول في شأنها:

حيث عللت محكمة الحكم المنتقد قضاها بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى بأن وفق مستندات الحكم المنتقد بأن «جريمة الإستيلاء على لقطة تستوجب ركن سوء النية وان المبلغ الواقع تنزيله بحساب المتهم كان بدون علمه وقام بسحبه عن غير قصد الإستيلاء عليه ضنا منه أن المبلغ قد يكون عائدا إليه بطريق ما شرعية».

وحيث أوجب المشرع ضمن الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على «المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة» أي أن يشتمل على أسباب ومنطوق وكون الأسباب أساس الحكم وأن تعليل الأحكام ينصب على الوقائع من أقوال وأفعال والدفع ثم ينتقل على

التكليف القانوني وتطبيق النصوص القانونية على الوقائع والرد على الدفوع ويعطي التحليل الذي إعتدته المحكمة للوصول إلى المنطوق الذي إنتهت إليه فيكون التعليل أساسا للمنطوق ولا بد له تبعاً لذلك من بيان مفصل ضرورة أن تعليل الأحكام من الإجراءات الأساسية وهو من أهم الضمانات التي فرضها القانون فهو مسألة جوهرية فضلاً عن أنه يبرز الدوافع والمبررات التي إعتدتها المحكمة لإصدار حكمها على نحو معين ولتتمكن محكمة التعقيب عند الطعن فيه من إجراء رقابتها طبق القانون.

وحيث لا يجب تبعاً لما سبق ذكره أن يكون الحكم مشوباً بالإجمال أو الإيهام أو الخطأ في تطبيق النص القانوني المترتب عن تحريف الوقائع وسوء فهم النص المنطبق.

وحيث تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة تطرقت إلى جريمة الإستيلاء على لقطة وأركانها القانونية وروحها إلى وقائع القضية وفق ما سبق بيانها بالطالع وإلى نص الإحالة الفصل 280 من المجلة الجزائية والجريمة المحال من أجلها المتهم وهي الإستيلاء عن سوء قصد على شيء وصل إليه غلطا أو بالمصادفة» يتضح أن محكمة الحكم المنتقد قد أهملت بيان الصورة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 280 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية.

وحيث أن الفصل 280 من المجلة الجزائية قد نص في فقرته الأولى على جنحة الإستيلاء على لقطة وهي في تعريفها ما يتم العثور عليه ملقى بالطريق العام أو الأماكن العمومية ويكون لها قيمة مادية أو معنوية وضاعت من أصحابها ومن يعلم من له النظر من السلطات أو صاحب الشيء في حين نص المشرع ضمن الفقرة الثانية من الفصل 280 على نوع خاص من الإستيلاء على ملك الغير وجرم نوعاً آخر من الأفعال يتمثل في الإستيلاء على شيء وصل إلى يد الجاني «غلطا أو بالمصادفة مما يعني أن الجاني في هذه الحالة لم يقيم بأي عمل مادي أدى إلى الإستيلاء ولم يختلس شيئاً على ملك الغير ولكن وقع تسليمه له «عن غلط» ضرورة أن المشرع إستعمل لفظ (وصل إلى يده) أي أن دور الجاني كان دوراً سلبياً ثم أن وصول الشيء على يده كان «غلطاً» أي أن صاحب الشيء كان يظن أنه سلمه لمن له الحق في ذلك والحال أنه سلمه على شخص آخر لا علاقة له

به ولا صفة له في تسلمه وبالتالي فإن الجاني لم يسع على الحصول على الشيء وإنما إستغل غلط صاحب الشيء وسكت عليه وبالتالي يكون تحصيله على ذلك الشيء والإستفادة منه إثر ذلك مبني عن سوء نية وهو الفعل المجرم بالفقرة الثانية من الفصل 280 من المجلة الجزائية مناط نص الإحالة.

وحيث تبين من وقائع القضية أن القائم بالحق الشخصي قد تولى تنزيل مبلغ ألف ومائة دينار غلطاً بحساب المتهم عدد 141242 الذي أقر بحثاً أنه كان يستغله وتنزل به جرائته ومستحقاته الوظيفية ثم أوقف التعامل بذلك الحساب دون غلقه منذ سنة 1993 وفتح حساباً جديداً لدى البنك الفلاحي أصبح يتم به تنزيل جرائته ومستحقاته الوظيفية وبناء عليه فإن عدم إستغلال المتهم للحساب المفتوح لدى مكتب البريد منذ سنة 1993 ثم خلال سنة 2008 يتم تنزيل مبلغ به غلطاً يتولى سحبه والإستفادة منه رغم إيقافه التعامل بذلك الحساب من قبل منذ سنة 1993 ورفضه إثر إعلامه بالخطأ إرجاع المبلغ يقيم في جانبه الأركان القانونية لجريمة نص الإحالة وطبق الفقرة الثانية من الفصل 280 من المجلة الجزائية الأمر الذي أغفلته محكمة الحكم المنتقد وإقتصرت ضمن مستندات حكمها على بيان أركان جنحة الفقرة الأولى وإساءات فهم الوقائع وتكييفها التكييف الصحيح وإنزال حكم القانون مما أورث حكمها ضعف التعليل وخرق القانون».

11-1-20 الإختلاس في السرقة-الإستيلاء على المعطيات المخزنة بالحواسيب
يُشكل اختلاسا

قرار تعقيبي عدد 94123 بتاريخ 8 جويلية 2020 صادر عن عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«حيث كان الطعن مسلطاً على قرار صادر عن دائرة الاتهام قاضياً بنقض قرار ختم البحث الذي وجه التهمة على المعقب ضدهم وحفظها في حقهم لعدم توفر أركانها القانونية.

وحيث أن دائرة الاتهام لا تصدر أحكاماً باتة ولا تقضي إلا في شأن قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة من عدم ذلك وهي بهذا المعنى صاحبة مطلق

الحرية في تقدير الوقائع لإستخلاص أركان الجريمة منها وعليه فإن الطعن بالتعقيب في قراراتها لا يتسلط إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها فهو أمر غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب أي أن هذه الأخيرة لا تملك سوى حق مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الوقائع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة أو التعليل المستساغ المرتكز على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف في صورة الحفظ لعدم توفر الأركان القانونية أو لعدم كفاية الحجة أو لعدم المؤاخذه أو لإنقضاء الدعوى العمومية بأحد موجبات الفصل 4 من م إ ج أو سقوطها بمرور الزمن.

وحيث خلصت دائرة القرار المطعون فيه إلى حفظ التهمة في حق المعقب ضدهم لإنعدام الأركان القانونية وتحديد الركن المادي قولاً منها أنه ولئن تبين أن المظنون فيهم الأجراء لدى الشركة الشاكية قد قاموا بإختلاس طلبيات تابعة للشركة التي يعملون فيها وتحويل وجهتها كتحويل وجهة الحرفاء إلى شركتهم المنافسة وإستعملوا في ذلك الأجهزة الإعلامية والعناوين الإلكترونية ومعدات العمل التابعة لمؤجرتهم وخصصوها لنشاط شركتهم فإن كل ذلك لا يعد من قبيل الإختلاس لأنه لم يتسلط على منقول كما أن مجرد إستعمالهم لتلك المعدات لم يخرجها من الحيابة القانونية والذمة المالية للمالك.

وحيث أن مثل هذا التعليل ينطوي على تضارب صارخ في الأسانيد فهو يقول بثبوت الإختلاس تارة وينفيه تارة أخرى بما يجعل مثل ذلك التعليل لا يؤدي منطقاً إلى النتيجة التي إنتهى إليها القرار المطعون فيه.

وحيث أن الإختلاس في السرقة إنما هو نقل الشيء من حيازة المجني عليه وهو الحائز الشرعي إلى حيازة الجاني بغير علم المجني عليه أو على غير رضاه ويجب أن يتسلط على شيء ملموس ومحسوس فلا تصلح الآراء والأفكار مثلاً لأن تكون محلاً للسرقة لأنها لا تدرك بالحس وإن كانت تحميها نصوص خاصة وإنما تصير محلاً للسرقة إذا أفرغت في محرر كالعقد أو المجلد أو الكتاب أو في حامل إلكتروني لأن ذلك المحرر صار بإفراغه على النحو المذكور شيئاً ملموساً ومنقولاً وبالتالي أصبح شيئاً مادياً يصلح لأن يكون محلاً للسرقة.

وحيث أن تعتمد المظنون فيهم الولوج إلى المعطيات المادية المخزنة بالحواسيب التي في إستعمالهم (والتي كانت مجرد أفكار قبل تخزينها في ذلك الحامل الإلكتروني) والتلاعب بها للحصول على مردود مادي لأنفسهم لا لمؤجرتهم التي جعلت تلك المعطيات في خدمتها وإثراء ذمتها يشكل إختلاسا محل شيء ملموس ومنقول أخرج من حيازة صاحبه وصار في قبضة المختلس وتحت تصرفه ضرورة وأن تلك البيانات أخذت حكم المنقول بمجرد تخزينها في الأجهزة المذكورة التي أصبحت الحامل المادي لها والتي بالإمكان تحميلها على الورق أو على أي حامل إلكتروني آخر.

وحيث ومن جهة أخرى فإن وضع الشركة الشاكية أجهزة الإعلامية معدات العمل المملوكة لها على ذمة أجراءها المظنون فيهم يجعل يد هؤلاء عارضة على تلك الأشياء لأن المؤجرة إنما وضعتها لإستخدامها في العمل لفائدتها لإثراء ذمتها بالمداخيل المتأتية من ذلك الإستعمال ولم تنقل حيازتها الكاملة أو الناقصة إلى الأجراء ولم تتخلى عنها لفائدتهم وإنما ظلت دوما في حيازتها القانونية لأن الغرض من تسليم تلك المعدات إنما كان لأجل عمل معين بأجر لا يتعداه إلى ما سواه. وعليه فإن في تولي الأجير الحلول محل المؤجر في إستعمال تلك الأدوات والإنتفاع بها والتصرف فيها لنفسه على نحو ما كان يفعل المؤجر بواسطة منظوريه يشكل فعل إختلاس مسلط على منقول يستمر طالما إستمرت مدة الحلول محل المؤجر في الإنتفاع بصورة غير مشروعة وتكون نية التملك متوفرة في جانب الفاعل ومعناها في هذا السياق إنما ينصرف إلى إرادة الجاني (وهو الأجير) حرمان المالك (وهو المؤجر) من سلطاته على تلك الأشياء والحلول محله في الإستعمال والتصرف والإنتفاع.

وحيث وبناء على ما تقدم فقد أساءت دائرة القرار المنتقد التعليل بإعتماد أسانيد متضاربة كما أساءت إستخلاص النتائج القانونية السليمة من الوقائع العروضة عليها فإستحق قرارها النقض للأسباب المذكور.

11-1-21 أداء الخدمة الوطنية لا يُحمل إلا على الشبان من جنس الذكور

قرار تعقيبي عدد 83628 بتاريخ 8 جويلية 2020 صادر عن الدائرة الرابعة عشر برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية المستشارين السيدين العقيد

قاضي ظافر الشتيوي وكمال بوكثير بمحضر المدعي العام السيد عادل الغالي ومساعدة كاتبة المحكمة السيدة سميرة بوشوشة.

» حيث رجوعا إلى قرار الاحالة فانه تمت احالة المتهم المعقب لمقاضاته من اجل عدم تسوية الوضعية ازاء قانون الخدمة الوطنية طبق الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 والفصل 66 من م م ع ع.

وحيث اقتضى الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المشار إليه انه: «يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عاما أن يتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين».

وحيث انه بقراءة أحكام الفصل المشار إليه يتبين وان واجب أداء الخدمة الوطنية يحمل مبدئيا على كل «مواطن» من جنس الذكور بلغ السن القانونية طالما وان أحكام القانون عدد 1 لسنة 2004 المشار إليه لم تنص على تحميل ذلك الواجب على كل «مواطنة» وهو ما درجت عليه الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة من سابق من جعل عملية التجنيد لا تنطبق الا على الشبان من جنس الذكور.

وحيث ان المتهمة هي من جنس الاناث ولذلك ليست مشمولة بواجب أداء الخدمة الوطنية على معنى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المذكور، وان الحكم المطعون فيه كان صائبا فيما قضى به من تبرئة ساحة المتهمة لعدم وجود جريمة وفقا للمبدأ القاضي بانه لا جريمة بدون نص سابق الوضع. وحيث انه من هذا المنطلق كان الحكم المنتقد قائما على أسانيد قانونية صحيحة ومعللا استنادا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

وحيث لم تأت مستندات التعقيب بما يوهن الحكم المنتقد في شيء، وكان بذلك الحكم معللا كما يجب قانونا دون تحريف للوقائع ولا خرق للقانون بما يؤدي إلى رفض المطاعن كلها لخلوها من المستند الصحيح».

11-1-22 إصدار شيك بدون رصيد

11-1-22-1 غياب الصك الأصلي يُفتقد معه الركن المادي للجريمة ولو أكد الاختبار بناءً على النسخة ثبوت التدليس

قرار تعقيبي عدد 82230 / 82198 بتاريخ 17 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرين برئاسة السيد رياض الامام وعضوية المستشارين السيد شكري

كمون والسيدة سامية العابد بحضور المدعي العام السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

« حيث ينعى الطاعن على محكمة القرار المنتقد سوء تطبيق أحكام الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية لعدم اعتماد نسخ الصكوك المدلّسة وعدم اعتمادها على ما انتهت إليه نتائج الاختبارات المجراة على أصل الصك بالنسبة للاختبار المجرى بالدولة المرتكبة بها الجريمة وكذلك الاختبار المجرى على نسخة من ذلك الأصل باذن من قاضي التحقيق والتي تأكد من خلالها عملية التدليس.

وحيث أن محكمة القرار المنتقد قد أحسنت تطبيق القانون حين اعتبرت أنه لا يمكن مؤاخذه المتهم من أجل ارتكابه لجريمة التدليس لفقدان الركن المادي للجريمة المذكورة والذي لا يمكن أن يتوفر في غياب الصك الأصلي الذي لا يمكن تجاوزه بنسخة منه ولو أكد الاختبار ثبوت التدليس. واتجه رد جملة الدفوعات المتعلقة بجريمة التدليس لعدم وجاهتها».

11-1-22-2 إصدار صك بدون رصيد جريمة شكلية لا تحجب الحق في محاكمة عادلة

قرار تعقيبي عدد 79965 بتاريخ 1 جوان 2020 صادر عن الدائرة الثالثة عشر برئاسة السيدة روضة أويش وعضوية المستشارين السيد زهير الحسني والسيدة شفيقة الحجللاوي وبحضور ممثل النيابة العمومية السيد عبد الحميد غانم وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«حيث ولئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الحجج والمؤيدات المعروضة عليها وإستخلاص النتائج القانونية منها إلا أن ذلك مشروط بتعليل ما إنتهت إليه تعليلا سائغا وسليما يتماشى مع ما يتوفر لديها من أوراق وقرائن.

وحيث تمسك الطاعن أمام محكمة القرار المنتقد بأن الصك موضوع التتبع أنتزع منه بالقوة وبإستعمال حيل وخزعات بعدما تم حجزه وإفتكاك جواز سفره ومنعه من مغادرة المغرب الأقصى مكان حصول جريمة التحيل وأنه ثبت ذلك من خلال نسخة حكم جزائي قضى بالإدانة أضاف نسخة منه لأوراق الملف.

وحيث كان من المسلّم به أن جريمة إصدار صك بدون رصيد هي جريمة شكلية فهي لا تحجب الحق في محاكمة عادلة وفي ضمان حق الدفاع المكفول بالدستور في فصله 108 وبالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 المصادق عليه من الدولة التونسية.

وحيث وعلى الرغم من أهمية ما دفع به الطاعن وتأثيره على وجه الفصل في النزاع أو حتى على تقدير العقوبة فإن محكمة القرار المطعون فيه لم تتطرق إلى ما أدلى به من مؤيدات ولم تناقشها ولم تبد رأيها فيها سلبا أو إيجابا ولم تسجل مدى وجاهتها مُقَصَّرة بذلك في تمحيص الأدلة المعروضة عليها وسبر ما إشتملت عليه من العناصر حتى يكون ما تنتهي إليه من إستنتاج ناطقا بحقيقة ما حصل وهو ما أورث قضاءها حال إغفالها لذلك ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع وإتجه لذلك قبول المطعنين المثارين ونقض القرار المطعون فيه مع الإحالة»

11-1-23 التّزوّج بثنائية والتّزوّج على خلاف الصّيغ القانونية

11-1-23-1 قرائن إثبات التّزوّج على خلاف الصّيغ القانونية

قرار تعقيبي عدد 82472 بتاريخ 22 جانفي 2020 صادر عن الدائرة الرابعة برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية المستشارين السيدين العقيد قاضي نورة الامام وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العمومي السيد عادل الغالي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة هاجر السلطاني.

«عن المطعنين معا لترابطهما واتحاد القول فيهما:

حيث انه من المسلمات ان القاضي الجزائي مطالب بالبحث دون توان على الحقيقة سواء كانت مفضية إلى اثبات البراءة أو إلى اثبات الادانة، وعليه لا بد من اتباع كل الاعمال الاستقرائية من تفتيش لموطن الواقعة للبحث عن الادلة أو حجز ما يمكن حجزه أو سماع ما توفر من الشهود أو اجراء المكافحات اللازمة واجراء ما يلزم من الاعمال المسهلة للبت في الوقائع وفهمها فهما صحيحا واستخلاص النتائج القانونية منها.

وحيث انه رجوعا إلى مظروفات ملف القضية واسانيد القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الموضوع قد خلصت إلى ان اركان الجريمة موضوع قرار الاحالة غير

متوفرة الاركان وقضت ببراءة المتهم، كل ذلك دون تدقيق في الوقائع المحتج بها من قبل الشاكية ومنها بالخصوص ان المتهم كان قائما بالانفاق عليها بما في ذلك توليه تأجير سكن لها وخلاصه لمعينات الكراء والتظاهر امام العموم، بما في ذلك صاحب المحل المسوغ، بانهما زوجين فضلا عن معاشرته لها معاشرة الأزواج بما ادى إلى انجاب طفلة منه بعد اجهاضها في مناسبتين. وتؤكد ذلك باقراره الحكمي في سائر اطوار المحاكمة بطوريها وبشهادة زوجته الاولى المدعوة ن. ز. وقد تغاضت المحكمة عن كل تلك العناصر رغم أهميتها في بيان توفر الاركان القانونية للجريمة موضوع قضية الحال، كما تجاهلت استعداد الشاكية عند الاقتضاء لاحضار شهودها بما في ذلك المسوغ لتأييد دعواها كل ذلك دون تعليل بما يتعارض مع أحكام الفصل 168 من م ا ج.

وحيث كان الحكم المنتقد منعدم التعليل وخارق للقانون بما يؤدي إلى نقضه مع الاحالة لاعادة النظر في القضية».

11-1-23-2 التزوج بثانية يقتضي زواج أول صحيح وزواج ثان إحترم شكلية العقد أو لم يحترمها

قرار تعقيبي عدد 86197 بتاريخ 4 نوفمبر 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«حيث أن تقدير الأدلة وإستخلاص النتائج القانونية السليمة منها مسألة موضوعية راجعة لقضاة الأصل شريطة التعليل المستمد من أوراق الملف ذلك أن إثبات المسؤولية الجزائية أو نفيها يستدعي بحثا وتمحيصا تتولاه محكمة الموضوع ويخرج عن نطاق محكمة التعقيب الذي يقتصر دورها على السهر على سلامة تطبيق القانون.

وحيث وخلافا لما تمسك به المعقب بخصوص توفر أركان جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية مناط أحكام الفصل 36 من القانون عدد 3 المؤرخ في غرة أوت 1957 فإن تلك الجريمة قد قضي فيها إبتدائيا بعدم سماع الدعوى ولم يقع إستئناف الحكم في شأنها من طرف النيابة العمومية وإنما تسلط الطعن

بالإستئناف من طرف المتهم فيما قضي به إيجابا بما يكون معه والأمر على ما ذكر قد إتصل القضاء بموضوع تلك الجريمة وتعين الإلتفات عن هذا المطعن لعدم وجاهته .

وحيث أن الدفع كذلك بتوفر شروط جريمة التزوج بثانية المنسوبة للمعقب ضده قولاً بأنه توفر بالملف عقدي صداق الأول مع ن. م. والثاني مع ص. ش. هو دفع في غير طريقه ضرورة وأن الأمر يقتضي أن يكون عقد الزواج الأول صحيحاً شكلاً وأصلاً طبقاً لمقتضيات الفصل 4 من م أ ش والفصل 31 من قانون الحالة المدنية وأن يعقبه زواج ثان أبرم بعد ذلك سواء إحترم شكلية العقد أو لم يحترمها حتى يمكن الحديث عن قيام جريمة التزوج بثانية.

وحيث بالرجوع إلى مظروفات ملف القضية فإن عقد الزواج المدعى به من قبل الشاكية تمثل في الكتب الخطي المحرر باللغة الإيطالية والصادر عن المجلس الإسلامي بمدينة فيرونا والمتضمن أن الشاكية والمعقب ضده عقدا العزم على إبرام عقد قران حسب الشريعة الإسلامية ولم يحرز ذلك العقد على الشروط القانونية لقيام عقد الزواج إذ لم يثبت خلو الطرفين من الموانع الشرعية عند إبرامه بل أن مدعية الضرر تقر بحثاً بأنها لم تتحلل من زواجها القائم إلا بعد تحرير ذلك العقد وتحديدًا عند صدور الحكم بالطلاق من زوجها الأول في 1/4/2016 فإنتهى بذلك وجود عقد زواج قانوني تقوم به الجريمة في جانب المعقب ضده لما عقد قرانه بالمسماة ص. ش. بتاريخ 23/1/2016 وأضحى بذلك الطعن خالياً من كل وجاهة خاصة وقد أحاطت محكمة القرار المنتقد بجميع العناصر واستخلصت النتيجة القانونية السليمة منها فأحسن تطبيق القانون دون تحريف للوقائع وجاء قرارها معللاً تعليلاً مستساغاً بما يتجه معه ردّ الطعن تصريحاً برفضه أصلاً».

11-1-24 القتل على وجه الخطأ نتيجة حادث مرور والفرار إثره للتفصي من المسؤولية الجزائية والمدنية

قرار تعقيبي عدد 40250 بتاريخ 18 نوفمبر 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي

وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي .

«حيث أن القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها وعليه فللمحكمة الجزائية مطلق الحرية في تقدير الأدلة التي إقتنعت بها وإطمأن إليها وجدانها لتبرير قضائها في نطاق إجتهادها شرط التعليل المستساغ المؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها في حكمها ودون تحريف للوقائع ودون أن يغيب عنها الموازنة بين الأدلة المثبتة للتهمة والأدلة النافية لها ثم الترجيح بينها.

وحيث تمسك الطاعن ضمن مستندات تعقيبه بإنتفاء الركن المشدد للجريمة المتمثل في الفرار لتفادي المساءلة الجزائية والمدنية وعدم بيان محكمة القرار المطعون فيه توفر ذلك الركن بصفة جلية.

وحيث أن الفرار إثر إرتكاب حادث مرور بقصد التفصي من المسؤولية الجزائية والمدنية هو واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات وتستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع المعروضة عليها بما له أصل ثابت بأوراق الملف.

وحيث وخلافا لما تمسك به نائب الطاعن فإن محكمة القرار المنتقد بعد أن إستعرضت الوقائع كيفما وردت بالأبحاث أبرزت بصورة واضحة العنصر المشدد للجريمة موضوع قضية الحال مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخلصت إلى القول بتوفر ركن الفرار من خلال صورة الحادث وتعمد المعقب إطفاء أنوار الشاحنة لحجب بياناتها ومواصلة السير دون توقف وعدم تقدمه إلى أي وحدة أمنية للإعلام على إمتداد يومين من تاريخ ترويج ملحوظة تفتيش عن السيارة المرتكبة للحادث ثم وازنت بين الأدلة بعد أن وقفت على أركان جريمة نص الإحالة وإستبعدت قرينة البراءة المستندة أساسا إلى إنكار المتهم وانتهت إلى القول بتوفر الإدانة في جانب المعقب معللة قرارها تعليلا سائغا بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ولم يكن الطعن يرمي في جوهره سوى إلى مناقشة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة وفيما إعتمدته وإطمأن إليه وجدانها لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي يخرج مجاله عن نظر محكمة التعقيب ضرورة أن الإجتهد لا ينقض بمثله واتجه استنادا إلى مقتضيات الفصل 258 من م إ ج القضاء برد الطعن تصريحاً برفضه أصلا».

11-1-25 توصيف الأفعال بالصبغة الإرهابية

قرار تعقيبي عدد 90139 بتاريخ 21 أكتوبر 2020

« حيث يستروح من الفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 أن المحور الأساسي للفعل الإرهابي هو بثّ الرعب والتهريب بين عموم الأفراد بقصد التأثير على سياسة الدولة تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي بإتيان أفعال مادية بغرض تحقيق ذلك القصد أو بما يخل بالنظام العام أو ينال من الأشخاص والأموال.

وحيث وخلافا لما دفع به نائب الطاعن فإن القناعة الدينية لهذا الأخير من أن الزوايا مكان شرك بالله قد تعدت مرحلة إستبطان ذلك الإعتقاد إلى محاولة حرق الزاوية بحجة قطع دابر الشرك نصرة للدين فتمظهرت في أفعال مادية إيجابية إصطبغت ضرورة والأمر على ما ذكر بطابع التهريب والترويع والنيل من الأشخاص والأموال والإخلال بالنظام العام لفرض نمط عقائدي وسلوكي يؤثر على سياسة الدولة فكان توصيف محكمة القرار المنتقد لتلك الأفعال بالصبغة الإرهابية على معنى الفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 يتفق مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف واتجه ردّ هذا المطعن لعدم وجاهته».

11-1-26 محاولة التنقيب والحفر عن الآثار دون رخصة

قرار تعقيبي عدد 81575 بتاريخ 12 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة الثانية والعشرون برئاسة السيد رضا العرعوري وعضوية المستشارين السيدين منير وردليتو وكمال بوكثير بمحضر المدعي العام السيد محمد القمودي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سنية العبادوي .

« حيث كان الحكم المنتقد قضى بعدم توفر الأركان القانونية للجريمة موضوع قرار الإحالة.

وحيث انه لقيام الجريمة المشار إليها وفقا أحكام الفصل 59 م ج و 82 مكرر من مجلة حماية التراث لا بد من شروع المتهم في تنفيذ الركن المادي الذي تقوم به الجريمة ثم توليه العدول عن ذلك لحدوث امر خارج عن ارادته.

وحيث أكد القرار التعقيبي الجزائي عدد 3289 المؤرخ في 25 / 11 / 1964 أن المقصود بركن الشروع في التنفيذ لتكوين جريمة المحاولة هي الاعمال التي

تؤدي مباشرة لاقتراف الجريمة المقصود ارتكابها والفرق بين ذلك والعمل التحضيري ان العمل التنفيذي هو الذي يؤدي حتما ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة ذاتها والعمل التحضيري هو عمل مبهم لا يمكن تحقيق الغرض منه.

وحيث انه بالنظر لما ورد بمحضر باحث البداية من كونه بتفتيش سيارة المتهم عثر الباحث على آلة لكشف المعادن نوع «جيوهانتى»، فانه يتبين وان المتهمين لم يشعرا في التنفيذ طالما وان الآلة المحجوزة كانت لا تزال داخل السيارة وهو عمل لا يؤدي مباشرة لاقتراف الجريمة المراد ارتكابها وهي التعقيب على الاثار، وانما كانا بصدد عمل تحضيرى لا يرتقى إلى مستوى الشروع في التنفيذ.

وحيث ان محكمة الحكم المطعون فيه لما استخلصت وان اركان الجريمة موضوع قرار الإحالة غير متوفرة قد أحسنت تطبيق القانون التطبيق السليم، فكان قرارها معللا التعليل المستساغ بما يتوافق واحكام الفصل 168 من م ا ج.

وحيث أن المطعن يرمي في حقيقة الأمر إلى مناقشة محكمة الحكم المنتقد فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي يدخل في نطاق اجتهادها المطلق لا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما كان تعليّلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

وحيث لم تأت مستندات التعقيب بما يوهن الحكم المنتقد في شيء، وكان بذلك الحكم معللا كما يجب قانونا دون تحريف للوقائع ولا خرق للقانون بما يؤدي إلى رفض المطعن لخلوه من المستند الصحيح».

11-1-27 التدوينة بشبكة التواصل الاجتماعي لا يُخَوّل للعموم الاطلاع عليها

قرار تعقيبي عدد 95683 بتاريخ 3 جوان 2020 صادر عن الدائرة الرابعة عشر برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية المستشارين السيدين العقيد قاضي نورة الامام وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العام السيد عادل الغالي ومساعدة كاتبة المحكمة السيدة سميرة بوشوشة.

«عن المطعن المتعلق بضعف التعليل وخرق القانون:

حيث انه خلافا لما اثاره المعقب فان محكمة الأصل استعرضت كافة عناصر القضية بما تبين معه ان اركان جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية

للاتصالات غير متوفرة تطبيقاً لاحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، ذلك وان ما ورد بتدوينه المتهمة [انا راجلي كلونال معديا عمري مقاجيا ومقدردفا صباح وليل كيف النشيد الوطني. واحد يعدي عام جيش واحد يعدي عمرو كامل قول لجارتك اهرب الشمس باهيا قبل ما يطيح عليك الليل بنجموا قتلوا ملازم قولها قتلت لمجربين ساقيك والمحطة موش لازم] هو مجرد تعبير عن راي في شأن من شؤونها الزوجية وكانت عبارة عن دردشة على نطاق ضيق ما بينها وبين صديقاتها على شبكة التواصل الاجتماعي ولم يكن مخولا للعموم الاطلاع عليها، وبذلك فانها لا تتضمن أي إساءة إلى زوجها أو للمس من هيئته هذا علاوة عن انتفاء الركن القصدي للجريمة المذكورة.

وحيث ان الطعن يرمي إلى مناقشة محكمة القرار المنتقد فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي يدخل في نطاق اجتهادها المطلق .

وحيث لم تأت مستندات التعقيب بما يوهن الحكم المنتقد في شيء ، وكان بذلك الحكم معللاً كما يجب قانوناً دون تحريف للوقائع ولا خرق للقانون بما يؤدي إلى رفض المطاعن كلها لخلوها من المستند الصحيح».

11-1-28 عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية - التقدم التلقائي

قرار تعقيبي عدد 98228 بتاريخ 8 جويلية 2020 صادر عن الدائرة الرابعة برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية المستشارين السيدين العميد قاضي نورة الإمام وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العام السيد عادل الغالي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سميرة بوشوشة .

«عن المطعن المأخوذ من خرق الفصل 31 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 14/01/2004 المتعلق بالخدمة الوطنية والفصل 66 من م م ع ع: حيث رجوعاً إلى قرار الاحالة فانه تمت احالة المتهم المعقب لمقاضاته من اجل عدم تسوية الوضعية ازاء قانون الخدمة الوطنية طبق الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 والفصل 66 من م م ع ع .

وحيث اقتضى الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المشار إليه انه: «يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عاماً أن يتقدم تلقائياً لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزماً بأدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين».

كما اقتضى الفصل 17 منه انه :«يجب على المواطن الذي تم إحصاؤه أن يتقدم عند حلول الحصة المعينة له ببطاقة الإحصاء إلى المركز الجهوي للتجنيد والتعبئة أو المكتب الجهوي للخدمة الوطنية التابع له قصد تسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية .تضبط تواريخ الالتحاق بالمراكز والمكاتب المذكورة بالنسبة إلى أفراد كل حصة حسب المعتمديات .ويتم الإعلان عنها عن طريق وسائل الاعلام وبمعلقات في الأماكن العمومية وعند الاقتضاء بواسطة الدعوة الشخصية».

وحيث انه تبعا للفصلين 2 و 17 المشار اليهما فان المتهم كان عليه ان يتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية بمجرد الإعلان عن تواريخ الالتحاق بالمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة أو المكتب الجهوي للخدمة الوطنية عن طريق وسائل الاعلام وبمعلقات في الأماكن العمومية وعند الاقتضاء بواسطة الدعوة الشخصية، وبالتالي فان المتهم ثبت اخلاله بواجبه في التقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية وانطبقت عليه أحكام الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 والفصل 66 من م.ع.ع.

وحيث انه خلافا لما ذكر من كون المعقب يتمتع بحق تأجيل الخدمة الوطنية لمزاولته للدراسة فانه لاشيء يؤكد صحة هذا المعطى الواقعي الذي يحمل على المعقب اثباته وطالما انه لم يفعل فقد اتجه رفض مطعنه».

11-2 إجراءات جزائية

11-2-1 النقل الحرفي لأسانيد الحكم الابتدائي يُخلّ بمبدأ التقاضي على درجتين وبمبدأ المحاكمة العادلة

قرار تعقيبي عدد 97577 بتاريخ 3 جوان 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«حيث أن تعليل الأحكام شرط لصحتها وإن ضعف التعليل أو غيابه يعيها عيبا جوهريا يوجب نقضها ضرورة وأن الفقرة 4 من الفصل 168 م.إ.ج أوجبت على القاضي الجزائي أن يعلل حكمه من الوجهتين الواقعية والقانونية تعليلا

واضحاً مقنعاً شاملاً لكافة عناصر القضية وخاصة الجوهرية منها ومؤدياً منطقياً لنتيجة الحكم ليتسنى للمحكمة الأعلى درجة على غرار محكمة التعقيب القيام بوظيفتها في الإشراف على حسن تطبيق القانون.

وحيث ورجوعاً إلى الأسانيد القانونية للقرار المطعون فيه يتبين أنها مجرد نقل حرفي ونسخ للأسانيد المضمنة بالحكم الابتدائي وإن الإختلاف بينهما يتمثل في أن أسانيد حكم البداية محررة بخط اليد في حين أن أسانيد القرار المنتقد هي مجرد نسخ لها بإستعمال أداة رقن رغم التنصيص على أن محكمة الدرجة الثانية قد تعهدت بالموضوع بموجب طعن بالإستئناف صادر عن النيابة العمومية وعن القائمين بالحق الشخصي.

وحيث أن الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف ينقل القضية برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتقضي فيها وفقاً للضوابط المسطرة بالفصل 216 م 1 ج بما يفترض معه أن يتضمن حكم محكمة الدرجة الثانية الأثر الذي يدل على ممارستها لدورها الرقابي وجوابها ولو تلميحا عن دفعات أطراف القضية بما يجعل المتقاضي واثقاً من تفحصها لجميع أوراق القضية ومطمئناً لإجتهادها ولحكمها أياً كانت نتيجة، أما وأن تقوم تلك المحكمة بالنسخ الحرفي لأسانيد الحكم الابتدائي دون زيادة أو نقصان فإن ذلك من شأنه إدخال الريبة في ذهن المستأنف كائناً من كان ولو كان ممثلاً للحق العام وأن يذهب به الظن إلى أن المحكمة لم تستشعر أمانة القضاء بما يمس من هيبة القاضي ويخدش مصداقيته في التعامل مع أوراق الملف ويهز بالتالي من الثقة فيه وينسف مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ المحاكمة العادلة.

وحيث وبناء عليه وبغض النظر عن المطاعن المثارة فإن نقل محكمة القرار المطعون فيه لحجيات واسانيد محكمة البداية وتضمينها بقرارها دون زيادة أو نقصان أو رقابة أو مراجعة ودون التعرض لطلبات الطاعنين والردّ عليها ولو بالدلالة يدخل في حكم غياب التعليل أصلاً ويشكل بالتالي خرقاً لأحكام الفقرة 4 من الفصل 168 م 1 ج يوجب النقض.

وحيث وفضلاً عن ذلك فقد جاء بتعليل محكمة البداية الذي نقلته محكمة الدرجة الثانية حرفياً بقرارها عند تغييرها للوصف القانوني للأفعال موضوع

جريمة محاولة القتل العمد مع سابقة الإضمار قولها ما نصه: «وحيث إن القصد الجنائي الخاص يقتضي إقدام الجاني على إزهاق روح الضحية وذلك تجسيدا لما خطط وفكر فيه سابقا بترؤ وهدوء وإن وقائع الحال تثبت أن تصرف جملة المتهمين كان بتشنج وحيناً نتيجة قتل قريبهم»، لتخلص مباشرة إلى اعتبار تلك الأفعال في العنف الشديد الناجم عنه سقوط وتدين البعض وتبرأ البعض الآخر رغم أن تلك الحثية فيها إدانة للجميع.

وحيث أن ذلك التعليل ينطوي على خلط واضح بين مفهوم الإضمار في جرمي القتل العمد مع سابقة القصد ومحاولة ذلك، ومفهوم القصد الجنائي الخاص المشترك لقيام جرائم القتل العمد أو القتل مع سابقة القصد أو محاولة ذلك والمتمثل في إنصراف نية الجاني نحو إزهاق روح الضحية والحرص على تحقيق تلك النتيجة بما أوقع محكمة القرار المطعون فيه والأمر على ما ذكر في سوء التعليل وسوء إستخلاص النتيجة القانونية السليمة من الوقائع المعروضة عليها والخطأ في تطبيق القانون.

وحيث علاوة على ذلك فقد إنتهت محكمة القرار المطعون فيه إلى إقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به سلباً في جرائم متعددة بإعادة رqn حثية يتيمة مجملة أوردتها محكمة الدرجة الأولى بحكمها مضمون نصها: «أن ركن الإسناد بقي منقوصاً وقاصراً بالملف»، وهي حثية ليس فيها تفصيل أو إستعراض للأدلة وموازنة بينها فكان التعليل على تلك الشاكلة على غاية من الوهن الذي يدخل في حكم غياب التعليل أصلاً بما يجعل النعي على القرار المنتقد بضعف التعليل في طريقه أيضاً.

وحيث وتأسيساً على ما تقدم فقد استحق القرار المطعون فيه النقض للأسباب السالف شرحها واتجه التصريح بنقضه مع الإحالة».

11-2-2 جرح ووفاة برصاص عون أمن أثناء الثورة- انتهاك جسيم من اختصاص الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية

قرار تعقيبي عدد 86255 بتاريخ 29 جانفي 2020 صادر عن الدائرة الرابعة عشر برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية المستشارين السيد ين المقدم

قاضي منير بن عبد الله وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العمومي السيد عادل الغالي وبمساعدة كاتب المحكمة السيد علي العمر اوي.

« حيث انه ودون الخوص في الأصل وبقطع النظر عن جدية المطعن المثار من عدمه فانه يتعين على محكمة القانون اثارة جملة من القواعد الاجرائية الأساسية ليتسنى تفعيل دور محكمة التعقيب في الرقابة على حسن تطبيق القانون وتاويله. وحيث نص الفصل 169 من م ا ج انه: «اذا ظهر ان الجريمة من خصائص محكمة اخرى تصدر المحكمة حكما بخروج القضية عن انظارها وتنتهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية

وحيث ومما لاشك فيه ان قواعد الاختصاص الحكمي تعتبر قواعد امرة لمساسها بالاجراءات الأساسية والنظام العام ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو الاخلال بها وتثيرها محكمة التعقيب ولو لأول مرة ولها ان تتمسك به من تلقاء نفسها تفصيلا لاحكام الفصل 169 من م ا ج.

وحيث نص الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12/06/2014 المتعلق باحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبالقضايا الممتدة بالفترة بين 17 ديسمبر 2010 و08 فيفري 2011 على انه « تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة او اصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.»

وحيث نص الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها المشار إليه على ان: «الانتهاك على معنى هذا القانون هو كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر على اجهزة الدولة أو مجموعات أو افراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها وان لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك كما يتصل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم به مجموعات منظمة».

وحيث نص الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المذكور على انه « تحدث باوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة

بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية ويتم تكوينهم تكويناً خصوصياً في مجال العدالة الانتقالية.

تتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون ومن هذه الانتهاكات خاصة:

- القتل العمد

- الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي

- التعذيب

- الاختفاء القسري

- الاعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة .

كما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لاسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة».

وحيث نص الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المشار إليه انه « تحيل الهيئة إلى النيابة العمومية الملفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويتم اعلامها بكل الاجراءات التي يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلطة القضائية ولا تعارض الملفات الواقع احالتها بمبدأ اتصال القضاء».

وحيث نص الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية على أن« المتهم بريء إلى ان تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة».

وحيث نص الفصل 108 من دستور الجمهورية التونسية أنه « لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول والمتقاضون متساوون امام القضاء .حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، ويسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية. ويضمن القانون التقاضي على درجتين .جلسات

المحاكم علنية الا اذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم الا في جلسة علنية.

وحيث نص الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية في فقرته التاسعة على ان «تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن».

وحيث لا جدال ان أحكام الفصل 5 من مجلة المرفعات والعقوبات العسكرية حددت اختصاص المحاكم العسكرية بالبت في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين الا ان المشرع التونسي وبصفة لاحقة واستنادا إلى أحكام الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها نظم اختصاص الدوائر القضائية المتخصصة بالبت في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام القانون المذكورة ويأتي على رأس تلك الانتهاكات القتل العمد.

وحيث اقتضى الفصل 33 من م م ع ع على أنه «اذا قررت دائرة التعقيب إبطال القرار أو الحكم المطعون فيه من حيث مرجع النظر فإنها تقرر أيضا إحالة القضية على المحكمة المختصة».

وحيث لا شك وان واقعة مدينة دوز موضوع قضية الحال وما آلت إليه من وفاة كل من ح. ط. ور. ع. وجرح بعض المتضررين بأضرار بدنية، وكان ذلك برصاص عون الامن المحكوم عليه تدرج في إطار الانتهاكات الجسيمة على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وهو ما يجعلها تخرج عن اختصاص القضاء العسكري واعتبارها من أنظار واختصاص الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية.

وحيث واستنادا إلى أحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12/06/2014 والقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ

في 24 ديسمبر 2013 وإلى مجلة المرفعات والعقوبات العسكرية والمجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية يتجه إحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية».

11-2-3 الدعوى العمومية

11-2-3-1 مفهوم إثارة الدعوى العمومية

قرار تعقيبي عدد 10021-10482-40149 بتاريخ 18 مارس 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين ماهر كنو ومنذر الهذيلي وبحضور المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير.

«عن المطعن المتعلق بخرق الفصول 51 و 55 و 104 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية وهضم حقوق الدفاع ومخالفة معايير المحاكمة العادلة:

حيث أنه عن كل جريمة تترتب دعوى عمومية الهدف منها تطبيق العقوبات وهذه الدعوى لا تنطلق بصفة فعلية إلا بإثارة الدعوى العمومية أو بتحريكها من مرحلة السكون إلى مرحلة تصيرها قائمة الذات ليتعهد بها هيكل قضائي.

وحيث نص الفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون وتتولى تنفيذ الأحكام.

وحيث أن المقصود بإثارة الدعوى العمومية هي العمل القانوني الذي يضع النزاع بين يدي السلطة القضائية المختصة لغرض الفصل فيه وإصدار حكم في الجريمة موضوع التتبع أو طلب إجراء الأبحاث الهادفة إلى الوصول إلى الحقيقة في إرتكاب الجريمة [كما هو الشأن عن فتح بحث تحقيقي] أما ممارسة تلك الدعوى فتكون بالقيام بجميع الأعمال الإجرائية من تقديم الطلبات والدفعات وتحرير المستندات وتقديم الطعون كل ذلك لغاية إصدار حكم بات.

وحيث أن إثارة النيابة العمومية للتتبع عند فتحها للبحث التحقيقي لا يمنعها من إثارة الدعوى العمومية مجددا عندما يظهر من الأبحاث ما يكشف عن أعمال إجرامية لم تكشف عنها الأبحاث الأولية التي على ضوئها فتح البحث التحقيقي ذلك أن النيابة العمومية طرف أصلي في الدعوى الجزائية أمام قلم التحقيق

ولم يقيد المشرع من سلطتها في إثارة الدعوى العمومية وممارستها ما لم تختتم الأبحاث بموجب قرار في ختم البحث ضرورة وأن القيد والمنع لا يكون إلا بموجب نص صريح الأمر الذي يجعل الدفعات المثارة بهذا الخصوص لا تجد لها سنداً في القانون الإجرائي الجزائي وإتجه الالتفات عنها لعدم وجاهتها [...]».

11-2-3-2 مفهوم إثارة الدعوى العمومية ومفهوم ممارستها- إنقضاء الدعوى العامة الجرائم الديوانية بمرور الزمن

قرار تعقيبي عدد 80911 بتاريخ 8 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«حيث كانت الإدارة قد تمسكت منذ الطور الأول بجلسة يوم 8/5/2018 بعدم إنقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بناء على تاريخ إيداع محضر البحث وطلبات الإدارة لدى النيابة العمومية وهو ما عاودت التمسك به جلسة لدى الطور الثاني لتجيبها محكمة القرار المطعون فيه بأن «لا عبرة بما تمسكت به» وتفضي بتقرير الحكم الابتدائي.

وحيث أن الإشكال في قضية الحال يستدعي إستدكار مفهوم إثارة الدعوى العمومية ومفهوم ممارستها وكذلك الخوض في من له إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية وأثر تلك الإثارة على إنقضاء الدعوى العامة بمرور الزمن .

وحيث لا خلاف في أن مرحلة التتبع الجزائي تجمع بين إثارة الدعوى العمومية وممارستها وهي تشمل جميع الأعمال الأولية التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لمعاينة الجرائم والأعمال اللاحقة التي تقوم بها السلطة المختصة بمباشرة الدعوى العمومية وتحقيق الملاحقة الجزائية.

وحيث أن الإثارة تعني تحريك الدعوى من السكون لتصير قائمة يتعهد بها هيكل قضائي وبهذا المعنى فإن إثارة الدعوى العمومية هي طرح القضية وعرضها على القضاء أي أنها العمل القانوني الذي يضع النزاع بين يدي السلطة القضائية المختصة للفصل فيها وإصدار الأحكام في الجريمة موضوع التتبع أو طلب إجراء الأبحاث الرامية إلى الوصول إلى الحقيقة حول ارتكاب جريمة وهي لذلك

الإجراء المبدئي الذي ينطلق به التتبع للكشف عن مرتكب الجريمة . أما ممارسة الدعوى العمومية فهي مجموع الأعمال الإجرائية التي يقع القيام بها بعد الإثارة وتحكّمها النيابة العمومية من إصدار لقرار الإحالة أو تقديم الطلبات وتحرير المستندات أو رفع الطعون والتي تكون الغاية منها إصدار حكم بات في القضية.

وحيث خصّ المشرع التونسي إدارة الديوانة وحدها بإثارة الدعوى العمومية بموجب أحكام الفصل 318 من المجلة الديوانية الذي نص على أنه: « يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر مستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة». كما أوجب المشرع على النيابة العمومية مدّ إدارة الديوانة بكل المعلومات التي تحصل عليها والتي تفترض وجود مخالفة ديوانية وذلك خلافا للمبدأ العام الذي يوجب على سائر الإدارات والموظفين إعلام وكيل الجمهورية بكل ما يبلغ لهم من علم بالجرائم وهو ما يستروح من صياغة الفصل 319 من المجلة الديوانية الذي ورد فيه: «تحيل النيابة العمومية على الإدارة كل المعلومات التي تحصل عليها والتي تفترض وجود مخالفة ديوانية أو أية مناورة ترمي أو ينتج عنها مخالفة القوانين والتراتيب التي لها صلة بتطبيق مجلة الديوانة وذلك بمناسبة النظر في قضايا مدنية أو تجارية أو بحث جزائي ولو إنتهى ذلك بعدم سماع الدعوى».

وحيث يتضح من الفصلين 318-319 من مجلة الديوانة أن النيابة العمومية لا تتولى إثارة الدعوى العمومية في الجريمة الديوانية بل تحيل الأمر عند وجود تلك الجريمة إلى إدارة الديوانة التي تقرر وحدها جدوى التتبع وتتولى إثارة الدعوى إذا ما قررت ذلك بحيث تكون سلطتها مطلقة في هذا المجال.

وحيث رجوعا إلى أوراق الملف يتبين أن الأبحاث قد ختمت بتاريخ 2014/10/19 وأحيلت من قبل إدارة الديوانة مرفوقة بطلباتها في إثارة منها للدعوى العمومية بتاريخ 2017/1/3 غير أن قرار الإحالة من النيابة العمومية على المجلس الجناحي لم يصدر إلا بتاريخ 2018/2/12.

وحيث يظهر من خلال ذلك أن إثارة الدعوى العمومية كانت خلال أمد غير مسقط لحق التتبع على معنى الفصل 323 من المجلة الديوانية وكذلك الفصل 5

من م إ ج وهذا جوهر دفعوعات الإدارة إلا أن محكمة القرار المطعون فيه لم تجبها بتعليل مستساغ عن تلك الدفعوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية وإنما إكتفت بالقول حرفيا بأن « لا عبرة بما تمسكت به الإدارة » فجاء قرارها لذلك قاصر التسبب خارقا بالتالي لأحكام الفصل 168 م إ ج واستحق النقض لهذا السبب».

11-2-3-3 تاريخ إحالة الديوانة لمحضر البحث المصحوب بطلباتها المالية هو تاريخ إثارة الدعوى العمومية وليس تاريخ قرار إحالة النيابة العمومية. قرار تعقيبي عدد 84301 بتاريخ 02 جوان 2020 صادر عن الدائرة الجزائية الثامنة والعشرون برئاسة السيد المنصف بلحاج وعضوية المستشارين السيدين صلاح الشبحاوي وريم دفدوف وبمحضر الادعاء العام السيد بديع الحكيم وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد.

» عن المطعن الوحيد:

حيث اقتضى الفصل 318 من مجلة الديوانة أنه يتولى الوزير المكلف بالمالية أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

وحيث يفهم من النص القانوني المذكور أن حق إثارة الدعوى العمومية في القضايا الديوانية من اختصاص إدارة الديوانة وليس النيابة العمومية بدليل أن النص الذي يليه (الفصل 319) ألزم النيابة العمومية إحالة كل المعلومات التي ترد عليها والتي لها علاقة بالجرائم الديوانية على إدارة الديوانة وذلك بمناسبة نظرها في القضايا الجزائية والمدنية.

وحيث أنه يترتب على ذلك أن قرار إحالة المتهم على المحكمة المختصة التي تتخذ النيابة العمومية لا يشكل إثارة للدعوى العمومية ولا يعتبر مرجعا في احتساب آجال سقوط الدعوى العمومية بصريح عبارات الفصل 318 من مجلة الديوانة الذي يعتبر نصا خاصا يسبق على النص العام الوارد بالفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وحيث أنه ترتباً على ذلك فإن تاريخ إحالة الديوانة لمحضر البحث المصحوب بطلباتها المالية المؤرخ في 11 أكتوبر 2006 هو تاريخ إثارة الدعوى العمومية وليس تاريخ قرار إحالة النيابة العمومية.

وحيث أنه طالما وأن الواقعة حصلت بتاريخ 08-12-2003 وتاريخ إثارة الدعوى العمومية كان بتاريخ 11-10-2006 فإن أجل الثلاث سنوات يكون لا زال ممتداً وتكون بذلك الدعوى العمومية لم تسقط بعد بمرور الزمن الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه حينما ذهب في غير ذلك الاتجاه يكون خارقاً للقانون ومستوجباً للنقض».

11-2-3-4 إجراءات التتبع تنطلق بموجب قرار الإحالة - بطلان محضر الاحتفاظ لا يطال في شيء صحة إجراءات التتبع

قرار تعقيبي عدد 91874-91892-92116-92837 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين ماهر كنو ومنذر الهذيلي بحضور المدعي العام السيد رياض الغربي ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«عن المظعن المتعلق ببطلان إجراءات التتبع

حيث ان التتبع في الجرائم إنما تتولاه النيابة العمومية بعد جمعها للاستدلالات وتلك الاستدلالات يتضمنها عادة محضر بحث ابتدائي محرر من قبل مأمور الضابطة العدلية تحت اشراف النيابة العمومية بمعنى ان جمع الاستدلالات هي مرحلة سابقة لاثارة الدعوى العمومية على معنى الفصل 20 من م ا ج التي يكون منطلقها في الجنايات فتح بحث تحقيقي الذي هو امر وجوبي وفقاً لاحكام الفصل 47 من م ا ج.

وحيث خلافاً لما اثاره لسان دفاع المعقبين فان إجراءات التتبع عند اثارة الدعوى العمومية قد انطلقت بموجب فتح البحث التحقيقي استناداً لاحكام الفصلين 20 و 47 م ا ج ولم ينعي الطاعن عليها شيئاً وانه وعلى فرض صحة الدفع ببطلان محضر الاحتفاظ لدى الباحث الاولي فان ذلك البطلان لا يطال في شيء صحة إجراءات التتبع التي انطلقت منذ فتح البحث التحقيقي وعليه فان

الدفع ببطلان محضري الاحتفاظ والتمديد وعلى فرض ثبوته اضحى غير وجيه خاصة وان نطاق مرمى البطلان لا يطل صحة إجراءات التتبع في شيء.

وحيث يكون الطعن الرامي إلى معارضة محكمة القرار المنتقد فيما انتهت إليه توصلا إلى بطلان جميع إجراءات التتبع في غير طريقه للأسباب السالف شرحها واتجه الاتفات عن دفعات الطاعنين المثارة بهذا الخصوص لعدم وجاهتها».

11-2-3-5 قرار الرجوع في الحفظ من النيابة العمومية يجب أن يكون صريحا ومعللا

قرار تعقيبي عدد 90840 بتاريخ 22 جانفي 2020 صادر عن الدائرة الرابعة عشر برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية المستشارين السنيين العقيد قاضي نورة الامام وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العمومي السيد عادل الغالي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة هاجر السلطاني.

« حيث وبغض النظر عن المطاعن المثارة من المعقبيين فانه بمراجعة أوراق القضية ومنها بالخصوص التدقيق في اجراءات التتبع تبين وان النيابة العسكرية وبعد تعهدها بالملف اتخذت بتاريخ 07 ديسمبر 2017 قرار في الحفظ لعدم توفر الاركان القانونية ثم اصدرت لاحقا بتاريخ 05 أفريل 2018 قرار ثان يقضي بإحالة المتهمين على المجلس الجناحي لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما. وحيث يستخلص مما ذكر وان النيابة العسكرية تراجعت في قرار الحفظ المذكور دون احترام لقاعدة توازي الشكليات باتخاذ قرار صريح ومعلل في الغرض بما جعل قرار الاحالة اللاحق له مناقضا له ومتعارضا معه .

وحيث يجدر التذكير وان أحكام الفصل 199 م ا ج تنص على انه: «تبطل كل الاعمال والاحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية...».

وحيث كانت اجراءات التتبع والحالة ما ذكر باطلة لمخالفتها للقواعد المتعلقة بالنظام العام وللقواعد الإجرائية الأساسية طبقا لاحكام الفصل 199 م ا ج المشار إليها ، وكان لزاما على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو في طور التعقيب.

وحيث انه باعمال أحكام الفصل 269 م.ا.ج فان المحكمة تقرر النقض دون احالة على اعتبار وان هذا النقض لم يترك شيئا يستوجب الحكم».

11-2-4-1 عدم بت قاضي التحقيق في مطلب القيام بالحق الشخصي بالقبول أو بالرفض - عدم اكتساب الشاكين الصفة في الطعن

قرار تعقيبي عدد 94331 بتاريخ 15 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي وبمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

« حيث إقتضى الفصل 258 م إ ج أنه » يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناء على عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه:

(3) القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية ..»

وحيث يتضح بمراجعة مطروقات ملف القضية أن الأستاذ ر. غ. أعلن نيابته عن الشاكين أمام قاضي التحقيق وقدم مطلبا في القيام بالحق الشخصي مؤرخ في 12/9/2018 إلا أن قاضي التحقيق المتعهد لم يتولى عرض ذلك المطلب على النيابة العمومية لإبداء رأيها كما لم يبت في ذلك المطلب بالقبول أو بالرفض طبق ما يقتضيه أحكام الفصل 38 م إ ج حتى يكتسب الشاكين صفة القائم بالحق الشخصي من عدمه.

وحيث أنه من الشروط الأساسية للطعن بالتعقيب توفر الصفة في الطاعن وفقا لأحكام الفصل 258 المذكور.

وحيث لم يكتسب المتضرران صفة القائم بالحق الشخصي ولم يكونا لنفسهما مركز قانوني في القضية في غياب البت في ذلك المطلب المقدم في الغرض من طرف قلم التحقيق وقبوله طبق الشروط القانونية حتى يمكن لهما الطعن بالتعقيب.

وحيث طالما لم يتم البت في مطلب القيام بالحق الشخصي من طرف قلم التحقيق ولم يكن للطاعنين مركز قانوني أمامه ومن بعده أمام دائرة القرار المنتقد فإنه لا صفة بالتالي لهما للطعن بالتعقيب في ذلك القرار بما يتجه التصريح برفض طعنهما شكلا لإنتفاء الصفة في الطاعن».

11-2-4-2 إعادة إستنطاق المتهم من قلم التحقيق إذا ما قرر تفكيك القضية

قرار تعقيبي عدد 96853 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن الدائرة الخامسة والعشرين برئاسة السيد محمد العسكري وعضوية مستشاريها السيدين نبيهة العويني ومحمد علي يمن بمحضر المدعي العام السيد نور الدين الزياتي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد علي العمراوي.

« حيث إتضح بالإطلاع على مستندات القرار المطعون فيه أنه أقر ما إنتهى إليه قلم التحقيق ولم يناقش الدفع القانوني المثار من طرف النيابة العمومية بطوريها بخصوص ضرورة إعادة إستنطاق المتهم من طرف قلم التحقيق إذا ما قرر هذا الأخير تفكيك القضية.

وحيث أن عدم الرد على مثل ذلك الدفع المتعلق بالإجراءات الأساسية والضمانات المكفولة للمتهم رغم جديته يورث القرار المنتقد ضعفا في التعليل. وحيث نص الفصل 69 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه على حاكم التحقيق أن يثبت هوية ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة ويعرفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها ويتلقى جوابه....

وحيث تبين بالرجوع إلى أوراق الملف أن قلم التحقيق إكتفى بالإستنطاق الأول للمتهم قبل قرار التفكيك وهو ما يعرض قراره للبطلان الأمر الذي تجاوزته دائرة القرار المنتقد رغم مساهمته بالإجراءات الأساسية التي تمس بالنظام العام.

وحيث أن قرار التفكيك الصادر عن قلم التحقيق بعد إستنطاق ذي الشبهة لا يمكن أن يغني عن إعادة سماعه بعد إصدار فتح بحث تحقيق جديد.

وحيث أن تخلف دائرة الاتهام عن مناقشة ذلك الدفع الذي أثير أمامها فضلا عن كونه يشكل ضعف تعليل فإنها تكون قد تجاوزت دفعا فيه مخالفة للنظام العام ويمكن لهذه إثارته من تلقاء نفسها ويتعين تبعا لذلك قبول مطلب التعقيب أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بالقيروان للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى».

11-2-4-3 تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي يحتم الإفراج الوجوبي

قرار تعقيبي عدد 84956 بتاريخ 18 مارس 2020 صادر عن الدائرة الرابعة عشر برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية مستشاريها السيدين القاضي مقدم رفيق بن إبراهيم والبشير العياري وبمحضر المدعي العام السيد سفيان بوزيد ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

« ثانيا: في خرق إجراءات الإيقاف التحفظي:

حيث أقتضى الفصل 85 م إ ج أنه يمكن إيقاف المظنون فيه تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف. والإيقاف التحفظي في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا يجوز أن يتجاوز الستة أشهر ويكون القرار معللا ويتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره وإذا إقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار معلل تمديد فترة الإيقاف بالنسبة لجنحة مرة واحدة من أربعة أشهر...» كما أضاف ذات الفصل بأنه لا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي يتحتم في هذه الحالة على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام حسب الأحوال الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره.

وحيث لا جدال في أن أحكام الفصل 85 م إ ج المبينة أعلاه تضمنت إجراءات أساسية وأحكام أمرة لتعلقها بإجراء إستثنائي وخطير يطال حرية الأشخاص لذلك تم تحديد الجهة القضائية المختصة لاتخاذ ذلك القرار مع تحديد صوره حصرا إقتصارا على الجنايات والجنح المتلبس بها كما وضبط شكلياته والمائل في القرار المعلل المتضمن لأسانيد الواقعية والقانونية مع حصر مدته وحالات التمديد مع وجوب إحترام سقف أقصى يتمثل في تسعة أشهر (9) بالنسبة للجنح وأربعة عشر شهرا بالنسبة للجنايات وفي صورة تجاوز المدة القصوى يكون الإفراج حتميا وبقوة القانون.

وحيث تبين ورجوعا لمظروفات الملف بأن السيد قاضي التحقيق المتعهد منطلقا كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في مواجهة المظنون فيه (أ.ع) تنفيذا

وحيث وبصرف النظر عن تحديد الوصف القانوني للأفعال إن كان الأمر يتعلق بجنحة القتل على وجه الخطأ مناهات أحكام الفصل 217 م ج أو جنابة القتل العمدة بسابقة القصد فإن احتساب إنطلاق مدة الإيقاف التحفظي الموافق لـ 2017/6/15 وتاريخ صدور القرار الاتهامي والموافق لـ 2018/11/27 نجده أن المدة القصوى للإيقاف التحفظي وقع خرقها دون احترام موجبات التمديد القانوني ومن ثمة بات من الوجوب الإفراج الحتمي عن المظنون فيه (أ.ع) من سجن إيقافه ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى لثبوت خرق أحكام الفصل 85 م إ.ج.».

قرار تعقيبي عدد 84859 بتاريخ 9 مارس 2020 صادر الدائرة السادسة والثلاثين برئاسة السيدة زكية الماجري وعضوية المستشارين السيدين عادل الأخضر وفصل بن عامر وبمحضر المدعي العام السيدة لطيفة العرفاوي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد علي العمراوي.

حيث أن تعليل الأحكام وتسيبها أمر واجب لصحتها ولا يكون ذلك التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل وترتبا عليه فإن كان لمحكمة الموضوع الاختصاص المطلق في تقدير الوقائع وإستخلاص النتائج القانونية منها إلا أن ذلك مرتبط بجدية التعليل وسلامته بما لا يتنافى ومظروفات أوراق القضية وبما له أصل ثابت بالملف.

وحيث نعى الطاعن صلب مستنداته على القرار المنتقد خرق أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وحيث وخلافا لما ذهب إلى ذلك الطاعن فإن الفصل المحتج به يتحدث على اختصاص دائرة الاتهام والإفراج والترجييع والإحالة والأبحاث التكميلية.

وحيث ما تم التمسك به بخرق مبدأ التقاضي على درجتين حيث أحال السيد قاضي التحقيق المعقب على أنظار محكمة الناحية دون إعلامه بقرار ختم البحث فيه سوء فهم لأحكام الفصلين 106 حسبما نقح بتاريخ 22 نوفمبر 1993 في فقرته الرابعة الذي نص: «إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جنحة تستوجب عقابا بالسجن فإنه يحيل المظنون فيه على قاضي الناحية أو المحكمة الجنائية بحسب الأحوال».

وحيث نص الفصل 109 من نفس المجلة في فقرته الأخيرة «قرار الإحالة على دائرة الاتهام يعلم به المظنون فيه ويكون له حق إستئنافه في الأجل نفسه».

وحيث بقراءة متقاطعة بين الفصلين المذكورين فإن واجب إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث يقتصر على الإحالة على دائرة الاتهام في الجنايات والقول أن على حاكم التحقيق إعلام المظنون فيه بقرار الإحالة على محكمة الناحية أو المجلس الجناحي فيه سوء فهم للفصول 106 و 109 من مجلة الإجراءات الجزائية التي يجب أن تقرأ بصفة متقاطعة ومتكاملة لذلك كان هذا الجزء من الطعون في غير طريقه وإتجه رفضه.

وحيث نعى الطاعن على القرار المنتقد خرقه لأحكام الفصلين 108 و 105 من الدستور.

وحيث وخلافا لما ذهب إلى ذلك الطاعن فإنه لا خلاف أن القواعد الدستورية هي البناء الجامع للمنظومة القانونية إلا أنه في مادة الإجراءات الجزائية فإن النصوص القانونية المنطبقة هي التي وردت بمجلة الإجراءات الجزائية الضامنة للحقوق الأساسية الحريات ولا يجوز والحالة تلك التمسك بقواعد الدستور بمناسبة قضية جزائية لإختلاف الأسس والغايات منها خاصة أن مجلة الإجراءات الجزائية لا تختلف في ما ورد من قواعد عامة متصلة بالحقوق والحريات الواردة بالدستور لذلك كان هذا الدفع النظري مجردا وإتجه رفضه أيضا لعدم جديته.

وحيث نعى الطاعن أيضا على محكمة الحكم المنتقد تحريفها للوقائع قولا أن الطاعن عمد إلى الإعتداء بالعنف على الشاكين كيفما بينته الأبحاث والأمر الذي ليس له اثر بالملف.

وحيث وخلافا لما جاء بمستندات التعقيب فإنه بالرجوع إلى محضر سماع الشاكية (ح.ع) لدى السيد قاضي التحقيق بتاريخ يوم 19 جويلية 2017 جاء بأقوالها أن المعقب المشتكى به في الأصل مسكها من كتفيها وقام بدفعها وأسقطها أرضا.

وحيث جاء وخلافا أيضا لما جاء بمستندات التعقيب فإنه بالرجوع إلى محضر سماع الشاكي (ع.إ) لدى السيد قاضي التحقيق بتاريخ يوم 19 جويلية 2017 «حينها قام بسؤال المعقب عن سبب دفعه وتعنيفه لزوجته قام كذلك بدفعه وركله وتم طردهما بالقوة وقامت زوجة المتهم (خ) وكاتبته بالحيلولة جون مواصلة الإعتداء بالعنف».

وحيث أحسنت محكمة القرار المطعون فيه تطبيق القانون وتقدير الوقائع وإستخلاص النتيجة القضائية السليمة لذلك إتجه عدم الإلتفات المطاعن المثارة لعدم جديتها وإتجه رفضها وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وحيث أن هذا الفرع من الطعون إنما كان يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع فيما إعمدته من العناصر لتبرير قضاءها وهو جدل موضوعي داخل في نطاق إجتهادها وليس لهذه المحكمة أن تنقض الإجتهد طالما كان معلا ومسببا وأن طلبه النقض دون إحالة سيرجع الطاعن إلى وضعية الحكم الإبتدائي القاضي بالإدانة والخطية وهو نفس الحكم الذي تم إقراره إستئنافيا.

11-2-4-5 جواز تبني قرار دائرة الاتهام للحثيات الواقعية لقرار ختم البحث

قرار تعقيبي عدد 91968 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن الدائرة الخامسة برئاسة السيد جلال الدين بوكثيف وعضوية المستشارين السيدين عدنان الهاني وأمال عاشور وبمحضر المدعي العام السيد أنيس ضيف الله وكاتبة المحكمة السيدة عائدة البرقاوي.

«[...] وحيث أنه ليس هناك أي فصل قانوني بمجلة الإجراءات الجزائية يمنع دائرة الاتهام من تبني الحثيات الواقعية لقرار ختم البحث المنظور من طرفها

وإعتمادها بنفس صياغتها باعتبار وأن الحثيات المذكورة تمثل تجميعاً وعرضاً لماديات الواقعة والأدلة والحجج التي أنتجت الأبحاث والإستقرارات المجراة في القضية وهذه المعطيات المادية والواقعية هي معطيات قارة لا تتغير من طور إلى آخر ولا تعبر عن رأي الهيئة القضائية التي تتعاطى مع القضية سواء كان قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو محكمة القضاء التي تصدر حكمها في الأصل وترتبا على ذلك وخلافاً لما ذهب إليه نائب الطاعنة فإن إستنتاج وقائع القضية ومادياتها الموضوعية من قرار ختم البحث لا يعيب القرار المتقدم في شيء ولا يمثل أي إخلال بالموجبات القانونية الإجرائية.

وحيث أن دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون لا غير.

وحيث أنه بالإطلاع على مستندات الحكم المطعون فيه تبين أنه لما قضى بالصورة المشار إليها فقد إعتد على مستندات صحيحة لا لبس فيها وتم احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

وحيث والحالة تلك فإن جميع تلك المطاعن قد خلت من مستندات صحيحة وقانونية مما يتعين معه رفضها».

11-2-4-6 المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام

قرار تعقيبي عدد 96200 بتاريخ 3 مارس 2020 صادر عن الدائرة الجزائية الثامنة والعشرون برئاسة السيد المنصف بلحاج علي وعضوية المستشارين السيدين صلاح الشياحي ومحمد رؤوف اليوسفي وبمحضر ممثل الإدعاء العام السيد بديع الحكيم وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد.

«عن المطعن الأول المتعلق بالإخلالات الشكلية:

حيث أن التمسك بالإخلالات الشكلية المتعلقة بالحجز وإمضاء محضر البحث الديواني في غير طريقها ضرورة أن فقه القضاء قد إستقر على اعتبار أن لقرار دائرة الاتهام مفعول تطهيري يجعل من جميع الإخلالات الشكلية على فرض وجودها في حكم المعلوم طالما لم يتول المتضرر منها الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام الأمر الذي يفهم منه أنه سلم بإجراءات البحث والتتبع وقبل بها على حالتها هذا فضلاً عن كون الباحث الابتدائي ومن بعده حاكم التحقيق قد

إحترما جميع الإجراءات التي نصت عليه مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعل الدفع المذكور في غير طريقه ومتين الردّ.

11-2-5 التصريح بالحكم الجنائي في كتابة المحكمة وفي غياب لائحة الحكم اجراء غير وجوبي

قرار تعقيبي عدد 99114 بتاريخ 14 جويلية 2020 صادر الدائرة العشرون برئاسة السيد المنذر اللومي وعضوية المستشارين السيد عادل بوصفارة والسيدة هناء سحنون بمحضر المدعي العام السيدة لمياء بن اسماعيل وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

« حيث وفي خصوص المطعن المتعلق بطلب نقض القرار المطعون فيه لمخالفة الفصلين 164 و 165 على اعتبار ان محكمة القرار المنتقد صرحت بالقرار بكتابة المحكمة وفي غياب لائحة الحكم فان هذا الاجراء لا يعتبر من الاجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها طالما لم ينص المشرع على وجوبية ذلك الاجراء ولا على جزاء مخالفته كما انه لم يقع التنصيص عليه بالفصلين 166 و 168 من م ا ج ولذا تعين رفض هذا المطعن».

11-2-6 حق الدفاع

11-2-6-1 حق الدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة يهم مصلحة المتهم الشرعية وله مرتبة دستورية

قرار تعقيبي عدد 98618 بتاريخ 15 جويلية 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي وبمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«حيث أن المهمة الأساسية لدائرة الاتهام إنما هي مراقبة أعمال التحقيق وإجراءاته وتنقيتها من العيوب والإخلالات وإبطال ما كان معيبا منها سندها في ذلك أحكام الفصل 199 م إ.ج. ويدخل في أعمال الرقابة أيضا التحقق من إحترام مقتضيات الفصل 85 م إ ج المتعلق بالإيقاف التحفظي من حيث شروط إتخاذ

القرار الصادر في هذا الشأن ووجوب تعليله والمدة والتمديد فيها عند الإقتضاء فضلا عن إعادة تكييف الأفعال بإعطائها الوصف القانوني الصحيح إذا لم يوفق قاضي التحقيق في إسباغ الوصف السليم عليها.

وحيث أن من أوكد مهام قاضي التحقيق بصريح الفصل 69 م إ ج هو التحقق من شخص ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة أمامه من خلال تثبيت هويته وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة وتلقي جوابه بعد تنبيهه بأن له الحق في أن لا يجيب إلا بمحضر محام يختاره. ذلك أن ضمان حق الدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة يهم مصلحة المتهم الشرعية وقد تم الإرتقاء به إلى مرتبة القاعدة الدستورية إذ جاء بأحكام الفصل 27 من الدستور الجديد ما نصه «المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة».

وحيث أن مصلحة المتهم الشرعية هي أحيانا من الإجراءات الأساسية وأحيانا أخرى من النظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عند الإخلال بها عملا بأحكام الفصل 269 م إ ج إلا أن بعض الإجراءات التي تهم المصلحة الفردية المحضة كعدم إشتمال محضر الإستنطاق على ذكر النص القانوني المنطبق أو عدم إمضاء أوراق البحث من قبل الكاتب سهوا أو عدم إعلام المظنون فيه بقرار تمكين الشاكي من القيام بالحق الشخصي فإنها تبقى رهينة تمسك من وضعت لصالحه مع وجوب إثباته لحصول ضرر له من خرقها وإثارة ذلك أمام محكمة الموضوع لعدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها من المبطلات الاختيارية .

وحيث أن الحضور الأول لذي الشبهة أمام قاضي التحقيق وإجراءات الإستنطاق الأول تأتي أغلبها ضمن الإجراءات الأساسية والقواعد التي لها صلة بالنظام العام لتعلقها بصورة من صور تنظيم كيفية سير مرفق العدالة في المادة الإجرائية الجزائية ولصلتها بضمان حق الدفاع في مرحلة التتبع .

وحيث إلتفتت دائرة القرار المطعون فيه عن طلب الوكالة العامة الرامي إلى إبطال قرار ختم البحث لخرق أحكام الفصل 69 م إ ج واعتبرت أن قاضي التحقيق المتعهد قد واصل أعماله في حق الرشد والحال أن لا أثر بأوراق الملف

على قيامه بأي عمل من أعمال التحقيق في شأن المعقب ضده وفق ما توجهه عليه أحكام الفصلين 50 و 69 م إ ج ولم يباشر إستنطاقه ولم يقرر شيئاً في مآل بطاقة الإيداع الصادرة ضده عن قاضي التحقيق المتخلي الذي جعل المظنون فيه على ذمته (ذمة القاضي المتخلي لفائدته) على الحالة التي هو عليها (بحالة إيقاف) وفقاً لمقتضيات الفصل 105 م إ ج .

وحيث إعتبرت دائرة القرار المطعون فيه كذلك أن قرار التفكيك وإفراد الطفل بإجراءات خاصة ضمن ملف مستقل إنما شرّع لمصلحة الطفل الفضلى وليست لمصلحة من تجاوز سنّ الطفولة ولذلك لا موجب لإعادة إستنطاق المظنون فيه محمد علي الميراوي (المعقب ضده الآن) طالما كان إستنطاقه مطابقاً لأحكام الفصل 68 وما بعده من م إ ج .

وحيث أن موقف دائرة القرار المطعون فيه كاد أن يكون سليماً لو تعلق الأمر بتعهد مباشر من قاضي التحقيق للأطفال بالموضوع ومباشرته إستنطاق جميع المظنون فيهم أطفالاً أو من تجاوز منهم سنّ الطفولة قبل إتخاذ قرار في تفكيك القضية بغية إفراد الرشد بالتتبع صلب ملف مستقل إذ لا يكون في هذه الصورة ملزماً بإعادة إستنطاق هؤلاء بعد التفكيك إلا إذا إقتضت ضرورة البحث ذلك كتوفر أدلة وبراهين أخرى لم تكن معلومة تؤكد التهمة من الواجب عرضها عليهم أو توجيه تهمة جديدة طالما انه صاحب الإختصاص الأصلي أما وأن الأمر تعلق بقرار صادر عن قاضي تحقيق غير مختص بالنظر حكماً يقضي بالتخلي عن القضية لفائدة الجهة القضائية المختصة مع جعل المظنون فيه على ذمته على حالته التي هو عليها (بحالة إيقاف بالنسبة للمعقب ضده) فإنه ولئن كان فحوى ومضمون ما حرره عليه هذا الأخير حرياً بالإعتماد من حيث الأصل في مواجهته أو لفائدته إلا أنه من الواجب أن يمثل المظنون فيه أمام القاضي المتخلي لفائدته باعتباره صاحب الإختصاص وأن يدافع أمامه عن نفسه في إطار التتبع الجديد الذي يقتضي وجوباً أن يمثل خلاله أمام ذلك القاضي ليباشر إستنطاقه وفقاً لمقتضيات الفصل 69 م إ ج ويعرّفه بالتهمة التي وجهتها النيابة بموجب قرار فتح البحث الجديد حتى يتبين له إن كانت ذاتها محل تتبع في القضية المتخلي عنها أم أضيفت إليها تهمة جديدة ويمكنه من الدفاع عن نفسه في إطار مبدأ المواجهة ويتيح له فرصة إبعاد التهمة عنه أو الإعتراف بها بغض النظر عن مضمون

الإستنتاج حتى وإن إقتصصر على تمسك ذي الشبهة بما تحرر عليه أمام قاضي التحقيق المتخلي فضلا على وجوب إتخاذ القاضي المتعهد صاحب الإختصاص قرارا في إبقاء المظنون فيه الموقوف - بموجب بطاقة الإيداع الصادرة ضده عن قاضي التحقيق المتخلي - تحت مفعول تلك البطاقة وبالتالي موقوفا على ذمة القضية المتعهد بها وإعلام المعني بالأمر بذلك القرار وإحاطة إدارة السجن بتلك الوضعية مع مراعاة المدة والتمديد عند الإقتضاء أو إيقاف مفعولها بالإفراج عنه .

وحيث وبناء على ما تقدم فقد جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون لما أقرّ قاضي التحقيق على مخالفته مقتضيات الفصلين 50 و 69 م إ ج ومساسه بمصلحة المتهم الشرعية فوقع بذلك تحت طائلة أحكام الفصل 199 م إ ج وأضحى بالتالي عرضة للنقض للأسباب السالف شرحها واتجه التصريح بنقضه مع الإحالة.

11-2-6-2 حق الدفاع لا يجب أن يكون مطية لتأخير القضية على خلاف ما يقتضيه سيرها العادي

قرار تعقيبي عدد 91195 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن الدائرة الخامسة والعشرين برئاسة السيد محمد العسكري وعضوية المستشارين السيدين نجوى الشريف ومحمد علي يمن وبمحضر المدعي العمومي السيد نور الدين الزياتي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد علي العمراوي.

« حيث نعى المعقب على محكمة القرار المنتقد عدم الإستجابة إلى طلب محامي المتهم في التأخير لإعداد وسائل الدفاع مما شكل هضما لحق الدفاع مبررا للنقض.

وحيث خلافا لما تمسك به نائب المعقب وإن كان حق الدفاع حقا مقدسا ومكفولا بموجب الأحكام الدستورية وخاصة الفصل 27 من الدستور التونسي وهو كذلك من الحقوق الطبيعية التي تعطي للشخص حقه في الثبات قبل البت في النزاع إلا أنه لا يجب أن يكون مطية لتأخير القضية على خلاف ما يقتضيه سيرها العادي.

وحيث خلافا لما تمسك به نائب المعقب وبالرجوع إلى ملف قضية الحال يتضح أن محكمة القرار المنتقد إستجابت إلى طلب المتهم في تكليف محام للدفاع عنه منذ جلسة يوم 12 أكتوبر 2018 وأعلن الأستاذ (ج) نيابته عن المتهم

وبجلسة يوم 26/12/2018 لم يحضر هذا الأخير وطلب المتهم التأخير ليتمكن نائبه من الدفاع عنه فإستجابت المحكمة لطلب التأخير وأخرت القضية لجلسة يوم 8 فيفري 2019 ثم إلى جلسة يوم 22 مارس 2019 وبها حضر الأستاذ (و) في حق الأستاذ (ج) وطلب مزيدا من التأخير لإعداد وسائل الدفاع عندها حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة وأصدرت الحكم دون تمكين نائب المتهم من طلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع.

وحيث إتضح من خلال أوراق الملف أن محكمة القرار المتقدمت مكنّت نائب المتهم من أجل معقول لإعداد وسائل الدفاع إلا أنه تخلف عن ذلك وعليه فإن التمشي الذي توجهت المحكمة لا ينطوي على أي هضم لحقوق الدفاع مما يتعين معه ردا لمطعن لعدم وجهته».

11-2-7 مشاركة القاضي في القرار الغيابي المعترض عليه

قرار تعقيبي عدد 90566 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن عن الدائرة الخامسة عشر برئاسة السيد جلال الدين بوكثيف وعضوية المستشارين السيدين عدنان الهاني ومنية عمار وبمحضر المدعي العام السيد أنيس ضيف الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة نجلاء الهمامي.

« عن المطعن الوحيد المتعلق بخرق أحكام الفصل 248 من م م ت:

حيث نعت نائبة المعقب على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الوارد بالباب السادس المتعلق بالتجريح في الأحكام والذي يحيل عليه الفصل 296 من مجلة الإجراءات الجزائية الوارد في باب التجريح في الأحكام وعليه يمكن بذلك اعتماد الفصل 248 من م م ت دون الرجوع إلى الفصول المنظمة للتجريح في الأحكام صلب مجلة الإجراءات الجزائية الممتدة من الفصل 296 إلى الفصل 304 والتي حددت الإجراءات المنظمة للتجريح من كيفية تقديمها والجهة التي يجب رفع طلب التجريح إليها والآجال المحددة لرفع الطلب وهي غير الإجراءات التي إنتهجها الطاعن الآن بإثارة مسألة مشاركة أحد مستشاري الدائرة الجنائية التي أصدرت القرار المطعون فيه في القرار في تركية الدائرة الجنائية التي أصدرت القرار الإستئنافي الغيابي المعترض عليه والذي إضمحل بموجب قبول الإعتراض من الناحية

الشكلية فضلا على عدم تضمن مجلة الإجراءات الجزائية على أي تحجير يمنع المحكمة أو الحاكم الذي شارك أو أصدر الحكم الغيابي من المشاركة أو إصدار الحكم الإعتراضي باعتبار أن الإعتراض هو في حد ذاته إعادة للمحاكمة بحضور المتهم الذي تخلف عن الحضور بسبب عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا ذلك حتى يتسنى له بتلك الوسيلة تدارك ما فاتته بالحضور لدى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض عليه وتقديم ما له من وسائل الدفاع وأدلة الإثبات لتبرئة ساحته مما قد يكون تعلق به من تهم وقعت محاكمته من أجلها بمقتضى الحكم المعارض عليه وأنه من البديهي أن يوكل النظر بمفعول الإعتراض للمحكمة المصدرة للحكم دون سواها لأنها هي المحكمة التي تعهدت أولا بالقضية.

وحيث أضحى هذا المطعن والحالة ما ذكر في غير طريقه واتجه رده «.

11-2-8 تأخير القضية مكتيبا لجلسة غير معينة يستوجب إعادة الاستدعاء

قرار تعقيبي عدد 10023 بتاريخ 24 جويلية 2020 صادر عن عن الدائرة الجزائية الصيفية برئاسة السيدة منيرة النحالي وعضوية المستشارين السيدة سامية العابد والسيدة سلوى التميمي بحضور المدعي العمومي السيد ومساعدة كاتب الجلسة السيد توفيق المناصري.

« حيث نص الفصل 141 م ا ج في فقرته الثالثة على ما يلي: «وإذا لم يحضر المظنون فيه بعد استدعائه قانونا أو لم يحضر نائبه في الصور المبينة بالفقرة الثانية أعلاه جاز للمحكمة أن لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وأن تصدر عليه حكما غيابيا اذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا، أو حكما يعتبر حضوريا اذا بلغه الاستدعاء شخصيا».

وحيث اقتضى الفصل 138 من م ا ج أنه: « اذا تأخرت القضية لجلسة معينة فلا يعاد الاستدعاء».

وحيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن المتهم الطاعن الآن سبق أن أحضر بجلسة 3 جانفي 2012 حين كان بحالة إيقاف في قضية أخرى. وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 3 فيفري 2012 لتسخير محامي للدفاع عنه. إلا انه تعذر اجراء الجلسة بالتاريخ المذكور بسبب هيجان أحد الموقوفين.

وحيث قررت المحكمة تبعا لذلك تأخير القضية على حالتها لجلسة يوم 24 فيفري 2012. إلا أن المتهم لم يحضر وتبين انه أطلق سراحه بموجب سراح شرطي كما لم تحضر نائبته المسخرة الأستاذة ح. ب. فتقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.

وحيث ولئن قررت المحكمة حل المفاوضة وتأخير القضية لجلسة يوم 17 أفريل 2012 استجابة لطلب نائبة المتهم المسخرة، الا أن ذلك لا يعفيها من ضرورة إعادة استدعاء المتهم طالما أنه لم يكن على علم بالتأخير الذي قرره مكتبيا ليوم 24 فيفري بعد أن تعذر إتمام الجلسة تطبيقا لأحكام الفصل 138 المذكور الذي يقتضي بقراءة عكسية لاحكامه أن التأخير لجلسة غير معينة يستوجب إعادة الاستدعاء.

وحيث لا شيء بأوراق الملف يفيد تولي المحكمة إعادة استدعاء المتهم ولا يمكنها والحالة تلك اصدار حكم حضوريا بالاعتبار ضده لما في ذلك من خرق للإجراءات الأساسية ومساس بمصلحة المتهم وحقه في الدفاع عن نفسه. واتجه النقص لهذا السبب».

11-2-9 تمتع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب دون أن يكون حاضرا بجلسة النطق بالحكم

قرار تعقيبي عد بتاريخ 1 جويلية 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

« حيث أن تقدير العقاب مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل التي لها التخفيف منه أو التشديد فيه أو منح تأجيل التنفيذ كلما كان ذلك وفق الشروط والضوابط المتعلقة بقواعد تطبيق سلم العقوبات دون خرق للقانون وليس لهذه المحكمة رقابة عليها إلا حينما يتم خرق تلك القواعد التي هي من القواعد الأمرة وتهم النظام العام.

وحيث نعى المعقب على القرار المطعون فيه تمتع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني رغم غياب المحكوم عليه بجلسة الحكم في خرق واضح لمقتضيات الفصل 53 م.ج.

وحيث رجوعا إلى مطروحات الملف يتبين وأن محكمة القرار المطعون فيه إرتأت توفر أركان الجريمة في حق المعقب ضده خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية وقضت غيابيا في حقه بعقوبة سجنية مع تمتيعه بتأجيل تنفيذ ذلك العقاب دون أن يكون المتهم حاضرا بجلسة النطق بالحكم.

وحيث نصت الفقرة 18 من الفصل 53 م ج على أنه: «على المحكمة عند القضاء بتأجيل التنفيذ أن تنذر المحكوم عليه بأنه لو حكم عليه من جديد في الظروف المبينة أنفا تنفذ عليه العقوبة الأولى وأن العقوبات المقررة للعود تسلط عليه».

وحيث أن الفهم الظاهري للفقرة المذكورة دون التأمل في جميع فقرات النص المذكور يحيل إلى أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ إلا عند حضور المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم وهو ما يعد فهما قاصرا عن تبين دلالات الفصل المشار إليه ضرورة وأن الأخذ به يمنع على المحكمة أن تمنح تأجيل التنفيذ إلا إذا ضمنت مثول المحكوم عليه أمامها ساعة النطق بالحكم لتحذيره مغبة العود المدة القانونية وهو ما يعني بداهة أنه لا يمكنها منح تأجيل التنفيذ إذا كان وصف الحكم حضوريا بالاعتبار أو غيابيا أو إذا كان المتهم في حالة سراح وحجزت المحكمة المنتصبة للقضاء في المادة الجناحية القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة لاحقة ولا شيء يضمن وقت إنعقادها للغرض مثوله أمامها ساعة النطق بالحكم.

وحيث أن القراءة السليمة والمنطقية لأحكام الفصل 53 م ج تخلص إلى أن منح تأجيل التنفيذ لا يقتضي بالضرورة أن يمثل المحكوم عليه أمام المحكمة ساعة النطق بحكمها ليقع إنذاره عاقبة العود المدة القانونية وإنما يكفي أن يشمل منطوق الحكم أي كان وصفه على تحذير المحكوم عليه بالتأجيل مغبة العود طالما أن الغاية من الإنذار تتحقق عند سماعه لذلك المنطوق إما وقت حضوره بجلسة النطق بالحكم إن حضر أو عند إعلامه بالحكم إذا ما صدر في حقه غيابيا أو حضوريا بالاعتبار.

وحيث وبناء على ذلك فإن بيان محكمة القرار المطعون فيه في حكمها لما حملها على التخفيف على المحكوم عليه ومنحه تأجيل التنفيذ إستنادا خاصة لثبوت نقاوة سوابقه ما يجعل قرارها سليما لا خدش فيه ولو أن وصف الحكم

كان غاييا ضرورة وأن عدم مثول المحكوم عليه ساعة النطق بالحكم لا يعيب ذلك الحكم في شيء للأسباب السالف شرحها آنفا بما يجعل الطعن خاليا من الوجهة القانونية واتجه رده تصريحا برفضه أصلا».

11-2-10 جريمة الشهادة زورا من اختصاص المحكمة الابتدائية

قرار تعقيبي عدد 96942 بتاريخ 26 أكتوبر 2020 صادر عن عن الدائرة الجزائية الثانية والعشرون برئاسة السيد رضا العرغوري وعضوية المستشارين السيدين منير وردليتو وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العام السيد محمد القمودي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سنية العبادوي.

« حيث انه رجوعا إلى الحكم المطعون فيه تبين أنه استند إلى أحكام الفصل 241 م ج التي تخصص للمتهم في جريمة الشهادة زورا نفس العقاب في الجريمة الاصلية، وبما ان جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية هي أصلا من انظار محكمة الناحية، فان الحكم المشار إليه استخلص وان إحالة النيابة العمومية قد تعلقت بجريمتين تخرجان عن أنظار المحكمة الابتدائية.

وحيث اقتضى الفصل 241 م ج المشار إليه انه «يعاقب كل من يتعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة التي هي موضوع القضية ... ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار».

وحيث من المؤكد وان المشرع اقر للمتهم بالشهادة زورا عقوبة سالبة للحرية هي السجن بنفس المدة للعقاب في الجريمة الاصلية وأخرى مالية وهي الخطية بمقدار ثلاثة آلاف دينار.

وحيث ان مقدار الخطية المخصص لجريمة الشهادة زورا يخرجها من أنظار محكمة الناحية، وكانت بذلك محكمة الدرجة الأولى قد أحسنت تطبيق القانون حين أقرت باختصاصها الحكمي بالنظر في قضية الحال كما وتطبيقا لاحكام الفصل 123 م ج سيما وان الفصل 131 من م ج في فقرته 2 ينص على أنه «واذا كانت الأفعال المرتبطة راجعة بالنظر لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها فالنظر في تلك الجريمة يكون للمحكمة الأعلى درجة».

وحيث انه على أساس ذلك فان محكمة الحكم المتقدم قد أساءت فهم النصوص القانونية المشار إليها لما قضت بالنقض لعدم الاختصاص الحكمي للنظر في الجريمتين موضوع الإحالة، الأمر الذي جعله عرضة للنقض مع الإحالة لاعادة النظر في القضية بهيئة أخرى».

11-2-11 الطعن بالتعقيب

11-2-11-1 التنقيص المنسوب لممثل النيابة العمومية على ظهر الملف في إشارة إلى تعقيب الحكم لا يمثل طعنا قانونيا طالما لم يقع تلقيه من كاتب المحكمة-قرار الضمّ غير قابل للتعقيب

قرار تعقيبي عدد 93259 بتاريخ 18 مارس 2020 صادر عن عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير.

« حيث إقتضى الفصل 262 م إ ج في فقرته الأخيرة أنه «يقع القيام بطلب تعقيب قرارات دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها».

وحيث رجوعا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يتضح أن القرار المطعون فيه قد صدر يوم 2019/4/18 بما يعني أن بداية تاريخ سريان أجل الطعن فيه بالتعقيب يكون اليوم الموالي الموافق ليوم 2019/4/19 ويكون يوم 2019/4/22 هو اليوم الرابع والأخير لتلقي مطلب الطعن.

وحيث نص الفصل 261 م إ ج في فقرته الأولى أنه: «يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

والكاتب الذي يتلقى العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا...».

وحيث أشّر مساعد الوكيل العام على ظهر الملف بأن الوكالة العامة تسجّل تعقيبيها وذلك يوم 2019/4/22 غير أن كاتب المحكمة لم يتلقى منه الطعن

ولم يحرر الوصل في تليقيه ولم يضمه بالدفاتر إلا يوم 23 / 4 / 2019 وقد وجه الوكيل العام بصفافس مكتوب إلى وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب بتاريخ 23 / 4 / 2019 تضمن أن « تقييد الطعن بدفاتر قسم التعقيب تمّ اليوم الموالي لتسجيل ممثل النيابة العمومية طعنه على ظهر الملف وأن ذلك كان مجرد سهو لا غير ».

وحيث يستروح من أحكام الفصلين 262 و 261 م إ ج أن المشرع قد أوجب على الطاعن بالتعقيب كائنا من كان أن يحضر أمام كاتب المحكمة لرفع طعنه وذلك هو الدليل القانوني الذي ترجع إليه المحكمة للحسم في ثبوت تقديم الطعن من صاحب الشأن وفي صحة ترسيمه دفعا لكل جدل قد يثار حول هذا الأمر ولا عبرة تبعا لذلك بالتنصيص المنسوب لممثل النيابة العمومية على ظهر الملف في إشارة إلى تعقيب الحكم لأن ذلك التنصيص لا يمثل طعنا قانونيا صادرا عنه في ظل عدم تلقيه من كاتب المحكمة بما يعني أن ما أشر عليه على ظهر الملف بتاريخ 22 / 4 / 2019 والمنسوب إلى ممثل الوكالة العامة بصفافس غير حري بالإعتماد ويبقى المعتمد هو تلقي طعنه من قبل كاتب المحكمة يوم 23 / 4 / 2019 الواقع منه خارج الأجل المبين بالفقرة الأخيرة من الفصل 262 م إ ج.

وحيث يكون الطعن الواقع خارج الأجل هو مؤديا حتما إلى سقوطه والمسقطات وجوبية تثيرها المحكمة وتتمسك بها من تلقاء نفسها.

وحيث أن هذا الرأي يتناغم مع ما قررته الدوائر المجتمعة بموجب قرارها عدد 420 المؤرخ في 4 / 7 / 2019.

وحيث وفضلا عن ذلك فإن القرارات القابلة للطعن بالتعقيب بحسب مقتضيات الفصل 258 م إ ج هي القرارات النهائية الصادرة في الأصل.

وحيث أن القرار المطعون فيه صدر بضم القضية عدد 22444 إلى القضية عدد 22447 التي لا تزال على بساط النشر إستنادا إلى أحكام الفصل 131.

وحيث أن القضية الواقع ضمها تصير بموجب قرار الضم ورقة من أوراق القضية المضمومة إليها عدد 22447 والتي يمكن تعقيب القرار الصادر فيها حينما يضع نهاية للإجراءات ويبت في أصل التهمة بالإحالة أو الحفظ وعليه فإن قرار الضم لا يعد قرارا نهائيا لأنه لم يضع حدا للإجراءات كما أنه لا يعد صادرا

في الأصل لأنه لم يبت في أصل التهمة وعليه فإنه لا يحوز على صفة القرار المخول الطعن فيه بالتعقيب وفق الشروط المبينة بالفصل 258 م إ ج.

وحيث وبناء على تلك الأسباب مجتمعة فإنه يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلاً.»

قرار تعقيبي عدد 93260 بتاريخ 3 جوان 2020 صادر عن عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير.

« حيث إقتضى الفصل 262 م إ ج في فقرته الأخيرة أنه: «يقع القيام بطلب تعقيب قرارات دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها».

وحيث رجوعاً إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يتضح أن القرار المطعون فيه قد صدر يوم 2019/4/18 بما يعني أن بداية تاريخ سريان أجل الطعن فيه بالتعقيب يكون في اليوم الموالي الموافق ليوم 2019/4/19 ويكون يوم 2019/4/22 هو اليوم الرابع والأخير لتلقي مطلب الطعن.

وحيث نص الفصل 261 م إ ج في فقرته الأولى أنه: «يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

والكاتب الذي يتلقى العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالاً بدفتر خاص معد للغرض ويسلم وصلاً فيها متضمناً تاريخ تقديمها ويعلم بها فوراً كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً...».

وحيث أشّر مساعد الوكيل العام على ظهر الملف بأن الوكالة العامة تسجل تعقيبيها للقرار وذلك يوم 2019/4/22 غير أن كاتب المحكمة لم يتلقى منه الطعن ولم يحرر الوصل في تلقيه ولم يضمه بالدفاتر إلا يوم 2019/4/23 وقد وجه الوكيل العام بصفاقس مكتوب إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 2019/4/23 تضمن أن: «تقييد الطعن بدفاتر قسم التعقيب تمّ

اليوم الموالي لتسجيل ممثل النيابة العمومية طعنه على ظهر الملف وأن ذلك كان مجرد سهو لا غير».

وحيث يستروح من أحكام الفصلين 262 و 261 م إ ج أن المشرع قد أوجب على الطاعن بالتعقيب كائنا من كان أن يحضر أمام كاتب المحكمة لرفع طعنه وذلك هو الدليل القانوني الذي ترجع إليه المحكمة للحسم في ثبوت تقديم الطعن من صاحب الشأن وفي صحة ترسيمه دفعا لكل جدل قد يثار حول هذا الأمر ولا عبرة تبعا لذلك بالتنصيص المنسوب لممثل النيابة العمومية على ظهر الملف في إشارة منه إلى تعقيب الحكم لأن ذلك التنصيص لا يمثل طعنا قانونيا صادرا عنه في ظل عدم تلقيه من كاتب المحكمة بما يعني أن ما أشر عليه على ظهر الملف بتاريخ 22 / 4 / 2019 والمنسوب إلى ممثل الوكالة العامة بصفاقس غير حري بالإعتماد ويبقى المعتمد هو تلقي طعنه من قبل كاتب المحكمة يوم 23 / 4 / 2019 الواقع منه خارج الأجل المبين بالفقرة الأخيرة من الفصل 262 م إ ج.

وحيث يكون الطعن الواقع خارج الأجل مؤديا حتما إلى سقوطه والمسقطات وجوبية تثيرها المحكمة وتتمسك بها من تلقاء نفسها.

وحيث أن هذا الرأي يتناغم مع ما قرره الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب بموجب قرارها عدد 420 المؤرخ في 4 / 7 / 2019.

وحيث وفضلا عن ذلك فإن القرارات القابلة للطعن بالتعقيب بحسب مقتضيات الفصل 258 م إ ج هي القرارات النهائية الصادرة في الأصل.

وحيث أن القرار المطعون فيه صدر بضم القضية عدد 22445 إلى القضية عدد 22447 التي لا تزال على بساط النشر إستنادا إلى أحكام الفصل 131 م إ ج.

وحيث أن القضية الواقع ضمها تصير بموجب قرار الضم ورقة من أوراق القضية المضمومة إليها عدد 22447 والتي يمكن تعقيب القرار الصادر فيها حينما يضع نهاية للإجراءات ويبت في أصل التهمة بالإحالة أو الحفظ وعليه فإن قرار الضم لا يعد قرارا نهائيا لأنه لم يضع حدا للإجراءات كما أنه لا يعد صادرا في الأصل لأنه لم يبت في أصل التهمة وعليه فإنه لا يحوز على صفة القرار المخول الطعن فيه بالتعقيب وفق الشروط المبينة بالفصل 258 م إ ج.

وحيث وبناء على تلك الأسباب مجتمعة فإنه يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا».

11-2-11-2 عدم استئناف النيابة للحكم الابتدائي لا يخول لها بعد ذلك الطعن بالتعقيب لانتفاء الصفة

قرار تعقيبي عدد 2335 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة السادسة والعشرين برئاسة السيد منجي شلغوم وعضوية مستشاريها السيدين عبد القادر غزال وحمادي الرحماني بمحضر المدعي العام السيد عبد الرحمان بن الحاج جلول وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني.

«حيث ولئن تضمن الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية قائمة الأشخاص المخول لهم طلب تعقيب الاحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وجعل من بينهم وكيل الجمهورية فإن مقبولية الطعن من الناحية الشكلية تظل مرتبطة بمدى توفر الصفة والمصلحة وبما إذا كان طرفا في القضية الاستئنافية. وحيث إنه من المبادئ الإجرائية الأساسية أن الطعن في الأحكام القضائية لا يُتاح إلا لمن تهمه القضية وله الصفة القانونية لذلك.

وحيث يترتب عن ذلك أن من لم يكن طرفا في الحكم لا يمكنه الطعن فيه لانتفاء الصفة لديه.

وحيث إنه من لم يكن طرفا في القرار الاستئنافي لا يحق له الطعن فيه بالتعقيب. وحيث بالرجوع إلى مظروفات الملف تبين أن النيابة العمومية لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى الجزائية وذلك بعدم تسجيل استئنافها طبق ما تقتضيه أحكام الفصل 212 م إ ج من تسجيل للطعن (على سند مستقل) وإمضاء من المستأنف عليه وما يستتبع ذلك من وجوب تضمين الطعن بالدفاتر المخصصة لذلك دون الاكتفاء بما دُون على ظهر الملف وقد وقفت المحكمة صلب أحكامها التحضيرية المتعاقبة على عدم تحقق ذلك وطالبت النيابة العمومية - دون جدوى أو استجابة - بالإدلاء ما يفيد استئنافها، بما يجعل الطعن المدعى به منعما ويحول دون اعتبار النيابة العمومية طرفا في القضية الاستئنافية وقد رضيت بما قضت به محكمة البداية لتكون قد تخلت نهائيا عن حقها في الطعن المكفول لها بموجب الفصل 210 م إ ج، بما لا يجيز لها الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي خصوصا وقد أقر نفس حكم البداية في خصوص الدعوى العامة بعدم سماعها وانحصر النزاع استئنافيا وجوبا في الجانب المدني

بين القائمين بالحق الشخصي والمستأنف ضده (المتهم المحكوم بالبراءة) بموجب استئناف القائمين بالحق الشخصي فقط، بما يجعل طعن وكيل الجمهورية بالتعقيب صادرا عن غير ذي صفة ومُختلا من الناحية الشكلية وحرىا بالرفض من هذه الناحية.

وحيث إن المبادئ والأحكام المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، ووجب على هذه المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام عملا بأحكام الفصل 269 م إ.ج.

وحيث يتجه حيز معلوم الخطية عملا بأحكام الفصل 263 م إ.ج».

11-2-11-3 عدم جواز الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة بالإدانة غاييا

قرار تعقيبي عدد 83682 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن الدائرة الثامنة والعشرون برئاسة السيد المنصف الحاج علي وعضوية المستشارين السيدين محمد رؤوف اليوسفي وريم دغدوف وبمحضر المدعي العام السيد بديع الحكيم وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد.

« حيث لا جدال في أن القواعد الإجرائية القانونية للطعن قوامها من جهة تأمين الاستقرار بإنهاء الخلاف وحسمه والوقوف به عند حد معين، ومن جهة ثانية أساسية إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لعرض أمره وما خوله المشرع أمام المحكمة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وتأمين مصلحة المجتمع، والطعن وسيلة وضعها المشرع في يد أطراف النزاع ليلجأ إليها من يشعر بأن الحكم الذي صدر في الدعوى مشوب بخطأ يجب تصحيحه أو أنه مبني على أسس غير سليمة يجب معها تعديله أو إلغائه.

وحيث خول المشرع بمقتضى أحكام الفصل 258 م إ.ج الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها.

وحيث بمراجعة ظروفات الملف يتضح أن القرار المنتقد حكما غاييا غير بات اعتبارا وأن المحكوم عليه المعقب ضده أجاز له القانون الإعتراض عليه طبق أحكام الفصل 175 وما بعده من م إ.ج وقد إستقر فقه القضاء على عدم جواز الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة بالإدانة غاييا لأن المعقب ضده سيحرم من درجة في التقاضي وسيوافقه مقتضيات حكم غايبي تنفيذا نهائيا دون أن تكون

له الإمكانية القانونية في مراجعة أصل الحكم مما يعد مساً من مصلحة المتهم الشرعية.

وحيث بات تبعا لذلك طعن الإدارة مخالفا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج وماسا بالنظام العام لتعلقها بمصلحة المتهم الشرعية وعليه يتجه رفض هذا المطعن شكلا».

قرار تعقيبي عدد 83696 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن الدائرة الثامنة والعشرون برئاسة السيد المنصف الحاج علي وعضوية المستشارين السيدين محمد رؤوف اليوسفي وريم دغدوف وبمحضر المدعي العام السيد بديع الحكيم وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد.

«حيث لا جدال في أن القواعد الإجرائية القانونية للطعن قوامها من جهة تأمين الإستقرار بإنهاء الخلاف وحسمه والوقوف به عند حد معين، ومن جهة ثانية أساسية إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لعرض أمره وما خوله المشرع أمام المحكمة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وتأمين مصلحة المجتمع، والطعن وسيلة وضعها المشرع في يد أطراف النزاع ليلجأ إليها من يشعر بأن الحكم الذي صدر في الدعوى مشوب بخطأ يجب تصحيحه أو أنه مبني على أسس غير سليمة يجب معها تعديله أو إلغائه.

وحيث خول المشرع بمقتضى أحكام الفصل 258 م إ ج الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها.

وحيث بمراجعة مظروفات الملف يتضح أن القرار المنتقد حكما غاييا غير بات اعتبارا وأن المحكوم عليه المعقب ضده أجاز له القانون الاعتراض عليه طبق أحكام الفصل 175 وما بعده من م إ ج وقد إستقر فقه القضاء على عدم جواز الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة بالإدانة غاييا لأن المعقب ضده سيحرم من درجة في التقاضي وسيواجه مقتضيات حكم غيابي تنفيذا نهائيا دون أن تكون له الإمكانية القانونية في مراجعة أصل الحكم مما يعد مساً من مصلحة المتهم الشرعية.

وحيث بات تبعا لذلك طعن الإدارة مخالفا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج وماسا بالنظام العام لتعلقها بمصلحة المتهم الشرعية وعليه يتجه رفض هذا المطعن شكلا».

11-2-11-4 تعقيب الوكيل العام - إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب

قرار تعقيبي عدد 84177 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن الدائرة الثامنة والعشرون برئاسة السيد المنصف الحاج علي وعضوية المستشارين السيدين صلاح الشياحي ومحمد رؤوف اليوسفي وبمحضر ممثل الإدعاء العام السيد بديع الحكيم وبمساعدة كاتب الجلسة السيد أحمد عبيد.

«حيث إقتضى الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محامي إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه والكاتب الذي تسلم العريضة (...) يعلم بها فوراً كتابة محكمة التعقيب كتابة محكمة التعقيب (...) والمعقب ضده.

وحيث يفهم من النص القانوني المذكور أن المشرع حرصاً منه على إحاطة الدعوى الجزائية بالضمانات الضرورية لتحقيق العدالة ومنعاً للتعسف عليها أو الحد منها فرض على الوكيل العام بصفته الطرف المعقب واجب إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته بالبراءة وذلك حتى يكون على علم بالإجراءات المتخذة ضده وحتى يتمكن من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها للمحكمة قبل موعداً لجلسة.

وحيث ولئن إقتصرت المشرع على التنصيص على واجب الإعلام دون ترتيب الأثر القانوني الناتج عن عدم إحترامه له فإنه لا خلاف في كون جزاء الإخلال بذلك الإجراء هو سقوط الحق في الطعن الذي يجد سنده في الصيغة الإلزامية لعبارات الفصل 261 المذكور وكذلك في مقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي نص على أنه تبطل جميع الأعمال والأحكام المنافية للنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.

وحيث إستقر فقه قضاء محكمة التعقيب (تع ج 54063 بتاريخ 21/06/1994) (تع ج 7966 بتاريخ 12/04/1971) (تع ج 53183 بتاريخ 23/09/2010) (تع ج 31151 بتاريخ 12/03/2003) (تع ج 2189 بتاريخ 12/10/2005) على أن إستدعاء المتهم للجلسة وإعلامه بموعدها يعتبر من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن عدم إحترامها ضرر مباشر يتمثل في عدم مواجهته بما هو منسوب إليه وحقه في الإستعانة بمن يدافع عنه وحقه في

مناقشة الأدلة المقدمة ضده من قبل سلطة الاتهام وغيرها من الحقوق التي كفلتها الدساتير والتشريعات الجزائية الحديثة حتى لا يقع التعسف على حقوق الدفاع التي تعتبر ضماناً أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة وإحدى أهم المبادئ السامية التي تقوم عليها فلسفة العدالة الجزائية.

وحيث أن التمشي المذكور يجد سنده كذلك في مقتضيات الفصل 108 من الدستور الذي نصّ على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة يكون حق الدفاع فيه مضموناً.

وحيث لا خلاف في كون تعقيب الوكيل العام للحكم القاضي ببراءة المتهم دون إعلامه بذلك الإجراء يترتب عنه إنعقاد جلسة المحاكمة في غيابه والحال أنه طرف أساسي في الدعوى الجزائية باعتباره يحمل الجزء الأكبر من الحقيقة القانونية والقضائية في حين أن صفة الاتهام التي وجهتها له النيابة العمومية تلحق الإنسان بصفة طارئة ووقتيّة ويوصف بها الشخص بمجرد توفر الأدلة الظاهرة والسطحية وهو ما من شأنه أن يمس من ضمانات المحاكمة العادلة كيفما نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية سنة 1966 ووضعت لها معايير تفصيلية تمثلت بالأساس في ضرورة إعلام المتهم بطبيعة التهمة الموجهة إليه وضرورة إعطائه من الوقت والتسهيلات ما يكفي لإعداد وسائل دفاعه.

وحيث يستخلص من جميع ما تقدم أن تخلف الوكيل العام عن إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته والقاضي ببراءته من جملة التهم المنسوبة له يمس بحقوق المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة وينجر عنه بسقوط الطعن».

11-2-12 سقوط العقاب بمرور الزمن في جنحة إستهلاك مادة مخدرة مدرجة هو عشرة سنوات

قرار تعقيبي عدد 89988 بتاريخ 5 فيفري 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين ماهر كنو وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة منيرة المانعي.

« حيث يتضح من القرار المنتقد أن المحكمة التي أصدرته إعتمدت الفترة الفاصلة بين تاريخ محضر الإعلام بالقرار الجنائي الغيابي وتاريخ تسجيل المعقب ضده إعتراضه على ذلك القرار للقول برفض الإعتراض شكلاً لوقوعه خارج آجال سقوط العقاب إستناداً إلى مقتضيات الفصلين 349 و350 من م.إ.ج. وحيث رجوعاً إلى ما له أصل ثابت بالملف يتضح أن المعقب ضده أحيل من أجل جريمة إستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» طبق الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992.

وحيث أن آجال سقوط العقاب في تلك الجريمة لا تخضع للقواعد العامة الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية كيفما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد وإنما تحكمها مقتضيات قانون الإحالة الذي أورد بالفصل 13 فقرة 2 منه أنه « ويسقط العقاب المحكوم به بمرور عشرة أعوام بالنسبة للجنة وبمرور عشرين عاماً بالنسبة للجناية وفق هذا القانون ».

وحيث أن المدة الفاصلة بين تاريخ محضر الإعلام بالحكم الإستثنائي الغيابي في 7/8/2010 وتاريخ تسجيل المعقب ضده إعتراضه على ذلك الحكم يوم 21/11/2018 لم تبلغ العشرة أعوام المنصوص عليها بالفصل 13 السالف الذكر للقول بسقوط العقاب بمرور الزمن وأن محكمة القرار المنتقد لما إعتبرت أن العقاب قد سقط بمرور الزمن عملاً بمقتضيات الفصل 349 من م.إ.ج وتغافلت عن النص القانوني الخاص تكون قد خالفت القانون مما يجعل قرارها عرضة للنقض ».

11-2-13 استجلاب القضية

11-2-13-1 الإستجلاب هو إجراء استثنائي لا يُتوسّع في تطبيقه

قرار تعقيبي عدد 767 بتاريخ 31 أوت 2020 صادر عن عن الدائرة الصيفية برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين ماهر كنو وتوفيق سويدي بحضور المدعي العام السيد لطفي البدوي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

« حيث إن انتزاع القضايا بطريق الإستجلاب من المحاكم المختصة بالنظر فيها وإحالتها على محاكم أخرى مماثلة لها على معنى أحكام الفصل 294 من

مجلة الإجراءات الجزائية هو إجراء استثنائي لا يلتجأ إليه إلا عند الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا مع وجوب توفر أحد السببين اللذين فرضهما ذلك النص القانوني وأولهما الحفاظ على الأمن العام وثانيهما دفع الشبهة الجائزة عن القضاة.

وحيث طالما كان ذلك الإجراء استثنائياً فإن الإستثناء لا يتوسّع فيه لأن مبناه التضييق وليس التوسع، وعليه وجب الوقوف على مدى توفر أحد الشرطين المذكورين بنص الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية بصورة لا لبس فيها حتى يتم إعمال مقتضياته.

وحيث إن الشرط الأول غير متوفر في قضية الحال وقد كان سبب طلب الإستجلاب مستنداً إلى ما تراءى للطالب من وجود شبهة جعلته لا يرتاح لقضاء المحكمة المتعہدة وقد تولدت له إسناد عدد ثان للملف وعدم إعلامه بقرار دائرة الاتهام.

وحيث إن تقييم ذلك واعتباره من قبيل الشبهة أمر لا سند له ذلك أن التأخير في البت في القضية ومراوحتها بين جهة قضائية وأخرى كان مردّه الإجهاد في تأويل لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2016، وقد تبين من مطروقات ملف القضية إدارة هيئة المحكمة للملف بصورة لا يظهر منها ما يوحي بانحراف في الإجراءات أو خروج عن الحياد والنزاهة، ولذلك فإن الشبهة الجائزة لا دليل عليها بما لا يصح معه القول بجواز انتزاع الملف من المحكمة المتعہدة طالما أن الأمر على ما ذكر. وحيث طالما لم تتوفر أسباب الإستجلاب فإنه يتعيّن التصريح برفض المطلب «.

11-2-13-1 تعريف الشبهة الجائزة

قرار تعقيبي عدد 0889 بتاريخ 26 فيفري 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

« حيث نص الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية أن « لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات

بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة».

وحيث أن الشبهة الجائزة (سبب تقديم المطلب الحالي) على معنى الفصل 294 م إ ج إنما هي إعتقاد المتقاضي لأسباب صحيحة أو خاطئة أن سير الأبحاث التحقيقية أو سير القضية لن يكون سيرا طبيعيا عاديا يضمن المحاكمة العادلة نظرا لنفوذ خصمه أو تدخلاته مما يبعث في نفس المتقاضي شعورا بعدم الإطمئنان والريبة من إمكانية معاملة خصمه معاملة خاصة قد تضر بمصلحة الشريعة.

وحيث كان سبب طلب الإستجلاب مستندا إلى ما تراء للطالبة من وجود شبهة جعلتها لا تترتاح لقضاء المحكمة المتعدهدة بدءا من النيابة العمومية التي إستبعدت من الأبحاث الخبير المشتكى به وانتهت إلى حفظ الشكاية لعدم كفاية الحجة وتخلي قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عن القضية بموجب التجريح في نفسه وكذلك توقف قلم التحقيق بالمكتب الثالث المتعهد بالموضوع على مجرد سماع القائم على المسؤولية الخاصة وإستنطاق الخبير العدلي المشتكى به ووجود علاقات صداقة قوية بين هذا الأخير وعدة قضاة بتلك المحكمة على شبكات التواصل الإجتماعي.

وحيث إن ذلك الطلب قد وجد سنداً له في تقرير السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببزرت المؤرخ في 8 / 11 / 2019 الذي يحيل إلى توفر الشبهة الجائزة فضلا على ما تبين من مظروفات ملف القضية من وجود تراخ في إنجاز أعمال التحقيق المطلوبة بالسرعة المعهودة والذي أرجعته الطالبة للإرتباط المهني بين المشتكى به وقضاة المحكمة بما يوحي بالخروج عن الحياد والنزاهة والمعاملة المتساوية بين المتقاضين وعدم إطمئنان الشاكية عن السير الطبيعي للقضية .

وحيث وبصرف النظر عن جدية دفعات الطالبة فإنه حفاظا على هيبة القضاء وعدالته ونبل رسالته وتجنباً للخدش في نزاهة القضاء وحياده وعدله ولو بشبهات محتملة وغير ثابتة ورفعاً لكل حرج عن قضاة المحكمة المراد إنتزاع الملف منها فإنه يكون من الوجيه دفعا لكل شبهة جائزة إستجلاب القضية موضوع الطلب وإحالة ملفها على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتعهد احد قضاة التحقيق بالمحكمة المذكورة بموضوعها .

11-2-14 التمييز بين محضر الحجز ومحضر ضبط الوزن وبيان نوع المادة
المحجوزة

قرار تعقيبي عدد 97846 بتاريخ 24 جوان 2020 صادر عن عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«وحيث تضمنت أسانيد القرار المطعون فيه نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى لبطلان إجراءات التتبع قولاً بأنه ولئن تم حجز كمية من مسحوق أبيض عن المتهم يشتبه في كونها مخدر الكوكايين إلا أن باحث البداية تخلف عن تحرير محضر حجز على معنى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992 المتعلق بالمخدرات والذي يجب أن يضبط فيه وزن الكمية المحجوزة وبيان نوعها في خرق لنصوص تهم النظام العام بما يجعل الإجراءات المقامة بدونه والمستند إليها من إختبارات وتحاليل مخبرية واستنتاجات ومكافحات وتتبع ومحاكمة باطللة قانونا عملاً بأحكام الفصل 199 م.إ.ج.

وحيث وخلافا لما ذهب إليه محكمة القرار المنتقد فإن القول بعدم سماع الدعوى يقتضي أن المحكمة قد نظرت في أصل الموضوع وقالت كلمتها في أن الفعلة لا تكون جريمة أو أنه لا يمكن نسبتها للمتهم أو أنها غير ثابتة في حقه بالحجة والدليل وفق أحكام الفصل 170 م.إ.ج. أما القول بعدم سماع الدعوى لبطلان إجراءات التتبع فذاك تعليل غير سليم للحكم على اعتبار وأن الجريمة في حد ذاتها لم تكن محل نظر المحكمة نفياً أو إثباتاً وإنما تم ردّ الدعوى العمومية للسبب المذكور إستناداً للفصل 199 م.إ.ج وعليه فإن صياغة أسانيد القرار على تلك الصورة قد أوقع المحكمة في إساءة التعليل ومخالفة مقتضيات الفصل 168 م.إ.ج.

وحيث ومن جهة أخرى فقد إعتبرت محكمة القرار المطعون فيه أن باحث البداية قد تخلف عن تحرير محضر حجز على معنى الفصل 26 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992 المتعلق بالمخدرات في خلط

واضح منها بين محضر الحجز الوارد به أحكام الفصل 25 من ذات القانون والذي تضمن ما نصه « تحجز جميع المواد المخدرة وتحرر فيها قائمة بمحضر ذي الشبهة وتحال عينة منها على الأقل على مخابر التحاليل المختصة التابعة للمؤسسات العمومية دون سواها لمعرفة محتواها وعناصر تركيبها» وبين محضر ضبط الوزن وبيان نوع المادة المحجوزة الوارد به مقتضيات الفصل 26 من ذلك القانون التي نصت على أن « جميع المواد المخدرة الواقع حجزها يحرر فيها محضر لضبط وزنها وبيان نوعها وتؤخذ منها كمية كافية لتوضع على ذمة المحكمة المتعھدة بالقضية ...»

وحيث رجوعا لما له أصل ثابت بأوراق الملف يتبين وأن باحث البداية باشر إجراءات الإستدلال والضبط في إحدى حالات التلبس وأدرك جريمة ظاهرة بحواسه كما أدرك توابعها حينما فتش المعقب ضده فعثر تحت طيات ثيابه على كمية من مسحوق أبيض اللون يشتبه في أنه مادة الكوكايين المخدرة واشتبه لذلك في إرتكاب المظنون فيه لجريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» بنية الإتجار فيها وحرر محضر الحجز عدد 17-3-18 بتاريخ 21 / 2 / 2018 الذي يعد من أهم الأدلة على قيام تلك الجريمة وغني عن البيان أن الجريمة المذكورة تعد جريمة مستمرة طالما إستمرت حيازة الجاني لتلك المادة بنية تحقيق غنم مادي من ورائها ومتى تم الكشف عنها فإن مرتكبها يعد متلبسا على معنى أحكام الفصل 33 أولا م إ ج ويراد بالتلبس هنا التعاصر أو التقارب بين زمن إرتكاب الجريمة وزمن إكتشافها وجمع أدلتها.

وحيث أن ذلك المحضر في الحجز وفور تحريره قد جعل المحجوز على ذمة العدالة وأثبت مصدره ونسبته للمحجوز عنه ودقق وصفه وهو ما يتفق مع مقتضيات الفصل 25 من القانون عدد 52 لسنة 1992 ويعتمد حجة على معنى الفصل 155 م إ ج لكونه جاء من الوجهة الشكلية محررا طبقا للقانون. أما الوقوف على وزن ونوع المادة المخدرة فإنه يعقب بالضرورة عملية الحجز لأن ذلك لا يكون إلا بإحالة عينة منها على مخابر التحاليل المختصة التابعة للمؤسسات العمومية وهو ما تم إحترامه من قبل الباحث بموجب المحضر عدد 340 المؤرخ في 21 / 2 / 2018 والمضمن صلبه ضبطا دقيقا لوزن المحجوز من قبل مصلحة الإختبارات والتحليل بإدارة الشرطة الفنية والعلمية يوم 22 / 2 / 2018 ثم

أعقب ذلك بيان لنوع المادة المحجوزة والجدول الذي تنتمي إليه بموجب نتيجة التحليل المبينة صلب تقرير تلك المصلحة المؤرخ في 23 / 2 / 2018 والذي يعد متما لذلك المحضر وأحد ملحقاته في إحترام لمقتضيات الفصل 26 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.

وحيث أن حسن النهايات من حسن البدايات وعليه فإن الأعمال الإجرائية محكمة من حيث صحتها بالمقدمات وقد كانت المقدمة (محضر الحجز ومحضر ضبط الوزن ونوع المحجوز) صحيحة ولم تكن باطلة حتى تكون النتيجة هي البطلان كما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد التي أساءت التعليل كما أساءت تطبيق القانون فعرضت قرارها للنقض وتعين لذلك التصريح بنقضه مع الإحالة».

11-2-15 حالات الإختصاص الترابي وردت على وجه الحصر دون ترتيب ولا أولوية

قرار تعقيبي عدد 83187 بتاريخ 3 مارس 2020 صادر عن الدائرة العشرين برئاسة السيد المنذر اللومي والمستشارين السيدين عادل بوصفارة وهناء سحنون بمحضر المدعي العام السيدة لمياء بن إسماعيل وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

«حيث عالج المشرّع الإختصاص الترابي بموجب أحكام الفصل 129 من م إ ج الذي نصّ على أنه تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي أرتكبت فيها أو محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه أو المكان الذي به محل إقامته الأخير أو محكمة المكان الذي وجد فيه وعلى المحكمة التي تعهدت أولا بالقضية أن تبث فيها.

وحيث تجد الإشارة إلى أن المسألة تعلقت بإجراءات تمس بالإختصاص الترابي حسب الحالات التي ذكرت بالفصل على وجه الحصر لا المثال وبالتالي يستبان أن الإختصاص الترابي وقع حصره دون ترتيب ولا أولوية في مكان إرتكاب الجرم أو مقر المظنون فيه أو آخر مقر له أو المكان الذي وجد به بما يعني أن تحقق حالة من الحالات المذكورة تكون المحكمة المختصة هي من تحقق لديها أحد الحالات الواقع التنصيب عليها سابقا وأنه بقضية الحال إتضح أن

الركن المادي لموضوع جريمة قضية الحال وهو إستخلاص دين مرتين أن المتهم المعقب ضده قام بإجراءات إستخلاص معين الصك البنكي عدد 00689196 المسحوب بتاريخ 18/9/2009 على حساب الشاكي المفتوح بالبنك الوطني الفلاحي فرع جندوبة وذلك على إثر إستخلاص نفس المتهم لمعين الصك البنكي عدد 00689196 المؤرخ في 10/07/2008 وبالتالي فإن تقديم الصك الثاني المكون لجريمة إستخلاص دين مرتين تم بفرع البنك الوطني بجندوبة وهو ما حدى بالمعقب ضده إلى إستصدار أمر بالدفع لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة وبالتالي فإن الأعمال المادية المكونة لجريمة الإحالة تمت جميعها بجندوبة وأن المحكمة الابتدائية بجندوبة تولت النظر في القضية طبق الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 129 من م إ ج وبالتالي كان تعهدها وقضائها إجرائيا متطابقا للقانون وبالتالي فإن محكمة الحكم المتتقد بتوجهها المذكور تكون قد أساءت تطبيق أحكام الفصل 129 من م إ ج وعرضت قضاءها للنقض.

وحيث أفلح الطاعن القائم بالحق الشخصي في طعنه واتجه تبعا لذلك إعفاء من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م إ ج».

11-2-16 الحكم بعدم سماع الدعوى لإتصال القضاء هو منطوق مغلوطة للحكم

قرار تعقيبي عدد 90034 بتاريخ 4 نوفمبر 2020 صادر عن عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغري وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

« حيث أن إتصال القضاء يقتضي إتحاد الموضوع والسبب والأطراف بعين الصفة السابقة لهؤلاء وأن يكون الحكم المستند إليه باتا مستوفيا لجميع طرق الطعن.

وحيث وخلافا لما ذهبت إليه محكمة القرار المتتقد فإن القول بعدم سماع الدعوى يقتضي أن المحكمة قد نظرت في أصل الموضوع وقالت كلمتها في أن الفعلة لا تكون جريمة أو أنه لا يمكن نسبتها للمتهم أو أنها غير ثابتة في حقه بالحجة والدليل وفقا لأحكام الفصل 170 من م إ ج. أما القول بعدم سماع

الدعوى لإتصال القضاء بالموضوع فهو منطوق مغلوطة للحكم على اعتبار أن الجريمة في حد ذاتها لم تكن محل نظر المحكمة نفيًا أو إثباتًا وإنما تم ردّ الدعوى العمومية لإنقضائها بموجب أحد الأسباب المحددة بالفصل 4 من م إ ج ، وعليه فإن صياغة الحكم على تلك الصورة جاء مخالفا للقانون».

11-2-17 مفهوم المستندات الواقعية والقانونية للحكم

قرار تعقيبي عدد 90885 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن عن الدائرة السابعة والعشرون برئاسة السيد عادل الأندلسي وعضوية المستشارين السيدين بلقاسم كعوان ومحمد بن مفتاح وبمحضر المدعي العام السيدة هندة الكتاري وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سميرة بوشوشة.

« حيث أسست محكمة الحكم المطعون فيه حكمها على اعتبار أن نقل المعقب ضده للمتضررة بواسطة شاحنته كان تحت إرادة مسلوقة بما ينفي عنه الركن المادي لجريمة تحويل وجهة شخص بإستعمال العنف.

وحيث ألزم الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية قاضي الموضوع على ذكر المستندات الواقعية والقانونية للحكم.

وحيث أن المستند هو الدعامة التي ينهض عليها الحكم ومنها يستمد قوته وعنهما تنتج آثاره فيكون مقبولا بين المتخاصمين مدنيا أو المحكومين والمدعين جزائيا ويرضون بنتيجته التي من شأنها أن تظهر حقوقا أو تعمر ذمما أو تمس من حريات الأشخاص أو تنال من أموالهم أو تحد من حقوقهم المدنية أو تؤذي سمعتهم وعلى ذلك الأساس يكتسي المستند سواء قانونيا أو واقعا أهمية قصوى في لائحة الحكم رغم أن المشرع لم يوضح بشكل جلي مفهوم المستندات بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بعملية تحليل وإستنتاج بإستعمال الأدوات القانونية لوقائع وأدلة تعرض على القاضي.

وحيث أن الواقعة في القانون الجنائي تشمل الحدث المادي الذي ينتج عن الفعل البشري المرتبط بالسياق العام الذي يقع فيه أي ما سبقه من أحداث وما تزامن معه وما تلاه والحوادث التي تطرأ في الأثناء وقاضي الموضوع محمول على تحليل الوقائع الثابتة بالأدلة المعروض عليه وهو ملزم بتحليل أجزائها الرئيسية والفرعية على حد سواء وفق قواعد المنطق السليم .

وحيث أن محكمة التعقيب وإن كانت رقابتها لا تمتد إلى أصل الوقائع أي أنها لا تعالج الوقائع كموضوع أصلي يطرح عليها للتداول فيه إثباتاً أو نفيًا وإنما تمتد رقابتها إلى التحقق من إلزام قاضي الموضوع بالوقائع التي عرضت عليه وعدم تغييره لها أو تحليلها خارج السياق الزمني والإطار المكاني الذي جرت فيه أو ترتيب نتائج مغايرة للنتائج المنطقية...».

11-2-18 اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها

قرار تعقيبي عدد 01201 بتاريخ 29 جانفي 2020 صادر عن الدائرة الرابعة عشر برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل ومستشاريها السيدان العقيد قاضي نورة الامام وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العام السيد عادل الغالي ومساعدة كاتب الجلسة السيد علي العمراوي.

« حيث انحصر الاشكال في تحديد مرجع النظر الحكمي بالنظر في قضية الحال وقد دفعت الاجابة إلى تنازع سلبي بين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف وقاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بباجة، وقد صدرت عنهما قرارات أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء وتعطل سير العدالة وهو ما استوجب تدخل هذه المحكمة للحسم في التنازع المشار إليه اعمالاً لاحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية.

وحيث كان القرار الصادر عن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بباجة تضمن التخلي عن القضية لفائدة القضاء العسكري لعدم الاختصاص الحكمي مستندا في ذلك إلى أحكام الفصل 5 من م م ع في فقرته السابعة.

وحيث اقتضت أحكام الفصل 5 فقرة 7 م م ع المشار إليه إلى ان المحاكم العسكرية تختص بالنظر في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها، ويفهم من النص المشار إليه ان تلك الجرائم المرتكبة من مدنيين وضد عسكريين لا تدخل ضمن نطاق الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري الا في احدى الحالتين وهو ان تكون تلك الجرائم حاصلة أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.

وحيث لئن كانت الحالة الاولى المتمثلة في مباشرة الخدمة غير مطروحة في قضية الحال باعتبار وأن وقائع قضية الحال جددت قبل انتهاء حصة راحة العسكريين وخارج الثكنة العسكرية، فانه من اللازم التوضيح وان الصورة الثانية لانعقاد اختصاص المحاكم العسكرية والمتمثلة في حصول الاعتداء على العسكري بمناسبة مباشرته للخدمة، المقصود منها كل الجرائم الواقعة ضد العسكريين والتي كانت دوافع وملازمات ارتكابها مرتبطة بمهام وخدمة المعتدى عليه العسكرية بحيث لم تكن لتسلط عليه لولا وظيفته ومهامه العسكرية.

وحيث وترتبا على ذلك فانه بالنظر إلى ان ما تسلط على العسكريين المتضررين في قضية الحال من اعتداء لم يكن قد طالهم أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها فان الاختصاص بالنظر في القضية لا يرجع إلى القضاء العسكري، ووضحت بذلك قضية الحال من اختصاص القضاء العدلي تطبيقا لاحكام الفصل 5 من م م ع المشار إليه .

وحيث اقتضى الفصل 199 من م ا ج انه: « تبطل كل الاعمال والاحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية ، والحكم الذي يصدر بالبطلان يعين نطاق مرماه».

وحيث وان قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة هو قرار باطل لمخالفته لقواعد الاختصاص التي تهم النظام العام بما جعله عرضة للابطال مع ارجاع ملف القضية إلى السيد وكيل الجمهورية بذات المحكمة للتعهد وفتح بحث فيها مجددا بواسطة قاضي تحقيق اخر».

11-2-19 عدم الإعلام بالحكم المعبر حضوري يجعل أجل الاستئناف مفتوحا
قرار تعقيبي عدد 82525 بتاريخ 18 فيفري 2020 صادر عن الدائرة العشرين برئاسة السيد المنذر اللومي والمستشارين السيدين عادل بوصفارة وهناء سحنون بمحضر المدعي العام السيدة لمياء بن اسماعيل وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العتير .

« حيث خلافا لما انتهجته محكمة الحكم المتقدم فان حكم البداية كان صدر معتبرا حضوريا ولم يتم اعلام المتهم به طبق ما يقتضيه القانون وبالتالي فقد ظل أجل الاستئناف مفتوحا في حقه ولا يمكن بالتالي اعتبار أجل الاستئناف الذي

سجل بموجبه قد سقط بتجاوز العشرة أيام من تاريخ صدوره عليه اعتبارا من أن ذلك التاريخ لا يسري إلا على الاحكام الحضورية فقط وبالتالي فقد ظل الحكم المنتقد مسيئا لتطبيق القانون موجبا للنقض».

11-2-20 يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته لا يضطر من يطلع عليه إلى الإعتماد على أية وثيقة أخرى خارجة عنه لفهم النزاع ووجه الفصل فيه

قرار تعقيبي عدد 99369 بتاريخ 1 جويلية 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة منيرة المانعي .

« حيث أوجب الفصل 168 من م إ ج أن يذكر بكل حكم المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة ونص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة والنصوص الزجرية الواقع تطبيقها.

وحيث يتضح من صيغة النص المذكور أن الحكم يجب أن يكون مكتفيا بذاته في وقائعه شاملا لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته فلا يضطر من يطلع عليه إلى الإعتماد على أية وثيقة أخرى خارجة عنه لفهم النزاع ووجه الفصل فيه خاصة إذا إقتضى الأمر الإحتجاج به في خصومة معينة أو الدفع بإتصال القضاء أو غيره وبشكل يمكن محكمة القانون من بسط رقبتها على سلامة الحكم وما إذا كان قاضي الموضوع قد فصل في جميع المسائل محل نظره دون تحريف واستخلص النتيجة القانونية السليمة من الوقائع المعروضة عليه .

وحيث بتصفح القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يتضمن في باب المستندات الواقعية أية إشارة إلى المستأنف ضده وإنما تعلقت تلك المستندات بغيره المشمولين بالقضية فلم يكن يفهم منها ما نسب للمستأنف ضده من أفعال أما المستندات القانونية فهي مفقودة أصلا وما جاء بابها وبمنطوق الحكم المضمن باللائحة إنما يتعلق بقرار مدني شغلي لا علاقة له بملف قضية الحال وكذلك الشأن بالنسبة للمنطوق المضمن باللائحة في مخالفة تامة لما هو مضمن بمحضر الجلسة ولم يرد بتلك اللائحة أي بيان أو تعليل لما توصلت إليه المحكمة صلب منطوق حكمها الوارد بمحضر الجلسة حتى تتمكن هذه المحكمة من إجراء

رقابتها القانونية على مدى حسن تطبيق القانون فيكون بذلك قرارها والأمر على ما ذكر خال من واجب التعليل خارجا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج ومستوجبا للنقض».

11-2-21 محاكمة المواطن التونسي الذي ارتكب جريمة خارج التراب التونسي - مجرد التتبع في البلد المرتكبة فيه الجريمة لا ينزع الاختصاص عن المحاكم التونسية

قرار تعقيبي عدد 82230 / 82198 بتاريخ 17 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرين برئاسة السيد رياض الامام وعضوية المستشارين السيد شكري كمون والسيدة سامية العابد بحضور المدعي العام السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير .

« حيث اقتضى الفصل 305 م إ ج أنه يمكن تتبع ومحاكمة المواطن التونسي من طرف المحاكم التونسية اذا ارتكب خارج تراب الجمهورية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونسي الا اذا تبين أن قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا يعاقب عليها أو أثبت المتهم أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج وفي صورة صدور الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقاب المحكوم به عليه أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو .

وحيث يتضح من أحكام الفصل أعلاه أن التمسك فقط بحصول التتبع في البلد المرتكبة فيه الجريمة موضوع قضية الحال لا ينزع الاختصاص عن المحاكم التونسية التي تظل صاحبة النظر طالما لم يقدم الطاعن ما يفيد توفر حالة من حالات عدم التتبع المنصوص عليها صلب الفصل المذكور . واتجه رد هذا المطعن لعدم وجاهته».

11-2-22 نسخة الحكم

11-2-22-1 خلو نسخة الحكم من حرفة المتهم والسوابق العدلية وموضوع التهمة

قرار تعقيبي عدد 82078 بتاريخ 18 فيفري 2020 صادر عن الدائرة العشرين برئاسة السيد المنذر اللومي وعضوية المستشارين السيدين عادل بوصفارة وهناء

سحنون بمحضر المدعي العام السيدة لمياء بن اسماعيل وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير .

« عن الطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 168 من م ا ج على اعتبار أن الحكم المنتقد كان خاليا من ذكر حرفة المتهمين وسوابقهم العدلية كذكر موضوع التهمة: حيث أن تخلف المحكمة عن التنصيص على حرفة المتهمين وسوابقهم العدلية وذكر التهمة الواقع احالتهم على المحكمة لا يمكن أن ينجر عنه البطلان اعتبارا من كون البيانات المذكورة لا يمكن أن تشكل سببا مباشرا في وجهة الحكم الصادر في حق المتهمين فالحرفة لا تنقص شيئا في وجهة المحكمة عند اعمالها لاجتهادها عند تعليل الحكم وأن السوابق تكون مضررة بملف القضية لإعمالها في تقدير العقوبة لا لتضمينها بنسخة الحكم المنتقد وأن ذكر التهمة الموجهة هو قرار مضمن بقرار ممثل النيابة العمومية ومضافا بنسخة الحكم الابتدائي مناط الطعن بالاستئناف وكانت المحكمة على علم به ونظرت في القضية على ضوءه وبالتالي فإن عدم التنصيص على ما ذكر لا يمكن أن يؤثر على مجرى القضية وبالتالي فقد ظل هذا المطعن واهيا واتجه تبعا لذلك رده» .

قرار تعقيبي عدد 90801 بتاريخ 10 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرون برئاسة السيد رياض الإمام وعضوية المستشارين السيدة سامية العابد والسيد سامي الداهش وبحضور المدعي العمومي السيد كريم المهدي ومساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير .

« حيث أن الدفع المتعلق بعدم ذكر حرفة المظنون فيه وسوابقه العدلية صلب القرار المطعون فيه هو دفع في غير طريقه ولا يوهن القرار المطعون فيه الذي تضمن الاسم الرباعي للمظنون فيه واسم والدته وتاريخ ولادته ومقر اقامته وهي معطيات كفيلة بالتعريف به وتمييزه عن غيره بدون أي لبس وتعين الالتفات عن هذا الدفع لعدم جديته» .

قرار تعقيبي عدد 81681 89668- بتاريخ 17 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرون برئاسة السيد رياض الإمام وعضوية المستشارين السيد شكري كمون والسيدة سامية العابد وبحضور المدعي العمومي السيد كريم المهدي ومساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير .

« حيث أن الدفع المتعلق بعدم ذكر السوابق العدلية للمظنون فيه صلب القرار المطعون فيه هو دفع في غير طريقه ولا يوهن القرار المطعون فيه الذي تضمن الاسم الرباعي للمظنون فيه واسم والدته وتاريخ ولادته ومقر اقامته وحرفته وهي معطيات كفيفة بالتعريف به وتمييزه عن غيره بدون أي لبس وتعين الالتفات عن هذا الدفع أيضا لعدم وجهته خاصة وأن الفصل 168 من م ا ج لم يرتب أي جزاء على السهو عن التنصيص على سوابق المتهم».

قرار تعقيبي عدد 83828 بتاريخ 3 مارس 2020 صادر عن الدائرة العشرين برئاسة السيد المنذر اللومي والمستشارين السيدين عادل بوصفارة وهناء سحنون بمحضر المدعي العام السيدة لمياء بن إسماعيل وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

« حيث أن البيانات المتعلقة بحرفة وسوابق المتهم المفترض التنصيص عليها بنسخة الحكم إنما خصصت لإبراز هوية المتهم وللتفريق بين الهويات المتشابهة وأنه إذا كانت الهوية كافية بعدم التنصيص على الحرفة والسوابق فإن ذلك لا يفقد الحكم مصداقيته ولا يكون قابلاً للإبطال وأن الشخص يمكن أن يغير الحرفة من حين إلى آخر ويمكن أن يكون له أكثر من حرفة كما يمكن أن لا تكون له حرفة من الأصل وهذا لا يؤثر في مجرى القضية في شيء إضافة إلى أن بطاقة السوابق لا يمكن أن تهم إلا المحكمة لإعتمادها في تقدير العقوبة ولمدى إعمال ظروف التخفيف من عدمه وبالتالي فإن عدم التنصيص على السوابق بنسخة الحكم لا يعيب الحكم في شيء خاصة وأن ملف القضية يتعلق بجنحة وليس بالضرورة إضافة بطاقة السوابق أو انتظار ورودها وانتظار تأخيرها لاستغلال معطياتها بالتنصيص على سوابق المتهم بنسخة الحكم المنتقد كما أنه من الثابت أن المحكمة كانت بينت بكون الطاعنة تمت إحالتها لمقاضاتها من أجل إرتكابها لجريمة البغاء السري وهذا كاف لمعرفة النص التجريمي بالرجوع إلى المجلة الجزائية لمعرفة النص الجزائي المنطبق على الجرم موضوع نص الإحالة وبالتالي فقد ظلت هذه الدفوعات واهية وإتجه تبعاً لذلك ردها».

11-2-22-2 اختلاف في اسم ممثل الإدعاء بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

- خطأ مادي

قرار تعقيبي عدد 96419 بتاريخ 9 أكتوبر 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرون برئاسة السيد رياض الإمام وعضوية المستشارين السيد شكري كمون والسيدة سامية العابد وبحضور المدعي العمومي السيد كريم المهدي ومساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير.

« حيث بمراجعة محضر الجلسة الحكمية يتضح فعلا وجود اختلاف في اسم ممثل الادعاء المذكور بها وبين الاسم المذكور بلائحة الحكم، الا أن ذلك الاختلاف لا يزيد عن كونه خطأ ماديا تسرب عند رقب القرار لا تأثير له على صحة الإجراءات، ضرورة أن العبرة بما دون بمحضر الجلسة أما ما جاء بلائحة الحكم من أخطاء مادية، فيمكن تصحيحها ولو تلقائيا من قبل المحكمة الصادر عنها الحكم ولا تأثير لها على سلامته من الناحية الإجرائية. واتجه رد هذا المطعن لعدم وجاهته».

11-2-23 تعليل الأحكام

قرار تعقيبي عدد 84556 بتاريخ 9 مارس 2020 صادر عن الدائرة الحادية عشر برئاسة السيدة ماجدة بن غربية وعضوية السديين محمد العفيف الجعدي وعماد الدغاري وبمحضر المدعي العام السيدة فوزية قمري وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة أمال بن نصر.

« حيث أوجب المشرع ضمن الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يشمل الحكم على «المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة البراءة» أي أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الأسباب أساس الحكم.

وحيث أن تعليل الأحكام ينصب على الوقائع من أقوال وأفعال والدفوع ثم ينتقل إلى التكييف القانوني وتطبيق النصوص القانونية على الوقائع والرد على الدفوع ويعطي التحليل الذي إعتمدته المحكمة للوصول إلى المنطوق الذي إنتهت إليه فيكون التعليل أساسا للمنطوق.

وحيث أن تعليل الأحكام من الإجراءات الأساسية وهو من أهم الضمانات التي فرضها القانون وأهم أدوات إبراز عدالة الأحكام وصحتها فهو مسألة جوهرية فضلا عن أنه يبرز الدوافع والمبررات التي إعتمدتها المحكمة لإصدار حكمها على نحو معين فلا يجب أن يكون الحكم تبعا لذلك مشوبا بالإجمال أو

الإيهام أو التضارب والتناقض بشكل يجعل أسباب الحكم متجافية مع منطوقه
فما تطرق إليه الاحتمال والتضارب كسأه ثوب التناقض وسقط به الاستدلال.

وحيث بالإطلاع على مستندات الحكم محل الطعن يتضح أن محكمة الحكم
المنتقد قد شابها التناقض والتضارب خاصة فيما ورد بطلال الصفحة عدد 14 من
الحكم وما يليه من حيثيات تتضمن إستدلالات متناقضة غير مفضية إلى النتيجة
التي إنتهت إليها المحكمة وتراوحت بين التعليل في إتجاه البراءة فضلا عما شاب
بيان المستندات الواقعية من نقل حرفي لما تضمنه قرار ختم البحث بجميع ما
إشتمل عليه من معطيات وخاصة ما تضمنته الصفحة عدد 13 من الحكم.

وحيث ثبت من جهة أخرى أن الشكاية شملت المعقب ضدهما ومشتكى به
ثالث وهو المدعو (هـ) محام وأثناء التحقيق في الدعوى طلبت النيابة العمومية
إحالة نسخة من الملف للنظر فيما نسب إلى المحامي المذكور ولم تتولى
المحكمة التحقق من مآل الأبحاث والتحقيق ضد من ذكر رغم إرتباطها الوثيق
بوقائع دعوى الحال ويتضح جليا تبعا لذلك أن القضية لم تتضح للمحكمة على
الوجه الكافي للبت فيها.

وحيث أن تماسك أجزاء الحكم وتعليله عاملان ضروريان لسلامته من العيوب
الموجبة للنقض والتناقض الواضح في الحكم المطعون فيه يورث قضاءها ضعف
التعليل ومخالفة القانون بخرق أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية
وهو يهيم النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 م.إ.ج وفضلا عن مخالفة أحكام
الفصل 143 م.إ.ج لعدم توضيح الدعوى على الوجه الكافي للبت فيها ولك ذلك
أضحى من المتجه نقض القرار محل الطعن مع الإحالة».

قرار تعقيبي عدد 85163 بتاريخ 18 ماي 2020 صادر عن الدائرة الحادية
عشر برئاسة السيدة ماجدة ين غربية وعضوية المستشارين السيدين محمد
العفيف الجعيدي وعادل الدغاري، ومحضر المدعي العام حسن بالحاج عبد الله
وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة آمال بنصر.

« حيث أوجب المشرع ضمن الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن
يشتمل الحكم على «رابعاً: المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم
بالبراءة أي أن يشتمل على أسباب ومنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكم.

وحيث أن تعليل الأحكام ينصب على الوقائع من أقوال وأفعال والدفع ثم ينتقل إلى التكييف القانوني وتطبيق النصوص القانونية على الوقائع والرد على الدفع ويعطي التحليل الذي اعتمدته المحكمة للوصول إلى المنطوق الذي انتهت إليه فيكون التعليل أساساً للمنطوق. فهو من الإجراءات الأساسية وليس رغبة من المشرع في استيفاء الأحكام لشكل معين بل هو من أهم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة فيظهر من خلاله قيامهم بواجب التدقيق والبحث وإمعان النظر في القضية فهو مسألة جوهرية يبرز الدوافع والمبررات التي اعتمدتها المحكمة لإصدار حكمها على نحو معين فلا يجب أن يكون الحكم تبعاً لذلك مشوباً بالتناقض أو التضارب أو استعمال العبارات العامة والفضفاضة بشكل يجعل أسباب الحكم مبتورة.

وحيث أن القاضي الجزائي مطالب بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة عليه ليقوم بتكييفها بصورة تجعل الحكم المنطبق عليها سليماً والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان مفصل في ذلك يبرز كيفية ترجيح إحداها على الأخرى وقيمتها الحجية في الإثبات، بتعليل كاف ليس فيه تغيير أو تناقض أو تحريف للوقائع أو إهمال لعناصر القضية أو قصور في البيان، ورقابة محكمة التعقيب تنصب في هذا الصدد على كيفية البناء المنطقي المستساغ للحكم المستمد من الوقائع الثابتة ملف القضية وتستهدف تطبيق القانون.

وحيث تعين تبعاً لما سبق شرحه وبيانه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بالقصرين لاعادة النظر فيه بواسطة هيئة أخرى».

11-2-24 وصف الحكم غلطا بكونه نهائي

قرار تعقيبي عدد 85399 بتاريخ 18 ماي 2020 صادر عن الدائرة الحادية عشر برئاسة السيدة ماجدة بن غربية وعضوية مستشارين السيدين محمد العفيف الجعيدي وعماد الدغاري بمحضر المدعي العام السيد حسن بن الحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة أمال بن نصر.

« حيث تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى أوراق القضية وما تضمنته من أعمال قضائية والإجراءات أن محكمة الحكم المنتقد قد تعهدت

بالقضية بموجب إحالة من النيابة العامة بتاريخ 28/12/2018 أحيل بمقتضاها المتهم «ن.ب.ج.ب.م.ف» على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بنعروس لمقاضاته من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة. فيكون تعهدها وفقا لما سلف بيانه بوصفها محكمة قضاء من الدرجة الاولى غير ان المحكمة الحكم المنتقد قد صدر منطوق حكمها غلطا بوصفها محكمة درجة ثانية وفق ما سلف بيانه بالطالع حال انه كان لزاما عليها البت ابتدائيا في ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم من عدم ذلك وتسليط العقاب المناسب وفق اجتهادها ان تبين لها ثبوتها أو ترك سبيله في صورة اقتناع وجدانها بالبراءة وليس من شأن ما ورد بمنطوق الحكم يجعل من حكمها الصادر على نحو السابق بيانه حكما نهائيا قابلا للطعن بالتعقيب ضرورة انه لا يقبل الطعن بالتعقيب وفقا لمنطوق الفصل 258 من م.ا.ج «الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائية ولو تم تنفيذها» فاختل بذلك شرط جوهرى اضحى معه الطعن مخالفا لأحكام الفصل 258 السالف الذكر.

وحيث ان مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام ولمحكمة التعقيب ان تثيره من تلقاء نفسها وتمسك به حسب صريح الفصل 269 من م.ا.ج فتعين تبعا لذلك رفض مطلب التعقيب شكلا».

11-2-25 رجوع في التعقيب

11-2-25-1 طلب الرجوع في مطلب الرجوع في التعقيب

قرار تعقيبي عدد 90420 بتاريخ 30 جوان 2020 صادر عن الدائرة العشرين برئاسة السيد المنذر اللومي المستشارين السيدين عادل بوصفارة وهناء سحنون بمحضر المدعي العام السيدة لمياء بن اسماعيل وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

«في طلب الرجوع في مطلب التعقيب ثم طلب الرجوع في ذلك المطلب وطلب الاستمرار في النظر في مستندات التعقيب وموقف ممثل الادعاء العام بهذه المحكمة المتضمن التمسك بالحكم وفق طلب الرجوع في الطعن وعدم اعتماد طلب الرجوع في مطلب الرجوع في الطعن بالوسيلة المذكورة طبق الطلبات المؤرخة في 15 أفريل 2020:

حيث أن طلب الرجوع في الطعن بالتعقيب يعد موقفا لا يهم إلا الطاعن بهذه الوسيلة ولا يمكن أن يهم الاجراءات التي تمس بالنظام العام المبينة بالاجراءات الجزائية. فالطعن بالتعقيب يجب أن تتوفر فيه شرط الصفة والمصلحة واحترام الآجال وأن طلب الرجوع في الطعن لا يكون خاضعا لرقابة محكمة التعقيب إلا في حدود الصفة فقط اعتبارا من كون المصلحة في الرجوع أو التماس في النظر في الطعن لا يهم إلا الطاعن بالتعقيب وأن المحكمة لا يسعها إلا الحكم وفق المطلب اذا ما تم التمسك به خلال نشر القضية إلى حد النظر في ذلك المطلب دون تغيير الموقف وموقف الطاعن الآن قد تغير قبل البت في القضية بأن طلب الرجوع في مطلب الرجوع في التعقيب وبالتالي بات النظر في مطلب التعقيب راجعا للقواعد المتعلقة بالطعن بالتعقيب طبق اجراءات تهم النظام العام المبينة بالباب المعلق بإجراءات التعقيب بمجلة الاجراءات الجزائية وقد اتضح أن نائب الطاعن كان قدم مستندات الطعن تطبيقا للإجراءات المضمنة بأحكام الفصلين 261 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك فيما يتعلق بآجال تقديم مستندات الطعن وبالتالي تكون محكمة التعقيب مجبرة على اعتبار مستندات الطعن قد قدمت في الآجال القانونية واتجه البت في بقية شروط قبول الطعن بهذه الوسيلة من عدمه وتجاوز مطلب الرجوع الذي لا يهم إلا الطاعن دون سواء بأن يتمسك به أو يتراجع عنه واتجه تبعا لذلك الالتفات عن موقف الادعاء العام لهذه المحكمة لخلوه من المستند الصحيح.

وحيث اتضح من جهة أخرى أن الحكم الاستئنافي موضوع الطعن بالتعقيب قد قضى بإقرار حكم البداية القاضي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة وأن ممثل الوكالة العامة لم يطعن في ذلك الحكم بالتعقيب وبالتالي فقد اتصل القضاء بالدعوى الجزائية ولم يعد للطاعن الآن بوصفه قائما بالحق الشخصي الصفة لان يطعن في الحكم المنتقد الذي اتصل به القضاء في جانبه الجزائي واتجه تبعا لذلك رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج».

11-2-25-2 معارضة النائب الثاني للمتهم طلب النائب الأول الرجوع في التعقيب

قرار تعقيبي عدد 12056 وعدد 12057 بتاريخ 5 أكتوبر 2020 صادرين عن الدائرة الثانية والعشرون برئاسة السيد رضا العرعوري وعضوية المستشارين السيدين منيرة حبيب وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العام السيد محمد القمودي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سنية العبدوي.

« حيث طلب نائب المتهم الأستاذ ص. الرجوع في التعقيب فيما تمسك في المقابل نائبه الثاني الأستاذ ف. بموقف معارض لذلك الطلب ورافع في حقه على ضوء ملحوظاته الكتابية.

وحيث ان المحكمة استجابت لطلب الأستاذ ف. في الترافع عنه وعدم تسجيل رجوعه في التعقيب وذلك ترجيحاً من المحكمة لمصلحة المتهم الشرعية التي تقتضي إعطائه فرصة أخرى للدفاع عن حقوقه في إطار توفير الضمانات التي يمنحه إياه القانون للوصول إلى ذلك بما يعني رفض المحكمة لطلب الرجوع في التعقيب».

11-2-26 مجال نظر محكمة الإحالة

قرار تعقيبي عدد 92620 بتاريخ 28 فيفري 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرين برئاسة السيد رياض الامام وعضوية المستشارين السيدة سامية العابد والسيد سامي الدايش وبحضور المدعي العام السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

«عن المطعن الوحيد المتعلق بمخالفة أحكام الفصل 37 من م ج:

حيث اقتضت أحكام الفصل 273 من م ج أن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع القضية للحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض وذلك في حدود ما قبل من المطاعن.

وحيث بالرجوع إلى نسخة الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الملف وخاصة منها القرار التعقيبي عدد 8045 يتضح أن محكمة القانون قد نقضت الحكم موضوع الطعن أمامها لمخالفته لأحكام الفصل 53 من م ج وذلك لتمتيع المتهمه الطاعنة الان بتأجيل تنفيذ العقوبة المسلطة عليها دون التحقق من نقاوة سوابقها العدلية.

وحيث وعملاً بأحكام الفصل 273 المذكور فإن مجال نظر محكمة الإحالة يقتصر على إعادة البت في مسألة اسعاف المتهممة بتأجيل التنفيذ أما مبدأ الإدانة وتوفر أركان الجريمة المنسوبة لها من قصد جنائي وركن مادي وكذلك قيام المسؤولية الجنائية في جانبها، فلم تكن من أسباب النقض وأضحت من المسائل التي اتصل بها القضاء ولا يمكن بالتالي لمحكمة القرار المنتقد بوصفها محكمة إحالة الخوض فيها من جديد ولو تمت اثارتها والتمسك بها أمامها. فضلاً على أن لسان دفاع المتهممة الطاعنة الآن لم يناقش مسألة مدى توفر المسؤولية الجنائية للمحكوم ضدها من عدمه واكتفى في طلباته الأخيرة المسجلة عليه بمحضر الجلسة الحكيمة بتاريخ 16/05/2019 بطلب إقرار حكم البداية.

وحيث وتبعاً لما تقدم فإن ما جاء بهذا المطعن من دفعات إنما يهدف في حقيقة الأمر إلى إعادة بسط مسائل اتصل بها القضاء بموجب القرار التعقيبي عدد 8045 ولا يمكن إعادة الخوض فيها من جديد لا أمام محكمة الحكم المطعون فيه ولا أمام محكمة القانون. وتعين تبعاً لذلك رد المطعن لعدم وجاهته ورفض الطعن أصلاً».

11-2-27 التفكيك والضم

11-2-27-1 التفكيك يفترض إفراد الموقوفين وليس من كانوا بحالة سراح قرار تعقيبي عدد 93389/94243/94143/94257/94604 بتاريخ 17 مارس 2020 صادر عن الدائرة الخامسة والعشرين برئاسة السيد محمد العسكري وعضوية مستشاريها السيدة نبيهة العويني والسيد محمد علي يمن بمحضر المدعي العام السيد نور الدين الزياتي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد علي العمراوي.

«عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 104 مكرر من م إ ج:

حيث أجازت أحكام الفصل 104 مكرر من م إ ج لحاكم التحقيق إمكانية تفكيك الملف دون التوقف على إنهاء أعماله وذلك لغاية تعجيل النظر في شأن الموقوفين.

وحيث بالرجوع لملف القضية الماثلة تبين أن قاضي التحقيق المتعهد قد أنجز كل الأعمال المستوجبة لإعداد القضية للفصل من استنطاقات ومكافحات

واختبارات بما يجعل قرار التفكيك الصادر عنه غير منسجم مع الأحكام الفصل 104 مكرر المذكور فضلا عن كون الفصل المشار إليه يفترض أفراد الموقوفين بالتتابع وليس من كانوا بحالة سراح كما هو الحال في القضية الماثلة.

وحيث لم يبين قرار التفكيك الأسباب الداعية له ولا المنطق المعتمد لاختيار مجموعة من المتهمين اللذين هم بحالة سراح وقد إنتهت الأبحاث في شأنهم لإفرادهم بتتابع مستقل رغم ارتباطهم الوثيق ببقية المتهمين المحالين ضمن الملف الأصلي وتكونهم جميعا للوفاق المفترض الأمر الذي يتطلب الإبقاء على السلسلة المكونة للوفاق مترابطة أحداثا وأشخاصا كل ذلك يجعل من قرار التفكيك متعارضا مع نص القانون ومقتضيات القضية الواقعية فضلا عن تأثيره على وضعية المتهمين المحالين ضمن هذه القضية والتهم الموجهة لهم.

وحيث ان المطاعن المشار إليها ولما كانت مؤسسة قانونا فقد أضحت حرية بالقبول بما يجعل قرار المطعون فيه مستوجبا للنقض من هذه الناحية.

وحيث بخصوص بقية المطاعن فإنها إنما تتعلق بمناقشة إجتهد محكمة القرار المطعون فيه وكيفية قراءتها للوقائع وإستخلاصها للنتائج القانونية منها اعتبارا لكون هذه المحكمة ليست بمحكمة درجة ثالثة في الأصل فإنه لا يمكنها نقض إجتهد بأخر خاصة إذا كان للأول ما يبرره من معطيات واقعية ثابتة بملف القضية وهو ما يتجه معه رد المطاعن المذكورة [...]».

11-2-27-2 تمايز المسار الإجرائي للقضيتين يحول دون ضمهما

قرار تعقيبي عدد 90712 بتاريخ 8 ماي 2020 صادر عن الدائرة الحادية عشر برئاسة السيدة ماجدة بن غربية وعضوية المستشارين السيدين عماد الدغاري ومحمد العفيف الجعيدى بمحضر المدعي العام السيدة فوزية القمري وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة آمال بن نصر.

« حيث اقتضى الفصل 269 من م ا ج ان محكمة التعقيب تنظر في حدود المطاعن المثارة الا اذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ويجب عليها ان تثير من تلقاء نفسها عند الاقتضاء

المطاعن المتعلقة بالنظام العام.

وحيث تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة القرار المنتقد التي تعهدت بنظر القضية عدد 109 بوصفها محكمة احالة ضمت لتلك القضية القضية عدد 471 التي تعهدت بها في اطار اعتراض عن حكم غيابي صدر عنها. وحيث يتبين مما سلف ان المسار الاجرائي للقضيتين متمايز بما يمنع ضم اجراءتهما وملفهما.

وحيث يكون الحكم المنتقد وقد ضم اجراءات الملفين القضائيين قد خرق الاجراءات الأساسية ويستدعي النقض.

وحيث وعلاوة على ما ذكر فيتبين من نظر مطلب التعقيب حصول صلح بين المتهم وإدارة الديوانة يتعين انفاذه .

وحيث يتعين احتراماً للحق في المحاكمة العادلة وانفاذاً للقواعد الاجرائية الآمرة نقض الحكم المطعون فيه».

11-2-28 تعديل بين الحكام

قرار تعقيبي عدد 1214 بتاريخ 3 مارس 2020 صادر عن الدائرة الثانية عشر برئاسة السيد محمد بن منصور وعضوية المستشارتين السيدتين سلوى التميمي وصباح يحي بحضور المدعي العام السيدة ليلي الشابي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد توفيق المناصري.

« حيث يهدف المطلب إلى التعديل بين قرار ختم البحث التحقيقي عدد 29249 الصادر عن السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببزرت بتاريخ 29/11/2019 القاضي بالتخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي الإقتصادي والمالي بمحكمة الإستئناف بتونس وقرار رفض التعهّد عدد 7202 الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20/01/2020.

وحيث إقتضى الفصل 291 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه: «يتمّ التعديل بين الحكام إذا وقعت جريمة وتعهدت بها محكمتان باعتبار أنها من أنظار كل منهما أو قررت المحكمتان خروجها عن أنظارهما أو قررت محكمة عدم أهليتها للنظر في قضية أحالها عليها حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام ونشأ عما ذكر نزاع في

مرجع النظر عطل سير العدالة من جراء إحراز القرارين المتناقضين الصادرين في القضية نفسها قوة ما إتصل به القضاء».

وحيث لا جدال وأن القرارين موضوع مطلب التعديل صدرا بعدم الإختصاص وقد إتصل بهما القضاء ممّا إنجر عنه لا محالة تعطيل سير القضاء ممّا إتجه معه التعديل في خصوص التنازع السلبي طبق أحكام الفصل 291 المذكور لتحديد المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع.

وحيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن قرار التخلي الصادر عن السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بنزرت إعتد على أن الجريمة موضوع نص الإحالة ذات صبغة إقتصادية ومالية باعتبار أنها تتعلق بتداخل حاصل بين مصالح وزارة الخارجية ومصالح رئاسة الجمهورية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بما يجعلها متشعبة.

بينما إعتد قرار رفض التعهد الصاد عن وكالة الجمهورية بتونس على سنيين إثنين أولهما مخالفة قرار التخلي للإجراءات الواردة بالفصل 4 من القانون عدد 77 لسنة 2016 الواجب إتباعها قبل صدور قرار التخلي وثانيهما يتعلق بعدم توفر شرط التشعب اللازم للتخلي.

وحيث أنّ الحسم في موضوع هذه القضية المتعلق بمرجع النظر يقتضي الرجوع إلى الأحكام القانونية الواردة بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 06/12/2016 المتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.

وحيث إقتضى الفصل 2 من القانون الأساسي المشار إليه «أنه يقصد بالجريمة المتشعبة كل جريمة إقتصادية ومالية تتطلب إجراء أعمال إستقرائية معمقة ودقيقة وباستعمال وسائل تحري خاصة أو قضية تقتضي الإستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الإختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي وذلك بالنظر خاصة إلى تعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن إرتكابها أو لامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية».

وحيث أقتضى الفصلان 4 و15 من نفس القانون أن يسبق كل تخلي عن أية قضية تحقيقية لفائدة القطب القضائي الإقتصادي والمالي الحصول على موافقة

كتابية من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بعد تثبته من توفر شروط التعهد.

وحيث لا جدال أن الأحكام الواردة بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المتعلقة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي هي أحكام تهم النظام العام وينجر عن مخالفتها بطلان الإجراءات المتعلقة بها.

وحيث من الثابت لدى هذه المحكمة وأن قرار التخلي الصادر عن السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببزرت لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 4 و 15 من القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المذكور إذ لم يسبقه عرض تقرير كتابي من وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببزرت على وكالة الجمهورية بتونس بخصوص قرار التخلي وموافقة هذه الأخيرة كتابيا على القرار المذكور بعد تثبتها من توفر شروط التعهد وفقا لأحكام الفصلين 4 و 15 المذكورين أعلاه.

وحيث يتضح أن قرار التخلي الصادر عن السيد قاضي التحقيق الأول كان مختلا لعدم إحترامه لإجراءات أساسية وجوهرية تهم النظام العام مما يجعله باطلا على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وحيث من جهة أخرى وبعد التمحيص في موضوع القضية التحقيقية المتخلى عنها فإنه يتضح أن وقائعها تتعلق بإبرام عقد شغل صوري من قبل وزير سابق وأحد الأشخاص الذي كان يعمل لديه بغاية تمتيعه بالتغطية الإجتماعية بصفة غير شرعية وهي جريمة لا تدخل تحت طائلة الفصل 2 المذكور أعلاه والمتعلق بالجريمة المتشعبة لإنعدام توفر شروط الشعب فيها.

وحيث يتبين مما سبق وأن قرار رفض التعهد الصادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كان في طريقه في حين أن قرار التخلي الصادر عن السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببزرت كان مختلا إذ لم يحترم الإجراءات القانونية الواجب إتباعها كما كان مفتقرا على شروطه القانونية مما توجب معه إبطاله وإحالة ملف القضية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببزرت لمواصلة الأبحاث التحقيقية».

11-2-29-29 البطلان الإجرائي

11-2-29-29 بطلان محضر الإحتفاظ لا يشمل آثاره باقي الأعمال

قرار تعقيبي عدد 85545 بتاريخ 2 جوان 2020 صادر عن الدائرة الجزائية الخامسة والثلاثين برئاسة السيدة ليلي الذويبي وعضوية مستشاريها السيدتين كوثر الشريفي ونورة البكوش وبمحضر المدعي العام السيد سفيان بوزيد وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة أمال بن نصر.

« عن المطعن الوحيد القائل بخرق القانون:

حيث أن تعليل الأحكام وتسبيبها هو من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها وأن التعليل ينبغي أيضا أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الفعلية منها والقانونية وأن يكون كذلك مطابقا للقانون.

وحيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن المحكمة قضت ببطلان إجراءات التتبع لخلو محضر الإحتفاظ من تاريخ إنتهاء مدته يوما وساعة.

وحيث خلافا لما ذهب إليه محكمة القرار المطعون فيه فإن بطلان محضر الإحتفاظ لا يمكن أن تشمل آثاره باقي الأعمال التي تظل قائمة وصحيحة في مواجهة المعقب ضده وذلك إستنادا إلى أحكام الفصل 13 مكرر جديد من م إ ج والذي ينص على أنه: «يظل العمل المخالف للإجراء المشار إليه» وكذلك من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 199 م إ ج التي جاء بها على أن «الحكم الذي يصدر بالبطلان يحدد نطاق مرماه».

وحيث يؤخذ من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 199 م إ ج أن بطلان إحدى أعمال التتبع لا يترتب عنه بطلان الدعوى برمتها بل أن باقي الأعمال تظل قائمة وصحيحة في مواجهة المعقب ضده ومنتجة لآثارها القانونية.

وحيث أن محكمة القرار المطعون فيه لما قضت بالصورة التي قضت بها تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض».

11-2-29-29 تصحيح محكمة الإستئناف للبطلان والحكم في الأصل

قرار تعقيبي عدد 85541 بتاريخ 2 جوان 2020 صادر عن الدائرة الخامسة والثلاثين برئاسة السيدة ليلي الذويبي وعضوية مستشاريها السيدتين كوثر

الشريفي ومرزقة جماعة وبمحضر المدعي العام السيد سفيان بوزيد وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة أمال بن نصر.

«حيث إقتضى الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه «إذا كان الحكم المستأنف صادرا في الأصل ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الإجراءات فإنها تصحح ذلك البطلان وتحكم في الأصل وإذا كان الحكم قابلا للإبطال فإن محكمة الاستئناف تتعهد بالأصل وتبت فيه».

وحيث كرس محكمة التعقيب في قراراتها هذا المبدأ من ذلك القرار التعقيبي الجزائي عدد 39809 المؤرخ في 14/04/2017 وجاء فيه «تنص الفقرة 2 من الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه إذا كان الحكم قابلا للإبطال فإن محكمة الاستئناف تتعهد بالأصل وتبت فيه وهو ما يستتج منه إتجاه القانون التونسي نحو السماح للمحكمة بتدارك الخلل المبرر لإمكانية الإبطال كلما سنح ذلك والبت في أصل التتبع» والقرار التعقيبي الجزائي عدد 19096 المؤرخ في 18/02/2015 وجاء فيه «عملا بمنطوق الفصل 218 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا كان الحكم المستأنف صادرا في الأصل ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الإجراءات فإنها تعين نطاق مرماء وتصحح ذلك البطلان إن كان وتحكم في الأصل وليس لها أن تعتمد ذلك لتبرير القضاء سلبا».

وحيث وخلافا لما ذهب إليه الطاعن فإن محكمة الحكم المطعون فيه لم تخرق القانون عندما تجاوزت الدفع المثار بخصوص بطلان إجراءات التتبع ونظرت في الأصل بل هي أحسنت تطبيق القانون وتحديد النص 218 المذكور فضلا عن أنه ثبت من أوراق الملف أن إحتفاظ باحث البداية بالمتهم وقع بنفس تاريخ الإذن بذلك الصادر عن النيابة العمومية 14/11/2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا».

11-2-29-3 تضمين الضابطة العدلية بالمحضر تكييفاً للإفعال غير ملزم ولا تأثير له على سلامة المحضر

قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 13 مارس 2020 صادر عن عن الدائرة ... برئاسة السيد ... وعضوية المستشارتين السيدتين ... بحضور المدعي العام السيد ... وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ... (قضية ذات صبغة إرهابية)

«بخصوص المطعن الأول المأخوذ من بطلان محاضر الباحث الابتدائي:

حيث تمسك لسان دفاع المعقب بأن محاضر البحث الجزائي تضمنت تكييف للأفعال المنسوبة لمنوبه وهي مسألة تخرج عن صلاحيات الباحث الابتدائي المبينة بالفصول 9 و13 و30 م إ ج علاوة على توليه إستخلاص إنتماء المظنون فيه إلى تنظيم إرهابي رغم أنه لم يقع إلقاء القبض عليه بحالة تلبس كما أن التنصيصات المضمنة بالمحاضر تم إنتزاعها بإستعمال الإكراه المادي والمعنوي منتهيا إلى بطلان أعمال الباحث الابتدائي على معنى أحكام الفصل 199 م إ ج.

وحيث وخلافا لما ذهب إليه نائب الطاعن فإن ما إعتبره تكييف الإفعال المنسوبة إلى منوبه من قبل باحث البداية يخالف أعمال هذا الأخير المحددة طبق الفصول 9 وما بعده م إ ج فإن ذلك التوصيف لا تأثير له على سلامة المحضر الجزائي من جهة كما لا يلزم المحكمة من جهة أخرى سيما وأن تنزيل الوصف القانوني المناسب ينطلق بداية من تعهد النيابة العمومية بالموضوع وصولا إلى الطور الحكمي للقضية بمختلف درجاته ويبقى الوصف المذكور بالمحضر بمثابة الإطار الذي يباشر فيه الباحث أعماله».

11-2-30 الإعتراض على الحكم الغيابي

11-2-30-1 قبول الإعتراض شكلا دون التوقف على الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية

قرار تعقيبي عدد 2303/9 بتاريخ 27 مارس 2020 صادر عن الدائرة السابعة عشر برئاسة السيدة روضة أويش ومستشاريها السيدين مفيدة المداني ومروان التليلي وبمحضر المدعي العام السيد عبد الحميد بن غانم وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة الهمامي.

« حيث قضت محكمة الحكم المنتقد «بالتشطيب على ملف القضية من دفاتر المحكمة والمنظومة الإعلامية والإذن للنياحة العمومية بالتمادي على التنفيذ».

وحيث وبالرجوع إلى مظروفات الملف نجد أن المتهم المعترض حضر بجلسة 23 جافني 2019 ولم تبت المحكمة في شكليات الإعتراض بتعلة أن المعترض لم يدلي ببطاقة تعريفه الوطنية .

وحيث أخرت محكمة الأصل القضية لجلسة أخرى لنفس السبب ثم قررت التصريح بالحكم المشار إليه دون تنفيذ الحكم التحضيري الذي سبق لها التأخير من أجله وهو الإدلاء بهوية المعارض.

وحيث وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الحكم المنتقد فقد نص الفصل 183 من م إ ج على أنه «إذا لم يحضر المعارض يحكم برفض إعتراضه بدون تأمل في الأصل».

وحيث وبالرجوع لقضية الحال نجد أن المتهم كان قد حضر بجلسة 23/01/2019 وبالتالي كان على محكمة الأصل قبول إعتراضه شكلا دون التوقف على الإدلاء ببطاقة تعريفه ضرورة أن هوية المتهم منصوص عليها بمحاضر البحث الأولي والإحالة وبالتالي كان على محكمة الحكم المنتقد أن تطلب من المتهم التصريح بهويته ثم تقع مقارنتها مع الهوية المنصوص عليها بمحضر البحث الأولي والإحالة ومقارنة إسمه الثلاثي وإسم والدته مع ما هو موجود بالملف ثم الإنصراف للبت في شكليات الإعتراض وتكون محكمة الحكم المنتقد لما إفلت هذا الجانب وقضت بالتشطيب على ملف القضية من دفاتر المحكمة قد حرّفت القانون وأساءت تطبيق الأحكام الغيابية وإستحق حكمها النقض والإحالة».

11-2-30-2 امكانية تقديم مطلب الإعتراض من المحامي وإعلام موكله بتاريخ الجلسة الإعتراضية

قرار تعقيبي عدد 11934 بتاريخ 19 ماي 2020 صادر عن عن الدائرة الخامسة برئاسة السيد جلال الدين بوكثيف وعضوية المستشارين السيدين عدنان الهاني وآمال عاشور وبمحضر المدعي العام السيد أنيس ضيف الله وكاتبة المحكمة السيدة منيرة المانعي.

« حيث اتضح بالاطلاع على أوراق الملف وإن المتهم الطاعن في قضية الحال «ه ش» كان قد اعترض على الحكم الاستئنافي حكمها عدد 13133 الصادر غيابيا في حق وتسلم حسبما يثبت الوصل المضاف للملف وصل الاستدعاء نائبه بتاريخ 15/11/19(2) للحضور بالجلسة الاعتراضية المعينة ليوم 11/12/2015 والتي لم يحضر بها.

وحيث نص الفصل 183 م اج على ما يلي: «إذا لم يحضر المعارض يحكم برفض اعتراضه بدون تأمل في الأصل». ويستخلص من أحكام الفصل المذكور انه ليس للمحكمة المتعده بالنظر في مطلب الاعتراض أن تقبله شكلا إذا لم يحضر المعارض لجلسة الاعتراض ولم ينص المشرع على أي استثناء ويكون بالتالي اعتراضه مرفوضا شكلا .

وحيث أن اعتراض المحكوم ضده غيايا لا تستوجب اجراءاته أن يتولى القيام بمطلب الاعتراض المحكوم عليه شخصا بل أن القانون خول لنائب إمكانية القيام بذلك المطلب نيابة عنه وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 175 من م اج وهو الأمر الذي يستدعي أن يتولى نائب المعارض تقديم مطلب الاعتراض وتسلم الاعلام بموعد الجلسة ويتولى بدوره وبمقتضى الوكالة في ذلك اعلام موكله بموعد الجلسة المعينة لإعادة النظر في القضية بموجب الاعتراض كإعلام بقية الخصوم عند الاقتضاء ويكون اعلام المتهم المعارض في تلك الحالة إعلاما قانونيا مطابقا لمقتضيات الفصل 175 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية مما يجعل نعي الحكم المطعون فيه بخرق القانون غير مستندا على السند الصحيح واتجه بالتالي رده.

وحيث ومن جهة أخرى فقد أحرز الحكم المنتقد على جميع مقوماته القانونية ولم يلاحظ به أي خلل اجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م اج».

11-2-30-3 الشهادة الطبية دليل لاثبات القوة القاهرة التي تحول دون حضور المعارض بالجلسة

قرار تعقيبي عدد 92494 بتاريخ 28 فيفري 2020 صادر عن الدائرة التاسعة والعشرين برئاسة السيد رياض الامام وعضوية المستشارين السيدة سامية العابد والسيد سامي الدايش وبمحضر المدعي العام السيد كريم المهدي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال العنتير.

«عن المطعن الوحيد المتعلق بمخالفة أحكام الفصل 183 من م اج:
«حيث لا خلاف أن الهدف الأصلي من الطعن بالاعتراض هو تمكين المتهم المحكوم ضده غيايا من حق الدفاع عن نفسه. وقد دأب عمل المحاكم على

اعتبار الشهادة الطبية دليل يمكن الأخذ به لاثبات القوة القاهرة التي تحول دون حضور المعارض بالجلسة.

حيث ثبت بالاطلاع على الشهادة الطبية المظروفة بالملف أن عدم حضور المعارض بجلسة الحكم الاعترافي كان مرده حالته المرضية في تاريخ البت في جلسة اعتراضه. ولعل ذلك يعد قوة القاهرة أو عذرا شرعيا يبرر غيابه.

وحيث أن الشهادة الطبية تعد مؤيدا مؤثرا على وجه الفصل في مطلبه تستوجب ابداء الرأي فيها من قبل محكمة الأصل من تأثير على مصلحة المتهم الشرعية في الدفاع عن نفسه. وتعين تبعا لذلك النقض وارجاع الملف لمحكمة القرار المنتقد لاعادة النظر فيما ذكر بواسطة هيئة أخرى».

11-2-31 أطفال

11-2-31-1 العبرة في اعتبار المتهم طفلا هو سنه زمن ارتكاب الجريمة وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالطفولة الجانحة ولو بلغ سن الرشد أثناء نشر القضية

قرار تعقيبي عدد 99233 بتاريخ 13 نوفمبر 2020 صادر عن عن الدائرة التاسعة والعشرون برئاسة السيد رياض الإمام وعضوية المستشارين السيد شكري كمون والسيدة سامية العابد وبحضور المدعي العمومي السيد كريم المهدي ومساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العتير.

«عن الدفع المتعلقة بالاخلال بالإجراءات ومخالفة أحكام الفصلين 99 و100 من مجلة حماية الطفل:

حيث خلافا لما جاء بمستندات الطعن، فقد تم التنصيب بطالع الحكم على أنها قضية أطفال. كما تاكد ذلك من تركيبة هيئة المحكمة التي تضمنت مستشاري الطفولة.

أما بخصوص مخالفة أحكام الفصلين 99 و100 من مجلة حماية الطفل، فان العبرة في اعتبار المتهم طفلا هو سنه زمن ارتكاب الجريمة وتطبق عليه تبعا لذلك الأحكام الخاصة بالطفولة الجانحة ولو بلغ سن الرشد أثناء نشر القضية. وبالرجوع إلى أحكام الفصل 100 المذكور، فانها لم تستثني الطفل الذي بلغ سن الرشد قبل صدور الحكم من تمتيعه بأحد التدابير التي جاءت بالفصل 99. أما

ضرورة تحديد مدة التدبير على معنى الفصل 100، فهي تتعلق بالتدابير التي تقرر المحكمة بموجبها وضع الطفل بأحد المؤسسات العمومية، أما تسليم الطفل إلى والديه، فإن القول بعدم جواز اتخاذ هذا التدبير بعد تجاوز الطفل سن 18 عاما بجانب للصواب ولمصلحة الطفل المتهم. واتجه رد هذه الدفوع لعدم وجاهتها».

11-2-31-2 مستشاري الطفولة لا يكتسبان صفة القاضي ولا تنسحب عليهما أسباب التجريح

قرار تعقيبي عدد 91556 بتاريخ 10 مارس 2020 صادر عن الدائرة السابعة والعشرون برئاسة السيد عادل الأندلسي وعضوية المستشارين السيدين بلقاسم كعوان ومحمد بن مفتاح وبمحضر المدعي العام السيدة هنده الكتاري وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سميرة بوشوشة.

« حيث إقتضى الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: «تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصالة على الحكام ... في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باسروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها».

وحيث أن التحجير المنصوص عليه بالفصل 248 يقتصر على القضاة دون غيرهم من الأعضاء الذين ينضمون تبعا لإجراءات خاصة إلى تركيبة المحكمة والذين لا يباشرون الوظائف القضائية وينحصر دورهم في إبداء رأي مرتبط بمجال مخصص من شأنه أن يساعد قضاة الأصل في قراءة الوقائع بشكل أفضل فلا يكون لهم تأثير مباشر في الحكم إذ يبقى القضاة أصحاب السلطة الأصلية لإصدار الأحكام وعليه فإن أسباب التجريح التي تنسحب على القضاة لا يمتد تأثيرها إلى غيرهم.

وحيث أن مستشاري الطفولة الذين أوجب المشرع صلب الفصلين 82 و83 من مجلة حماية الطفل إنضمامها إلى تركيبة المحكمة لا يكتسبان بموجب ذلك صفة القاضي والتالي لا تنسحب عليهما أسباب التجريح الواردة في الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية».

11-2-31-3 طعن لمصلحة القانون - حرمان الطفل من مقتضيات مجلة حماية الطفل

قرار تعقيبي عدد 177 بتاريخ 19 ماي 2020 صادر عن عن الدائرة الثانية عشر برئاسة السيدة منيرة النحالي وعضوية المستشارين السيدين محمد بن منصور وسلوى التميمي بحضور المدعي العام السيد نبيل غرس الله وبمساعدة كاتب الجلسة السيد توفيق المناصري.

« حيث كان الطلب يرمي إلى نقض الحكم الصادر عن محكمة الناحية بالمكين تحت عدد 76810 بتاريخ 27/11/2018 لمصلحة القانون.

وحيث بالإطلاع على الحكم المذكور وعلى أوراق القضية يتضح أن الحكم المطعون فيه أضحي نهائيا لانقضاء أجل الطعن فيه أمام هذه المحكمة.

وحيث بالرجوع إلى رسم ولادة المحكوم عليه ق.ع. عدد 11 لسنة 2002/2007 والمضمن بلف القضية يتضح أنه مولود بتاريخ 18 فيفري 2002 بينما يرجع تاريخ الواقعة المنسوبة إليه إلى 26/09/2018 مما يجعل سنه في تاريخها لم يبلغ الثمانية عشر عاما.

وحيث نص الفصل 71 من مجلة حماية الطفل «لا يحال الأطفال الذين سنّهم بين الثلاثة عشر والثمانية عشر عاما المنسوبة إليهم مخالفة أو جنحة أو جناية على المحاكم الجزائية العادية وإنم يرجعون بالنظر لقاضي الأطفال أو محكمة الأطفال».

وحيث إن قواعد الإختصاص الحكمي تهم النظام العام وقد كان على قاضي الناحية المتعهد بالقضية التخلي عنها لفائدة قاضي الأطفال طالما أن المحكوم عليه لم يبلغ بعد السن القانونة المنصوص عليها صلب الفصل 71 المذكور.

وحيث لا خلاف وأن إخضاع المحكوم عليه لإجراءات المحاكمة العادية وحرمانه من تطبيق مقتضيات مجلة الطفل طالما وأنه كذلك فيه خرق للقانون ولأحكام الفصل 71 المذكور.

وحيث طالما أصبح الحكم المطعون فيه باتا لعدم الطعن فيه من قبل المحكوم عليه أو النيابة وفيه خرق للقانون كما سلف بيانه فإنه يتوجب على هذه المحكمة تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة طبقا لأحكام الفصل 276 من م.إ.ج.».

11-2-31-4 اختصاص قاضي الأطفال بالنظر في الجرائم المرتكبة من الطفل ولو كانت ضد العسكريين

قرار تعقيبي عدد 87542 بتاريخ 5 فيفري 2020 صادر عن عن الدائرة الرابعة عشر برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية المستشارين السيدين العقيد قاضي نورة الامام وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العمومي السيد عادل الغالي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة هاجر السلطاني.

« حيث انه ودون الخوص في الأصل وبقطع النظر عن جدية المطعن المثار من عدمه فانه يتعين على محكمة القانون اثارة جملة من القواعد الاجرائية الأساسية ليتسنى تفعيل دور محكمة التعقيب في الرقابة على حسن تطبيق القانون وتاويله. وحيث نص الفصل 169 من م ا ج انه « اذا ظهر ان الجريمة من خصائص محكمة اخرى تصدر المحكمة حكما بخروج القضية عن انظارها وتنتهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية».

وحيث ومما لاشك فيه ان قواعد الاختصاص الحكمي تعتبر قواعد امرة لمساسها بالاجراءات الأساسية والنظام العام ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو الاخلال بها وتثيرها محكمة التعقيب ولو لاول مرة ولها ان تتمسك به من تلقاء نفسها تفعيلا لاحكام الفصل 169 من م ا ج.

وحيث لا جدال ان أحكام الفصل 5 من مجلة المرفعات والعقوبات العسكرية حددت اختصاص المحاكم العسكرية بالبت في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وفي جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين . وحيث انه رجوعا إلى ملف القضية تبين وان المتهم المعقب كان طفلا في زمن الواقعة.

وحيث اقتضى الفصل 86 من مجلة حماية الطفل انه :«...وإذا تعلققت القضية بطفل وبعسكري وجب على وكيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة للطفل في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية للتعهد لفائدة محكمة الأطفال المختصة».

وحيث يستخلص من أحكام الفصل المشار إليه انه كلما تعلق الأمر بطفل ينسب إليه ارتكاب جريمة ما من جرائم الحق العام ولو كانت ضد العسكريين،

فإن الاختصاص بنظرها لا يكون من انظار القضاء العسكري طبق أحكام الفصل 5 م م ع ع ، وانما يسند الاختصاص بنظرها لقضاء الاطفال تفعيلا لاحكام الفصل 86 م ح ط المشار إليها التي تقدم في التطبيق سيما وان الطفل يتمتع بحماية خاصة أساسها مصلحة الطفل الفضلى حتى في حالة اتخاذ احد التدابير المنصوص عليها صلب الفصل 99 من م ح ط أو تسليط عقاب جزائي ضده.

وحيث انه تطبيقا لاحكام الفصل 86 م ح ط المشار إليه ، فان قضية الحال تعلقت مما لا شك فيه بطفل وهو ما يجعلها تخرج عن اختصاص القضاء العسكري واعتبارها من أنظار واختصاص قضاء الاطفال ...».

وحيث اقتضى الفصل 33 من م م ع ع على أنه « اذا قررت دائرة التعقيب إبطال القرار أو الحكم المطعون فيه من حيث مرجع النظر فإنها تقرر أيضا حالة القضية على المحكمة المختصة.

وحيث واستنادا إلى أحكام مجلة حماية الطفل المشار إليها والى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية يتجه إحالة ملف القضية على المحكمة المختصة بقضاء الاطفال بسيدي بوزيد».

قرار تعقيبي عدد 01210 بتاريخ 11 مارس 2020 صادر عن عن الدائرة الرابعة عشر برئاسة السيد محمد عماد بن عبد الجليل وعضوية المستشارين السيدين العقيد قاضي نورة الامام وكمال بوكثير وبمحضر المدعي العمومي السيد عادل الغالي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة سميرة بوشوشة

«حيث انحصر الاشكال في تحديد مرجع النظر الحكمي بالنظر في قضية الحال وقد دفعت الاجابة إلى تنازع سلبي بين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وقاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بينزرت، وقد صدرت عنهما قرارات أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء وتعطل سير العدالة وهو ما استوجب تدخل هذه المحكمة للحسم في التنازع المشار إليه اعمالا لاحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية.

وحيث كان القرار الصادر عن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بينزرت تضمن التخلي عن القضية لفائدة القضاء العسكري لعدم الاختصاص الحكمي مستندا في ذلك إلى أحكام الفصل 5 م م ع ع.

وحيث نص الفصل 169 من م ا ج انه « اذا ظهر ان الجريمة من خصائص محكمة اخرى تصدر المحكمة حكما بخروج القضية عن انظارها وتنتهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية.

وحيث ومما لاشك فيه ان قواعد الاختصاص الحكمي تعتبر قواعد امرة لمساسها بالاجراءات الأساسية والنظام العام ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو الاخلال بها وتشيرها محكمة التعقيب ولو لأول مرة ولها ان تتمسك به من تلقاء نفسها تفعيلا لاحكام الفصل 169 من م ا ج.

وحيث لا جدال ان أحكام الفصل 5 من مجلة المرفعات والعقوبات العسكرية حددت اختصاص المحاكم العسكرية بالبت في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وفي جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين.

وحيث انه رجوعا إلى ملف القضية تبين وان المتهمين ج. ح. وع. ح. كانا طفلين في زمن الواقعة.

وحيث اقتضى الفصل 86 من مجلة حماية الطفل انه :«... وإذا تعلققت القضية بطفل وبعسكري وجب على وكيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة للطفل في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية للتعهد لفائدة محكمة الأطفال المختصة».

وحيث يستخلص من أحكام الفصل المشار إليه انه كلما تعلق الأمر بطفل ينسب إليه ارتكاب جريمة ما من جرائم الحق العام ولو كانت ضد العسكريين فان الاختصاص بنظرها لا يكون من انظار القضاء العسكري طبق أحكام الفصل 5 م م ع ، وانما يسند الاختصاص بنظرها لقضاء الاطفال تفعيلا لاحكام الفصل 86 م ح ط المشار إليها التي تقدم في التطبيق عن غيرها من النصوص القانونية، سيما وان الطفل يتمتع بحماية خاصة أساسها مصلحة الطفل الفضلى حتى في حالة اتخاذ احد التدابير المنصوص عليها صلب الفصل 99 من م ح ط أو تسليط عقاب جزائي ضده.

وحيث انه تطبيقا لاحكام الفصل 86 م ح ط المشار إليه ، فان قضية الحال تعلققت مما لا شك فيه بطفل وهو ما يجعلها تخرج عن اختصاص القضاء العسكري واعتبارها من أنظار واختصاص قضاء الاطفال...».

وحيث اقتضى الفصل 33 من م ع ع أنه « اذا قررت دائرة التعقيب إبطال القرار أو الحكم المطعون فيه من حيث مرجع النظر فإنها تقرر أيضا إحالة القضية على المحكمة المختصة.

وحيث واستنادا إلى أحكام مجلة حماية الطفل المشار إليها وإلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية يتجه إحالة ملف القضية على السيد قاضي التحقيق المختص بقضايا الاطفال بنزرت .

وحيث اقتضى الفصل 199 من م ا ج انه « تبطل كل الاعمال والاحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية ، والحكم الذي يصدر بالبطلان يعين نطاق مرماه».

وحيث وان قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنزرت هو قرار باطل لمخالفته لقواعد الاختصاص التي تهم النظام العام بما جعله عرضة للإبطال مع ارجاع ملف القضية إلى السيد وكيل الجمهورية بذات المحكمة للتعهد وفتح بحث فيها مجددا بواسطة قاضي تحقيق آخر».

11-2--32 سقوط الدعوى بمرور الزمن في جنحتي إقامة صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعماله

قرار تعقيبي عدد 91445-91446-91451 بتاريخ 2 مارس 2020 صادر الدائرة الحادية عشر برئاسة السيدة ماجدة بن غربية وعضوية المستشارين السيدين عيسى ساسي ومحمد العفيف الجعدي بمحضر المدعي العام السيدة فوزية القمري وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة أمال بن نصر.

«حيث إقتضى الفصل 269 من م ا ج أن محكمة التعقيب تنظر في حدود المطاعن المثارة إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ويجب عليها أن تثير من تلقاء نفسها عند الإقتضاء المطاعن المتعلقة بالنظام العام.

وحيث كانت الدعوى في جنحتي إقامة صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية وإستعماله مناط الفصل 199 من المجلة الجزائية.

وحيث نص الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية على كون الدعوى العمومية تسقط فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور ثلاثة

أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك إبتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

وحيث يتبين من الرجوع للحكم المطعون فيه أن محكمة القرار المنتقد صرحت بعدم سقوط تهمتي الإحالة بمرور الزمن بدعوى أن آجال السقوط تحتسب من تاريخ علم الشاكي بواقعة إقامة الصك بما كان معه تأسيسها لموقفها القانوني خارقا لصريح النص الإجرائي الأمر.

وحيث كان على محكمة القرار المنتقد أن تنظر قبل كل تناول منها لأصل الاتهام في سقوط الدعوى العمومية في الجرمين موضوع المحاكمة وفق أحكام الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية وياعتماد ما ثبت لها من تاريخ ثابت لإقامة الصكين المدعى افتعالهما أولا وبنظر تاريخ إستعمالهما ثانيا.

وحيث يتجه تبعا لذلك نقض الحكم المطعون فيه لخرقه إجراءات أساسية تهم النظام العام.

وحيث يفرض التصريح بخرق محكمة القرار المنتقد لقواعد إجرائية على علاقة بإنقضاء الدعوى العمومية بصرف النظر عن الدفوعات التي تهم أصل الاتهام اعتبارا لكون نظرها لم تتوفر شروطه القانونية».

33-2-11

1-33-2-11 قرار فتح البحث على كل من عسى أن يكشف عنه البحث يُطلق يد حاكم التحقيق في استنطاق كل من تكشف عنه الأبحاث دون رجوع إلى النيابة قرار تعقيبي عدد 91110-91114-91239 بتاريخ 11 مارس 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين ماهر كنو وتوفيق سويدي وبحضور المدعي العامة السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير.

« حيث خلافا لما دفع به نائب الطاعنة من أن منوبته لم تكن مشمولة بقرار فتح البحث ولم تقع إثارة الدعوى العمومية في شأنها فإن النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها استنادا إلى أحكام الفصل 20 من م ا ج وقد عهدت بالبحث في قضية الحال إلى قلم التحقيق موجهة التهم موضوع قرار فتح البحث

لمن تكشف عنه الأبحاث الأولية وكذلك لكل من عسى أن يكشف عنه البحث فأطلقت يد هذا الأخير في استنطاق كل من تكشف عنه الأبحاث من أجل تلك التهم موضوع قرار فتح البحث دونما حاجة للرجوع إليها في طلب توجيه التهمة من جديد لأنها وجهت كيفما ذكر بموجب قرار فتح البحث وهو عمل مطابق للقانون لا خرق فيه له واتجه الالتفات عن هذا الدفع لعدم وجاهته».

11-2-33-2 طلب وكيل الجمهورية من حاكم التحقيق إجراء أعمال لازمة لكشف الحقيقة-عدم إجراء الأعمال يكون بقرار معلل في ظرف ثلاثة أيام-أجل يهم النظام العام

قرار تعقيبي عدد 94631 بتاريخ 15 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«حيث أن دائرة الاتهام لا تصدر أحكاما باتة ولا تقضي إلا في شأن قيام الحجاج الكافية لتوجيه التهمة من عدم ذلك وهي بهذا المعنى صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة منها وعليه فإن الطعن بالتعقيب في قراراتها لا يتسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف ، أما تقدير الوقائع وأدلتها فهو أمر غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب أي أن هذه الأخيرة لا تملك سوى حق مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الوقائع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة.

وحيث أن محكمة القرار المنتقد إنتهت إلى تأييد قرار ختم البحث القاضي بحفظ التهم قولا منها بأن الإدعاء بقي مجردا في ظل إنتفاء أي دليل أو قرينة تثبت الأفعال وتسندها للمظنون فيهما.

وحيث أن التعليل الذي إنتهجته محكمة القرار المطعون فيه ينطوي على تحريف للوقائع وعدم إحاطة بجميع العناصر التي أفرزتها الأبحاث ضرورة وأنها لفتت نظرها عما ورد بشهادة المدعو ي.ع. الذي شاهد كيفية محاولة إستيلاء

أحد المظنون فيهما على دراجة المتضرر إلا أن تدخله حال دون إتمام عملية السرقة وكذلك شهادة المدعو م.ع.

وحيث أن دائرة الاتهام بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية ملزمة قانونا بمراقبة أعمال التحقيق المجراة لدى الطور الأول والتحقق من سلامة الإجراءات وإبطال كل إجراء أو عمل فيه إخلال بأحكام الإجراءات الأساسية إنفاذا في هذا لأحكام الفصل 199 م إ.ج.

وحيث وبغض النظر عن بقية المطاعن المثارة فقد تبين بالرجوع أوراق الملف أن قاضي التحقيق أحال الملف على النيابة العمومية لتقديم طلباتها في الأصل بتاريخ 2019/2/12 فحرر ممثل النيابة طلباته بتاريخ 2019/2/13 طالبا إجراء المكافحات بين أطراف النزاع والشهود بعد التحرير على هؤلاء وتحليفهم اليمين القانونية وتحذيرهم مغبة الشهادة زورا ومكافحتهم مع المظنون فيهما والمتضرر عند الإقتضاء بناء على أن الشهود الواقع سماعهم من قبل الباحث المناب لم يؤدوا اليمين القانونية ولم يحذروا من مغبة الشهادة زورا ولم تتم مكافحتهم بالمظنون فيهما والمتضرر إلا أن قاضي التحقيق ختم البحث في القضية بعد سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلبات وتحديد يوم 2019/2/20 خارج الأجل المبين بالفصل 55 م إ.ج في تحريف صارخ للوقائع ورأى أن تلك الطلبات في غير طريقها معتبرا أن الشهود الواقع سماعهم حققوا صحة رواية المظنون فيهما واتجه في رأيه تجاوز تلك الطلبات لكونها غير منتجة.

وحيث نص الفصل 55 م إ.ج أن: «لوكيل الجمهورية أن يطلب من حاكم التحقيق في قرار إفتتاح البحث وفي كل طور من أطوار التحقيق بمقتضى قرار تكميلي إجراء الأعمال التي يراها لازمة لكشف الحقيقة.

ولهذا الغرض يمكنه ان يطلب الإطلاع على سائر أوراق القضية على أن يرجعها إلى حاكم التحقيق في ظرف ثمان وأربعين ساعة.

وإذا تراءى لحاكم التحقيق أن لا ضرورة لإجراء الأعمال المطلوبة منه فيجب عليه أن يصدر في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ طلبات وكيل الجمهورية قرارا معللا. وهذا القرار يقبل الإستئناف لدى دائرة الاتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإطلاع عليه».

وحيث أن القاعدة الواردة بالفصل 55 المذكور هي من الإجراءات الأساسية وهي قاعدة أمرة بدليل إستعمال المشرع لعبارة «يجب عليه» وقد شُرعت في إطار تنظيم العلاقة بين ركيزتين من ركائز مرفق العدالة وهما النيابة العمومية بوصفها تثير الدعوى العمومية وتمارسها في حق المجتمع الذي تمثله وقاضي التحقيق بوصفه سلطة قضائية مستقلة مكلفة بعمل البحث والإستقراء في الجنايات وحتى في الجنح كلما تم تعهده بالبحث فيها وهي لذلك قاعدة إجرائية لها علاقة بتنظيم مرفق العدالة وطالما أنها كذلك فإنه لها بالضرورة مساس بأحكام تهم النظام العام.

وحيث نص الفصل 269 من نفس المجلة: «تنظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ويجب عليها أن تثير من تلقاء نفسها عند الإقتضاء المطاعن المتعلقة بالنظام العام».

وحيث يكون لزاما على هذه المحكمة إعمالاً لأحكام الفصل 269 المذكور إثارة هذه المسألة من تلقاء نفسها حتى وإن لم تقع إثارتها ضرورة وأن خرق تلك القاعدة الإجرائية المتصلة كما سلف بيانه بالنظام العام وتغافل دائرة الاتهام عن التعرض لها كتغافلها عن عدم بت قلم التحقيق في تهمة التهديد بسلح الموجهة على المظنون فيه سفيان وفق ما توجبه عليه أحكام الفصل 104 م إ ج يجعل ما إنتهت إليه تلك الدائرة في غير طريقه على اعتبار وأن ترتيب الأثر على خرق تلك القاعدة وعلى خرق أحكام الفصل 104 المذكور يكون الأولى بالنظر وكان عليها ترتيب الأثر على ذلك بإبطال قرار ختم البحث إنفاذاً لأحكام الفصل 199 م إ ج ولما لم تفعل تكون قد أساءت تطبيق القانون وهو من موجبات النقض واتجه نقض قرارها مع الإحالة».

11-2-33-3 صيغة تسجيل استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث

قرار تعقيبي عدد 95323 بتاريخ 8 ماي 2020 صادر عن الدائرة الرابعة والثلاثون برئاسة السيد كمال دويك وعضوية المستشارين السيدين آسيا الفرشيشي وزينب لغلوغ بحضور المدعي العام السيد محمد الزواوي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائدة برقايوي.

«عن المطعن الوحيد المأخوذ من خرق الفصلين 109 و 110 من المجلة
الإجراءات الجزائية:

حيث تمسك الوكيل العام بأن ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد من رفض
استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث شكلا هو في غير طريقه، ومخالف
لأحكام الفصل 109 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي خول للنياحة العمومية
حق استئناف قرارات حاكم التحقيق. كما بين الفصل 110 من ذات المجلة صيغة
مطلب الاستئناف الذي يرفع كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق دون أن يحصر
تلك الصيغة بمطلب مستقل ومحرر كتابيا.

وحيث تبين من خلال الاطلاع على قرار ختم البحث عدد 15212 موضوع
استئناف النيابة العمومية أن هذه الأخيرة سجلت طعنها بأخر القرار المذكور
بتاريخ 20/11/2017، وقيد بالدفتري المعد لذلك تحت عدد 1453 بكتابة
التحقيق.

وحيث أن دائرة الاتهام المطعون في قرارها، ولما انتهت إلى رفض استئناف
النيابة العمومية لقرار ختم البحث المذكور بمقولة أنه عندما يقع رفع ذلك الطعن
إلى كاتب التحقيق تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وأساءت فهم أحكام
الفصل 110 من المجلة الإجراءات الجزائية مما يجعل قرارها معرضا للنقض
واستحق ذلك».

11-2-35 مسك مادة مخدرة جريمة مستمرة يُعد مرتكبها متلبسا ولا حاجة
للحصول على إذن كتابي من النيابة العمومية

قرار تعقيبي عدد 89000 بتاريخ 22 جانفي 2020 صادر عن الدائرة التاسعة
برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي
وتوفيق السويدي وبمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة
الجلسة السيدة منيرة المانعي.

«حيث إعتبرت محكمة القرار المطعون فيه أن عملية تفتيش محل سكني
المعقب ضده تمت بدون إذن كتابي من النيابة العمومية بعد ورود معلومات على
مأموري الضابطة العدلية مفادها تحوز المذكور بكمية من مادة القنب الهندي
بمحل سكنه وهو معروف لديهم بالإتجار في تلك المادة وهو ما لا يشكل حالة

تلبس وفقا للتعريف الوارد بالفصل 33 م إ ج وخلصت إلى ضرورة الحصول على إذن كتابي لتفتيش محلات السكنى في جرائم المخدرات في غير حالات التلبس والذي هو إجراء أساسي يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات طبقاً لأحكام الفصل 199 م إ ج وأُسست حكمها بناء على ذلك التسيب.

وحيث وخلافا لما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه فقد تبين مما له أصل ثابت بأوراق الملف ضبط كمية من القنب الهندي من قبل الضابطة العدلية داخل محل سكنى المتهم تبين أنها مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب».

وحيث أن مسك المادة المخدرة المدرجة بالجدول «ب» في غير الأحوال المسموح بها قانوناً بنية إستهلاكها أو بنية الإتجار فيها يعد جريمة مستمرة طالما إستمرت الحيازة ومتى تم الكشف عنها فإن مرتكبها يعتبر متلبساً بها على معنى الفصل 33 أولاً من م إ ج ضرورة وأن مقارفته للفعل الإجرامي ومباشرته له تستمر بإستمرار حيازته لتلك المادة المعدة منه لأحد الأغراض المذكورة.

وحيث يراد بالتلبس التعاصر أو التقارب بين زمنين زمن إرتكاب الجريمة وزمن إكتشافها وهو ما يخول في هذه الحالة سلطات إستثنائية لمأموري الضابطة العدلية.

وحيث أن السرعة التي تقتضيها حالة التلبس توجب تخويل مأموري الضابطة العدلية على سبيل الإستثناء التحرك التلقائي دون إنتظار الإذن الكتابي من النيابة العمومية وحتى لا تضيق معالم الجريمة وأدلتها ويفر الجاني وهو ما كرسه المشرع صلب الفصل 23 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 / 5 / 1992 والذي أحال في صورة التلبس إلى الفصل 94 من م إ ج الذي خول لمأموري الضابطة العدلية في صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها تفتيش محلات السكنى دون حاجة للحصول على إذن كتابي من النيابة العمومية.

وحيث وطالما أن الأمر على ما ذكر فإن محكمة القرار المطعون فيه تكون قد أساءت إستخلاص النتائج القانونية السليمة من الوقائع المعروضة عليها حينما إعتبرت خروج حالة المعقب ضده عن حالات التلبس ورتبت الأثر على ذلك بالتصريح ببطلان الإجراءات الأمر الذي أورث قضائها الخطأ في تطبيق القانون الموجب للنقض.

وحيث تعين بناء على ما تقدم نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب مع الإحالة».

11-2-36 المكلف العام ينوب المؤسسات التي لم يسند لها القانون حق تمثيل نفسها

قرار تعقيبي عدد 91943 بتاريخ 25 نوفمبر 2020 صادر عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين منذر الهذيلي وتوفيق السويدي بمحضر المدعي العام السيد رياض الغربي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

« حيث وخلافا لما دفعت به نائبة الطاعن فإن ممثل إدارة الغابات ينوب عن الإدارة لدى المحاكم الجزائية للدفاع عن مصالحها وله الصفة للقيام بالحق الشخصي التي تمكنه من القيام مباشرة لدى المحاكم دون حاجة للإستعانة بالمكلف العام بنزاعات الدولة طبق ما يخوله الفصل 141 من مجلة الغابات ذلك أن المشرع أوكل للإدارة العامة للغابات وحدها حق معاينة الجرائم المرتكبة وإجراء المصالحة في شأنها والقيام بالحق الشخصي دون أي إشارة لنيابة المكلف العام بنزاعات الدولة وإن النص العام الوارد به القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 17/3/1988 ولئن أوجب في الفصل الأول منه أن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل الدولة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية لدى المحاكم فإن الفصل يهتم المؤسسات التي لم يسند لها القانون حق تمثيل نفسها بمقتضى نصوص خاصة وهذا الرأي قرره الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بموجب قرارها عدد 92084 بتاريخ 11/6/1998 وقرارها عدد 103967 بتاريخ 8/7/1999 الأمر الذي يتعين معه ردّ هذا الدفع لعدم وجاهته.

وحيث وبخصوص الدفع المتعلق بحجية المحضر سند الدعوى فقد نص الفصل 113 من مجلة الغابات على أن معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة والبحث فيها منوط بعهدة أعوان الغابات كما نص الفصل 114 من نفس المجلة على أنه: «يقع إثبات المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة بمحاضر أو شهادة شهود في صورة عدم وجود المحاضر أو إذا كانت تلك المحاضر غير كافية» وأنه رجوعا إلى المحضر المحرر في الواقعة موضوع قضية الحال يتبين

وأن معاينة الجنحة قد تمت من قبل عونين تابعين لإدارة الغابات .وقد نص الفصل 117 من مجلة الغابات على أن: « المحاضر الممضاة من طرف عونين شاركوا في معاينة المخالفة معتمدة إلى أن يقع القيام بدعوى التدليس ضدها أما المحاضر الممضاة من طرف عون فهي تعتمد أيضا ما لم يقع الإدلاء بحجة مضادة للأعمال المادية التي تضمنتها». وعليه وطالما لم يأتي الطاعن أمام محكمة القرار المنتقد بما يخالف فحوى ذلك المحضر فإن إعتداد تلك المحكمة له لا مأخذ عليها فيه واتجه ردّ هذا الدفع أيضا لعدم وجاهته.

وحيث لم ينهض من الأوراق ما يوجب نقض القرار المطعون فيه لأمر يهم النظام العام مما يتعين معه بناء على جميع ما سلف بسطه ردّ الطعن تصريحاً برفض أصلاً.

وحيث يتجه حيز معلوم الخطية المؤمن طبق الفصل 263 م إ ج».

مختارات من طلبات الادعاء العمومي

- قضية عدد 24127 - دعوة الدوائر المجتمعة لتوحيد الآراء -
مدى قابلية القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام للطعن فيها
بالتعقيب حال أنها ليست صادرة في الأصل ولا هي نهائية -
التمديد في قرار الإيقاف التحفظي

«[...] أولا : من حيث الشكل :

حيث تعلق الطعن بالتعقيب في قضية الحال بالقرار الصادر عن دائرة الاتهام
بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 481 بجلسة يوم 02 / 06 / 2021
والقاضي: «قبول مطلب الاستئناف شكلا ورفض مطلب الإفراج المقدم في حق
المظنون فيه ن.ق وإرجاع القضية إلى السيد قاضي التحقيق المتعهد لصياغة قرار
تمديد في فترة الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر ابتداء من 05 / 05 / 2021»

وحيث يتبين من القرار المذكور أنه لم يكن صادرا في الأصل، أي في أصل
التهمة المتعلقة بها الدعوى العمومية، وإنما كان متعلقا بالنظر استثنائيا في «قرار
رفض الإفراج عن المظنون فيه» صادر عن قاضي تحقيق في قضية كانت ولا
زالت جارية لديه، ولم يكن نهائيا إذ هو قابل للمراجعة وللرجوع فيه في كل وقت.
وحيث اقتضى الفصل 120 من م.إ.ج أنه: «يقع الإعلام بقرارات دائرة الاتهام
طبق أحكام الفصل 109 ويمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب الشروط المقررة
بالفصل 258 وما بعده من هذا القانون».

وحيث ورد بالفصل 258 من م.إ.ج أنه: «يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام
بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك
بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في
تطبيقه:

- (1) المحكوم عليه
- (2) المسؤول مدنيا.
- (3) القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية.
- (4) وكيل الجمهورية.
- (5) الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الاستئناف.
- (6) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على الأمر الصادر له من كاتب الدولة للعدل...»

وحيث نصّ الفصل 259 من نفس المجلة على أن: «القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجنائية أو على حاكم الناحية لا يمكن الطعن فيه لدى محكمة التعقيب إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها».

وحيث يتبين من الفصول 120 و258 و259 ما يلي :

أولا : أن تعقيب قرارات دائرة الاتهام يجب أن يكون خاضعا للشروط المقررة بالفصل 258 التي حددت:

أ- القرارات القابلة للطعن بالتعقيب: وهي بصريح عبارة النص «القرارات الصادرة في الأصل نهائيا».

وهو ما يترتب عليه بالضرورة وبداهة استبعاد القرارات غير الصادرة في الأصل وكذلك القرارات غير النهائية من دائرة الطعن بالتعقيب، ومنها القرارات المطعون فيها الآن، لكونها لا هي متعلقة بالأصل الذي هو توجيه التهمة أو حفظها، ولا هي نهائية، بحكم إمكانية الرجوع فيها ومراجعتها في أي وقت.

ب- الأطراف المخول لهم ممارسة ذلك الطعن: وهم الذين عددهم النص حصرا.

ج- الأسباب التي يجب أن يتأسس عليها الطعن.

وحيث أن ما ورد بمستندات التعقيب من حصر وقصر لعبارة: «حسب الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من هذا القانون» الواردة بالفصل 120 من م إ ج على الشروط المتعلقة بأسباب الطعن، وإهمال باقي الشروط الأخرى وهي المتعلقة بالقرارات القابلة للتعقيب وبالأطراف المخول لهم ممارسة ذلك الطعن فيه مخالفة للنص يترتب عنها إفراغه من محتواه، كما ينجر عنها انحراف بإرادة المشرع.

ثانياً: أنّ القرارات الصّادرة عن دائرة الاتّهام بالحفظ أو بالإحالة على الدائرة الجنائية، قابلة دائماً للطعن فيها بالتعقيب لتوفّر الشرطين المستمدين من عبارة «الصّادرة في الأصل نهائياً» الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 258

ثالثاً: عدم قابلية قرارات دائرة الاتّهام الصّادرة بالإحالة على محكمة الناحية أو على المحكمة الجناحية للطعن فيها بالتعقيب إلا في حالتين فقط وردتا بالفصل 259 من م إ ج، ولا موجب لذكرهما.

رابعاً: عدم قابلية سائر القرارات والتدابير الوقية والاحترازية الصادرة عن دائرة الاتّهام للطعن فيها بالتعقيب بالنظر لطبيعتها الوقية التي تجعلها قابلة في كل وقت للمراجعة، ولعدم تعلقها بأصل التهمة حفظاً أو إحالة .

وحيث وبذلك يكون الطعن بالتعقيب في قضية الحال مختلاً شكلاً لتسلّطه على قرارات لا تستجيب لشروط الفصل 258 وما بعده من م إ ج لأنها غير صادرة في الأصل ولا هي نهائية، ولا تقبل بالتالي الطعن فيها بتلك الوسيلة.

وحيث ولتدعيم مطلبهم من الناحية الشكلية فقد استدلّ نائبو المعقبين بجملة من القرارات التعقيبية، رأوا أنها كانت قضت بقابلية قرارات دائرة الاتهام غير الصادرة في الأصل للطعن بالتعقيب، وهي القرارات التالية:

1- القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 5088 بتاريخ 3 ديسمبر 1966 .

2- القرار التعقيبي عدد 5499 الصادر في 13 نوفمبر 2012 .

3- والقرار التعقيبي عدد 96778 الصادر في 9 أكتوبر 2019 .

4- القرار التعقيبي عدد 2354 الصادر في 23 / 05 / 2012 (و الذي تبين أنه في الحقيقة متعلق بتعقيب قرار استثنائي جناحي صادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة 2 تحت عدد 63 بتاريخ 22 / 2 / 2013، واتجه لذلك استبعاده من دائرة المناقشة).

وحيث أنّ الاستدلال بالقرارات المذكورة مردود من وجهين، الأول عام ينسحب عليها جميعا، والثاني خاص متعلق إما بالأول منها بمفرده، وإما بالثاني والثالث معا ودون الأول:

الوجه الأول: وهو المنطبق عليها جميعا، ويتعلق بكونها قد جاءت كلّها في مخالفة للعبارة الواضحة والصريحة لنصّ الفصل 258 م إ ج الذي جاء فيه أنه «يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا»، إذ أنّ عبارة القانون الواضحة والصريحة أولى بالاعتماد من العمل القضائي المخالف لها، وأبعد من أن يُلتجأ فيها إلى التأويل.

الوجه الثاني:

- في خصوص القرار التعقيبي عدد 5088 الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 3 / 12 / 1966: فيلاحظ بشأنه أنه جاء مبنيا على فهم وتطبيق للفصل 170 من قانون المرافعات الجنائية آنذاك المغاير لأحكام الفصلين 120 و 258 من م إ ج الحاليين، اللذين صدرا في تاريخ لاحق (24 جويلية 1968) وألغيا وعوضا القانون المذكور، ولا يصلح فهم وتطبيق محكمة التعقيب المزامن له لأن يُعتمد في فهم النصوص الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية.

- في خصوص القرارين التعقيبيين عدد 5499 الصادر في 13 / 11 / 2012 وعدد 96778 الصادر في 9 / 10 / 2019:

حيث يتبين من مراجعة القرارين المذكورين أنهما وحين نظرهما في المسألة، قد اشتركا في إغفال الوقوف على عبارة: «الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا» الواردة بالفصل 258 من م إ ج، كما اشتركا في إهمال ترتيب الآثار القانونية لتلك العبارة بما يحول دون إمكانية الاستدلال بهما في المسألة من جهة

أولى، وكذلك دون اعتبارهما حجة على مُراد واضع الفصل 258 من م إ ج لعدم استيعابهما لكامل عباراته من جهة ثانية.

وحيث ومن جهة أخرى، وخلافا لما ذهب إليه نائبو المعقبين، فإن قراءة الفصل 259 من م إ ج لا يمكن أن تكون بمعزل عن الفصل 258 من نفس المجلة، لأن مؤسسة التعقيب في المادة الجزائية، سواء من حيث هي كوسيلة طعن غير عادية، أو في خصوص ما أراده لها المشرع من شروط، لم ترد إلا في الفصل 258 المذكور الذي يترتب على استبعاده استبعاد الوسيلة برمتها.

وحيث ومن جهة ثالثة، فقد استدل نائبو المعقبين على قابلية بطاقات الإيداع المطعون فيها للطعن بالتعقيب بما أوجبه أحكام الفصل 85 من م إ ج من تعليل كل قرارات الإيقاف التحفظي، معتبرين أن التعليل يقتضي دائما المراقبة.

وحيث وخلافا لذلك، فإن الادعاء العام يلاحظ أن التعليل لا يعني بالضرورة الخضوع للمراقبة، وأن اشتراط التعليل يرمي إلى تحقيق غايات أخرى، بالإضافة إلى ما يرمي إليه من تسهيل المراقبة حين تسمح بها الإجراءات، وهو مشروط في كل القرارات القضائية، حتى ولو كانت لا طعن فيها ولا مراقبة عليها، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع قرارات محكمة التعقيب.

فاشترط التعليل يدفع بالقاضي إلى الإلمام بالملف ووقائعه وأوراقه، والتمعن في النصوص القانونية المنطبقة عليه، حتى يتمكن من اتخاذ القرار الصائب واقعا وقانونا، وحتى إذا ما أوشك على اتخاذ القرار الخاطئ فإنه يعسر عليه تعليله، فيتراجع عنه قبل المضي فيه، ويسدّ النظر فيما هو معروض عليه.

كما أن اشتراط التعليل يبعث الأمان في نفس المتقاضى لعلمه بأن ما قد يقع اتخاذه من قرارات بشأنه لن يكون مبني على الارتجال أو الانطباعية، وإنما سيكون معلّلا ومؤسّسا على أسباب قانونية وواقعية ثابتة بالملف تبرّره. وذلك كله فضلا على ما تبعثه القرارات القضائية المعلّلة من طمأنينة لدى كل من قد يطّلع عليها بوقوفه على أسبابها ومبرراتها.

وحيث ولكل ذلك، فإن الادعاء العام يرى عدم قابلية قرارات دائرة الاتهام غير الصادرة في الأصل نهائيا للطعن فيها بالتعقيب، كما هو الحال بالنسبة إلى

القرارات المطعون فيها في هاته القضية، وهو الرأي الذي استقرت عليه محكمة التعقيب في السواد الأعظم من قراراتها منذ إلغاء قانون المرافعات الجنائية القديم وتعويضه بمجلة الإجراءات الجزائية الحالية في 24 جويلية 1968.

ثانيا وبصورة احتياطية

حيث تنحصر المسألة القانونية المطروحة على مستوى الشكل في قضية الحال في مدى قابلية القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام للطعن فيها بالتعقيب حال أنها ليست صادرة في الأصل ولا هي نهائية.

و حيث تنظم المسألة القانونية المذكورة النصوص التالية :

الفصل 120 من م إ ج : « يقع الإعلام بقرارات دائرة الاتهام طبق أحكام الفصل 109 ويمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من هذا القانون ».

الفصل 258 من م إ ج « يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه:

(1) المحكوم عليه

(2) المسؤول مدنيا.

(3) القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية.

(4) وكيل الجمهورية.

(5) الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الاستئناف.

(6) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على الأمر الصادر له من

كاتب الدولة للعدل...»

وحيث وبالرجوع إلى القرارات الصادرة عن محكمة التعقيب يتبين أن الغالبية الساحقة منها قد كانت، ومنذ إصدار مجلة الإجراءات الجزائية في 24 جويلية 1968، مستقرة على اعتبار أن الطعن في قرارات دائرة الاتهام لا يكون مقبولا إلا إذا كانت تلك القرارات صادرة في الأصل، أي في أصل التهمة موضوع

التتبع، ونهائية أي منهية للنزاع بشأنها على مستوى الطور التحقيقي (ومنها القرار التعقيبي عدد 37344 المؤرخ في 18 ديسمبر 2015 والقرار التعقيبي عدد 95439 المؤرخ في 13 سبتمبر 2019).

وحيث ومع ذلك فقد صدرت عن محكمة التعقيب، وفي نفس المسألة القانونية، بعض القرارات التي خالفت ذلك الاتجاه، ونحت في الموضوع منحى مغايرا أساسه القول بقابلية القرارات المذكورة للطعن فيها بالتعقيب رغم عدم صدورها في الأصل ورغم إمكانية مراجعتها أو الرجوع فيها في كل وقت (ومنها القرار التعقيبي عدد 5499 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 والقرار التعقيبي عدد 96778 المؤرخ في 9 أكتوبر 2019 وكذلك القرار التعقيبي عدد 40002-40061 الصادر في 29/01/2020).

وحيث أن القرارات الأخيرة في الذكر، ورغم عددها الضئيل، فقد عكرت صفو استقرار الرأي الذي كان ولا زال هو السائد على نحو أصبح يؤكّد وجود اختلاف في الآراء بخصوص المسألة الشكلية المطروحة بلغ حدّ التضارب والتناقض كما لو كان الأمر متعلّقاً بنظامين قانونيين مختلفين وليس بنظام قانوني واحد .

وحيث أنّ دور محكمة التعقيب هو مراقبة حسن تطبيق القانون على نحو واحد من طرف جميع المحاكم وعلى جميع المتقاضين.

وحيث وحتى تستطيع محكمة التعقيب أداء ذلك الدور الرئيسي والهامّ فلا بد لها من أن تكون الآراء القانونية الصادرة عنها بدورها موحّدة لا يشوبها التضارب ولا يُعيبها التناقض، وذلك كله بغاية إخضاع الكافة لنظام قانوني موحّد نصا وفهما وتطبيقا.

وحيث ولتحقيق تلك الغاية جاء الفصل 275 من م ا ج ناصّا على ما يلي :
«تجتمع الدوائر المجتمعة أيضا كلما كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين مختلف الدوائر».

وحيث سبق لإحدى الدوائر بمحكمة التعقيب أن رفضت طلب إحالة الملف المحال عليها على الدوائر المجتمعة لتوحيد الآراء القانونية طبقا لأحكام الفصل 275 من م ا ج، وعللت رفضها ذاك بأن دعوة الدوائر المجتمعة لتوحيد الآراء

القانونية «تدخل ضمن صلاحيات الرئيس الأول ودون توقف على وجود قضية منشورة في الموضوع من عدمه».

وحيث أنّ ما ذهبت إليه الدائرة المذكورة من عدم جواز انعقاد الدوائر المجتمعة لتوحيد الآراء القانونية بمناسبة وجود قضية منشورة في الموضوع هو رأي مجانب للصواب، ذلك أنّ الفصل المشار إليه قد نص على ما يلي «تجتمع الدوائر المجتمعة أيضا كلما كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين مختلف الدوائر»، وهو بذلك لم يشترط أن تكون الدعوة لذلك الاجتماع مطلقة ودون ارتباط بملف منشور، كما أنه لم يمنع قيامها بمناسبة النظر في ملف معروض أمام محكمة التعقيب، لاسيما وأن مجلة الإجراءات لم تمنع من أن تكون تلك الدعوة الصادرة من الرئيس الأول قد جاءت بناء على اقتراح من دائرة متعہدة بملف يطرح إشكالية تضاربت الآراء بشأنها، أو من الادعاء العام.

وحيث، وبصرف النظر عن موقف الدائرة المتعہدة من وجوب أو عدم وجوب انعقاد الدوائر المجتمعة لمواجهة التضارب في الآراء الحاصل بين الدوائر التعقيبية بخصوص الإشكالية الإجرائية المطروحة في هذا الملف، فإن الادعاء العام يؤكد على أنّ في الاختلاف الحاصل بين مواقف الدوائر التعقيبية بخصوص المسألة الإجرائية المطروحة، نيلا كبيرا من وحدة المنظومة القانونية ومن مبدأ المساواة بين المتقاضين يوجب بالضرورة تفعيل أحكام الفصل 275 من م.أ.ج لتوحيد الرأي القانوني بين الدوائر.

ثالثا من حيث الأصل وبصورة احتياطية جدا:

حيث نعي نائبو المعقب على القرار المطعون فيه ما يلي :

المطعن الأول : خرق القرار المعقب للمقتضيات القانونية المتعلقة بالإيقاف التحفظي والتمديد فيه : قد جاء المطعن في ثلاثة فروع وهي :

1) مخالفة مقتضيات الفصل 85 من م.أ.ج : وذلك حين اعتبرت، أي دائرة الاتهام، أنّ عدم التمديد في فترة الإيقاف التحفظي بعد مرور ستة أشهر لا يترتب عنه وجوبا للإفراج عن المظنون فيه طالما أنّه لم يبلغ الأربعة عشر شهرا التي هي

الحالة الوحيدة التي يتحقق فيها الإفراج الوجوبي، وهو رأي ليس له سند، ويفرغ الفصلين 85 و 86 من مضمونهما ويجعل التمديد في الإيقاف التحفظي مجرد إجراء بلا جدوى، مع ما يترتب على ذلك من حرمان النيابة العمومية والمتهم من ممارسة ما لهما من حقوق إزاء إجراء التمديد ومن الضمانات التي جاء بها القانون للطعن فيه، فضلا على أنه، أي القرار المطعون فيه، قد منح لدائرة الاتهام صلاحية بدون نص وهي اتخاذ قرار التمديد في بطاقة الإيداع.

(2) مخالفة مقتضيات الفصول من 116 إلى 119 من م.أ.ج: وذلك لما ترتب عن القرار المطعون فيه من منح دائرة الاتهام صلاحية إصدار قرار بالتمديد في الإيقاف التحفظي دون نص .

(3) مخالفة أحكام الفصل 199 من م.أ.ج: وذلك بمقولة إن ما ذهبت إليه دائرة الاتهام مخالف للإجراءات الأساسية (لما فيه من استبعاد لإجراءات التمديد وشروطه وصيغته)، ولمصلحة المتهم الشرعية (بسبب إبقائه في سجنه حال أن مدة الإيقاف التحفظي قد انتهت بمجرد استكمال الستة أشهر دون تمديد)، وللنظام العام (لتعلق الأمر بالحريات).

المطعن الثاني: مخالفة قواعد تأويل النصوص القانونية :

وقد جاء المطعن في ثلاثة فروع ويقوم على أن قول دائرة الاتهام بأن الإفراج لا يتوجب على قاضي التحقيق إلا في صورة تجاوز المدة القصوى المقدرة بأربعة عشر شهرا فيه :

(1) مخالفة مقتضيات الفصل 533 من م.أ.ع ومبدأ التأويل الضيق للنص الجزائي: بمقولة إن الفصل 533 المذكور يقتضي جريان عبارة الإفراج الوجوبي التي وردت بالقانون مطلقة على إطلاقها.

(2) مخالفة مقتضيات الفصل 540 من م.أ.ع: بمقولة إن الإيقاف التحفظي قد ورد محددًا بستة أشهر، وأن الإفراج عن المظنون فيه الموقوف بعد تلك المدة، ودون تمديد، هو في حكم الوجوب، وإلا وقع مجاوزة القدر المحصور من حيث مدته، وهو ما تم في قضية الحال في مخالفة للفصل المذكور.

3) مخالفة أحكام الفصل 541 من م.أ.ع وقاعدة تأويل النصوص الجزائية لصالح المتهم : لما فيه من تشديد وتفسير وتضييق.

المطعن الثالث : ضعف التعليل :

بمقولة إنّ دائرة الاتّهام ولئن نصّت على أنّ لها سلطة رقابية على سلامة الإجراءات وصحتها، فإنّها لم تبين الأساس القانوني الذي يخولها تدارك تلك الإخلالات الإجرائية المتعلقة في قضية الحال بعدم اتخاذ قرار التمديد في الإيقاف التحفظي، وهو ما يترتب عنه ضعف في التعليل، فضلا على ما فيه من خلط بين مفهوم الخلل الإجرائي وبين وقائع القضية المتعلقة بإجراء أساسي يهم الحقّ في الحرّية الذي يكفله القانون.

رأي الادّعاء العام

عن المطعن الأول : خرق القرار المعقب للمقتضيات القانونية المتعلقة بالإيقاف التحفظي والتمديد فيه : قد جاء المطعن في ثلاثة فروع وهي :

1) مخالفة مقتضيات الفصل 85 من م.أ.ج : وذلك حين اعتبرت، أي دائرة الاتّهام، أنّ عدم التمديد في فترة الإيقاف التحفظي بعد مرور ستة أشهر لا يترتب عنه وجوبا الإفراج عن المظنون فيه طالما أنّه لم يبلغ الأربعة عشر شهرا التي هي الحالة الوحيدة التي يتحقّق فيها الإفراج الوجوبي، وهو رأي ليس له سند، ويفرغ الفصلين 85 و86 من مضمونهما ويجعل التمديد في الإيقاف التحفظي مجرد إجراء بلا جدوى، مع ما يترتب عليه من حرمان النيابة العمومية والمتهم من ممارسة ما لهما من حقوق إزاء إجراء التمديد ومن الضمانات التي جاء بها القانون للطعن فيه، فضلا على أنّه منح لدائرة الاتّهام صلاحية بدون نصّ وهي اتخاذ قرار التمديد في بطاقة الإيداع.

حيث وكما ورد بمستندات التعقيب، فإنّ القرار الصادر عن دائرة الاتّهام والمتضمن القول بـ «أنّ عدم صدور قرار من السيد قاضي التحقيق المتعهد بالتمديد في فترة الإيقاف التحفظي بعد مرور ستة أشهر لا يترتب عنه الإفراج وجوبا عن المظنون فيه باعتبار أنّ الإفراج الوجوبي الذي نصّ عليه الفصل 85

المذكور يتعلق بالمدة القصوى للإيقاف التحفظي المقدّرة بأربعة عشر شهراً» هو قرار :

— مخالف لمقتضيات الفصل 85 من م.ا.ج الذي نصّ في فقرته الثانية على عدم جواز تجاوز الإيقاف التحفظي الستّة أشهر، وهو ما لا يسع قاضي التحقيق معه، وبعد انقضاء المدة المذكورة إلا توخي أحد سبيلين : إمّا الإفراج عن المتهم وجوباً لانتهاؤ مدّة الإيقاف التحفظي، وهو الأصل، وإما التمديد فيه قبل انتهاء اليوم الأخير من أيام الفترة الأولى، متى اضطرّته مصلحة البحث إلى ذلك، وبقرار معلّل بعد أخذ رأي النيابة العمومية، حسب باقي الشروط الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 85 م.ا.ج، وعليه إعلام المظنون فيه الذي له حق الطعن في قرار التمديد، ولما لم يحصل أيّ إجراء تمديد فقد بات من الواجب على قاضي التحقيق ومن بعده دائرة الاتّهام إعمال أحكام الفصل 199 والفقرة الثانية والثالثة من الفصل 85 م.ا.ج إزاء إيقاف تحفظي بلغ منتهى مدته ولم يقع التمديد فيه في آجاله .

— مخالف لمقتضيات الفصول من 116 إلى 119 من م.ا.ج لكونه أعطى دائرة الاتّهام صلاحية لم ترد بالفصول المذكورة التي تنظّم صلاحيات الدائرة.

— مخالف لأحكام الفصل 199 من م.ا.ج التي قضت ببطلان كل الأعمال والأعمال المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، وذلك لكون مسألة الحريات وإجراءات المحاكمات هي من القواعد الإجرائية الأساسية وتهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، لقداسة مبدأ الحرية التي أوكل الفصل 102 من الدستور للسلطة القضائية (و منها دائرة الاتّهام) واجب حمايتها، وبات المطعن والحالة تلك في طريقه وتعين طلب قبوله.

عن المطعن الثاني : القائم على القول بمخالفة قرار دائرة الاتّهام لقواعد تأويل النصوص القانونية (بجميع فروعه لارتباطها واتحاد القول فيها :

حيث أن ما ذهبت إليه دائرة الاتّهام من القول بأن تجاوز الإيقاف التحفظي ستة أشهر دون تمديد لا يترتب عليه الإفراج وجوباً هو تأويل خاطئ لأحكام الفصل 85 المذكور لما فيه من تجاوز للعبارة المطلقة للنص القانون ولما فيه من شدة

وزيادة في الاستثناء ومن تفسير على المتهم، وهو بذلك مخالف لأحكام الفصول 533 و 540 و 541 من م.إ.ع وتعين طلب قبول المطعن الثاني.

المطعن الثالث : ضعف التعليل : وهو القائم على القول بأن دائرة الاتّهام ولئن نصّت على أنّ لها سلطة رقابية على سلامة الإجراءات وصحتها، فإنّها لم تبين الأساس القانوني الذي يخولها تدارك تلك الإخلالات الإجرائية المتعلقة، في قضية الحال بعدم اتخاذ قرار التمديد في الإيقاف التحفظي، وهو ما يترتب عنه ضعف في التعليل، فضلا على ما فيه من خلط بين مفهوم الخلل الإجرائي وبين وقائع القضية المتعلقة بإجراء أساسي يهم الحقّ في الحرية الذي يكفله القانون: حيث جاء المطعن في فرعين، ويرى الادّعاء العام أن الفرع المتعلق بضعف التعليل في غير طريقه إذ أن الفصول من 116 إلى 119 من مجلة الإجراءات الجزائية قد تضمنت الأساس القانوني لصلاحيّة دائرة الاتّهام في مراقبة أعمال قاضي التحقيق والحرص على سلامة الإجراءات والأعمال الصادرة عنه، ولا يرى الادّعاء العام في عدم التنصيص عليها أيّ ضعف في التعليل وتعين لذلك طلب ردّ المطعن من هاته الناحية لعدم الوجاهة.

وحيث وفي خصوص الفرع الثاني من المطعن وهو المتعلق بما في قرار دائرة الاتّهام من خلط بين مفهوم الخلل الإجرائي وبين وقائع القضية المتعلقة بإجراء أساسي يهم الحقّ في الحرية : حيث لا جدال في أن القرار المطعون فيه خلط بين الحرص على حسن تطبيق القانون وبين إضفاء الشرعية على وضعية لا شرعية قانونية لها، إذ أن انتهاء فترة الإيقاف التحفظي، دون تمديد في صيغه القانونية السليمة، هو مسألة واقعية وإجرائية مرتبة لآثارها القانونية، وهي اعتبار المظنون فيه قد أصبح بحالة سراح، وقد تمّ التعرض إلى ذلك عند النظر في المطعن الأول، وبات المطعن الثالث في فرعه الثاني في طريقه وتعين طلب قبوله.

لهاته الأسباب :

فإنّ الادّعاء العام يطلب من جناب الدائرة :

أولا وبصفة أصلية، رفض مطلب التعقيب شكلا .

ثانيا وبصفة احتياطية، عرض الملف على السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لعرض المسألة القانونية المطروحة على مستوى الشكل على الدوائر المجتمعة لتوحيد الآراء القانونية إعمالا لأحكام الفصل 275 من م.ا.ج. ثالثا وفي صورة قبول مطلب التعقيب شكلا، فالنقض والإحالة على ضوء ملاحظتنا أعلاه.

المنتصر بن صفطه

المدعي العام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب «

- قضية عدد 00469 - تعريف الخطأ البين - الخلل الشكلي الجزئي - طعن أحد المعقبين لا يوجب بطلان الطعن برمته - تباين المصالح.

«[...] الإشكال القانوني:

يتعلق الإشكال القانوني في هذا المجال بمعرفة ما إذا كان الخلل الشكلي اللاحق بطعن أحد المعقبين الموجب لرفض مطلب التعقيب شكلا في حق جميع المعقبين يعد غلطا واضحا على معنى أحكام الفصل 192 من م.م.م. ت. من عدمه؟

النقاش والرأي القانوني:

إنّ الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي في مرحلة أولى تحديد مفهوم الغلط الواضح (المبحث الأول)، قبل تناول مسألة تفعيل هذا المفهوم على المعطيات الخاصة بقضية الحال (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مفهوم الغلط الواضح

من المعلوم في هذا الشأن أنّ المشرع ولئن أرسى هاته المؤسسة بموجب القانون عدد 87 المؤرخ في الأول من سبتمبر 1986 والمنقح لمجلة المرافعات المدنية والتجارية، فإنه لم يعرفها، وهناك من حاول حصرها في جانبها الإجرائي معتبرا أنها طعن استثنائي يخول للدوائر المجتمعة في حدود نطاق ضيق مراجعة

قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب(1)، وهناك من اعتبره «آلية إجرائية» ليست البتة درجة من درجات التقاضي وإنما هي إصلاح من نفس المحكمة لقراراتها عن طريق هيئة أعلى من الهيئة التي وقعت في الغلط الواضح، وأن الأمر لا يتعلق في الواقع بطعن آلي بل يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة التعقيب(2)، وقد لا يكون لها نظير في القانون المقارن، ولا يمكن الوقوف على الأسباب التي دفعت المشرع التونسي لاستحداثها والانفراد بها، الأمر الذي يعكس في الواقع «الحذر» الشديد بشأنها(3) والذي يظهر خاصة في كيفية تعاطي فقه قضاء الدوائر المجتمعة معه.

وقد أمكن لفقه قضاء الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب فكّ بعض رموز الغلط الواضح، فقد جاء في أحد قرارات هاته الدوائر: «أنه ولئن لم يعرف المشرع الخطأ البين أو الغلط الواضح فقد استقر فقه قضاء المحكمة على اعتباره خطأ الذي لا يختلف اثنان في ثبوته، فيقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله ذلك الغلط على أن يكون ناشئاً عن مجرد السهو أو الغفلة»(4)،

وقد اعتبرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب أن الغلط الواضح كحالة من حالات الخطأ البين التي وردت على سبيل الحصر صلب أحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعد استثناء من قاعدة لا تعقيب على التعقيب وينبغي الوقوف عند حدوده دون توسع في التأويل باعتباره نصاً استثنائياً(5)، وسيرا على هدي هذا التعاطي الفقهي والفقه قضائي مع مفهوم الغلط الواضح يتجه تناول المعطيات الخاصة بقضية الحال.

المبحث الثاني: تطبيق مفهوم الخطأ البين على وقائع قضية الحال

بمراجعة لائحة القرار المطعون فيه بالخطأ البين يتضح أن الدائرة التعقيبية لم تتعرض لطعن المعقبين ك. وزوجته ن. وأبنائه نادر ونضال وندي ونسرين (الفقرة الأولى) كما اعتبرت أن رفض طعن أحد المعقبين شكلاً يستتبع رده بالنسبة إلى غيرهم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: عدم تعرض القرار الموصوم بالخطأ البين لتعقيب الطاعنين أصحاب مطلب التصحيح

حيث يتضح بمراجعة القرار التعقيبي موضوع الطعن يتضح أن الدائرة التعقيبية لم تتعرض إلى طعن المعقبين ك. وزوجته ن. وأبنائه نادر ونضال وندى ونسرین على الأقل بصفة صريحة ولم تشر إليه لا من قريب ولا من بعيد وكأنه غير موجود أصلاً وهو ما قد يفرض تساؤلاً عن إمكانية الحديث في هذا الشأن على سهو المحكمة على البت في هذا الطعن، وإذا ما سلمنا بذلك فإنه لا مناص من الاعتراف بانبناء القرار التعقيبي المذكور على غلط واضح على معنى أحكام الفصل 192 من المجلة المذكورة موجب لطلب إبطاله.

الفقرة الثانية: رفض طعن أحد المعقبين شكلاً يستتبع ردّه لغيرهم

حيث اعتبرت الدائرة التعقيبية الموصوم قرارها بالخطأ البين أنّ أحد المعقبين وهو المدعو ت. ك. قد توفي قبل تسجيل طعنه بالتعقيب، يضاف إلى ذلك أن المعقبة و. الس. قد عقت القرار الاستئنافي في حق ابنتها القاصرة م. والحال أن هاته الأخيرة قد رشدت، وأنّ اختلال طعن المعقبين المذكورين شكلاً يستتبع ردّه لغيرهما من المعقبين تبعاً لعدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة مستندة في ذلك للفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وهو قول قد سها عن مراعاة الاعتبارين التاليين:

1 - حيث وخلافاً لما انتهت إليه الدائرة التعقيبية بموجب قرارها موضوع مطلب التصحيح فإن ت. ك. وس. س. وإن كانا من ضمن الأطراف التي عقت القرار الاستئنافي المطعون فيه إلا أنّهما يحافظان على صفة البائعين للعقار محل النزاع حال أنّ أصحاب مطلب التصحيح بالخطأ البين وهم ك. الو. وزوجته ن. الخ. وأبنائه الرشد نادر ونضال وندى ونسرین لهم صفة المشترين وهو ما يعكس تباين المصالح بين الطرفين المذكورين حتى وإن كانت لهما صفة المدعى عليهم في دعوى الإبطال المرفوعة من المعقب ضده الأول ن. الح. في الطور الابتدائي، يضاف لذلك أن عريضة الطعن بالتعقيب وإن قدمت في حقهم جميعاً من قبل الأستاذ اله. الع. إلا أن المشترين لموضوع التداعي

المذكورين قد استأثروا في الطور التعقيبي بناية الأساتذة س. و. ون. الج. وم.ج. إضافة للأستاذ الع.، وبالتالي فلا يمكن التسليم بأن ما شاب تعقيب بعض البائعين من إخلالات شكلية يتحمل وزره المشترون رغم عدم ثبوت أيّ تقصير من جانبهم في هذا الشأن في ظل استيفاء طعنهم كافة أوضاعه وصيغته الشكلية على معنى أحكام الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التساؤل يفرض نفسه في هذا المجال: لماذا تتبنى الدائرة التعقيبية المطعون في حكمها فكرة أن الخلل الشكلي الجزئي اللاحق بطعن أحد المعقبين يوجب بطلان الطعن في حق الجميع ودون الخوض في اتحاد ركن المصلحة بينهم من عدمه، ولا تأخذ بفكرة أن استيفاء طعن بعض المعقبين لصيغته الشكلية من شأنه أن يصحح كل خلل شكلي لحق بطعن البعض الآخر خاصة أن ذلك يضمن حفظ حقوق الأطراف على حساب الالتصاق بجمود القواعد الإجرائية على غموضها، فالإجراءات ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي السبيل الذي يتبعه المتقاضي لرفع دعواه أمام محكمة البداية أو الطعن فيها أمام محكمة أعلى درجة (6)، كما أنّ هذا الاتجاه يسمح بتفعيل مقتضيات القاعدة الأصولية مناصب الفصل 541 من مجلة الالتزامات والعقود والتي تنص على أنه « إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعياً لزيادة التضييق أبداً » يضاف لذلك أنه كان من الأجدى في أقصى الحالات ترتيب الأثر القانوني اللازم على كل طرف، فمن استوفى طعنه صيغته الشكلية يصرح بقبوله من الوجهة الشكلية ومن شاب طعنه خلل يقضى برفضه شكلاً، ولا مجال للدائرة التعقيبية للتعلل بعدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة لتبرير تعميمها جزاء الرضا شكلاً ضرورة وأنه لا يمكن مجاراتها في هذا القول بدليل أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بالتعقيب أمام الدائرة التعقيبية المذكورة قد نفت عن النزاع الحالي صفة عدم قابليته للتجزئة من خلال رفض طعن أحد المستأنفين لديها وهي المرأة قمر الأصرم شكلاً وقبوله من هذه الوجهة في حق بقية المستأنفين.

2 - حيث بالاطلاع على لائحة القرار التعقيبي مناط مطلب التصحيح بالخطأ
البين أن المحكمة وفي إطار تبريرها لسحب جزاء الرافض شكلاً لتعقيب كل
من ت. ك. و. س. في حق ابنتها القاصرة م. على طعن بقية المعقبين ومن بينهم
أصحاب مطلب التصحيح قد استندت بصفة خاصة على أحكام الفصل 179 من
مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والحال أن سندها التشريعي المذكور يعدّ
هشاً في هذا الشأن على اعتبار أنّ المشرع قد أرسى صلب هذا الفصل قاعدة
وجوب تعلق موضوع الطعن بسبب يهم الطاعن نفسه مجزاً بصفة استثنائية تعلقه
بسبب يخص غيره من الطاعنين إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة، وأنه لا
يعلم مفهوماً أو توظيفاً آخر للفصل 179 المذكور في الفقه والقضاء (7) كذلك
الذي اعتمده القرار الموصوم بالخطأ البين.

حيث يتحصص من جملة المعطيات القانونية والواقعية المبين سابقاً أن
القرار التعقيبي القاضي برفض طعن المعقبين ك. الو. وزوجته ن. الخ. وأبنائه
نادر ونضال وندى ونسرين شكلاً قد انبنى وبامتياز على غلط واضح على معنى
أحكام الفصل 192 من م. م. م. ت.

وعليه وترتّباً على كل ذلك فإن الادّعاء العام يطلب قبول مطلب تصحيح
الخطأ البين شكلاً وأصلاً وإبطال القرار التعقيبي المدني الصادر بتاريخ 4
نوفمبر 2019 تحت عدد 72631 وإرجاع ملف القضية إلى السيد الرئيس الأول
للإذن بإعادة نشرها أمام دائرة أخرى وإعفاء الطاعنين من الخطية وإرجاع معلومها
المؤمن إليهم.

المدعي العام

حسن الحاج عبد الله

- قضية عدد 00465 - تعريف الخطأ البين - الرفض شكلا لعدم تقديم بطاقتي الإعلام بالبلوغ سهوا.

«[...]الإشكال القانوني:

يتعلق الإشكال القانوني في هذا المجال بمعرفة ما إذا كان رفض الدائرة التعقيبية لطعن نائب المعقين شكلا لعدم تقديمه علامتي البلوغ المتعلقة بالمعقب ضدهما قد انبنى على غلط واضح على معنى أحكام الفصل 192 من م. م. ت. من عدمه

النقاش والرأي القانوني:

إنّ الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي بالضرورة تناول المسألة على مستويين يتعلق الأول بالجانب القانوني الصرف للمسألة وينصرف لتحديد مفهوم الغلط الواضح (المبحث الأول)، فيما يهم المستوى الثاني جانبها الواقعي فيما يخص المعطيات الخاصة بقضية الحال (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مفهوم الغلط الواضح

من المعلوم في هذا الشأن أنّ المشرع ولئن أرسى هاته المؤسسة بموجب القانون عدد 87 المؤرخ في الأول من سبتمبر 1986 والمنقح لمجلة المرافعات المدنية والتجارية، فإنه لم يعرفها، وهناك من حاول حصرها في جانبها الإجرائي معتبرا أنها طعن استثنائي يخول للدوائر المجتمعة في حدود نطاق ضيق مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب(1)، وهناك من اعتبره «آلية إجرائية» ليست البتة درجة من درجات التقاضي وإنما هي إصلاح من نفس المحكمة لقرارها عن طريق هيئة أعلى من الهيئة التي وقعت في الغلط الواضح، وأنّ الأمر لا يتعلق في الواقع بطعن آلي بل يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة التعقيب(2)، وقد لا يكون لها نظير في القانون المقارن، ولا يمكن الوقوف على الأسباب التي دفعت المشرع التونسي لاستحداثها والانفراد بها، الأمر الذي يعكس في الواقع «الحذر» الشديد بشأنها(3) والذي يظهر خاصة في كيفية تعاطي فقه قضاء الدوائر المجتمعة معه.

وقد أمكن لفقه قضاء الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب فكّ بعض رموز الغلط الواضح، فقد جاء في أحد قرارات هاته الدوائر «أنه ولئن لم يعرف المشرع الخطأ البين أو الغلط الواضح فقد استقر فقه قضاء المحكمة على اعتباره الخطأ الذي لا يختلف اثنان في ثبوته، فيقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله ذلك الغلط على أن يكون ناشئاً عن مجرد السهو أو الغفلة» (4)،

وقد اعتبرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب أنّ الغلط الواضح كحالة من حالات الخطأ البين التي وردت على سبيل الحصر صلب أحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعدّ استثناء من قاعدة لا تعقيب على التعقيب وينبغي الوقوف عند حدوده دون توسع في التأويل باعتباره نصّاً استثنائياً (5)، وفي قرار آخر اعتبرت أنّ مناقشة محكمة التعقيب فيما اقتنعت به لا يعد من قبيل الخطأ البين المحدد بالفصل 192 المذكور فالرأي الاجتهادي ولو كان انفرادياً لا يعد خطأ بيناً (6)، كما ذهب في مناسبة أخرى إلى تأكيد هذا التوجه مشيرة إلى «أنّ الرأي القائل باعتبار تقديم كل الوثائق من طرف المعقب في أجل شهر ضروري لصحة التبليغ خصوصاً في حالة غياب المعقب عليه إنّما اجتهاد منفرد من إحدى الدوائر في فهم وتطبيق الفصل 185 من م.م.م.ت. قد لا توافقها عليه بقية الدوائر لكنه لا يوصف بكونه غلطاً مادياً واضحاً» (7)، ذلك «أن تفسير القانون واختلاف الآراء في فهمه وتطبيقه لا يعد من قبيل الغلط المادي وبالتالي لا يدخل ضمن الخطأ البين ولا يستباح لذلك اعتماده سبباً للطعن بهذه الوسيلة المحددة مجالاتها حصراً بمقتضى الفصل 192 من م.م.م.ت.» (8)

وسيرا على هدي هذا التعاطي الفقهي والفقه قضائي مع مفهوم الغلط الواضح يتجه تناول المعطيات الخاصة بقضية الحال.

المبحث الثاني: المعطيات الخاصة بقضية الحال

إنّ الدائرة التعقيبية الموصوم قرارها بالخطأ البين قد عللت رفضها لطعن نائب المعقبين شكلاً بعدم إدلائه بعلاّمي البلوغ المتعلقين باستدعاء المعقب ضدهما، وفي هذا الشأن لا مناص من إبداء الملاحظات التالية:

أولاً: أنّ طعن المعقبين لم يوجه ضد شخصين فقط حتى يتم اشتراط الإدلاء بعلامتي البلوغ الخاصتين باستدعائهما، بل إنّ الطعن قد شمل مجموعة من الأشخاص تمّ حصرهم صلب محضر تبليغ مستندات التعقيب في طرفين أساسيين هما...

ثانياً: أنّ القرار التعقيبي المطعون فيه قد اعتبر أنّ نائب الطاعنين لم يقدم علامتي البلوغ المتعلقتين باستدعاء المعقب ضدّهما والحال أنّ تبليغ مستندات التعقيب لم يتم وفق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 8 من م.م.م.ت حتى تطالب الدائرة التعقيبية بإضافة علامتي البلوغ ضرورة وأنّ التبليغ قد حصل على معنى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 المذكور ذلك أنّ أحد المعقب ضدّهم وهو المدعوّ مصطفى قد تسلم مستندات التعقيب في حق نفسه وفي حق بقية ورثة والده الهادي وأيضاً في حق ورثة عمه صالح بوصفه مميزاً ومساكناً لهم وبعد أن عرّف بهويته لعدل التنفيذ القائم بأعمال التبليغ إثر استظهاره ببطاقة تعريفه الوطنية.

ثالثاً: إنّ المطّلع على لائحة القرار التعقيبي الموصوم بالخطأ البين يلاحظ أنّه قد تضمّن التنصيب على أنّ المعقب ضدّهما هما الهادي وصالح والحال أنّ مستندات الطعن قد بلغت لورثة هذين الأخيرين إثر حصول وفاتهما، ويبدو أنّ الدائرة التعقيبية عند المفاوضة وتحرير لائحة قرارها قد توقفت زمنياً بخصوص من شمله الطعن بالتعقيب عند حدود عريضة الطعن المقدمة لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي المطعون فيه بالتعقيب وهو المركز الفرعي للمحكمة العقارية بالقيروان.

رابعاً: أنّ تقديم نائب المعقبين لتقرير إضافي مُرفق بمؤيدات وإعلام نائبة المعقب ضدّهم به عبر مصالح البريد بموجب جذرين بريدين قد يكون المعطى الذي جعل الدائرة التعقيبية الموصوم قرارها بالخطأ البين تقع في خلط وتعتقد أنّ الجذرين البريدين يتعلّقان بتبليغ مستندات التعقيب ولم يتم الإدلاء بعلامتي البلوغ الخاصتين بهما والحال أنّهما تتعلّقان بتقرير إضافي مقدّم من نائب الطاعنين.

وحيث يتحصص من جملة المعطيات القانونية والواقعية المبينة سابقا أنّ القرار التعقيبي القاضي برفض طعن نائب المعقبين شكلا بتعلة عدم تقديم علامتي البلوغ المتعلقة بالمعقب ضدهما قد انبنى وبامتياز على غلط واضح على معنى أحكام الفصل 192 من م.م.ت.

وعليه وترتبا على كل ذلك فإنّ الادّعاء العام يطلب قبول مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا وأصلا وإبطال القرار التعقيبي المدني الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2019 تحت عدد 63251 وإرجاع ملف القضية إلى السيد الرئيس الأول للإذن بإعادة نشرها أمام دائرة أخرى وإعفاء الطاعنين من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليهم.

المدعي العام

حسن الحاج عبد الله

- قضية عدد 346 - خطأ بين - تطبيق نصّ سبق نسخه

[...] حيث يتضح بمراجعة لائحة القرار الموصوم بالخطأ البين أنّ الدائرة التعقيبية قد انتهت إلى رفض مطلب التعقيب المقدم في حق كل من ط. ب. وم. ر. أصلا بعد اعتبارها أنّ اجتهاد محكمة الاستئناف المطعون فيه لديها والقاضي بثبوت إدانتها من أجل جريمة المشاركة في بيع ما سبق بيعه على معنى أحكام الفصلين 32 و 292 من المجلة الجزائية سليما واقعا وقانونا والحال أنّ هذين النصين التشريعيين قد تمّ نسخهما بصدور النص الأصلي لمجلة الحقوق العينية بموجب القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 والتنقيح الهام المدخل عليها بموجب القانون المؤرخ 4 ماي 1992 تحت عدد 46 والذي أرسى المفعول المنشئ للترسيم. وأنّ النصين الأصلي والتنقيحي لمجلة الحقوق العينية المذكورين قد وردا لاحقين في الزمن للأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 الذي صدرت بمقتضاه المجلة الجزائية. مع الإشارة في هذا الشأن أنّ نسخ القوانين بقوانين أخرى ليس بالضرورة نسخا صريحا من خلال تنقيص المتأخرة

منها على ذلك تنصيحا صريحا بل يمكن أن يكون النسخ ضمينا إذا كانت القوانين اللاحقة في الزمن منافية لما سبقتها أو استوعبت جميع فصولها وهذا ما قرّره المشرع صلب الفصل 542 من مجلة الالتزامات والعقود. والملاحظ في هذا الشأن أن المشرع قد أثر تنظيم التصرفات القانونية المتعلقة بالعقارات المسجلة صلب مجلة الحقوق العينية مكرسا نظام الإشهار العيني الذي يوجب قبل تحرير الصكوك والاتفاقات - من قبل الجهات التي خصها الفصل 377 مكرر من المجلة المذكورة بصفة حصرية بهاته المهمة - بضرورة الاطلاع على الرسم العقاري واعتمادا على ما ضمّن به من بيانات. وترتبا على ذلك، وطالما تعلق البيع بعقار مسجل فإن تحقق أركان جريمة المشاركة في بيع ما سبق بيعه مناط الفصلين 32 و292 من المجلة الجزائية قد أضحي تقريبا أمرا مستحيلا وذلك سواء استوجب التصرف القانوني تطبيق المفعول المنشئ للتسجيل أو إعمال مفعوله الاحتجاجي. فبالنسبة إلى المفعول المنشئ للتسجيل والمنطبق على الرسوم العقارية المحدثة بعد شهر أفريل 1998 فإنه لا يمكن الحديث عن بيع وانتقال ملكية إلا بعد ترسيم العقد بالسجل العقاري ولا يُتصور واقعا وقانونا تفويت شخص في عقار مسجل لفائدة شخص آخر وترسيم هذا الأخير لمشتراه ثم يقوم البائع بإعادة البيع لنفس العقار لشخص ثانٍ ضرورة أنه يستحيل على المالك السابق للعقار إعادة التفويت فيه بعد أن فقد صفة المالك بموجب ترسيم المشتري لمشتراه وأن كل متعامل على العقار سيتحقق من هذه المعطيات بمجرد اطلاعه على البيانات المنصوص عليها بالرسم العقاري للعقار موضوع التعاقد. وإذا ما تعلق الأمر بالمفعول الاحتجاجي للتسجيل والمنطبق على الرسوم العقارية المحدثة قبل شهر أفريل 1998 فإن كلّ مشترٍ لعقار مسجل لا «يؤاخذ» إلا بما تضمنه الرسم العقاري من بيانات دون غيرها من المعطيات الواقعية الأخرى التي قد يحصل له العلم بها بطريقة أو بأخرى. فطالما تأكدت سلامة شرائه للعقار بالاعتماد على بيانات الرسم العقاري التي اطلع عليها محرّر العقد وأعلمه بها، فإنه يعد في مركز الغير حسن النية ويصبح جديرا بالحماية التشريعية التي منحها له الفصل 305 من م.ح.ع. في فقرته الثانية والتي تصل إلى إقصاء كل معارضة له بما في ذلك إبطال

الترسيمات. وأن هذه الوضعية المتميزة لمشتري العقار المسجل تتناقض بشكل أو بآخر مع فكرة إحالته على القضاء الجزائي من أجل جريمة المشاركة في بيع ما سبق بيعه مناط الفصلين 32 و 292 من المجلة الجزائية إذ أن العمليات العقارية التي تتعلق بالعقارات المسجلة إنما تكتسي بامتياز صبغة مدنية بحتة ولا مجال لقبول فكرة نفاذ القانون الجزائي في هذا الشأن. فتتظيم مختلف المراحل التي يمر بها الحق العيني من نشأة وإحالة واستمرار وانقضاء ترجع بالنظر للقانون العقاري ك فرع للقانون المدني دون القانون الجزائي الذي يقتصر دوره في هذا الشأن وفي أقصى الحالات على ضمان فاعلية ونجاعة النظام القانوني الواقع إرساؤه. ولا يمكن القبول ولو عرضيا بفكرة تداخل الوظائف بين القانونين والتسليم بأولوية انطباق القانون الجزائي تحت غطاء استقلاليته.

وحيث يتحصص من كل ذلك أن القرار التعقيبي الموصوم بالخطأ البين لما اعتبر إدانة محكمة الاستئناف للمحكوم عليهما ط. ب. وم. ر. من أجل جريمة المشاركة في بيع ما سبق بيعه مناط الفصلين 32 و 292 من المجلة الجزائية اجتهدا سليما واقعا وقانونا قد اعتمد في نهاية المطاف نصا قانونيا سبق نسخه بموجب النصين الأصلي والتنقيحي لمجلة الحقوق العينية

وحيث وترتبا على كل ذلك، فإن الادعاء العام يطلب من السيد الرئيس الأول قبول مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ م. خ. في حق المحكوم عليهما شكلا وفي الأصل دعوة الدوائر المجتمعة للانعقاد للبت فيه .

المدعي العام

حسن الحاج عبد الله

» [...] حيث لا مناص من التذكير في هذا الشأن أنّ مؤسسة الاستجلاب مناط الفصل 294 المذكور سابقاً تعدّ إجراء استثنائياً لقواعد الاختصاص الترابي العادية للمحاكم الجزائية المبيّنة صلب مجلة الإجراءات الجزائية.

وحيث إنّ الاستجابة لطلب الاستجلاب تقتضي توفّر على الأقل أحد شرطيه المنصوص عليهما بالفصل 294 المذكور سابقاً وهما مراعاة مصلحة الأمن العام ودفع الشبهة الجائزة.

وحيث مما لا شك فيه أن البت في مدى وجهة مطلب الاستجلاب لا يمكن أن يؤدي إلى البحث في حيادية المحكمة أو نزاهتها، وإنما يرمي أولاً وأخيراً إلى الحرص على النأي بالمؤسسة القضائية عن كلّ شبهة ولو كانت منحصرة في أذهان المتقاضين وذلك حفظاً لسمعة القضاء وصوناً لثقة العامة فيه

وحيث إنّ إصرار العارضة على استجلاب قضية ابنها القاصر بناء على ما شهدته من معطيات تتعلق خاصة بنوعية الخروقات التي شابت مسارها الإجرائي وصفة الشاكي كأب لابنها ومباشرته لمهنة المحاماة بالمكان، إضافة إلى تعدّد القضايا الجزائية المثارة بين العارضة وابنها ووالده، إنما يعكس ترسّخاً في ذهنها فكرة تنامي حجم التهديد الذي يستهدف حياة وحقوق ابنها القاصر المذكور، وهو ما يعدّ سبباً معتبراً يبرر الاستجابة لطلبها في الاستجلاب وذلك بقطع النظر عن صحة وجود مثل هذا التهديد من عدمه.

وحيث وترتّباً على ذلك، فإنّ الادّعاء العام يطلب من الدائرة التعقيبىة صاحبة النظر قبول مطلب الاستجلاب شكلاً وأصلاً وسحب القضية الجناحية المنشورة لدى قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تحت عدد 2020 / 35 والمؤخرة لجلسة ليوم 25 سبتمبر 2020 وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة.

المدعي العام

حسن الحاج عبد الله

**- قضية عدد 30951/30950 - القطع التعسفي للعلاقة الشغلية
من الأجير - التنازع بين قواعد مجلة الشغل وقواعد الاتفاقيات
المشتركة**

» [...] رأي الادعاء العام

[...]

ثانيا: من حيث الأصل

عن المطعنين لتداخلهما واتحاد وجه القول فيهما:

حيث وخلافا لما تضمنته مستندات الطعن فإن إثبات القطع التعسفي للعلاقة الشغلية بين العامل والمؤجر القديم لقبول دعوى المطالبة بمنحة التعويض المقامة من هذا الأخير ضد أجيرو والمؤجر الجديد ليس شرطا ضروريا على اعتبار وأن الفصل 44 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك لم ينص على هذا الشرط بل اكتفى بمجرد المغادرة التلقائية للعمل من قبل الأجير في حين أن الفصل 26 من مجلة الشغل يقتضي ثبوت القطع التعسفي لعقد الشغل من قبل العامل. كذلك فإن الفصل 26 ولئن اشترط ضرورة علم المؤجر الجديد بسبق عمل الأجير لدى المؤجر القديم فإن الفصل 44 من الاتفاقية لم يتطرق إلى هذا الشرط أيضا، وهو ما يعكس وجود وضعية تنازع بين القاعدة التشريعية والقاعدة الاتفاقية بما يقتضي تحديد القاعدة التي تحظى بالأولوية في التطبيق مقارنة بنظيرتها. وفي هذا المجال لا مناص من التذكير بأن الاتفاقيات المشتركة هي «اتفاق متعلق بشروط العمل مبرم بين المؤجرين المنظمين لكتلة أو القائمين شخصا من جهة وبين مؤسسة أو عدة مؤسسات نقابية للعمال من جهة أخرى» (الفصل 31 من مجلة الشغل). فهي ثمرة للتفاوض الجماعي بين الفاعلين المهنيين، ولئن تحدث الفقه المقارن والوطني في تناوله للمصادر الشكلية للقواعد القانونية المنظمة للمادة الشغلية عن تكامل بين التشريع والعقد فإنه لم يهمل وضعيات التنافس التي قد يفرزها الواقع بين المصدرين المذكورين (سواء السويسي مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة في إطار الندوة الدولية

حول خمسينية مجلة الشغل التي نظمها المعهد الوطني للشغل يومي 27 و 28 أفريل 2016). وقد تميز دور الاتفاقيات المشتركة بأنه غير محدد بعدم المخالفة المطلقة للتشريع بما أدى إلى نزاع المكانة الثانوية أو الاحتياطية لها في مقارنتها بالتشريع إلى درجة أنها أصبحت تحظى بأولوية في التطبيق طالما كانت في الاتجاه الأصح للأجير، وهي بهذا المنطق تفقد هذه «الشرعية» كلما عجزت عن ضمان الحد الأدنى من الحماية التشريعية العمالية. لذلك فلا غرابة في تنصيب الفصل 42 من مجلة الشغل على عدم جواز مساس الاتفاقيات المشتركة بالحرية النقابية أو بحرية الرأي .

وحيث وبالرجوع إلى وقائع قضية الحال يتّضح أنّ المشرع بالفصل 26 من مجلة الشغل ولئن اشترط القطع التعسفي للعلاقة الشغلية من العامل وعلم المؤجر الجديد بسبق عمل أجيره لدى المؤجر القديم لجواز القيام عليه بدعوى منحة التعويض بالتضامن مع مؤجره الجديد، فإن الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك قد اكتفت بفصلها 44 بمجرد المغادرة التلقائية للعامل دون التطرق لمسألة العلم بالعلاقة الشغلية السابقة، بما يعكس أنّ الاتفاقية قد تضمنت بنوداً أعسر للعامل مقارنة بما قرره التشريع، إذ أجازت مقاضاته ومطالبته بالتضامن مع مؤجره الجديد بدفع منحة التعويض بعد أن أعفت المؤجر - رغم كونه الطرف الأقوى في العلاقة الشغلية الثنائية- من إثبات التعسف في قطع أجيره العمل لديه وعلم المؤجر الجديد بسبق التعاقد الشغلي مع المؤجر القديم وما يستتبعه ذلك بالضرورة من تحميل المؤجر الجديد للقائم بمثل دعوى الحال بعبء الإثبات في هذا الشأن وحشد وسائل الإثبات اللازمة في الغرض، الأمر الذي يقتضي لا محالة استبعاد القاعدة العقدية مناط الفصل 44 من الاتفاقية القطاعية المذكورة من التطبيق على النزاع الحالي باعتبار أنّ إقرارها لم يكن في اتجاه مصلحة العامل ولو لم يكن ذلك ما انصرفت إليه النية الصريحة للطرف الاجتماعي الممثل للعملة عند صياغة هذا البند من الاتفاقية، وأنه يخول للدعاء العام في إطار الالتزام بمقتضيات الفصل 187 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إثارة هذه المسألة ولو لم تتضمنها بصفة صريحة ومباشرة مستندات

الطعن طالما تتصل بتطبيق قواعد مجلة الشغل في بعدها المتصل بالنظام العام الحمائي وخاصة تلك المكرسة لمبدأ تكريس القاعدة الأصلح للأجير على غرار الفصول 14 مكرر و 22 و 333 من هذه المجلة، هذا فضلا على تعارضه و«القاعدة الأصولية والأساسية في مادة الشغل التي تقتضي أن يقع تطبيق القانون أو العقد أو الاتفاقية التي تتضمن أكثر دعما للعامل وتمنحه حقوقا أكثر من غيرها» (قرار تعقيبي مدني عدد 20812 بتاريخ 2 مارس 1992 ن. م. ت 1992 ص 148 - قرار تعقيبي مدني عدد 20814 بتاريخ 2 مارس 1992 ن. م. ت 1992 ص 126)، وهي النتيجة التي لم توفق محكمة القرار المخدوش فيه في الاهتداء إليها بما يجعله حريا بطلب النقض من هذا الجانب.

وحيث ومن جهة أخرى فإن الفصل 26 من مجلة الشغل وهو النص الأوّل في التطبيق على النزاع الحال لم يتضمن التنصيص - في إطار بيان حدود التحجير على العامل في عقد علاقة شغلية جديدة بعد القطع التعسفي لعقد الشغل مع المؤجر القديم - على مسألة العمل بالمقرّات الاجتماعية والمراكز الفنية والوكالات التجارية والإدارية للمؤجر الجديد بما قد يجعل المطعن الدفوعات المثارة من نائب الطاعنة في هذا الشأن غير ذي موضوع وحرية بطلب الالفات عنها، وحيث وترتبا على ذلك، فإنّ الادّعاء العام يطلب:

1 - رفض مطلب التعقيب المقدّم من الاستاذح. شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

2 - قبول مطلب التعقيب المقدّم من مكتب ز.م.م شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بينزرت لإعادة النظر فيه بهيئة أخرى وإعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليها والإذن بإرجاع المبلغ المالي المؤمن بالخزينة العامة بموجب إذن بالتأمين من الرئيس الأوّل للمحكمة إليها.

المدعي العام

حسن الحاج عبد الله



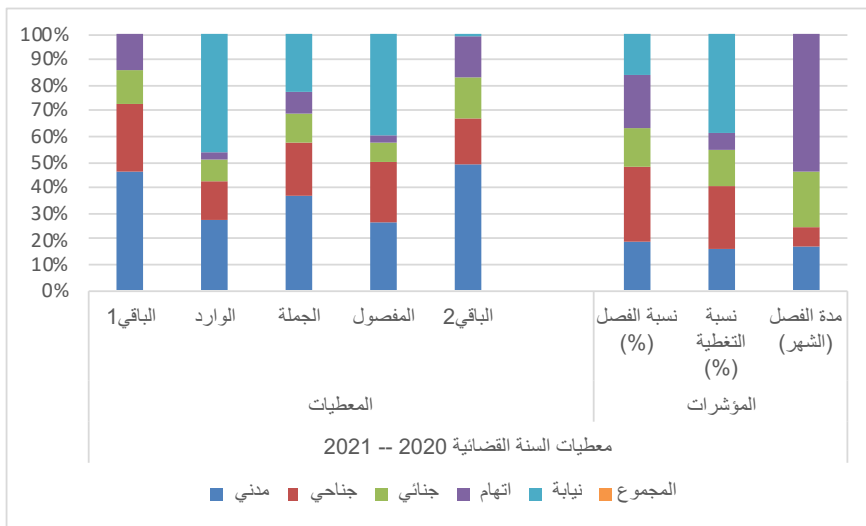
الكتاب الرابع

معطيات إحصائية

توزيع النشاط القضائي لمحكمة التعقيب حسب المادة خلال السنة القضائية 2020 - 2021

معطيات السنة القضائية 2020 - 2021								المادة
المؤشرات			المعطيات					
مدة الفصل (الشهر)	نسبة التغطية (%)	نسبة الفصل (%)	الباقى 2	المفصول	الجملة	الوارد	الباقى 1	
18,0	40,1	112,8	18072	12079	30151	10708	19443	مدني
7,5	61,5	178,4	6587	10542	17129	5910	11219	جناحي
22,2	35,1	88,3	5868	3172	9040	3594	5446	جنائي
55,8	17,7	123,0	5740	1235	6975	1004	5971	اتهام
0,3	97,4	98,3	485	18003	18488	18318	170	نيابة
9,8	55,1	113,9	36752	45031	81783	39534	42249	المجموع

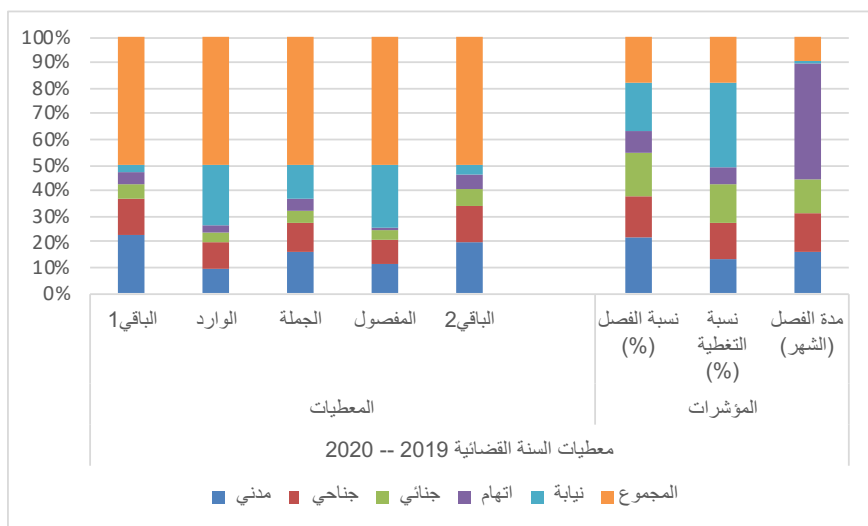
توزيع النشاط القضائي لمحكمة التعقيب حسب المادة خلال السنة القضائية 2020 - 2021



توزيع النشاط القضائي لمحكمة التعقيب حسب المادة خلال السنة القضائية 2019 - 2020

معطيات السنة القضائية 2019 - 2020								المادة
المؤشرات			المعطيات					
مدة الفصل (الشهر)	نسبة التغطية (%)	نسبة الفصل (%)	الباقى 2	المفصول	الجملة	الوارد	الباقى 1	
21,6	35,7	108,3	18951	10514	29465	9708	19757	مدني
20,5	37,0	81,8	13429	7874	21303	9625	11678	جناحي
16,7	41,8	89,5	5347	3838	9185	4289	4896	جنائي
60,6	16,5	41,9	5943	1176	7119	2808	4311	اتهام
1,8	86,8	94,9	3320	21828	25148	23009	2139	نيابة
12,5	49,0	91,5	46990	45230	92220	49439	42781	المجموع

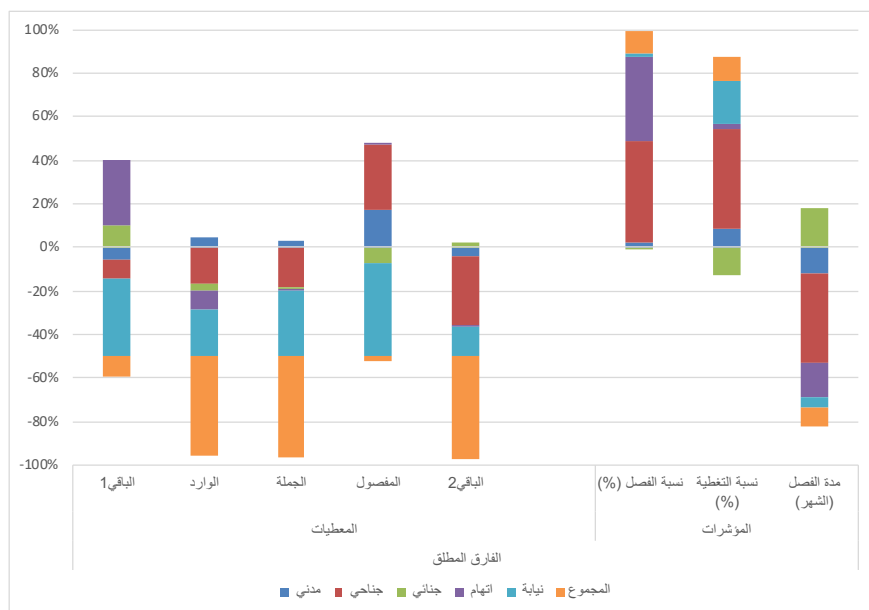
توزيع النشاط القضائي لمحكمة التعقيب حسب المادة خلال السنة القضائية 2019 - 2020



الفارق المطلق للنشاط القضائي لمحكمة التعقيب خلال السنتين القضائيتين: 2019 - 2020 و 2020 - 2021

الفارق المطلق								المادة
المؤشرات			المعطيات					
مدة الفصل (الشهر)	نسبة التغطية (%)	نسبة الفصل (%)	الباقى 2	المفصول	الجملة	الوارد	الباقى 1	
-3,7	4,4	4,5	-879	1565	686	1000	-314	مدني
-13,0	24,6	96,6	-6842	2668	-4174	-3715	-459	جناحي
5,5	-6,7	-1,2	521	-666	-145	-695	550	جنائي
-4,9	1,2	81,1	-203	59	-144	-1804	1660	اتهام
-1,5	10,6	3,4	-2835	-3825	-6660	-4691	-1969	نيابة
-2,7	6,0	22,4	-10238	-199	-10437	-9905	-532	المجموع

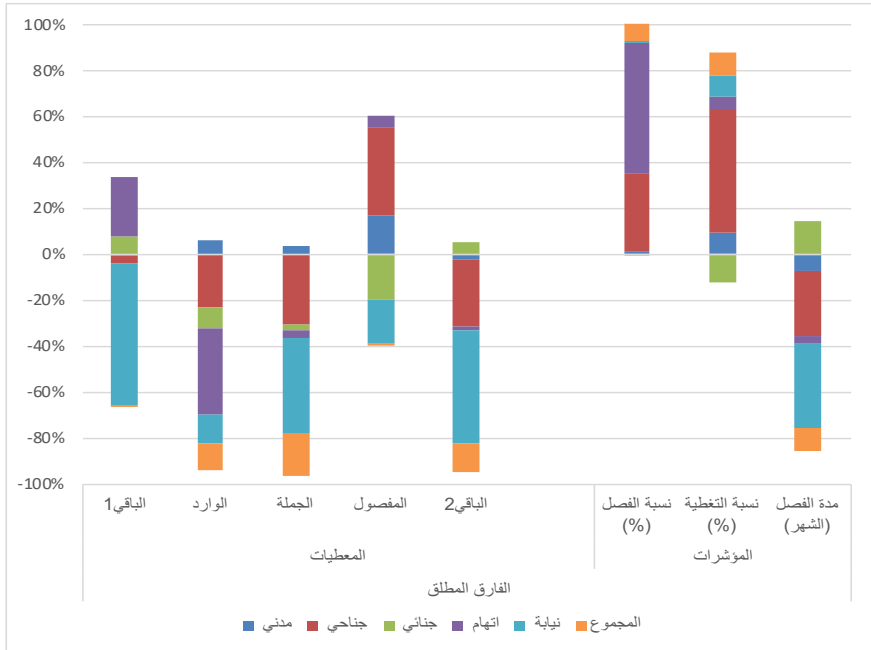
الفارق المطلق للنشاط القضائي لمحكمة التعقيب خلال السنتين القضائيتين: 2019 - 2020 و 2020 - 2021



الفارق النسبي للنشاط القضائي لمحكمة التعقيب خلال السنتين القضائيتين: 2019 - 2020 و 2020 - 2021

الفارق المطلق								المادة
المؤشرات			المعطيات					
مدة الفصل (الشهر)	نسبة التغطية (%)	نسبة الفصل (%)	الباقى 2	المفصول	الجملة	الوارد	الباقى 1	
-17,0	12,3	4,2	-4,6	14,9	2,3	10,3	-1,6	مدني
-63,4	66,5	118,0	-50,9	33,9	-19,6	-38,6	-3,9	جناحي
32,8	-16,0	-1,4	9,7	-17,4	-1,6	-16,2	11,2	جنائي
-8,0	7,2	193,7	-3,4	5,0	-2,0	-64,2	38,5	اتهام
-82,3	12,2	3,6	-85,4	-17,5	-26,5	-20,4	-92,1	نيابة
-21,4	12,3	24,5	-21,8	-0,4	-11,3	-20,0	-1,2	المجموع

الفارق النسبي للنشاط القضائي لمحكمة التعقيب خلال السنتين القضائيتين: 2019 - 2020 و 2020 - 2021



معدل القضايا المفصولة لكل قاضي
خلال السنة القضائية 2020 - 2021

عدد القضايا المفصولة لكل قاضي	عدد القضاة	القضايا المفصولة	درجة المحكمة
228	197	45031	التعقيب

معدل القضايا المفصولة لكل قاضي
خلال السنة القضائية 2020 - 2021

